

LUIZ GUILHERME MARINONI
DANIEL MITIDIERO

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE I PROCESSO CIVIL

ARTIGOS 1.º AO 69

LUIZ GUILHERME MARINONI

DIRETOR

SÉRGIO CRUZ ARENHART

DANIEL MITIDIERO

COORDENADORES



THOMSON REUTERS

REVISTA DOS
TRIBUNAIS

2019 - 03 - 04

Comentários ao CPC - v. I - Marinoni - Ed. 2018

EXPEDIENTE

Expediente

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais

Juliana Mayumi Ono

Editorial: Andréia Regina Schneider Nunes, Cristiane Gonzalez Basile de Faria, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo, Marcella Pâmela da Costa Silva e Thiago César Gonçalves de Souza

Assistente Editorial: Francisca Lucélia Carvalho de Sena

Produção Editorial

Coordenação

Iviê A.M. Loureiro Gomes

Líder Técnica de Qualidade Editorial: Maria Angélica Leite

Analista de Projetos: Larissa Gonçalves de Moura

Analistas de Operações Editoriais: Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Felipe Augusto da Costa Souza, Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos, Maria Eduarda Silva Rocha, Mayara Macioni Pinto, Patrícia Melhado Navarra, Rafaella Araujo Akiyama e Thaís Rodrigues Sampaio

Analistas de Qualidade Editorial: Carina Xavier e Daniela Medeiros Gonçalves Melo

Estagiários: Angélica Andrade, Miriam da Costa Leite, Nicolas Eugênio Almeida Bueno e Sthefany Moreira Barros

Capa: Chrisley Figueiredo

Adaptação de capa: Linotec

Diagramação: Carla Lemos

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

Marcello Antonio Mastro Rosa Pedro

Analistas: Ana Paula Cavalcanti, Jonatan Souza, Luciano Guimarães e Rafael Ribeiro

Administrativo e Produção Gráfica

Coordenação

Mauricio Alves Monte

2019 - 03 - 04

Comentários ao CPC - v. I - Marinoni - Ed. 2018

SOBRE OS AUTORES

Sobre os Autores

Luiz Guilherme Marinoni

Professor Titular – com defesa de tese – de Direito Processual Civil nos cursos de graduação, mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná – UFPR. Pós-Doutorado na *Università degli Studi di Milano* e na *Columbia University*. *Visiting Scholar* na Columbia University. Professor Visitante em várias Universidades da América Latina e da Europa. Vice-Presidente da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional. Membro do Conselho Consultivo do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP e da *International Association of Procedural Law* – IAPL. Diretor do *Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal* – IIBDP. Tem mais de uma dezena de livros publicados no exterior. Recebeu o Prêmio Jabuti em 2009 e em 2017, tendo sido indicado ao mesmo prêmio nos anos de 2007 e 2010. Ex-Procurador da República. Ex-Presidente da OAB-Curitiba. Advogado e Parecerista, com intensa atuação nas Cortes Supremas.

Daniel Mitidiero

Pós-Doutorado pela *Università degli Studi di Pavia*. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Professor Associado de Direito Processual Civil nos cursos de Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Publicou 30 livros – quatro deles no exterior (Espanha, Itália e Peru) – e diversos artigos em revistas especializadas nacionais e estrangeiras, dentre as quais o *International Journal of Procedural Law*, *Revista Argentina de Derecho Procesal*, a *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, a *Revue Internationale de Droit Comparé* e a *Zeitschrift für Zivilprozess International*. Membro da *International Association of Procedural Law* – IAPL, do *Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal* – IIBDP, e do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP. Recebeu o Prêmio Jabuti em 2009 e em 2017. Advogado e Parecerista, com intensa atuação nas Cortes Supremas.

Apresentação

Desde a formação da ciência jurídica como a conhecemos, a prática do direito orientou-se pela doutrina formada em torno de textos dotados de autoridade – primeiro com a *Glosa* e logo em seguida com os *Comentários*. Esse hábito de argumentar invocando a *communis opinio doctorum* é particularmente tão arraigado na tradição luso-brasileira que a glosa de Accursio e opinião de Bartolus constituíam fonte subsidiária do direito nas Ordenações Afonsinas e Manuelinas, tendo inclusive mantido esse mesmo patamar nas Ordenações Filipinas – com a única diferença de que a glosa de Accursio e a opinião de Bartolus não poderiam ser contrárias à *communis opinio doctorum* para então figurarem como fonte do direito.

Nesse cenário, em que se refletem as mais fundas raízes da cultura jurídica brasileira, é natural que os *Comentários* tenham tido grande proeminência na conformação da prática do direito brasileiro. Especialmente no campo do processo civil, não só o Código de 1939 despertou a atenção para a redação de textos com intenção sistemática, mas também o Código de 1973 experimentou idêntico interesse.

Atenta à tradição – e ao mesmo tempo ciente de seu compromisso em renová-la à luz das necessidades atuais – a Editora Revista dos Tribunais/Thomson Reuters organizou não só duas coleções de *Comentários ao Código de 1973* (a primeira organizada por Sérgio Bermudes e a segunda por Ovídio Baptista da Silva), mas igualmente se preocupou em convidar-nos para coordenar estes *Comentários*, os primeiros a constituírem uma coleção completa entregue à cultura jurídica nacional a respeito do Código de 2015. A fim de que o seu conteúdo pudesse espelhar os diferentes fios que se entrelaçam para dar sustentação ao processo civil brasileiro, a coleção é composta de autores do mais alto nível de formação acadêmica, atuantes em diferentes segmentos da prática jurídica e pertencentes a todos os quadrantes do nosso país.

Estes *Comentários* estão voltados a todos aqueles que trabalham diariamente com o Código de Processo Civil. É por essa razão que é uma grande alegria apresentar esta coleção de *Comentários ao Código de Processo Civil de 2015*, ao mesmo tempo em que agradecemos a confiança depositada pela Editora em nosso trabalho, pelos nossos coautores em nossa capacidade de levar adiante o projeto e pelo público interessado em torná-los seus instrumentos de trabalho. Enredar-se na tradição a fim de torná-la sempre viva e comprometida com a prática do direito é motivo de enorme felicidade para nós – ainda mais quando o seu objeto é o processo civil, ramo das leis mais rente à vida, sem o qual a tutela dos direitos não passa de uma mal-acabada impressão.

Luiz Guilherme Marinoni

Sérgio Cruz Arenhart

Daniel Mitidiero

SUMÁRIO

Lei n. 13.105, de Março de 2015 - Código de Processo Civil

PARTE GERAL

LIVRO I - DAS NORMAS PROCESSUAIS CIVIS

TÍTULO ÚNICO - Das Normas Fundamentais e da Aplicação das Normas Processuais

CAPÍTULO I - Das Normas Fundamentais do Processo Civil [Art. 1º a 12]

CAPÍTULO II - Da Aplicação das Normas Processuais [Art. 13 a 15]

LIVRO II - Da Função Jurisdicional

TÍTULO I - Da Jurisdição e da Ação [Art. 16 a 20]

TÍTULO II - Dos Limites da Jurisdição Nacional e da Cooperação Internacional

CAPÍTULO I - Dos Limites da Jurisdição Nacional [Art. 21 a 25]

CAPÍTULO II - Da Cooperação Internacional [Art. 26 a 41]

TÍTULO III - Da Competência Interna

CAPÍTULO I - Da Competência [Art. 42 a 66]

CAPÍTULO II - Da Cooperação Nacional [Art. 67 a 69]

Comentários ao CPC - v. I - Marinoni - Ed. 2018

LEI 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

A Presidenta da República.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

1. Processo Civil e Cultura: dos Forais e das Ordenações ao Código de 2015. Os sistemas jurídicos são sistemas culturais¹. Vale dizer: constituem um todo interpretativo com ordem e unidade, formados a partir das diferentes manifestações da cultura positiva de certos povos em determinados momentos históricos².

O processo civil brasileiro é fruto das vicissitudes históricas do nosso país e das múltiplas influências culturais a que estiveram expostas as pessoas encarregadas de pensá-lo e construí-lo. A sua adequada interpretação, portanto, depende de uma apropriada compreensão a respeito das suas marchas e contramarchas – dos caminhos e dos desvios que marcaram o nosso processo civil.

1.1. Dos Forais e das Ordenações ao Código de 1939. O processo civil brasileiro, como o nosso direito em geral, não pode ser estudado “desde as sementes”, porque “nasceu do galho de planta, que o colonizador português – gente de rija têmpera, no ativo século XVI e naquele cansado século XVII em que se completa o descobrimento da América – trouxe e enxertou no novo continente”³. A primeira grande influência do direito brasileiro, portanto, só pode ser buscada diretamente no direito português – e, é claro, indiretamente nos próprios fatores que conformaram a cultura jurídica portuguesa. O antigo direito português pode ser dividido em dois grandes períodos: o da sua individualização⁴ – também conhecido como período de direito costumeiro ou foraleiro – e o da sua inspiração romano-canônica – o qual pode ser igualmente subdividido em dois: período da recepção do direito romano em Portugal e período das Ordenações⁵. Para a compreensão da maneira como o processo civil atuava é preciso ter presente igualmente um desenho da forma com que o direito em geral era concebido.

O período de direito consuetudinário e foraleiro vai do século XII ao século XIII, especificamente do ano em que Afonso Henriques passa a intitular-se rei (e, pois, da fundação da nacionalidade portuguesa, 1140) até o início do reinado de Afonso III (1248). O sistema jurídico vai principalmente dominado pelo costume – notadamente de origem germânica, sem que se possa, no entanto, descartar a confluência de outras fontes, como a muçulmana e a francesa – e pelos forais. Trata-se de conformação oriunda da necessidade de criação espontânea do direito, na medida em que o Rei se encontrava mais interessado na Reconquista do que na organização jurídica do reino⁶.

No que concerne aos costumes, sustenta-se normalmente a sua origem germânica – ainda que de certo modo já romanizados, uma vez que os visigodos, no quando da ocupação da península ibérica, já haviam sentido em dada medida a poderosa influência romana⁷. Não se pode recusar, contudo, a confluência de elementos muçulmanos (principalmente na construção do vocabulário técnico-jurídico), franceses (como a posse de ano e dia e sua proteção processual por meio de “ações de força”⁸, tidas pelos velhos juristas portugueses como ações com *mandatum de manutenendo*⁹) e, ainda, a influência de fatores próprios do momento da Reconquista, que assim não se filiam nem a essa, nem àquela experiência anterior (como a instituição do “concelho”, em que os homens se reuniam, longe da autoridade régia, para discussão de interesses comuns)¹⁰. Quanto ao direito foraleiro, destaca-se o Código Visigótico, também conhecido como “*lex gothorum*”, “*forum judicum*” ou “*liber iudicialis*”, tido pela doutrina como um “dos mais notáveis monumentos jurídicos da Idade Média”¹¹, nele se refletindo basicamente compromissos romanos,

eclesiásticos e germânicos antigos¹². Outras fontes, ainda, tiveram lugar no período, como, por exemplo, as Cartas de Privilégio, as Leis da Cúria de Leão e dos Concílios de Coiança e Oviedo e nas Concórdias – todas, porém, com importância menos marcada na caracterização do sistema jurídico da época¹³.

Quanto ao processo civil, esse se encontrava basicamente regido pelo “*forum judicum*” que, em seu segundo livro (“de los juicios y causas”), cuidava do chamado direito judiciário¹⁴. O dever de julgar ficava a cargo dos homens do povo, regularmente investidos na função de juiz. As causas, porém, raramente terminavam por sentença de mérito, com um juízo de valor sobre o pedido do demandante, mas por desistência de alguma das partes ou por transação de ambas, dado altamente demonstrativo de uma autêntica crise na cultura jurídica da época¹⁵.

O período de influência romano-canônica em Portugal, como já observado, pode ser agrupado em dois grandes grupos: o primeiro concerne à recepção do direito romano renascido no direito português, ao passo que o segundo assinala a sua consolidação nas Ordenações portuguesas. O período de influência romano-canônica vai dos séculos XIII a XVIII, sendo que o período de recepção se encontra entre os anos de 1248 a 1447 e o de consolidação entre os anos de 1446 a 1750.

No tocante à recepção, é preciso desde logo observar que é impróprio aludir simplesmente à “recepção do direito romano”. Isso porque, sem a devida explicitação de que a recepção é a do direito romano renascido, pode-se chegar à equivocada conclusão de que o direito romano era até então completamente ignorado pela experiência cultural da Alta Idade Média. Em realidade, sendo a Igreja a única instituição de maior expressão que sobreviveu à derrocada da Antiguidade, fazendo o elo entre o romano e o bárbaro – e sendo o direito romano a sua *lex approbata* (*lex saeculi*), pertinente aos seus negócios terrenos – é certo que a sua influência e a sua prática jamais desapareceram¹⁶. Quando se alude, pois, à “recepção do direito romano”, pretende-se apontar mais precisamente o fenômeno da “recepção do direito romano renascido”. Vale dizer: quer-se apontar o reencontro do direito romano mediante o estudo das fontes justinianas genuínas por meio de seu estudo independente e autônomo.

Até o seu renascimento, o direito romano era estudado pelos juristas medievais dissolvido nas *artes liberales*, constituídas pelo *trivium* da gramática, da lógica (dialética) e da retórica, sem que houvesse, salvo no oriente bizantino, escolas de formação especificamente jurídicas¹⁷. É somente com a Escola de Bolonha e o método da glosa e posteriormente dos comentários que o panorama se modificou sensivelmente¹⁸. Aliás, há quem sustente mesmo que o *Corpus Iuris Civilis* tenha sido recepcionado na Europa e apenas formalmente, uma vez que materialmente o direito romano recepcionado teria sido o direito romano já trabalhado pelos glosadores e comentaristas¹⁹.

A recepção do direito romano em Portugal teve um objetivo bastante específico: transformar o Rei em Imperador. Vale dizer: procurou ampliar o espectro de atuação política real²⁰. Uma das consequências mais importantes dessa ampliação está em que o Rei passa a legislar, apropriando-se do papel de criador do direito.

Em termos práticos, a recepção ocorreu por força da influência de obras doutrinárias e documentos legais castelhanos, escritos em idioma de mais fácil acesso que o latim, os quais contavam com soluções justinianas indicadas de maneira resumida²¹. Dentre as obras, são bem conhecidas as *Flores de Derecho* (também conhecida como *Flores de las Leyes*), o *Doctrinal de los Pleytos* e os *Nuevos Tiempos del Juicio*, todas de Jácome Ruiz (Mestre Jacob das Leis), todas com ênfase no direito judiciário civil. Dentre os documentos legais, exerceram grande influência o *Fuero Real*, composto entre 1252 e 1255, e *Las Siete Partidas* – obra que em Castela é introduzida com valor legislativo, passa a ter em seguida feição doutrinária e finalmente, em 1348, adquire valor de direito subsidiário, tendo sido vertida para o português ainda no século XIII e cuja influência na redação das Ordenações Afonsinas é notória. Ademais, a doutrina aponta a influência das classes cultas – isto é, letradas – na difusão do direito romano em Portugal²², além da presença de jurisconsultos estrangeiros na Península Ibérica, o maior acesso ao *Corpus Iuris Civilis* e à glosa respectiva e o ensino do direito romano de modo autônomo nas Universidades²³.

De resto, no período de recepção do direito romano, tinham vigência em Portugal outras fontes jurídicas: quanto aos assuntos temporais, ainda era grande a influência do costume e no âmbito local os forais continuavam a ser a principal fonte de direito. Algumas leis gerais, porém, começavam a aparecer aqui e ali como concreta expressão da apropriação do direito pelo soberano²⁴.

Nesse período, o processo civil vinha disciplinado na Terceira Partida das *Siete Partidas*, a qual “fabla de la Iufticia, e como fe ha de fazer ordenadamente en cada logar, por palabra de Iuyzio, e por obra de fecho, para defembargar los pleytos”, em trinta e dois títulos, cada qual devidamente subdividido em “leys”, representando essencialmente uma tábua de soluções processuais romanas²⁵. A influência romana era evidente, tanto que se observava o princípio da demanda, o direito ao contraditório (representada pela conformação do juízo como um ato de três pessoas, Títulos II, III, IV e X) e a imparcialidade jurisdicional (Título III), os quais representam sabidamente características fundamentais do processo civil romano²⁶.

Ultimado o ciclo da recepção do direito romano renascido, segue-se o período da sua consolidação. Isto é, chega-se à época das Ordenações, a qual representa antes de qualquer coisa um esforço de sistematização das fontes do direito, então vigentes em Portugal, a fim de que se tornasse melhor identificável o direito. Três foram as Ordenações: Afonsinas (1446), Manuelinas (1521) e Filipinas (1603).

Em termos estruturais, as Ordenações Afonsinas foram repartidas em cinco livros, os quais se organizavam internamente em títulos e em parágrafos, sempre precedidos de um proêmio. A forma quinária, aliás, traz à lembrança a organização das decretais de Gregório IX²⁷. Quanto à matéria tratada em cada um dos livros, lembra a doutrina que “o Livro I, que compreende 72 títulos, contém regimentos dos cargos públicos, quer régios, quer municipais. O Livro II, dividido em 123 títulos, contempla a matéria respeitante à Igreja e à situação dos clérigos, direitos do rei, em geral, e administração fiscal, jurisdição dos donatários, privilégios da nobreza, e legislação especial de judeus e mouros. O Livro III, abrangendo 128 títulos, ocupa-se do processo civil. O Livro IV, nos seus 112 títulos, trata do direito civil; enfim, o Livro V, com 121 títulos, versa direito e processo penal”²⁸. Substancialmente, consoante refere ainda a doutrina, “as Ordenações Afonsinas constituem uma compilação, actualizada e sistematizada, das várias fontes de direito que tinham aplicação em Portugal. Assim, e grande parte, são elas formadas por leis anteriores, respostas a capítulos apresentados em Cortes, concórdias e concordatas, costumes, normas das *Siete Partidas* e disposições dos direitos romano e canônico”²⁹. Do ponto de vista do conteúdo jurídico, portanto, as Ordenações Afonsinas não chegaram a representar uma inovação de soluções, porque síntese dos elementos multiformes que presidiam a experiência jurídica portuguesa no período de afirmação do direito romano.

Em termos de evolução histórica, todavia, os preceitos nela recolhidos possuem grande importância. No diagnóstico da doutrina, “as Ordenações Afonsinas assumem uma posição destacada na história do direito português. Constituem a síntese do trajecto que, desde a fundação da nacionalidade, ou, mais aceleradamente, a partir de Afonso III, afirmou e consolidou a autonomia do sistema jurídico nacional no conjunto peninsular. Além disso, representam o suporte da evolução subsequente do direito português. Como se apreciará, as Ordenações ulteriores, a bem dizer, pouco mais fizeram do que, em momentos sucessivos, actualizar a coletânea afonsina. Embora não apresente uma estrutura orgânica comparável à dos códigos modernos e se encontre longe de oferecer uma disciplina jurídica tendencialmente completa, trata-se de uma obra muito meritória quando vista na sua época. Nada desmerece em confronto com as compilações semelhantes de outros países”³⁰.

O mesmo se pode dizer da sua importância no plano político, tendo em conta que as Ordenações Afonsinas imediatamente “resultavam da necessidade da afirmação nacional”³¹. Nessa linha, também observa a doutrina que “a publicação das Ordenações Afonsinas liga-se ao fenómeno geral da luta pela centralização. Traduz esta colectânea jurídica uma espécie de equilíbrio das várias tendências ao tempo não perfeitamente definidas, ou seja, uma área intermédia em que ainda podiam encontrar-se. De um outro ângulo, acentua-se a independência

do direito próprio do Reino em face do direito comum, subalternizado no posto de fonte subsidiária por mera legitimação da vontade do monarca”³².

As Ordenações Afonsinas constituíam uma compilação e consolidação de soluções jurídicas sem qualquer pretensão de plenitude – que só apareceria mais tarde, como marca típica das codificações racionalistas³³, informada mentalidade continental dos Setecentos e dos Oitocentos³⁴. Daí a razão pela qual um dos problemas que logo se colocaram para os juristas foi o das fontes subsidiárias que permitissem a operacionalização do direito para o caso de lacunas e obscuridades das normas afonsinas. A fonte precípua era o direito próprio do Reino (*Ley do Regno, Estilo ou Costume suso dito*), sendo invocável subsidiariamente o direito comum (*Leyx Imperiaaes*, em assuntos temporais, e *Santos Canones*, em tema de pecado) e as glosas de Acúrsio e a opinião de Bartolo³⁵, clara expressão da autoridade dos doutores que permeou todo o pensamento jurídico medieval³⁶. Finalmente, tudo falhando, recorria-se à autoridade do Rei para a solução da questão.

O problema do direito subsidiário em Portugal e a sua solução coloca-nos na contingência de identificar um traço decisivo para a compreensão das mais fundas raízes do direito brasileiro: o “bartolismo”³⁷. Tendo em conta a lacunosidade das Ordenações e a deficiência da técnica jurídica dos textos ali recolhidos, os julgadores se encontraram na contingência de buscar respostas aos problemas práticos na autoridade dos doutores – que, afinal, encarnavam a própria autoridade do *Corpus Iuris Civilis*, aí entendido como repositório próprio de “todo o conjunto de saber possível”. Os juristas medievais viam no *Corpus*, nas glosas e nos comentários não apenas testemunhos históricos sobre dada realidade, mas a própria *ratio scripta*, a própria razão “convertida em palavra”³⁸. A argumentação tendo como apoio a doutrina era uma prática comum ao longo de todo o arco das Ordenações.

O problema da identificação e consolidação do direito português fora solucionado pelas Ordenações Afonsinas. Outros, porém, estavam na hora do dia das preocupações lusitanas, dentre os quais o de maior envergadura era o da divulgação do direito do Reino: esse desiderato tocava especificamente às Ordenações Manuelinas³⁹. Cumpriu às Ordenações Manuelinas, a tarefa de tornar público e de conhecimento de todos, o direito reinol, com o que contou com a colaboração da criação da imprensa, que aporta em Portugal provavelmente em 1487⁴⁰.

Em termos de estrutura, as Ordenações Manuelinas mantiveram o que já tínhamos com as Ordenações Afonsinas, registrando-se, no entanto, certa variação em seu conteúdo e o aparecimento de uma nova técnica legislativa. As disposições legais referentes aos judeus, por exemplo, desapareceram, tendo em conta a expulsão dos mesmos do Reino, em 1496, assim como a autonomização das normas fazendárias, que se excluíram das Ordenações principais para composição das Ordenações da Fazenda, em 1521. No que concerne à técnica legislativa, abandonou-se o estilo retrospectivo (mera transcrição de leis anteriores, com a indicação dos monarcas que as promulgaram), presente nas Ordenações de Afonso V, em função da adoção de um estilo decretório, como se de normas novas se tratasse. No que atine às soluções encampadas, não se registra qualquer transformação radical ou profunda em relação às Ordenações precedentes, mantendo-se, essencialmente, o direito anterior⁴¹.

Dada a permanência do caráter lacunoso, também em relação às Ordenações Manuelinas, sentiu-se a necessidade de regular o direito subsidiário. As normas sobre o tema foram alocadas no Livro II, Título V, mantendo-se a primazia das fontes nacionais, seguida do recurso ao direito comum (romano e canônico, com a peculiaridade de que agora o direito romano deveria guardar-se pela boa razão em que fundado), à glosa de Acúrsio e aos comentários de Bartolo (desde que não colidentes com a comum opinião dos doutores, caso em que essa tinha preferência, outro dado novo em relação às Ordenações Afonsinas). Tudo falhando, buscava-se a autoridade régia para a solução da questão⁴². Portanto, ainda aqui mantida a tradição bartolista, dado que os mesmos problemas que pontuavam as Ordenações Afonsinas continuaram a se insinuar pelas vestes das novas Ordenações.

O objetivo de compilar-se novamente o direito português, nasce do elevado número de legislações esparsas posteriores às Ordenações Manuelinas, o que de certa maneira poderia

infirmar a posição central das Ordenações, sobre dificultar a identificação do direito vigente. Foi essa a justificativa para a redação das Ordenações Filipinas⁴³.

Tendo em conta que o seu conteúdo constitui praticamente o mesmo das Ordenações Manuelinas, resta certo que a finalidade da sua promulgação estava em uma “pura revisão actualizadora das Ordenações Manuelinas”⁴⁴. Estruturalmente, manteve-se o esquema livros, títulos e parágrafos.

Quanto ao direito subsidiário, restou inalterado o esquema desenhado pelas Ordenações Manuelinas, tirante no que tocava à sua localização. Antes albergado no Livro II das Ordenações precedentes, o problema do direito subsidiário vinha agora colocado no Livro III das Ordenações Filipinas, alocado na estrutura referente à disciplina judiciária. Como observa a doutrina, “este último aspecto do enquadramento não parece fortuito. Na verdade, a referida transposição significa que o problema do direito subsidiário deixou de ser disciplinado a propósito das relações entre a Igreja e o Estado (liv. II), deslocando-se para o âmbito do processo (liv. III). Ora, pode detectar-se aí, como salienta Braga da Cruz, a ruptura da ‘última amarra’ que ligava a questão do direito subsidiário à idéia anterior de um conflito de jurisdições entre o poder temporal e o poder eclesiástico, simbolizados, respectivamente, pelo direito romano e pelo direito canônico. Tornou-se, em suma, de acordo com a atitude da época, um puro e simples problema técnico-jurídico”⁴⁵.

Buscando uma síntese da evolução histórica das fontes de direito no período das Ordenações, registra a doutrina que “desde a entrada em vigor das Ordenações Afonsinas até ao fim do período que estudamos isto é, durante cerca de três séculos, se mantém um mesmo sistema de hierarquização das fontes, com a única alteração de se haver introduzido a *communis opinio*, tutelando a *glosa de Acúrsio* e a *Bártoli opinio*. Pode, assim, dizer-se que, durante todo esse tempo, a matéria temporal vai ser, praticamente, regida pelos direito português e romano; constituirá o direito português a regra, uma vez, no imperativo das Ordenações, só se deverá recorrer ao direito comum, na falta de direito pátrio. Sabemos já, também, que o direito português, codificado nas várias Ordenações, não formava um todo orgânico, dado que fora legislado tendo como pressuposto a vigência do direito comum. De um modo geral, o rei legislara para esclarecer, ou contrariar regras de direito justinianeus: nomeadamente, no âmbito do direito privado, a lei nacional surgira como tomada de posição, frente ao direito comum. Deste modo, ao menos substancialmente, quase pode dizer-se que o direito romano constituía a regra, e o pátrio, a excepção”⁴⁶. Assim, o trabalho de colocar o manancial legislativo comum para alavancar as relações sociais e o desenvolvimento da sociedade cumpriu em um primeiro momento à doutrina (representado por Acúrsio e Bartolo e depois pela comum opinião dos doutores) e logo em seguida à jurisprudência, que acabou por funcionar como o grande elemento de evolução e estabilização do direito no período das Ordenações (pense-se, por exemplo, no papel dos assentos judiciais).

O processo civil desenhado nas Ordenações (tanto Afonsinas, como Manuelinas e Filipinas) é um típico exemplo de processo comum⁴⁷, forjado pela confluência dos elementos romano, canônico e germânico antigo. Suas soluções são soluções muitas vezes de força (como se percebe com bastante nitidez em alguns institutos, como, por exemplo, nas “cartas de segurança”⁴⁸), com adiantamento de execução à cognição (como nas nossas antigas ações cominatórias, também conhecidas como “ação de embargos à primeira”⁴⁹), atitude típica do direito germânico antigo. Nada obstante, procura-se prestigiar também a concepção de juízo como um ato de três pessoas⁵⁰, o que indica a observância do contraditório e da imparcialidade na decisão da causa, cuja influência romana é notória, além da influência canônica vincada no tom conciliatório que se procurou agregar à figura judicial⁵¹. O procedimento era secreto e escrito, informado pelos princípios da demanda e dispositivo, com proeminência do autor em relação ao juízo⁵², dividido em fases bem distintas (sistema de preclusão por fases, com larga adoção das técnicas da eventualidade e da concentração, nada obstante certa flexibilidade no que tange à postulação em juízo⁵³), rigidamente regrado com relação à formação da prova⁵⁴.

O processo civil das Ordenações Filipinas continuou vigente mesmo após a nossa independência. Isso porque, a Consolidação Ribas, aprovada por Resolução Imperial de 1876, apenas recolheu o direito luso-brasileiro vigente, tornando-o mais facilmente identificável⁵⁵. O

processo civil brasileiro só foi alcançado pela legislação nacional com a promulgação do Decreto 763/1890, que mandou aplicar ao foro cível o Regulamento 737/1850 – que, nada obstante tenha procurado simplificar algumas formas, manteve basicamente a estrutura do processo, particularizando-se apenas por aportar uma nova técnica legislativa à ordem jurídica nacional⁵⁶.

O Código de Processo Civil de 1939 – que unificou o processo civil brasileiro depois de um período em que tivemos legislações processuais civis estaduais⁵⁷ – constituiu um primeiro passo rumo à assimilação do legado da ciência processual europeia entre nós. O Código contava com 1.052 artigos e estava dividido em dez livros, os quais tratavam respectivamente: i) disposições gerais; ii) do processo em geral; iii) do processo ordinário; iv) dos processos especiais; v) dos processos acessórios; vi) dos processos de competência originária dos tribunais; vii) dos recursos; viii) da execução; ix) do juízo arbitral; e x) disposições finais e transitórias.

Embora fosse possível perceber a influência das lições de Giuseppe Chiovenda na primeira parte, bem como das ideias das principais codificações europeias, certo é que o Código de 1939 carregava ainda nítidos traços do processo comum das Ordenações⁵⁸. Além disso, a presença de inúmeras ações especiais previstas no Código sugere uma visão do legislador excessivamente comprometida com uma compreensão civilista ou sincretista do direito processual civil⁵⁹. A realização da autonomia do processo civil brasileiro – no que isso tem de positivo e de negativo – só foi obra do nosso segundo Código de Processo Civil, o Código Buzaid, de 1973.

1.2. Do Código Buzaid ao Código Reformado. Em 1964, entregou Alfredo Buzaid o Anteprojeto do nosso anterior Código de Processo Civil, atendendo a convite do Ministro da Justiça, Oscar Pedroso Horta, que lhe incumbiu da tarefa como Professor Catedrático de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Em 1972, o Projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional, por mensagem do Presidente da República. Discutido e aprovado, foi sancionado o Código de Processo Civil em 1973 por Emílio Médici, devidamente coadjuvado pelo seu então Ministro da Justiça, Alfredo Buzaid.

A influência da processualística alemã do final dos Oitocentos – a chamada “*Konstruktive Prozessrechtswissenschaft*”⁶⁰ – e mais fortemente da doutrina italiana da primeira metade dos Novecentos – da chamada “*scuola sistematica*”⁶¹ – na formação do Código Buzaid é evidente. Atesta-o Buzaid, ao recomendar as *Instituições* de Chiovenda como livro-chave para sua compreensão⁶² e ao consagrá-lo como “um monumento imperecível de glória a Liebman, representando fruto de seu sábio magistério no plano da política legislativa”⁶³; atesta-o Cândido Rangel Dinamarco, com a indicação do *Manual* de Liebman como o “guia mais seguro para a perfeita compreensão de nossa lei processual”⁶⁴.

A repercussão das ideias do conceitualismo processual civil europeu no Código Buzaid pode ser nitidamente aferida a partir da sua estrutura. Igualmente, as linhas fundamentais do sistema do Código Buzaid podem ser bem compreendidas diante das suas relações com a realidade social e com o direito material, do mesmo modo determinadas pelo clima do cientificismo próprio ao conceitualismo.

Significativamente, o Anteprojeto de Código de Processo Civil entregue por Alfredo Buzaid em 1964 para o Governo Federal contém apenas a redação dos três primeiros livros do Código, correspondentes ao *processo de conhecimento* (arts. 1.º a 612), ao *processo de execução* (arts. 613 a 845) e ao *processo cautelar* (arts. 846 a 913). Não contempla a redação do livro quarto, correspondente aos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de jurisdição voluntária.

É preciso perceber duas coisas a partir daí: a primeira concerne ao real intento de Buzaid com a proposta de seu Anteprojeto. Na sua ótica, muitíssimo provavelmente bastavam apenas o processo de conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar para organização de um Código de Processo Civil. Intimamente, Alfredo Buzaid possivelmente considerava terminada a sua missão com a redação dos três primeiros livros do Anteprojeto. Isso porque, na sua visão conceitualista, o que interessava para o direito processual civil eram apenas conceitos puramente processuais, impermeáveis ao direito material. A segunda diz respeito à própria terminologia

utilizada posteriormente por Buzaid para tratar do livro quarto. Porque estreitamente vinculados ao direito material, ali não existiriam propriamente *processos* especiais, mas simples *procedimentos*. Nesse clima cultural, as “ações especiais” certamente constituíam quinquilharias, da época em que ainda se confundia direito material e processo⁶⁵ – processo é conceito da ciência processual que não pode ser adjetivado com conceitos ligados ao direito material, sob pena de ameaçada a sua autonomia.

Em 1972 é encaminhado ao Congresso Nacional o Projeto do Código de Processo Civil. A influência das ideias da doutrina italiana da primeira metade dos Novecentos na sua construção é palmar. Importa analisá-las, reproduzindo-as no que agora interessa para que se possa seguir o rastro doutrinário do Código Buzaid.

O *processo de conhecimento* visa dar razão a uma das partes mediante sentença declaratória, constitutiva ou condenatória⁶⁶. O processo de conhecimento inicia com a propositura da ação (art. 263), que constitui direito ao processo e a um julgamento de mérito⁶⁷, e termina com a prolação da sentença (art. 162, § 1.º). Prolatada a sentença de mérito, o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional (art. 463, *functus officio*)⁶⁸.

O *processo de execução* tem por objetivo promover a transformação do mundo fático, sem o concurso da vontade do obrigado, de modo a *realizar a prestação* consubstanciada no título executivo que lhe serve de suporte⁶⁹. A execução é uma atividade necessariamente posterior à cognição ou, pelo menos, à atividade que deu lugar à formação do título executivo (*nulla executio sine titulo – primo intentanda est actio; non est incoandum ab executione*)⁷⁰. Entre cognição e execução há conexão sucessiva⁷¹. Não é tarefa do juiz dar ordens às partes⁷². A execução atua tão somente por meios sub-rogatórios⁷³ (arts. 625, 631, 633, 634, 636, 637, 643 e 647). O título executivo representa uma obrigação certa, líquida e exigível (art. 586). Submetem-se ao processo de execução tanto os títulos executivos judiciais como os títulos executivos extrajudiciais (arts. 583-585). A atividade jurisdicional executiva é uma atividade unificada, seja fundada em título judicial ou extrajudicial, disciplinada em conjunto. São espécies do mesmo gênero a ação executória e a ação executiva⁷⁴. Não é tarefa do juiz do processo de execução dar razão a uma das partes. Não há equilíbrio entre as partes na execução, porque o título executivo já indica que uma das partes tem razão⁷⁵. A tarefa do juiz é simplesmente a de traduzir em fato aquilo que se encontra normativamente encerrado no título executivo.

Como o processo de execução contém apenas atividade executiva, eventual defesa diante da situação substancial encerrada no título executivo não pode ser nele apresentada. Para voltar-se contra a execução e contra a obrigação encerrada no título, promovendo o conhecimento do juiz sobre determinados pontos, tem o executado de propor ação específica para este fim, a ação de embargos do executado (art. 736), que acarretará o início de um novo processo de conhecimento, incidental à execução⁷⁶.

O *critério* que fundamenta a separação entre processo de conhecimento e processo de execução é o critério da *atividade do juiz*. Com a legitimação histórica do direito romano clássico e com observações conceitualistas, pontua a doutrina que cognição e execução não são fases distintas de um mesmo processo, mas representam atividades que devem ser realizadas, de maneira naturalmente autônoma, em dois processos distintos⁷⁷. Naquele, o juiz apenas conhece com o fim de decidir a causa; nesse, apenas promove a adequação do mundo àquilo que se encontra estampado no título executivo⁷⁸.

O *processo cautelar* visa assegurar que uma das partes, ou o próprio processo, em última análise, não venha a sofrer um “dano jurídico”⁷⁹, ocasionado por um perigo de tardança ou por um perigo de infrutuosidade da tutela jurisdicional⁸⁰, enquanto pendente o processo de conhecimento ou de execução ou enquanto quaisquer umas destas atividades se encontrem prestes a iniciar. O provimento cautelar é, nessa linha doutrinária, dependente e acessório do provimento do processo de conhecimento ou de execução⁸¹ (arts. 796 e 806-808). Constitui proteção provisória emprestada aos processos de conhecimento e de execução⁸². É um instrumento do instrumento⁸³.

O *critério* que fundamenta a separação do processo cautelar, de um lado, do processo de conhecimento e do processo de execução, de outro, *não é o da atividade do juiz*. Sob este ponto de vista, o processo cautelar é uma “unidade”⁸⁴. O critério que fundamenta a separação do processo cautelar, numa ponta, do processo de conhecimento e de execução, em outra, é o critério da *estrutura dos provimentos* de cognição, execução e cautelar⁸⁵. Enquanto os provimentos de conhecimento e de execução são definitivos, os provimentos cautelares são provisórios. Essa a nota conceitual que singulariza o provimento cautelar, na ótica do Código Buzaid⁸⁶. Nessa linha, pouco importa a satisfatividade ou não do provimento para caracterização da função cautelar. Os provimentos cautelares poderiam ser no Código Buzaid tanto assecuratórios como satisfativos⁸⁷. O que interessava era a provisoriedade para delineamento das espécies que entravam no processo cautelar.

Com a coordenação do processo de conhecimento, de execução e cautelar o Código Buzaid propiciou às partes um procedimento padrão para tutela dos direitos *fundado tão somente em conceitos processuais*, isto é, totalmente independentes da natureza do direito material posto em juízo. Qualquer causa poderia ser tratada mediante a coordenação destas atividades e provimentos.

O Código Buzaid, dado o neutralismo científico que pressupunha, acabou disciplinando o processo civil tendo presente dados sociais da Europa do final dos Oitocentos. As relações sociais e as situações jurídico-materiais pressupostas eram as relações do homem do Código Civil de 1916, de Clóvis Beviláqua, não por acaso, ele mesmo considerado um Código Civil tipicamente oitocentista⁸⁸. Não pode causar espanto, pois, o fato de o Código Buzaid ser considerado, em suas linhas gerais, um Código *individualista, patrimonialista*, dominado pela ideologia da *liberdade tendencialmente irrestrita* e da *segurança jurídica como defesa da manutenção do status quo*, pensado a partir da ideia de *dano* e preordenado a prestar tão somente uma *tutela repressiva* aos direitos.

É fundamental perceber que o conceitualismo impôs à ciência processual uma atitude neutra com relação à cultura⁸⁹. Ao fazê-lo, acabou perenizando indevidamente determinado contexto cultural. Ao isolar o direito da realidade social, congelou a história no momento de sua formulação. O direito processual civil, ao seguir o programa metodológico da pandectística, encampado logo em seguida pelo método italiano, pressupôs a permanência inalterada ao longo de boa parte dos Novecentos da realidade social dos Oitocentos.

O Código Buzaid teve por base a cultura dos Oitocentos, seja porque alimentado pelo conceitualismo europeu, que a pressupunha, seja porque teve como referência as situações substanciais do Código Civil de 1916, de Clóvis Beviláqua, igualmente embevecido em enorme parte pelas ideias do *Code Civil* (1804)⁹⁰ e, indiretamente, pelas lições de Savigny, dada a influência do *Esboço* de Teixeira de Freitas na sua redação⁹¹.

Em seu Código, Beviláqua desenha a vida do homem de seu tempo: o homem nasce e torna-se capaz na vida civil (Livro I, Parte Geral). Um de seus primeiros atos é o matrimônio (aí se situa as coisas da *mater*, da esposa, da mãe, da sua vida privada, Livro II, Direito de Família). Logo em seguida, constitui patrimônio (formado pelas coisas do *pater*, do marido, do pai, Livro III, Direito das Coisas), busca ampliá-lo com o tráfego jurídico (Livro IV, Direito das Obrigações) e falece deixando patrimônio (Livro V, Direito das Sucessões). Nele não há preocupação com a questão da dignidade da pessoa humana e com seus direitos de personalidade. Não há preocupação com questões de índole social, como o trabalho, a saúde e o ensino, tampouco com assuntos que extrapolem o indivíduo, como o meio ambiente e a regulação dos mercados, ou que procurem agrupar as pessoas em determinados grupos sociais, como consumidores, crianças e adolescentes e idosos. A preocupação do Código Beviláqua está centrada no binômio *indivíduo-patrimônio*, cuja melhor tradução jurídica encontra-se no par *liberdade-propriedade*.

Não se trata, obviamente, de uma atitude isolada do legislador⁹². Além de atentar à estrutura social do Brasil de sua época⁹³, Beviláqua espelha ainda as preocupações das Codificações Oitocentistas europeias que lhe antecederam e condicionaram-no. Significativamente, ao prefaciá-

edição brasileira do Código Civil de Napoleão, observa a doutrina que o binômio liberdade-propriedade constituía a “viga mestra de todo o ordenamento jurídico da época”⁹⁴, sendo um Código pensado para indivíduos que dispõem e administram um patrimônio⁹⁵.

A liberdade envolve o espírito da época e a sua melhor expressão corporifica-se no livre e tendencialmente irrestrito exercício da vontade⁹⁶. Converte-se em dogma a autonomia individual⁹⁷, “fetiche” da época⁹⁸, passando a sua incolumidade a comparecer ao cenário jurídico como algo juridicamente relevante. O tráfego comercial alimenta-se dessa liberdade, instrumentalizado por vezes para melhor circulação de riquezas inclusive por títulos de créditos. Um dos efeitos da sacralização da vontade é a impossibilidade de sua coação, dominando o cenário obrigacional a regra da equivalência das prestações⁹⁹. A propriedade que move a cultura de então é a propriedade imobiliária, bem inerente à produção de riquezas pelos fazendeiros que alavancavam na ocasião a economia nacional.

Dentro destas coordenadas resta fácil compreender as características centrais do Código Buzaid. De lado as verdadeiras tutelas jurisdicionais diferenciadas conferidas aos *fazendeiros* (ações possessórias, arts. 920 a 933) e aos *comerciantes* (ações executivas fundadas em títulos de crédito, art. 585, inciso I), que comportam, no primeiro caso, possibilidade de tutela preventiva e antecipação de tutela, e, no segundo, execução prévia à cognição, fruto evidente do poder da ideologia dominante na conformação do processo¹⁰⁰, o processo padrão para tutela dos direitos no Código Buzaid é individualista, patrimonialista, dominado pela ideologia da liberdade e da segurança, pensado a partir da ideia de dano e apto tão somente a prestar uma tutela jurisdicional repressiva. É com o Código Buzaid que sentimos, em toda a sua extensão, a força da invasão da cultura jurídica europeia sobre o processo civil brasileiro¹⁰¹.

O *individualismo* do Código Buzaid é patente¹⁰². Não tendo compromisso com questões de cunho social e metaindividuais, a que o Código Beviláqua e o espírito dos Oitocentos não acudiam, Alfredo Buzaid desenhou um sistema para tutela dos direitos partindo do pressuposto da afirmação de um litígio entre duas pessoas em juízo, supondo-o ainda do tipo obrigacional¹⁰³, permitindo no máximo a intervenção de terceiros, individualmente considerados, que se julguem com interesse jurídico, que se afirmem titulares de direito sobre a *res in iudicium deducta* ou que apresentem determinadas ligações com o direito posto em causa. Assim o é porque a regra de legitimação para causa no Código Buzaid está em que tão somente o titular do direito material afirmado em juízo tem legitimidade para propor ação para sua proteção judicial, sendo excepcional, dependendo de expressa autorização legal, a possibilidade de propositura de ação em nome próprio para tutela de direito alheio (art. 6.º). A coisa julgada, nessa mesma linha, alcança apenas aqueles que foram parte no processo (art. 472).

Da mesma maneira, a influência do *patrimonialismo* na formação do Código Buzaid salta aos olhos. Essa patrimonialidade do legislador pode ser aferida em pelo menos duas frentes. Primeiro, pode-se surpreendê-la a partir da relevância emprestada à *propriedade imobiliária*. O art. 10, *caput*, prevê *legitimatio ad processum* conjunta de ambos os cônjuges para propositura de ações que versem sobre direitos reais imobiliários. Logo em seguida, o § 1.º impõe litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges quando o processo versar sobre direitos reais imobiliários (inciso I) e quando tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóveis de um ou de ambos os cônjuges (inciso IV). Ambas as regras de legitimação processual (art. 10, *caput*) e material (art. 10, § 1.º) visam a proteger o patrimônio imobiliário familiar, distinguindo-o com a ciência ou atuação de ambos os cônjuges em juízo em demandas envolvendo litígios dessa ordem¹⁰⁴. Segundo, pelo *caráter patrimonial de toda a execução* do Código Buzaid. Para confirmá-lo, basta perceber que, a fim de disciplinar a execução em geral (Livro II, Título I), Alfredo Buzaid discorre sobre a responsabilidade patrimonial do executado (Livro II, Título I, Capítulo IV), pontuando que o executado responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 591). A suposição aí é igualmente evidente: *na ótica do legislador, toda e qualquer execução, no fundo, tem por objeto bens, que respondem pelo cumprimento da prestação exigida em juízo*.

A patrimonialidade do Código Buzaid deixa antever ainda a orientação do legislador no sentido

da *mercantilização dos direitos*, reduzindo todas as situações substanciais a situações patrimoniais exprimíveis em pecúnia¹⁰⁵. Vale dizer: em esperar, como resultado padrão do processo, uma tutela jurisdicional pelo equivalente monetário. Trata-se de fato perfeitamente compreensível se tivermos presente o dogma da equivalência das prestações materiais sobre o qual erigido o *Code Civil* e daí o espírito dos Códigos Oitocentistas, dentre os quais se insere inequivocamente o Código Beviláqua.

O que determina a patrimonialidade executiva, no fundo, é a sacralização da autonomia individual e de sua *incoercibilidade* (*Nemo ad factum praecise cogi potest*). Por debaixo da patrimonialidade pulsa, na verdade, a proteção tendencialmente irrestrita ao valor *liberdade individual*.

A concretização desse princípio no processo civil tem duas direções. A primeira está em limitar a execução apenas ao patrimônio do executado, com medidas sub-rogatórias que, por definição, não lhe forcem a vontade¹⁰⁶. Não é possível, em outras palavras, coagir a vontade do executado, exigindo-se a sua colaboração para obtenção da tutela jurisdicional. A jurisdição é uma atividade substitutiva¹⁰⁷, que independe da atividade do executado. A execução é promovida pelo Estado – o executado apenas sobre a execução, submetendo-se¹⁰⁸. A execução é forçada, porque ao juiz não é dado dar ordem às partes: o executado não pode ser coagido a agir, daí porque apenas sofre a execução. A segunda, que as técnicas processuais executivas, voltadas à agressão do patrimônio do executado, estão todas previstas em lei. São técnicas processuais típicas. A razão desse posicionamento é singela: “as formas do processo sempre foram vistas como ‘garantias das liberdades’”¹⁰⁹. Com a previsão legal de técnicas processuais executivas, exclui-se qualquer outra maneira de agressão à esfera jurídica da parte, realizando-se o ideal de não intervenção do Estado nos domínios do indivíduo, salvo quando expressamente autorizado em lei. Trata-se de simples especificação do princípio da liberdade no processo civil, caríssima ao constitucionalismo liberal triunfante na Revolução Francesa¹¹⁰ e que inspirou o *Code Civil*, chegando por essa mão ao direito brasileiro.

À liberdade ajunta-se a *segurança* na conformação do processo civil de 1973. Juntas, caracterizam os princípios centrais do Código Buzaid. O “*mondo della sicurezza*” domina-o¹¹¹. A segurança é obviamente condição de existência do Estado Constitucional e nessa linha constitui um dos elementos axiológicos centrais de qualquer processo preocupado com a promoção do império do Direito¹¹². A segurança que alimenta o Código Buzaid, porém, constitui antes de tudo a garantia de manutenção do *status quo*.

É fácil percebê-lo. O procedimento comum do processo de conhecimento é um procedimento de cognição plena e exauriente, que só permite a decisão da causa depois de amplo exame das questões postas em juízo e de o juiz formar um convencimento de certeza a respeito das alegações das partes. Nele não é admitida qualquer espécie de decisão provisória sobre o mérito da causa, de modo a tutelar antecipada e interinamente o direito da parte que provavelmente tem razão. Vale dizer: nele não se admite antecipação da tutela. Mesmo depois de todo o exame da causa em cognição plena e exauriente pelo juiz de primeiro grau, a decisão não é imediatamente eficaz em regra (art. 520), só produzindo efeitos depois de reexaminada *in totum* pelo Tribunal a que se dirige o recurso de apelação (art. 497)¹¹³.

Semelhante orientação do Código Buzaid revela verdadeira desconfiança com a atuação do Estado. O Poder Judiciário só pode decidir, proclamando a “vontade concreta da lei” ou a “vontade concreta do direito”¹¹⁴, alterando a vida das partes depois de amplo exame e reexame do feito. Não por acaso, ao fazê-lo, presta tributo a uma das ideias centrais das Codificações Oitocentistas – a certeza jurídica¹¹⁵, aí compreendida como segurança do significado prévio da norma, que se imaginava de possível alcance tão somente a partir de expedientes processuais lineares e que possibilitassem amplo debate das questões envolvidas no processo.

Enfeixando as características gerais do Código Buzaid, pode-se afirmá-lo como um sistema processual civil totalmente dominado pela ideia de *dano* e ordenado à prestação de uma *tutela tão somente repressiva*. O conceito de ato ilícito pressuposto no Código Beviláqua obviamente

concorreu em enorme medida para esse caráter puramente sancionatório da atividade jurisdicional na legislação de 1973. Para o legislador civil de 1916, ato ilícito constituía o ato contrário a direito, praticado com dolo ou culpa, por ação ou omissão, de que decorria dano a alguém (art. 159)¹¹⁶. Fica patente a confusão entre ato ilícito, fato danoso e responsabilidade civil. A confusão entre esses conceitos, dentre outras contingências, impediu o legislador de identificar e disciplinar uma *tutela preventiva* voltada à inibição, reiteração ou continuação de um ato ilícito ou de seus efeitos¹¹⁷. Impediu da mesma forma de identificar e viabilizar uma tutela repressiva voltada tão somente à remoção do ilícito ou de seus efeitos.

Observando-se de perto o Código Buzaid, constata-se com facilidade que nele não surpreende nenhum dispositivo idôneo à viabilização de uma tutela preventiva, especialmente mediante abstenções. Poder-se-ia supor que o art. 642 teria o condão de patrocinar a realização de abstenções em juízo, já que abre a Seção II (da obrigação de não fazer), Capítulo III (da execução das obrigações de fazer e de não fazer), Título II (das diversas espécies de execução) do Livro II (do processo de execução) do Código. Pela sua simples leitura, porém, percebe-se que o legislador ali disciplina não a imposição judicial de uma abstenção, o que permitiria a viabilização de uma tutela preventiva, como seria de se esperar pela rubrica em que se insere, mas a simples possibilidade de desfazimento de algo realizado de maneira indevida¹¹⁸. Vale dizer: no lugar de instrumentalizar a realização de uma tutela preventiva, nosso legislador previu simplesmente a prestação de uma tutela repressiva. O processo padrão, para tutela dos direitos, encampado pelo Código Buzaid não foi, em nenhum momento, pensado para prestar tutela jurisdicional atípica contra o ilícito, nem para possibilitar uma tutela preventiva atípica aos direitos¹¹⁹.

O modelo de tutela dos direitos desenhado pelo Código Buzaid – fundado no binômio *cognição–execução forçada* e no *processo cautelar* como válvula de escape para toda e *qualquer providência provisória urgente*, preocupado tão somente na viabilização de uma *tutela repressiva contra o dano* – sofreu o seu mais duro golpe com a Reforma de 1994, em que se inseriu no bojo do processo de conhecimento ao mesmo tempo o instituto da *antecipação da tutela* e o da *ação unitária* para tutela das imposições de fazer e não fazer. Essa Reforma minou a estrutura do Código Buzaid e abriu espaço para a teorização de um novo modelo para tutela dos direitos.

Com a introdução do instituto da antecipação da tutela e da ação unitária no processo de conhecimento os *dois alicerces estruturais* do Código Buzaid ruíram. Em primeiro lugar, tanto a antecipação da tutela como a ação unitária viabilizam a prolação de *provimentos executivos dentro do processo de conhecimento*. Com isso, o seu primeiro pilar foi abalado – a separação entre processo de conhecimento e processo de execução. No modelo original, o processo de conhecimento começava com o exercício da ação e terminava com a prolação de uma sentença sem que qualquer ato executivo pudesse ser praticado ao longo do procedimento. O processo era de puro conhecimento, de modo que toda e qualquer atividade executiva deveria ser praticada apenas no processo de execução. A antecipação de tutela pressupõe justamente a possibilidade de que atos executivos e atos mandamentais serem praticados ao longo do processo de conhecimento. A ação unitária para tutela das imposições de fazer e não fazer é uma unidade justamente porque pressupõe que se seguirá à prolação da sentença de mérito, sem qualquer intervalo, a atividade executiva ou mandamental capaz de concretizar o comando sentencial, não sendo necessária a instauração de outro processo para tanto. Em segundo lugar, a antecipação da tutela permite a prolação de *provimentos provisórios dentro do processo de conhecimento*. Com isso, o seu segundo pilar foi ao chão – a separação entre o processo de conhecimento e o processo de execução, de um lado, e o processo cautelar, de outro, fundada na qualidade dos provimentos de cada um desses processos: enquanto o processo de conhecimento e o processo de execução dão lugar a provimentos definitivos, o processo cautelar viabiliza apenas a prolação de provimentos provisórios. Como a antecipação da tutela tem por função exatamente viabilizar a prolação de provimentos provisórios fundados em cognição sumária ao longo do processo de conhecimento, a separação fundada na estrutura dos provimentos rigorosamente desaparece, na medida em que também o processo de conhecimento passa a contar com a possibilidade de dar lugar a provimentos provisórios. Vale dizer: o processo de conhecimento deixou de ser um processo de puro conhecimento e de provimentos sempre definitivos para se tornar um *processo sincrético* (que admite cognição e execução) e capaz de gerar também *provimentos provisórios*.¹²⁰

Mas não é só. Com a introdução do instituto da antecipação da tutela e da ação unitária para a tutela das imposições de fazer e não fazer viabilizou-se a construção de um modelo de *tutela preventiva dos direitos*. Isso porque, a ação para a tutela das imposições de fazer e não fazer permite a prestação de tutelas capazes de impor *abstenções*, inclusive de forma sumária e provisória mediante antecipação da tutela. A partir daí a doutrina passou a contar com técnicas processuais capazes de permitir uma adequada teorização sobre o tema da tutela dos direitos – o que viabilizou a teorização sobre a *tutela específica* dos direitos e, especialmente, sobre a *tutela inibitória*.¹²¹

As Reformas de 2002, 2005 e 2006 seguiram pelo caminho aberto pela Reforma de 1994 e transformaram em ações igualmente unitárias as ações para tutela do direito à coisa e para a tutela do dever de pagar quantia, além de aperfeiçoar o instituto da antecipação da tutela, da ação para a tutela das imposições de fazer e não fazer e a execução por títulos extrajudiciais¹²². Com isso, o processo de conhecimento passou a albergar toda a execução fundada em sentença sob a rubrica de *cumprimento de sentença*. Dadas as evidentes diferenças estruturais e funcionais entre esses dois momentos do Código de 1973, passou-se inclusive a falar em *Código Buzaid* e *Código Reformado* para demarcá-los terminologicamente.

1.3. Do Código de 2015: do Processo à Tutela dos Direitos. Dentro do Estado Constitucional, um Código de Processo Civil só pode ser compreendido como um esforço do legislador infraconstitucional para densificar o direito de ação como direito a um processo justo e, muito especialmente, como um direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva. O mesmo vale para o direito de defesa. Um Código de Processo Civil só pode ser visto, em outras palavras, como uma *concretização* dos direitos fundamentais processuais civis previstos na Constituição.

O papel que qualquer codificação atual pode aspirar dentro da ordem jurídica é o de *centralidade* – vale dizer, consistir em eixo a partir do qual se articulam os vários institutos de determinado ramo do Direito, dando-lhes um *sentido comum mínimo*. Um Código contemporâneo é antes de tudo um Código central. No Estado Constitucional, a *ordem* e a *unidade* do direito processual civil estão asseguradas pela Constituição e, muito especialmente, pelos direitos fundamentais processuais civis que compõem o nosso modelo de processo justo. É a partir daí que devemos construir interpretativamente o *sistema* do processo civil brasileiro.

Se é verdade, contudo, que o Estado Constitucional se singulariza pelo seu dever de promover adequada tutela aos direitos mediante a sua própria atuação, então um Código de Processo Civil deve *reproduzir* e *densificar* o modelo de processo civil proposto pela Constituição. Do contrário, incorre o Estado Constitucional na *proibição de proteção insuficiente* e, em alguns casos, mesmo na *proibição de ausência de proteção* ao direito fundamental ao processo justo. Em semelhante situação, o legislador infraconstitucional encontrar-se-ia em mora com os compromissos assumidos pelo Estado Constitucional. Isso quer dizer que no plano infraconstitucional um Código de Processo Civil tem de significar a garantia de um *sistema constitucionalmente orientado para todo o processo civil*, assumindo aí a condição de *centro normativo infraconstitucional* do processo civil.

Um Código de Processo Civil, portanto, não pode pretender hoje constituir uma disciplina *plena* da ordem jurídica processual civil. Isso não é possível por várias razões. Duas devem ser sobrelevadas: a uma, a necessidade de compreender o direito processual civil dentro do quadro da teoria dos direitos fundamentais; a duas, a concorrência de fontes normativas de mesma densidade que, a partir dos conceitos e institutos comuns propostos pelo Código, visam à disciplina de aspectos especiais do processo civil. A *plenitude* das codificações dos Oitocentos, construídas à base de um forte consenso das necessidades sociais de então, depois de combalida pelo fenômeno da decodificação próprio à década de setenta dos Novecentos, cede passo à *centralidade* da ideia de Código no Estado Constitucional, cuja seiva-bruta deve ser buscada na Constituição¹²³.

Daí que é imprescindível para compreensão do Código de 2015 a sua leitura a partir da cultura do Estado Constitucional, tornando-o um instrumento idôneo para servir à prática sem descurar das imposições que são próprias da ciência jurídica, como necessidade de ordem e unidade, sem as quais não há como se falar em sistema nem tampouco cogitar da *coerência* que lhe é essencial¹²⁴.

Isto quer dizer que o Código deve ser pensado a partir de sua *finalidade* e de *eixos temáticos fundados em sólidas bases teóricas*.

Isso quer dizer que é preciso imprimir ao Código de 2015 uma linha teórica para sua adequada compreensão. Não basta o simples intuito pragmático. É a partir da sua inspiração teórica que se pode surpreender a sua unidade. Fora daí, corre-se o grave risco de ler-se o Código sem ter presente seus compromissos constitucionais – sem nele surpreender o nosso *sistema constitucional densificado*. Rigorosamente, aliás, sequer se poderia falar em um Código sem que nele se exprima um sistema. Não se quer dizer com isso, que o Código de 2015 não deve servir à prática ou, muito menos, que não deve se preocupar com problemas concretos. É claro que não. Um Código de Processo Civil tem antes de qualquer coisa um *compromisso inafastável com o foro*. Deve servi-lo. Esse compromisso, contudo, deve ser entendido e adimplido dentro de um quadro teórico coerente. A recíproca implicação entre teoria e prática deve ser constante a fim de que a legislação processual civil possa constituir meio efetivamente idôneo para orientar a sociedade civil e o Poder Judiciário a respeito do *significado do direito* e para resolver os *problemas concretos* apresentados pelas partes.

Para que o direito processual civil possa realmente ter a sua âncora na Constituição e ser compreendido como verdadeiro instrumento de efetiva proteção dos direitos, é fundamental que todo o processo civil seja orientado pelo seu *dever de dar tutela aos direitos* de maneira geral (*formando precedentes*) e de maneira particular (*decidindo de forma justa* as controvérsias e dando *adequada efetivação* às suas decisões). Muito especialmente – que todo o processo seja pensado a partir da *teoria da tutela dos direitos*. Essa é a *finalidade* do processo civil no Estado Constitucional e constitui o *eixo central* a partir do qual deve ser estudado, interpretado e aplicado.

Se, em uma perspectiva geral, o *significado do Direito* depende de uma outorga de sentido a textos e a elementos não textuais da ordem jurídica, então a *interpretação judicial do Direito*, seja no nível ordinário (dos juízes de primeiro grau, dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais com a *formação da jurisprudência* – fonte permanente de colaboração para a formação de precedentes pelos órgãos responsáveis), seja no nível extraordinário (das Cortes Supremas, isto é, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça com a *formação de precedentes*) conta como elemento de decisiva importância para concretização da segurança jurídica, da liberdade e da igualdade de todos perante o Direito. Daí a razão pela qual os precedentes das Cortes Supremas constituem evidente enriquecimento do direito vigente e servem para lhe outorgar unidade – seja retrospectiva, resolvendo problemas interpretativos, seja prospectiva, desenvolvendo-o para atender às novas necessidades sociais. Vale dizer: valem como direito positivo.

Se, em uma perspectiva particular, ter um direito significa antes de tudo ter uma posição juridicamente tutelável, então é evidente que é imprescindível primeiro identificarem-se quais são as *tutelas possíveis aos direitos*. Só depois disso é que é possível cogitar da segunda etapa – aferir quais as *técnicas processuais* que devem ser prestadas mediante processo justo para realização do direito material. Isso autoriza a conclusão de que é inafastável da compreensão do processo civil no Estado Constitucional o binômio técnica processual e tutela dos direitos. Por essas razões, a tutela dos direitos constitui ao mesmo tempo a finalidade do processo civil no Estado Constitucional e o eixo a partir do qual a interpretação do Código deve ser pautada.

O Código de 2015 conta com uma *parte geral* e com uma *parte especial*, sendo que a parte especial está dividida em *processo de conhecimento e cumprimento de sentença*, *processo de execução* e *processos nos tribunais e meios de impugnação das decisões judiciais*. Parece-nos que essa divisão centrada no *processo de conhecimento* e no *processo de execução* não é a mais apropriada.

Partindo-se do pressuposto que o Estado Constitucional se caracteriza pelo seu dever de outorgar tutela aos direitos, então um Código de Processo Civil sintonizado com os seus fins deve ser pensado a fim de promovê-la e deve ser pensado nessa perspectiva. Nessa linha, é pouco organizar o processo civil simplesmente a partir das atividades processuais (conhecimento e execução) que podem ter lugar em determinados processos. É claro que isso era sem dúvida

suficiente quando a doutrina processual pensava o processo de forma alheia ao direito material e à realidade social. A partir do exato momento em que se passou a pensar o processo para além de si mesmo, essa maneira de pensar o processo civil revelou-se insuficiente.

Mas não só a congruência com os fins do Estado Constitucional e a necessidade de construção do processo civil a partir da tutela dos direitos e do contexto social em que inserido impõem essa solução. Também a própria ideia de processo de conhecimento e de processo de execução como processos puros, que se encontra na raiz conceitual desses institutos, não se verifica no Código de 2015.

Tanto o processo de conhecimento como o processo de execução, como esboçados no Código, são processos sincréticos: o processo de conhecimento admite fase de cumprimento de sentença, em que se desenvolve atividade executiva; o processo de execução admite cognição ao, por exemplo, permitir a declaração de ineficácia da arrematação nos seus próprios autos. Rigorosamente, o processo de conhecimento não é de conhecimento tão somente, nem o processo de execução de pura execução.

É também importante perceber que nada justifica a disciplina em apartado do processo nos tribunais e dos recursos em livro próprio. O apropriado é que o assunto seja tratado na parte geral ou no processo de conhecimento. Certo, no direito alemão, a *Zivilprozessordnung* reservou um livro próprio para o direito recursal (*Buch 3, Rechtsmittel*, §§ 511 a 577). Isso pode ser explicado, contudo, pelo fato de anteriormente o *Buch 2* disciplinar o *Verfahren im ersten Rechtszug* – isto é, o procedimento na primeira instância. Aí faz sentido prever, na sequência, um livro dedicado aos recursos. Fora desse contexto sua previsão em livro próprio não encontra sustentação. Ao que se saiba, nenhum dos Códigos de Processo Civil atuais tem semelhante divisão – o *Codice di Procedura Civile* italiano (em que o assunto vai disciplinado *Libro Secondo, Del Processo di Cognizione, Titolo Terzo, Delle Impugnazioni*, arts. 323 a 408), por exemplo, não encampa semelhante orientação.

O ideal é que o Código de Processo Civil seja pensado a partir da ideia de *tutela dos direitos*. É o compromisso do Estado Constitucional com a tutela dos direitos e, em termos processuais civis, com a efetiva tutela jurisdicional dos direitos em sua dupla dimensão que singulariza o Estado Constitucional. Esse se caracteriza justamente por ter um *verdadeiro dever geral de proteção dos direitos*. Fica claro, portanto, a razão pela qual a interpretação que o Código de 2015 merece caracteriza-se por um sintomático deslocamento – do *processo à tutela*.

Daí porque parece apropriada a *reconstrução interpretativa do sistema* do Código de 2015 a partir da teoria da tutela dos direitos. Assim, em termos dogmáticos, importa dividi-lo em *três grandes linhas*: a *primeira*, voltada à *teoria do processo civil*, responsável pela construção dos conceitos de base do direito processual civil; a *segunda*, preocupada com a *tutela dos direitos mediante o procedimento comum*, âmbito teórico em que situados todos os temas ligados à tutela padrão dos direitos; e a *terceira*, vocacionada à *tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados*, área em que situados todos os temas concernentes às diferenciações legislativas procedidas para a tutela dos direitos. Como parte desse esforço de reconstrução sistemática, escrevemos nosso *Curso de Processo Civil*, o qual segue exatamente essa organização da matéria¹²⁵.

O Código de 2015 inequivocamente é suscetível de sistematização a partir do eixo da tutela dos direitos. Partindo-se do pressuposto que o processo civil tem por finalidade dar *tutela aos direitos em uma dupla dimensão*, é possível ver em seu art. 6.º o desiderato de dar tutela aos direitos no caso concreto, assinalando ao processo civil o objetivo de viabilizar uma *decisão de mérito justa e efetiva* mediante a colaboração judicial, ao mesmo tempo em que é possível perceber em seu art. 926 o objetivo de promover a *unidade da ordem jurídica* mediante a atuação das Cortes Supremas por força de precedentes judiciais.

Ademais, o Código de 2015 utiliza em pontos centrais expressões que permitem a construção de um sistema para a tutela dos direitos capaz não só de prestar tutela repressiva voltada contra o dano e vocacionada para a proteção de direitos patrimoniais. Em atenção aos *novos direitos*, o Código fala em *tutela do direito* contra o ilícito e contra o dano, fazendo alusão inclusive à possibilidade de inibição do ilícito e de sua remoção (art. 497, parágrafo único). Para promovê-las,

arrola inúmeras *técnicas processuais* que podem ser empregadas pelo juízo, como as técnicas antecipatórias (arts. 294 e ss.) e as técnicas executivas (art. 139, IV). A compreensão da técnica processual a partir da tutela dos direitos faz com que seja possível alcançar às partes *tutela específica* aos direitos, inclusive *tutela preventiva* contra o ilícito, isto é, tutela inibitória, quebrando-se com isso o círculo vicioso da violação dos direitos e do seu simples ressarcimento em pecúnia como resposta padrão do processo civil.

O uso de expressões abertas pelo Código de 2015 é da mais alta importância para prestação de *tutela aos direitos não patrimoniais*. Nossa Constituição arrola inúmeros direitos não patrimoniais como dignos de tutela – os direitos de personalidade, o direito ao meio ambiente equilibrado, o direito à higidez do mercado, o direito à saúde, o direito ao ensino, o direito à segurança no trabalho, dentre vários outros. É evidente que uma adequada tutela desses direitos não se compraz com o binômio condenação-execução forçada, cujo resultado acaba sempre em uma tutela pelo equivalente monetário. Daí a razão pela qual a adoção pelo Código de 2015 de expressões como tutela dos direitos, perigo na demora e medidas necessárias – justamente porque abertas e moldáveis concretamente às mais diferentes situações de direito material carentes de tutela – constitui prova de sua atenção à realidade social e ao direito material que lhe cabe efetivamente tutelar.

2. Conceitos Fundamentais para a Adequada Interpretação do Código de 2015. **Técnica Processual e Tutela dos Direitos.** No Código Buzaid, o manancial conceitual ao qual deveria recorrer o seu intérprete para sua aplicação constituía-se basicamente de formas processuais: os processos de conhecimento, de execução e cautelar; as ações e as sentenças declaratórias, constitutivas, condenatórias e executivas. Dada a sua orientação à tutela adequada, efetiva e tempestiva do direito material, o Código de 2015 requer não apenas que se pense igualmente na tutela dos direitos, mas também uma reformulação dos conceitos processuais básicos para a sua apropriada interpretação. Em outras palavras, é preciso pensar o processo civil na perspectiva da tutela dos direitos, isto é, pensar a técnica processual a serviço do direito material.

A *tutela dos direitos* no campo jurisdicional¹²⁶ é prestada mediante o emprego de diversas *técnicas processuais*. Esses meios são pensados pelo legislador de modo a, sem perder de vista as necessidades de proteção do direito material, respeitar e preservar também os *direitos fundamentais processuais* das partes e de terceiros – vale dizer, o *direito ao processo justo* que a Constituição a todos assegura em nossa ordem jurídica (art. 5.º, LIV, CRFB)¹²⁷.

Isso quer dizer que o procedimento deve ser concebido tendo em vista os vários interesses que convergem na solução da controvérsia e na prestação de uma *tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva* (art. 5.º, XXXV, CRFB), sejam eles interesses estritamente processuais – respeitantes aos direitos fundamentais processuais que integram o direito ao processo justo e aos direitos processuais previstos pelo legislador infraconstitucional – sejam eles interesses ligados ao direito material – construídos a partir do desenho dado pelo Direito a cada instituto de direito material. Surgem aí os grandes conflitos com que o direito processual civil deve lidar, a exemplo da colisão entre o interesse à rapidez na solução do litígio e a preservação do direito de defesa do réu; do contraste entre o direito à tutela jurisdicional adequada e a preservação da liberdade do demandado e por aí fora.

O procedimento em que encarnado o direito ao processo justo, assim, é uma resultante da harmonização desses vários interesses que confluem no processo. E, porque esses valores têm todos assento constitucional direto ou indireto, a colisão entre esses interesses implica de um modo geral considerações relacionadas à colisão de direitos fundamentais e a necessidade da respectiva concordância prática, harmonização ou eventual ponderação¹²⁸.

Segue daí que toda limitação a um direito fundamental processual deve ter por base o atendimento a outro direito também fundamental – e, mais do que isso, *só se legitima alguma limitação a um direito fundamental processual se – e apenas no exato limite em que – essa atenda justificadamente a outro direito também fundamental*. Assim, por exemplo, só se admitem técnicas processuais que sacrifiquem a efetividade na prestação da tutela jurisdicional quando isso tiver por intuito a preservação de direitos fundamentais da parte contrária, como a observância do

direito de defesa ou do direito ao contraditório.

Nessa linha, o desenho do perfil traçado pelo direito processual civil para os instrumentos que se destinam à tutela dos direitos tem como ponto de partida *as necessidades concretas da pretensão material a ser protegida*. Vale dizer: da *tutela do direito* que emana do *direito* que deve ser protegido em juízo. A partir dessas necessidades, somam-se interesses das partes e de terceiros que comparecem ao processo – de cunho material ou processual – e, então, chega-se ao seu produto, que será o procedimento empregado para a tutela daquela situação substancial.

Isso quer dizer que existe uma prioridade na consideração do direito material em relação ao direito processual. *Se o processo civil é um instrumento para tutela do direito, então a primeira tarefa de quem quer que esteja preocupado com o adequado funcionamento da Justiça Civil está na apropriada identificação das necessidades da situação substancial que deve ser tutelada em juízo*. Nessa perspectiva, a idoneidade do processo civil como meio efetivo para tutela dos direitos depende de um discurso preocupado com a tutela dos direitos – isto é, com o direito material.

Logicamente, a convergência das pretensões a serem tuteladas e desses outros interesses processuais e materiais pode exigir diferentes soluções do legislador e do juiz. Em certos casos, também será possível que mais de uma técnica processual seja idônea para atender a todos esses interesses, o que implica dizer que nem sempre haverá apenas uma única resposta possível para atender às necessidades com que trabalha o direito processual. Vale dizer: a consideração da *tutela dos direitos* pode levar a diferentes opções em termos de *técnica processual* para adequada estruturação do processo civil.

Desse modo, têm-se casos em que não se dá ao legislador – ou à jurisdição – discricionariedade para escolher o desenho adequado para a tutela do direito. Haverá situações, por exemplo, que demandarão maior complexidade no trato da prova, a exemplo da ação que visa à prestação da tutela inibitória. Outras exigirão preocupação com o momento de efetiva implementação do direito que foi reconhecido como existente e das técnicas processuais idôneas para tanto (por exemplo, admissão do uso de multa coercitiva e de busca e apreensão de bens). Outras situações ainda exigirão lidar com a necessidade de adequada gestão do tempo necessário para que a proteção possa ser oferecida (recorrendo-se à técnica antecipatória para adequada distribuição do ônus do tempo no processo). Enfim, pode haver uma infinidade de situações pontuais que exigirão técnicas processuais específicas para seu adequado tratamento.

Ao lado disso, porém, haverá casos em que o legislador pode, por razões diversas, escolher dar proteção mais facilitada ou menos facilitada a certas situações, tal como ocorre com a técnica executiva, com o procedimento monitorio ou com a cognição parcial das ações possessórias. Na primeira, o legislador opta por conferir presunção de “veracidade” a certos documentos, autorizando ao seu portador a dar início, desde logo, a atos de satisfação de um direito afirmado, ainda que ele não tenha sido previamente reconhecido judicialmente. Na segunda, ocorre algo semelhante, oferecendo-se ao portador de prova documental de uma obrigação a faculdade de, diante da não oposição da parte contrária, iniciar prontamente a efetivação de seu direito. E, nas ações possessórias, limita o legislador a cognição judicial, excluindo do âmbito de discussão a questão da propriedade, a fim de simplificar a situação daquele que detém a posse de algum bem, tout court. Como se vê, nesses casos, poderia o legislador escolher outras soluções para tais casos. Porém, razões de política judiciária levaram-no a escolher essas técnicas, priorizando certas situações jurídicas.

A importância do tempo para a proteção processual dos direitos, por exemplo, é mais do que evidente. Caso pudesse haver um processo “instantâneo”, a resposta jurisdicional que se daria aos direitos seria muito próxima daquilo que o titular do interesse faria em reação à eventual ameaça ou lesão. Todavia, isso é impossível, e a atividade jurisdicional demanda um processo que, de seu turno, exige certo espaço de tempo para desenvolver-se. A ideia de processo remete logicamente à uma situação dinâmica e progressiva¹²⁹, com o que por si só repele o conceito de instantaneidade¹³⁰. Logicamente, quanto maior a demora da resposta estatal a violações ou ameaças a direitos, mais distante ela tende a ser das necessidades do interesse objeto da proteção e maior o *dano marginal* que a parte que tem razão experimenta pelo simples fato de ter recorrido

ao processo para obtenção da tutela do direito¹³¹. Porém, há casos em que mesmo a demora normal do processo se mostra incompatível com as necessidades de certas situações.

Em todos esses casos, o processo civil tem de se adequar às necessidades de tutela evidenciadas pelas especificidades do direito material afirmado em juízo. É tarefa do legislador na concepção legal do procedimento e do juiz na condução do processo responder a essa *necessidade de adequação* da tutela jurisdicional. Ao desempenhá-la, a *técnica processual* deve ser evidentemente pensada na perspectiva da *tutela dos direitos* – do contrário, o processo civil corre o risco de se converter em um procedimento desorientado e indiferente aos seus fins, em que a sua finalidade é esfumada pela ausência de sua efetiva percepção.

2.1. Tutelas contra o Ilícito e Tutelas contra o Dano. **Tutela Satisfativa e Tutela Cautelar.** Ao afirmar que o fim da jurisdição é atuar a vontade da lei¹³² e não dar tutela ao direito material, a doutrina do final do século XIX e início do século XX pretendeu ficar definitivamente distante da teoria que confundiu o direito de ação com o direito material.¹³³ Desse modo, a necessidade de estabelecer a autonomia do direito processual e a finalidade pública do processo conduziu ao abandono da ideia de que a jurisdição deveria dar tutela aos direitos.¹³⁴ Com isso, se de um lado o processo civil forjava sua autonomia conceitual e científica, de outro dava um perigoso passo rumo ao esquecimento de sua umbilical ligação com o direito material. Daí que o discurso preocupado em evidenciar a ligação entre técnica processual e tutela dos direitos é antes de qualquer coisa um discurso engajado na retomada dos esquecidos laços entre direito e processo.

Considerar o processo civil um meio para a tutela dos direitos significa antes de qualquer coisa pensar *primeiro* nas situações de direito material que se pretende proteger por meio do exercício da ação para somente *depois* cogitar das técnicas processuais adequadas para sua efetiva proteção¹³⁵. Basicamente, o processo civil pode prestar *tutela satisfativa* ou *tutela cautelar* aos direitos. Há tutela satisfativa quando a tutela jurisdicional se destina a *realizar concretamente o direito da parte*. Essa tutela satisfativa serve para prestar *tutela contra o ilícito* – visando a inibir a sua prática, reiteração ou continuação (*tutela inibitória*) ou visando à remoção da sua causa ou de seus efeitos (*tutela de remoção do ilícito*) – ou *tutela contra o dano* – visando à sua reparação (*tutela reparatória*) ou ao ressarcimento pela sua ocorrência (*tutela ressarcitória*). Há tutela cautelar quando a tutela jurisdicional se destina simplesmente a *assegurar a satisfação eventual e futura do direito da parte*. Enquanto a tutela satisfativa pode proporcionar tanto uma tutela contra o ilícito (preventiva ou repressiva) como uma tutela contra o dano (repressiva), a tutela cautelar é sempre uma tutela contra o dano¹³⁶. Isso porque a tutela cautelar apenas assegura para o caso de, ocorrendo o fato danoso, ser possível eventual e futuramente a realização do direito – a tutela cautelar, nada obstante possa ser concedida anteriormente ao dano, tem a sua atuabilidade condicionada à sua ocorrência¹³⁷.

Ter direito no plano do direito material significa ter *direito à tutela do direito* e à sua *exigibilidade (pretensão)*. Daí que é da própria existência do direito que decorre o direito à tutela contra a ameaça ou a efetiva ocorrência de um ilícito ou à tutela contra o dano. É o plano do direito material, portanto, que concede direito à tutela inibitória, à tutela de remoção do ilícito, à tutela reparatória e à tutela ressarcitória. É no plano do direito material que existe *direito à satisfação* do direito e *direito à sua cautela*. O fato de o legislador processual civil mencionar ou não essas categorias é absolutamente irrelevante para a sua respectiva existência. Isso quer dizer que *subsiste o direito à tutela cautelar* sob a égide do Código de 2015 – o que desapareceu apenas foi o *processo cautelar conceitualmente autônomo* para a sua prestação¹³⁸ (nosso Código, aliás, faz várias alusões à tutela cautelar, inclusive às tutelas cautelares nominadas, art. 154, inciso I, 301, 495, § 1.º). O que o legislador processual civil tem o dever de mencionar e conformar, porém, são as *técnicas processuais* adequadas para efetiva e tempestiva proteção dos direitos. Esse é o campo próprio de atuação do Código de Processo Civil.

No que agora interessa, importa lembrar que o legislador processual civil organizou o Código de 2015 partindo de técnicas processuais atinentes à *atividade jurisdicional* desempenhada pelo órgão jurisdicional para prestação da tutela dos direitos (cognição e execução) e à *diversificação de procedimentos* para sua consecução (procedimento comum e procedimentos diferenciados,

procedimentos de cognição exauriente e procedimentos de cognição sumária). A combinação dessas técnicas processuais no caso concreto viabiliza a tutela jurisdicional dos direitos.

2.2. Cognição e Execução no Sistema da Tutela Jurisdicional dos Direitos. O tema da tutela dos direitos pertence ao campo do direito material. Não é o legislador processual civil que outorga direito à tutela satisfativa ou à tutela cautelar, direito à tutela inibitória ou à tutela ressarcitória – para ficarmos com alguns exemplos. Dada a interdependência entre direito e processo¹³⁹, porém, a sua efetiva atuabilidade depende da existência de técnicas processuais idôneas para sua proteção¹⁴⁰. Como é evidente, a tutela jurisdicional é apenas um dos aspectos que devem ser levados em consideração para a efetiva tutela dos direitos¹⁴¹. É da compreensão da técnica processual a partir da tutela do direito que a tutela jurisdicional se torna idônea para sua prestação.

Embora o Código de 2015 ainda aluda a processo de conhecimento e a processo de execução, é certo que conhecimento e execução são *atividades* que podem ser desempenhadas ao longo do processo¹⁴². Não são propriamente espécies ou formas processuais – prova disso é que o processo de conhecimento no Código de 2015 é um *processo sincrético*, em que se misturam atividades de cognição e de execução para tutela dos direitos. O processo de conhecimento rigorosamente não é um processo de simples conhecimento, em que o juiz se limita a dar razão a uma das partes diante de um litígio: isso porque o juiz pode no processo de conhecimento, em sendo o caso, antecipar a tutela (art. 294 e ss.), o que pressupõe uma decisão que contenha ao mesmo tempo cognição e execução (art. 297), e pode desenvolver atividade executiva posterior à sentença mediante cumprimento de sentença (arts. 513 e ss.). A sua denominação, portanto, é um resquício conceitualmente incômodo que o legislador equivocadamente quis conservar da doutrina que outorgou as bases do revogado Código Buzaid¹⁴³. A história do processo de conhecimento, como é sabido, é a história da sua transformação em um processo efetivamente comprometido com a tutela dos direitos e, portanto, muito distante de um processo meramente pré-ordenado à prolação de uma simples sentença que se limita a dar razão a uma das partes¹⁴⁴.

Cognição e execução são atividades judiciais que podem ser exercidas de *forma separada* ou de *conjunta* ao longo do processo. Saber se a cognição deve sempre preceder à execução (*Nulla executio sine titulo*) ou se deve anteceder-lá (*Solve et repete*) por força de uma previsão do legislador ou de uma decisão judicial é uma questão de *política legislativa*¹⁴⁵ – que naturalmente deve ser orientada pelos direitos fundamentais processuais que dão vida ao direito ao processo justo (art. 5.º, LIV, CRFB) e muito especialmente pelo direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva (art. 5.º, XXXV e LXXVIII, CRFB). O mesmo vale para saber se as atividades de cognição e de execução devem ser desempenhadas em um processo autônomo ou não¹⁴⁶.

A demanda do autor introduz no processo *alegações fático-jurídicas* que indicam uma narrativa a partir da qual se deduz um ou mais *pedidos* de tutela jurisdicional (art. 319 e ss.). A defesa do réu introduz igualmente *alegações* no processo, limitando-se em regra a simplesmente pedir a *improcedência dos pedidos* formulados pelo autor (arts. 336, 337 e 341). Depois de oportunizada a *prova dessas alegações* pelas partes ou mesmo determinadas *provas de ofício* (art. 370), o juiz tem o *dever de julgar a controvérsia* (art. 489, inciso III), preferencialmente *enfrentando o mérito da causa* (arts. 6.º, 317, 485, § 7.º, 488 e 932, parágrafo único). Para tanto, o juiz tem o *dever de conhecer* das alegações e das provas produzidas no processo, isto é, de efetivamente enfrentá-las na fundamentação da sua decisão (art. 489, §1.º, IV) para, a partir daí, *dar razão a uma das partes* (art. 490). Nisso consiste a atividade de cognição: examinar justificadamente alegações e provas para então dar razão a uma das partes.

A prolação da sentença que resolve o litígio entre as partes *pode ou não ser suficiente* para a tutela do direito do autor. Vale dizer: pode ser necessária ou não *atividade executiva posterior* para a sua consecução (art. 513 e ss.). A atividade executiva será indispensável toda vez que a sentença depender da prática de *atos processuais posteriores* para ser atendida concretamente pelo réu ou para ser imposta pelo próprio juiz. Nesse caso, a sentença deverá ser *cumprida* mediante *técnicas processuais executivas* (arts. 139, IV, e 520)¹⁴⁷, isto é, mediante a prática de atos processuais que viabilizem a realização efetiva do comando sentencial. Daí a *ligação funcional* entre cognição e

execução no sistema da tutela jurisdicional dos direitos¹⁴⁸. A atividade de execução, portanto, é uma atividade vocacionada à realização dos direitos com ou sem a colaboração do réu, a qual parte do pressuposto de que uma das partes tem provisória ou definitivamente razão nas suas postulações.

As atividades de cognição e execução podem ser desenvolvidas mediante o procedimento comum ou mediante procedimentos diferenciados. A atividade de execução pode ser fundada em cognição sumária ou exauriente.

2.3. Processo e Tutela dos Direitos: Tutela dos Direitos mediante Procedimento Comum e Procedimentos Diferenciados. O procedimento comum do processo de conhecimento – que é o nosso *procedimento padrão para a tutela dos direitos* – viabiliza ao longo do seu desenvolvimento tanto atividades de cognição como de execução para tutela dos direitos. Em regra, portanto, cognição e execução encontram-se *funcionalmente pré-ordenadas* no procedimento comum para consecução da tutela jurisdicional. No procedimento comum, a atividade executiva pode estar fundada em cognição sumária (antecipação da tutela) ou em cognição exauriente (cumprimento de sentença). Vale dizer: as atividades de cognição e execução são *concretamente adaptáveis* pelo juiz no procedimento comum para atender às necessidades evidenciadas pelo direito material ao longo do seu desenvolvimento.

Ao lado do procedimento comum, o legislador desenhou *procedimentos diferenciados* para a tutela dos direitos, *adaptados desde logo em abstrato* pelo fato de a execução preceder à cognição (como no caso da execução fundada em título executivo extrajudicial, art. 771 e ss.) ou pela necessidade de maior adequação do processo ao direito material, o que pode determinar cortes na cognição no plano horizontal para limitação do debate a determinadas questões (como no caso das ações possessórias, em que o debate está limitado à posse, sendo vedada qualquer discussão dominial, art. 554 e ss.) ou particularizações procedimentais em atenção a certas especificidades do direito material posto em juízo (como no caso da ação de consignação em pagamento, art. 539 e ss.) ou a certas especificidades do modo como determinado direito pode ser evidenciado no processo (como no caso da ação monitória, em que o direito só pode ser demonstrado mediante prova escrita, art. 700 e ss.).

Em todos esses casos, o procedimento adapta-se ao direito material – seja pelo legislador, seja pelo juiz, seja em função da primazia da cognição ou da execução, seja em relação ao nível de cognição ou em relação às técnicas executivas disponíveis para tutela dos direitos. Pensado na perspectiva da tutela dos direitos, uma das perspectivas pelas quais o Código de 2015 pode ser sistematizado é a do binômio procedimento comum – procedimentos diferenciados. Nessa linha, as técnicas processuais adaptam-se às necessidades evidenciadas pelo direito material para sua efetiva e tempestiva tutela.

2.4. Processo e Tutela dos Direitos: Tutela Definitiva Fundada em Cognição Exauriente e Tutela Provisória Fundada em Cognição Sumária. O procedimento pode levar à prestação de uma tutela definitiva fundada em *cognição exauriente* ou a uma tutela provisória fundada em *cognição sumária*. Isso quer dizer que, independentemente de a cognição ser definitiva, pode haver tutela do direito, inclusive com a prática de atividade executiva para sua concretização.

A tutela é exauriente quando é prestada mediante um procedimento em que ambas as partes foram ouvidas – ou, pelo menos, tiveram a oportunidade de ser ouvidas – e em que a decisão se encontra fundada em um quadro probatório completo – ou, pelo menos, em um quadro probatório tão completo quanto admitido pela natureza do procedimento. As sentenças que julgam procedente ou improcedente os pedidos formulados pelas partes no procedimento comum são exemplos clássicos de decisões fundadas em cognição exauriente (arts. 354 a 356, 485 e 487). A tutela fundada em *cognição exauriente* é uma *tutela definitiva* e é *idônea* à formação da coisa julgada (art. 502).

A tutela é sumária quando é prestada mediante um procedimento em que apenas uma das partes teve a oportunidade de se manifestar ou em que o material probatório recolhido ainda é passível de enriquecimento ao longo do procedimento ou ainda de outro procedimento. A tutela

sumária, assim, é caracterizada pela incompletude material da causa (“*materielle Unvollständigkeit der causae cognitio*”¹⁴⁹). Exemplos de tutelas que podem ser prestadas mediante a técnica da cognição sumária são as tutelas de urgência e de evidência (arts. 300 e 311). A tutela fundada em cognição sumária é uma *tutela provisória* e é *inidônea* à formação da coisa julgada. A propósito, é por essa razão que o legislador fala em *tutelas provisórias* nos art. 294 e ss.

A doutrina que forneceu as bases teóricas do Código Buzaid encontrava-se fundada no mito da *nulla executio sine titulo* – impossibilidade de qualquer espécie de execução antes do trânsito em julgado¹⁵⁰. Uma clara manifestação dessa orientação encontrava-se na compreensão da tutela cautelar como uma tutela do processo ao processo – e não como uma tutela do direito – e na compreensão de toda tutela sumária como tutela cautelar¹⁵¹. Como pelo princípio da *nulla executio* não poderia existir tutela do direito fundada em cognição sumária, toda e qualquer proteção que se outorgasse a uma das partes ao longo do processo só poderia ser camuflada como uma tutela dirigida ao processo.

O Código de 2015 repele a ideia de que apenas as sentenças transitadas em julgado podem dar lugar à execução. Na sistemática atual, tanto a cognição sumária como a cognição exauriente podem dar lugar à prática de atos executivos (arts. 297, 515, I, 520 e ss., e 523 e ss.). Seja mediante tutelas provisórias (isto é, mediante procedimento de cognição sumária), seja mediante tutelas definitivas (isto é, mediante procedimento de cognição exauriente), é possível obter por meio do exercício da ação a cabal realização dos direitos.

3. O Código de Processo Civil como Texto, como Norma e como Sistema. O Código de Processo Civil apenas metaforicamente é uma norma e um sistema: na verdade, o Código é um documento textual dotado de autoridade jurídica que, uma vez interpretado, dá lugar a um sistema de normas¹⁵². Em outras palavras, o Código de Processo Civil só alcança a sua condição sistemática e normativa mediante interpretação¹⁵³.

O fato de o Código de Processo Civil – como os textos em geral – depender de interpretação para resultar em um sistema normativo faz com que se perceba que inexistente um sistema *a priori* ou mesmo uma norma jurídica antes da interpretação: uma e outra dependem de uma decisão interpretativa que adscreeva um sentido ao texto ou ao seu conjunto. Daí porque a produção normativa vai das *fontes às normas* e das *normas ao sistema* – ao contrário do que se supunha quando se imaginava a interpretação como simples declaração de uma norma inserida em um sistema (aí compreendidas ambas com significados totalmente determinados antes da interpretação)¹⁵⁴.

3.1. Das Fontes às Normas. O Código de Processo Civil é uma fonte, um documento textual dotado de autoridade jurídica. Não é ainda, porém, uma norma. A norma é o resultado da sua interpretação. Isso quer dizer que antes da interpretação existem vários significados possíveis que podem ser adscritos pelo intérprete ao texto, mas não existem ainda propriamente normas.

Essa contingência é devida à dupla indeterminação do direito¹⁵⁵: equivocidade textual e vagueza normativa são atributos que implicam indeterminação. A equivocidade (ambiguidade, complexidade, implicabilidade, defectibilidade e abarcabilidade) e a vagueza (impossibilidade de antever exatamente quais são os fatos que recaem nos seus respectivos âmbitos de incidência) são paulatinamente desbastadas no processo de interpretação do direito a fim de que se possa chegar institucionalmente a uma interpretação única capaz de guiar a administração da justiça civil e a sociedade como um todo a respeito do significado normativo de determinado enunciado textual. Daí porque a unidade do direito obedece a um processo dinâmico e argumentativo de reconstrução interpretativa que vai das fontes às normas.

Um texto é equívoco porque dá azo a *dúvidas interpretativas a respeito do seu significado*, seja porque ambíguo, complexo, implicativo, defectível ou redigido de forma aberta ou fechada. Um texto é *ambíguo* quando dá lugar a dois ou mais significados possíveis excludentes – significa uma coisa ou outra. É *complexo* quando dá lugar a dois ou mais significados possíveis concorrentes – significa uma coisa e outra. É *implicativo* quando dá lugar logicamente a outro. É *defectível* quando o texto está sujeito a exceções implícitas. Por fim, os textos podem ainda ser equívocos por força

do modo com que redigidos, se aludindo a *simples exemplos* ou se contendo uma *pretensão de taxatividade* – em um e em outro caso a *analogia* e o *argumento analógico* são fatores de equívocidade textual¹⁵⁶.

Essa potencial equívocidade dos textos, contudo, não é algo que possa ser eliminado simplesmente pelo *apuramento linguístico* na sua redação. Na verdade, a equívocidade não é propriamente um defeito *objetivo* do texto, mas uma decorrência de *diferentes interesses e concepções a respeito da justiça dos intérpretes* e da *multiplicidade de concepções dogmáticas e métodos interpretativos por eles utilizados* que interferem na atividade de individualização, valoração e escolha de significados. A interpretação varia de acordo com a posição assumida pelo intérprete na sociedade ou diante de determinado conflito (diferentes interesses), com as suas inclinações ético-políticas (concepções de justiça), com os conceitos jurídicos de que se vale (concepções dogmáticas) e com os argumentos interpretativos eleitos (métodos interpretativos)¹⁵⁷ – e é justamente por essa razão que a *vida do Direito*, concretizada na sua interpretação e aplicação, não depende *apenas da lógica*, mas é antes de tudo *experiência* (“*the life of the law has not been logic: it has been experience*”)¹⁵⁸.

Uma norma é vaga porque dá lugar a *dúvidas interpretativas a respeito dos casos* que recaem ou não sob o seu campo de aplicação¹⁵⁹. As normas são vagas porque se valem de *predicados* para comunicar aquilo que esperam de seus destinatários. Os predicados aludem não a entidades individuais, mas a *classes*, isto é, um conjunto de entidades individuais, cujo significado depende das suas *características* (isto é, dos *atributos* do objeto) e da sua *extensão* (isto é, dos objetos que são alcançados pelas características). A vagueza normativa, portanto, deriva do fato de os predicados normativos terem seus confins de aplicação incertos por força da indeterminação das suas características e do seu alcance¹⁶⁰.

Conquanto, a fim de que o direito possa *orientar* condutas a fim de cumprir com os seus objetivos básicos de prover uma ordem jurídica pautada pela *liberdade* e pela *igualdade*, é preciso *reduzir a sua indeterminação*. A interpretação é o modo pelo qual essa operação é paulatina e contextualmente realizada.

Para que esse processo de permanente determinação do direito possa ser realizado de forma segura, é preciso que seja empreendido de forma racional seja do ponto de vista da *atividade interpretativa*, seja do ponto de vista do seu *resultado*. Em outras palavras, a fim de que exista uma segura densificação do direito é preciso que a interpretação seja racional. Sem *racionalidade* não há como realizar um *controle intersubjetivo das razões* invocadas pelo intérprete para suportar as suas decisões diante das *dúvidas interpretativas* surgidas em face do direito aplicável¹⁶¹.

Uma interpretação é racional quando a atividade do intérprete é *justificada* e o seu resultado é *coerente e universalizável*.

Sendo a interpretação uma *atividade lógico-argumentativa*, a sua justificação deve igualmente abranger essas duas linhas que conduzem o raciocínio judiciário. Essa é a razão pela qual a justificação é normalmente classificada em *justificação interna* e *justificação externa*¹⁶².

De um lado, uma decisão apresenta *justificação interna* sempre que o *dispositivo decorre logicamente da fundamentação* e que essa contempla *todos os fundamentos* arguidos pelas partes. Na justificação interna, portanto, interessa a *correção lógica* e a *completude* da fundamentação da decisão¹⁶³. Daí que a justificação interna é uma justificação *formal* que responde à *necessidade de não contradição* no discurso jurídico¹⁶⁴. É o campo em que a *lógica* atua no processo interpretativo¹⁶⁵, no qual o julgador raciocina de forma *dedutiva* para solução das questões¹⁶⁶.

De outro, uma decisão tem justificação externa (*externe Rechtfertigung*) sempre que as premissas adotadas na decisão são adequadas. A justificação externa, portanto, concerne à adequação das escolhas das premissas empregadas na justificação interna. Nessa linha, constitui uma justificação material que responde à necessidade de adoção de razões suficientes para tomada de decisão¹⁶⁷, envolvendo o exame tanto de normas como de fatos¹⁶⁸, na medida em que

entre ambos existe uma absoluta implicação¹⁶⁹. É o campo em que a argumentação atua no processo interpretativo¹⁷⁰, no qual o julgador individualiza, valora e decide de forma não dedutiva¹⁷¹.

Como campo próprio da argumentação jurídica, entram em consideração na justificação externa, por exemplo, as normas jurídicas, as normas sobre interpretação, as normas preferenciais argumentativas e as construções doutrinárias empregadas na decisão¹⁷². Em outras palavras, encontra-se no âmbito da justificação externa o *material* que se encontra à disposição do intérprete para consecução do processo interpretativo.

No que concerne às normas jurídicas, impende observar que quanto *maior a abertura semântica, maior a justificativa* que deve ser empreendida para sua aplicação. Isso vale para todas as espécies normativas, mas ganha especial relevo para a aplicação dos *princípios jurídicos* e para concretização de *termos vagos* empregados pelo legislador¹⁷³. Em todo e qualquer caso, o processo argumentativo que justifica as escolhas ligadas às premissas do raciocínio judiciário deve ser orientado por *códigos interpretativos*, os quais fornecem *diretrizes primárias*, que servem para atribuição de significado a enunciados textuais (por exemplo, *diretrizes para interpretação linguística, para interpretação da intenção do legislador e para interpretação teleológica*), *diretrizes secundárias*, que servem para disciplina e valoração da utilização das diretrizes primárias (por exemplo, *diretrizes seletivas e procedimentais*, dentre as quais se destacam as *preferenciais*) e *diretrizes terciárias*, que servem para outorgar uma direção ao processo interpretativo como um todo (por exemplo, *diretriz que entende que o fim da interpretação está na promoção da segurança jurídica*)¹⁷⁴. Dentre as diretrizes secundárias de maior importância para o processo argumentativo encontram-se aquelas que erigem *diretrizes preferenciais* – que, por exemplo, determinam a prevalência *prima facie*, nesta ordem, de *argumentos linguísticos* (*linguistic arguments*), *sistemáticos* (*systemic arguments*) e *teleológicos* (*teleological-evaluative arguments*)¹⁷⁵. Vale dizer: argumentos *linguísticos* são preferíveis a argumentos *sistemáticos*, argumentos *sistemáticos* são preferíveis a argumentos *teleológicos* e assim por diante¹⁷⁶.

O resultado da interpretação para ser racional tem de ser *coerente*. A interpretação tem de ser capaz de ser reconduzida a “um conjunto, internamente consistente, formal e materialmente, de princípios e regras” amalgamadas por “princípios fundamentais” comuns¹⁷⁷. Um sistema jurídico preocupado com a sua *unidade* é necessariamente um sistema preocupado com a *hierarquia* e a *coerência* normativas¹⁷⁸.

A coerência é uma conexão de sentidos que se estabelece entre as normas. Pode ser *formal* ou *substancial*. A coerência formal existe quando há uma relação normativa *consistente* (em que inexiste contradição) e *completa* (em que há inteireza e coesão). A ausência de quaisquer desses elementos leva à ausência de coerência. A coerência substancial existe quanto maior for a *dependência recíproca* e *afinidade* entre as normas. Ao contrário do aspecto formal da coerência, o seu aspecto substancial permite graduação. Vale dizer: enquanto a coerência formal existe ou não, a coerência material pode existir em maior ou menor medida¹⁷⁹.

Para ser racional o resultado da interpretação tem de ter ainda capacidade de *universalização* (“*universalization in justification*”¹⁸⁰). Como enfaticamente observa a doutrina, “*there is no justification without universalization*”¹⁸¹. Em outras palavras, a justificação tem que ter condições de ser *replicável* para os casos futuros idênticos ou semelhantes. Sem replicabilidade (“*replicability*”) da justificação, não há *objetividade* e *imparcialidade* na interpretação¹⁸².

O Código de Processo Civil, portanto, a fim de que deixe sua qualidade de simples documento textual e ganhe contornos normativos tem de ser interpretado. Para que esse processo seja condizente com as necessidades impostas pelo Estado Constitucional, é preciso que seja pautado pela racionalidade.

3.2. Das Normas ao Sistema. O mesmo processo interpretativo dinâmico e argumentativo marca a compreensão do conceito de sistema, que por essa razão é relativamente aberto, em permanente reconstrução e por vezes construção – tendo em conta a possibilidade de se perceberem lacunas e

antinomias ao longo da tarefa interpretativa. Assim como as normas não preexistem à interpretação, também o sistema é o seu resultado. Essa é a razão pela qual o sistema não preexiste às normas: a sua reconstrução em termos de ordem e unidade depende da conexão de sentido entre as normas que o compõem. Daí porque das normas ao sistema.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Para o direito em geral, Renato Treves, *Diritto e Cultura*; Torino: Giappichelli, 1947; Angelo Falzea, *Introduzione alle Scienze Giuridiche – Il Concetto di Diritto*, 5. ed, Milano: Giuffrè, 1996, p. 492; Norbert Horn, *Einführung in die Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie*, 5. ed; Heidelberg: C. F. Müller, 2011, p. 33-35. Para o processo civil em particular, Luiz Guilherme Marinoni, *Novas Linhas do Processo Civil*, 4. ed., São Paulo: Malheiros, 2010; Alvaro de Oliveira, *Do Formalismo no Processo Civil*, 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2010; Baptista da Silva, *Jurisdição e Execução na Tradição Romano-Canônica*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 1997; Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil – Pressupostos Sociais, Lógicos e Éticos*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015.

2

Para o conceito de sistema como ordem e unidade, Claus-Wilhelm Canaris, *Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz*, 2. ed. Berlin: Duncker & Humblot, 1983, p. 16; para o conceito de sistema como resultado da interpretação, Riccardo Guastini, *Teoria e Dogmatica delle Fonti*, Milano: Giuffrè, 1998, p. 144; para o conceito de cultura e, em especial de cultura positiva, Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil – Pressupostos Sociais, Lógicos e Éticos*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 21-28.

3

Pontes de Miranda, *Fontes e Evolução do Direito Civil Brasileiro*, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 27.

4

Mário Júlio de Almeida Costa, *História do Direito Português*, 2. ed., Coimbra: Almedina, 1992, p. 174.

5

Mário Júlio de Almeida Costa, *História do Direito Português*, 2. ed., Coimbra: Almedina, 1992, p. 174-175; Nuno Espinosa Gomes da Silva, *História do Direito Português*, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, p. 99, 129 e 185, vol. I.

6

Consoante observa Nuno Espinosa Gomes da Silva, *História do Direito Português*, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, p. 106, vol. I.

7

Assim, Nuno Espinosa Gomes da Silva, *História do Direito Português*, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, p. 40-41, vol. I; Marcello Caetano, *História do Direito Português* (1140-1495), 2. ed., Lisboa: Editorial Verbo, 1985, p. 92.

8

Ovídio Baptista da Silva, *Procedimentos Especiais – Exegese do Código de Processo Civil* (arts. 890 a 981), Rio de Janeiro: Aide Editora, 1993, p. 226.

9

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 185, tomo XIII.

10

Nuno Espinosa Gomes da Silva, *História do Direito Português*, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, p. 109-111, vol. I.

11

Marcello Caetano, *História do Direito Português* (1140-1495), 2. ed., Lisboa: Editorial Verbo, 1985, p. 106.

12

Marcello Caetano, *História do Direito Português* (1140-1495), 2. ed., Lisboa: Editorial Verbo, 1985, p. 106. Referido foral compunha-se de um primeiro título (“De la eleccion de los príncipes et del insinnamiento como deben iudgar derecho et de la pena de aquellos que iudgan torto”), no qual se continham doze livros (Libro I, “Del facedor de la ley et de las leyes”, Libro II, “De los juicios y causas”, Libro III, “De los casamientos é de las nascencias”, Libro IV, “Del linage natural”, Libro V, “De las avenencias é de las compras”, Libro VI, “De los malfechos é de las penas é de los tormentos”, Libro VII, “De los furtos é de los engannos”, Libro VIII, “De las fuerzas é de los dammos é de los quebrantamientos”, Libro IX, “De los siervos foidos é de los que se tornan”, Libro X, “De las particiones é de los tiempos é de los annos é de las lindes”, Libro XI, “De los fisicos é de los mercadores de ultramar é de los marineros” e Libro XII, “De devedar los tuertos é derraigar las sectas é sus dichos”).

13

Mário Júlio de Almeida Costa, *História do Direito Português*, 2. ed., Coimbra: Almedina, 1992, p. 186-194.

14

O *forum iudicium* estava dividido em cinco títulos: “de los jueces, y de lo que iudgan”, “de los compezamientos de los pleytos”, “de los mandadores y de las cosas que mandam”, “de las testimonias y de lo que testimoniam” e “de los escriptos que deben valer ó nón, é de las mandas de los muertos”, cada qual com inúmeras subdivisões internas (o primeiro deles, e talvez o mais interessante, por exemplo, tinha

trinta e uma subdivisões: “en quanto tiempo deven valer las leys que son emendadas”, “que el rey é los pueblos devem seer sometidos de las leys”, que tod omne deve saber las leys”, “que las cosas del príncipe deven seer ante ordenadas, é las del pueblo depues”, “de toller la cobdicia de los príncipes, é cuemo deven seer fechos por escriptos en su nombre de los príncipes”, “de los que son rebelles, ó mal obedientes contral príncipe, ó contral pueblo, ó contra la tierra”, “que ningún omne non deve blasphemar el príncipe, nil maldezir”, “de toller las leys de los omnes estrannos”, “que ningun omne non aya otro libro si non este que es fecho d’nuevo”, “de los dias, é de las fiestas que non deven tener pleytos”, “que los iuezes non oyan ningun pleyto, si no aquel que contenido es en las leys”, “que los pleytos pues que una vez fueren acabados, que non sean depues reboltos”, “que ningun omne non deve seer iuez si no al qui lo mandare el príncipe, ó aquel que fuere de consentimiento de las partes, ó demandado de los otros iuezes”, “quales pleytos deven iudgar, é á quales personas los deven dar à iudgar”, “que los iuezes deven iudgar los pleytos criminales, é los otros”, “de la pena que deven aver aquellos que iudgan, é non an poder de iudgar”, “de los que son llamados por letras del iuez, ó por seyello, é non quisieren venir”, “del iuez que non quier oyr à aquel quel demanda quel faga derecho, ó quel iudga tuerto por enganno, ó por non saber”, “del iuez que iudga tuerto por ruego, ó por ignorancia”, “del iuez que faz perder alguna cosa por arte, ó por enganno á alguna de las partes”, “del iuez que bien quiere entender el pleyto, que deve primeramente afazer”, “del iuez que a sospechosa alguna de las partes”, “del iuez cuemo deve iudgar”, “del pro, é del danno que deve aver el sayon”, “que tod omne à quien es dado poder de iudgar aya nombre iuez”, “que tod atamiento que fuere fecho por fuerza del alcalde depues iuyzio non derecho, non vala”, “que el iuyzio, que es dado por mandado del rey, ó por miedo, si es torticero, non vala”, “del poder que an los obispos sobre los iuezes, que iudgan tuerto”, “que el iuez deve dar razon de quantol demandaren”, “de la pena que deve aver el iuez, que toma las cosas aienas, ó las manda tomar” e “de los que non quieren venir por mandado del rey”).

15

É a opinião de Nuno Espinosa Gomes da Silva, *História do Direito Português*, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, p. 111, vol. I.

16

Paul Koschaker, *Europa y el Derecho Romano*, Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, p. 103; Nuno Espinosa Gomes da Silva, *História do Direito Português*, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, p. 141-142, vol. I. Assim, observa Mario Júlio de Almeida Costa: “na verdade, a palavra ‘renascimento’ inculca a ideia de que o direito romano justinianeu tenha deixado, em absoluto, de ser conhecido, estudado e aplicado. Ora, isso jamais se verificou. No Oriente, as fontes justinianeas permaneceram até à queda de Constantinopla (1453). Claro que não pode pensar-se numa aplicação completa e inalterada ao longo de tantos séculos. Após a morte de Justiniano, a sua obra legislativa tornou-se largamente objecto de paráfrases, traduções para grego, resumos, etc. E essa literatura deu ensejo a que se introduzissem modificações substanciais. A vigência das colectâneas justinianeas, no Ocidente, foi, sem dúvida, algo efêmera. Liga-se, bem dizer, à Itália, mercê do domínio bizantino e de uma promulgação expressa, pelos meados do século VI (a ‘pragmatica sanctio’ de 554), cuja eficácia persistiria cerca de catorze anos. Seguiu-se a conquista dos Lombardos (568), que não abrangeu todo o território transalpino, embora quebrasse a sua unidade política e circunscrevesse o direito justinianeu a determinadas cidades, como Roma e Ravena, que conservaram relativa autonomia. Também sabemos que as tropas bizantinas ocuparam o Sul da Península Ibérica. Não terá sido, contudo, uma presença susceptível de conduzir a grandes influências jurídicas. De qualquer modo, as colectâneas justinianeas chegaram ao mundo

ocidental, ainda nessa época. Uma vez conhecidas, continuaram, mais ou menos, a ser conservadas e até analisadas, designadamente nos centros de cultura eclesiástica. Mas isto não significa que, durante os primeiros séculos medievos, tenham conseguido divulgação notória ou alcance efectivo. Pelo contrário, os textos justinianeus, de um modo geral, perderam-se ou caíram no esquecimento. Ora, é para assinalar o contraste entre essa difusão muito modesta ou indiferença e o interesse decisivo que o seu estudo, já com antecedentes no século XI, assume no século XII em diante que se explica e mesmo se justifica a qualificação de renascimento do direito romano” (História do Direito Português, 2. ed, Coimbra: Almedina, 1992, p. 206-207).

17

Franz Wieacker, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit*, 2. ed. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996, p. 29.

18

A glosa consistia em mera explicação gramatical, de carácter tão somente exegetico, de palavras ou frases suscetíveis ao ver dos juristas da época de mais de uma interpretação. O expoente dessa vertente é Acúrsio, autor da célebre obra Magna Glosa, escrita provavelmente entre 1220 e 1234. Nos comentários, de outro lado, os autores já possuem uma preocupação em construir um sistema lógico entre as proposições jurídicas, apto a superar eventuais e aparentes contradições. O primeiro jurista dessa escola é Cino de Pistoia (1270-1336), mas certamente o mais famoso é Bártolo (1313-1353), seguido de Baldo (1327-1400), tudo conforme Nuno Espinosa Gomes da Silva, *História do Direito Português*, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, p. 142-145, vol. I.

19

Paul Koschaker, *Europa y el Derecho Romano*, Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955, p. 240; Mário Júlio de Almeida Costa, “*Fundamentos Históricos do Direito Brasileiro*”, Estudos de Direito Civil Brasileiro e Português (I Jornada Luso-Brasileira de Direito Civil), São Paulo: Ed. RT, 1980, p. 111.

20

Nuno Espinosa Gomes da Silva, *História do Direito Português*, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, p. 153-157, vol. I.

21

Nuno Espinosa Gomes da Silva, *História do Direito Português*, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, p. 159, vol. I.

22

Marcello Caetano, *História do Direito Português (1140-1495)*, 2. ed., Lisboa: Editorial Verbo, 1985, p. 340.

23

Mário Júlio de Almeida Costa, *História do Direito Português*, 2. ed., Coimbra: Almedina, 1992, p. 225-231.

Nuno Espinosa Gomes da Silva, *História do Direito Português*, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, p. 165-167, vol. I.

A matéria apresentava-se da seguinte maneira (ora se reproduzem os títulos na respectiva ordem): “de la iufticia”, “del demandador, e de las cofas que ha de catar ante que ponga la demanda”, “de los demandados, e de las cofas que deven demandar”, “de los juezes, e de las cofas que deven fazer guardar”, “de los perfoneros”, “de los abogados”, “de los emplazamientos”, “de los affentamientos”, “quando deven meter la cofa que contienden en mano del fiel”, “como fe deven començar los pleytos por demanda, e por refpuefta”, “de las juras que las partes fazen en los pleytos, defpues que fon començados por demanda, e por refpuefta”, “de las preguntas que los juezes pueden fazer a las partes en juyzio, defpues que el pleyto es començado por demanda, e por refpuefta, a que llaman en latin, pofitiones”, “de las conofcencias, e de las refpuestas que fazen las partes en juyzio a las demandas, e a las preguntas que fon fechas en razon dellas”, “de las pruebas, e de las fofpechas que los omne aduzen en juyzio fobre las cofas negadas, e dubdofas”, “de los plazos que deven dar los judgadores a las partes en juyzio , para provar fus intenciones”, “de los teftigos”, “de los pefqueridores que han poderio de recibir pruebas por fi de fu officio, maguer las partes no fe las aduxeffen delante”, “de las efcrituras porque fe pruevan los pleytos”, “de los efcrivanos, e quãtas maneras fon dellos, e que pro nafce de fu officio quando lo fazen lealmente”, “de los fellos, e de los felladores de la cancellaria”, “de los confejeros”, “de los juyzios que dan fin, e acabamiento a los pleytos”, “de las alçadas que fazen las partes quando fe tienen por agraviadas de los juyzios que dan contra ellas”, “como los juyzios fe pueden revocar, e oyr de cabo, quando el Rey quifiere fazer merced a alguna de las partes, maguer non fe ouiffe alçado dellos”, “de como fe pueden quebrantar los juyzios que fueffen dados contra los menores de veynte, e cinco años, o fus guardadores, maguer non fue effe tomada alçada”, como fe puede defatar el juyzio que es dado por falfas cartas, o por falfas pruebas contra ley”, “como los juyzios q fon valederos deven fer cumpridos, e quien los puede cumplir”, “de las cofas en que ome puede auer feñono, e como lo puede ganar”, “de los tiepos porque ome pierde las fus cofas, e como lo puede ganar”, de los tiepos porque ome pierde las fus cofas, tambien muebles como rayzes”, “en quãtas maneras puede ome ganar poffefsion, tenencia de las cofas”, “de las ferundumbres q han unas cofas en otras, e como fe pueden poner”, “de las labores nuevas como fe puede embargar que fe non fagan, e de las viejas que fe quieren fazer como fe han de fazer”.

Mas Kaser, *Römisches Privatrecht*, 19. ed. München: C. H. Beck, 2008, p. 397.

Pontes de Miranda, *Fontes e Evolução do Direito Civil Brasileiro*, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 39.

Nuno Espinosa Gomes da Silva, *História do Direito Português*, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, p. 192, vol. I.

30

Mário Júlio de Almeida Costa, *História do Direito Português*, 2. ed., Coimbra: Almedina, 1992, p. 274.

31

Pontes de Miranda, *Fontes e Evolução do Direito Civil Brasileiro*, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 274.

32

Mário Júlio de Almeida Costa, *História do Direito Português*, 2. ed., Coimbra: Almedina, 1992, p. 274-275.

33

Karl Engisch, *Einführung in das juristische Denken*, 11. ed. Stuttgart: Kohlhammer, 2010, p. 189.

34

Giovanni Tarello, *Storia della Cultura Giuridica Moderna*, Bologna: Il Mulino, 1976, p. 19.

35

Livro II, Título IX: “se o caso de que se traute em pratica, nom fosse determinado per ley do Regno, ou estilo, ou custume suso dito ou Leyx Imperiaaes, ou Santos Canones, entom mandamos que se guardem as grosas d’Acursio encorporadas nas ditas Leys. E quando pelas ditas grosas o caso non for determinado, mandamos, que se guarde a opiniom de Bartholo, não embargante que os outros Doutores diguam o contrario”.

36

Paolo Grossi, *L’Ordine Giuridico Medievale*, 3. ed., Roma: Laterza, 2007, p. 154 e ss.; Castanheira Neves, *Metodologia Jurídica – Problemas Fundamentais*, Coimbra: Coimbra Editora, 1993, p. 86.

37

Judith Martins-Costa, *A Boa-Fé no Direito Privado*, São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 241.

38

Franz Wieacker, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit*, 2. ed. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996, p. 63-64.

39

Nuno Espinosa Gomes da Silva, *História do Direito Português*, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, p. 206, vol. I.

40

Segundo Mário Júlio de Almeida Costa, além da preocupação com a difusão do direito do Reino, também haveria contado para elaboração das Ordenações Manuelinas a vaidade de D. Manuel, então rei de Portugal. Com efeito, após indicar a hipótese alvitrada no texto, refere Mário Júlio de Almeida Costa que “ainda se menciona outro aspecto. O de que não seria indiferente a D. Manuel, que assistiu a pontos altos da gesta dos descobrimentos, ligar o seu nome a uma reforma legislativa de vulto. A suposição alicerça-se em vários testemunhos, inclusive na importância atribuída pelo rei ao direito e à realização da justiça” (*História do Direito Português*, 2. ed., Coimbra: Almedina, 1992, p. 277-278).

41

Assim, Nuno Espinosa Gomes da Silva, *História do Direito Português*, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, p. 209-210, vol. I.

42

A respeito da diferente conformação que se opera no direito subsidiário das Ordenações Afonsinas para as Ordenações Manuelinas e Filipinas, escreve Mário Júlio de Almeida Costa: “cifram-se em duas as diferenças essenciais de conteúdo que separam no âmbito do direito subsidiário, as Ordenações Manuelinas e as Ordenações Filipinas do precedente texto afonsino. A saber: I – Quanto à aplicação dos textos de direito romano e de direito canônico, deixa-se de referir a distinção entre problemas jurídicos temporais e espirituais. Apenas se consagra o critério do pecado, que fornecia o único limite à prevalência subsidiária do direito romano sobre o direito canônico, qualquer que fosse a natureza do caso omissio. II – A respeito da Glosa de Acúrsio e da opinião de Bartolo, cuja ordem de precedência se conserva, estabelece-se o requisito de a ‘comum opinião dos doutores’ não contrariar essas fontes. Relativamente a Bartolo, a restrição seria definida tão-só pelos autores que tivessem escrito depois dele. O facto de a letra da lei colocar a ‘*communis opinio*’ como filtro da Glosa de Acúrsio e da opinião de Bartolo levou à interpretação, posto que não pacífica, de que aquela constituía, em si mesma, uma fonte subsidiária. Por outras palavras: na falta de direito nacional, de direito romano e de direito canônico, caberia recorrer à opinião comum, antes da Glosa de Acúrsio e da opinião de Bartolo” (*História do Direito Português*, 2. ed., Coimbra: Almedina, 1992, p. 311).

43

Monograficamente sobre a história da Justiça Civil brasileira à luz da sua influência europeia, especialmente a partir das Ordenações Filipinas, Michele Taruffo e Daniel Mitidiero, *A Justiça Civil – da Itália ao Brasil, dos Setecentos a Hoje*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

44

Mário Júlio de Almeida Costa, *História do Direito Português*, 2. ed., Coimbra: Almedina, 1992, p. 285.

45

Idem, p. 310.

46

Nuno Espinosa Gomes da Silva, *História do Direito Português*, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985, p. 254, vol. I.

47

Enrico Tullio Liebman, “*Il Nuovo ‘Codigo de Processo Civil’ Brasileiro*”, *Problemi del Processo Civile*, Napoli: Morano Editore, 1962, p. 483.

48

Ordenações Filipinas, *Livro V*, Título CXXVIII. Sobre o assunto, Ovídio Araújo Baptista da Silva, *Curso de Processo Civil*, 4. ed., São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 349-351, vol. II.

49

Ordenações Filipinas, *Livro III*, Título LXXVIII, § 5.º, conforme Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 2. ed., Rio de Janeiro: Revista Forense, 1959, p. 5-12, tomo V.

50

Ordenações Afonsinas, *Livro III*, Título XX, § 1.º.

51

Ordenações Manuelinas, *Livro III*, Título XV, § 1.º.

52

Tanto que chamado em determinadas oportunidades de “Senhor do Preito” pelas Ordenações, como, por exemplo, Ordenações Afonsinas, *Livro III*, Título XXIII.

53

Como corretamente observa Heitor Sica, *Preclusão Processual Civil*, 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 39-42.

54

Alvaro de Oliveira, *Do Formalismo no Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 30-33.

55

José da Silva Pacheco, *Evolução do Processo Civil Brasileiro*, 2. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 132-135.

56

Enrico Tullio Liebman, “*Istituti del Diritto Comune nel Processo Civile Brasiliano*”, Problemi del Processo Civile, Napoli: Morano Editore, 1962, p. 500. Sobre o assunto, mais extensamente, Alvaro de Oliveira, *Do Formalismo no Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 44-46; José da Silva Pacheco, *Evolução do Processo Civil Brasileiro*, 2. ed., Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 128-131.

57

Para análise do período dos códigos estaduais, Moacir Lobo da Costa, Breve Notícia Histórica do Direito Processual Civil Brasileiro e de sua Literatura, São Paulo: Ed. RT, 1970, p. 57 e ss.

58

Conforme o clássico estudo de Enrico Tullio Liebman, “*Istituti del Diritto Comune nel Processo Civile Brasiliano*”, Problemi del Processo Civile, Napoli: Morano Editore, 1962, p. 502-516.

59

Moacir Lobo da Costa, *Breve Notícia Histórica do Direito Processual Civil Brasileiro e de sua Literatura*, São Paulo: Ed. RT, 1970, p. 100-101.

60

Bernhard Hahn, *Kooperationsmaxime im Zivilprozess?* Köln: Carl Heymanns, 1983, p. 7.

61

Vittorio Denti, “*Sistematica e Post-sistematica nell’Evoluzione delle Dottrine del Processo Civile*”, *Sistemi e Riforme – Studi sulla Giustizia Civile*. Bologna: Il Mulino, 1990, p. 13 e ss.

62

“Prefácio às Instituições de Direito Processual Civil de Chiovenda”, *Grandes Processualistas*, p. 11.

63

“A Influência de Liebman no Direito Processual Civil Brasileiro”, *Grandes Processualistas*, São Paulo: Saraiva, 1982, p. 45.

64

“A Formação do Moderno Processo Civil Brasileiro (Uma Homenagem a Enrico Tullio Liebman)”, *Fundamentos do Processo Civil Moderno*, p. 39, tomo I.

65

Ovídio Baptista da Silva, *Curso de Processo Civil*, p. 116-117, vol. I.

66

Giuseppe Chiovenda, *Instituições de Direito Processual Civil*, p. 183, vol. I.

67

Enrico Tullio Liebman, “L’Azione nella Teoria del Processo Civile”, *Problemi del Processo Civile*, p. 45; *Manual de Direito Processual Civil*, p. 200, vol. I.

68

Giuseppe Chiovenda, *Instituições de Direito Processual Civil*, p. 196, vol. III.

69

Enrico Tullio Liebman, *Processo de Execução*, p. 4.

70

Enrico Tullio Liebman, *Op. Cit.*, p. 10; “La Sentenza come Titolo Esecutivo”, *Problemi del Processo Civile*, Napoli: Morano Editore, 1962, p. 333.

71

Enrico Tullio Liebman, *Op. Cit.*, p. 38.

72

Enrico Tullio Liebman, *Op. Cit.*, p. 13.

73

Enrico Tullio Liebman, *Op. Cit.*, p. 23-25.

74

Enrico Tullio Liebman, *Op. Cit.*, p. 18-19; “Execução e Ação Executiva”, *Estudos sobre o Processo Civil Brasileiro*, 1976, p. 33-78.

75

Enrico Tullio Liebman, *Op. Cit.*, p. 34.

76

Enrico Tullio Liebman, *Embargos do Executado* (Oposições de Mérito ao Processo de Execução), p. 177-182.

77

Enrico Tullio Liebman, Op. Cit., p. 34 e 38.

78

Enrico Tullio Liebman, Op. Cit., p. 33.

79

Piero Calamandrei, *Introduzione allo Studio Sistematico dei Provvedimenti Cautelari*, p. 15.

80

Calamandrei, Op. Cit., p. 55-58.

81

Piero Calamandrei, Op. Cit., p. 21-22.

82

Piero Calamandrei, Op. Cit., p. 9-12. Na doutrina de Calamandrei, entra igualmente no conceito de provisoriedade o conceito de temporariedade. A provisoriedade funciona ao mesmo tempo como gênero e espécie. Provisório é aquilo que tem duração limitada em função de algo que irá necessariamente lhe substituir. Temporário, simplesmente aquilo que não dura para sempre, independentemente da superveniência de algo que o substitua (Op. Cit., p. 10).

83

Piero Calamandrei, Op. Cit., p. 22.

84

Enrico Tullio Liebman, “*Unità del Procedimento Cautelare*”, *Problemi del Processo Civile*, p. 104-110.

85

Piero Calamandrei, Op. Cit., p. 8-9.

86

Piero Calamandrei, Op. Cit., p. 9-12.

87

Tanto é assim que Piero Calamandrei entendia como cautelares os provimentos antecipatórios da decisão final de mérito do processo de conhecimento, no que foi fielmente seguido pelo legislador brasileiro de 1973, Op. Cit., p. 31-51, especialmente p. 38-44.

88

É a opinião de Pontes de Miranda, *Fontes e Evolução do Direito Civil Brasileiro*, p. 85, para quem “não seria errôneo dizê-lo o antepenúltimo Código do século passado” (isto é, do século XIX), analisando-o do ponto de vista do rigor “científico”. Também é a lição de Clóvis do Couto e Silva, “O direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão de futuro”, p. 19, que registra: “se examinarmos os institutos básicos do Código Civil brasileiro de 1916, veremos que ele é um dos melhores Códigos do século XIX, ainda quando publicado no século XX”, e de Judith Martins-Costa, *A Boa-Fé no Direito Privado*, p. 259.

89

Franz Wieacker, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit*, p. 431.

90

Pontes de Miranda, Op. Cit., p. 93 e 440.

91

Atesta a influência de Savigny sobre Teixeira de Freitas, Clóvis do Couto e Silva, “O Direito Civil Brasileiro em Perspectiva Histórica e Visão de Futuro”, *O Direito Privado Brasileiro na Visão de Clóvis do Couto e Silva*, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p. 17; atesta a influência do Esboço na redação do Código Beviláqua, Pontes de Miranda, Op. Cit., p. 93.

92

Eugênio Facchini Neto, “*Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do direito privado*”, p. 17.

93

Analisando o tema, pontua Orlando Gomes, *Raízes Históricas e Sociológicas do Código Civil Brasileiro*, p. 25: “o quadro econômico e social em que se processa a obra dos codificadores, de 1899 a 1916, deve ser traçado, em suas linhas gerais, para a melhor compreensão do sentido da codificação, melhor aferição do seu valor, e melhor fixação das suas coordenadas. A esse tempo não se iniciara o processo de transformação da economia brasileira, que a guerra mundial de 14 viria a desencadear. A estrutura agrária mantinha no país o sistema colonial, que reduzia a sua vida econômica ao binômio da exportação de matérias-primas e gêneros alimentares e da importação de artigos fabricados. A indústria nacional não ensaiara os primeiros passos. Predominavam os interesses dos fazendeiros e dos comerciantes, aqueles produzindo para o mercado internacional e estes importando para o comércio interno. Esses interesses eram coincidentes. Não havia, em consequência, descontentamentos que suscitassem grandes agitações

sociais. A preservação e a defesa desses interesses estavam confiadas a uma classe média escassa, cujo marginalismo econômico se compensava no exercício dos cargos burocráticos, dos quais se assenhoreara em consequência da urbanização prematura de alguns pontos do país. Para organização social do país, a racionalização dos interesses dos fazendeiros e comerciantes se processou por intermédio dessa classe, que os matizou com os pigmentos de seus preconceitos. Ajustada, então, material e espiritualmente, à situação econômico-social do país, pelo apoio que recebia da burguesia rural e mercantil, transfundiu a ordem jurídica a seiva de sua ilustração, organizando uma legislação inspirada no Direito estrangeiro, que, embora estivesse, por vezes, acima da realidade nacional, correspondia, em verdade, aos interesses cuja guarda e desenvolvimento se devotava”.

94

Miguel Reale, “Significação histórica do Código Civil Francês”, p. VIII.

95

Guido Alpa, *Trattato di diritto civile – Storia, fonti, interpretazione*, p. 22, vol. I.

96

Judith Martins-Costa, *Op. Cit.*, p. 182.

97

Judith Martins-Costa, *Op. Cit.*, p. 202.

98

Ricardo Aronne, “*Sistema jurídico e unidade axiológica: os contornos metodológicos do direito civil-constitucional*”, p. 43.

99

Guido Alpa, *Op. Cit.*, p. 28.

100

Alvaro de Oliveira, “*Procedimento e ideologia no direito brasileiro atual*”, p. 79-85, n. 33; Ovídio Baptista da Silva, *Processo e ideologia*; Laércio Becker, *Contratos bancários – execuções especiais*.

101

Daniel Mitidiero, *Elementos para uma teoria contemporânea do processo civil brasileiro*, p. 36.

102

Alvaro de Oliveira, *Do formalismo no processo civil*, p. 125; Ovídio Baptista da Silva, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 76, vol. I; Hermes Zaneti Júnior, *Mandado de segurança coletivo*, p. 45 e 92.

103

Sobre a “pessoalização” dos direitos na cultura jurídica de que tributária o Código Buzaid, Ovídio Baptista da Silva, *Jurisdição e execução na tradição romano-canônica*, p. 134-145; Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela inibitória*, p. 305-312.

104

Regras, aliás, que já tinham inclusive suscitado a repreensão parcial de Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 5. ed, Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 268-269, tomo I, por entendê-las demasiadamente patrimonialistas.

105

Ovídio Baptista da Silva, *Processo e Ideologia*, cit., p. 198-200; Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela Inibitória*, cit., p. 293-297.

106

Trata-se de perfil executivo bem ao gosto da doutrina italiana que inspirou Alfredo Buzaid. Lembre-se que, para Liebman, só é execução aquela que age a despeito da vontade do executado (Processo de Execução, cit., p. 4). As chamadas medidas de coerção, dentre as quais se ensartam as *astreintes*, não eram consideradas técnicas processuais executivas (Liebman, Op. Cit., p. 5 e 160).

107

Giuseppe Chiovenda, *Instituições de Direito Processual Civil*, p. 9-14, vol. II.

108

Piero Calamandrei, *Istituzioni di Diritto Processuale Civile secondo il Nuovo Codice*, p. 69, vol. IV.

109

Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica Processual e Tutela dos Direitos*, cit., p. 35.

110

Ingo Wolfgang Sarlet, *A Eficácia dos Direitos Fundamentais*, p. 46-47.

111

A expressão é utilizada por Natalino Irti, *L'Età della Decodificazione*, p. 21-22, e deve ser entendida nos

exatos termos em que aparece trabalhada pelo autor.

112

Alvaro de Oliveira, *Do formalismo no processo civil*, cit., p. 79-83.

113

Para um exame das raízes destas ideias, Ovídio Baptista da Silva, *Jurisdição e execução na tradição romano-canônica*, cit., p. 102-133; *Processo e ideologia*, cit., p. 131-150; Luiz Guilherme Marinoni, *Antecipação da tutela*, p. 117-118; *Tutela antecipatória e julgamento antecipado*, p. 175-185.

114

Expressões que, dado o voluntarismo comum e a suposição de que o sentido normativo é totalmente prévio à decisão judicial, dão no mesmo, ressalvado o espectro mais amplo da segunda no que tange à conformação do fenômeno jurídico. A primeira expressão é notoriamente devida a Giuseppe Chiovenda, *Instituições de direito processual civil*, cit., p. 40, vol. I; a segunda, é utilizada como sucedâneo da primeira por Cândido Rangel Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, cit., p. 309, vol. I, e José Roberto dos Santos Bedaque, *Direito e processo – Influência do direito material sobre o processo*, p. 68, que fala em “vontade concreta da norma de direito material”.

115

Guido Alpa, *Op. Cit.*, p. 28.

116

Como não poderia deixar de ser, outro não era o conceito de ato ilícito defendido por Clóvis Beviláqua na doutrina: “ato ilícito é, portanto, o que praticado sem direito, causa dano a outrem” (Teoria geral do direito civil, p. 270).

117

Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela inibitória*, cit., p. 30-36; *Técnica processual e tutela dos direitos*, cit., p. 52-62.

118

José Carlos Barbosa Moreira, “Tutela Sancionatória e Tutela Preventiva”, *Temas de Direito Processual*, p. 23, Segunda Série.

119

Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela Inibitória*, cit., p. 25.

120

Ovídio Baptista da Silva, *Curso de Processo Civil*, p. 133 e ss., 147 ss., vol. I; Luiz Guilherme Marinoni, *Antecipação da tutela*, p. 43 e ss.; Daniel Mitidiero, *Antecipação da tutela*, p. 37 e ss., 83 e ss.

121

Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela inibitória*; Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual e tutela dos direitos*; Sérgio Cruz Arenhart, *A tutela inibitória da vida privada*; Perfis da tutela inibitória coletiva.

122

Sobre as Reformas de 2005 e 2006, Alvaro de Oliveira (coord.), *A nova execução*; Alvaro de Oliveira (coord.), *A nova execução de títulos extrajudiciais*.

123

Sobre o conceito de codificação, Giovanni Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*; Judith Martins-Costa, *A boa-fé no direito privado*.

124

Sobre o conceito de coerência, Neil MacCormick, *Rhetoric and the rule of law*, p. 189-213; *Legal reasoning and legal theory*, p. 152-194; Humberto Ávila, *Teoria dos princípios*, p. 166-175.

125

Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*, vols. I, II e III.

126

A tutela dos direitos pode ser prestada pelo legislador, pelo administrador e pelo juiz. A tutela jurisdicional dos direitos, portanto, é apenas uma das formas pelas quais a tutela dos direitos pode ser prestada: “as normas de direito material que respondem ao dever de proteção do Estado aos direitos fundamentais – *normas que protegem o consumidor e o meio ambiente*, por exemplo – evidentemente prestam tutela – ou proteção – a esses direitos. É correto dizer, assim, que a mais básica forma de tutela dos direitos é constituída pela própria norma de direito material. A atividade administrativa – nessa mesma linha – também pode contribuir para a prestação de tutela aos direitos. A tutela jurisdicional, portanto, deve ser compreendida somente como uma modalidade de tutela dos direitos. Ou melhor, *a tutela jurisdicional e as tutelas prestadas pela norma de direito material e pela Administração constituem espécies do gênero tutela dos direitos*. Entretanto, a tutela jurisdicional pode, ou não, prestar a tutela do direito. Há tutela do direito quando a sentença e a decisão interlocutória *reconhecem* o direito material. Isso significa que a tutela jurisdicional engloba sentença de procedência (que presta tutela do direito) e a sentença de improcedência (que não presta a tutela do direito, embora constitua resposta ao dever do Estado de prestar tutela jurisdicional). Daí já se percebe que a decisão interlocutória e a sentença constituem apenas técnicas para a prestação da tutela do direito. Ou seja, resposta ou tutela jurisdicional há sempre, mas tutela do direito apenas no caso em que a técnica processual reconhecer o direito, isto é, quando a sentença for de procedência” (Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual e tutela dos direitos*,

p. 145-146). A tutela dos direitos incide ainda tanto sobre o *direito material* como sobre o *direito processual*. Quando o legislador densificou o direito fundamental à proteção do consumidor promulgando um Código de Defesa do Consumidor, ele prestou tutela legislativa ao direito. Ainda, quando o legislador promulgou o Código de Processo Civil, ele pretendeu justamente adimplir com o seu dever de dar tutela ao direito fundamental ao processo justo e, muito especialmente, o direito fundamental à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva que é dele inseparável.

127

Sobre os direitos fundamentais processuais que integram o direito ao processo justo, Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Curso de processo civil*, vol. I; Marinoni e Mitidiero, *Curso de direito constitucional*, p. 703 e ss., em coautoria com Ingo Sarlet.

128

Humberto Ávila, *Teoria dos princípios*, p. 158 e ss.

129

James Goldschmidt, *Der Prozess als Rechtslage*, p. 227; Rosenberg, Schwab e Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 1.

130

Ovídio Baptista da Silva, *Curso de processo civil*, p. 13, vol. I.

131

A expressão “*danno marginale*” é de Enrico Finzi, cunhada em comentário à decisão de 31 de janeiro de 1925 da Corte de Apelação de Florença, “*Questioni controverse in tema di esecuzione provvisoria*”, publicado na *Rivista di Diritto Processuale Civile*, p. 50, sempre lembrada pela doutrina a propósito da tardança do processo e de seus efeitos na esfera jurídica do demandante que tem razão em seu pleito (Piero Calamandrei, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, p. 18; Italo Andolina, “Cognizione” ed “esecuzione forzata” nel sistema della tutela giurisdizionale, p. 17; Andrea Proto Pisani, “Appunti sulla tutela cautelare”, *Rivista di Diritto Civile*, p. 111; *Lezioni di diritto processuale civile*, p. 593).

132

Foi Chiovenda quem afirmou que a função da jurisdição era a de dar atuação à vontade concreta da lei (Giuseppe Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale civile*, v. 1), reproduzindo claramente Adolf Wach (*Handbuch des deutschen Zivilprozessrechts*. Leipzig: Duncker & Humblot, 1885, p. 267).

133

Abordando a obra de Chiovenda, Giannini escreveu: “Affrontava decisamente una ricostruzione del diritto processuale, con carattere pubblicistico, *sulla base dell'autonomia dell'azione e del rapporto giuridico processuale*, elevando la scienza processuale, con un balzo di dignità, su quello già compiuto dal Mortara,

ad una ricostruzione sistematica storico-dogmatica („,„)” (Amedeo Giannini, Gli studi di diritto processuale civile in Italia. *Rivista Trimestrale diDirittoe Procedura Civile*, p. 109).

134

“La c. d. ‘pubblicizzazione’ del processo civile inverte i presupposti di fondo che erano alla base del codice del 1865 e della dottrina ottocentesca: il processo non è più esclusivamente un ‘affare delle parti’ ma un luogo in cui si esprime l’autorità dello Stato; esso *non mira solo alla tutela di interessi privati, ma realizza l’interesse pubblico all’amministrazione della giustizia*; il perno del processo non è più l’iniziativa delle parti, ma la funzione del giudice. In sintesi, il processo non è più visto come una forma in cui si esplica l’autonomia privata nell’esercizio dei diritti, ma come uno strumento che lo Stato mette a disposizione dei privati in vista dell’attuazione della legge. Con tutto ciò si salda perfettamente la ridefinizione del concetto di azione, compiuta essenzialmente da Chiovenda: *l’azione non è più una sorta di appendice del diritto sostanziale privato, ma un diritto autonomo di natura pubblica*, che mira a produrre conseguenze giuridiche nella sfera della controparte (dove la nota definizione dell’azione come diritto potestativo), *ma che soprattutto chiama in gioco l’autorità dello Stato come tramite e garante dell’attuazione della legge*” (Michele Taruffo, *La giustizia civile in Italia dal’700 a oggi*, p. 188).

135

Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual e tutela dos direitos*, p. 145 e ss.

136

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, *Curso de processo civil*, p. 19 e ss., vol. IV; Daniel Mitidiero, *Antecipação da tutela*, p. 48-50.

137

Sobre a tutela dos direitos, Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela inibitória*; Técnica processual e tutela dos direitos; Sérgio Cruz Arenhart, *A tutela inibitória da vida privada*; Perfis da tutela inibitória coletiva; Daniel Mitidiero, *Antecipação da tutela*.

138

Daí a necessidade, sempre frisada pela doutrina, de distinguirmos processo cautelar de tutela cautelar (conforme, por todos, Ovídio Baptista da Silva, *Curso de processo civil*, p. 15, vol. III).

139

Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, p. 5.

140

Francesco Carnelutti, *Diritto e processo*, p. 33.

141

Vittorio Denti, *La giustizia civile*, p. 116-117.

142

Por todos, Piero Calamandrei, *Istituzioni di diritto processuale civile*, p. 63.

143

Sobre as bases teóricas do Código Buzaid, Daniel Mitidiero, “O processualismo e a formação do Código Buzaid”, *Revista de Processo*, n. 183, p. 165 e ss. Para uma crítica da estrutura do Anteprojeto do Código, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, *O projeto do CPC – Crítica e propostas*, p. 64 e ss.

144

Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual e tutela dos direitos*, p. 98 e ss.

145

Vittorio Denti, “*Il processo do cognizione nella storia delle riforme*”, p. 279-280; Ovídio Baptista da Silva, *Jurisdição e execução na tradição romano-canônica*, p. 102 e ss.

146

Crisanto Mandrioli, *L'azione esecutiva*, p. 109 e ss.; Humberto Theodoro Júnior, A execução de sentença e a garantia do devido processo legal, *passim*.

147

Para um panorama de direito comparado, Michele Taruffo, “A atuação executiva dos direitos: perfis comparados”, *Processo civil comparado – Ensaio*, p. 85 e ss.

148

Italo Andolina, “*Cognizione*” ed “*esecuzione forzata*” nel sistema della tutela giurisdizionale, p. 6 e ss.

149

Hans Karl Briegleb, *Eileitung in die Theorie der summarischen Processe*, p. 12. Sobre o assunto, ainda, Luiz Guilherme Marinoni, *Antecipação da tutela*, p. 36-39; Daniel Mitidiero, *Antecipação da tutela*, p. 92-95.

150

Por todos, Piero Calamandrei, *Istituzioni di diritto processuale civile*, p. 51 e 66 e ss.

151

Luiz Guilherme Marinoni, *Antecipação da tutela*, p. 113 e ss.; Daniel Mitidiero, *Antecipação da tutela*, p. 18-36.

152

Mauro Barberis, *Manuale di Filosofia del Diritto*, Torino: Giappichelli, 2011, p. 164.

153

Riccardo Guastini, *Teoria e Dogmatica delle Fonti*, Milano: Giuffrè, 1998, p. 144.

154

Extensamente, Riccardo Guastini, *Teoria e Dogmatica delle Fonti*, Milano: Giuffrè, 1998, p. 57 e ss.

155

Riccardo Guastini, *Interpretare e Argomentare*, Milano: Giuffrè, 2011, p. 39 e ss.

156

Riccardo Guastini, *Interpretare e Argomentare*, Milano: Giuffrè, 2011, p. 40-44.

157

Riccardo Guastini, *Interpretare e Argomentare*, Milano: Giuffrè, 2011, p. 46-52; Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell' Interpretazione Giuridica*, Bologna: Il Mulino, 2007, p. 144-145.

158

Oliver Wendell Holmes Jr., *The Common Law (1881)*, Cambridge: Harvard University Press, 1963, p. 5. Para uma adequada contextualização dessa célebre afirmação, Giovanni Tarello, *Il Realismo Giuridico Americano*, Milano: Giuffrè, 1962, p. 39-40: “la distinzione tra mere sopravvivenze e diritto che ha una funzione sociale si muove parallelamente ad un'altra distinzione holmesiana: la distinzione tra ‘forma’ e ‘sostanza’ del diritto. All'inizio di *The Common Law* Holmes afferma che ‘la sostanza del Diritto in ogni época corrisponde abbastanza a ciò che in quella stessa época è considerato utile (convenient); ma la sua forma ed il suo macchinismo (machinery), e la misura in cui esso è capace di conseguire i risultati voluti dipendono invece in larga parte dal suo passato’. Appare chiaro ad un esame degli scritti di Holmes che la forma del Diritto altro non è che quanto sopravvive di epoche passate, ed è sprovvisto di rapporti con ciò che attualmente è ‘convenient’. Sulla base di queste distinzioni è sufficientemente chiaro cosa Holmes intendesse con le affermazioni – troppe volte citate fuori dal contesto – secondo cui ‘la vita del diritto non è logica ma esperienza’. Egli intendeva semplicemente dire che, di fatto, i processi attraverso i quali si evolvono gli ordinamenti giuridici, cioè per Holmes i processi di decisione giudiziaria che portano alla formulazione di regole, sono condizionati non tanto da sviluppi sillogistici di regole precedentemente formulate quanto da una serie di fattori in senso lato social che vanno dalla struttura degli interessi in gioco sino alle teorie politiche dominante ed ai pregiudizi dei singoli giudici. Cosichè, mentre la veste esteriore delle decisioni, cioè

la loro 'forma' è secondo Holmes 'logica', la loro 'sostanza' è 'legislativa': ove è palese una assimilazione tra le sopravvivenze del passato che hanno perso una funzione, la forma ed il macchinismo (le tecniche) del diritto, e l'aspetto che Holmes forse poco propriamente chiama 'logico' del diritto".

159

Riccardo Guastini, *Interpretare e Argomentare*, Milano: Giuffrè, 2011, p. 52-53.

160

Idem, p. 54.

161

Daí a razão pela qual se um dia a segurança jurídica chegou a ser identificada com uma suposta segurança do significado prévio do texto normativo (cujo pressuposto estava justamente na prévia determinação do direito), partindo-se da sua dupla indeterminação afirma-se que a segurança jurídica se resolve na segurança do procedimento lógico-argumentativo que leva ao significado normativo (conforme Humberto Ávila, *Segurança Jurídica*, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 250-256; Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas (2013)*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2014, p. 21-23; Id., *Precedentes – da Persuasão à Vinculação*, São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 22-24).

162

Assim, Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*. Frankfurt im Main: Suhrkamp, 1983, p. 273; Aulis Aarnio, *The Rational as Reasonable – A Treatise on Legal Justification*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1987, p. 119-120; Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell'Interpretazione Giuridica*. Bologna: Il Mulino, 2007, p. 14-15. A distinção entre “justificação interna” e “justificação externa” na teoria da argumentação é devida notoriamente a Jerzy Wróblewski, “Legal Decision and Its Justification”, *Logique et Analyse*, 1971, p. 412, n. 14. Para um amplo debate, Jerzy Wróblewski, *The Judicial Application of Law*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992, especialmente p. 209-262.

163

A necessidade de *completude* da fundamentação decorre do direito ao contraditório das partes, entendido como *direito de influência* das partes (art. 10, CPC) e *dever de diálogo* judicial (art. 489, § 1.º, IV, CPC), que coloca o *juiz como um dos sujeitos do contraditório* (Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil – Pressupostos Sociais, Lógicos e Éticos* (2009), 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 85-90 e 143-158).

164

Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell'Interpretazione Giuridica*, Bologna: Il Mulino, 2007, p. 14.

165

Giovanni Tarello, *L'Interpretazione della Legge*, Milano: Giuffrè, 1980, p. 75-85.

166

Riccardo Guastini, *Interpretare e Argomentare*, Milano: Giuffrè, 2011, p. 258.

167

Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell' Interpretazione Giuridica*, Bologna: Il Mulino, 2007, p. 15.

168

Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell' Interpretazione Giuridica*. Bologna, Il Mulino, 2007, p. 14-15.

169

Giovanni Tarello, *L' Interpretazione della Legge*, Milano: Giuffrè, 1980, p. 33.

170

Giovanni Tarello, *L' Interpretazione della Legge*, Milano: Giuffrè, 1980, p. 85-99.

171

Riccardo Guastini, *Interpretare e Argomentare*, Milano: Giuffrè, 2011, p. 258.

172

Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*. Frankfurt im Main: Suhrkamp, 1983, p. 285.

173

Como observa Cláudio Michelin, “a expressão ‘princípio jurídico’ tem tido uma presença frequente em decisões judiciais e na doutrina brasileiras. A expressão foi popularizada entre os profissionais e teóricos do direito no Brasil a partir de uma leitura direta ou, frequentemente, indireta de autores como Ronald Dworkin e Robert Alexy. Ironicamente, um conceito que foi originalmente elaborado como uma forma de estabelecer critérios de racionalidade que limitam a discricionariedade judicial é mais comumente associado no Brasil a um instrumento que permite ao juiz mais liberdade em relação à lei e ao direito posto. De fato, os princípios são muitas vezes utilizados por tribunais e doutrinadores como uma forma de eliminar dificuldades postas por regras complexas e/ou que destoam da concepção de justiça do juiz ou escritor. Na maior parte da América Latina os princípios dworkinianos foram recebidos não tanto como uma reação à crítica *realista* ao formalismo na argumentação jurídica, mas como uma forma de reação ao próprio *formalismo* interpretativo tardio que, segundo alguns, caracterizava a região. No caso particular do Brasil, a inserção dos princípios na argumentação jurídica faz parte da segunda geração de ataques ao formalismo jurídico, que se segue à primeira geração composta pelo amplo espectro de teorias relacionadas direta ou indiretamente ao chamado ‘direito alternativo’. Essa segunda onda de ataque ao formalismo atingiu o seu alvo e o paradigma formalista de argumentação não é mais a regra no Brasil (se é que um dia foi). Todavia, o ataque ao formalismo atingiu muito mais do que o seu alvo declarado. O que se coloca em questão a partir do modo como os princípios jurídicos vêm sendo utilizados tanto na

doutrina como na prática do direito brasileiro é a própria noção de que o direito é algo criado dinamicamente pela comunidade política e não algo derivado de um conjunto abstrato e vago de bens ou valores por especialistas que têm um *insight* privilegiado sobre como esses bens e valores fundamentais devem conformar nossas instituições e decisões políticas. Ou seja, o que está em jogo é a legitimidade democrática desse arranjo institucional” (“Princípios e Coerência na Argumentação Jurídica”, *Direito e Interpretação – Racionalidades e Instituições*, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 261-262).

174

Amplamente, Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell’ Interpretazione Giuridica*, Bologna: Il Mulino, 2007, p. 80-123.

175

Como observam Neil MacCormick e Robert Summers, “*in this model, the first three of our categories form the ground for a prima facie ordering of arguments. When the interpretative conditions for linguistic arguments are satisfied, these arguments should be tried out prior to consideration of any other arguments; one should move to considering systemic arguments only after a preliminary scrutiny of the output of linguistic ones, and only if there is some reason to doubt the satisfactoriness of the linguistically interpretation; likewise, one should move to the teleological-evaluative arguments (if at all) only after scrutiny of the former two*” (“*Interpretation and Justification*”, *Interpreting Statutes – A Comparative Study*. Dartmouth: Ashgate, 1991, p. 530).

176

Humberto Ávila, *Segurança Jurídica*, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 273 e 278. Para uma proposta analítica, Humberto Ávila, “Teoria Giuridica dell’ Argomentazione”, *Analisi e Diritto*, Madrid: Marcial Pons, 2012, p. 11-40, especialmente p. 17 e ss.

177

Cláudio Michelson, “Princípios e Coerência na Argumentação Jurídica”, *Direito e Interpretação – Racionalidades e Instituições*, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 267; Humberto Ávila, *Segurança Jurídica*, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 273. Sobre a coerência na argumentação em geral, Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law*, Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 189-213; *Legal Reasoning and Legal Theory* (1978), Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 152-194; Aleksander Peczenik, *On Law and Reason* (1989), Dordrecht: Springer, 2009, p. 131-152.

178

Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios* (2003), 15. ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 166 e ss. O postulado da unidade da ordem jurídica é integrado por basicamente dois outros postulados: o da hierarquia e o da coerência. O primeiro tem por objeto as relações resultantes da *estrutura escalonada* da ordem jurídica, resolvendo-se no plano da *validade* normativa. O segundo, as *conexões de sentido* entre as diferentes normas que compõem a ordem jurídica, resolvendo-se no plano da *eficácia*. O primeiro funciona a partir de uma sistematização *linear* (“a norma superior constitui o fundamento da norma inferior”), *simples* (“baseada numa relação de hierarquia linear entre as normas”) e *não gradual* (“as normas estão, ou não,

sistematizadas enquanto hierarquicamente postas”). O segundo, a partir de uma sistematização *circular* (“as normas superiores condicionam as inferiores, e as inferiores contribuem para determinar os elementos das superiores”), *complexa* (“não há apenas uma relação vertical de hierarquia, mas várias relações horizontais, verticais e entrelaçadas entre as normas”) e *gradual* (“a sistematização será tanto mais perfeita quanto maior for a intensidade da observância dos seus vários critérios”).

179

Tudo conforme Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios* (2003), 15. ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 169-171.

180

Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law*, Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 97. Amplamente, Paula Pessoa Pereira, *Legitimidade dos Precedentes – Universabilidade das Decisões do STJ*, São Paulo: Ed. RT, 2014.

181

Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law*, Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 99.

182

Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law*, Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 91; Melvin Eisenberg, *The Nature of the Common Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1991, p. 8-12.

29

Idem, *ibidem*.

Comentários ao CPC - v. I - Marinoni - Ed. 2018

PARTE GERAL

1. Previsão da Parte Geral. O Código de 2015 está dividido em Parte Geral e Parte Especial. Ao prever uma Parte Geral, o legislador resolveu retomar a trilha do Código de 1939, afastando-se do caminho tomado pelo Código Buzaid – que nesse particular foi criticado pela doutrina¹.

A parte geral é um reflexo legislativo da *Allgemeine Rechtslehre* que floresceu no seio da pandectística alemã dos Oitocentos². Vale dizer: é um reflexo legal da proposta teórica de identificação de uma teoria geral do direito, cujos contornos iniciais já podem ser sentidos com a *analytical jurisprudence* inglesa³.

Com a parte geral procura-se traçar os compromissos fundamentais do Código (arts. 1.º a 12), prever os institutos fundamentais do processo civil (arts. 16 a 20), além da sua disciplina subjetiva (os sujeitos do processo, arts. 21 a 187) e objetiva (os atos processuais, arts. 188 a 317). Ao instituí-la, o legislador procurou amalgamar em um só lugar as bases do processo civil, as quais servem para iluminar a interpretação e colaborar na aplicação de todo o processo civil brasileiro – de todos os institutos previstos na parte especial e também na legislação extravagante⁴.

Portanto, a principal função da parte geral é assegurar unidade ao sistema, interligando não só todas as matérias que compõem a estrutura codificada, mas também toda a legislação processual civil⁵. Com isso, acomete-se à parte geral o objetivo de principiar e enfeixar a disciplina infraconstitucional do processo civil.

É claro, no entanto, que nem todos os institutos gerais estão previstos na parte geral. O caso sem dúvida mais eloquente diz respeito à matéria concernente aos processos nos tribunais e aos recursos. É evidente o caráter geral do tema, nada obstante o legislador tenha inexplicavelmente procurado destacá-lo do local pertinente.

2. Diálogo entre a Parte Geral e a Parte Especial. Como já observado, a divisão entre parte geral e parte especial serve tradicionalmente para evidenciar a existência de normas e institutos que servem para compreensão e estruturação de todo o processo civil, enquanto outras normas e institutos possuem um alcance circunscrito apenas a determinadas espécies procedimentais ou atendem a finalidades especificadas adscritas à tutela jurisdicional dos direitos. No entanto, existem várias matérias disciplinadas ao longo da parte especial que na verdade possuem aplicação geral: a disciplina dos recursos, por exemplo, obviamente tem caráter geral, nada obstante esteja inserida na parte especial.

Nada obstante, a necessidade de o Código ser visto como um sistema – ainda que em permanente reconstrução e mesmo em alguns casos, construção – faz com que a ligação entre a parte geral e a parte especial coloque-se não apenas no fluxo que pode ser visto pela lógica tradicional da parte geral para a parte especial, mas também em uma interdependência de sentido que atua igualmente na direção da parte especial para a parte geral. Com isso, as disposições da parte especial também têm o condão de colaborar na interpretação e aplicação do Código como um todo. Trata-se de exigência ligada à racionalidade do direito, especialmente no que tange à necessidade de coerência (art. 926, CPC).

NOTAS DE RODAPÉ

1

José Carlos Barbosa Moreira, “Os Códigos de Processo Civil de 1973 e de 1939: Contrastes e Confrontos”, *Estudos sobre o Novo Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Liber Juris, 1974, p. 49.

2

Franz Wieacker, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit*, 2. ed. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996, p. 486. Como observa Judith Martins-Costa, “a estruturação em uma Parte Geral e uma Parte Especial é devida aos pandectistas alemães do séc. XIX. Segundo informa Moreira Alves, primeiramente ela se encontra na segunda edição (1796) da obra *System der gesamten heutigen Civilrechts*, de Dabelow, de onde foi a ideia retirada por Gustav Hugo e, após, por Georg Arnold Heise, que dela se utilizou em 1807 em sua obra *Grundriss eines Systems des gemeinen Zivilrechts*, acabando por ganhar corpo no Código da Saxônia, de 1863, e, ao final do século, no BGB” (“O Novo Código Civil Brasileiro: em Busca da ‘Ética da Situação’”, *Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil Brasileiro*, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 95, nota de rodapé n. 31, em coautoria com Gerson Branco).

3

Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Oxford: Oxford University Press, 1996, p. 293-295; John Austin, *The Uses of the Study of Jurisprudence, The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence*, Indianapolis: Hackett, 1998, p. 367.

4

Miguel Reale, *História do Novo Código Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2005, p. 80.

5

Judith Martins-Costa, “O Novo Código Civil Brasileiro: em Busca da Ética da Situação”, *Diretrizes Teóricas do Novo Código Civil Brasileiro*, São Paulo: Saraiva, 2002, p. 96, em coautoria com Gerson Branco.

Comentários ao CPC - v. I - Marinoni - Ed. 2018

LIVRO I - DAS NORMAS PROCESSUAIS CIVIS

1. Das Normas Processuais Civis: da Constituição ao Código de Processo Civil. As normas processuais civis estão em primeiro lugar na Constituição. É lá que é tecida a trama mais firme que dá sustentação ao processo civil brasileiro.

A Constituição prevê o direito fundamental ao processo justo e os direitos fundamentais processuais que participam do seu conteúdo mínimo. O Livro I da Parte Geral do Código de Processo Civil, portanto, não reúne todas as normas processuais civis – apenas enuncia aquelas que devem ser vistas como os seus compromissos fundamentais, além de traçar diretrizes interpretativas e aplicativas.

Além do mais, os textos normativos formulados pelo legislador infraconstitucional devem ser lidos como verdadeiro “direito constitucional aplicado”¹. Se é verdade que o legislador tem o dever de dar tutela aos direitos, então o Código de Processo Civil deve ser visto como uma primeira tentativa de densificação desse dever constitucional.

2. Do Direito Fundamental ao Processo Justo e da sua Relação com as Normas Fundamentais do Processo Civil. Isso quer dizer que certas normas fundamentais do processo civil constituem *concretizações infraconstitucionais* de determinados direitos fundamentais processuais que compõem o direito fundamental ao processo justo (art. 5.º, LIV, CRFB) – é o caso dos arts. 2.º a 7.º e 9.º a 12, CPC. Outras normas fundamentais, visando assegurar uma adequada interpretação e aplicação do direito, explicitam postulados interpretativos e aplicativos – é o caso dos arts. 1.º, 8.º e 13 a 15, CPC.

É claro, no entanto, que nem as concretizações infraconstitucionais do direito fundamental ao processo justo e nem os postulados interpretativos e aplicativos deixam-se esgotar parte concernente às normas fundamentais do processo civil. Por exemplo: em conjunto, os arts. 16 e 42, CPC, concretizam o direito fundamental ao juiz natural; o art. 189, CPC, concretiza o direito fundamental à publicidade; o art. 489, §§ 1.º e 2.º, CPC, o direito fundamental à fundamentação das decisões; os arts. 322, § 2.º, e 489, § 3.º, CPC, concretizam o direito fundamental à segurança jurídica processual ao determinar a interpretação conforme a boa-fé; e o art. 926, CPC, concretiza o direito à unidade da ordem jurídica ao prever o dever de coerência das Cortes Supremas.

3. Do Direito Fundamental ao Processo Justo: da Necessidade de Leitura Conjunta com as Normas Fundamentais. Como as normas fundamentais do processo civil – e, mais propriamente, toda a legislação processual civil – constituem uma concretização do direito fundamental ao processo justo, impõe-se uma leitura constitucionalmente orientada das normas fundamentais do processo civil. Vale dizer: uma leitura das normas fundamentais tendo como pano de fundo o quadro normativo do direito fundamental ao processo justo. É claro que para tanto é necessário ter presente os seus principais traços.

3.1. Introdução. De forma absolutamente inovadora na ordem interna, nossa Constituição assevera que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (art. 5.º, inciso LIV). Com isso, institui o *direito fundamental ao processo justo* no direito brasileiro.

Embora de inspiração estadunidense notória, sendo nítida a sua ligação com a V e a XIV Emendas à Constituição dos Estados Unidos da América², certo é que se trata de norma presente hoje nas principais constituições ocidentais³, consagrada igualmente no plano internacional na Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948, arts. 8.º e 10), na Convenção Europeia dos

Direitos do Homem (1950, art. 6.º), no Pacto Internacional relativo aos Direitos Civis e Políticos (1966, art. 14) e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969, art. 8.º)⁴. O direito ao *fair trial*, não por acaso, constitui a maior contribuição do *Common Law* para a civilidade do Direito⁵ e hoje certamente representa o novo *jus commune* em matéria processual⁶.

O direito ao processo justo constitui *princípio fundamental* para organização do processo no Estado Constitucional. É o *modelo mínimo* de atuação processual do Estado e mesmo dos particulares em determinadas situações substanciais⁷. A sua observação é condição necessária e indispensável para obtenção de decisões justas⁸.

A Constituição fala em *devido processo legal* (*due process of law*). A expressão é criticável no mínimo em duas frentes. Em primeiro lugar, porque remete ao contexto cultural do *Estado de Direito* (*Rechtsstaat, État Légal*), em que o processo era concebido unicamente como um *anteparo ao arbítrio estatal*, ao passo que hoje o Estado Constitucional (*Verfassungsstaat, État de Droit*) tem por missão *colaborar na realização da tutela efetiva dos direitos mediante a organização de um processo justo*. Em segundo lugar, porque dá azo a que se procure, por conta da tradição estadunidense em que colhida, uma *dimensão substancial* à previsão (*substantive due process of law*), quando inexistente necessidade de pensá-la para além de sua *dimensão processual* no direito brasileiro⁹. Daí a razão pela qual prefere a doutrina falar em direito ao *processo justo* (*giusto processo, procès équitable, faire Verfahren, fair trial*) – além de culturalmente consentânea ao Estado Constitucional, essa desde logo revela o cariz puramente processual de seu conteúdo¹⁰.

O direito ao processo justo é um *modelo mínimo* de conformação do processo. Com rastro fundo na história e desconhecendo cada vez mais fronteiras, o direito ao processo justo é reconhecido pela doutrina como um modelo em *expansão* (tem o condão de *conformar* a atuação do legislador infraconstitucional – e não é por outra razão que o art. 1.º do CPC de 2015 sintomaticamente refere que o processo civil será “ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República”), *variável* (pode assumir *formas diversas*, moldando-se às exigências do direito material e do caso concreto) e *perfectibilizável* (passível de aperfeiçoamento pelo legislador infraconstitucional – que, não por acaso, explicitou o direito fundamental à colaboração no processo civil, art. 6.º, CPC, e atuou de forma firme na concretização do conteúdo do direito fundamental ao contraditório como direito de influência e dever de debate, arts. 9.º, 10 e 489, § 1.º, inciso IV, CPC)¹¹. Expansividade, variabilidade e perfectibilidade são características do direito ao processo justo que o tornam suscetível de concretização não só pelo legislador infraconstitucional, mas também pelo órgão jurisdicional.

3.2. Âmbito de Proteção. O direito ao processo justo é um direito de natureza *processual*. Ele impõe *deveres organizacionais* ao Estado na sua função *legislativa, judiciária e executiva*. É por essa razão que se enquadra dentro da categoria dos direitos à organização e ao procedimento¹².

A legislação infraconstitucional constitui um meio de densificação do direito ao processo justo pelo legislador. É a forma pela qual esse cumpre com o seu dever de organizar um processo idôneo à tutela dos direitos. Como já observado, nessa perspectiva as leis processuais não são nada mais, nada menos do que concretizações do direito ao processo justo.

O mesmo se passa com a atuação do Executivo e do Judiciário. A atuação da administração judiciária tem de ser compreendida como uma forma de concretização do direito ao processo justo. O juiz tem o dever de interpretar e aplicar a legislação processual em conformidade com o direito fundamental ao processo justo. O Estado Constitucional tem o dever de tutelar de forma efetiva os direitos. Se essa proteção depende do processo, ela só pode ocorrer mediante processo justo. No Estado Constitucional, o processo só pode ser compreendido como o meio pelo qual se tutela os direitos na dimensão da Constituição¹³ (art. 1.º, CPC).

O direito ao *processo justo* visa assegurar a obtenção de uma *decisão justa* (art. 6.º, CPC) e a viabilização de uma ordem jurídica pautada pela unidade (art. 926, CPC). Ele é o meio pelo qual se exerce *pretensão à justiça* (*Justizanspruch*) e *pretensão à tutela jurídica* (*Rechtsschutzanspruch*)¹⁴. O exercício da pretensão à tutela jurídica dá lugar à tutela dos direitos, que constitui o seu objetivo

central dentro do Estado Constitucional.

Não é possível definir em abstrato a cabal conformação do direito ao processo justo. Trata-se de *termo indeterminado*. O direito ao processo justo constitui *cláusula geral* – a norma prevê um termo indeterminado no seu suporte fático e não comina consequências jurídicas à sua violação¹⁵. No entanto, é possível identificar um “núcleo forte ineliminável”¹⁶, um “conteúdo mínimo essencial”¹⁷ sem o qual seguramente não se está diante de um processo justo. O direito ao processo justo conta, pois, com um *perfil mínimo*.

Em primeiro lugar, do ponto de vista da “divisão do trabalho” processual, o processo justo é pautado pela *colaboração* do juiz para com as partes¹⁸. *O juiz é paritário no diálogo e assimétrico apenas no momento da imposição de suas decisões*¹⁹ (art. 6.º, CPC). Em segundo lugar, constitui processo capaz de prestar *tutela jurisdicional adequada e efetiva* (art. 3.º, CPC), em que as partes participam em pé de *igualdade* e com *paridade de armas* (art. 7.º, CPC), em *contraditório* (arts. 9.º, 10 e 489, § 1.º, IV, CPC), com *ampla defesa*, com *direito à prova*, perante *juiz natural*, em que todos os seus pronunciamentos são *previsíveis, confiáveis e motivados* (art. 489, CPC), em procedimento *público* (arts. 11 e 189, CPC), com *duração razoável* (art. 4.º, CPC) e em, em sendo o caso, com direito à *assistência jurídica integral* e com formação de *coisa julgada* (art. 502, CPC).

Obviamente, o fato de o legislador infraconstitucional não ter indicado como norma fundamental do processo civil esse ou aquele direito fundamental processual – como, por exemplo, o direito à ampla defesa ou o direito à segurança jurídica processual – não lhe retira essa condição. Isso porque, embora se possam ver em várias normas fundamentais, concretizações do direito fundamental ao processo justo, certo é que semelhantes normas exprimem mais propriamente *compromissos fundamentais* do legislador na estruturação do processo civil.

A observância dos *elementos* que compõem o *perfil mínimo* do direito ao processo justo são os *critérios* a partir dos quais se pode aferir a *justa estruturação do processo*. *O processo justo depende da observância de seus elementos estruturantes*. A aferição da justiça do processo mediante a *verificação pontual* de cada um de seus elementos é *método* recorrente na jurisprudência²⁰. Trata-se de *meio objetivo* de controle de justiça processual.

3.3. Titularidade e Destinatários. O direito fundamental ao processo justo obriga o Estado Constitucional. Isso quer dizer que o Legislativo, o Judiciário e o Executivo são os seus *destinatários*. Eles têm o dever de atuar para densificação e viabilização do direito ao processo justo para que os seus *titulares* possam exercer as posições jurídicas a ele inerentes.

O seu primeiro destinatário é o legislador²¹. O legislador tem como tarefa concretizá-lo mediante a promulgação de normas processuais²². O administrador judiciário tem o dever de organizar estruturalmente o Poder Judiciário a fim de capacitá-lo a cumprir com a sua função de tutela jurisdicional efetiva dos direitos. O direito ao processo justo, portanto, também tem como destinatário o administrador. O juiz é obrigado a interpretar as normas em conformidade com o direito fundamental ao processo justo e, sendo o caso, tem inclusive o dever de densificá-lo *diretamente* (art. 5.º, § 1.º, CRFB)²³. Trata-se de comando cujo fundamento reside na necessidade de observar a *hierarquia* existente entre Constituição e legislação infraconstitucional²⁴.

Os *titulares* do direito fundamental ao processo justo são todos aqueles que são titulares do direito de ação e do direito de defesa. Vale dizer: todo aquele que tem personalidade processual – ou capacidade para ser parte – é titular do direito fundamental ao processo justo.

3.4. Eficácia. O direito ao processo justo goza de eficácia *vertical*, *horizontal* e *vertical com repercussão lateral*. O mesmo se diga de seus elementos estruturantes. Ele obriga o Estado Constitucional a adotar condutas concretizadoras do ideal de protetividade que dele dimana (eficácia vertical), o que inclusive pode ocasionar repercussão lateral sobre a esfera jurídica dos particulares (eficácia vertical com repercussão lateral)²⁵. Ainda, obriga os particulares, em seus processos privados tendentes a restrições e extinções de direitos, a observá-lo (eficácia horizontal).

O direito ao processo justo é *multifuncional*. Ele tem função *integrativa*, *interpretativa*,

bloqueadora e otimizadora ²⁶. Como princípio, exige a realização de um estado ideal de proteção aos direitos, determinando a *criação* dos elementos necessários à promoção do ideal de protetividade, a *interpretação* das normas que já preveem elementos necessários à promoção do estado ideal de tutelabilidade, o *bloqueio* à eficácia de normas contrárias ou incompatíveis com a promoção do estado de proteção e a *otimização* do alcance do ideal de protetividade dos direitos no Estado Constitucional²⁷.

Enquanto concretizações do direito fundamental ao processo justo, as normas fundamentais do processo civil contam com essas mesmas funções integrativa, interpretativa, bloqueadora e otimizadora. Em outras palavras, dada necessidade de pensar as normas fundamentais no quadro do direito fundamental ao processo justo, as mesmas eficácias associadas a um devem ser reconhecidas às outras.

4. Direito e Processo: Normas Materiais e Normas Processuais. Do ponto de vista funcional, o direito pode ser dividido em direito material e em direito processual. O direito material atribui bens às pessoas dentro da ordem jurídica mediante direitos, pretensões, deveres e exceções. O direito material depende para sua realização da adoção de comportamentos pessoais. O direito processual visa prevenir ou reprimir crises comportamentais de colaboração na realização do direito material.

Em regra, o direito material realiza-se independentemente da intervenção do direito processual. Por vezes, porém, podem surgir dúvidas a respeito do significado e da existência de determinados fatos, a respeito do significado de determinados dispositivos e do respectivo âmbito de aplicação que podem levar a diferentes visões a respeito de qual solução deve ser dada a um certo caso. Por vezes, inclusive, pode haver a pura e simples recusa na adoção do comportamento esperado pela ordem jurídica por uma das pessoas envolvidas em determinada situação jurídica.

Em todas essas situações é preciso valer-se do processo civil para saber quem tem razão ou para impor determinada solução ao caso. Entre direito material e direito processual existe, portanto, uma interdependência em termos de efetividade: sem o processo civil o direito material não tem condições de se impor para solução de conflitos sociais; sem o direito material o processo civil não tem razão de ser. É comum aludir-se à divisão direito material e direito processual também simplesmente como “direito” e “processo”²⁸.

5. Normas Heterotópicas. As normas de direito material encontram-se normalmente agrupadas em torno de institutos de direito material em documentos constitucionais e legais que tenham por função específica atribuir bens às pessoas dentro da ordem jurídica: o Código Civil e o Código Tributário Nacional são exemplos. As normas de direito processual civil encontram-se normalmente na Constituição, no Código de Processo Civil e na legislação extravagante de natureza processual.

No entanto, é possível que existam normas de natureza material no Código de Processo Civil, assim como é possível que existam normas processuais no Código Civil. Essas normas que se encontram deslocadas do seu próprio âmbito são chamadas de normas heterotópicas²⁹. Quando, de um lado, o Código Civil refere, por exemplo, que o negócio jurídico pode ser provado por determinados meios de prova (art. 212), esse obviamente está cuidando de matéria processual. De outro, quando o Código de Processo Civil institui, por exemplo, a regra da preferência pela tutela específica do direito em detrimento da tutela pelo equivalente monetário (arts. 497 a 499, CPC), esse igualmente está atuando em um âmbito que rigorosamente não é o seu: o direito à tutela do direito constitui assunto ligado ao direito material, nada obstante previsto heterotopicamente no Código de Processo Civil.

1

A expressão é amplamente empregada na doutrina alemã – por todos, pode-se conferi-la em Rudolf Wassermann, *Der soziale Zivilprozeß*. Neuwied und Darmstadt: Luchterhand, 1978, p. 20 (“*Zivilprozeßrecht als angewandtes Verfassungsrecht*”); na doutrina brasileira, Alvaro de Oliveira, “O Processo Civil na Perspectiva dos Direitos Fundamentais”, *Do Formalismo no Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 261 (com apoio em Hans Friedhelm Gaul e Rudolf Pollak).

2

Assim: i) “*Amendment V. No person shall be (,,) deprived of life, liberty, or property, without due process of law*”; ii) “*Amendment XIV. Section I. (...) nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law*”.

3

Assim, por exemplo: Itália, arts. 24 e 111; Espanha, art. 24; Alemanha, art. 103; Portugal, art. 20. Para um amplo desenvolvimento do tema na perspectiva comparada, Luigi Paolo Comoglio, *Etica e Tecnica del “Giusto Processo”*, Torino: Giappichelli, 2004.

4

Para consulta aos textos, Sérgio Mattos, *Devido Processo Legal e Proteção de Direitos*, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 17-25. Sobre o assunto, ainda, Marcelo Veiga Franco, *Processo Justo*, Belo Horizonte: Del Rey, 2016; Ronnie Preuss Duarte, *Garantia de Acesso à Justiça – Os Direitos Processuais Fundamentais*, Coimbra: Coimbra Editora, 2007. Para um amplo desenvolvimento do tema na perspectiva do direito internacional e comunitário europeu, Nicolò Trocker, *La Formazione del Diritto Processuale Europeo*, Torino: Giappichelli, 2011.

5

Arthur Goodhardt, “Legal Procedure and Democracy”, *Cambridge Law Journal*, 1964, p. 54.

6

Serge Guinchard, *Droit Processuel – Droit Commun et Droit Comparé du Procès Équitable*, 4. ed., Paris: Dalloz, 2007, p. 123.

7

Alvaro de Oliveira e Daniel Mitidiero, *Curso de Processo Civil*, São Paulo: Atlas, 2010, p. 27-28, vol. I.

8

Michele Taruffo, “*Idee per una Teoria della Decisione Giusta*”, *Sui Confini – Scritti sulla Giustizia Civile*, Bologna: Il Mulino, 2002, p. 224.

De um lado, é preciso perceber que os deveres de *proporcionalidade* e de *razoabilidade* não decorrem de uma suposta dimensão substancial do devido processo, como parece à doutrina (entre outros, Carlos Roberto Siqueira e Castro, *O Devido Processo Legal e os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade*, 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 212-214, e Nelson Nery Júnior, *Princípios do Processo na Constituição Federal*, 9. ed., São Paulo: Ed. RT, 2009, p. 83) e como durante bom tempo se entendeu na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (pode-se conferir completo exame do tema em Sérgio Mattos, *Op. Cit.*, p. 91-102). Mesmo no direito estadunidense semelhante entendimento não se configura correto (consulte-se a crítica profunda de Sérgio Mattos nesse sentido, *Op. Cit.*, p. 102-129). Os postulados da proporcionalidade decorrem dos princípios da liberdade e da igualdade – as posições jurídicas têm de ser exercidas de forma proporcional e razoável dentro do Estado Constitucional (Humberto Ávila, “O que é Devido Processo Legal?”, *Revista de Processo*, n. 163, São Paulo: Ed. RT, 2008, p. 50-59, n. 163). De outro, não é necessário recorrer ao conceito de *substantive due process of law* “com o objetivo de reconhecer e proteger direitos fundamentais implícitos” (é a proposta de Sérgio Mattos, *Op. Cit.*, p. 127, ao que parece encampada por Fredie Didier Júnior, *Curso de Direito Processual Civil*, 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2010, p. 48-49, vol. I), na medida em que nossa Constituição conta expressamente com um *catálogo aberto* de direitos fundamentais (art. 5.º, § 2.º), o que desde logo permite a consecução desse mesmo fim: reconhecimento e proteção de direitos fundamentais implicitamente previstos e mesmo não previstos na Constituição (conceito material de direitos fundamentais). Para crítica do devido processo legal substancial, consulte-se também Roberto Del Claro, “Devido Processo Legal Substancial?”, *Estudos de Direito Processual Civil – Homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão*, São Paulo: Ed. RT, 2005, p. 192-213.

10

Por exemplo, Alvaro de Oliveira, “Os Direitos Fundamentais à Efetividade e à Segurança em Perspectiva Dinâmica”, *Revista Forense*, vol. 395, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 35-51; Humberto Theodoro Júnior, “Constituição e Processo: Desafios Constitucionais da Reforma do Processo Civil no Brasil”, *Processo e Constituição – Os Dilemas do Processo Constitucional e dos Princípios Processuais Constitucionais*, Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010.

11

Italo Andolina e Giuseppe Vignera, *Il Modello Costituzionale del Processo Civile Italiano*, Torino: Giappichelli, 1997, p. 14-15.

12

Ingo Sarlet, *A Eficácia dos Direitos Fundamentais*, 10. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 194-198.

13

Luiz Guilherme Marinoni, *Curso de Processo Civil*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2008, p. 465, vol. I. A Constituição *precede* ao Estado Constitucional, organizando-o, outorgando as suas balizas de funcionamento (Ernst-Wolfgang Böckenförde, *Stato, Costituzione, Democrazia – Studi di Teoria della Costituzione e di Diritto Costituzionale*, a cura di Michele Nicoletti e Omar Brino, Milano: Giuffrè, 2006,

p. 596) e, também, os fins *sociais* que devem ser promovidos pela sua atuação.

14

Rosenberg, Schwab e Gottwald, *Zivilprozessrecht*, 17. ed., München: C.H. Beck, 2010, p. 14-16.

15

Para caracterização das cláusulas gerais, Judith Martins-Costa, *A Boa-Fé no Direito Privado*, São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 273-377.

16

Andrea Proto Pisani, “Giusto Processo e Valore della Cognizione Piena”, *Rivista di Diritto Civile*, Padova: Cedam, 2002, p. 267.

17

Luigi Paolo Comoglio, *La Garanzia dell’ Azione ed il Processo Civile*. Padova: Cedam, 1970, p. 156.

18

Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil – Pressupostos Sociais, Lógicos e Éticos*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015.

19

Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, cit.

20

A *Supreme Court* dos EUA, por exemplo, considera basicamente cinco questões para *testar* a justiça do processo: i) qual o tipo de notícia é requerido para o caso; ii) quando o contraditório deve ser efetivado – antes ou depois da restrição à esfera jurídica da parte; iii) qual a espécie de contraditório é requerido para o caso; iv) quem tem o ônus da prova e qual o standard probatório para formação do convencimento judicial; v) qual o juiz natural (*Mathews v. Eldrige*, 424 U.S. 319 (1976), sobre o assunto, Erwin Chemerinsky, *Constitutional Law – Principles and Policies*, 3. ed. New York: Aspen Publishers, 2006, p. 580-604).

21

Konrad Hesse, *Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha*, tradução de Luís Afonso Heck, Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998, p. 247.

22

Pedro Scherer de Mello Aleixo, “O Direito Fundamental à Tutela Jurisdicional Efetiva na Ordem Jurídica Brasileira – A Caminho de um ‘Devido Processo Proporcional’”, *Direitos Fundamentais e Direito Privado – Uma Perspectiva de Direito Comparado*, Coimbra: Almedina, 2007, p. 428.

23

Luiz Guilherme Marinoni, *Curso de Processo Civil*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2008, p. 117-120, vol. I; Daniel Mitidiero, *Processo Civil e Estado Constitucional*, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 91.

24

Antonio Enrique Pérez Luño, *Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución*, 9. ed., Madrid, Tecnos, 2005, p. 288.

25

Analogicamente, Luiz Guilherme Marinoni, *Curso de Processo Civil*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2008, p. 87, vol. I.

26

Humberto Ávila, “O que é Devido Processo Legal?”, *Revista de Processo*, n. 163, São Paulo: Ed. RT, 2008, p. 50-59.

27

Alvaro de Oliveira e Daniel Mitidiero, *Curso de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2010, p. 27, vol. I.

28

Francesco Carnelutti, *Diritto e Processo*, Napoli: Morano Editore, 1958, p. 33.

29

José Carlos Barbosa Moreira, O Código Civil e o Direito Processual, *Temas de Direito Processual*, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 2, Nona Série.

Comentários ao CPC - v. I - Marinoni - Ed. 2018**TÍTULO ÚNICO - DAS NORMAS FUNDAMENTAIS E DA APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS**

1. Da Jurisdição às Normas Fundamentais: uma Nova Perspectiva para o Processo Civil. A compreensão do processo civil na perspectiva do Estado Constitucional – e, portanto, dos direitos fundamentais processuais – é o pano de fundo que alimenta toda a interpretação e aplicação do processo civil atual (art. 1.º, CPC). A consciência do caráter cultural do processo civil e de seu íntimo relacionamento com a teoria do direito, com o direito material e com o direito constitucional evidenciam a necessidade de se pensar o processo civil a partir de uma renovada base teórica. Isto é, a partir de um caldo de cultura capaz não só de oferecer soluções constitucionalmente comprometidas com um ângulo interno de análise do processo (como, por exemplo, aquele ligado à equilibrada distribuição do trabalho entre o juiz e as partes – a que o princípio da colaboração procura oferecer uma resposta, art. 6.º, CPC), mas também com um ângulo externo (como, por exemplo, aquele ligado à técnica processual e à tutela dos direitos, arts. 6.º e 926, CPC)¹.

Um dos frutos mais evidentes dessa nova postura teórica está na abertura do Código de 2015. Vale dizer: na previsão de normas fundamentais como compromissos centrais do legislador para com a Justiça Civil². É sintomática essa abertura: se olharmos para a ZPO alemã, de 1877, e para o *Codice di Procedura Civile* italiano, de 1942, perceberemos que em ambos os casos o legislador principia tratando da jurisdição: a ZPO dedica o seu § 1.º à competência material dos tribunais (“*sachliche Zuständigkeit*”), ao passo que o *Codice* alude em seu art. 1.º à jurisdição (“*giurisdizione dei giudici ordinari*”). Se, porém, saltarmos no tempo, veremos que o *Nouveau Code de Procédure Civile* francês, de 1975, não inicia da mesma maneira: ele começa enunciando *princípios diretores do processo* (“*princípios directeurs du procès*”, artigos 1.º a 24). Se dermos mais um passo, a fim de “fecharmos”³ os Novecentos em termos de legislação processual civil, veremos que o legislador inglês de 1997 inicia declinando qual o seu *objetivo principal* (“*overriding objective*”, Rule 1.1).

Nosso Código de Processo Civil segue nesse particular esse último caminho: desde o início, o legislador entorna *normas fundamentais* que servem para densificar o direito ao *processo justo* previsto na Constituição (artigo 5.º, inciso LIV), dar as *linhas-mestras* que o estruturam e oferecer postulados interpretativos e aplicativos para sua atuação. Isso quer dizer que o Código de 2015 se desloca de uma perspectiva unilateral e estatal de compreensão do processo civil (a *jurisdição*) para uma que mais plural e capaz de conjugar as diferentes visões que marcam todos aqueles que participam do processo (as suas *normas fundamentais*).

NOTAS DE RODAPÉ

1

Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, 3. ed., cit., p. 50-51.

2

3

C. H. van Rhee, “The Development of Civil Procedure Law in Twentieth Century Europe: a Retrospective View”, *Direito Processual Comparado – XIII World Congress of Procedural Law*, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 623.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. I - Marinoni - Ed. 2018

CAPÍTULO I - DAS NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL

1. Do Significado das Normas Fundamentais do Processo Civil. As normas fundamentais do processo civil brasileiro constituem os *compromissos fundamentais do legislador* para com a Justiça Civil – em verdade, para com toda a Justiça não Penal (art. 15, CPC). O que as particularizam não é propriamente o fato de constituírem uma espécie de *direito processual fundamental* ou *direito processual geral*, aplicável ao processo em geral¹, mas sim o fato de consubstanciarem *opções-chave* por um determinado desenho normativo.

Também não existe nos arts. 1.º a 12, CPC, homogeneidade no que tange à espécie normativa: convivem a título de normas fundamentais princípios, regras e postulados (interpretativos e aplicativos)². Por exemplo: a boa-fé é um princípio (art. 5.º, CPC), a vedação à decisão-surpresa é uma regra (art. 10, CPC) e a proporcionalidade é um postulado (art. 8.º, CPC). Aliás, mesmo que se procurasse entender o conceito de princípio com um sentido fraco, isto é, como generalizações que visam a informar a atuação do legislador (isto é, como “*Prozeßmaximen*”³ ou como “*formative principles*”⁴).

O desenho traçado pelo legislador com as normas fundamentais revela um compromisso radical do processo civil com o Estado Constitucional. Em outras palavras, procura conceber um processo civil compatível com o ideal de protetividade dos direitos inerente à cláusula do Estado Democrático de Direito (art. 1.º, CRFB)⁵.

Como Estado Democrático, o Estado Constitucional preocupa-se em viabilizar um adequado exercício do *direito de participação* das partes em juízo (direito ao contraditório, arts. 9.º e 10, CPC), assegurando-se que os fundamentos de seus pedidos e requerimentos serão objeto de consideração e resposta pública pelo órgão jurisdicional (direito à fundamentação e direito à publicidade, arts. 11 e 489, CPC). Em outras palavras, procura instituir um *processo civil democrático*, aberto à participação das partes e sujeito a um amplo controle do poder no processo pelas partes, pelo próprio poder e pela sociedade civil⁶.

Como Estado de Direito, o Estado Constitucional preocupa-se em viabilizar um *processo civil seguro* (vedando a surpresa, art. 10, CPC, velando pela boa-fé, art. 5.º, CPC, e pela realizabilidade tempestiva dos direitos, arts. 4.º e 12, CPC⁷) e apto a promover a *liberdade* (com o chamado princípio da demanda, art. 2.º, CPC) e a *igualdade* (com o direito à igualdade, art. 7.º, CPC, com uma equilibrada distribuição do trabalho no processo civil a partir do princípio da colaboração, art. 6.º, CPC, e com a justiça multiportas, art. 3.º, cuja instituição responde à necessidade de consideração das diferentes necessidades de tutela evidenciadas pelos litígios).

Além disso, o legislador procura igualmente traçar postulados interpretativos e aplicativos para o processo civil. Esses postulados obviamente não são específicos do processo civil. No entanto, ganham um significado especial no contexto do Código de 2015, na medida em que permitem outorgar uma interpretação constitucionalmente adequada à legislação como um todo. Por exemplo: a previsão da dignidade da pessoa humana como cânone interpretativo (art. 8.º, CPC) significa que o processo civil deve ser pensado em uma perspectiva que privilegie a tutela dos direitos – os consumidores de justiça – e não em um plano que justifique soluções unicamente inspiradas na eficiência do aparato estatal.

2. Da Adequada Interpretação das Normas Fundamentais e da Função das Cortes Supremas mediante Recurso Extraordinário e Recurso Especial. Entre as normas fundamentais do processo

civil, alguns dispositivos apenas reproduzem o texto da Constituição, sem acréscimo de sentido, ao passo que outros claramente buscam densificar os direitos fundamentais que integram o direito ao processo justo, com acréscimo de texto e de sentido. Essa contingência – de *reprodução* e de *densificação* – coloca o problema da competência para a adequada interpretação das normas fundamentais pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quando estiver em causa o significado do direito fundamental tal como reproduzido ou densificado pelo Código, caberá recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça. É claro que a simples reprodução textual não deixa de ter uma conotação “simbólica”⁸ – essa circunstância, porém, não apaga o fato de que o seu encarte no sistema do Código faz com que o texto sofra influências dos demais dispositivos que o compõem, decorrendo daí a necessidade de sua leitura sistemática no plano da legislação infraconstitucional.

Quando, porém, estiver em causa eventual questionamento sobre a injusta proteção ao direito fundamental processual pelo Código (por ausência de proteção, proteção insuficiente ou retrocesso de proteção), caberá recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Isso porque aí o que estará em causa é a adequação da atuação do legislador infraconstitucional diante do comando constitucional. Em outras palavras: caberá ao Supremo Tribunal Federal pronunciar-se a respeito do acerto ou desacerto do legislador na densificação da Constituição.

Art. 1.º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código.

1. Processo Civil e Estado Constitucional. Em primeiro lugar, o art. 1.º, CPC, procura colocar em evidência a necessidade de se pensar o processo civil em uma perspectiva constitucionalizada⁹. Isso porque as relações entre o processo civil e a Constituição nem sempre foram óbvias. Não por acaso, é possível separar no mínimo três estágios dessa relação: um primeiro em que o processo civil era visto como um problema infraconstitucional; um segundo, que marca a sua primeira constitucionalização, em que era encarado apenas no plano das garantias constitucionais; e finalmente um terceiro, que marca a sua segunda constitucionalização, em que o processo civil é visto em toda a sua plenitude a partir da ótica dos direitos fundamentais¹⁰.

1.1. Do Processo Civil como um Problema Infraconstitucional. Até as primeiras décadas dos Novecentos, o direito constitucional poderia ser compreendido em geral como um *direito político* – o direito que cuida da *organização política* do Estado. A ideia de Constituição como elemento que *conforma a atuação do Estado* a partir dos *direitos individuais da pessoa humana* é mais recente e pode ser individualizada de maneira mais nítida somente desde o *constitucionalismo de valores* emergente do final da Segunda Guerra Mundial.

É natural, portanto, que o debate processual civil eventualmente existente a partir do encontro entre o direito constitucional e o direito processual civil no início dos Novecentos se limitasse a uma *perspectiva ligada tão somente ao funcionamento do Estado*. Nessa linha, por exemplo, a doutrina costumava limitar a ligação entre o processo civil e a Constituição a problemas concernentes à competência para legislar em matéria processual¹¹. Todas as demais questões referentes ao processo civil permaneciam apenas tratadas pela legislação infraconstitucional.

A relação que se percebia entre o processo civil e a Constituição nesse momento dizia respeito tão somente à atribuição de competência para legislar sobre o direito processual civil. A perspectiva de análise do tema era *puramente interna à organização da própria atividade estatal*.

1.2. Da Primeira Constitucionalização do Processo Civil. A experiência do totalitarismo e do gravíssimo desrespeito à pessoa humana emergente da Segunda Guerra Mundial provou ser inviável ao direito uma abordagem puramente estatista. Ao mesmo tempo, assinalou à Constituição e ao direito constitucional não só mais o papel de organização do Estado, mas de sua fundação a partir da pessoa humana. Vale dizer: a Constituição passou a se ocupar também com o reconhecimento de direitos e garantias ao cidadão, fundando o direito desde um *ponto de vista externo* ao próprio Estado.

Nessa mesma época, a doutrina começou a se preocupar com as relações entre o processo civil e a Constituição desde uma perspectiva diferente. De um *ângulo puramente interno ao Estado*, a relação evoluiu para reconhecer a necessidade de o direito de ação ser circundado por garantias mínimas a fim de evitar o arbítrio na atuação do Estado. Eis aí a *primeira constitucionalização do processo civil* – uma constitucionalização preocupada em fortificar o processo com garantias mínimas, deduzindo-as ora da existência de um Estado de Direito, ora da garantia de acesso à jurisdição¹².

A perspectiva de análise do tema deixa de ser *puramente interna* e passa a levar em consideração necessariamente a *pessoa*. O objetivo dessa primeira constitucionalização estava em reconhecer um *grau mais elevado de proteção ao processo civil*, capaz de proteger o seu núcleo-duro da atuação do legislador infraconstitucional, do administrador da justiça e do próprio órgão jurisdicional.

O denominador comum de todos os trabalhos produzidos nesse período de primeira constitucionalização está na construção de uma *sólida ancoragem* do processo civil na Constituição. O intuito é o de salvaguardar um núcleo mínimo de garantias processuais da atuação do Estado, colocando-as fora do alcance do constituinte, do legislador infraconstitucional, do administrador da justiça e do órgão jurisdicional. A ideia é impor limites à atuação do Estado¹³.

1.3. Da Segunda Constitucionalização do Processo Civil. O advento do Estado Constitucional – aí compreendido como uma fórmula eloquente capaz de sintetizar o Estado Democrático de Direito cujo principal compromisso é dar tutela os direitos na perspectiva dos direitos fundamentais – proporcionou à doutrina a oportunidade de dar um novo passo na constitucionalização do processo civil. Do binômio, *direitos e garantias*, passou a doutrina a falar em *direitos fundamentais* – e, em especial, a enxergar o direito ao processo justo e à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva, seu integrante ineliminável, como direito à organização de um processo justo, posição jurídica que tem como sujeito passivo o Estado Constitucional como um todo – o legislador infraconstitucional, o administrador da justiça e o órgão jurisdicional¹⁴.

As relações entre o processo civil e a Constituição certamente não encerram mais tão somente uma preocupação como a possibilidade de arbítrio estatal. A segunda constitucionalização do processo civil coloca o Estado na condição de meio para consecução de um processo justo. Vale dizer: antes de figurar como um inimigo, o Estado tem o dever de atuar para viabilização de um processo justo¹⁵.

Sem descurar da ideia de que o processo serve potencialmente de proteção contra o arbítrio do Estado, a segunda constitucionalização representa um momento em que a *nova teoria das normas* e a *metodologia dos direitos fundamentais* são incorporadas ao discurso processual civil. Vale dizer: de um lado, o processo civil passa a emprestar relevo à normatividade dos princípios, das regras e a reconhecer a aplicabilidade dos postulados normativos, trabalha com textos redigidos com termos jurídicos indeterminados e como cláusulas gerais, de outro, outorga importância à autoaplicabilidade dos direitos fundamentais, à proibição de proteção insuficiente, de proteção excessiva e de retrocesso na proteção dos direitos fundamentais, além de atentar para dimensão objetiva desses, cuja eficácia irradiante impõe o dever de interpretação da legislação de acordo com os direitos fundamentais¹⁶.

Isso quer dizer que a *segunda constitucionalização do processo civil* remete necessariamente à ideia de Estado Constitucional e, daí, à compreensão do processo a partir dos direitos fundamentais. O direito fundamental ao processo justo – *modelado* de acordo com a colaboração do juiz para com as partes e *estruturado* a partir das posições jurídicas mínimas que o compõem – constitui *um dos parâmetros essenciais* para aferição da *justiça da decisão* e da *unidade da ordem jurídica*, fins do processo civil no Estado Constitucional.

2. Ordenado, Disciplinado e Interpretado. O processo civil é direito constitucional aplicado e por essa razão tem que ser ordenado, disciplinado e interpretado conforme as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República. Na verdade, o processo civil deve ser interpretado a fim de que possa ser sistematizado (ordenado com unidade – isto é, possa ser

disciplinado) e aplicado conforme a Constituição.

Interpretar significa adscrever sentido a textos e a elementos não textuais da ordem jurídica. O objeto da interpretação é o texto ou algum elemento não textual da ordem jurídica (por exemplo, o costume). O resultado da interpretação é a norma¹⁷.

A atividade interpretativa é reconstrutiva, porque parte de significados existentes reconduzíveis aos textos que constituem o seu objeto. A interpretação exige um processo de identificação de sentidos, valoração entre sentidos concorrentes e decisão por um desses sentidos. Interpretar implica identificar, valorar e decidir.

Como a norma é o resultado da interpretação, é tecnicamente impossível qualquer aplicação normativa sem prévia interpretação. Nada obstante, é perfeitamente possível interpretação sem aplicação: a interpretação doutrinária é um exemplo claro de interpretação sem aplicação.

Enquanto a interpretação tem por objeto os textos, a aplicação tem por objeto as normas. Aplicar normas significa produzir efeitos jurídicos concretos sobre determinada situação jurídica. É pressuposto inarredável da aplicação a interpretação.

A interpretação e aplicação do processo civil deve levar em conta a Constituição (art. 1.º, CPC). Ao referi-lo, nosso Código explicita o postulado da interpretação conforme à Constituição, que deriva do postulado da supremacia da Constituição, segundo o qual todos os atos normativos “devem ter como critério de medida a constituição e os direitos fundamentais”¹⁸.

O postulado da supremacia da Constituição é composto de três postulados, segundo os quais é preciso interpretar a ordem jurídica promovendo-se: i) a “máxima eficácia e efetividade da Constituição”; ii) a “força normativa da Constituição”; e iii) a interpretação “conforme à Constituição”. Consoante o primeiro, é dever do intérprete preferir o sentido que assegure maior eficácia às normas constitucionais; o segundo, é dever do intérprete atualizar sempre que possível o programa constitucional, conferindo-lhe permanência; e o terceiro, preferir os sentidos constitucionais e mais especificamente conforme aos direitos fundamentais do que outros sentidos igualmente possíveis.

O fato de o art. 1.º, CPC, ter mencionado apenas a “interpretação conforme” não apaga a necessidade de o processo civil ser ordenado, disciplinado e interpretado levando em consideração o postulado – por assim dizer – guarda-chuva da supremacia da Constituição. O mesmo vale para os demais integrantes do postulado da supremacia da Constituição – os postulados da máxima eficácia e efetividade e da força normativa.

Art. 2.º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

1. Princípio da Demanda. No início dos Oitocentos a doutrina alemã cunhou a expressão “*Verhandlungsmaxime*” para designar – ao mesmo tempo – o direito da parte de propor a ação em juízo, definir o conteúdo do processo (o seu objeto litigioso) e ainda o de conduzi-lo, apresentando as provas pertinentes à apuração da verdade¹⁹. Em outras palavras, para apontar o domínio das partes (“*Parteiherrschaft*”) sobre a relação jurídica litigiosa, sobre o início, o desenvolvimento e o conteúdo do processo²⁰.

A justificativa encontrada pela doutrina para todas essas repercussões no plano do processo estava ancorada na natureza privada do direito debatido em juízo, a qual deveria implicar domínio das partes não só sobre o seu exercício, mas também sob a condução do processo²¹. Sendo privado o direito alegado em juízo, privada também deveria ser a condução do processo, sob pena de indevida restrição da liberdade das partes. Além disso, procurava-se ver na necessidade de se observar a “*Verhandlungsmaxime*” um modo de se preservar a imparcialidade do juiz – não por acaso, chegou-se a tentar traduzi-la no *Common Law* inglês como “*rule of neutrality*”²².

Entre o final dos Oitocentos e a primeira metade dos Novecentos, porém, a própria doutrina

alemã procurou distinguir os problemas ligados à propositura da ação e à definição do conteúdo do processo dos problemas concernentes à sua condução. Para se referir à liberdade inerente à propositura da ação e à definição do mérito da causa, a doutrina começou a falar em “*Dispositionsprinzip*”, reservando a expressão “*Verhandlungsmaxime*” somente ao problema ligado à sua condução – especificamente, para designar o princípio pelo qual a condução do processo compete às partes. Ao chegar nesse ponto, porém, a doutrina contrapôs à chamada “*Verhandlungsmaxime*” a “*Untersuchungsmaxime*”, justamente para apontar a solução pela qual a condução do processo pertence não às partes, mas ao juiz²³.

Como é sabido, a doutrina italiana da segunda metade dos Novecentos valeu-se amplamente dessa distinção. É notória, por exemplo, a proposta teórica que separa o “*principio dispositivo in senso sostanziale*” (o que a doutrina alemã hoje chama de “*Dispositionsprinzip*”²⁴ e a doutrina brasileira de princípio da demanda²⁵) do “*principio della trattazione*” (o que a doutrina alemã hoje chama de “*Verhandlungsmaxime*”²⁶ e a doutrina brasileira de princípio dispositivo²⁷)²⁸. O objetivo para tanto foi o mesmo que animou a doutrina alemã: distinguir o âmbito das questões concernentes à propositura da ação e à conformação do objeto litigioso do âmbito das questões ligadas à condução do processo.

Atualmente, costuma-se reconduzir ao chamado princípio da demanda o seguinte conteúdo: i) o processo civil começa por iniciativa da parte, sendo vedada a prestação de tutela jurisdicional de ofício (*nemo iudex sine actore* e *ne procedat iudex ex officio*); ii) a determinação do mérito da causa compete às partes; iii) a tutela jurisdicional deve ser congruente com o pedido; e iv) o processo civil pode ser extinto por desistência da ação, pelo reconhecimento do pedido, pela renúncia ao direito e pela transação²⁹. É fácil perceber, portanto, que o princípio da demanda se move no âmbito da “autonomia da vontade”, procurando-se preservar a “isonomia” e perseguir o “interesse público de bem administrar a justiça”³⁰. A simples leitura dos arts. 2.º, 141, 485, VIII, 487, III, 490 e 492, CPC, portanto, afiança claramente a sua positivação entre nós.

O processo civil começa por iniciativa da parte, sendo vedada a atuação do juiz de ofício (art. 2.º, CPC). Isso quer dizer que a concessão da tutela do direito depende da propositura da ação e da formulação do respectivo pedido.

Essa regra vale tanto para a concessão da *tutela satisfativa* como da *tutela cautelar*. Houve um tempo, é certo, em que se procurou legitimar a possibilidade de concessão de tutela cautelar de ofício pelo juiz. A premissa que estava por debaixo desse raciocínio, porém, hoje se encontra superada: partia-se do pressuposto de que a tutela cautelar não constituía propriamente uma tutela do direito, mas um simples instrumento para a proteção de outro processo. Em outras palavras, imaginava-se que a tutela cautelar não tutelava o direito material propriamente dito, limitando-se apenas a proteger o resultado útil do processo.

Sendo, porém, a tutela cautelar uma tutela do direito, que incide sobre o direito material, ainda que apenas para assegurar a sua realização futura, não há razão para excepcioná-la do princípio da demanda. A tutela cautelar não é uma simples técnica processual *instrumental* a outro processo; é uma tutela do direito *referível* a outro direito. A relação que se estabelece entre uma e outra é no plano do direito material, não no plano do processo.

A determinação do mérito da causa compete às partes (arts. 141, 319, III e IV, 336, 343 e 350, CPC). Isso quer dizer que os *atos jurídicos principais* – dos quais decorrem as consequências jurídicas pretendidas pelas partes – só podem ser conhecidos pelo juiz uma vez alegados. Há um ônus de alegação das partes. Obviamente, também os pedidos só podem ser apreciados uma vez formulados, havendo aí do mesmo modo ônus de alegação.

Todavia, a proibição de conhecimento de fatos pelo juiz por força do princípio da demanda não atinge os chamados *atos jurídicos secundários*, os quais podem ser livremente conhecidos pelo juiz. Fatos jurídicos secundários são aqueles que apenas levam ao conhecimento dos fatos jurídicos principais – e justamente por não implicarem qualquer disposição de direito no plano material não estão submetidos ao princípio da demanda³¹.

A sentença deve ser congruente com o pedido (arts. 490 e 492, CPC). Vale dizer: a tutela do direito deve ser aquela expressamente postulada pela parte. O princípio da demanda, porém, não impede que a *tutela específica* seja substituída de ofício pelo juiz pela *tutela pelo resultado prático equivalente* (arts. 497 e 498, CPC). Como há equivalência no plano do direito material entre as tutelas, não há que se falar em ofensa ao princípio da demanda: o demandante obterá em juízo aquilo que pretende no plano do direito material, nada obstante de forma diversa daquela por ele indicada.

O fato de o juiz poder variar a técnica executiva (arts. 139, IV, e 536 a 538, CPC) para prestação da tutela ao direito também não constitui ofensa ao princípio da demanda. A razão para tanto é ainda mais clara: a técnica executiva encontra-se no plano processual (isto é, é uma técnica processual), ao passo que o princípio da demanda diz respeito ao plano material (isto é, concerne à tutela do direito).

Por fim, o processo pode ser extinto porque a parte desistiu da ação proposta ou porque houve autocomposição entre as partes. Em ambos os casos, o princípio da demanda é que justifica esse domínio da parte, partindo-se do pressuposto de que as partes são as pessoas que melhor podem dimensionar “o voo mais conveniente na defesa de seus direitos”³².

É claro, porém, que semelhantes atos de disposição não têm o condão de impedir que a tutela do direito seja prestada quando essa estiver vocacionada não à viabilização de uma decisão de mérito justa e efetiva para o litígio (art. 6.º, CPC), mas quando se encontrar direcionada para a unidade da ordem jurídica (art. 926, CPC). Em outras palavras, quando as Cortes Supremas atuam para a unidade do direito, o fato de haver um ato de disposição das partes não impede a pronúncia da corte sobre a questão de direito – impede, apenas, que semelhante provimento possa alcançá-las. Como aí o processo civil não atua para o caso concreto, para tutela do direito da parte, mas apenas utiliza o caso concreto como um pretexto para outorgar significado ao direito, não há que se falar igualmente em ofensa ao princípio da demanda. Essa é a razão que se encontra por detrás do art. 998, parágrafo único, CPC – analogicamente aplicável a todos os atos de disposição.

2. Princípio Dispositivo e Princípio Inquisitório. A distinção entre o plano material e o plano processual – isto é, entre a técnica processual e a tutela do direito – que conduziu à separação entre o princípio da demanda e o princípio dispositivo viabilizou a percepção de que a condução do processo não deveria necessariamente estar entregue ao domínio exclusivo das partes. Vale dizer: também seria possível pensar em um processo conduzido pelo juiz. Nesse caso, o processo seria regido não pelo princípio dispositivo, mas pelo princípio inquisitório (*Untersuchungsmaxime*).

No entanto, esses princípios dificilmente conseguiram disciplinar o processo civil em toda a sua extensão de forma exclusiva³³. Em outras palavras, os legisladores de um modo geral procuraram sempre mesclar as iniciativas das partes e as iniciativas do juiz para dividir o trabalho no processo.

Seguindo essa linha, o processo civil brasileiro vale-se de ambos os princípios para estruturar os poderes do juiz e das partes. E mais: como deixa claro o art. 6.º, CPC, procura igualmente uma espécie de equilíbrio entre ambos a partir do princípio da colaboração.

O princípio dispositivo indica a necessidade de se respeitar a liberdade das partes na conformação do processo, no exercício de suas posições processuais e na prática dos respectivos atos processuais. Tendo em conta essa ligação umbilical entre a liberdade e o princípio dispositivo, parece-nos claro que o *autorregramento da vontade* não constitui propriamente um princípio autônomo do processo civil, situando-se antes perfeitamente no domínio temático do princípio dispositivo³⁴.

Várias são as manifestações do princípio dispositivo. As regras da liberdade da forma dos atos processuais³⁵ (art. 188, CPC) e do ônus da prova³⁶ (art. 373, CPC) são dois clássicos exemplos. No Código de 2015, porém, uma das mais abrangentes manifestações do princípio dispositivo está na ampla possibilidade de celebração de acordos ou convenções processuais (art. 190, CPC)³⁷ – um dos

ângulos mais privilegiados de visão das relações entre a liberdade e a autoridade no processo civil³⁸.

O princípio inquisitório aponta para a necessidade de se outorgar poderes ao juiz para a condução do processo. Em especial, procura-se sustentar essa necessidade a fim de que o processo civil tenha condições de tutelar efetivamente os direitos, não se deixando a sorte dos litígios apenas na eventual habilidade – maior ou menor – dos litigantes.

Também várias são as manifestações do princípio inquisitório no processo civil brasileiro. Sem dúvida alguma, a mais clássica dessas é aquela que outorga poderes instrutórios ao juiz (art. 370, CPC). Outras, porém, são igualmente relevantes, dentre as quais aquela que determina que o andamento do processo se dá por impulso oficial (art. 2.º, CPC) e que a condução do processo compete ao juiz (art. 139, CPC).

3. Impulso Oficial. Depois de afirmar que o processo civil começa por iniciativa da parte, positivando entre nós o chamado princípio da demanda, o legislador esclarece que o seu andamento não depende de um permanente impulso da parte (*“Parteibetrieb”*, *“party-prosecution”*), ocorrendo por impulso oficial (*“Offizialbetrieb”*, *“judicial prosecution”*)³⁹. Como o impulso oficial subtrai do controle das partes a marcha procedimental, consubstancia-se em uma manifestação do princípio inquisitório.

Nada obstante o procedimento avance por impulso oficial, velando o juiz pela sua duração razoável (arts. 5.º, LXXVIII, CRFB, e 4º, CPC)⁴⁰, existem situações em que se requer expressa manifestação das partes para que o processo possa se desenvolver. Se o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes (art. 485, II, CPC) ou se o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias por não praticar os atos que lhe incumbe (art. 485, III, CPC), a regra do impulso oficial não é capaz de impedir a extinção do processo sem resolução de mérito.

4. Exceções Legais. A regra é de que o juiz não proceda de ofício, isto é, não atue sem provocação da parte. Isso quer dizer que toda e qualquer possibilidade de o juiz agir de ofício deve estar devidamente autorizada em lei. São exemplos de exceções os arts. 485, § 3.º, e 487, II, CPC.

Art. 3.º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

§ 1.º É permitida a arbitragem, na forma da lei.

§ 2.º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3.º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

1. Direito de Ação como Direito à Tutela Adequada, Efetiva e Tempestiva. O direito de ação obviamente não constitui mais direito à sentença de mérito. No Estado Constitucional, o direito de ação só pode significar direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva.

O art. 3.º, *caput*, CPC, limita-se a reproduzir o art. 5.º, XXXV, CRFB. O legislador perdeu aqui uma oportunidade: poderia ter explicitado o significado do art. 5.º, XXXV, CRFB, referindo que a proibição da justiça de mão própria tem como contrapartida o direito de ação como direito à tutela adequada, efetiva e tempestiva dos direitos. Em seus parágrafos, porém, procura instituir claramente um sistema de justiça multiportas em nosso país, procurando adequar a prestação de justiça com as especificidades do direito material.

Ao proibir a justiça de mão própria e afirmar que a “lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5.º, XXXV, CRFB), nossa Constituição afirma a existência de *direito à tutela jurisdicional adequada e efetiva*. Nesse particular, como já observamos, o Código de 2015 limita-se a repeti-la. Obviamente, a proibição da autotutela só pode acarretar o dever do Estado Constitucional de prestar *tutela jurisdicional idônea aos direitos*. Pensar de forma diversa significa *esvaziar* não só o direito à *tutela jurisdicional* (plano do direito processual), mas também

o próprio direito material, isto é, o *direito à tutela do direito* (plano do direito material). É por essa razão que o direito à tutela jurisdicional constitui direito à “proteção jurídica efetiva”⁴¹ (*Recht auf effektiven Rechtsschutz, droit d'accès effectif à la justice, diritto alla tutela giurisdizionale effettiva*).

O direito à tutela jurisdicional é exercido mediante propositura de ação. A ação é direito à tutela adequada e efetiva mediante processo justo. Importa antes de qualquer coisa o ângulo teleológico do assunto. A rica literatura formada a respeito do *conceito de ação* na primeira metade dos Novecentos, principalmente na Itália, portanto, com o advento da *fundamentalização do direito de ação*, ganha novo significado – o *foco* é deslocado do *conceito* para o *resultado* propiciado pelo seu exercício. Vale dizer: a ação passa a ser teorizada como meio para prestação da tutela jurisdicional adequada e efetiva aos direitos⁴². Trata-se de direção oriunda da consciência de que “não basta declarar os direitos”, importando antes “instituir meios organizatórios de realização, procedimentos adequados e equitativos”⁴³, sem os quais o *direito* perde qualquer significado em termos de *efetiva atuabilidade*.

É nessa perspectiva que o Código de 2015 deve ser interpretado: o direito de ação implica direito a técnicas processuais adequadas, efetivas e capazes de outorgar tempestividade à tutela dos direitos. Reconhecida ao mesmo tempo como direito fundamental (art. 5.º, XXXV, CRFB) e como compromisso fundamental (art. 3.º, CPC), a previsão do direito de ação como direito à tutela adequada e efetiva – seja em uma perspectiva ligada às formas de justiça (justiça multiportas), seja em uma perspectiva ligada às técnicas processuais – constitui um dos pilares estruturais do processo civil brasileiro.

1.1. Tutela Adequada. A tutela jurisdicional tem de ser *adequada* para tutela dos direitos⁴⁴. O processo tem de ser *capaz de promover* a realização do direito material. O *meio* tem de ser idôneo à promoção do *fim*.

A adequação da tutela revela a necessidade de análise do direito material afirmado em juízo para somente a partir daí se estruturar um processo dotado de *técnicas processuais aderentes* à situação levada a juízo⁴⁵. A igualdade material entre as pessoas – e entre as situações substanciais carentes de tutela por elas titularizadas – só pode ser alcançada na medida em que se possibilite *tutela jurisdicional diferenciada* aos direitos⁴⁶. O processo tem de ser “*adequato allo scopo cui è destinato*”⁴⁷ a alcançar, o que significa que é “*insopprimibile*”⁴⁸ do campo da tutela jurisdicional a relação entre meio e fim, capaz de outorgar *unidade teleológica* à *tutela jurisdicional dos direitos*.

O direito à tutela jurisdicional adequada determina a previsão: i) de *procedimentos com nível de cognição apropriado* à tutela do direito pretendida⁴⁹; ii) de distribuição adequada do ônus da prova, inclusive com possibilidade de *dinamização e inversão*⁵⁰; iii) de *técnicas antecipatórias* idôneas a distribuir isonomicamente o ônus do tempo no processo, seja em face da *urgência*, seja em face da *evidência*⁵¹; iv) de *formas de tutela jurisdicional com executividade intrínseca*; v) de *técnicas executivas* idôneas⁵² e vi) de *standards para valoração probatória* pertinentes à natureza do direito material debatido em juízo⁵³. É dever do legislador estruturar o processo em atenção à necessidade de adequação da tutela jurisdicional.

Foi em atenção ao direito à tutela adequada, portanto, que o legislador distribuiu de forma fixa o ônus da prova (art. 373, *caput*, CPC), possibilitando, no entanto, a sua dinamização (art. 373, §§ 1.º e 2.º, CPC); que viabilizou a obtenção de tutelas provisórias com fundamento na urgência ou na evidência (arts. 294, 300 e 311, CPC); que previu as sentenças mandamental e executiva (arts. 536 a 538, CPC); e que previu a atipicidade da técnica executiva (art. 139, inciso IV, CPC). Previstas as técnicas processuais capazes de promover a adequação da tutela, é dever do juiz empregá-las para tanto.

É por força da necessidade de prestar tutela adequada aos direitos que não é possível ao Estado, por exemplo, *proibir a prestação de tutela antecipatória* indiscriminadamente. É ínsito ao Poder Judiciário o poder de prestar tutela antecipatória⁵⁴. No entanto, existem significativas restrições, no plano infraconstitucional, à concessão da tutela antecipatória contra a Fazenda Pública (art. 1.º, Lei 9.494/1997)⁵⁵. Essas restrições, contudo, não têm o condão de excluir o cabimento de antecipação

de tutela contra a Fazenda Pública. São inconstitucionais. Frise-se que o direito de ação, compreendido como o direito à técnica processual adequada, não depende do reconhecimento do direito material. O direito de ação exige técnica antecipatória para a viabilidade do reconhecimento da probabilidade do direito e do fundado receio de ilícito ou de dano, sentença idônea para a hipótese de sentença de procedência e meio executivo adequado a ambas as hipóteses. Se o direito não for reconhecido como suficiente para a concessão da antecipação da tutela ou da tutela final, não há sequer como pensar em tais técnicas processuais. A norma do art. 5.º, XXXV, CRFB, ao contrário das normas constitucionais anteriores que garantiam o direito de ação, afirmou que a lei, além de não poder excluir lesão, está proibida de excluir “ameaça de lesão” da apreciação jurisdicional. O objetivo do art. 5.º, XXXV, CRFB, nesse particular, foi deixar expresso que o direito de ação deve poder propiciar a tutela inibitória e ter a sua disposição técnicas processuais capazes de permitir a antecipação da tutela. A mesma leitura deve ser dada ao art. 3.º, CPC.

No STF existem *três correntes* em relação à interpretação do direito à tutela jurisdicional em caso de “ameaça a direito”. A primeira delas, afirmada especialmente pelos Ministros Celso de Mello e Carlos Velloso, sustenta que a lei que veda a concessão de liminares viola o art. 5.º, XXXV, CRFB, podendo ser expressa através da seguinte passagem do voto do Min. Celso de Mello na MC na ADI 223/DF: “a proteção jurisdicional imediata, dispensável a situações jurídicas expostas a lesão atual ou potencial, não pode ser inviabilizada por ato normativo de caráter infraconstitucional que, vedando o exercício liminar da tutela jurisdicional cautelar pelo Estado, enseje a aniquilação do próprio direito material”⁵⁶. A segunda, radicalmente oposta, pode ser captada a partir dos votos do Min. Moreira Alves. Disse o Ministro, na MC na ADI 223/DF: “o proibir-se, em certos casos, por interesse público, a antecipação provisória da satisfação do direito material lesado ou ameaçado não exclui, evidentemente, da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça a direito, pois ela se obtém normalmente na satisfação definitiva que é proporcionada pela ação principal, que, esta sim, não pode ser vedada para privar-se o lesado ou ameaçado de socorrer-se do Poder Judiciário”. Mais tarde, na MC na ADI 1.576/DF, o Ministro Moreira Alves consignou que, além de a lei poder vedar a concessão de liminares, “a tutela antecipada não é instituto constitucional. Ela foi criada pela lei. Assim como foi criada, a princípio, sem certos limites, não vejo por que não se possa limitá-la”⁵⁷. Por fim, a terceira posição, capitaneada pelo Min. Sepúlveda Pertence, enuncia que não é correto recusar constitucionalidade a toda e qualquer limitação legal à outorga de liminar, devendo a lei restritiva ser analisada segundo um critério de razoabilidade. Na já referida MC na ADI n. 223/DF, que teve por objeto a Medida Provisória que proibiu a concessão de liminar nas ações cautelares e nos mandados de segurança questionadores do Plano Econômico do Governo Collor, assim conclui o Min. Pertence: “a solução estará no manejo do sistema difuso, porque nele, em cada caso concreto, nenhuma medida provisória pode subtrair ao juiz da causa um exame da constitucionalidade, inclusive sob o prisma da razoabilidade, das restrições impostas ao seu poder cautelar, para, se entender abusiva essa restrição, se a entender inconstitucional, conceder a liminar, deixando de dar aplicação, no caso concreto, à medida provisória, na medida em que, em relação àquele caso, a julgue inconstitucional, porque abusiva”.

A posição do Min. Moreira Alves não merece guarida, uma vez que o direito fundamental de ação garante a efetiva tutela do direito material e, por consequência, a técnica antecipatória, imprescindível para permitir a antecipação da tutela e, dessa forma, dar efetividade à tutela inibitória – capaz de impedir a violação do direito – e, além disso, evitar a prática de ilícito e a ocorrência de eventual dano. Na verdade, a posição do Min. Moreira Alves encampa nitidamente a superada ideia de direito de ação como direito a uma sentença sobre o mérito. *A técnica antecipatória é imprescindível para dar proteção ao direito fundamental de ação. A sua supressão ou indevida limitação, assim, é flagrantemente atentatória à norma dos arts. 5.º, inciso XXXV, CRFB, e 3.º, CPC.* Por outro lado, a posição do Min. Pertence não distingue direito à técnica antecipatória de direito à obtenção da antecipação da tutela. É claro que não há direito à antecipação da tutela, uma vez que essa depende da constatação da probabilidade do direito e do perigo de ilícito ou de dano diante do caso concreto, os quais são pressupostos para a concessão da tutela antecipada com base nos art. 300, CPC. O Min. Pertence sustenta que a restrição à concessão de liminar pode se mostrar abusiva (e aí a lei ser considerada inconstitucional) em determinado caso concreto e não

em outro. Porém, como a abusividade da restrição diria respeito às necessidades presentes no caso concreto, a eventual inconstitucionalidade da lei dependeria da aferição dos próprios pressupostos à concessão da liminar ou da antecipação da tutela. *Acontece que, quando se penetra na verificação dos pressupostos da liminar, obviamente não se está perquirindo sobre a abusividade da restrição ao requerimento de liminar ou à aferição da sua concessão, mas sim se analisando se a liminar é necessária para tutelar o direito material.* Nessa situação, caso o juiz se convença de que a liminar não é imprescindível, a conclusão não será de que a lei restritiva é constitucional, mas sim de que a liminar não deve ser concedida em razão das particularidades da situação concreta. *Ocorre que, para que o juiz possa chegar à conclusão de que a liminar não deve concedida, ele necessariamente terá que admitir a inconstitucionalidade da lei.* O ponto chave, para a solução da questão, está em perceber que a lei “proíbe a própria aferição” dos pressupostos da liminar, embora se fale, por comodidade de linguagem, que a lei “proíbe a concessão” de liminar. *Uma lei que proíbe a aferição dos pressupostos necessários à concessão de liminar obviamente nega ao juiz a possibilidade de utilizar instrumentos imprescindíveis ao adequado exercício do seu poder.* E, ao mesmo tempo, viola o direito fundamental à *viabilidade* da obtenção da efetiva tutela do direito material. De modo que, entre as várias posições adotadas no STF, está correta a liderada pelo Min. Celso de Mello, para quem “o acesso à jurisdição, proclamado na norma constitucional de garantia, significa a possibilidade de irrestrita invocação da tutela jurisdicional cognitiva, da tutela jurisdicional executiva e da tutela jurisdicional cautelar do Estado”. *O direito à tutela antecipada decorre expressamente do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva e tem foro constitucional entre nós.* Pensar de modo diverso importa grave ofensa à adequação da tutela jurisdicional e à paridade de armas no processo civil (arts. 5.º, I, CRFB, e 7.º, CPC), sobre admitir-se que, quando ré a Fazenda Pública em processo judicial, pouco interessa à ordem jurídica a lesão ou a ameaça de lesão dos direitos dos particulares, lógica essa que é evidentemente contrária ao Estado Constitucional, fundado na dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III, CRFB) e preocupado com a efetiva tutela dos direitos (arts. 5.º, inciso XXXV, CRFB, e 3.º, CPC).

A *adequação da técnica executiva* é imprescindível para prestação da *tutela efetiva*. A efetiva atuabilidade da tutela do direito depende da previsão de *técnicas executivas idôneas*. Nesse particular, o direito processual civil brasileiro conta com um *sistema atípico*: como refere o art. 139, inciso IV, CPC, cumpre ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”⁵⁸.

A atipicidade da técnica executiva, que mais interessa para prestação de tutela jurisdicional adequada aos direitos, tem a sua maior expressão nos arts. 139, IV, 536 e 538, CPC. Para além da possibilidade de imposição de *astreintes* (art. 537, CPC), a tutela do direito pode ser concretizada mediante quaisquer “medidas necessárias” – busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial, são apenas exemplos. Nada obsta ao juiz, desde que *justificadamente* e com emprego da *proporcionalidade* (adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), que determine outras medidas, desde que promovam o fim, sejam o menos restritivas possíveis e prestigiem o direito constitucionalmente mais relevante⁵⁹. Entram sem dúvida na categoria de “medidas necessárias”, por exemplo, a suspensão do direito de dirigir⁶⁰, a suspensão do direito de contratar com o Poder Público e a imposição de prisão civil.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu pela *impossibilidade de prisão civil* no Brasil fora dos casos ligados à *prestação alimentar*. Notadamente, já decidiu pela impossibilidade de prisão civil do *depositário infiel* à luz do Pacto de São José da Costa Rica. Assim: “*Habeas Corpus*. Prisão Civil. Depósito Judicial. Revogação da Súmula n. 619/STF. A Questão da Infidelidade Depositária. Convenção Americana de Direitos Humanos (artigo 7.º, n. 7). Natureza Constitucional ou Caráter de Supralegalidade dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos? Pedido Deferido. Ilegitimidade Jurídica da Decretação da Prisão Civil do Depositário Infiel, ainda que se cuide de Depositário Judicial. Não mais subsiste, no sistema normativo brasileiro, a prisão civil por infidelidade depositária, independentemente da modalidade de depósito, trate-se de depósito voluntário (convencional) ou cuide-se de depósito necessário, como o é o depósito judicial. Precedentes. Revogação da Súmula 619/STF. Tratados Internacionais de Direitos Humanos: as suas

Relações com o Direito Interno Brasileiro e a Questão de sua Posição Hierárquica. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Art. 7.º, n. 7). Caráter subordinante dos tratados internacionais em matéria de direitos humanos e o sistema de proteção dos direitos básicos da pessoa humana. Relações entre o direito interno brasileiro e as convenções internacionais de direitos humanos (CF, art. 5.º e §§ 2.º e 3.º). Precedentes. Posição hierárquica dos tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento positivo interno do Brasil: natureza constitucional ou caráter de supralegalidade? Entendimento do Relator, Min. Celso de Mello, que atribui hierarquia constitucional às convenções internacionais em matéria de direitos humanos. A Interpretação Judicial como Instrumento de Mutação Informal da Constituição. A questão dos processos informais de mutação constitucional e o papel do Poder Judiciário: a interpretação judicial como instrumento juridicamente idôneo de mudança informal da Constituição. A legitimidade da adequação, mediante interpretação do Poder Judiciário, da própria Constituição da República, se e quando imperioso compatibilizá-la, mediante exegese atualizadora, com as novas exigências, necessidades e transformações resultantes dos processos sociais, econômicos e políticos que caracterizam, em seus múltiplos e complexos aspectos, a sociedade contemporânea. Hermenêutica e Direitos Humanos: a Norma mais Favorável como Critério que Deve Reger a Interpretação do Poder Judiciário. Os magistrados e Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio hermenêutico básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos), consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica. O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia o critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado), deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se palavras vãs. Aplicação, ao caso, do Artigo 7.º, n. 7, c/c o Artigo 29, ambos da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica): um caso típico de primazia da regra mais favorável à proteção efetiva do ser humano”⁶¹.

É fácil perceber, no entanto, que a *ratio decidendi* do julgado não infirma a possibilidade de *prisão civil como meio coercitivo* ou *como meio para tutela da autoridade do tribunal*. Seu cabimento não pode ser negado⁶². Observe-se que o art. 5.º, LXVII, CRFB, refere que “não haverá prisão por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel”. A interpretação dessa norma deve levar em consideração os direitos fundamentais. Assim, se é necessário vedar a prisão do devedor que não possui patrimônio – e assim considerar essa vedação um direito fundamental –, também é absolutamente indispensável permitir o seu uso, em certos casos, para a como técnica adequada para efetividade da tutela dos direitos. Há necessidade de estabelecer-se uma interpretação que leve em consideração todo o contexto normativo dos direitos fundamentais.

Nessa perspectiva, não há como deixar de interpretar a norma no sentido de que a prisão deve ser vedada quando a prestação depender da disposição de patrimônio, mas permitida para a jurisdição poder evitar – quando a multa coercitiva e as outras medidas para efetivação dos direitos não se mostrarem adequadas – a violação de um direito. Do contrário, várias situações substanciais podem ficar desprovidas de tutela adequada e efetiva. A prisão civil pode ser utilizada para impor um não fazer ou mesmo para impor um fazer infungível que não implique disposição de dinheiro e seja imprescindível à efetiva proteção de um direito. Nesses casos, ao mesmo tempo em que a prisão não estará sendo usada para constranger o demandado a dispor de patrimônio, ela estará viabilizando – no caso em que a multa e as demais medidas para efetivação das decisões judiciais não se mostrarem idôneas – a efetiva tutela do direito.

A prisão civil, depois de descumprida a ordem judicial, somente conserva caráter coercitivo no caso em que ainda se espera um fazer infungível, pois, no caso em que a ameaça de prisão objetiva um não fazer, a efetivação da prisão evidentemente não pode ter função coercitiva. Em

semelhante situação, a efetivação da prisão não tem caráter coercitivo, nem a função de castigar o réu, mas sim o objetivo de preservar a seriedade da função jurisdicional. A prisão civil, ordenada pelo próprio órgão jurisdicional da causa, somente tem cabimento no caso em que outra modalidade de efetivação das decisões não se mostrar adequada e o cumprimento da ordem não exigir a disponibilização de patrimônio. Assim, deve o juiz demonstrar na sua decisão que, para o caso concreto, não existe nenhuma outra técnica processual capaz de dar efetividade à tutela jurisdicional, além de demonstrar que o uso da prisão não importará na restrição da liberdade de quem não observou a ordem apenas por não possuir patrimônio. A própria decisão que ameaça de prisão a parte deve fixar o prazo de sua duração, considerando as circunstâncias do caso concreto. Dentro dessas coordenadas, a prisão civil estará garantindo a efetividade ao direito à tutela jurisdicional sem violar o direito daquele que, por não possuir patrimônio, não pode ser obrigado a cumprir a ordem judicial, nem muito menos punido por não a ter observado.

1.2. Tutela Efetiva. A tutela jurisdicional tem de ser *efetiva*. Trata-se de imposição que respeita aos próprios fundamentos do Estado Constitucional, já que é fácil perceber que a força normativa do Direito fica obviamente combalida quando esse carece de *atuabilidade* ⁶³. Não por acaso a *efetividade* compõe o princípio da *segurança jurídica* – um ordenamento jurídico só é *seguro* se há *confiança* na *realização* do direito que se *conhece*.

A efetividade da tutela jurisdicional diz respeito ao *resultado* do processo ⁶⁴. Mais precisamente, concerne à necessidade de o resultado da demanda espelhar o mais possível o direito material, propiciando-se às partes sempre *tutela específica* – ou *tutela pelo resultado prático equivalente* – em detrimento da *tutela pelo equivalente monetário* ⁶⁵. O direito à efetividade da tutela jurisdicional, portanto, implica necessidade: i) de encarar o processo *a partir do direito material* – especialmente, a partir da *teoria da tutela dos direitos* ⁶⁶ (arts. 139, IV e VI, 497 a 501, CPC) e ii) de viabilizar-se não só *tutela repressiva*, mas também e fundamentalmente *tutela preventiva* aos direitos ⁶⁷ (art. 497, parágrafo único, CPC).

É imprescindível para prestação de tutela jurisdicional efetiva a fiel identificação da tutela do direito pretendida pela parte. Vale dizer: é preciso em primeiro lugar olhar para o direito material a fim de saber-se qual a situação jurídica substancial que se pretende proteger judicialmente.

Durante muito tempo foi suficiente pensar em *tutelas repressivas contra o dano* para prestar tutela jurisdicional ⁶⁸. Ocorre que o aparecimento dos *novos direitos*, marcados em geral pela ideia de *inviolabilidade*, obrigou o Estado a reconhecer o direito à *tutela preventiva contra o ilícito*. Em outras palavras, determinou o reconhecimento do *direito à tutela inibitória*, capaz de prestar impedir a prática, a continuação ou a reiteração de um ilícito ⁶⁹. Daí ficou fácil à doutrina, na verdade, perceber a necessidade de pensar *todo o processo a partir do direito material* com o objetivo de promover a sua efetividade, propondo-se a estruturação do processo como um todo a partir do *direito à tutela específica* dos direitos.

Não é possível ao Estado *negar direito à tutela preventiva dos direitos*, isto é, *negar direito à tutela inibitória*. É *inconstitucional* qualquer posicionamento nesse sentido. Um Estado realmente preocupado com a *integridade* de sua ordem jurídica tem o dever de viabilizar tutela inibitória à parte que é dela carecedora.

A tutela jurisdicional pode ter por objetivo a proteção contra o *ilícito* ou contra o *dano*. Ato ilícito é ato contrário ao Direito. Fato danoso é prejuízo juridicamente relevante. São conceitos que não se confundem ⁷⁰. Nada obsta, inclusive, a que o mesmo processo viabilize tutela contra o ilícito e tutela contra o dano. A tutela contra o ilícito pode ser prestada de forma *preventiva* (*tutela inibitória*) ou de forma *repressiva* (*tutela de remoção do ilícito*, também conhecida como *tutela reintegratória*). A primeira visa impedir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito. É uma tutela voltada para o *futuro*. A segunda, a remover a causa de um ilícito ou os seus efeitos. É uma tutela voltada ao *passado*. A tutela contra o dano é sempre *repressiva*. Ela pressupõe a ocorrência do fato danoso. Ela pode visar à reparação do dano (*tutela reparatória*) ou ao seu ressarcimento em pecúnia (*tutela ressarcitória*).

Essa é a razão pela qual o art. 497, parágrafo único, CPC, procura deixar claro que o direito à

tutela contra o ilícito (tutela inibitória e tutela de remoção do ilícito) independem da demonstração de dano ou de dolo ou culpa. Quando o legislador refere que esses elementos são “irrelevantes”, o que ele quer dizer é que esses não podem compor o mérito da causa concernente à prestação da tutela contra o ilícito.

Aonde existe um direito existe igualmente direito à sua realização. Um direito é uma posição juridicamente tutelável. É da sua previsão que advém o direito à sua tutela – já que o fim do direito é a sua própria realização. *A previsão do direito pela ordem jurídica outorga desde logo pretensão à sua proteção efetiva.* Se a ordem jurídica prevê direito inviolável à imagem, honra, intimidade e vida privada, por exemplo, prevê no mesmo passo direito à tutela inibitória capaz de prevenir a sua ilícita violação, direito à tutela reintegratória para remover a fonte do ilícito ou seus efeitos e direito à tutela reparatória contra o dano experimentado. Na lição sempre lembrada da doutrina, “*il processo deve dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch’egli ha diritto di conseguire*”⁷¹.

No julgamento da ADPF n. 130/DF, no entanto, o STF concluiu de forma equivocada pela inexistência de direito à tutela inibitória para prevenir ilícita violação do direito envolvendo liberdade de imprensa⁷². *A tutela reparatória (direito de resposta e atribuição de responsabilidade), porque repressiva do dano e posterior à prática do ilícito, obviamente não é idônea para inibir a violação dos direitos de personalidade por ato ilícito da imprensa.* Há gravíssima confusão entre tutela repressiva e tutela preventiva no ponto. Ceifar de forma absoluta o direito à tutela inibitória diante da imprensa é o mesmo que afirmar *franca violabilidade* do direito à imagem, honra, intimidade e vida privada das pessoas, em aberto conflito à inviolabilidade outorgada pela Constituição à personalidade humana⁷³.

2. Da Jurisdição à Justiça Multiportas. No paradigma do Código Buzaid, a menção à tutela dos direitos remetia o intérprete imediatamente à tutela *jurisdicional* dos direitos, pressupondo-se a jurisdição como único meio possível – ou pelo menos como meio larguissimamente dominante – para solução de disputas judiciais. Nesse particular, o Código de 2015 promoveu uma “inversão dos paradigmas na justiça”⁷⁴, sendo apontada essa circunstância pela doutrina como uma das suas mais importantes e profundas inovações⁷⁵.

A razão para essa inversão decorre da necessidade de se reconhecer que a imposição de uma decisão pela via jurisdicional pode não ser, em determinados casos, o meio mais idôneo para solução de litígios. É por essa razão que o Código de 2015 reconhece que, muitas vezes, a forma jurisdicional pode não ser a mais adequada para a resolução da disputa: é por essa razão, portanto, que o seu art. 3.º, § 1.º, reconhece a arbitragem e que os seus §§ 2.º e 3.º declaram que é dever do Estado promover e estimular a solução consensual dos litígios. Como corretamente observa a doutrina, o “estímulo à solução consensual dos conflitos” converte-se em uma efetiva “política pública”⁷⁶.

É importante notar que o Código corretamente não alude à arbitragem, à conciliação e à mediação e a outros métodos como meios *alternativos*, mas simplesmente como *métodos de solução consensual de conflitos*. Embora tenham nascido como meios alternativos de solução de litígios (*alternative dispute resolution*), o certo é que o paulatino reconhecimento desses métodos como os meios mais idôneos em determinadas situações (como, por exemplo, a mediação para conflitos familiares, cuja maior idoneidade é reconhecida pelo próprio legislador, art. 694, CPC) fez com que se reconhecesse a necessidade de alteração da terminologia para frisar semelhante contingência. Em outras palavras: de métodos alternativos passaram a métodos adequados, sendo daí oriunda a ideia de que o sistema encarregado de distribuir justiça não constitui um sistema que comporta apenas uma porta, contando sim com várias portas (*multi-door dispute resolution*), cada qual apropriada para um determinado tipo de litígio⁷⁷.

2.1. Métodos Autocompositivos. O Código de 2015 tem como compromisso promover a solução consensual do litígio, sendo uma das suas marcas a viabilização de significativa abertura para a autonomia privada das partes – o que se manifesta não só no estímulo a que o resultado do processo seja fruto de um consenso das partes (art. 3.º, §§ 2.º e 3.º, CPC), mas também na

possibilidade de estruturação contratual de determinados aspectos do processo (negócios processuais, art. 190, CPC, e calendário processual, art. 191, CPC). O juiz dirigirá o processo com a incumbência de promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais (art. 139, V, CPC). Os conciliadores e mediadores judiciais são auxiliares do juízo cujas atribuições estão disciplinadas nos arts. 165 a 175, CPC. A Lei n. 13.140, de 2015, dispõe sobre a mediação.

A conciliação e a mediação são métodos de solução de litígios que não se confundem. Em ambos os casos há autocomposição, isto é, as partes chegam à própria solução para o litígio. No primeiro caso, porém, o terceiro participa de forma mais ativa na construção da solução do caso, podendo o conciliador sugeri-la para as partes. No segundo, o terceiro tem uma atuação mais discreta, na medida em que participa da solução do conflito como um facilitador do diálogo entre as partes.

2.2. Métodos Heterocompositivos. Ao lado da jurisdição, a ordem jurídica brasileira reconhece a possibilidade de pessoas capazes solucionarem seus litígios envolvendo direitos patrimoniais disponíveis mediante arbitragem (arts. 3.º, § 1.º, CPC, 1.º, Lei 9.397/1996). Ambas constituem métodos heterocompositivos de solução de litígios: um terceiro impõe determinada decisão para o conflito das partes, legitimado ora pela soberania estatal (jurisdição), ora pela autonomia da vontade das partes (arbitragem).

O Supremo Tribunal Federal entende que a previsão de arbitragem é constitucional: “Lei de Arbitragem (L. 9.307/96): constitucionalidade, em tese, do juízo arbitral; discussão incidental da constitucionalidade de vários dos tópicos da nova lei, especialmente acerca da compatibilidade, ou não, entre a execução judicial específica para a solução de futuros conflitos da cláusula compromissória e a garantia constitucional da universalidade da jurisdição do Poder Judiciário (CF, art. 5.º, XXXV). Constitucionalidade declarada pelo plenário, considerando o Tribunal, por maioria de votos, que a manifestação de vontade da parte na cláusula compromissória, quando da celebração do contrato, e a permissão legal dada ao juiz para que substitua a vontade da parte recalcitrante em firmar o compromisso não ofendem o artigo 5.º, XXXV, da CF. Votos vencidos, em parte – incluído o do relator – que entendiam inconstitucionais a cláusula compromissória – dada a indeterminação de seu objeto – e a possibilidade de a outra parte, havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, recorrer ao Poder Judiciário para compelir a parte recalcitrante a firmar o compromisso, e, conseqüentemente, declaravam a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 9.307/96 (art. 6.º, parág. único; 7.º e seus parágrafos e, no art. 41, das novas redações atribuídas ao art. 267, VII e art. 301, inciso IX do C. Pr. Civil; e art. 42), por violação da garantia da universalidade da jurisdição do Poder Judiciário. Constitucionalidade – aí por decisão unânime, dos dispositivos da Lei de Arbitragem que prescrevem a irrecorribilidade (art. 18) e os efeitos de decisão judiciária da sentença arbitral (art. 31)”⁷⁸.

Submetida determinada questão cuja solução deve ser arbitral ao Poder Judiciário por conta da existência de convenção de arbitragem, tem o interessado de arguir a existência de convenção na contestação (art. 337, X, CPC), sob pena de sua omissão implicar aceitação da jurisdição e renúncia ao juízo arbitral (art. 337, § 6.º, CPC). Tendo em conta a cláusula de convencionalidade processual atípica, nada obsta a que as partes insiram em contratos outra forma de arguir a exceção de convenção de arbitragem. É plenamente válida, por exemplo, a previsão contratual de necessidade de arguir a convenção em determinado prazo a contar da citação, sem necessidade de apresentação da contestação. Trata-se de providência que pode interessar às partes para resguardar eventual confidencialidade do negócio submetido à arbitragem.

Da decisão que rejeita no todo ou em parte a alegação de convenção de arbitragem cabe agravo de instrumento (art. 1.015, III, CPC). Da decisão que acolhe, extinguindo o processo, cabe apelação (art. 1.009, CPC).

Art. 4.º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

1. Direito Fundamental à Duração Razoável do Processo e aos Meios que a Garantam. O direito

de ação, numa concepção clássica, não é mais do que o direito à solução do litígio ou o direito a uma sentença sobre o mérito, seja ela de procedência ou de improcedência do pedido. Nessa dimensão, não há dúvida que o direito de ação fica muito distante do direito à duração razoável do processo.

Quando o direito de ação é compreendido como o direito às técnicas processuais idôneas à viabilidade da obtenção das tutelas prometidas pelo direito material⁷⁹, há aproximação do direito à duração razoável do processo. Isto porque quando se considera o direito à obtenção da tutela do direito material se toma em conta a sua “efetividade”, que também reclama “tempestividade”. Ao se deixar de lado a concepção clássica de direito de ação, atribui-se a este direito o significado de direito à tutela jurisdicional efetiva, inserindo-se no direito de ação o direito à tempestividade da prestação jurisdicional⁸⁰.

O inciso LXXVIII do art. 5.º da Constituição Federal, quando se refere ao direito à duração razoável do processo, expressa que este direito requer os meios que garantam a celeridade da sua tramitação. Assim, explicita-se que o direito à duração razoável exige prestações positivas do legislador, do administrador e do juiz.

Seria possível dizer que o conteúdo dessa explicitação estaria embutido no próprio direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva (art. 5.º, XXXV, CRFB), que, ao também garantir a tempestividade da tutela jurisdicional, obrigaria o legislador, o administrador e o juiz à prestação dos meios imprescindíveis à outorga de celeridade ao processo.

Não obstante, como a compreensão do direito de ação como direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva constitui um processo de aprendizagem e de maturação, não há como deixar de ver a importância do inciso LXXVIII, inserido no art. 5.º pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004. Essa é a mesma razão pela qual é importante destacar a sua previsão a título de compromisso fundamental do processo civil brasileiro (art. 4.º, CPC).

O direito à duração razoável é garantido por um postulado constitucional autônomo (inciso LXXVIII)⁸¹, tornando fora de dúvida o dever de o Estado dar tempestividade à tutela jurisdicional, mediante prestações do legislador, do administrador e do juiz. De outra parte, é preciso atenção para a circunstância de que o inciso LXXVIII fala em duração razoável do processo e não em celeridade da tutela jurisdicional do direito. Ou melhor: a norma não garante apenas tutela jurisdicional tempestiva ao autor, mas também confere ao demandado e à sociedade o direito à duração razoável do processo.

O réu também tem direito à celeridade do processo, embora o seu interesse não tenha a mesma qualidade do interesse do autor. O direito do demandado à celeridade do processo não pode ser extraído do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva ou ser visto como seu corolário. O direito do réu, mais do que exigir prestações positivas do Estado, tem a configuração de direito de defesa, constituindo uma garantia do cidadão contra o Estado, precisamente uma garantia de que não será submetido ao poder estatal – jurisdicional ou administrativo – por mais tempo que o necessário.

A sociedade, ou aqueles que não participam do processo como partes, igualmente tem o direito de ver os processos desenvolvidos em tempo razoável. Pense-se, nesta perspectiva, em primeiro lugar nas ações voltadas à tutela da coisa pública (ação popular) e à tutela dos direitos transindividuais (ação coletiva ou ação civil pública), e depois nas ações de improbidade e nos processos penal e eleitoral.

2. Destinatários do Direito Fundamental à Duração Razoável. O legislador é obrigado a dar proteção normativa ao direito fundamental à duração razoável em três dimensões. Deve editar normas com o fim de regular a prática dos atos processuais em prazo razoável. Assim, deve estabelecer prazos que realmente permitam a prática dos atos processuais (preparação da defesa, interposição de recurso, produção de provas etc.), inclusive considerando as dificuldades concretas das partes (prazo diferenciado para a Advocacia Pública)⁸², e fixar sanções preclusivas diante da não observância dos prazos. Deve ainda editar normas para viabilizar a distribuição do

ônus do tempo processual conforme as circunstâncias do caso concreto (art. 294 e ss., CPC), bem como reprimir mediante previsão de sanções a atuação protelatória das partes (arts. 77, IV, 80, IV e VII e 81, CPC).

A norma do art. 300 do CPC, relativa à tutela de urgência contra o perigo na demora, é exemplo de regra que viabiliza a obtenção da tutela jurisdicional de forma tempestiva, constituindo proteção imprescindível ao direito fundamental à duração razoável. Nesse sentido, mais claro ainda são o art. 311, que abre oportunidade à tutela de evidência, e o art. 356, que tornou fora de dúvida a cisão do julgamento do mérito conforme o instante em que a matéria de fato não mais necessita de prova para ser elucidada. Embora a cisão da definição do mérito tenha se tornado viável em 2002 mediante tutela antecipada (art. 273, § 6.º, CPC de 1973), agora foi corretamente delineada como hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito. Note-se que a norma não viabiliza a tempestividade da tutela jurisdicional em virtude de uma circunstância externa, como o perigo na demora, mas simplesmente regula a marcha processual, impondo a definição do mérito no momento em que parcela do litígio, para ser resolvida, não mais requer a atividade jurisdicional probatória. Afinal, o processo é, para a parte do litígio que restou incontroversa, não apenas inútil, como incompatível com o direito à tutela jurisdicional tempestiva, de modo que a possibilidade de cisão do julgamento do mérito é logicamente inseparável da noção de processo⁸³.

O legislador tem o dever de dar ao juiz o poder de distribuir o ônus do tempo do processo. Isto, é claro, pressupõe que o tempo seja compreendido como ônus, o que sequer é intuído pela doutrina processual tradicional. O tempo é visto pela doutrina clássica como algo neutro ou cientificamente não importante para o processo. Certamente por isso foi jogado nas costas do autor, como se esse fosse o culpado pela demora inerente à cognição dos direitos. Acontece que o tempo é uma necessidade do juiz, que dele precisa para formar a sua convicção, assim como uma necessidade democrática, advinda do direito de as partes participarem adequadamente do processo.

Ora, se o Estado tem o monopólio da jurisdição, o tempo para a distribuição da justiça somente pode ser problema seu e, deste modo, deve ser distribuído entre as partes para que o princípio da isonomia não reste ferido. A norma que permite a tutela da evidência (art. 311, CPC) constitui o fundamento para a distribuição do ônus do tempo do processo de acordo com a evidência do direito afirmado pelo autor e a fragilidade da defesa⁸⁴.

Sem tais normas o processo civil seria inconstitucional, por não viabilizar a realização do direito fundamental à duração razoável do processo e não tratar as partes de forma isonômica.

Como está claro, incumbe ao legislador traçar os procedimentos e as técnicas processuais idôneas a dar duração razoável ao processo. Para tanto, o legislador deve desenhar procedimentos especiais para determinadas situações, técnicas voltadas à aceleração do procedimento comum e ainda instituir regras processuais capazes de permitir à parte construir o procedimento adequado ao caso concreto⁸⁵. Nessa linha a incidência do direito fundamental à duração razoável sobre o legislador está expressa na segunda parte (os meios que garantam a celeridade de sua tramitação) do inciso LXXVIII do art. 5.º da Constituição Federal. Não obstante, não há como esquecer que duração razoável também significa duração idônea à prática dos atos processuais – e, assim, direito ao prazo adequado à preparação da defesa, por exemplo –, o que evidencia que não há apenas direito aos meios que garantam a celeridade da tramitação do processo, mas também direito aos meios que garantam a adequada participação no processo.

Ademais, tem o legislador o dever de dar às partes meios de controle das decisões judiciais que violem as normas processuais destinadas a dar proteção ao direito fundamental à duração razoável, assim como formas de controle das decisões que, sem atentar contra as regras infraconstitucionais, neguem diretamente o direito fundamental à duração razoável. Essa última hipótese pode ocorrer quando, não obstante a ausência de regra infraconstitucional, seja possível à parte demonstrar a omissão do legislador em proteger o direito fundamental.

Por fim, como a violação do direito fundamental à duração razoável pode trazer danos patrimoniais e não patrimoniais, o legislador tem o dever de instituir meios processuais capazes

de permitir o exercício da pretensão à tutela ressarcitória contra o Estado⁸⁶. Neste caso, torna-se importante estabelecer a competência para o julgamento da demanda ressarcitória. Não há racionalidade em dar a um juízo ou tribunal que apreciou a demanda em que ocorreu a violação do direito fundamental à duração razoável, ou que ordinariamente tem competência para apreciá-la, o poder de julgar a ação ressarcitória. Porém, isto não quer dizer que, enquanto não definida adequadamente a via e a competência para o exercício da pretensão ressarcitória, não possa o lesado exercitá-la, indicando o órgão competente de acordo com o sistema posto à luz da Constituição.

A questão temporal tem grande importância quando se está diante da tutela jurisdicional dos direitos. A jurisdição tem o dever de tutelar os direitos, fundamentais ou não. A tutela jurisdicional dos direitos é certamente indissociável da dimensão do tempo, pois tutelar de forma intempestiva equivale a não proteger ou a proteger de forma indevida.

Contudo, o juiz tem o dever de prestar a tutela jurisdicional em prazo razoável não somente para tutelar os direitos, mas igualmente para que o réu tenha um processo justo. Não é justo submeter o réu aos males da pendência processual por um prazo desrazoável.

É preciso combater os atos judiciais que dilatam o processo de forma não razoável⁸⁷. Tais atos podem ter natureza comissiva e omissiva. Assim, por exemplo, o juiz pode determinar a produção de prova sobre um fato incontrovertido ou impertinente, omitir-se em apreciar pedido de tutela de urgência ou de tutela de evidência ou deixar de analisar pedido de julgamento antecipado parcial do mérito.

Além disto, a dilação indevida pode decorrer de uma escolha equivocada, ou melhor, da escolha de uma técnica processual inidônea a dar a devida tempestividade à tutela jurisdicional. É o que ocorre, por exemplo, quando o juiz determina a execução da tutela antecipada de soma através das regras que servem à execução da sentença condenatória, desprezando a utilização da multa ou do desconto em folha ou de rendas periódicas.

O ato judicial, para importar em violação do direito fundamental, deve gerar “dilação injustificada”. A injustificativa da dilação é imanente ao ato comissivo ou equivocado – que determina a utilização de uma técnica processual em lugar de outra. Mas há maior dificuldade diante de dilação omissiva. Se não há como admitir a demora na análise de pedido de tutela de urgência, em relação a outras situações, como a da demora em realizar audiência de instrução, proferir sentença ou julgar um recurso, torna-se difícil estabelecer quando a demora é injustificada ou não razoável. Fala-se que a demora não é injustificada quando se equipara àquela que tem ocorrido em casos similares.⁸⁸ Esse raciocínio já chegou a ser utilizado pelo Tribunal Constitucional espanhol (STC 5/1985; STC 43/1985). Entretanto, entender que a duração é razoável quando se consome o tempo que em outros casos vem sendo gasto constitui pecado lógico, pois a prática reiterada do errado não o transforma em certo ou razoável. Note-se, por exemplo, que não é possível aceitar a demora derivada da substituição periódica de juízes, feita sem atenção a qualquer critério racional voltado à efetividade da distribuição da justiça.

De outro lado, a costumeira desculpa judicial de “acúmulo de trabalho”, se pode retirar a responsabilidade pessoal do magistrado pela demora do processo, constitui verdadeira confissão de que o Estado não está respondendo ao seu dever de prestar a tutela jurisdicional de modo tempestivo.

Em todos estes casos cabe invocar o direito fundamental à duração razoável, o que pode ocorrer quando a dilação está em curso ou já se consumou. A diferença é a de que, no caso em que a dilação está em curso, a parte terá que afirmar o direito fundamental à duração razoável no próprio processo em que a demora injustificada está ocorrendo, ao passo que, quando a demora não razoável se consumou causando dano, terá que ser proposta ação ressarcitória contra o Estado.

Frise-se que duração razoável, como o próprio nome indica, nada tem a ver com duração limitada a um prazo certo ou determinado. Se essa confusão fosse aceita, não se trataria de

“duração razoável”, mas de “duração legal” ou do simples dever de o juiz respeitar o prazo fixado pelo legislador para a duração do processo. O direito à duração razoável faz surgir ao juiz o dever de, respeitando o direito de participação adequada das partes, dar a máxima celeridade ao processo. E dar a máxima celeridade ao processo implica em não praticar atos dilatórios injustificados, sejam eles omissivos ou expressos.

Sublinhe-se, ainda, que o juiz tem o dever de controlar a constitucionalidade das regras processuais à luz do direito à duração razoável, podendo compatibilizá-las com este direito fundamental mediante o emprego da técnica da “interpretação conforme”.

Por fim, resta frisar que a jurisdição, para se desincumbir do seu dever de prestar a tutela jurisdicional de modo tempestivo, necessita de boa estrutura administrativa, ou seja, pessoal qualificado, tecnologia e material de expediente idôneos. Para tanto, o Poder Judiciário necessita de orçamento adequado. O Estado é obrigado a reservar parte da sua receita para dotar o Judiciário de forma a lhe permitir prestar a tutela jurisdicional de forma efetiva e célere.

Portanto, o direito fundamental à duração razoável exige do Executivo uma prestação de caráter econômico. O Executivo, diante deste direito fundamental, é gravado por um dever de dotação.⁸⁹

Por outro lado, quando a execução da sentença judicial depende da participação do Executivo, e esse deixa de colaborar sem justificativa para a efetivação da tutela jurisdicional do direito, a dilação indevida é da sua responsabilidade. Nesse caso, a prestação fático-administrativa do Executivo é imprescindível para a realização do direito fundamental à duração razoável.

3. Direito à Tempestividade da Tutela Jurisdicional, Direito ao Prazo Adequado e Direito de Não Ser Submetido ao Processo por Tempo Desnecessário. Direito à duração razoável não é sinônimo de direito à celeridade do processo, embora esta confusão possa decorrer, à primeira vista, da dicção da segunda parte do inciso LXXVIII, que fala em “meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Não há como pensar em duração razoável quando as partes não podem participar do processo de modo adequado. Note-se que não há aqui exclusiva preocupação com o réu, uma vez que não é apenas a defesa que depende de prazo hábil para a sua efetiva e real preparação. Os prazos devem permitir ao autor e ao réu a prática dos atos que estão localizados dentro do direito de influir sobre o convencimento judicial.

A parte não apenas tem o direito a prazo que lhe garanta tratamento isonômico diante do seu adversário (igual prazo para interpor e responder determinado recurso), mas sobretudo direito ao prazo que efetivamente lhe possibilite a prática do ato processual, independentemente deste ato estar inserido entre as posições processuais do autor ou do réu.⁹⁰

As partes têm, em virtude do direito à duração razoável do processo, o direito ao prazo adequado. Vincenzo Vigoriti, no direito italiano, extrai o direito ao prazo adequado do *due process*.⁹¹ Este direito também poderia ser relacionado com o contraditório, garantido na Constituição Federal brasileira no art. 5.º, LV, mas é inquestionável a sua derivação do direito à duração razoável do processo.

Além do direito à tempestividade da tutela jurisdicional e do direito ao prazo adequado, é necessário isolar o direito de o litigante não ser submetido ao processo, especialmente a atos processuais que interfiram na sua esfera jurídica, por tempo superior ao necessário.

Alguns atos jurisdicionais, como o que concede tutela cautelar, restringem a esfera jurídica da parte antes da solução definitiva do litígio. Como a tutela cautelar restringe o direito do demandado com base em juízo de verossimilhança, e por este motivo é essencialmente provisória, os seus efeitos não podem perdurar além do tempo necessário à proteção de segurança. A manutenção da tutela cautelar, além do indispensável ao alcance daquilo que foi pressuposto no momento da sua concessão, configura violação indisfarçável ao direito à duração razoável.

Portanto, o direito à duração razoável confere i) direito à tutela jurisdicional tempestiva, ii) direito ao prazo adequado para a prática dos atos processuais e iii) direito de não ter a esfera jurídica restringida por tempo superior ao devido. Não há como confundir direito à duração razoável com direito à celeridade do processo.

4. Duração Razoável do Processo e Técnicas de Aceleração e de Cognição: Procedimento Acelerado, Procedimento de Cognição Sumária e Procedimento de Cognição Parcial. Tanto o procedimento de cognição sumária quanto o procedimento acelerado são caracterizados pela brevidade, ambos permitindo uma tutela jurisdicional mais tempestiva do que a comumente outorgada. Mas o procedimento acelerado não pode ser confundido com o procedimento de cognição sumária. O procedimento de cognição sumária restringe o direito à produção das provas mais elaboradas, cujo tempo para produção é incompatível com aquele necessário à prestação da tutela urgente, conduzindo a uma decisão *fundada em probabilidade*. Já o procedimento acelerado pode limitar ou não a produção de provas, mas sempre culmina em sentença que, para definir o litígio, *não necessita de outras provas*.

Note-se que o procedimento caracterizado apenas pela aceleração dos atos processuais, praticados em espaço de tempo mais curto, não tem qualquer distinção, em termos de possibilidade de adequada cognição do objeto litigioso, em relação a um procedimento *formalmente* mais lento. Também há procedimento que, embora restrinja a produção de provas, não limita a cognição do litígio. É assim o procedimento do mandado de segurança, que não admite prova diferente da documental. Caso o litígio posto no mandado de segurança exija provas diferentes da documental, reserva-se ao autor a possibilidade de discuti-lo em procedimento em que a instrução probatória é plena.⁹²

O procedimento de cognição sumária, além de restringir a produção de prova, limita a cognição *aprofundada* do litígio e, assim, não pode permitir a formação de um juízo que não seja de verossimilhança, embora suficiente para legitimar sentença de procedência. No procedimento acelerado não há restrição ao direito à produção de prova, ao passo que, no procedimento de cognição sumária, as partes têm os seus direitos de produzir prova limitados em nome da necessidade de tutela jurisdicional urgente.

Contudo, além do procedimento de cognição sumária, há o procedimento de cognição parcial. No primeiro, diante da restrição à produção de provas, a cognição judicial é limitada no sentido vertical. No segundo, fica a parte proibida, em virtude de regra processual definidora do desenho do procedimento, de alegar e discutir determinadas defesas de direito material.

O procedimento de cognição parcial, assim como o procedimento de cognição sumária, almeja maior celeridade. A diferença é de que o procedimento de cognição parcial, ao buscar tempestividade, não abre mão da certeza, pois não se limita a um juízo de probabilidade ou de *fumus bonis iuris*. Este procedimento permite cognição exauriente sobre o mérito, mas afasta a cognição do juiz sobre a questão que a parte foi proibida de invocar.

O procedimento de cognição parcial conduz a uma sentença com força de coisa julgada material, em tempo inferior ao que seria gasto para o exame de toda a extensão da situação litigiosa, mas não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário a questão que não pode ser discutida, dita, então, “questão reservada”. Lembre-se que o Dec.-lei 3.365, de 21.6.1941, afirma que a contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço; e que qualquer outra questão somente poderá ser ventilada em ação própria (art. 20). Na ação de desapropriação, a lei proíbe a discussão de qualquer questão de direito material que não diga respeito ao preço. Porém, diante do direito à duração razoável, esta limitação obviamente não teria legitimidade caso o demandado não pudesse discutir as questões afastadas ou reservadas (o fundamento da desapropriação) mediante ação autônoma dirigida contra o Poder Público.

Mas não basta simplesmente admitir ação autônoma posterior para discutir a exceção afastada pelo legislador. Para se admitir a legitimidade da celeridade do procedimento que limita o âmbito de discussão da parte é preciso verificar se o seu fundamento está de acordo com a Constituição Federal. Não estando, há violação ao direito à duração razoável. A legitimidade da restrição das

alegações de defesa mediante as regras instituidoras do procedimento não se resolve a partir da verificação da possibilidade de o réu poder afirmar as alegações afastadas em ação autônoma, mas exige a aferição da racionalidade da inversão da oportunidade da alegação à luz das normas constitucionais⁹³.

5. Âmbito de Incidência do Direito Fundamental à Duração Razoável. O direito à duração razoável incide sobre todas as espécies de processos jurisdicionais e, inclusive, sobre o processo administrativo, como deixa claro o próprio inciso LXXVIII.

No processo civil, o direito à duração razoável incide de forma diferenciada, segundo o procedimento seja comum ou diferenciado. É claro que o tempo e, assim, a demora, não possuem a mesma significação em procedimentos diversos. Do mesmo modo, conforme as peculiaridades do procedimento diferenciado, a demora pode ter maior ou menor impacto.

Diante da natureza da tutela cautelar, por exemplo, o legislador resta obrigado a desenhar procedimento e a instituir técnica processual capazes de viabilizar a obtenção da tutela jurisdicional em prazo idôneo. Tal prazo deve guardar relação com a urgência inerente à natureza da tutela cautelar.

A urgência pode exigir a execução da tutela cautelar antes da ouvida do réu. Alega-se, neste caso, que uma situação substancial ameaçada por perigo de dano iminente e irreparável pode tornar necessárias medidas imediatas sem um completo esclarecimento da situação fática e recorda-se, ainda, que a omissão da audiência prévia do réu pode ser ditada pelo objetivo de não o colocar em condições de frustrar a eficácia prática do próprio provimento. A legitimidade destes motivos foi acolhida pelo *Bundesverfassungsgericht* alemão, que advertiu que, tratando-se de ingerência na esfera jurídica da parte, a derrogação ao princípio geral da audiência prévia somente pode ser admitida quando resultar indispensável para o alcance do escopo do provimento⁹⁴.

Lembre-se que a concessão da tutela cautelar, ao restringir a esfera jurídica do demandado, não pode perdurar além do tempo necessário à proteção de segurança. Caso isto aconteça o demandado estará sendo submetido a processo com tempo desrazoável. Se a execução de tutela cautelar *inaudita altera parte* pode ser necessária para assegurar a tutela do direito⁹⁵, a sua excepcionalidade decorre do fato de postergar o contraditório⁹⁶. Em nome da efetividade do contraditório, ao réu deve ser permitido demonstrar, com a maior brevidade possível, a eventual inexistência dos fundamentos que autorizaram a concessão da tutela cautelar e mesmo a sua impropriedade – por não representar a medida que produz a “menor restrição possível”.

Portanto, há razão para o legislador se preocupar em exigir a breve citação do réu (art. 302, II, CPC). Além de uma medida cautelar não poder permanecer eficaz por tempo superior ao suficiente à segurança, esta não pode causar um gravame despropositado ao réu e, portanto, deve obedecer à regra da “menor restrição possível”. Isto para não falar que o réu tem direito à substituição da medida cautelar por medida menos gravosa, bastando que seja suficiente para a tutela cautelar.

Se a efetivação da liminar antes da ouvida do réu, porque representa derrogação do princípio geral de audiência prévia, somente é admitida em casos excepcionais, a não citação do réu em prazo breve impede o réu de exercer o seu direito à substituição da medida cautelar, assim como lhe retira a possibilidade de requerer a modificação da tutela cautelar ou a aplicação da regra da menor restrição possível, o que torna excessivamente grave a postergação do contraditório.

A previsão de responsabilidade objetiva diante da não apresentação dos “meios necessários para a citação” (art. 302, II, CPC) é apenas um demonstrativo de que a regulação do procedimento deve estar atenta ao tempo em que o réu é submetido a uma decisão que restringe a sua esfera jurídica no curso do processo.

Por outro lado, a execução civil, dada a sua particularidade para a efetividade da tutela do direito material, também constitui um ponto muito sensível quando o processo é posto à luz do direito fundamental à duração razoável. A omissão dilatória na prática dos atos executivos impede

a tutela do direito no momento em que o direito já foi reconhecido, seja em decisão interlocutória – ao conceder tutela antecipatória – em sentença executável na pendência do recurso ou mesmo em sentença transitada em julgado. Por isto, a dilação omissiva na execução, especialmente no caso das tutelas jurisdicionais prestadas com base nos artigos 536 e 538, é facilmente caracterizável como demora injustificada.

6. Direito à Tempestividade da “Solução Integral do Mérito, Incluída a Atividade Satisfativa”. O direito à tempestividade constitui direito à tempestividade da tutela do direito. Vale dizer: interessa a realização do direito da parte. Essa é a razão pela qual o legislador explicita que o direito à duração razoável do processo necessariamente inclui a *atividade executiva* – expressão, aliás, que representa de forma mais técnica aquilo que o legislador quis dizer ao redigir o dispositivo.

6.1. A Sentença Condenatória não Constitui Tutela Jurisdicional do Direito. A ideia de que a condenação presta tutela jurisdicional ao direito é admitida pela doutrina, seja por aquela que classifica as sentenças apenas com base em critérios processuais, seja por aqueles que tentam classificar as sentenças, inclusive a condenatória, a partir do direito material.

Quem admite – a partir de visão exclusivamente processual – que a condenação é tutela jurisdicional, é obrigado a supor que a condenação basta para satisfazer o que se procura através da ação, sabido que a ação, como é inegável, deve proporcionar a tutela jurisdicional. Por outro lado, ao se tentar pensar na condenação a partir do direito material, não se consegue qualquer resultado positivo, uma vez que a condenação é incapaz de realizar o direito material ou prestar a tutela do direito.

Situação exemplar desta situação é a da doutrina de Pontes de Miranda, que em vão tenta identificar a condenação como o resultado da ação de direito material do credor. Segundo Pontes, “o direito processual tem de atender à eficácia das ações segundo o direito material”, sendo que, em sua concepção, “a ação de condenação supõe que aquele ou aqueles, a quem ela se dirige, tenham obrado contra o direito, que tenham causado dano e mereçam, por isso, ser condenados (*con-damnare*)”.⁹⁷ Porém, a ação de direito material não pode ter eficácia condenatória, uma vez que ninguém que tenha sofrido dano ou não recebido o pagamento de seu crédito tem direito material à condenação. A condenação é simples técnica processual, dando contornos a uma espécie de ação que nela finaliza, mas não serve à prestação da tutela jurisdicional do direito.

A perspectiva de direito material jamais poderia atrelar a ação à condenação, pois quem exerce a ação deseja a realização do direito, obtível por meio da execução. Já a perspectiva eminentemente processual, para se contentar com a condenação, vendo-a como tutela jurisdicional, foi obrigada a teorizá-la como título executivo, atribuindo-lhe a qualidade de autorizar a execução.

A doutrina clássica, mediante um exercício de abstração, desligou a prestação jurisdicional do direito material, tornando a condenação mera *fase* da tutela jurisdicional do direito, porém imprescindível à propositura da ação de execução ou à realização do direito de crédito.⁹⁸ É bom recordar que, para Liebman, a sentença condenatória tem conteúdo e função duplos, pois, além de declarar o direito existente, “faz vigorar para o caso concreto as forças coativas latentes da ordem jurídica, mediante aplicação da sanção adequada ao caso examinado – e nisto reside a sua função específica, que a diferencia das outras sentenças (função sancionadora)”.⁹⁹ Na concepção de Liebman, a sentença condenatória, ao aplicar a sanção, constitui a situação jurídica que abre oportunidade para a execução. Liebman demonstrou, de fato, que a condenação opera um fenômeno complexo e vasto, que consiste na constituição de uma nova situação jurídica, autônoma no que concerne à relação substancial obrigacional, fundada na concreta vontade do Estado de que a sanção executiva seja atuada, e que se resolve subjetivamente no poder do órgão processual de proceder à atuação da sanção executiva, no poder do credor de provocá-la (ação executiva) e na sujeição do devedor a suportá-la (responsabilidade executiva).¹⁰⁰

6.2. A Ação como Direito Capaz de Permitir a Obtenção da Tutela do Direito Material. Após a percepção de que a ação não se confunde com o direito material nela afirmado, o direito de ação

foi visto como direito a uma sentença de mérito, favorável ou desfavorável ao autor. Trata-se da ideia de ação ainda em voga entre a maioria dos processualistas, especialmente após Liebman ter dito que a ação, para existir, depende de condições. Lembre-se que, para Liebman, tais condições “são os requisitos constitutivos da ação”, sendo que, “na sua presença, esta deve ser considerada existente, *como direito a provocar o exame e a decisão do mérito*; depois, essa decisão poderá ser, conforme os resultados do processo, tanto favorável como desfavorável, no sentido de que o pedido poderá ser acolhido ou rejeitado e conseqüentemente a medida postulada poderá ser concedida ou negada”.¹⁰¹

Este conceito se mostrou insuficiente quando o direito de ação foi pensado como direito fundamental, incidente sobre o legislador e sobre o juiz, passando a significar um direito em exercício, ou melhor, o direito de influir sobre o convencimento judicial e o direito à utilização das técnicas processuais idôneas à obtenção da tutela do direito material. O direito de ação, quando visto no quadro dos direitos fundamentais, não pode ser resumido ao direito de ir a juízo, ao direito de acesso à justiça ou ao direito ao julgamento de mérito. O direito de ação é o direito de utilizar o processo para poder obter a tutela do direito, desde que, obviamente, o direito seja reconhecido em juízo.

As sentenças satisfativas – declaratória e constitutiva – são suficientes para satisfazer o autor ou outorgar a tutela jurisdicional do direito, mas a tutela do direito não é prestada pelas sentenças dependentes de execução, como a que determina a inibição do ilícito, a reintegração na posse, a remoção do ilícito ou a condenação ao pagamento de soma em dinheiro.

Se as sentenças dependentes de execução, ao contrário das sentenças satisfativas, não prestam a tutela jurisdicional do direito, é evidente que a ação que culmina em uma sentença que depende de atos de execução não presta a tutela do direito material. A antiga ação condenatória, única alternativa para quem desejava soma em dinheiro até meados de 2006, apesar de responder ao conceito tradicional de ação, pois garantia uma sentença de mérito, não viabilizava, por si só, a tutela do direito material. Isto é suficiente para fazer ver a diferença abismal *entre direito a uma sentença de mérito e direito à possibilidade de obtenção da tutela do direito material, o qual depende de um processo tecnicamente adequado e justo, capaz de espelhar o direito à preordenação das técnicas processuais adequadas e o direito à participação no procedimento, mediante a oportunidade de alegações e produção de provas, isto é, de convencimento do juiz*.

Aliás, quando se pensa no conceito contemporâneo de direito de ação, a falta de sintonia entre condenação e ação obriga a afastar, de uma vez por todas, as nomenclaturas que ligavam o direito de ação às técnicas processuais, como as espécies de procedimentos – por exemplo, ação *ordinária* – e de sentenças – por exemplo, ação *condenatória* – fazendo com que a ação passe a se relacionar com a sua única razão de ser, isto é, com a tutela do direito material.

Nesta dimensão, a ação, quando voltada à obtenção da tutela ressarcitória pelo equivalente, é ressarcitória e não condenatória. Ninguém que pretende ressarcimento pelo equivalente em dinheiro ou pagamento de obrigação pecuniária deseja somente condenação, até porque essa é apenas *uma das técnicas processuais* instituídas para que seja possível a obtenção da tutela do direito. Ao lado da condenação, estão predispostas, igualmente como técnicas processuais, a liquidação – através de suas diferentes espécies – e as várias modalidades executivas. *O que a ação realmente almeja, portanto, é a tutela do direito*, e assim, na hipótese referida, a tutela ressarcitória pelo equivalente ou a tutela do adimplemento da obrigação de pagar quantia.

6.3. Direito ao Meio Executivo Idôneo à Prestação da Tutela Jurisdicional em Prazo Razoável. O art. 4.o, quando alude a “direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”, simplesmente afirma o direito à tempestividade da obtenção da tutela jurisdicional do direito que depende de execução. Ora, quando a tutela do direito depende de execução é evidente que o autor tem direito à execução em prazo razoável. De modo que, além de o juiz ter o dever de evitar e sancionar dilações injustificadas na fase de execução, o legislador tem o dever de instituir meios executivos idôneos à obtenção da tutela do direito em prazo tempestivo.

O direito fundamental de ação garante a preordenação das técnicas processuais idôneas à

viabilidade da obtenção da tutela do direito material. *Não é por outra razão, aliás, que a ação não pode se exaurir na sentença condenatória transitada em julgado.* A ação almeja a tutela do direito, que pode depender da execução ou, mais precisamente, da idoneidade dos meios executivos. Assim, não há dúvida que o direito ao meio executivo idôneo é corolário do direito fundamental de ação, garantido no inciso XXXV do art. 5.º da Constituição Federal.

Se o direito ao meio executivo idôneo deriva do direito fundamental de ação, o direito ao meio executivo capaz de outorgar tempestividade à tutela do direito decorre do direito fundamental à duração razoável. *Significa dizer que a lei não pode instituir qualquer meio executivo, mas apenas os meios executivos idôneos e aptos a dar tempestividade à efetivação da tutela jurisdicional do direito*¹⁰². Nesta perspectiva, é fácil demonstrar, por exemplo, o equívoco em rejeitar a penhora *on-line* sob o argumento de que existem bens móveis ou imóveis que podem ser penhorados e o erro em concluir que a tutela antecipada de soma em dinheiro apenas pode ser executada mediante os meios que servem à execução da sentença condenatória. Essas interpretações não estão de acordo com o direito fundamental à duração razoável do processo. Aliás, esse direito fundamental deve presidir a compreensão das regras processuais sem permitir que, como é óbvio, seja pago o preço do direito de defesa.

7. Parâmetros para Aferição da Duração Razoável. Pressuposto para aferição da duração razoável do processo é a definição do seu *spatium temporis* – o *dies a quo* e o *dies ad quem* entre os quais o processo se desenvolve. O processo deve ser avaliado, para fins de aferição de sua duração, levando-se em consideração *todo o tempo em que pendente a judicialização do conflito entre as partes*. Isso quer dizer que a propositura de ação visando à concessão de *tutela cautelar preparatória* serve para fixação do *termo inicial*, assim como a atividade voltada à *execução do direito* também deve ser computada para determinação do *termo final*. A duração razoável do processo deve levar em conta o tempo para prestação da *tutela do direito* – acaso a parte autora se sagra vencedora – ou a simples prestação da *tutela jurisdicional* – acaso a parte autora sucumba ou seja prolatada decisão que extinga o processo sem resolução de mérito¹⁰³.

A jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos desenvolveu *critérios* para aferição da duração razoável do processo. Em sua primeira formulação, a Corte erigiu como critérios: i) a *complexidade* da causa; ii) o *comportamento das partes* e iii) o *comportamento do juiz* na condução do processo¹⁰⁴. Hoje, além desses três clássicos parâmetros, a Corte vem apreciando igualmente a razoabilidade da duração do processo a partir da *relevância do direito reclamado em juízo* para vida do litigante prejudicado pela duração excessiva do processo – critério da *posta in gioco*, que determina redobrada atenção do Estado nos casos em que o litígio versa sobre responsabilidade civil por contágio de doenças¹⁰⁵, *status* pessoal¹⁰⁶ e que ameacem a liberdade pessoal do réu no processo penal¹⁰⁷. Vale dizer: a *importância da decisão da causa na vida do litigante* adquire significativa importância para análise da razoabilidade da duração do processo¹⁰⁸.

Esses parâmetros são perfeitamente aplicáveis no direito brasileiro para fins de aferição da concretização do direito ao processo sem dilações indevidas. A complexidade da causa, sua importância na vida do litigante, o comportamento das partes e o comportamento do juiz – ou de qualquer de seus auxiliares – são critérios que permitem aferir racionalmente a razoabilidade da duração do processo.

Alguém poderia imaginar que o *comportamento inadequado da parte* que acarrete dilação indevida não gera direito à tutela reparatória por duração não razoável do processo por *ausência de nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano à parte*. Contudo, se a parte se comporta de forma inaceitável, gerando incidentes procrastinatórios, por exemplo, há responsabilidade do Estado. É preciso perceber que o juiz tem o dever de velar pela rápida solução do litígio, tendo de conduzir o processo de modo a assegurar a tempestividade da tutela jurisdicional. Daí que o juiz que se omite na repressão ao ato abusivo da parte *contribui* para dilação indevida, dando azo à responsabilização estatal.

8. Direito à Reparação por Violação do Direito à Duração Razoável. A violação do direito à duração razoável gera direito à *tutela reparatória*. A responsabilidade do Estado é pela *integralidade do dano* experimentado pela parte prejudicada pela duração excessiva do processo,

medindo-se a *reparação* pela sua *extensão* (art. 944, CC)¹⁰⁹.

Nada obsta à configuração de direito à reparação por *danos patrimoniais* e por *danos extrapatrimoniais* – por exemplo, por *danos morais* e por *danos à imagem* – em face da excessiva duração do processo¹¹⁰. A ação visando à indenização pela duração excessiva do processo segue o procedimento comum e deve ser proposta em primeiro grau de jurisdição. Pode ser proposta tanto contra a União, perante a Justiça Federal (art. 109, I, CRFB), se a responsabilidade pela condução do processo em que ocorreu a dilação indevida for de juízo federal (comum ou especializado), quanto contra o Estado, perante a Justiça Estadual (art. 125, CRFB), se a responsabilidade for de juízo estadual.

9. Duração Razoável do Processo e Economia Processual. O direito à tutela tempestiva implica direito à economia processual, na medida em que o aproveitamento na maior medida possível dos atos processuais já praticados – sem decretações de nulidade e repetições desnecessárias de atos – promove um processo com consumo equilibrado de tempo. Daí a razão pela qual se entende que a economia processual entra no núcleo duro do direito à tutela jurisdicional tempestiva¹¹¹.

Art. 5.º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

1. Boa-Fé. Houve um tempo em que se imaginou que o processo poderia ser caracterizado como um ambiente infenso à boa-fé (“*moralinfrei*”) – procurando-se inclusive afeiçoá-lo à guerra (“*Krieg*”) e à política (“*Politik*”)¹¹². Um solene compromisso contra esse modo de ver o processo civil pode ser visualizado no art. 5.º, CPC, na medida em que institui um dever geral de boa-fé no processo civil.

Seguindo uma tendência presente em quase todos os ordenamentos jurídicos¹¹³, a positivação da cláusula geral da boa-fé (“*bona fides*”, “*buona fede*”, “*Treu und Glaube*”, “*good faith clause*”, “*loyauté*”) no Código de 2015 pode ser compreendida no mínimo duas perspectivas distintas. Em uma perspectiva mais abrangente, a cláusula da boa-fé visa compor um determinado modelo de processo civil (o modelo cooperativo¹¹⁴, art. 6.º, CPC, permitindo que a igualdade e o contraditório floresçam em um ambiente confiável – e, portanto, seguro¹¹⁵). Em uma perspectiva mais restrita, a cláusula visa conformar o comportamento das partes com um compromisso de aderência à realidade e com a confiança no tráfego processual.

O Código de 2015 positiva tanto um dever de boa-fé subjetiva – medida por um “estado de consciência”, traduzindo um “convencimento individual de obrar em conformidade ao direito” – como um dever de boa-fé objetiva – dever de se comportar de modo aderente à realidade e capaz de despertar a confiança no tráfego processual. Enquanto a primeira remonta à canonística e à “primeira codificação” (o *Code* francês de 1804), a segunda pode ser reconduzida à “segunda codificação” (o BGB alemão de 1900) e à tradição dos países de *Common Law*.¹¹⁶ No Código, os arts. 79 a 81 tratam do dever de boa-fé subjetiva¹¹⁷, ao passo que o art. 5.º positiva a cláusula geral de boa-fé objetiva¹¹⁸.

Além de conformar o processo e as posições das partes (arts. 5.º, 6.º e 79 a 81, CPC), a boa-fé também desempenha uma função interpretativa¹¹⁹. Assim, a fim de tornar os limites do debate e da decisão bem demarcados (e, portanto, seguros, especialmente confiáveis), os arts. 322, § 2.º e 489, § 3.º, CPC, determinam que as postulações e a decisão da causa sejam interpretadas como um todo e de acordo com a boa-fé.

2. Boa-Fé Objetiva. Comporta-se com boa-fé aquele que não abusa de suas posições jurídicas. São manifestações da proteção à boa-fé no processo civil a *exceptio doli*, o *venire contra factum proprium*, a inalegabilidade de nulidades formais, a *supressio* e a *surrectio*, o *tu quoque* e o desequilíbrio no exercício do direito¹²⁰. Em todos esses casos há frustração à confiança ou descolamento da realidade, o que implica violação ao dever de boa-fé como regra de conduta.

A *exceptio doli* é a exceção que tem a pessoa para paralisar o comportamento de quem age dolosamente contra si. O *venire contra factum proprium* revela a proibição de comportamento

contraditório. Traduz o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente pelo exercente. Age contraditoriamente quem, dentro do mesmo processo, frustra a confiança de um de seus participantes. A inalegabilidade de vícios formais protege a boa-fé objetiva na medida em que proíbe a alegação de vícios formais por quem a eles deu causa, intencionalmente ou não, desde que por aí se possa surpreender aproveitamento indevido da situação criada com a desconstituição do ato. A *supressio* constitui a supressão de determinada posição jurídica de alguém que, não tendo sido exercida por certo espaço de tempo, crê-se firmemente por alguém que não mais passível de exercício. A *supressio* leva a *surrectio*, isto é, ao surgimento de um direito pela ocorrência da *supressio*. O *tu-quoque* traduz a proibição de determinada pessoa exercer posição jurídica oriunda de violação de norma jurídica por ela mesma patrocinada. O direito não pode surgir de uma violação ao próprio Direito ou, como diz o velho adágio do *Common Law*, “*equity must come with clean hands*”. A ideia de desequilíbrio no exercício do direito revela, em seu conjunto, o despropósito entre o exercício do direito e os efeitos dele derivados. Três são as manifestações do exercício desequilibrado do direito: o exercício inútil danoso, a ideia subjacente ao brocardo *dolo agit qui petit quod statim redditurus est* e a desproporcionalidade entre a vantagem auferida pelo titular do direito e o sacrifício imposto pelo exercício a outrem¹²¹.

A ausência de boa-fé leva à ineficácia do ato processual contrário à boa-fé e, em sendo o caso, à responsabilização por dano processual e inclusive à sanção pecuniária. Em outras palavras, o ato contrário à boa-fé é despido de eficácia, tendo que ser declarada a sua ineficácia por requerimento da parte ou de ofício pelo juiz (art. 139, inciso III, CPC). Se o ato contrário à boa-fé causou algum dano à parte, cabe a responsabilização da parte, seguindo-se a regra geral pela responsabilização pelo dano processual (arts. 79 e 81, CPC).

A declaração de ineficácia do ato processual contrário à boa-fé deve ser levada a cabo dentro do processo em que praticado o ato. O mesmo vale igualmente para a responsabilização por dano processual, cujo dimensionamento deve ser feito nos próprios autos (art. 81, § 3.º, *in fine*, CPC).

3. Qualquer Forma. Todos os participantes do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé: partes, advogados, membro do Ministério Público, da Defensoria Pública e juiz. Também aqueles que participam apenas episodicamente do processo também estão sujeitos ao dever de boa-fé processual.

Exemplos: se a parte penhora determinado bem do patrimônio do devedor, essa constrição não deve extrapolar a finalidade executiva que lhe é assinalada na legislação brasileira. Vale dizer: havendo a possibilidade de substituição da penhora por bem de idêntica graduação na ordem legal (art. 835, CPC) ou mesmo por bem de maior liquidez, a recusa injustificada por parte do exequente – quiçá para forçar um acordo lesivo – caracteriza exercício desequilibrado do direito. Se o juiz indefere o pedido de prova admissível formulado pelas partes, não pode julgar de forma imediata o pedido pela regra do ônus da prova (art. 355, CPC), na medida em que o pressuposto para o julgamento imediato é a existência de convencimento do juiz a respeito da veracidade ou falsidade das alegações de fato ou a inexistência de provas a serem produzidas.

Art. 6.º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

1. A Colaboração no Processo Civil. Problema central do processo está na sua equilibrada organização subjetiva¹²² – vale dizer, da “divisão do trabalho” entre os seus participantes¹²³. O modelo do nosso processo justo é o *modelo cooperativo* – pautado pela *colaboração* do juiz para com as partes¹²⁴. Como observa a doutrina, “*le procès équitable implique un principe de coopération efficiente des parties et du juge dans l’élaboration du jugement vers quoi est tendue toute procédure*”¹²⁵.

São basicamente dois os enfoques com que a colaboração pode ser observada no direito processual civil: como *modelo* e como *princípio*. O Código de 2015 encampou a colaboração com ambos os sentidos (art. 6.º)¹²⁶. A adequada construção do modelo cooperativo de processo e do princípio da colaboração que é a ele inerente servem como linhas centrais para organização de um

processo civil que reflita de forma efetiva os pressupostos culturais do Estado Constitucional. A colocação da colaboração nesses dois patamares visa destacar, portanto, a necessidade de entendê-la como o *eixo sistemático* a partir do qual se pode estruturar um processo justo do ponto de vista da divisão do trabalho entre o juiz e as partes no processo civil.

Não por acaso, constitui uma tendência do processo civil atual¹²⁷, assinalando a doutrina a sua previsão como uma das mais profundas novidades textuais do Código de 2015¹²⁸. A propósito, também essa é a percepção do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema: “Processual Civil. Previdenciário. Julgamento *Secundum Eventum Probationis*. Aplicação do Art. 10 do CPC/2015. Proibição de Decisão Surpresa. Violação. Nulidade. 1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. 2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. 4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 5. O novo sistema processual impõe aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC. 6. A proibição de decisão-surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. 7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espalhados pelo Código. 8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente “sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 209). 9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de legitimação decisória. 10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de abrir oitiva das partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, §4º, da LEF, e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. 11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório

dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica *error in procedendo* e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. 12. *In casu*, o Acórdão recorrido decidiu o recurso de apelação da autora mediante fundamento original não cogitado, explícita ou implicitamente, pelas partes. Resolveu o Tribunal de origem contrariar a sentença monocrática e julgar extinto o processo sem resolução de mérito por insuficiência de prova, sem que as partes tenham tido a oportunidade de exercer sua influência na formação da convicção do julgador. Por tratar-se de resultado que não está previsto objetivamente no ordenamento jurídico nacional, e refoge ao desdobramento natural da controvérsia, considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão surpresa, posto não terem as partes obrigação de prevê-lo ou advinha-lo. Deve o julgado ser anulado, com retorno dos autos à instância anterior para intimação das partes a se manifestarem sobre a possibilidade aventada pelo juízo no prazo de 5 (cinco) dias. 13. Corroborando a pertinência da solução ora dada ao caso o fato de a resistência de mérito posta no Recurso Especial ser relevante e guardar potencial capacidade de alterar o julgamento prolatado. Apesar da analogia realizada no julgado recorrido com precedente da Corte Especial do STJ proferido sob o rito de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.352.721/SP, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 28/4/2016), a extensão e o alcance da decisão utilizada como paradigma para além das circunstâncias ali analisadas e para ‘todas as hipóteses em que se rejeita a pretensão a benefício previdenciário em decorrência de ausência ou insuficiência de lastro probatório’ recomenda cautela. A identidade e aplicabilidade automática do referido julgado a situações outras que não aquelas diretamente enfrentadas no caso apreciado, como ocorre com a controvérsia em liça, merece debate oportuno e circunstanciado como exigência da cooperação processual e da confiança legítima em um julgamento sem surpresas. 14. A ampliação demasiada das hipóteses de retirada da autoridade da coisa julgada fora dos casos expressamente previstos pelo legislador pode acarretar insegurança jurídica e risco de decisões contraditórias. O sistema processual pátrio prevê a chamada coisa julgada *secundum eventum probationis* apenas para situações bastante específicas e em processos de natureza coletiva. Cuida-se de técnica adotada com parcimônia pelo legislador nos casos de ação popular (art. 18 da Lei 4.717/1965) e de Ação Civil Pública (art. 16 da Lei 7.347/1985 e art. 103, I, CDC). Mesmo nesses casos com expressa previsão normativa, não se está a tratar de extinção do processo sem julgamento do mérito, mas de pedido julgado “improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova” (art. 16, ACP). 15. A diferença é significativa, pois, no caso de a ação coletiva ter sido julgada improcedente por deficiência de prova, a própria lei que relativiza a eficácia da coisa julgada torna imutável e indiscutível a sentença no limite das provas produzidas nos autos. Não impede que outros legitimados intentem nova ação com idêntico fundamento, mas exige prova nova para admissibilidade *initio litis* da demanda coletiva. 16. Não é o que se passa nas demandas individuais decididas sem resolução da lide e, por isso, não acobertadas pela eficácia imutável da autoridade da coisa julgada material em nenhuma extensão. A extinção do processo sem julgamento do mérito opera coisa julgada meramente formal e torna inalterável o *decisum* sob a ótica estritamente endoprocessual. Não obsta que o autor intente nova ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, inclusive com o mesmo conjunto probatório, e ainda assim receba decisão díspar da prolatada no processo anterior. A jurisdição passa a ser loteria em favor de uma das partes em detrimento da outra, sem mecanismos legais de controle eficiente. Por isso, a solução objeto do julgamento proferido pela Corte Especial do STJ no REsp 1.352.721/SP recomenda interpretação comedida, de forma a não ampliar em demasia as causas sujeitas à instabilidade extraprocessual da preclusão máxima. 17. Por derradeiro, o retorno dos autos à origem para adequação do procedimento à legislação federal tida por violada, sem ingresso no mérito por esta Corte com supressão ou sobreposição de instância, é medida que se impõe não apenas por tecnicismo procedimental, mas também pelo efeito pedagógico da observância fiel do devido processo legal, de modo a conformar o direito do recorrente e o dever do julgador às novas e boas práticas estabelecidas no Digesto Processual de 2015. 18. Recurso Especial provido”¹²⁹.

2. Como Modelo: o Processo Civil como uma Comunidade de Trabalho. A colaboração é um *modelo* que visa organizar o papel das partes e do juiz na conformação do processo, estruturando-o como uma verdadeira *comunidade de trabalho* (*Arbeitsgemeinschaft*), em que se privilegia o *trabalho processual em conjunto* do juiz e das partes (*prozessualen Zusammenarbeit*)¹³⁰. Em outras palavras: visa dar feição ao formalismo do processo, dividindo de forma *equilibrada* o trabalho entre todos os seus participantes. Como modelo, a colaboração rejeita a *jurisdição* como polo metodológico do processo civil, ângulo de visão evidentemente unilateral do fenômeno processual, privilegiando em seu lugar a própria ideia de *processo* como centro da sua teoria¹³¹, concepção mais pluralista e consentânea à feição democrática ínsita ao Estado Constitucional¹³².

Semelhante modelo processual resulta da *superação histórica* – e, pois, cultural – dos modelos de *processo isonômico* e de *processo assimétrico*¹³³. Há quem caracterize a cooperação, ainda, a partir das conhecidas linhas do *processo dispositivo* e do *processo inquisitório*¹³⁴. Seja qual for a perspectiva, é certo que a análise histórico-dogmática da *tradição* processual mostra o rastro pelo qual se formou e ganhou corpo a colaboração no nosso contexto processual.

A colaboração é um modelo que se estrutura a partir de *pressupostos culturais* que podem ser visualizados sob os ângulos *social*, *lógico* e *ético*¹³⁵.

Do ponto de vista social, o *Estado Constitucional de modo nenhum pode ser confundido com o Estado-Inimigo*. Nessa quadra, assim como a sociedade pode ser compreendida como um empreendimento de cooperação entre os seus membros visando à obtenção de proveito mútuo¹³⁶, também o Estado deixa de ter um papel de pura abstenção e passa a ter que prestar positivamente para cumprir com seus deveres constitucionais. O Estado Constitucional é um Estado marcado pelo seu *dever de dar tutela aos direitos*, com o que deve promover os fins ligados à pessoa humana e não antepor barreiras para o seu adequado desenvolvimento.

Do ponto de vista lógico, o processo cooperativo pressupõe o reconhecimento do *caráter cultural e problemático do Direito*, reabilitando-se a sua *feição lógico-argumentativa*¹³⁷. Isso quer dizer que a ciência do Direito deixa de ser compreendida simplesmente como uma *ciência descritiva*, as normas jurídicas passam a ser vistas como o *resultado de uma colaboração entre o legislador e o juiz* a partir de elementos *textuais* e *não textuais* da ordem jurídica e a interpretação jurídica deixa de ser encarada como uma atividade puramente *cognitivista*.

Finalmente, do ponto de vista ético, o processo pautado pela colaboração é um processo *orientado pela busca*, tanto quanto possível, *da verdade*¹³⁸ (arts. 369 e 370, CPC) e que, para além de emprestar relevo à *boa-fé subjetiva* (arts. 79 a 81, CPC), também exige de todos os seus participantes a observância da *boa-fé objetiva* (art. 5.º, CPC), sendo igualmente seu destinatário o juiz, tendo como objetivo produzir decisões justas (art. 6.º, CPC)¹³⁹.

O modelo de processo pautado pela colaboração visa outorgar *nova dimensão ao papel do juiz na condução do processo* (arts. 6.º e 139, CPC). O juiz do processo cooperativo é um juiz isonômico na sua condução e assimétrico apenas quando impõe suas decisões. *Desempenha duplo papel: é paritário no diálogo e assimétrico na decisão*¹⁴⁰.

A *paridade* na sua condução está em que, embora dirija processual e materialmente o processo, atuando ativamente¹⁴¹, fá-lo de maneira dialogal¹⁴² (art. 139, CPC). Vale dizer: o juiz participa do processo colhendo a impressão das partes a respeito dos seus rumos, possibilitando assim a influência dessas na formação de suas possíveis decisões¹⁴³ (de modo que o *iudicium* acabe sendo efetivamente um ato *trium personarum*, como se entendeu ao longo de toda praxe do *jus commune*¹⁴⁴). Toda a condução do processo dá-se com a observância, inclusive com relação ao próprio juiz, do contraditório¹⁴⁵. A propósito, o § 139 da ZPO alemã e o artigo 16 do *Nouveau Code de Procédure Civile* são paradigmáticos a respeito do tema¹⁴⁶. A *assimetria*, de outro lado, está em que o juiz, ao decidir as questões processuais e as questões materiais do processo, necessariamente *impõe o seu comando*, cuja existência e validade independem de expressa adesão ou de qualquer espécie de concordância das partes.

Além de ser uma comunidade de trabalho, o processo civil pode ainda ser qualificado mais especificamente como uma *comunidade argumentativa de trabalho*. A razão para tanto é simples: as partes têm o ônus de alegar e o juiz tem o dever de decidir invocando razões jurídicas. Vale dizer: em ambos os casos existe a necessidade dessas interpretações estarem fundadas no Direito (arts. 1.º, CRFB, e 1.º, 8.º e 926, CPC). Daí que se o juiz tem o dever de fundamentação analítica (arts. 93, inciso IX, CRFB, e 489, §§ 1.º e 2.º, CPC), as partes têm o ônus de alegação específica (arts. 6.º, 9.º, 319, III, 336, 350 e, analogicamente, 489, §§ 1.º e 2.º, CPC).

Isso quer dizer que em todas as suas postulações (seja com a propositura da ação, seja com o oferecimento da defesa, seja com a interposição do recurso, seja com a apresentação das contrarrazões), as partes têm o ônus de alegar de forma especificada: i) a conexão da norma com o caso; ii) o significado do termo vago invocado; iii) o significado do princípio invocado e dos postulados empregados para a solução de eventuais antinomias normativas; e iv) as semelhanças ou distinções entre os precedentes debatidos em juízo). Não o fazendo, pode o juiz determinar o esclarecimento da alegação incompleta ou de algum modo imperfeita, indicando precisamente aquilo que deve ser objeto da atividade da parte (arts. 6.º e, analogamente, 321, CPC).

A maneira como esse *modelo* cooperativo opera no processo é obra do *princípio* da colaboração.

3. Como Princípio: os Deveres de Colaboração do Juiz. A colaboração no processo é um *princípio jurídico*¹⁴⁷. Ela impõe um *estado de coisas* que tem de ser promovido¹⁴⁸. O fim da colaboração está em servir de elemento para organização de um processo justo idôneo a alcançar uma decisão justa¹⁴⁹ (art. 6.º, CPC).

Para que o processo seja organizado de forma justa os seus participantes têm de ter *posições jurídicas equilibradas* ao longo do procedimento. Portanto, é preciso perceber que a organização do processo cooperativo envolve – antes de qualquer coisa – a necessidade de um *novo dimensionamento de poderes no processo*, o que implica necessidade de *revisão da cota de participação* que se defere a cada um de seus participantes ao longo do arco processual. A colaboração implica *revisão das fronteiras* concernentes à responsabilidade das partes e do juiz no processo¹⁵⁰. Em outras palavras: *a colaboração visa organizar a participação do juiz e das partes no processo de forma equilibrada*.

A colaboração impõe a organização de processo cooperativo – em que haja colaboração entre os seus participantes. *O legislador tem o dever de perfilar o processo a partir de sua normatividade, densificando a colaboração no tecido processual*. É por essa razão que o Código de 2015 é permeado pela colaboração (arts. 5.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10, 11, 139, VIII e IX, 191, 317, 319, § 1.º, 321, 357, § 3.º, 487, parágrafo único, 488, 489, §§ 1.º e 2.º, 772, III, 926, § 1.º, 932, parágrafo único, 1.007, §§ 2.º, 4º e 7.º, e 1.017, § 3.º, CPC).

Aqui, porém, importa desde logo deixar claro: *a colaboração no processo não implica colaboração entre as partes*. As partes não querem colaborar. A colaboração no processo que é devida no Estado Constitucional é a colaboração do juiz para com as partes. Gize-se: *não se trata de colaboração entre as partes*. As partes não colaboram e não devem colaborar *entre si* simplesmente porque obedecem a diferentes interesses no que tange à sorte do litígio¹⁵¹. O máximo que se pode esperar é uma colaboração *das partes para com o juiz* no processo civil¹⁵².

Esse ponto é digno de nota: enquanto os deveres de colaboração no *plano do direito material* tiveram sua origem no campo obrigacional a partir dos estudos ligados à boa-fé, o que acabou desaguando na construção de *deveres cooperativos entre as partes*, no processo esses deveres não se originam da boa-fé e não podem ser concebidos como *deveres que gravam as partes entre si*. É que no plano do direito material as partes constroem vínculos jurídicos com uma *finalidade comum*. Vale dizer: os *interesses são convergentes*. O *adimplemento* é o fim do processo obrigacional e domina toda a sua estruturação¹⁵³. Inexiste a princípio qualquer *crise* que afaste as partes da finalidade comum no plano do direito material. O plano do processo, porém, pressupõe justamente uma *ameaça de crise* ou uma *efetiva crise* na realização do direito material. E a partir desse exato momento os *interesses das partes* deixam de ser convergentes e passam a ser *divergentes*. Isso obviamente não dispensa as partes de agirem com boa-fé no processo. No

entanto, daí para exigência de colaboração entre as partes existe uma significativa distância.

O *princípio* da colaboração estrutura-se a partir da previsão de *regras* que devem ser seguidas pelo juiz na condução do processo. O juiz tem deveres de *esclarecimento*, de *diálogo*, de *prevenção* e de *auxílio* para com os litigantes. É assim que funciona a cooperação. *Esses deveres consubstanciam as regras que estão sendo enunciadas quando se fala em colaboração no processo* ¹⁵⁴.

O *dever de esclarecimento* constitui “o dever de o tribunal se esclarecer junto das partes quanto às dúvidas que tenha sobre as suas alegações, pedidos ou posições em juízo”¹⁵⁵. O de *diálogo*, o dever de o órgão judicial dialogar e consultar as partes antes de decidir sobre qualquer questão, possibilitando que essas o influenciem a respeito do rumo a ser dado à causa¹⁵⁶. O de *prevenção*, o dever de o órgão jurisdicional prevenir as partes do perigo de o êxito de seus pedidos “ser frustrado pelo uso inadequado do processo”¹⁵⁷. O *dever de auxílio*, “o dever de auxiliar as partes na superação de eventuais dificuldades que impeçam o exercício de direitos ou faculdades ou o cumprimento de ônus ou deveres processuais”¹⁵⁸.

Várias são as situações em que esses deveres gravam o juiz ao longo do processo.

O dever de esclarecimento impõe ao juiz o dever de indicar às partes eventuais *obscuridades* ou *incoerências* nas narrativas que evidenciam suas posições quanto às questões fático-jurídicas que compõem a causa. Isso quer dizer que é *vedado ao juiz indeferir de imediato* eventuais postulações das partes pela simples ausência de compreensão da narrativa, sendo imperiosa a oportunização de manifestação das partes para esclarecimento da questão. Trata-se de providência que visa viabilizar um mais adequado entendimento da argumentação das partes no processo¹⁵⁹.

Especial atenção na conformação do processo civil do Estado Constitucional assume o *dever de diálogo* – o qual é visto por parcela da doutrina como “o mais agudo dos pontos da cooperação imposta ao juiz”¹⁶⁰. Por questões sistemáticas, porém, o assunto será devidamente tratado nos comentários aos arts. 9.º, 10 e 11, CPC.

O dever de prevenção incumbe o juiz de indicar às partes que eventuais *escolhas equivocadas* do ponto de vista do processo podem acarretar na *frustração do exame* do direito material. Assim, por exemplo, é vedado ao juiz não conhecer de determinada postulação da parte por defeito processual sanável sem que se tenha primeiramente dado oportunidade para a parte saná-lo¹⁶¹. E isso por uma razão muito simples: não faz sentido afirmar que o Estado tem o dever de tutelar os direitos e ao mesmo tempo permitir que o direito sucumba diante de defeitos formais sanáveis não relevados pelo próprio Estado. É por essa razão que os arts. 317 e 932, parágrafo único, CPC, funcionam como verdadeiras normas abertas a respeito do dever de prevenção.

E aqui desde logo uma observação se impõe: o dever de prevenção tem como corolário a “primazia do mérito” no processo civil¹⁶². É mediante o dever de prevenção que o juiz indica que determinado comportamento pode levar à extinção do processo sem resolução de mérito ou ao não conhecimento de determinado recurso.

O dever de auxílio determina ao juiz que colabore com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres no processo. Trata-se de dever que visa viabilizar o adequado atendimento aos ônus e aos deveres das partes no processo. Pense-se, por exemplo, no exequente que não encontra bens penhoráveis do executado para satisfação de seu crédito. É tarefa do juiz auxiliá-lo na identificação do patrimônio do executado a fim de que a tutela executiva possa ser realizada de forma efetiva.

É fácil perceber, por fim, a ligação entre o modelo cooperativo e o princípio da cooperação. Existe um efetivo enlace entre eles. Os deveres inerentes à colaboração no processo respondem aos pressupostos que sustentam o modelo cooperativo. Os deveres de esclarecimento e de consulta respondem principalmente aos pressupostos lógicos e éticos do modelo cooperativo de processo, na medida em que decorrem do caráter problemático-argumentativo do Direito e da necessidade de proteção contra a surpresa. Os deveres de prevenção e de auxílio descendem diretamente do

pressuposto social do modelo, haja vista evidenciarem o fato de o sistema processual civil ser um sistema orientado para tutela dos direitos, tendo o juiz o dever de realizá-los a partir da relativização do binômio direito e processo e do compartilhamento da responsabilidade pela atividade processual. Vale dizer: deve o juiz ver o processo não como um sofisticado conjunto de fórmulas mágicas e sagradas, ao estilo das *legis actiones*, mas como um *instrumento* para efetiva realização do direito material.

Art. 7.º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus e aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

1. Direito à Igualdade no Processo Civil

O direito à igualdade perante o Estado Constitucional é pressuposto básico de toda e qualquer concepção *jurídica* de Estado. Estado Constitucional é Estado em que há *juridicidade* e *segurança jurídica*. A *juridicidade* – todos *abaixo* do Direito¹⁶³ – remete à *justiça*, que de seu turno remonta à *igualdade*¹⁶⁴. Natural, portanto, que componha o direito ao processo justo o *direito à igualdade e à paridade de armas no processo*. Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “a igualdade das partes é imanente ao ‘*procedural due process of law*’”¹⁶⁵. Trata-se de direito fundamental que, nada obstante não previsto expressamente na Constituição para o campo do processo, decorre naturalmente da ideia de Estado Constitucional e do direito fundamental à igualdade perante a ordem jurídica como um todo (art. 5.º, *caput*, CRFB)¹⁶⁶. É muito oportuna a sua previsão expressa no Código de 2015.

A igualdade no processo tem de ser analisada sob duas perspectivas distintas. Na primeira, importa ter presente a distinção entre *igualdade perante a legislação* (igualdade formal) e *igualdade na legislação* (igualdade material)¹⁶⁷. Na segunda, é preciso ressaltar a diferença entre *igualdade no processo* e *igualdade pelo processo* – *igualdade diante do resultado da aplicação da legislação* no processo.

2. Igualdade perante a Legislação e Igualdade na Legislação

A igualdade perante a legislação determina a *aplicação uniforme* da lei processual. O juiz tem o dever de aplicar a legislação de modo igualitário. É seu dever dirigir o processo e velar pela igualdade das partes (art. 139, I, CPC).

A igualdade na legislação pressupõe a *inexistência de distinções arbitrárias* no seu conteúdo. A distinção tem de ser feita de forma *racional* pelo legislador¹⁶⁸. É claro que a igualdade “não consiste em um tratamento igual sem distinção de todos em todas as relações”, já que “senão aquilo que é igual deve ser tratado igualmente”¹⁶⁹. O problema da igualdade na legislação, portanto, está na utilização de *critérios legítimos* para distinção entre *pessoas* e *situações* no processo¹⁷⁰. É vedada, em outras palavras, a existência de “distinções arbitrárias” na legislação¹⁷¹, isto é, realizadas sem finalidade legítima (“*legitimate purpose*”)¹⁷².

O direito à igualdade e à paridade de armas, para além de vincular o legislador, vincula igualmente o juiz na condução do processo. É inadmissível que, por ato judicial, as partes tenham *oportunidades assimétricas* ao longo do processo. É o que pode ocorrer, por exemplo, pela aplicação equivocada das regras sobre o ônus da prova. Como é amplamente sabido, as regras sobre o ônus da prova possuem *dupla finalidade*: funcionam como *regra de instrução* e como *regra de julgamento*¹⁷³. Quando o juiz *inverte* o ônus da prova ou *dinamiza-o*, é imprescindível que a parte onerada *ex novo* tenha oportunidade de desempenhá-lo de forma adequada (art. 373, § 1.º, CPC), sob pena de violado não só o direito à prova, mas também o direito à igualdade e à paridade de armas no processo¹⁷⁴.

3. Igualdade no Processo e Igualdade pelo Processo

O direito à igualdade – em sua dupla dimensão – dá lugar à *igualdade no processo*. Mas é preciso ir além. É, aliás, curioso, que a doutrina se preocupe com a estruturação do processo a partir da igualdade, mas não mostre idêntica preocupação no que tange à *igualdade pelo processo*¹⁷⁵. O processo justo visa à decisão justa. *E não há justiça se não há igualdade – unidade – na aplicação do Direito pelo processo*. O processo tem de se estruturar com técnicas capazes de promover a igualdade de todos perante a ordem jurídica. Embora esse não seja um problema ligado propriamente à *igualdade no processo*, certamente constitui assunto de direito processual a necessidade de promoção da *igualdade pelo processo*. Daí que a igualdade pelo processo – que é a *igualdade diante dos resultados produzidos pelo processo* – tem estreita ligação com a adoção de um *sistema de precedentes obrigatórios* pelo Código de 2015 (arts. 489, § 1.º, 926 e 927, CPC)¹⁷⁶, sem o que, paradoxalmente, focamos na igualdade no *meio*, mas não na igualdade no *fim*, atitude cuja correção lógica pode ser sem dúvida seriamente questionada. Só há sentido em preocupar-se com a *igualdade no processo* se nos preocuparmos igualmente com a *igualdade pelo processo* – o meio serve ao fim e ambos devem ser pensados na perspectiva da igualdade.

4. Paridade de Tratamento e Efetivo Contraditório

O direito à igualdade processual – formal e material – é o suporte do direito à *paridade de armas* no processo (*Waffengleichheit, parità delle armi, égalité des armes*)¹⁷⁷. O processo só pode ser considerado justo se as partes dispõem das *mesmas oportunidades* e dos *mesmos meios* para dele participar. Vale dizer: se dispõem das *mesmas armas*.

Trata-se de exigência que obviamente se projeta sobre o legislador e sobre o juiz: há dever de estruturação e condução do processo de acordo com o direito à igualdade e à paridade de armas. Como facilmente se percebe, a igualdade e a paridade de armas nela implicada, constitui *pressuposto* para efetiva participação das partes no processo e, portanto, é requisito básico para plena realização do *direito ao contraditório* (art. 7.º, *in fine*, CPC).

Art. 8.º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

1. Ordenamento Jurídico

A aplicação do ordenamento jurídico pelo juiz está condicionada, segundo a primeira parte do art. 8.º, à observância dos fins sociais e às exigências do bem comum, com resguardo e promoção da dignidade da pessoa humana. Trata-se de norma que atua sobre a interpretação de outras normas: o juiz, considerando a dignidade da pessoa humana, deve atender aos fins sociais e às exigências do bem comum ao aplicar o ordenamento jurídico.

De outro lado, o art. 8.º, CPC, ressalta que o juiz deve aplicar o ordenamento jurídico. Isso quer dizer que deve interpretar a ordem jurídica procurando promover a sua unidade¹⁷⁸ (arts. 1.º e 8.º, CPC), tendo presente que “não se interpreta o direito em tiras”¹⁷⁹.

2. Fins Sociais e Bem Comum

A identificação de finalidades exige a prévia identificação da função (como refere a doutrina, “le but du droit est de servir la finalité”¹⁸⁰) – especificamente no que agora interessa, a função do processo civil no Estado Constitucional. O processo civil serve para dar tutela aos direitos em uma dupla dimensão: prover justiça para o caso concreto e prover razões capazes de tornar o direito, a partir do caso concreto, menos indeterminado.

Daí que a exigência de aplicação do ordenamento jurídico de acordo com fins sociais e com as exigências do bem comum não pode significar outra coisa senão aplicação do ordenamento jurídico processual exatamente dentro das suas funções. Em outras palavras, por força do art. 8.º, CPC, não está o juiz autorizado a desvirtuar os fins do processo civil ou impor deveres não

previstos em lei¹⁸¹. A subordinação da aplicação da ordem jurídica a fins sociais e ao bem comum, portanto, não importa previsão de fins outros que não aqueles assinalados pela sua função dentro do ordenamento jurídico ao processo civil.

3. Dignidade da pessoa humana

O art. 8.º, primeira parte, CPC, refere que o juiz ao aplicar o ordenamento jurídico deve resguardar e promover a dignidade da pessoa humana – a qual constitui sabidamente um dos fundamentos do Estado Constitucional (art. 1.º, III, CRFB). Com isso, reafirma a dignidade da pessoa humana como ponto em que se apoia o Estado Constitucional para assentar a sua “unidade axiológica” e do qual retira a sua “legitimidade”¹⁸².

Em primeiro lugar, a dignidade da pessoa humana determina a compreensão do processo civil como um meio para tutela dos direitos¹⁸³. Vale dizer: o processo civil não pode ser visto como um instrumento a serviço do Estado, como um instrumento que não se encontre orientado à realização dos fins da pessoa humana. Em outras palavras, o processo civil serve para realização dos direitos e para orientação das pessoas a respeito do significado do direito.

Em segundo lugar, a dignidade da pessoa humana conecta-se com o direito à liberdade e à autonomia privada, o que explica a necessidade de respeito, dentro dos limites constitucionais e legais, às convenções processuais realizadas entre as partes (art. 190, CPC) e constitui estímulo à realização de calendários processuais entre o juiz e as partes como instrumento para eficiente gestão do tempo no processo civil (art. 191, CPC). Também sob o ângulo do livre desenvolvimento da personalidade – conhecida fórmula com que se procura sintetizar o núcleo-duro do conceito de dignidade da pessoa humana¹⁸⁴ – é importante perceber a ênfase dada à necessidade de respeito aos precedentes: se só é possível tomar decisões juridicamente orientadas a partir do conhecimento do direito, isto é, fazer escolhas, exercer a autonomia inerente à liberdade humana, então a dignidade da pessoa humana constitui também fonte do dever de prover uma ordem jurídica segura como as Cortes Supremas têm (art. 926, CPC). Não por acaso, a doutrina há muito relaciona liberdade, segurança e racionalidade, denunciando a aleatoriedade como um indício da existência de um direito feito não para pessoas humanas, mas para cachorros (“dog law”¹⁸⁵).

Em terceiro lugar, a dignidade da pessoa humana veda a transformação das partes em objeto da atividade jurisdicional. É por essa razão que a dignidade da pessoa humana tem estreita ligação com o direito de participação das partes na construção dos provimentos jurisdicionais – isto é, na previsão do direito ao contraditório como direito de influência (arts. 9.º e 10, CPC) e o dever de fundamentação como dever de debate (arts. 11 e 489, §§ 1.º e 2.º, CPC).

O juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico e ao conduzir o processo, deve resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, o que significa encarar o processo como um meio para tutela dos direitos, respeitar a liberdade das partes nos seus espaços de autodeterminação e adotar o contraditório como método de trabalho. Esse é o *significado mínimo* da previsão constante dos arts. 1.º, III, CRFB, e 8.º, CPC.

4. Legalidade

O juiz deve fidelidade ao direito – isto é, à ordem jurídica (arts. 7.º e 140, CPC). Diante disso, o juiz ao aplicar o ordenamento jurídico deve observar não só a legalidade, mas a juridicidade: a alusão no art. 7.º, CPC, à legalidade, portanto, deve ser lida como alusão ao direito como um todo.

Em uma perspectiva interpretativa lógico-argumentativa, porém, é preciso observar que o respeito ao direito depende da outorga de significado às disposições textuais e aos elementos não textuais da ordem jurídica. Lei significa, sobretudo, interpretação da lei – interpretação dada pelo órgão encarregado constitucional e institucionalmente de fazê-lo¹⁸⁶. Isso quer dizer que o respeito à juridicidade e à legalidade impõe fidelidade à juridicidade e à legalidade tal como retratadas pelas Cortes Supremas, que têm o dever de dar unidade ao direito (art. 926, CPC)¹⁸⁷. Respeitar a lei

significa respeitar a sua interpretação.

Isso quer dizer que havendo precedentes constitucionais e precedentes federais sobre determinada questão, o respeito à juridicidade e à legalidade para a administração da Justiça Civil significa respeito à interpretação institucionalmente vinculante dada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça às respectivas questões (art. 927, CPC). Vale dizer: respeito aos precedentes judiciais.

5. Proporcionalidade e Razoabilidade

A aplicação do direito depende de um processo interpretativo lógico-argumentativo racionalmente estruturado. Por essa razão, não só a proporcionalidade e a razoabilidade devem ser observadas na aplicação do direito, mas também a coerência (art. 926, CPC), a concordância prática e a ponderação (art. 489, § 2.º, CPC). Em todo e qualquer caso, a utilização desses postulados submete-se à necessidade de fundamentação analítica (art. 489, §§ 1.º e 2.º, CPC).

O postulado da proporcionalidade resulta da necessidade de otimização do princípio da liberdade e impõe que os meios sejam proporcionais aos fins buscados. Aplicação proporcional de normas jurídicas significa aplicação em que os meios são necessários, adequados e proporcionais em sentido estrito. A proporcionalidade serve para estruturar a aplicação de outras normas que se colocam em uma relação de meio e fim¹⁸⁸.

O postulado da razoabilidade resulta da necessidade de aplicação do princípio da igualdade e impõe dever de equidade (consideração na aplicação das normas jurídicas daquilo que normalmente acontece), dever de atenção à realidade (consideração da efetiva ocorrência do suporte fático que autoriza sua incidência) e dever de equivalência na aplicação do direito (consideração da existência de dever de equivalência entre a medida adotada e o critério que a dimensiona). O postulado da razoabilidade não pressupõe, como o postulado da proporcionalidade, uma relação entre meio e fim – pressupõe, no entanto, uma relação entre o geral e o particular¹⁸⁹.

6. Razoabilidade e Equidade

Quando se imaginava que a aplicação do direito não deveria levar em consideração outra coisa senão a lei, era comum vedar-se a invocação da equidade para solução de problemas jurídicos – ou então relegar a sua utilização a um posto excepcional. O art. 140, parágrafo único, CPC, é um resquício desse tempo. Daí que a antinomia existente entre o art. 8.º e o art. 140, parágrafo único, CPC, é apenas aparente: aplicar o ordenamento jurídico observando a razoabilidade significa autorização para o emprego da equidade na justificação das decisões judiciais em geral – ao menos se entendermos equidade como um dos elementos caracterizadores da razoabilidade¹⁹⁰.

7. Publicidade

A administração da Justiça Civil é pública, de modo que o processo civil segue esse mesmo destino. Não só os pronunciamentos judiciais são públicos (art. 93, IX, CRFB, e 11, CPC), mas também todos os atos processuais que compõem o procedimento destinado à distribuição de justiça. Conjuntamente com o direito ao contraditório e com o dever de fundamentação das decisões, a publicidade forma o núcleo duro de uma administração judiciária permeada por uma ideologia democrática.

8. Eficiência

O juiz deve dirigir o processo de modo eficiente. Isso significa que deve alocar tempo adequado e dimensionar adequadamente os custos da solução de cada litígio. A necessidade de eficiência na gestão do processo guarda íntima relação com a ideia de proporcionalidade entre os meios e os fins que são visados pela administração da Justiça Civil¹⁹¹.

Daí que o juiz tem o dever de dirigir o processo eficientemente, prevenindo as partes a respeito de eventuais equívocos que possam importar em não aproveitamento de determinado ato processual ou do processo como um todo (arts. 6.º, 139, IX, 317 e 932, parágrafo único, CPC), aproveitando o processo, sempre que possível, para tratar coletivamente os litígios individuais (arts. 139, X, e 976, CPC). Eficiência, porém, não significa dirigir o processo levando em consideração apenas o aspecto quantitativo da atividade judiciária: significa, dentro de uma preocupação com os resultados da tutela jurisdicional, preocupar-se em bem administrar os recursos humanos disponíveis para o gerenciamento dos processos e bem aplicar as técnicas processuais existentes para a tutela dos direitos.

Art. 9.º Não se proferirá decisão contra uma das partes, sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no *caput* não se aplica:

I – à tutela provisória de urgência;

II – às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III – à decisão prevista no art. 701.

1. Direito ao Contraditório

O direito ao contraditório constitui a mais óbvia condição do processo justo e é inseparável de qualquer ideia de administração organizada de Justiça¹⁹², funcionando como verdadeiro “cardine della ricerca dialettica” pela justiça do caso concreto¹⁹³, tamanha a sua importância que o *próprio conceito de processo* no Estado Constitucional está construído sob sua base¹⁹⁴.

O direito de ação, como direito ao processo justo, tem o seu exercício balizado pela observância do direito ao contraditório ao longo de todo arco procedimental¹⁹⁵ (art. 5.º, LIV e LV, CRFB). Daí a razão pela qual o novo Código destacou o direito ao contraditório nos arts. 9.º e 10 como norma fundamental do novo processo civil brasileiro. Somado ao dever de fundamentação e à publicidade, o contraditório constitui clara projeção do direito à participação que está na raiz de toda e qualquer administração democrática da Justiça Civil.

Em geral, do ponto de vista do seu *conteúdo*, o direito ao contraditório por muito tempo foi identificado com a *simples bilateralidade da instância, dirigindo-se tão somente às partes*. Dentro desse quadro histórico, o contraditório realizava-se apenas com a observância do binômio *conhecimento-reação*. Isto é, uma parte tem o direito de conhecer as alegações feitas no processo pela outra e tem o direito de, querendo, contrariá-las. Semelhante faculdade estende-se igualmente à produção da prova. Trata-se de feição do contraditório própria à cultura do Estado Liberal¹⁹⁶, confinando as partes, no fundo, no terreno das alegações de fato e da respectiva prova¹⁹⁷.

Nessa linha, o órgão jurisdicional nada tinha que ver com a realização do direito ao contraditório, na medida em que *apenas os litigantes seriam os seus destinatários*. Partindo desse pressuposto, o Supremo Tribunal Federal já chegou a decidir que “a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, tem como destinatários os litigantes em processo judicial ou administrativo e não o magistrado que no exercício de sua função jurisdicional, à vista das alegações das partes e das provas colhidas e impugnadas, decide fundamentadamente a lide”¹⁹⁸.

Atualmente, porém, a doutrina tem identificado no direito ao contraditório muito *mais do que simples bilateralidade da instância*. Ao binômio conhecimento-reação tem-se oposto a ideia de *cabal participação como núcleo-duro do direito ao contraditório*. É lógico que o contraditório, no processo civil do Estado Constitucional, tem significado completamente diverso daquele que lhe era atribuído à época do direito liberal¹⁹⁹. Contraditório significa hoje conhecer e reagir, mas não só. *Significa participar do processo e influir nos seus rumos*. Isto é: *direito de influência*²⁰⁰. Com essa nova dimensão, o direito ao contraditório deixou de ser algo cujos destinatários são tão somente as

partes e começou a *gravar igualmente o juiz*. Daí a razão pela qual eloquentemente se observa que o juiz tem o dever não só de velar pelo contraditório entre as partes, *mas fundamentalmente a ele também se submeter* ²⁰¹. O juiz encontra-se igualmente sujeito ao contraditório.

2. Formas de Realização do Contraditório

O contraditório pode se realizar de *diferentes maneiras* no processo. Como o direito ao contraditório não é o único direito fundamental que compõe o processo justo, por vezes é necessário *harmonizá-lo* com os seus demais elementos estruturantes, em especial com o *direito à tutela adequada e efetiva dos direitos*. É por essa razão que é *perfeitamente legítimo* na nossa ordem jurídica o emprego de *contraditório diferido* e de *contraditório eventual* na organização do perfil procedimental do processo. Tanto o contraditório *prévio* como o *diferido* e o *eventual* são legítimos para organização do processo justo.

Em geral, no processo civil o *contraditório é prévio: audiatur et altera pars*. Primeiro o juiz ouve ambas as partes para tão somente depois decidir. Pode ocorrer, contudo, de o órgão jurisdicional ter que *decidir de forma provisória* determinada questão ao longo do processo antes de ouvir uma das partes (*inaudita altera parte*). É o que ocorre, por exemplo, quando o juiz antecipa a tutela (isto é, quando presta tutela provisória, arts. 294 e ss., CPC). O contraditório aí fica *postergado – diferido* – para depois da concessão da tutela jurisdicional. A restrição ao contraditório ocorre em função da necessidade de *adequação e efetividade* da tutela jurisdicional. Não há qualquer inconstitucionalidade na postergação do contraditório. Sendo *necessária* a concessão de tutela antecipada antes da oitiva do demandado, essa se impõe como decorrência do direito à tutela adequada dos direitos. *Não se trata, portanto, de medida excepcional*: verificados os seus pressupostos, o juiz tem o dever de antecipar a tutela.

Também não há qualquer inconstitucionalidade no *contraditório eventual* – que é aquele que se realiza em outro processo na *eventualidade* de o interessado propor demanda para *ampliação* ou *exaurimento* da cognição. É o exemplo clássico dos processos de *cognição parcial* e de *cognição sumária*. As chamadas ações possessórias ilustram bem o ponto referente à cognição parcial. A proteção possessória independe da propriedade. A discussão a respeito do domínio é *vedada* no processo possessório. O interessado em debater o tema tem o ônus de propor ação para que o contraditório se instaure sobre o ponto. Do contrário, a discussão fica restrita, não se possibilitando o contraditório sobre a questão *reservada* para eventualidade de outro processo. O legislador infraconstitucional pode, em atenção à importância do direito material carente de tutela, organizar *tutelas jurisdicionais diferenciadas* mediante o emprego de *contraditório eventual*. O controle da legitimidade de sua opção está na escolha de *situações substanciais constitucionalmente relevantes* para diferenciação da tutela pelo emprego do contraditório eventual.

3. Exceções

É possível que o contraditório seja diferido diante de decisões provisórias, isto é, decisões que poderão ser modificadas ao longo do procedimento. É o caso das decisões fundadas em cognição sumária capazes de prestar tutela de urgência (arts. 9.º, I, e 300, CPC), algumas hipóteses de tutela de evidência (arts. 9.º, II, e 311, II e III, CPC) e que servem para estruturação do procedimento monitório (arts. 9.º, III, e 701, CPC). O denominador comum entre as três hipóteses – e que torna legítima a exceção, justamente porque não invade o núcleo duro do direito ao contraditório – é a provisoriedade da decisão.

Diante da tutela provisória fundada na urgência, o contraditório poderá ser postergado para prestação de antecipação de tutela *inaudita altera parte*: i) quando a oitiva da parte contrária for capaz de colocar em risco a possibilidade de obtenção de *tutela específica do direito* – vale dizer, quando a *demora* inerente à formação do contraditório implicar concretização da ameaça que se pretende inibir, reiteração de ilícito ou sua continuação, ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ou agravamento injusto do dano experimentado pela parte (art. 5.º, XXXV, CRFB), e ii) quando a oitiva da parte contrária faz capaz de colocar em risco a *eficácia da antecipação da*

tutela – isto é, quando a *atuação* da parte contrária for capaz de frustrar o resultado que com ela se pretende obter. Nesses casos, o direito ao contraditório cede o passo e permite maior concretização do direito à tutela adequada e efetiva dos direitos. A possibilidade de o *tempo* ou a *atuação* da parte contrária *frustrar a efetividade da antecipação de tutela* constitui pressuposto para *postergação do contraditório* no processo civil.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

1. Vedação à Decisão-Surpresa

Por força da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência, a regra está em que *todas as decisões definitivas do juízo se apoiem tão somente em questões previamente debatidas pelas partes*, isto é, sobre matéria debatida anteriormente pelas partes. Em outras palavras, veda-se o juízo de “terza via”²⁰².

Há proibição de *decisões-surpresa* (*Verbot der Überraschungsentscheidungen*)²⁰³. O direito ao contraditório promove aí a participação das partes em juízo, tutelando a segurança jurídica do cidadão nos atos jurisdicionais do Estado.

Essa nova ideia de contraditório, como facilmente se percebe, acaba alterando a maneira como o juiz e as partes se comportam diante da ordem jurídica. Nessa nova visão, é absolutamente indispensável que tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo o que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício²⁰⁴ (art. 10, CPC). Fora daí há evidente violação à colaboração e ao diálogo no processo, com afronta inequívoca ao dever judicial de consulta e ao contraditório²⁰⁵.

Semelhante exigência, de um lado, encontra evidente respaldo no *interesse público* de chegar-se a uma *solução bem amadurecida* para o caso levado a juízo, não podendo ser identificada de modo nenhum como uma providência erigida no interesse exclusivo das partes²⁰⁶. Consoante observa a doutrina, o debate judicial amplia necessariamente o quadro de análise, constrange ao cotejo de argumentos diversos, atenua o perigo de opiniões preconcebidas e favorece a formação de uma decisão mais aberta e ponderada²⁰⁷. Funciona, pois, como um evidente instrumento de “democratização do processo”²⁰⁸. De outro, conspira para reforçar a confiança do cidadão no Poder Judiciário, que espera, legitimamente, que a decisão judicial leve em consideração apenas proposições sobre as quais pode exercer o seu direito a conformar o juízo²⁰⁹.

É exatamente nessa linha, aliás, que se move *precedente* do Superior Tribunal de Justiça a respeito da interpretação dos arts. 6 e 10, CPC: “Processual Civil. Previdenciário. Julgamento *Secundum Eventum Probationis*. Aplicação do Art. 10 do CPC/2015. Proibição de Decisão-Surpresa. Violação. Nulidade. 1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. 2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 3. Trata-se de proibição da chamada decisão-surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. 4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 5. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a

pedra de toque do novo CPC. 6. A proibição de decisão-surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão-surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. 7. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espalhados pelo Código. 8. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente "sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício" (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209). 9. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de legitimação decisória. 10. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. Tal necessidade de abrir oitiva das partes previamente à prolação da decisão judicial, mesmo quando passível de atuação de ofício, não é nova no direito processual brasileiro. Colhem-se exemplos no art. 40, §4º, da LEF, e nos Embargos de Declaração com efeitos infringentes. 11. Nada há de heterodoxo ou atípico no contraditório dinâmico e preventivo exigido pelo CPC/2015. Na eventual hipótese de adoção de fundamento ignorado e imprevisível, a decisão judicial não pode se dar com preterição da ciência prévia das partes. A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica *error in procedendo* e nulidade do julgado, devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. 12. *In casu*, o Acórdão recorrido decidiu o recurso de apelação da autora mediante fundamento original não cogitado, explícita ou implicitamente, pelas partes. Resolveu o Tribunal de origem contrariar a sentença monocrática e julgar extinto o processo sem resolução de mérito por insuficiência de prova, sem que as partes tenham tido a oportunidade de exercer sua influência na formação da convicção do julgador. Por tratar-se de resultado que não está previsto objetivamente no ordenamento jurídico nacional, e refoge ao desdobramento natural da controvérsia, considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão-surpresa, posto não terem as partes obrigação de prevê-lo ou advinha-lo. Deve o julgado ser anulado, com retorno dos autos à instância anterior para intimação das partes a se manifestarem sobre a possibilidade aventada pelo juízo no prazo de 5 (cinco) dias. 13. Corroborar a pertinência da solução ora dada ao caso o fato de a resistência de mérito posta no Recurso Especial ser relevante e guardar potencial capacidade de alterar o julgamento prolatado. A despeito da analogia realizada no julgado recorrido com precedente da Corte Especial do STJ proferido sob o rito de recurso representativo de controvérsia (REsp 1.352.721/SP, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 28/4/2016), a extensão e o alcance da decisão utilizada como paradigma para além das circunstâncias ali analisadas e para "todas as hipóteses em que se rejeita a pretensão a benefício previdenciário em decorrência de ausência ou insuficiência de lastro probatório" recomenda cautela. A identidade e aplicabilidade automática do referido julgado a situações outras que não

aquelas diretamente enfrentadas no caso apreciado, como ocorre com a controvérsia em liça, merece debate oportuno e circunstanciado como exigência da cooperação processual e da confiança legítima em um julgamento sem surpresas. 14. A ampliação demasiada das hipóteses de retirada da autoridade da coisa julgada fora dos casos expressamente previstos pelo legislador pode acarretar insegurança jurídica e risco de decisões contraditórias. O sistema processual pátrio prevê a chamada coisa julgada *secundum eventum probationis* apenas para situações bastante específicas e em processos de natureza coletiva. Cuida-se de técnica adotada com parcimônia pelo legislador nos casos de ação popular (art. 18 da Lei 4.717/1965) e de Ação Civil Pública (art. 16 da Lei 7.347/1985 e art. 103, I, CDC). Mesmo nesses casos com expressa previsão normativa, não se está a tratar de extinção do processo sem julgamento do mérito, mas de pedido julgado "improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova" (art. 16, ACP). 15. A diferença é significativa, pois, no caso de a ação coletiva ter sido julgada improcedente por deficiência de prova, a própria lei que relativiza a eficácia da coisa julgada torna imutável e indiscutível a sentença no limite das provas produzidas nos autos. Não impede que outros legitimados intentem nova ação com idêntico fundamento, mas exige prova nova para admissibilidade *initio litis* da demanda coletiva. 16. Não é o que se passa nas demandas individuais decididas sem resolução da lide e, por isso, não acobertadas pela eficácia imutável da autoridade da coisa julgada material em nenhuma extensão. A extinção do processo sem julgamento do mérito opera coisa julgada meramente formal e torna inalterável o *decisum* sob a ótica estritamente endoprocessual. Não obsta que o autor intente nova ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, inclusive com o mesmo conjunto probatório, e ainda assim receba decisão díspar da prolatada no processo anterior. A jurisdição passa a ser loteria em favor de uma das partes em detrimento da outra, sem mecanismos legais de controle eficiente. Por isso, a solução objeto do julgamento proferido pela Corte Especial do STJ no REsp 1.352.721/SP recomenda interpretação comedida, de forma a não ampliar em demasia as causas sujeitas à instabilidade extraprocessual da preclusão máxima. 17. Por derradeiro, o retorno dos autos à origem para adequação do procedimento à legislação federal tida por violada, sem ingresso no mérito por esta Corte com supressão ou sobreposição de instância, é medida que se impõe não apenas por tecnicismo procedimental, mas também pelo efeito pedagógico da observância fiel do devido processo legal, de modo a conformar o direito do recorrente e o dever do julgador às novas e boas práticas estabelecidas no Digesto Processual de 2015. 18. Recurso Especial provido"²¹⁰.

2. *Iura novit curia*

O direito ao contraditório – lido na perspectiva do direito ao diálogo, inerente à colaboração – condiciona a aplicação da máxima *Iura novit curia* ao prévio diálogo judicial. É certo que o juiz continua com o poder de aplicar o direito ao caso concreto, inclusive invocando normas jurídicas não invocadas pelas partes.

No entanto, a validade da aplicação ao caso concreto dessa inovação está condicionada ao prévio diálogo com as partes. Vale dizer: o juiz tem o dever de oportunizar às partes que o influenciem a respeito do acerto ou desacerto da solução que pretende outorgar ao caso concreto (art. 10, CPC). Isso quer dizer que a máxima do *Iura novit curia* continua plenamente vigente no novo Código: apenas a sua aplicação é que está condicionada ao prévio diálogo com as partes²¹¹.

3. *Da mihi factum, dado tibi ius*

O reconhecimento do caráter problemático do direito e o papel reconstrutivo da sua interpretação judicial fez com que a divisão do trabalho entre o juiz e as partes fosse impactada sensivelmente: as partes não estão mais confinadas na matéria de fato, assim como o juiz não está mais circunscrito à matéria de direito. Isso porque, a uma, as partes têm o direito de se pronunciar previamente sobre as normas jurídicas que serão aplicadas ao caso concreto pelo juiz e, a duas, o juiz tem o poder de conhecer de ofício fatos secundários e de determinar prova de ofício.

Daí que a colaboração judicial e o contraditório como direito de influência alteraram a

tradicional solução outorgada à divisão do trabalho processual pelo brocardo *da mihi factum, dado tibi ius* – que destinava às partes tão somente o papel de narrar os fatos e ao juiz o de aplicar o direito. O Código de 2015 reconhece que as partes têm direito de se pronunciar sobre o material jurídico de forma prévio à sua aplicação judicial.

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público.

1. Administração Democrática da Justiça Civil

A alocação do dever de fundamentação e do direito à publicidade como normas fundamentais do processo civil – especialmente previstas em conjunto e na sequência do direito ao contraditório – visa caracterizar o processo civil brasileiro e a administração da Justiça Civil em nosso país a partir de uma ideologia democrática. As razões invocadas pelas partes devem ser ouvidas e a fundamentação ocorre em função da necessidade de controle de poder pelas partes e pela sociedade em geral, o que é justamente assegurado pela publicidade do processo e dos seus atos²¹².

2. Direito à Fundamentação

Nossa Constituição refere que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX)²¹³. O dever de motivação das decisões judiciais é *inerente* ao Estado Constitucional²¹⁴ e constitui verdadeiro *banco de prova do direito ao contraditório* das partes²¹⁵. O art. 11, CPC, apenas reproduz textualmente a Constituição, relegando para o seu art. 489 a tarefa de densificar infraconstitucionalmente o significado constitucional do dever de fundamentar.

Não por acaso a doutrina liga de forma muito especial contraditório, fundamentação e direito ao processo justo. Sem motivação, a decisão judicial perde *duas características centrais*: a *justificação* da norma jurisdicional para o caso concreto e a *capacidade de orientação* de condutas sociais²¹⁶. Perde, em uma palavra, o seu próprio caráter jurisdicional²¹⁷.

A decisão judicial é o momento em que ocorre a *interpretação* e a *aplicação* do direito no processo judicial. O juiz, a partir do *diálogo* com as partes, interpreta e aplica o direito a fim de resolver a controvérsia apresentada em juízo.

Como nem os fatos²¹⁸ e nem o direito²¹⁹ independem de *interpretação*, o material com que trabalha o juiz no processo é o *resultado* de uma operação interpretativa. Dada a *dupla indeterminação* do direito (oriunda da *equivocidade dos textos* e da *vagueza das normas*)²²⁰, o juiz para decidir uma controvérsia tem que *primeiro se decidir* a respeito de como dissipará a indeterminação inerente ao problema jurídico²²¹. Daí que a decisão como um todo depende de várias decisões interpretativas, sem as quais não há ainda norma a ser aplicada para solução do caso concreto.

Isso quer dizer que as decisões, as sentenças e os acórdãos contêm *decisões* interpretativas. Saber, por exemplo, se a inviolabilidade domiciliar (“a casa é o asilo inviolável do indivíduo”, art. 5.º, XI, CRFB) protege igualmente o escritório profissional privativo de determinada pessoa é uma questão que *depende da outorga de sentido* a um termo equívoco: casa. Apenas *depois* de sabermos qual o significado constitucional apropriado do termo casa para efeitos de proteção da pessoa é que poderemos pensar em resolver o problema ligado à extensão da inviolabilidade domiciliar no direito brasileiro.

Em termos jurídicos, porém, pouco importa saber quais foram os *motivos reais* que determinaram a decisão judicial nesse ou naquele sentido²²². Em outras palavras, não interessam as *razões psicológicas* que levaram o juiz a decidir. O que interessa é saber se existem ou não

razões jurídicas que suportam validamente dentro da ordem jurídica a tomada de decisão²²³. Em outras palavras, interessa a *justificativa* da decisão judicial – importam as *razões oriundas do sistema jurídico* capazes de justificar a decisão²²⁴.

Assim, as decisões, as sentenças e os acórdãos resultam de *decisões* que devem ser apoiadas em *razões* que as *justifiquem*. Aliás, bem pode ocorrer – e amiúde ocorre – de a sentença, por exemplo, ser composta de várias decisões interpretativas, sendo que cada uma das quais deve encontrar a respectiva justificativa no ordenamento jurídico. Pouco importa, porém, o contexto da decisão (os motivos reais que levaram o juiz a decidir nesse ou naquele sentido – o *context of discovery*): o que interessa para aferição da sua validade e para permitir o seu controle do ponto de vista da ordem jurídica é o contexto da justificativa (as razões que foram invocadas para sua justificação – o *context of justification*)²²⁵. É a partir das *razões justificadoras* da decisão que é possível *controlá-la intersubjetivamente* ²²⁶.

As decisões judiciais requerem decisões interpretativas sobre os fatos (o que normalmente implica decisões interpretativas sobre a prova) e decisões interpretativas sobre o direito. Em outras palavras, o juiz para decidir deve formar a sua convicção a respeito dos fatos, das provas e do direito. Embora o Código de 2015 em seus arts. 11 e 489, §§ 1.º e 2.º, tenha se preocupado apenas com a fundamentação do direito, é certo que o dever de fundamentação também alcança a necessidade de uma justificativa no que tange à convicção quanto aos fatos e quanto à prova das alegações.

2.1. Decisão e Convicção

Para que o juiz possa analisar e decidir “as questões de fato e de direito” (art. 489, II, CPC) que as partes lhe submeteram, ele tem de formar a sua *convicção* a respeito dos elementos fáticos e jurídicos debatidos no processo, inclusive no que tange à prova da existência ou inexistência dos fatos alegados.

2.1.1. Verdade e Convicção

A impossibilidade de o juiz descobrir a essência da verdade dos fatos – a *verdade absoluta* – não lhe dá o direito de julgar o mérito sem a *convicção* da verdade. *Estar convicto da verdade não é o mesmo que encontrar a verdade*, até porque, quando se requer apenas a convicção de verdade, não se nega a possibilidade de que “as coisas não tenham acontecido assim”.²²⁷ Lembre-se que Calamandrei, após afirmar que “a natureza humana não é capaz de alcançar verdades absolutas”, salientou que “é um dever de honestidade acentuar o esforço para se chegar o mais perto possível dessa meta inalcançável”.²²⁸

Ou seja, a verdade, quando compreendida na linha da teoria do conhecimento, não pode se colocar no mesmo plano da *convicção* de verdade. A *convicção* – a *certeza* – é um estado *subjetivo*, ao passo que a *verdade* é *objetiva* ²²⁹. Ao lado dessa última categoria deve ser colocada a *convicção* de verossimilhança, pois não há como aceitar a antítese “convicção-verossimilhança”,²³⁰ como se fosse possível pensar que a convicção somente pode ser qualificada pela verdade. Ora, pode tanto haver convicção de verdade como convicção de verossimilhança.

A convicção da verdade é relacionada à limitação da própria possibilidade de buscar a verdade e, especialmente, com a correlação entre essa limitação e a necessidade de definição dos litígios. O juiz chega à convicção da verdade *a partir da consciência da impossibilidade da descoberta da sua essência, uma vez que é aquela que demonstra a falibilidade do processo para tanto. Dessa tomada de consciência, para a conclusão de que o processo, apesar de tudo isso, não pode impedir a eliminação dos conflitos, é um passo.*

Em resumo: o juiz, para pôr fim ao conflito, deve estar convicto, dentro das suas limitações, a respeito da verdade – o que não significa, obviamente, que chegou à verdade.

2.1.2. Convicção e Participação Judicial

Não há dúvida que o juiz, para formar a sua convicção, pode determinar prova de ofício²³¹ (art. 370, CPC). Porém, isso não significa que a participação de ofício do juiz se dirija à busca da verdade absoluta. O objetivo da produção da prova de ofício é o de possibilitar ao juiz, quando as provas produzidas pelas partes lhe parecem insuficientes, a elucidação dos fatos imprescindíveis para a formação da sua *convicção* sobre o mérito da causa.

Não é preciso dizer que essa forma de atuação do juiz, ainda que bem-vinda, não pode ser vista como um remédio milagroso, até porque a prova de ofício apenas pode ser determinada em casos muito específicos, isto é, basicamente em relação às provas periciais, pois é quase impossível ao juiz conhecer da existência de documentos ou testemunhas que possam servir para esclarecer os fatos. A limitação à prova de ofício aqui não constitui propriamente uma limitação jurídica, mas sociológica.

De modo que a prova de ofício não se destina à descoberta da verdade absoluta, mas apenas a suprir, dentro de limitações naturais, a insuficiência de produção de provas pelas partes, com o fim de possibilitar ao juiz a formação do seu *convencimento* para a resolução do mérito da causa.

Lembre-se, ainda, que a prova de ofício, além de ter que ser adequadamente justificada pelo juiz, deve abrir às partes a devida oportunidade: i) de considerar sobre a sua oportunidade; ii) de participar da sua produção; e iii) de falar sobre o seu resultado (arts. 7.º, 9.º e 10). Portanto, a prova de ofício não retira das partes a possibilidade de participar da sua formação (produção) e interpretação (consideração dos seus resultados).

Aliás, a prova de ofício jamais poderá eliminar a importância da participação das partes para o *convencimento* judicial, pois são elas que têm as melhores condições de saber quais são as provas que podem e devem ser produzidas. A participação das partes é imprescindível para a formação do *convencimento* judicial, ainda que, em alguns casos, o juiz possa – de forma supletiva – atuar de ofício.

2.1.3. Limitações à Produção da Prova

A cognição sumária em que fundada a antecipação da tutela – dita no Código *tutela provisória*, arts. 294 a 311 – admite que uma decisão seja proferida com base em parcela das provas que pode ser produzida pelas partes. Ou ainda: a cognição sumária é uma técnica que limita em determinado momento do processo a participação das partes e, ainda assim, viabiliza a decisão do juiz.

Essa limitação da participação das partes, que, na verdade, mais se aproxima a uma limitação da possibilidade de produzir prova, é característica às tutelas provisórias – tutela cautelar e à antecipação da tutela. Nessas duas hipóteses, o legislador processual estabelece a limitação da produção de prova, mandando o juiz se contentar com uma convicção de probabilidade.

Nessa linha, o Código de Processo Civil afirma que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Trata-se de exemplo que limita a possibilidade da produção de prova e, por isso, permite que o juiz decida com base em uma convicção de probabilidade.

Quando se pensa em probabilidade, nesses casos, alude-se simplesmente à convicção que o juiz pode formar diante de limitações à produção de provas. Trata-se, portanto, de expressas autorizações para o juiz decidir com base em uma convicção de probabilidade. Essa espécie de convicção pode ser oposta à convicção de verdade, própria ao juízo final, momento em que as provas suficientes já devem ter sido produzidas.

Diante disso, alguém poderia imaginar que o juiz apenas pode decidir com convicção de probabilidade no curso do processo ou quando a participação das partes tiver sido postecipada. Mas não é bem assim: o juiz, ainda que deva, nos casos de rotina, finalizar o processo com uma convicção de verdade, pode excepcionalmente sentenciar com base em convicção de probabilidade.

Gerhard Walter, em sua obra fundamental sobre a livre apreciação da prova, fala em *redução do módulo da prova*, para significar o que acontece quando o juiz decide no curso do processo e o que ocorre quando o juiz, em razão de determinadas circunstâncias, obriga-se a julgar com base em convicção de probabilidade ao final do processo.²³² Portanto, parece expressar, com o mesmo termo, dois significados.

Contudo, não há como deixar de ver a grande distinção entre essas duas situações. Na primeira, a lei processual autoriza a convicção de probabilidade, enquanto, na segunda, o juiz pode, ainda que sem autorização legal, excepcionalmente decidir com base em convicção de probabilidade, porque aí é o próprio direito material que determina a formação da convicção de modo diferente do comum. Na antecipação da tutela, a convicção de probabilidade é efeito da autorização da lei processual, ao passo que, na sentença, a redução do módulo da prova é fruto da impossibilidade de o juiz chegar diante do caso concreto a um juízo de verdade e de o direito material recomendá-la. Em um caso, a lei reduz a prova e, no outro, a lei não faz redução alguma, embora se entenda que o juiz possa, justificadamente, reduzir o módulo da prova.

2.1.4. A Tese Sueca sobre o Convencimento Judicial

Como demonstrado no capítulo sobre prova, a regra do ônus da prova faz pesar normalmente sobre o autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo e sobre o réu o ônus de demonstrar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo (art. 373, CPC). A ideia posta nessa regra não é bem vista por muitos, que dizem que não há racionalidade em julgar contra o autor que demonstrou o que alegou com certo grau de probabilidade, embora não tenha conseguido convencer o juiz.²³³

A teoria que se estabeleceu na Escandinávia – e foi desenvolvida mais intensamente na Suécia, especialmente em razão da obra de Per Olof Ekelöf²³⁴ – tem uma vinculação muito íntima com essa problemática. Essa teoria propõe uma restrição da importância da regra do ônus da prova, sintetizando a ideia de que ao juiz bastaria uma convicção de verossimilhança²³⁵.

Em certos casos, o juiz deveria chegar à verossimilhança prevista na lei, enquanto em outros, ele mesmo poderia determinar o grau de verossimilhança necessário, considerando as circunstâncias do caso concreto. Ou seja, a falta de previsão legal não retiraria do juiz a possibilidade de julgar com base em verossimilhança, quando então o julgamento deveria considerar as consequências que derivariam da exigência de um grau de verossimilhança muito alto e, portanto, de um julgamento fundado na regra do ônus da prova.²³⁶

Nessa dimensão, o raciocínio judicial deveria observar duas fases: na primeira, o juiz estabelece o grau de prova suficiente e, na segunda, atribui determinado grau às provas produzidas.²³⁷ Somente quando a prova não alcançar o grau preestabelecido é que o juiz lançará mão da regra do ônus da prova.

Patti, baseado nos escritos de Ekelöf, lembra que, através de exemplo, se uma regra requer, em relação à determinada situação, um grau de verossimilhança de 75%, a prova não pode ser considerada satisfatória se alcançar 70%. Mas, se chegar a 75% ou mais, deve ser considerada suficiente, quando se elimina, ao menos em face disso, qualquer problema de “convencimento judicial”²³⁸.

2.1.5. A Acentuação da Função da Verossimilhança. Överviktsprinzip e Überwiegensprinzip e Verossimilhança Preponderante

Não satisfeita com a ideia de que o julgamento fundado em verossimilhança apenas seria possível nas hipóteses em que a lei, ou o juiz, considerando as especificidades de determinada situação de direito material, determinassem um grau de probabilidade suficiente, a doutrina sueca foi mais adiante, para concluir que o julgamento poderia fugir da regra do ônus da prova quando existisse um *mínimo* de preponderância da prova, vale dizer, *um grau de 51%*.

Melhor explicando: se a posição de uma das partes é mais verossímil que a da outra, *ainda que minimamente*, isso seria suficiente para lhe dar razão. Nessa lógica, ainda que a prova do autor

demonstrasse com um grau de 51% a verossimilhança da alegação, isso tornaria a sua posição mais próxima da verdade, o que permitiria – segundo a doutrina escandinava – *um julgamento mais racional e mais bem motivado que aquele que, estribado na regra do ônus da prova, considerasse a alegação como não provada.* ²³⁹

Nesse sentido, a doutrina fala em verossimilhança preponderante – na Suécia em Överviktsprinzip e na Alemanha em Überwiegensprinzip – para significar a suficiência da preponderância de um grau de probabilidade *mínimo*. ²⁴⁰ Aí, como é fácil perceber, a ideia de ônus da prova acaba assumindo importância não como mecanismo de distribuição desse ônus e, muito menos, como regra de juízo, mas como uma espécie de *régua* que indicaria a parte que deveria obter êxito.

O ônus da prova constituiria o ponto central dessa régua e assim o ônus de produzir prova *não pesaria sobre nenhuma das partes*. A parte que conseguisse fazer a régua pender para o seu lado, ainda que a partir de um mínimo de prova, mereceria ganhar a causa, quando então prevaleceria o princípio da “verossimilhança preponderante”. ²⁴¹

Essa tese – que obviamente não é imune a críticas – ao menos serve para chamar a atenção para o seguinte problema: é certo pensar que a verossimilhança preponderante é um estado de dúvida, que assim impede a formação da convicção judicial e deve conduzir à rejeição do pedido, ou esse grau de probabilidade, ainda que mínimo, significa que, na realidade, o juiz superou a dúvida, para concluir que o autor tem razão?

2.1.6. A Teoria de Gerhard Walter

Walter – processualista alemão que muito contribuiu para o estudo da convicção judicial – refere três métodos de constatação dos fatos: o modelo da convicção da verdade, o modelo de controle por terceiros e o modelo da verossimilhança, cuja variante mais importante seria o modelo da preponderância ²⁴².

A particularidade da sua tese, em relação às teses antes expostas, reside no fato de que ele pergunta se existiria um *princípio unitário, válido para todos os casos e procedimentos*, segundo o qual deveria ser feita a constatação dos fatos. Indaga, em outros termos, se aquilo que chama de “módulo da prova” *poderia variar conforme a situação concreta.* ²⁴³

Comparando a convicção judicial no processo penal e no processo civil, afirma Walter que, *se a presunção de inocência que emana do princípio do Estado de Direito não deve ser desvirtuada apenas por ser muito verossímil a culpabilidade do acusado, o princípio do Estado Social seria invalidado se, para a prova de um acidente de trabalho ou do direito a uma pensão, fosse exigido o mesmo grau de certeza do processo penal.* Nessa linha, conclui que, quando se determina o “módulo da prova”, não há como deixar de levar em conta a *matéria subjacente ao direito processual*, sob pena de os fins do próprio direito material serem desvirtuados, ou ainda de se entrar em choque com outros importantes princípios do direito. ²⁴⁴

Argumenta que, para se pensar na adequação e na legitimidade do módulo da prova, não basta considerar as linhas fundamentais da ordem jurídica, ainda que as mais elevadas, mas é também necessário analisar os propósitos que o legislador teve em relação a uma matéria concreta, seja quando a lei os mencione expressamente como fins, ou quando possam ser inferidos a partir das razões da lei ou do procedimento. *O módulo da prova dos procedimentos diferenciados tem que responder a esses fatores e, assim, ser variável.* ²⁴⁵

Afirma, então, que *não há como se pensar na aplicação de um modelo unitário, chamado “verdade”, para todas as situações concretas.* Não obstante – e aqui fica nítido o seu distanciamento em relação à tese da verossimilhança preponderante –, conclui, a partir da premissa de que o legislador alemão estabeleceu a necessidade de o juiz se convencer da verdade, que é inadmissível se pensar em reduzir, *para todas as situações concretas*, o módulo de prova. ²⁴⁶ Ou seja, o seu entendimento é de que nem o modelo da convicção de verdade, nem o modelo da verossimilhança preponderante (ou ainda o modelo de controle por terceiros), poderiam ser aplicados a todos os

casos.

A encruzilhada, posta no meio do desenvolvimento do seu raciocínio, impôs a análise acerca de quando o método da convicção da verdade pode ser dispensado em favor do método da verossimilhança. É quando demonstra a necessidade de um agrupamento dos casos que exigiriam a redução do módulo da prova.

Como exemplos de grupos de casos, ressalta: enfermidades profissionais; acidentes de trabalho; lesões pré-natais; casos de refugiados e de vítimas do nazismo; casos de seguros; trabalho perigoso; proteção do trabalhador contra a despedida; recusa ao serviço militar por razões de consciência; responsabilidade objetiva; infrações a determinados deveres.²⁴⁷ Adverte que esses casos não são taxativos. O seu objetivo é unicamente deixar claro o sistema subjacente. Os casos devem formar um campo que, diante de sua natureza, tem dificuldade de ser esclarecido. Ademais, o direito material deve deixar entrever que essas dificuldades de prova não devem ser suportadas pela vítima.²⁴⁸

Walter, ao lembrar que os tribunais alemães reduzem o módulo de prova nas decisões em que a apuração dos fatos resulta em especiais dificuldades – e ao apontar para as indenizações pagas às vítimas do regime nacional socialista e aos refugiados, e, ainda, para os casos em que, por razões de consciência, a pessoa se nega a prestar o serviço militar –, afirma que, diante da diversidade dos casos que se deve solucionar e dos fatos que se deve esclarecer, e, sobretudo, levando-se em consideração as consequências que as decisões acarretam, *não há sentido em insistir em um módulo da prova unitário* ²⁴⁹.

2.1.7. Objeções à Teoria da Verossimilhança Preponderante

Não há como negar que o juiz não pode apreender a verdade absoluta e que a prova não pode ser pensada como meio capaz de reconstruir de forma cabal os fatos da causa. Isso não significa, entretanto, conforme já dito, que o juiz não deva procurar se convencer a respeito da verdade.

Ou melhor, não é porque a verdade do processo é construída através das narrativas oriundas da participação das partes e da percepção do próprio juiz e, nesse sentido, não pode ser confundida com a verdade absoluta dos fatos – que é inatingível –, que o juiz pode definir o conflito de interesses com base na tese da verossimilhança preponderante, como pretendia a doutrina sueca e parte da doutrina alemã. O juiz, ainda que não possa buscar, na perspectiva gnosiológica, a verdade absoluta dos fatos, evidentemente não pode abrir mão da necessidade de se *convencer* para julgar o mérito.

Aliás, mesmo aqueles que desejam que o juiz dê ganho de causa à parte cujo direito é mais verossímil encontram um obstáculo insuperável na sustentação dessa teoria. É que não é possível medir, em termos matemáticos, a graduação de uma prova ou de um conjunto de provas, o que impediria a devida justificação da “verossimilhança preponderante”. É preciso que exista algo externo à prova para justificar a redução da sua exigência.

De qualquer forma, não há como negar a obviedade de que o juiz, para julgar adequadamente, deve buscar se *convencer* da verdade.²⁵⁰ Ora, supor que o juiz, *em regra*, deve proferir a sentença com base na verossimilhança que preponderar é simplesmente imaginar que o juiz não precisa se convencer para julgar.

Não há dúvida de que *a dificuldade de prova e a natureza do direito material* podem justificar a redução das exigências de prova *no caso concreto*, dando ao juiz a possibilidade de se contentar com a verossimilhança. *Mas isso somente pode ser admissível em casos excepcionais* – e não como regra.

A probabilidade somente pode ser vista como regra no juízo fundado em cognição sumária, ou melhor, quando o juiz deve decidir antes de dar às partes a devida oportunidade de participação, como acontece na antecipação da tutela, que se funda em probabilidade. Mas isso não é decorrência da dificuldade de prova ou da natureza do direito material discutido, mas sim uma

limitação derivada da postecipação do contraditório, isto é, de uma limitação à participação imposta pela própria lei processual.

2.1.8. O Convencimento Judicial e a Regra do Ônus da Prova

Como é sabido, em casos excepcionais o juiz pode julgar fundado na dificuldade da prova e nas particularidades do direito material com base em verossimilhança.

Mas, por enquanto, é oportuno tratar da questão relativa ao julgamento com base na regra do ônus da prova, ou mais precisamente, da situação em que o juiz, *por não ter se convencido* de que o autor provou o fato constitutivo, proferiu a sentença afirmando que a regra do ônus da prova não foi observada.

É claro que o juiz, quando não convencido pela prova das partes, pode determinar prova de ofício. Acontece que essa possibilidade pode não ser suficiente para permitir a elucidação de todos os casos concretos, especialmente porque, na maioria das vezes, não há outras provas a produzir ou o juiz desconhece os meios de prova que efetivamente podem auxiliar. Portanto, a tão decantada tese de que o juiz deve determinar prova de ofício deve ser vista como uma ideia simplista e ingênua, caso tenha a pretensão de se constituir em uma alternativa ao julgamento baseado na regra do ônus da prova.

Em alguns casos, o juiz pode estar em estado de dúvida no momento de sentenciar. Nessas hipóteses, se a dificuldade da prova e as características do direito material em litígio não justificarem a chamada “redução do módulo da prova” ou a modificação do ônus da prova, não resta outra saída ao juiz senão julgar improcedente o pedido com base na regra do ônus da prova.

Portanto, *além de ser falsa a suposição de que o juiz sempre julga depois de “ter descoberto a verdade”, é impossível afirmar que o juiz pode deixar de julgar por não estar convencido*. Salaverría lembra que, se é possível esperar até o final dos tempos a solução definitiva do debate a respeito do local em que nasceu Colombo, um conflito obviamente não pode ser colocado no congelador até que surja uma informação capaz de permitir a sua solução à distância de qualquer dúvida. Como lembra Salaverría, os assuntos submetidos ao juiz – como a maioria dos concernentes à vida prática – devem ser resolvidos imperiosamente em um prazo de tempo²⁵¹.

Não há mais como supor que a decisão jurisdicional encontre apenas fundamento na verdade absoluta. A convicção do juiz se faz a partir da argumentação e das provas trazidas ao processo, inclusive as determinadas de ofício, o que *gera uma verdade reconstruída a partir das narrativas formuladas no processo*. O que legitima a decisão jurisdicional é a *orientação à verdade* que deve nortear a atuação do juiz e a devida participação das partes e do juiz, ou melhor, a observação das *próprias regras que criam as balizas para a reconstrução da verdade processual*.

2.2. Fundamentação e Prova

Nada obstante a *valoração da prova* seja livre pelo juiz, já que o direito brasileiro adotou – e continua adotando, conquanto a supressão do adjetivo “livre”, tendo em conta que a eventualidade de ter o juiz de escolher entre duas versões probatórias é ineliminável – a regra da livre valoração da prova (art. 371, CPC), as razões que fundaram o seu *convencimento* a respeito da prova devem constar da fundamentação da sentença. É por essa razão que se diz que o juiz tem de estar *racionalmente convencido* das alegações de fato à luz do conjunto probatório. A aferição da racionalidade do convencimento do juiz ocorre mediante a análise da fundamentação da sentença no que tange à prova²⁵².

2.2.1. O Relatório dos Fatos Controvertidos e das Provas das Partes

O art. 489, I, CPC, é expresso em exigir como um dos elementos essenciais da sentença “o relatório, que conterà os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo”.

Na perspectiva do discurso do caso concreto, isto é, da fundamentação da sentença, pouca coisa pode interessar mais ao relatório do que a definição dos fatos controvertidos e das provas admitidas e produzidas. Não há dúvida que a fixação dos pontos controvertidos, que deve ser feita na fase de organização do processo (art. 357, CPC), é imprescindível para o juiz deixar claro o que deve ser elucidado na instrução. Diante disso, torna-se também fundamental que a sentença relate as provas que foram admitidas, produzidas e justifique como foram valoradas.

A relação entre as provas admitidas e as produzidas é importante para destacar a razão pela qual a parte, apesar de ter a prova admitida, não a produziu, e qual o significado que daí se pode extrair. Por outro lado, a relação entre a prova produzida e a valorada permite à parte controlar se o juiz valorou todas as provas produzidas e, até mesmo, se valorou alguma prova que não foi produzida. Essa última necessidade deixa de ser meramente fantasiosa quando se constata o caso lembrado por Salaverría, em que a Corte de Cassação italiana se baseou no depoimento de uma testemunha – fundamental para o deslinde da causa – que havia falecido dezessete anos antes de o processo ser instaurado²⁵³. Ademais, o relatório das provas valoradas também tem importância para permitir a eventual identificação de provas ilícitas ou que foram produzidas em desrespeito às regras processuais ou ao direito ao contraditório.

2.2.2. A Explicação e a Contextualização do Conteúdo e do Significado das Provas

Contudo, não basta apenas elencar as provas produzidas e valoradas. Ao juiz cabe explicar e contextualizar o conteúdo e o significado das provas e do conjunto probatório, sob pena de a indicação dessas provas perder em importância.

Isso para que o juiz não incorra no equívoco de motivar a sentença com base em prova substancialmente diferente da produzida. Não é incomum, na prática, sentenças fundadas em quesitos periciais que não retratam as respostas que estão nos autos ou mesmo sentenças que distorcem depoimentos testemunhais.

Porém, a exigência de explicação e contextualização do conteúdo e do significado das provas se relaciona mais de perto à necessidade de o juiz expor o seu entendimento sobre elas, imprescindível para o controle da racionalidade do seu raciocínio. Essa última situação é especialmente ligada aos casos em que a prova é dúbia, seja por apontar em um ou mais sentidos, seja por conduzir a um resultado que possa sustentar duas ou mais hipóteses.

Nesses casos, o juiz deve referir a “dubiedade da prova”, embora essa possa sempre pender mais para um sentido ou hipótese. É que as provas, além de exigirem valoração individual, devem ser valoradas conjuntamente, ocasião em que todas as valorações individuais são relacionadas entre si. A valoração conjunta não depende apenas da valoração de cada uma das provas, mas de um efetivo diálogo entre as valorações individuais, capaz de permitir ao magistrado chegar a um juízo acerca de todas as provas produzidas.

2.2.3. A Motivação da Prova indiciária e da Presunção

Como demonstrado no capítulo sobre prova, o indício é um fato que serve para o juiz se orientar a respeito do fato probando (essencial), enquanto *a prova indiciária é aquela que se destina a prová-lo*. De modo que tudo o que foi dito sobre a necessidade de referir as provas e seus conteúdos vale para as provas indiciárias. A diferença é a de que, aqui, há um *elemento* entre a prova e a convicção *final do julgador*. Trata-se da *presunção*, que, embora também constitua um juízo, constitui um verdadeiro argumento para a convicção do juiz.

Para a formação da presunção não basta apenas o indício e a prova indiciária, pois a presunção é o resultado do raciocínio judicial que, considerando a prova do indício, daí extrai, por dedução, o fato probando. Como a presunção é o resultado desse raciocínio judicial, é preciso considerá-la de forma individualizada e ao lado das demais provas e de outras eventuais presunções. Em outros termos: embora a presunção exija um juízo individual, ela faz parte do conjunto probatório.

Além disso, ainda que, a princípio, a presunção deva ser estabelecida em um momento

cronológico anterior ao da apreciação do conjunto probatório, isso não elimina a possibilidade de o próprio raciocínio presuntivo (necessário para a formação da presunção) considerar as demais provas. Ou seja, o fato de a presunção exigir um raciocínio atento a fato e prova determinados (indiciários) e, particularmente, regras de experiência que a ela digam respeito, não impede que o raciocínio presuntivo considere as demais eventuais presunções e outras provas.

2.2.4. Motivação não é apenas se Basear nas Provas que Convergem na Direção da Hipótese Vencedora

Na prática forense, são usuais as sentenças motivadas *somente* com base nas provas que demonstram a hipótese vencedora. Alguém dirá que isso é normal, pois o juiz, quando motiva, deve justificar a razão pela qual optou pela versão de uma das partes.

Porém, embora o que ocorra na prática possa parecer lógico, o certo é que o juiz não justifica as suas razões apenas ao aludir às provas produzidas por uma das partes. Para que possa realmente justificar a sua decisão, o magistrado não pode deixar de demonstrar que as eventuais provas produzidas pela parte perdedora não lhe convenceram.

Aliás, a prova requerida e produzida pela parte vencedora pode favorecer à perdedora, *ainda que em parte*. Nesse caso, fica ainda mais claro que o juiz não pode tomar em conta apenas parte da prova, uma vez que a função da motivação não é de demonstrar *uma escolha*, mas sim a de justificar *porque foi feita uma determinada escolha*.

Lembre-se do que ocorre com muita frequência em relação às provas testemunhais. Diante dessas, muitas vezes o juiz procura recortar os depoimentos das testemunhas para dar ênfase aos trechos que demonstram a hipótese vencedora. Acontece que o juiz não pode considerar uma parte do depoimento e esquecer a outra, como estivesse justificando a versão do vencedor. Desse modo o juiz não justifica as suas razões, mas sim simplesmente elege as razões de uma das partes. Por isso, é preciso eliminar a ideia de que justificar a decisão é o mesmo do que lembrar as provas e argumentos que servem ao vencedor.

Na verdade, a necessidade de o juiz justificar as suas próprias razões, demonstrando o motivo pelo qual prefere uma prova em relação à outra, nada mais é do que um corolário do direito à prova, uma vez que, como é evidente, o direito a provar não se resume à possibilidade de produzir prova, mas também ao direito de ter essa prova valorada, pouco importando qual venha a ser o sentido da decisão judicial²⁵⁴.

Aliás, nesse sentido nos parece correta a advertência, já feita em sede doutrinária, de que a motivação é mais importante para o perdedor do que para o vencedor.²⁵⁵ A motivação importa mais para o perdedor não apenas porque é ele que pode recorrer, mas especialmente porque é o perdedor que pode não se conformar com a decisão e assim ter a necessidade de buscar conforto e explicação na justificação judicial.

Além disso, não há como esquecer a obviedade de que a motivação também se dirige aos terceiros, isto é, ao público, que tem o direito de conhecer as exatas razões do juiz, além de ser imprescindível para o controle do seu poder²⁵⁶. É evidente que o juiz que nada fala sobre as provas que foram produzidas ou beneficiam a parte vencida, nada explica aos terceiros e foge do controle sobre o seu poder.

Frise-se, por fim, que a sentença, por ser *resultado de um diálogo pautado na lógica e na argumentação* (arts. 7.º, 9.º, 10, 11 e 489, § 1.º, IV), obviamente deve justificar as razões pelas quais os argumentos de uma das partes são rechaçados em prol da outra.

2.2.5. A Necessidade de Motivação de Todas as Provas Produzidas

Nessa altura, não deve mais existir dúvida sobre a necessidade de o juiz explicar as razões pelas quais não acolhe as provas do perdedor. A razão desse tópico é outra. O seu objetivo é enfrentar a propalada possibilidade de o juiz deixar de valorar as chamadas provas *supérfluas*.

E possível que o juiz, após a definição dos fatos controversos, permita que a testemunha aborde um fato reputado incontroverso. Alguém poderia dizer que isso não traria prejuízo à cognição dos fatos e que assim não haveria motivo para obstaculizar esse comportamento. Porém, permitir que a prova testemunhal recaia sobre um fato incontroverso é certamente retirar da parte a quem beneficia a incontrovérsia a possibilidade de produzir provas em relação a esse fato. Isso viola o direito ao contraditório, vale dizer, o direito de participar adequadamente do processo (arts. 7.º, 9.º e 10, CPC).

Não obstante – e isso deve ficar claro –, não é por isso que o juiz pode se calar sobre tal parte do depoimento testemunhal, *raciocinando como se ele não existisse*. Cabe ao juiz, nessa situação, *explicar as razões que impedem que essa parte do depoimento possa servir para apoiar a hipótese contrária à decisão – proferida na fase de organização do processo – que reputou o fato como incontroverso*.

Também não é impossível que o juiz admita a produção de prova em relação a um fato impertinente ou irrelevante ou mesmo uma prova irrelevante ou incapaz de propiciar a elucidação dos fatos. É certo que, nesses casos, a situação é diferente, pois a prova foi expressamente admitida no processo.

Entretanto, não há como obrigar o juiz a ter um fato como pertinente ou relevante quando verifica, ao final do procedimento, que ele não possui uma dessas qualidades. O mesmo ocorre, como é óbvio, em relação às provas irrelevantes e inidôneas ao objetivo a que se destinam.

Acontece que a existência de provas que – com um nome abrangente – *podem ser ditas “supérfluas”, porque incapazes de alterar a convicção judicial, não dá ao juiz a faculdade de se omitir sobre elas.*²⁵⁷ Se isso fosse viável, isto é, se bastasse ao juiz se calar diante de uma prova que reputa supérflua, *seria impossível saber quando a sentença se omitiu por entender a prova supérflua ou quando a esqueceu ou mesmo quando a encobriu para melhor justificar a hipótese do vencedor*²⁵⁸.

2.2.6. Raciocínio Probatório, Decisão e Justificação

É importante distinguir o raciocínio que se faz sobre a prova (probatório), o raciocínio para decidir (decisório) e o raciocínio para justificar a decisão (justificatório). É certo que os dois primeiros têm pontos de contato, pois o juiz raciocina a respeito da prova para decidir. Porém, muitas vezes o juiz faz um raciocínio a respeito dos fatos e das provas sem que com ele possa imediatamente decidir. Por isso, não há como deixar de ver distinção, de um lado, entre raciocinar sobre a prova para posteriormente decidir e, de outro, raciocinar, ainda que sobre a prova, decidindo.

A análise da credibilidade da prova, da relação entre as provas e os fatos e das presunções constitui um *raciocínio que antecede a decisão*, enquanto, através do raciocínio decisório, o juiz analisa o conjunto probatório ou outros critérios que lhe permitam decidir. Embora os raciocínios probatório e decisório pareçam se identificar, é bem mais fácil separá-los do raciocínio justificativo, uma vez que, após o juiz ter raciocinado sobre as provas e chegado à sua decisão, resta-lhe *apenas justificar*.

Não há dúvida que a análise das provas e a respectiva decisão devem ser guiadas por critérios racionais. Isso, porém, não elimina a necessidade de o juiz justificá-los. Nesse sentido, há uma brutal diferença entre os critérios de análise probatória e de decisão e os argumentos de justificação.

A diferença entre esses critérios e os argumentos de justificação está presente na radical distinção de natureza entre o raciocínio que trabalha com tais critérios e aquele que se vale dos argumentos justificativos. Quando se pensa, por exemplo, na credibilidade de uma prova, ou mesmo em um critério de decisão, realiza-se um raciocínio que se coloca frente a duas opções e deve escolher uma delas, ao passo que, quando se está diante do raciocínio justificativo, *não há mais o que escolher, pois é apenas necessário justificar, mediante argumentos, os raciocínios que antes foram feitos e que levaram à decisão*.

E óbvio que a distinção entre essas modalidades de raciocínio não quer dizer que a racionalidade da justificativa não deva ter base na racionalidade dos raciocínios que conduziram à decisão. A justificativa não exclui a necessidade de racionalidade de critérios probatórios e decisórios. A justificativa, *apesar de comprometida com as opções* derivadas dos raciocínios que lhe antecederam, *deve expressar as razões que levaram às conclusões dos raciocínios sobre as provas e para a tomada da decisão.*

Alguém poderia dizer, é certo, que uma justificativa racional pode esconder critérios probatórios e decisórios irracionais, e que a racionalidade desses critérios não excluiu uma justificativa fundada em argumentos não racionais. Porém, essa lembrança, ao contrário de invalidar a distinção entre os raciocínios, a confirma ainda mais.²⁵⁹

2.2.6.1. A Justificação da Credibilidade da Prova

Toda prova impõe ao juiz o dever de relacioná-la com o fato que deseja evidenciar. Isso ocorre, com maior clareza, no caso da prova de um fato essencial, mas também está presente quando se pensa na prova de um fato indiciário, uma vez que, antes de o juiz poder raciocinar a partir do fato indiciário para o fato essencial, deve concluir a respeito da relação entre a prova indiciária e o indício (fato indiciário).

Antes de o juiz estabelecer a ligação entre a prova e o fato, deve valorar a credibilidade da prova. Não se trata de valorar se a prova identifica o fato, mas sim se o documento é formalmente exato ou se o perito e a testemunha são idôneos, ou mesmo se a prova pericial e a prova testemunhal têm saliências que retirem a sua credibilidade.

Convém lembrar, desde logo, que o perito pode ser recusado por impedimento ou suspeição (art. 467, CPC) e ainda ser substituído quando carecer de conhecimento técnico ou científico (art. 468, CPC) ou evidentemente de idoneidade moral. No que diz respeito à testemunha, a parte pode contraditá-la, arguindo a sua incapacidade, impedimento ou suspeição (art. 457, § 1.º, CPC). Além disso, o juiz pode, de ofício ou a requerimento, determinar “a acareação de duas ou mais testemunhas ou de alguma delas com a parte, quando, sobre fato determinado, que possa influir na decisão da causa, divergirem as suas declarações” (art. 461, II, CPC).

Mas isso não basta para o controle da credibilidade da prova. A prova pericial está sujeita a pedidos de esclarecimentos pelas partes e pelo juiz (art. 477, § 2.º, CPC) e, excepcionalmente, pode abrir ensejo a uma segunda perícia, que, segundo o art. 480, § 1.º, CPC, “tem por objeto os mesmos fatos sobre que recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu”. Enquanto isso, se um dos motivos que apontem para incapacidade, impedimento ou suspeição for revelado apenas no curso do depoimento, é claro que ele deve ser tomado em consideração. Aliás, o juiz deve atentar para as condições mentais e psicológicas do depoente e para a lógica do seu depoimento, com o objetivo de detectar eventuais desvios de memória e contradições conscientes ou inconscientes da testemunha.

Para a valoração da credibilidade da testemunha, o juiz tem que se valer das regras de experiência comum, o que, obviamente, deixa o seu raciocínio muito longe de um simples esquema dedutivo-demonstrativo. Mas isso não quer dizer que o juiz fique impedido de justificar racionalmente a sua valoração e que, assim, a sua decisão possa ficar ausente de controle. O real problema, como é fácil perceber, consiste na determinação e no correto emprego dos critérios capazes de propiciar uma adequada valoração da testemunha.²⁶⁰ Para exemplificar, basta lembrar que Taruffo, ao aludir a tais critérios, afirma que não se pode excluir, a princípio, o recurso a perícias que ajudem o juiz a valorar a credibilidade de uma testemunha, ao menos quando essa valoração seja particularmente difícil e delicada²⁶¹.

Qualquer circunstância que aponte para a desestabilização da prova deve ser revelada na motivação da sentença, ainda que não interfira na sua valoração individual ou no resultado do julgamento. Ou seja, ainda que uma “anormalidade” não retire a credibilidade da prova, e assim permita a sua relação com o fato, ou mesmo que a credibilidade da prova ou a própria prova do fato não sejam capazes de propiciar um julgamento favorável à parte que nela possui interesse, o

juiz não pode deixar de aludir a essa circunstância na sua motivação.

Em suma: antes de se tentar ligar a prova ao fato é preciso analisar a sua credibilidade, pois a prova somente pode provar depois de ter sido aprovada, ou, como salienta Iacoviello, “toda prova, antes de provar, deve ser provada”²⁶².

2.2.6.2. A Credibilidade da Prova e a sua Valoração Individualizada

A credibilidade da prova tem relação com a sua idoneidade. Assim, a prova pericial que contém contradições que inviabilizam a sua própria prestabilidade para o esclarecimento do fato, do mesmo modo que o depoimento que contém em seu bojo graves contradições, *não passam pelo teste de credibilidade e, assim, sequer podem ser relacionados com o fato que almejam elucidar*.

Embora a situação seja diferente quando a prova é considerada idônea ou crível, nesse caso o juiz deve valorá-la individualmente para apenas depois considerar todas as provas e presunções e, assim, o conjunto probatório.

Portanto, antes da valoração do conjunto probatório, o juiz deve estabelecer a relação entre a prova e o fato essencial e a prova e o fato indiciário, ligando mentalmente, nessa última hipótese, o fato indiciário (quando reputado provado) com o fato essencial para estabelecer a presunção. Essa prévia análise, assim, não tem a ver com o raciocínio que o juiz faz ao valorar o conjunto probatório. Somente existe um conjunto probatório a partir da definição das provas e das presunções. *Note-se bem:* não apenas depois da definição da credibilidade da prova, mas sim após a conclusão de que uma prova pode, ou não, demonstrar um fato ou indicar uma presunção.

O que indica, de forma clara, que o sentido de uma prova ou presunção estabelecido previamente pelo *raciocínio do juiz* é simplesmente a existência de várias provas e presunções.

Contudo, essa separação entre a valoração individualizada e a valoração do conjunto probatório não elimina a possibilidade de o “sentido” de uma prova ou de uma presunção ser estabelecido com o auxílio das outras provas e presunções.

2.2.6.3. O Percurso do Raciocínio do Juiz entre a Prova e o Fato

Não há como ignorar a diferença entre a prova com a qual o contato do juiz é imediato (inspeção judicial) e a prova intermediada (por exemplo, prova testemunhal).

Nesse último caso, o juiz deve analisar a credibilidade da prova antes de relacioná-la com o fato. Isso porque a segurança da ponte mental entre a prova e o fato depende da real idoneidade da prova.

Não obstante, uma vez estabelecida a idoneidade da prova, o juiz deve ligá-la ao fato que se propõe a demonstrar. Ou seja, após o juiz ter conferido credibilidade à prova, o seu raciocínio deve estabelecer a ligação entre essa e o fato, seja essencial ou indiciário.

No que diz respeito ao fato que a prova se propõe a demonstrar, o raciocínio do juiz caminha apenas entre a hipótese fática e a prova, uma vez que a relação entre esses dois elementos é proposta de forma antecedente no plano lógico-semântico. Assim, tal raciocínio é o que basta para unir os dois elementos, sem necessidade de maior complexidade.

O raciocínio judicial que liga a prova ao fato essencial possui a mesma estrutura daquele que se coloca entre a prova indiciária e o fato indiciário. Nesse último caso, porém, o juiz vai além, uma vez que, após concluir que o fato indiciário está provado pela prova indiciária, o seu raciocínio deve ir adiante para estabelecer a relação inferencial entre o fato indiciário e o fato essencial (presunção). É que, no caso de fato indiciário, não basta relacionar o fato com a prova, sendo necessário ao juiz estabelecer – através de raciocínio que chamamos de presuntivo – uma relação inferencial entre o fato indiciário e o fato essencial.

2.2.6.4. O Raciocínio entre o Indício e o Fato Essencial

Nesse percurso entre o indício e o fato essencial, através do qual se olha para a presunção, o juiz precisa de bases para o seu caminho. Ou melhor: o juiz, para verificar se o indício aponta, e em que medida, para o fato essencial, deve se orientar por critérios, que são chamados de regras de experiência²⁶³.

Não é difícil perceber que, se as regras de experiência guiam o raciocínio presuntivo, é preciso controlá-las. Diante disso, impõe-se imediatamente a conclusão de que as regras de experiência, sejam quais forem, devem ser precisamente relatadas e motivadas na decisão para que seja possível controlar o poder do juiz, basicamente a consistência da sua base empírica e eventual arbitrariedade na sua utilização²⁶⁴.

Acontece que a motivação, no caso, depende da adequada valoração das regras de experiência incidentes no caso concreto. Nessa perspectiva, cabe distinguir as regras de experiência comum e as regras de experiência técnica. As primeiras, segundo o art. 375, CPC, são “subministradas pela observação do que ordinariamente acontece”. Ora, aquilo que “ordinariamente acontece” tem, em princípio, um valor menos crível do que as regras de experiência técnica. Mas, para que essa separação fique mais compreensível, é preciso dar significados às regras de experiência “comum” e às regras de experiência “técnica”.

As regras de experiência técnica podem variar de uma posição firmemente aceita na comunidade científica, passando por definições ainda discutidas pela ciência, e chegando a observações do que ordinariamente acontece no manuseio de algumas técnicas – essa última situação em que na verdade se discute se as regras de experiência têm natureza técnica ou comum.

Em relação à primeira hipótese, ainda que essa seja a regra de experiência que melhor possa explicar a presunção, nem sempre há consenso a respeito de uma regra científica. Portanto, parece ser inadequada a solução que já foi utilizada no direito estadunidense, no sentido de determinar a credibilidade da regra técnica a partir do seu *consenso* na esfera científica – por meio do que se denominou de *general acceptance test*.²⁶⁵ Aliás, esse critério já foi desacreditado nos Estados Unidos por não permitir a consideração de “descobertas” novas e originais, *ainda não amplamente aceitas pelos cientistas*.²⁶⁶

A exigência de consenso, além de não permitir a consideração de boa parte das situações concretas, encontra o seu maior equívoco na falta de constatação de que a regra de experiência não precisa ter precisão absoluta e, mais do que isso, que é quase impossível se dar credibilidade absoluta a uma regra de experiência ou mesmo a uma prova de um fato direto.

Como a presunção faz parte da valoração probatória, ela deve ser relacionada com outras eventuais presunções e provas e por essa razão não há qualquer sentido em se impor uma regra de experiência de validade universal. O que importa é estabelecer o grau de aceitabilidade da regra na comunidade científica²⁶⁷ (e, como antecedente, logicamente verificar se a técnica foi difundida em congressos e em revistas científicas especializadas), quem são os cientistas que a aceitam (se têm maior ou menor reconhecimento na comunidade) e, ainda, fixar qual é a exata discussão sobre ela.

Ao utilizar a regra de experiência técnica, o juiz deverá não apenas referir e explicar a regra científica, como também precisar o grau e a qualidade da sua aceitação, além de contextualizá-la em face do litígio e das eventuais outras provas e presunções. Além disso, nada impede que o juiz, nessa situação, determine a oitiva de um perito da sua confiança sobre a circunstância, dando às partes a oportunidade de indicar assistentes técnicos. Nada impede igualmente que determine, se o caso comportar, prova técnica simplificada (art. 464, §§ 2.º e 3.º, CPC).

Vejamos, agora, a terceira hipótese, isto é, as regras que decorrem da observação do que ordinariamente acontece no manuseio de algumas técnicas. Aqui, ao contrário do que se pode supor, não há regra de experiência técnica, mas sim regra de experiência comum relacionada ao uso de alguma técnica, o que é algo completamente diferente. Portanto, é o momento de passar a enfrentar os critérios que podem gerar credibilidade nas regras de experiência comum.

As regras de experiência comum têm relação com condutas individuais e sociais que se fundam em leis supostamente científicas, em observações da natureza, ou em outras regras vulgarizadas na sociedade.

É claro que o emprego dessas regras e das regras de experiência técnica *deve ser motivado, até para que se verifique em que o juiz se fundou e a partir de que razão. O problema é justamente o de saber se essa “razão”, a que o magistrado se apegou, merece credibilidade*. Nessa dimensão, é preciso que o juiz explique o sentido da regra de experiência, para se evitar que a ela seja atribuído um significado que não possui.

Antes de tudo, porém, é necessário frisar que a regra de experiência comum deve ser aceita na sociedade em que a decisão vai ser tomada. Quando há dúvida sobre a aceitação da regra pelo senso comum, é racional considerá-la como destituída de legitimação *in re ipsa* e dessa forma como carecedora de própria e específica confirmação ou justificação.²⁶⁸ Como diz Taruffo, somente as noções e informações que são clara e evidentemente patrimônio da cultura média do ambiente social em que a decisão é proferida podem ser utilizadas sem justificação específica, ao menos até que não sejam adotadas razões convincentes capazes de excluir o seu emprego²⁶⁹.

A partir daí, é preciso verificar se a regra de experiência eventualmente *colide* com uma regra de experiência técnica ou outra regra de experiência comum. Tratando-se de colisão com regra de experiência técnica, há de prevalecer essa última, pois seria completamente irracional aceitar a possibilidade de o juiz se valer de uma regra de experiência comum desacreditada pela ciência²⁷⁰.

Mas nada impede que uma regra de experiência comum entre em choque com outra regra da mesma natureza. No caso em que duas regras de experiência comum estão à disposição do juiz, *não se pode admitir que ele possa escolher uma ou outra sem base ou critério racional, pois isso seria legitimar o arbítrio*.

A regra de experiência comum, colida com outra de igual natureza ou não, não pode fugir da ideia de probabilidade. Para tanto, é preciso analisar a sua base empírica, ou melhor, o número de vezes em que a hipótese nela consubstanciada se repete²⁷¹. O magistrado deve apontar as características da regra de experiência ao analisar o fato probando, não estando impedido, como já foi dito, de relacioná-la com outras provas ou presunções.

Aliás, verificando-se que determinada regra de experiência comum, diante de sua base empírica, possui exceções, torna-se indispensável estabelecer uma ligação entre elas, o contexto do litígio e todos os argumentos (provas etc.) das partes. Nesse caso, como a credibilidade da regra de experiência é *sensivelmente abalada*, a sua probabilidade resta ligada às demais circunstâncias do caso concreto²⁷².

2.2.6.5. Valoração Individual e Valoração Conjunta

Há uma nítida distinção entre a valoração individual da prova e a valoração do conjunto probatório.

A valoração individual tem o objetivo de verificar a relação entre certa prova e o fato. O que importa, nessa fase, é estabelecer se determinada prova demonstra a hipótese fática. Por isso, é acertado dizer que a própria valoração da prova se integra à fase da valoração individual, uma vez que tem a intenção de evidenciar a aptidão de uma prova específica para demonstrar um fato. A valoração individual, assim, somente viabiliza a constatação de que uma prova demonstra um fato em determinado sentido e grau (obviamente, não matemático).

É possível perguntar o local em que a presunção se insere entre a valoração individual e a valoração do conjunto probatório. Como dito, a presunção é um juízo e não uma prova. Trata-se de juízo que decorre de raciocínio (que chamamos de presuntivo) que parte da prova (indiciária) de um fato indiciário (indício). Nesse caso, considerada a prova do fato indiciário, o juiz raciocina, através de regras de experiência, para concluir se pode dele deduzir o fato essencial.

Não há qualquer dúvida que a valoração da prova indiciária é uma valoração individualizada. O problema é saber se valoração individualizada abarca a prova indiciária e a presunção (o juízo), ou se a presunção somente é formada quando da valoração do conjunto probatório.

Pois bem. A presunção encontra-se, no *iter* do raciocínio judicial, entre a valoração da prova indiciária e a valoração do conjunto probatório. Dessa forma, é antecedente à valoração do conjunto das provas. Nesse sentido, aliás, é mais exato concluir que a valoração do conjunto probatório é, na realidade, a valoração dos argumentos de convicção, aí incluídas as provas e as presunções.

É certo que determinado caso conflitivo pode comportar duas ou mais presunções, que assim podem convergir ou ter sentidos contrários. Nessa situação, como é evidente, a valoração do conjunto incluiu a valoração das presunções.

Não se pretende dizer, com isso, que uma prova ou uma presunção, após terem sido valoradas, não podem ser redimensionadas quando da valoração conjunta. O que se quer demonstrar, através da demarcação dos momentos de valoração, é que, dentro do raciocínio lógico, a valoração da prova, a valoração da presunção e a valoração do conjunto de argumentos têm momentos diferentes. Mas isso não teria maior importância se essa distinção não fosse fundamental para permitir o controle da racionalidade do raciocínio judicial.

Portanto, o que deve ficar claro é que a valoração individual e a valoração final não são excludentes – e esse, obviamente, não é o desejo de quem alude a elas – ou meramente complementares, mas sim dois momentos de um todo, ou algo que se forma a partir de partes inter-relacionadas²⁷³.

2.2.6.6. A Valoração Conjunta, o Encontro de Duas Narrativas Aceitáveis e a Reconstrução da Verdade no Processo

Alguém poderia dizer que a valoração conjunta deve conduzir a uma boa narrativa ou a uma narrativa convincente. Ainda que isso guarde uma boa dose de procedência, é preciso esclarecer que essa narrativa somente será convincente quando tomar em conta as valorações que lhe antecederam, isto é, as provas e as presunções.

A valoração conjunta propõe-se à reconstrução de uma narrativa de forma racional, para a qual é fundamental a atenção às provas e às presunções. Nessa altura, seria supérfluo dizer que essa narrativa deve levar em conta as presunções em sentido contrário e as provas da parte contrária.

Porém, não basta nem mesmo que o juiz se baseie nas provas e presunções, quando lhe é viável elaborar duas ou mais narrativas a princípio aceitáveis. Se as provas e as presunções permitem a elaboração de duas ou mais versões, cabe ao juiz estabelecer a melhor entre elas ou, como escreve Taruffo, a “melhor” narração possível entre aquelas que parecem sensatas em relação ao caso concreto²⁷⁴.

2.2.6.7. As Dimensões Analítica e Sintética

Como se pode perceber, agora o problema passa a ser o da fixação da melhor das versões. E, para tanto, mais uma vez surge a necessidade de critérios racionais justificáveis e controláveis. Para tanto, Taruffo propõe a distinção entre duas dimensões capazes de conduzir à escolha da melhor das versões, quais sejam as dimensões *analítica* e *sintética*²⁷⁵.

A primeira dimensão indica que o juiz deve escolher a versão que esteja baseada nas *provas* que outorguem convicção de verdade. As provas conferem a cada uma das várias hipóteses possíveis, relativas a cada um dos fatos, graus diversos de confirmação, sendo que a escolha *racional* deve ser a que prefere as hipóteses que geram, a partir dessas provas, a maior convicção e, por consequência, a versão que esteja mais profundamente ancorada nas provas disponíveis²⁷⁶.

Afaste-se a ideia errônea de que a dimensão *sintética* se destina à valoração conjunta das várias valorações que foram feitas em relação a cada uma das provas. Isso nada tem a ver com a dimensão sintética, pois é o *resultado* do emprego do método analítico, que, ao enfrentar cada uma das provas, pode chegar à versão mais fortemente baseada no conjunto probatório²⁷⁷.

Quando, a partir das provas, aparecem duas narrativas igualmente viáveis, surge a necessidade de estabelecer mais um método de escolha racional. É quando passa a importar a perspectiva *sintética*, entrando em consideração os critérios da *coerência* e da *congruência*²⁷⁸.

A dimensão sintética diz respeito à *melhor entre duas narrativas centradas sobre as provas*. Portanto, nessa dimensão não há racionalidade em preferir uma *narrativa*, cujos fatos careçam de prova ou se fundem em provas que ofereçam menor grau de convencimento²⁷⁹.

As dimensões analítica e sintética não se excluem. Trata-se de perspectivas e dimensões diferentes, destinadas a possibilitar uma escolha racional das hipóteses em confronto. A perspectiva sintética não constitui uma *alternativa* à analítica, mas sim uma perspectiva *complementar* que pode ser utilizada para uma *eventual* escolha – quando essa escolha for necessária, ou seja, quando dos fatos provados não decorrer apenas uma narrativa.

Mas, se as provas estabelecidas na dimensão analítica dão origem a várias narrativas, todas viáveis a partir das provas e relações de inferência fixadas, não resta alternativa a não ser escolher a narrativa que confira o maior grau de *coerência* e *congruência*.

2.2.6.8. Coerência Narrativa e Reconstrução da Verdade no Processo

Ainda que alguns sustentem, simplesmente, que o juiz deve escolher a narrativa de uma das partes, isto é, aquela que lhe parecer mais coerente independentemente das provas, não é possível ignorar que dessa maneira se admitiria que fosse possível escolher uma narração coerente, mas não verdadeira. Porém, a coerência narrativa tem relação com as diversas narrativas que podem ser propostas em relação a um caso, *a partir das provas estabelecidas* e, portanto, jamais se deve pensar que o critério da coerência é capaz de excluir a dimensão analítica.

Taruffo afirma que o processo não deve ter interesse nas narrações coerentes e falsas, mas deve ter nas narrações verdadeiras, ainda que incoerentes.²⁸⁰ Essa afirmação, contudo, deve ser mais bem ponderada.

É certo que a dimensão analítica prevalece sobre o critério narrativo, pois ninguém pode duvidar que o juiz deva preferir a versão ancorada nas provas. Acontece que uma versão, apesar de fundada nas provas, obviamente não tem que corresponder à verdade absoluta (até porque essa não pode ser penetrada) e, por essa razão, não há motivo para excluir a tese de que há uma verdade reconstruída no processo.

Essa verdade não precisa obviamente ser uma das propostas pelas partes, uma vez que o juiz pode reconstruir a sua, sem ter a necessidade de optar por uma das narrativas dos litigantes, pois nada impede – e até mesmo é comum – que o juiz aceite apenas parte da narrativa do autor e parte da narrativa do réu.

Isso quer dizer que a verdade do processo não precisa estar em uma das narrativas, pois dificilmente vai alcançar um *status* que seja diferente daquele da verdade no processo, que não pode se desligar da participação dialética das partes²⁸¹.

Ora, se o juiz não precisa se render a uma das narrativas das partes, não há como aceitar que ele possa admitir uma narrativa incoerente. O magistrado pode construir a sua própria versão com base nas provas e no critério da coerência, vistas essas dimensões como complementares e não como excludentes. Sendo a coerência um critério *complementar* ao analítico, o juiz jamais poderá negar a perspectiva analítica – e assim as provas – para preferir uma versão incoerente.

A menos que se pense em verdade e falsidade em termos absolutos – o que é totalmente

descabido. Ora, se o juiz não pode desprezar a dimensão analítica ao raciocinar sobre a coerência, é mais do que óbvio que não pode propor como coerente uma versão destituída de provas e, nesse sentido, falsa.

As ideias de narrativa coerente e falsa e de narrativa verdadeira e incoerente só fazem sentido quando se aceita a premissa de que o juiz deve optar por uma das narrações, sem poder reconstruir a sua.

2.2.6.9. A Coerência Lógica

Quando se pensa na versão a ser estabelecida, não se pode negar a importância da sua coerência lógica. Como demonstra Taruffo, relevam aí os elementos lógicos da versão, basicamente os relacionados à *ausência de contradição* e à *coerência inferencial* ²⁸².

Uma versão não contraditória não pode aceitar um mesmo fato como verdadeiro e falso, admitir fatos incompatíveis como verdadeiros ou empregar, em um mesmo contexto, regras de inferência também incompatíveis. Por outro lado, as inferências com que o juiz elabora as suas concatenações para ligar os fatos indiciários e essenciais, objetivando formar juízos a partir das provas, igualmente devem ser coerentes (coerência inferencial) ²⁸³.

Ainda que essas questões devam ser enfrentadas quando da fixação dos pontos controvertidos, da admissão e da valoração das provas e da elaboração das presunções, não há dúvida que a versão (das partes ou a fixada pelo juiz) não terá coerência lógica se contiver alguma dessas ilogicalidades – e, nessa linha, não poderá servir para fundar a sentença.

2.2.6.10. A Congruência

Congruente é a narração que reflete o conjunto dos fatos ou, em outras palavras, a que estabelece uma ligação com o conjunto dos fatos provados. A melhor versão, além de ausente de contradições, deve ser a que realmente *espelha* os fatos provados. A congruência, nesse sentido, é um teste de verificação da correspondência entre a narrativa judicial e os fatos provados.

Nessa perspectiva, Taruffo afirma que são incongruentes as narrativas incompletas ou “superabundantes”. ²⁸⁴

No caso em que uma prova, parcela de uma prova ou mesmo um fato provado não são tomados em consideração pela narrativa judicial há incompletude. Não é incomum, com efeito, sentenças que deixam de se referir a determinados depoimentos testemunhais, a parte deles, ou ainda a fatos provados.

Por outro lado, são muito frequentes as decisões que se referem apenas às provas que confirmam a versão da parte vencedora ou, o que é pior, decisões que retalham as provas para dar fundamento à versão do vencedor. Como é evidente, aqui não estamos na dimensão do raciocínio *decisório*, mas sim na do raciocínio *justificativo*, pois o juiz não está buscando critérios racionais para decidir, mas sim argumentos para justificar como decidiu. Porém, o fato de o juiz ter que justificar, e não mais decidir, não lhe dá o direito de apenas lembrar as provas que apontam na direção da versão da parte vencedora, como se justificar fosse somente argumentar em favor da parte que venceu, e não argumentar em favor da decisão mesma. Ora, se o juiz preferiu as provas “A” e “B” – que favorecem o autor – em detrimento da prova “C” – que beneficia o réu –, não basta fazer referência às provas “A” e “B”, sendo necessário explicar a razão pela qual a prova “C” não lhe convenceu.

Mas alguém poderia dizer que o juiz não precisa assim proceder, pois a aceitação das provas “A” e “B” implica rejeição implícita da prova “C”. Essa ideia, contudo, não pode ser aceita, pois não há como pensar em justificação implícita, que, na realidade, é uma maneira de acobertar a inexistência de justificação. Ora, é preciso que o juiz faça referência a todas as provas, explicitando os motivos que o levaram a acolher umas e não outras.

Não é possível identificar – embora lamentavelmente isso não seja incomum – a desnecessidade de o juiz enfrentar todos os fundamentos de direito da parte autora acaso acolha o primeiro deles com uma imprópria desnecessidade de o juiz analisar as provas que não beneficiam a parte vencedora. Quando um dos fundamentos de direito é suficiente para o acolhimento do pedido, não há razão para o juiz explicar porque o outro fundamento, também trazido pelo autor, não mereceu acolhida. No caso oposto ocorre o mesmo, pois, se um dos fundamentos leva à improcedência, não há porque justificar que os outros não levam.

Nessas situações, nenhum prejuízo é trazido à parte que articulou mais de um fundamento, diante da lembrança expressa contida no art. 1.013, § 2.º: “quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais”. Isso quer dizer que, se o tribunal chegar à conclusão de que o fundamento acolhido pela sentença não tem procedência, ele poderá apreciar os outros, ainda que a parte vencedora não tenha interposto recurso.

Caso o entendimento fosse no sentido de que o juiz deveria apreciar todos os fundamentos, ou o outro fundamento seria acolhido – e o pedido julgado procedente com base em dois fundamentos – ou rejeitado, quando a parte vencedora continuaria na mesma situação. A conclusão que daí se pode retirar é a de que não há motivo para a apreciação do outro fundamento, pois a sua não apreciação não prejudica as partes, *o que não acontece na hipótese de várias provas, umas favoráveis ao autor e outras ao réu. Ora, é claro que a parte perdedora tem interesse nas provas que lhe são favoráveis e, assim, tem direito de saber a razão pela qual elas não foram acolhidas.*

Por outro lado, também é incongruente, e nesse caso por “superabundância”, a narrativa que se refere a um fato alegado, *mas não provado*. Em tal hipótese a decisão estaria, no mínimo, ferindo a regra do ônus da prova.²⁸⁵

Como é óbvio, nada impede que uma mesma sentença sofra dos dois males, por não considerar uma prova ou um fato provado e admitir um fato não provado²⁸⁶.

2.2.6.11. A Integração entre os Métodos Analítico e Sintético

Se ninguém nega a importância da motivação como direito do cidadão, pouco importa alardear isso de forma demagógica. Se o juiz tem o dever de motivar a sentença, é preciso que ele possa decidir com base em *critérios racionais explicáveis*.

Ou melhor, é necessário que a decisão se funde em “critérios racionais” e, além disso, que esses sejam “racionalmente justificados ou explicados”. Como se vê, não basta apenas que a decisão se funde em *critérios racionais*, pois também é preciso a justificação desses critérios²⁸⁷.

A importância disso tudo, além de relacionada à legitimidade da função jurisdicional – uma vez que a justificação é imprescindível para o juiz dar conta das suas razões ao público –, *está em conferir ao litigante a possibilidade de controlar a decisão*. Quando do controle da racionalidade da justificação, será possível verificar se a versão fática está evidenciada por meio de provas e se os critérios empregados na sua valoração e na relação entre as várias hipóteses fáticas e as provas – especialmente as regras de experiência – são dotados de racionalidade.

Além disso, a justificativa judicial também poderá ser submetida aos exames da coerência e da congruência, pois não há cabimento em aceitar uma decisão que, a princípio, está ancorada em provas, se essa apresenta contradições (incoerência) ou, ainda, por exemplo, sofre do vício da incompletude (incongruência). De modo que, quando se pensa no controle da decisão, não há motivo para priorizar o método analítico em face do sintético.

Contudo, algo um pouco diverso acontece quando se pensa no *desenvolvimento do raciocínio judicial que conduz à decisão*. É que aí os métodos analítico e sintético têm a função de *viabilizar os raciocínios probatório e decisório e, dessa forma, a própria decisão*, ao passo que, *no controle da decisão*, a consideração de tais métodos tem o objetivo de permitir a verificação da racionalidade da justificativa. Perceba-se que, na primeira hipótese, o juiz deve *racionalizar o seu raciocínio para*

chegar à decisão e, na outra, o tribunal – ou alguém externo ao juiz – é que vai verificar se a justificativa é racional.

Quando o juiz está desenvolvendo o *raciocínio que objetiva culminar na decisão*, ele poderá pensar na coerência e na congruência das versões das partes e, inclusive, propor aquela que, nessa perspectiva, lhe parecer adequada. Mas, quando se toma em consideração a *justificativa* – que *trabalha com argumentos e não testando hipóteses* –, não mais importará a coerência e a congruência como métodos destinados a fornecer uma decisão – até porque esta já existe –, mas sim a coerência e a congruência como qualidades imprescindíveis à própria *justificativa*, cuja ausência pode ser apontada pelo tribunal em razão do recurso.

Os métodos analítico e sintético são sempre complementares, embora tenham *funções diferentes, diante do raciocínio decisório e do raciocínio justificativo*. Salaverría, sem atentar para a dupla função desses métodos, afirma que “la manera de justificar la verdad” de uma proposição “pasa por el test de la narración coherente”. O jurista espanhol, nessa perspectiva, está pensando no controle da decisão. Diz ele: “La coherencia no constituye la verdad pero la garantiza”.²⁸⁸ Ao que parece, essa afirmação supõe que a prova concretiza a verdade e a coerência lhe garante.

Acontece que a prova pode não permitir, por si só, nem mesmo o encontro da verdade no processo, pois podem existir, a partir dela, duas versões viáveis, quando tal verdade seria encontrada através do método sintético. Por consequência, ou precisamente pela razão de que a coerência também é um critério para a fixação da verdade processual, é equivocado dizer que ela serve apenas para “garantir a verdade”. *Ela serve, isto sim, para viabilizar a decisão e para permitir o controle da sua justificativa.*

2.3. Fundamentação e Direito

O Código de 2015 dedicou especial atenção à fundamentação da sentença no que tange à interpretação do direito. Tanto é assim que, além de ligá-la diretamente ao direito ao contraditório, referiu expressamente o que entende por uma *decisão não fundamentada*.

Diz o art. 489, § 1.º, CPC, que “não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência; III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo juiz; V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. Na sequência, o § 2.º desse mesmo artigo refere que “no caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão”.

Em outras palavras, para que uma decisão possa ser considerada *como fundamentada* à luz dos arts. 93, IX, CRFB, e 7.º, 9.º, 10, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º, CPC, exige-se: i) a enunciação das escolhas desenvolvidas pelo órgão judicial para, a) individualização das normas aplicáveis; b) verificação das alegações de fato; c) qualificação jurídica do suporte fático; d) consequências jurídicas decorrentes da qualificação jurídica do fato; ii) o contexto dos nexos de implicação e coerência entre tais enunciados e iii) a justificação dos enunciados com base em critérios que evidenciam ter a escolha do juiz sido racionalmente apropriada²⁸⁹.

A *necessidade de individualização das normas aplicáveis* repele a possibilidade de o juiz se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase (aqui entendida como simples reelaboração do texto legal com outras palavras) de ato normativo (art. 489, § 1.º, I, CPC). Isso porque para a individualização das normas aplicáveis é preciso em primeiro lugar explicar as razões pelas quais

as normas aplicadas servem para solução do caso concreto: isto é, é preciso mostrar por quais motivos as normas devem ser aplicadas. Se isso é verdade, é claro que a simples *transcrição* do texto legal – sem qualquer menção ao caso concreto – não serve para individualização do direito que deve ser aplicado.

A mesma observação vale para os casos em que o debate do caso concreto envolve a concretização de *termos vagos* (art. 489, § 1.º, II, CPC, presentes, por exemplo, nos conceitos jurídicos indeterminados e nas cláusulas gerais)²⁹⁰. Se não se outorga sentido ao termo vago e não se mostra a razão pela qual esse pertine ao caso concreto, a indeterminação normativa do texto impede que se tenha por individualizada a norma que será aplicada para solução da questão debatida entre as partes.

Do mesmo modo, também são problemas ligados à ausência de identificação das normas aplicáveis ao caso concreto aqueles oriundos da *invocação de precedente sem a devida justificação* da identidade ou semelhança entre os casos (art. 489, § 1.º, V, CPC) e da *omissão de justificativa capaz de levar à distinção* entre o caso sentenciado e o caso invocado como precedente ou *capaz de mostrar a superação* do precedente invocado pela parte, mas não aplicado (art. 489, § 1.º, VI, CPC).

Ainda, o processo de individualização das normas aplicáveis, dado que os arts. 9.º e 10, CPC, referem que “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida” e que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”, está condicionado a um *prévio diálogo* entre o juiz e as partes a respeito da *seleção do material* que servirá à interpretação e à aplicação do direito. Essa seleção, dimensionada a partir das manifestações das partes e eventualmente por indicações do juiz (*Hinweispflicht*), cria a *expectativa legítima* para as partes de que a decisão será fundamentada dentro da moldura delineada pelo debate processual.

Como já observamos, essa expectativa legítima constitui manifestação do direito à segurança jurídica no processo e veda a prolação de *decisões-surpresa* no processo. Daí que a necessidade de efetivo diálogo entre o juiz e as partes, tendo em conta o caráter lógico-argumentativo da interpretação do direito, repele que se possa considerar como fundamentada uma decisão que invoca “motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão” (art. 489, § 1.º, III, CPC) e que não enfrenta “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489, § 1.º, V, CPC).

Se determinada decisão apresenta fundamentação que serve para justificar qualquer decisão, é porque essa decisão *não particulariza o caso concreto*. A existência de *respostas padronizadas* que servem indistintamente para qualquer caso *justamente pela ausência de referências às particularidades do caso* demonstra a inexistência de consideração judicial pela *demanda* proposta pela parte. Com fundamentação padrão, desligada de qualquer aspecto da causa, a parte não é ouvida, porque o seu caso não é considerado.

A decisão judicial deve conter o enfrentamento de “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489, § 1.º, IV, CPC). Esse dispositivo, como já observamos, só pode ser compreendido adequadamente a partir dos novos contornos do direito ao contraditório – que de seu turno só encontram apropriada justificação a partir da adoção de uma perspectiva *não cognitivista da interpretação* judicial do direito.

Ao tempo em que se entendia o contraditório como algo somente atinente às partes e, portanto, em sentido fraco (contraditório como bilateralidade da instância), afirmava-se que o dever de motivação das decisões judiciais *não poderia ter como parâmetro para aferição de correção a atividade desenvolvida pelas partes em juízo*. Bastava ao órgão jurisdicional, para ter considerada como motivada sua decisão, *demonstrar quais as razões que fundavam o dispositivo*. Bastava a *não contradição* entre as proposições constantes da sentença. Partia-se de um *critério intrínseco* para aferição da completude do dever de motivação²⁹¹.

Ocorre que o entendimento dessa ordem *se encontra em total descompasso com a nova visão a*

respeito do direito ao contraditório. Se contraditório significa direito de influir (arts. 7.º, 9.º e 10, CPC), é pouco mais do que evidente que há de ter como contrapartida *dever de debate* – *dever de consulta*, de *diálogo*, de *consideração*. Como é de fácil intuição, *não é possível aferir se a influência foi efetiva, se não há dever judicial de rebate aos fundamentos levantados pelas partes*. Daí a razão pela qual não basta o critério da não contradição: além de não ser contraditória, a fundamentação tem a sua completude pautada também por um *critério extrínseco* – a consideração pelos argumentos desenvolvidos pelas partes em suas manifestações processuais²⁹².

É importante perceber, porém, que o art. 489, § 1.º, IV, CPC, *não visa fazer com que o juiz rebata todo e qualquer argumento invocado pelas partes no processo*. O Poder Judiciário tem o dever de dialogar com a parte a respeito dos *argumentos capazes de determinar por si só* a procedência ou improcedência de um pedido – ou de determinar por si só o conhecimento, não conhecimento, provimento ou desprovimento de um recurso. Isso quer dizer que todos os *demaís argumentos* só precisam ser considerados pelo juiz com o fim de *demonstração de que não são capazes de determinar conclusão diversa* daquela adotada pelo julgador.

Dentro de uma perspectiva não cognitivista da interpretação do direito, reconhece-se com tranquilidade que as decisões judiciais são formadas a partir de *escolhas interpretativas* que devem ser devidamente *justificadas* pelo órgão judicial. É certo que houve um tempo em que se imaginava que seria possível estabelecer uma univocidade de sentido textual da legislação, com o que não seria reconhecido qualquer espaço de discricionariedade ao juiz na interpretação do direito. Esse foi o tempo do cognitivismo interpretativo dos Oitocentos, influenciado pela cultura racionalista herdada dos filósofos iluministas dos Setecentos²⁹³.

É certo igualmente que determinadas concepções ainda hoje em voga a respeito do direito – como aquela que vê o direito a partir do conceito de integridade (“integrity”)²⁹⁴ – também pressupõem a inexistência de um espaço de escolha judicial no processo interpretativo. Essas concepções, porém, fecham os olhos para a dupla indeterminação do direito e apostam – como no caso de Ronald Dworkin – em uma insustentável possibilidade de demonstração de valores morais objetivos no processo da interpretação judicial do direito²⁹⁵. Ao negar a existência de escolhas no processo interpretativo, essas concepções negam igualmente a possibilidade de se estabelecer um controle intersubjetivo das razões a partir de pautas lógico-argumentativas.

A nossa perspectiva teórica, porém, não ignora a trivial constatação de que julgar significa decidir entre alternativas racionalmente aceitáveis²⁹⁶. Daí a razão pela qual uma decisão fundamentada deve conter a *justificação* dos enunciados com base em critérios que evidenciem ter sido a *escolha* do juiz racionalmente apropriada.

O art. 489, § 2.º, CPC, exemplifica como a fundamentação deve se dar em semelhantes hipóteses, valendo-se do *postulado da ponderação* – uma *norma sobre como aplicar outras normas* (normas de segundo grau ou metanormas)²⁹⁷. O legislador poderia ter exemplificado essa necessidade de justificação racional das escolhas interpretativas aludindo a outros postulados direcionados à aplicação de outras normas, como os postulados da *proporcionalidade* e da *razoabilidade* (mencionados no art. 8.º, CPC), da *concordância prática* ou da *proibição do excesso*. Poderia ter exemplificado inclusive com textos que dão lugar a *normas de primeiro grau*, que também dependem de escolhas racionais para adequada adscrição de sentido normativo²⁹⁸. Optou por fazê-lo em relação a ponderação.

Para que se possa compreender o significado do art. 489, § 2.º, CPC, é preciso em primeiro lugar entender a razão pela qual existem *normas que são dirigidas à estruturação da aplicação de outras normas*. Em segundo lugar, é preciso fazer um *acordo semântico* a respeito dos conceitos de *ponderação*, *proporcionalidade* e *razoabilidade* – para ficarmos com os exemplos lembrados pelo próprio Código. Somente depois de assentadas essas premissas é que será possível esboçar uma adequada interpretação desse dispositivo.

Existem normas que são destinadas a reger o caso concreto, ao passo que existem normas que visam viabilizar a interpretação e a aplicação de outras normas. No primeiro grupo entram as normas de primeiro grau – destinadas à aplicação ao caso concreto: sobre princípios e regras. No

segundo, as normas de segundo grau – destinadas à interpretação e aplicação de outras normas: os postulados hermenêuticos e os postulados aplicativos. Como as normas de primeiro grau relacionam-se entre si de diferentes maneiras, pode ocorrer de ser necessário guiar o processo de interpretação e aplicação a partir de um *determinado método*. Esse é justamente o papel dos postulados: servir como meio de *estruturação metódica* para interpretação e aplicação do direito²⁹⁹.

O Código de 2015 menciona expressamente três postulados normativos: proporcionalidade, razoabilidade e ponderação. A *proporcionalidade* é um postulado que visa estruturar a aplicação de duas normas que se encontram em uma *relação de meio e fim*. O objetivo é preservar o máximo possível do *princípio da liberdade*, restringindo-se a esfera jurídica de determinada pessoa apenas naquilo que for necessário para consecução do fim que deve preponderar. A proporcionalidade exige o exame de três diferentes elementos: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito³⁰⁰. A razoabilidade é um postulado que visa estruturar a aplicação de outras normas visando à harmonização e à vinculação à realidade. O objetivo é preservar o máximo possível o *princípio da igualdade*. A razoabilidade pode ser trabalhada em três acepções básicas: razoabilidade como *equidade* (em que a razoabilidade visa resolver um problema envolvendo uma *relação entre o geral e o particular*), como *congruência* e como *equivalência*.³⁰¹ A ponderação, por fim, é um postulado que visa *atribuir pesos* a elementos que se entrelaçam³⁰². Como se pode perceber facilmente, cada um desses postulados serve para resolver um problema normativo específico e cada qual apresenta uma estrutura própria de aplicação. Esses diferentes objetivos, que refletem diferentes exigências aplicativas, devem estar projetados na fundamentação da decisão.

Dentre as diferentes maneiras com que as normas podem se relacionar encontra-se aquela exemplificada pelo art. 489, § 2.º, CPC: *diferentes finalidades normativas* podem apontar *soluções diversas* e até mesmo *opostas* para resolução de determinados casos (é o que o Código chama de “colisão entre normas”). O Código fala em *ponderação*, mas pode ser o caso de o conflito normativo ser resolvido com o emprego da *proporcionalidade*. No primeiro caso, deve o juiz “justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão”. No segundo, deve o juiz retratar a relação entre meio e fim e justificar argumentativamente a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito da decisão. O emprego genérico de postulados normativos, sem qualquer referência às suas funções e àquilo que no caso concreto autoriza o respectivo emprego, constitui violação ao *dever judicial de fundamentação analítica*.

3. Direito à Publicidade

A publicidade é essencial ao princípio democrático e ao princípio do Estado de Direito (*auf dem Demokratie- und dem Rechtsstaatsprinzip*)³⁰³. Tem assento, portanto, nos dois corações políticos que movem o Estado Constitucional³⁰⁴. Por essa razão, ainda que não fosse prevista constitucionalmente de forma expressa, sua imprescindibilidade seria facilmente compreendida como consequência necessária do caráter democrático da administração da justiça no Estado Constitucional.

A publicidade é elemento indispensável para conformação do processo justo. Conforme assevera nossa Constituição, “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem” (art. 5.º, LX). Adiante, determina que “todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos, (...), podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação” (art. 93, IX).

A publicidade no processo pode ser *geral* ou *restrita*. Pode ainda ser *imediata* ou *mediata*. A publicidade geral é aquela em que todos têm acesso ao conteúdo dos autos (*allgemeine Öffentlichkeit*). Restrita, em que apenas as partes ou seus advogados têm acesso aos autos (*Parteinöffentlichkeit*). A publicidade imediata é aquela em que é facultada ao público em geral, às

partes e aos seus advogados a presença no momento da prática dos atos processuais (*unmittelbare Öffentlichkeit*). Mediata, aquela em que é acessível ao público, às partes e aos seus advogados apenas o resultado da prática do ato processual (*mittelbare Öffentlichkeit*)³⁰⁵.

A regra no processo é a publicidade *geral* e *imediata*. A todos é facultado acesso ao conteúdo dos autos e presença no momento da prática dos atos processuais. A Constituição apenas *restringe* em nome da “defesa da intimidade” ou em função do “interesse social” (art. 5.º, LX). Torna *mediata*, “em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação” (art. 93, IX).

Em primeiro lugar, é tarefa do legislador infraconstitucional densificar os casos em que é necessária *restrição* em nome da “defesa da intimidade” ou em função do “interesse social” (exemplo, art. 189, CPC) ou *mediatização* para proteção do “direito à intimidade”. A destinação primária, contudo, não impede o juiz de concretizar excepcionalmente o regime de publicidade restrita e mediata para realização da tarefa constitucional de proteção à intimidade e ao interesse social no processo³⁰⁶.

Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão.

§ 1.º A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores.

§ 2.º Estão excluídos da regra do *caput*:

I – as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido;

II – o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos;

III – o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas;

IV – as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932;

V – o julgamento de embargos de declaração;

VI – o julgamento de agravo interno;

VII – as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça;

VIII – os processos criminais, nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal;

IX – a causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada.

§ 3.º Após elaboração de lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais.

§ 4.º Após a inclusão do processo na lista de que trata o § 1.º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência.

§ 5.º Decidido o requerimento previsto no § 4.º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista.

§ 6.º Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no § 1.º ou, conforme o caso, no § 3.º, o processo que:

I – tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução;

II – se enquadrar na hipótese do art. 1.040, inciso II.

1. Ordem Preferencialmente Cronológica

Como meio de promoção da duração razoável do processo e de respeito à impessoalidade, o Código de 2015 instituiu o dever de os juízes e tribunais julgarem preferencialmente as causas em ordem cronológica, tomando como parâmetro de controle a data de conclusão dos autos para sentença ou acórdão (art. 12, CPC). Fins de fiscalização, a lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório ou secretaria e na rede mundial de computadores (art. 12, § 1.º, CPC).

Eventual requerimento formulado pela parte depois da inclusão do seu processo na lista de julgamento não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar reabertura da instrução ou conversão do julgamento em diligência. A razão para tanto está em que o litigante não interessado no julgamento poderia adiá-lo indefinidamente utilizando-se de semelhante expediente. Daí que, decidido eventual requerimento, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista.

2. Listas

A ordem cronológica atinge os processos em geral (art. 12, § 1.º, CPC) e os processos em que há preferência legal de julgamento (art. 12, § 3.º, CPC). Elaborada a lista, inclusive aquelas atinentes às preferências legais, deve-se seguir a ordem cronológica de conclusão para o julgamento.

Ocupará o primeiro lugar na respectiva lista o processo em que: I – tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução; II – se enquadrar na hipótese do art. 1.040, II, CPC, isto é, for contrário à orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos.

3. Fora da Ordem

A imposição de julgamento em ordem cronológica visa à promoção da duração razoável do processo e o respeito à impessoalidade – evitando, assim, que determinadas pessoas tenham seus processos julgados de forma mais rápida de maneira indevida. Nessa linha, a necessidade de ordem cronológica de julgamento também é um modo de realização do princípio da igualdade no processo civil (art. 7.º, CPC).

Nada obstante, a previsão de uma ordem cronológica rígida de julgamento pode resultar em técnica contrária à ideia de eficiência administrativo-jurisdicional (arts. 37, *caput*, CRFB, e 8.º, CPC). Pode bem ocorrer de em determinado momento o órgão jurisdicional deparar-se com vários processos que tratam de questões concernentes à mesma matéria (sem serem repetitivos), mostrando-se conveniente o enfrentamento conjunto. É comum ainda que as assessorias judiciais nos juízos de primeiro grau e nos tribunais sejam organizadas por especialização de matéria, de modo que os diferentes ritmos de trabalho podem impor natural descompasso entre processos julgados e processos arrolados em lista para julgamento.

Nesses casos, eventual quebra da ordem cronológica não visa privilegiar determinado advogado ou litigante – não significa, portanto, quebra de impessoalidade e de igualdade: significa simples arranjo de trabalho visando à maior eficiência jurisdicional, que pode inclusive resultar em uma tutela jurisdicional – considerado o acervo de processos para julgamento em seu conjunto – mais tempestiva. Essa é a razão pela qual o art. 12, CPC, fala em ordem preferencial – isto é, não se trata de uma ordem rígida imposta pelo legislador, o que sem dúvida colocaria em risco a possibilidade de o juiz gerir adequadamente o caso (isto é, o *case management* judicial, art. 139, CPC). Daí que o julgamento fora de ordem não constitui causa de inexistência, nulidade ou ineficácia do julgamento.

4. Exceções

Estão legalmente excluídas da ordem cronológica de julgamento todas as causas mencionadas no § 2.º do art. 12, CPC. Se a exclusão decorre da existência de preferências legais, tem-se que elaborar listas próprias: dentro de cada lista haverá ordem cronológica de julgamento (art. 12, § 3.º, CPC). Nos demais casos, em que inexistente espaço para elaboração de listas, a ordem para julgamento é livre.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Como sugere Fredie Didier Júnior, Curso de Direito Processual Civil, 18. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 63, vol. I. Note-se que com isso não se quer dizer que as normas fundamentais do processo civil não constituem direito processual geral: constituem. O que se quer grifar apenas é que não é essa nota conceitual que as particularizam.

2

Para os conceitos de princípio, regra e postulado, Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios*, 15. ed., Salvador: JusPodivm, 2014.

3

Wolfgang Lüke, *Zivilprozessrecht*, 9. ed., München: C. H. Beck, 2006, p. 5-44.

4

Robert Wyness Millar, The Formative Principles of Civil Procedure, in *History of Continental Civil Procedure*, Boston: Little, Brown & Company, 1927, p. 6.

5

Para uma ampla análise das relações entre o Processo Civil e o Estado Democrático de Direito, Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias, *Processo Constitucional e Estado Democrático de Direito*, 4. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2018.

6

Ligando especificamente contraditório, fundamentação e publicidade com uma ideologia democrática de administração da justiça, Michele Taruffo, *La Motivazione della Sentenza Civile*. Padova: Cedam, 1975, p. 407 (há versão em português, *A Motivação da Sentença Civil*, tradução de Daniel Mitidiero, Rafael Abreu e Vitor de Paula Ramos, São Paulo: Marcial Pons, 2015); Vittorio Denti, *La Giustizia Civile*, 2. ed. Bologna: Il Mulino, 2004, p. 104; Eduardo Couture, *Las Garantías Constitucionales del Proceso Civil*, in *Estudios de Derecho Procesal Civil*. Buenos Aires: Ediar, 1948, p. 20-21, tomo I.

7

Sendo o princípio da segurança jurídica uma norma que visa promover um estado de coisas cognoscível, estável, confiável e efetivo (Humberto Ávila, *Segurança Jurídica*, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 250-256), é claro que a vedação à decisão-surpresa e a necessidade de observância da boa-fé participam do seu núcleo-duro: isso porque, em ambos os casos, se procura tutelar a confiança (nos limites daquilo que foi efetivamente debatido em juízo e nos comportamentos concretamente assumidos pelos participantes do processo). É igualmente claro que a tempestividade também participa do seu núcleo-duro: uma ordem jurídica segura é uma ordem jurídica efetiva, isto é, que se realiza. Nada adianta, porém, que se realize tardiamente, de forma intempestiva. Essa é a razão pela qual a tempestividade da tutela compõe pode ser reconduzida ao princípio da segurança jurídica processual.

8

Como observa Fredie Didier Júnior, *Curso de Direito Processual Civil*, 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 64, vol. I.

9

Sobre a constitucionalização do direito em geral, Luís Roberto Barroso, *Curso de Direito Constitucional Contemporâneo*, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 351 e ss.; Virgílio Afonso da Silva, *A Constitucionalização do Direito*, São Paulo: Malheiros, 2005. Trata-se de orientação amplamente aceita: por todos, Cássio Scarpinella Bueno, in Bueno, Cássio Scarpinella (coord.), *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2017, pp. 21 e seguintes, vol. I.

10

Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 43; Alvaro de Oliveira e Mitidiero, *Curso de Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 17-18, vol. I; Guilherme Rizzo Amaral, *Comentários às Alterações do Novo CPC*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 46.

11

Por todos, Estevam de Almeida, *O Direito Processual Civil Brasileiro em face da Constituição – Arts. 34, n. 23, 35 e 65, n. 2*, Ed. RT., São Paulo: Ed. RT, 1918, p. 269-276, n. 26.

12

Ao que se tem notícia, o primeiro ensaio versando a temática remonta a Eduardo Couture, *“Las Garantías Constitucionales del Proceso Civil”*, *Estudios de Derecho Procesal Civil*. Buenos Aires: Ediar, 1948, p. 19-95, tomo I, o qual foi saudado com grande entusiasmo por Enrico Tullio Liebman, *“Diritto Costituzionale e Processo Civile”*, *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1952, ora recolhido nos *Problemi del Processo Civile*, Napoli: Morano, 1962, p. 149-154. A doutrina italiana logo em seguida produziu muitos trabalhos a respeito do tema: entre outros, são muito conhecidos os de Mauro Cappelletti, *“Diritto di Azione e di Difesa e Funzione Concretizzatrice della Giurisprudenza Costituzionale (art. 24 Costituzione e ‘Due Process of Law Clause’)”*, *Processo e Ideologie*. Bologna: Il Mulino, 1969, p. 499-509; *“Le Garanzie Costituzionali delle Parti nel Processo Civile Italiano”*, em coautoria com Vincenzo Vigoriti, publicado em *Giustizia e società*, Milano: Edizioni di Comunità, 1972, p. 339-386; de Luigi Paolo Comoglio, *La Garanzia*

Costituzionale dell'Azione ed il Processo Civile. Padova: Cedam, 1970; de Vincenzo Vigoriti, *Garanzie Costituzionali del Processo Civile – Due Process of Law e art. 24 Costituzione*, Milano: Giuffrè, 1970; e de Nicolò Trocker, *Processo Civile e Costituzione – Problemi di Diritto Tedesco e Italiano*, Milano: Giuffrè, 1974. O mesmo se diga da doutrina brasileira, a qual enfrentou e consolidou o tema principalmente pelas mãos de José Frederico Marques, *Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária* (1952), 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1959, p. 17-31, especialmente p. 27; Ada Pellegrini Grinover, *As Garantias Constitucionais do Direito de Ação*, São Paulo: Ed. RT, 1973; Id., *Os Princípios Constitucionais e o Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 1975; José Carlos Barbosa Moreira, “A Motivação das Decisões Judiciais como Garantia Inerente ao Estado de Direito”, publicado em 1978 na *Revista Brasileira de Direito Processual* e ora recolhido nos *Temas de Direito Processual*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1988, Segunda Série; Id., “A Garantia do Contraditório na Atividade de Instrução”, ora recolhido nos *Temas de Direito Processual*, São Paulo: Saraiva, 1984, Terceira Série; José Rogério Cruz e Tucci e Rogério Lauria Tucci, *Constituição de 1988 e Processo – Regramentos e Garantias Constitucionais do Processo*, São Paulo: Saraiva, 1989; Nelson Nery Junior, *Princípios do Processo Civil na Constituição Federal*, São Paulo: Ed. RT, 1992; e Cândido Dinamarco, *A Instrumentalidade do Processo*, 8. ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 24-30.

13

Daniel Mitidiero, op. cit., p. 43.

14

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, *Curso de Direito Constitucional*, 5. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 738-739, em coautoria com Ingo Sarlet.

15

Muitos são os trabalhos que marcam essa virada. Para ficarmos apenas com alguns exemplos na doutrina brasileira, Luiz Guilherme Marinoni, “O Direito à Efetividade da Tutela Jurisdicional na Perspectiva da Teoria dos Direitos Fundamentais”, *Gênesis Revista de Direito Processual Civil*, n. 28, Curitiba: Gênesis, 2003, p. 342-381; Alvaro de Oliveira, “O Processo Civil na Perspectiva dos Direitos Fundamentais”, *Gênesis Revista de Direito Processual Civil*, n. 26, Curitiba: Gênesis, 2002, p. 653-664; Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015; Hermes Zaneti Júnior, *A Constitucionalização do Processo Civil* (2007), 2. ed., São Paulo: Atlas, 2014.

16

Luiz Guilherme Marinoni, Op. Cit.; Daniel Mitidiero, Op. Cit.

17

Conforme, na teoria do direito, Giovanni Tarello, *L' Interpretazione della Legge*, Milano: Giuffrè, 1980, p. 9-10; Riccardo Guastini, *Interpretare e Argomentare*, Milano: Giuffrè, 2011, p. 8-9; Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell' Interpretazione Giuridica*. Bologna: Il Mulino, 2007, p. 142; Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios*, 12. ed., São Paulo: Malheiros, 2011, p. 32-34; Eros Grau, *Por Que Tenho Medo dos Juízes* (a Interpretação/Aplicação do Direito e os Princípios), 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 37-39; conforme, no processo civil, Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes Obrigatórios*, 4. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 74-

76; Id., O STJ enquanto Corte de Precedentes, São Paulo: Ed. RT, 2013, p. 79-118; Daniel Mitidiero, Cortes Superiores e Cortes Supremas – do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2014, p. 81-90; Id., Precedentes – da Persuasão à Vinculação, São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 58-77.

18

Ingo Wolfgang Sarlet, Curso de Direito Constitucional, 5. ed., São Paulo: Saraiva, 2016, p. 222, em coautoria com Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero.

19

Trata-se de expressão notoriamente cunhada por Nikolaus Thaddäus Gönner, *Handbuch des deutschen gemeinen Prozesses*. Erlangen: Palm, 1801, p. 261, vol. I. Sobre a inserção de Gönner no âmbito do jusracionalismo alemão dos Setecentos, Falk Bomsdorf, *Prozeßmaximen und Rechtswirklichkeit – Verhandlungs- und Untersuchungsmaxime im deutschen Zivilprozeß – Vom gemeinen Recht bis zur ZPO*. Berlin: Duncker & Humblot, 1971, p. 111-150.

20

Adolf Wach, *Vorträge über die Reichs-Civilprocessordnung*, 2. ed. Bonn: Adolph Marcus, 1896, p. 53.

21

Idem, p. 61.

22

Foi a proposta de Frederick Pollock, *The Expansion of the Common Law*. London: Stevens and Sons, 1904, p. 34, a qual foi criticada por Robert Wyness Millar, *The Formative Principles of Civil Procedure, in History of Continental Civil Procedure*, Boston: Little, Brown, and Company, 1927, p. 13 (que preferiu traduzi-la como “*principle of party-presentation*”).

23

Para uma ampla exposição, Tito Carnacini, “*Tutela Giurisdizionale e Tecnica del Processo*”, *Studi in Onore di Enrico Redenti nel XL Anno del suo Insegnamento*. Milano: Giuffrè, 1951, p. 724-730, vol. II.

24

“*Dispositionsprinzip*” ou “*Dispositionsgrundsatz*”, conforme Rosenberg, Schwab e Gottwald, *Zivilprozessrecht*, 17. ed. München: C. H. Beck, 2010, p. 395-396.

25

Por todos, Ovídio Baptista da Silva, Curso de Processo Civil, 5. ed., São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 63-66, vol. I.

26

“*Verhandlungsmaxime*” ou “*Beibringungsgrundsatz*”, conforme Rosenberg, Schwab e Gottwald, *Zivilprozessrecht*, 17. ed. München: C. H. Beck, 2010, p. 396-407.

27

Por todos, Ovídio Baptista da Silva, *Curso de Processo Civil*, 5. ed., São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 61-63, vol. I.

28

Mauro Cappelletti, *La Testimonianza della Parte nel Sistema dell'Oralità*, Milano: Giuffrè, 1962, p. 303-375, vol. I.

29

Joan Picó i Junoy, *El Juez y la Prueba*. Barcelona: Bosch, 2007, p. 99-100.

30

Otávio Domit, in Bueno, Cássio Scarpinella (coord.), *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 68, vol. I.

31

Alvaro de Oliveira, *Do Formalismo no Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 154.

32

Idem, p. 142.

33

Ovídio Baptista da Silva, *Curso de Processo Civil*, 5. ed., São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 62, vol. I.

34

Contra, autonomizando o autorregramento da vontade, nele tratando questões que rigorosamente ora entram no princípio da demanda (como, por exemplo, o estímulo à autocomposição), ora entram no princípio dispositivo (como, por exemplo, as convenções processuais), Fredie Didier Júnior, *Curso de Direito Processual Civil*, 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 135-136, vol. I.

35

Cândido Rangel Dinamarco, *Instituições de Direito Processual Civil*, 3. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 229, vol. I.

36

Ovídio Baptista da Silva, *Curso de Processo Civil*, 5. ed., São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 62, vol. I.

37

Sobre o tema, com amplas indicações bibliográficas, Antonio do Passo Cabral, *Convenções Processuais*. Salvador: JusPodivm, 2016.

38

Remo Caponi, “Autonomia Privata e Processo Civile: gli Accordi Processuali”, *Accordi di Parte e Processo*, Milano: Giuffrè, 2008, p. 100.

39

Para um apanhado histórico-comparado, Robert Wyness Millar, *The Formative Principles of Civil Procedure, in History of Continental Civil Procedure*, Boston: Little, Brown, and Company, 1927, p. 21-27.

40

Marcelo Bonicio, *Princípios do Processo no Novo Código de Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 186.

41

Robert Alexy, *Theorie der Grundrechte*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985, p. 444, com remissão a vários julgados do *Bundesverfassungsgericht* (por exemplo, 24, 367 (401); 35, 348 (361); 37, 132 (148); 39, 276 (294); 44, 105 (120), entre outros).

42

Nicolò Trocker, *Processo Civile e Costituzione – Problemi di Diritto Tedesco e Italiano*, Milano: Giuffrè, 1974, p. 186.

43

Jorge Miranda, *Manual de Direito Constitucional*, 3. ed, Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 93, tomo IV.

44

José Joaquim Gomes Canotilho, *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*, 3. ed., Coimbra: Almedina, 1999, p. 465.

45

Daniel Mitidiero, *Processo Civil e Estado Constitucional*, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 92.

46

Nicolò Trocker, *Processo Civile e Costituzione* – Problemi di Diritto Tedesco e Italiano, Milano: Giuffrè, 1974, p. 701; Andrea Proto Pisani, “Sulla Tutela Giurisdizionale Differenziata”, *Rivista di Diritto Processuale*, Padova: Cedam, 1979, p. 537.

47

Giuseppe Tarzia, “Il Giusto Processo di Esecuzione”, *Rivista di Diritto Processuale*, Padova: Cedam, 2002, p. 340.

48

Luigi Paolo Comoglio, “Principi Costituzionale e Processo di Esecuzione”, *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1994, p. 454.

49

Sobre a formação do procedimento comum ordinário, de *cognição plena e exauriente*, como procedimento único para tutela dos direitos no Código Buzaid, Ovídio Baptista da Silva, *Jurisdição e Execução na Tradição Romano-Canônica*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 1997; Id., *Processo e Ideologia*, Rio de Janeiro: Forense, 2004; sobre a necessidade de diferenciação do procedimento a partir da cognição judicial, Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica Processual e Tutela dos Direitos*, São Paulo: Ed. RT, 2004; Kazuo Watanabe, *Da Cognição no Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 1987.

50

Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 139-145; Artur Carpes, *Ônus Dinâmico da Prova*, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. Sobre o assunto, Vitor de Paula Ramos, *Ônus da Prova no Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015; Lucas Buril de Macedo e Ravi Peixoto, *Ônus da Prova e sua Dinamização*, 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016.

51

Luiz Guilherme Marinoni, *Antecipação da Tutela*, 12. ed., São Paulo: Ed. RT, 2011; Daniel Mitidiero, *Antecipação da Tutela* – da Tutela Cautelar à Técnica Antecipatória, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2014.

52

Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica Processual e Tutela dos Direitos*, São Paulo: Ed. RT, 2004.

53

Sobre o assunto, Jordi Ferrer Beltrán, *La Valoración Racional de la Prueba*, Madrid: Marcial Pons, 2008; Danilo Knijnik, *A Prova nos Juízos Cível, Penal e Tributário*, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 25-48.

54

STF, Pleno, MC na ADPF n. 172/DF, rel. Min. Marco Aurélio, j. 10.06.2009, *DJe* 21.08.2009.

55

O STF, Pleno, MC na ADC n. 4, rel. Min. Sydney Sanches, j. 11.02.1998, *DJ* 21.05.1999, p. 2, já examinou semelhante restrição em sede de cognição sumária, concluindo pela sua constitucionalidade. O entendimento firmado não se aplica, contudo, em matéria previdenciária (Súmula 729, STF: “a decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária”).

56

STF, Pleno, MC na ADI n. 223/DF, rel. para acórdão Min. Sepúlveda Pertence, *DJ* 29.06.1990, voto do Min. Celso de Mello.

57

STF, Pleno, MC na ADI n. 1.576/DF, rel. Min. Marco Aurélio, *DJ* 06.06.2003, voto do Min. Moreira Alves.

58

Sobre o tema, na perspectiva do direito comparado, Michele Taruffo, “L’ Attuazione Esecutiva dei Diritti: Profili Comparatistici”, *Processo e Tecniche di Attuazione dei Diritti*, Napoli: Jovene, 1989, vol. I; Marcelo Lima Guerra, *Execução Indireta*, São Paulo: Ed. RT, 1999.

59

Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios*, 12. ed., São Paulo: Malheiros, 2011, p. 173-185.

60

O Código de Trânsito Brasileiro prevê a suspensão do direito de dirigir como *pena* e, por isso, exige *prévio processo administrativo* para sua imposição (art. 256, inciso III; sobre o assunto, Nei Pires Mitidiero, *Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro*, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 1.277). Não é o caso alvitrado. No *processo*, a imposição de suspensão do direito de dirigir *prescinde de prévio processo administrativo porque ostenta simplesmente caráter coercitivo*: o suspenso traz consigo o próprio poder de liberar-se da suspensão, bastando para tanto cumprir com a decisão judicial.

61

STF, 2.^a Turma, HC 96.772/SP, rel. Min. Celso de Mello, j. 09.06.2009, *DJe* 20.08.2009.

62

Sobre o assunto, extensamente, Sérgio Cruz Arenhart, “A Prisão Civil como Meio Coercitivo”, *Instrumentos de Coerção e Outros Temas de Direito Processual Civil – Estudos em Homenagem aos 25 Anos de Docência do Professor Dr. Araken de Assis*, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 632-656.

63

Luigi Ferrajoli fala em *atuabilidade* das situações jurídicas para destacar a necessária *efetivação* do direito como *condição* para o *reconhecimento* de sua própria existência (*Principia Iuris* – Teoria del Diritto e della Democrazia, Roma: Laterza, 2007, p. 321, vol. I).

64

Daniel Mitidiero, Processo Civil e Estado Constitucional, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 93.

65

Sobre a pessoalização dos direitos, com a conseguinte expansão da tutela pelo equivalente monetário, Ovídio Baptista da Silva, Jurisdição e Execução na Tradição Romano-Canônica, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 1997; sobre a necessidade de prestação de tutela específica aos direitos, no campo do processo, Luiz Guilherme Marinoni, Técnica Processual e Tutela dos Direitos, São Paulo: Ed. RT, 2004; no campo do direito material, Judith Martins-Costa, Comentários ao Novo Código Civil, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 66-68, vol. V, tomo II; Jorge Cesa Ferreira da Silva, Adimplemento e Extinção das Obrigações, São Paulo: Ed. RT, 2007, p. 61-62.

66

Luiz Guilherme Marinoni, Técnica Processual e Tutela dos Direitos, São Paulo: Ed. RT, 2004.

67

Luiz Guilherme Marinoni, Tutela Inibitória, 4. ed., São Paulo: Ed. RT, 2006.

68

Sobre o Código Buzaid e a sua vocação para prestação tão somente de tutela jurisdicional repressiva contra o dano, Daniel Mitidiero, “O Processualismo e a Formação do Código Buzaid”, *Revista de Processo*, n. 183, São Paulo: Ed. RT, 2010.

69

Longamente, Luiz Guilherme Marinoni, Tutela Inibitória, 4. ed., São Paulo: Ed. RT, 2006; Sérgio Cruz Arenhart, Tutela Inibitória da Vida Privada, São Paulo: Ed. RT, 2000; Perfis da Tutela Inibitória Coletiva, São Paulo: Ed. RT, 2003. Na doutrina estrangeira, por todos, Cristina Rapisarda, *Profili della Tutela Civile Inibitoria*. Padova: Cedam, 1987.

70

Luiz Guilherme Marinoni, Tutela Inibitória, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 36-38; Aldo Frignani, *L'Injunction nella Common Law e l'Inibitoria nel Diritto Italiano*, Milano: Giuffrè, 1974, p. 413-417; Cristina Rapisarda, *Profili della Tutela Civile Inibitoria*. Padova: Cedam, 1987, p. 108 e ss.; José de Oliveira Ascensão, *Direito Civil – Teoria Geral*, 2. ed., Coimbra: Coimbra, 2003, p. 28, vol. II; António Menezes Cordeiro,

Tratado de Direito Civil Português, 3. ed, Coimbra: Almedina, 2007, p. 447, vol. I, tomo I; Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, 3. ed, Rio de Janeiro: Borsoi, 1970, p. 88-89, tomo I; Judith Martins-Costa, Comentários ao Novo Código Civil. 2. ed, Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 188, vol. V, tomo II. Nada obstante, a unificação da categoria da ilicitude com a da responsabilidade civil, que leva à concepção de que o dano é elemento essencial do conceito de ato ilícito, que acaba por mercantilizar todos os direitos, ainda está presente na doutrina do direito civil brasileiro. Consta, por exemplo, em Orlando Gomes, Obrigações, Rio de Janeiro: Forense, 1992, p. 313-314: “não interessa ao Direito Civil a atividade ilícita de que não resulte prejuízo. Por isso, o dano integra-se na própria estrutura do ilícito civil. Não é de boa lógica, seguramente, introduzir a função no conceito. Talvez fosse preferível dizer que a produção do dano é, antes, um requisito da responsabilidade, do que do ato ilícito. Seria este simplesmente a conduta *contra jus*, numa palavra, a injúria, fosse qual fosse a consequência. Mas, em verdade, o Direito perderia seu sentido prático se tivesse de ater-se a conceitos puros. O ilícito civil só adquire substantividade se é fato danoso”. Incidindo na mesma assimilação indevida, Francisco Amaral, Direito Civil – Introdução, 7. ed, Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 552: “ato ilícito é ato praticado com infração de um dever legal ou contratual, de que resulta dano para outrem”.

71

Giuseppe Chiovenda, “*Dell’ Azione Nascente del Contratto Preliminare*”, *Saggi di Diritto Processuale Civile (1894-1937)*, Milano: Giuffrè, 1993, p. 110, vol. I.

72

STF, Pleno, ADPF n. 130/DF, rel. Min. Carlos Britto, j. 30.04.2009, *DJe* 05.11.2009.

73

Sobre a possibilidade de restrição à liberdade de imprensa – aqui defendida a partir da possibilidade de tutela inibitória contra atos ilícitos potencialmente violadores de direitos da personalidade também constitucionalmente consagrados – é importante ter presente a lição de Virgílio Afonso da Silva, Direitos Fundamentais – Conteúdo Essencial, Restrições e Eficácia, São Paulo: Malheiros, 2009, p. 118: “como se pode perceber, a ampliação do âmbito de proteção da liberdade de imprensa feita pelos Mins. Celso de Mello e Marco Aurélio [na MC na ADI n. 2.566/DF], que passa a abarcar toda e qualquer forma de manifestação – incluindo-se aí toda e qualquer forma de proselitismo –, por não ser acompanhada de uma necessária possibilidade de restrição, cria problemas jurídico-legais, teóricos e práticos. *Jurídico-legais* porque é a própria Constituição que, de forma expressa e clara, prevê casos em que a liberdade poderá ser restringida. *Teóricos* porque, ao absolutizar um direito (a liberdade de expressão e de imprensa), coloca-o, na verdade, acima dos demais, criando uma relação hierárquica de difícil compatibilização com a ideia de sopesamento, já que direitos absolutos e superiores não podem ser relativizados por direitos não-absolutos e inferiores; sem possibilidade de relativização, não há sopesamento possível. E *práticos* porque impossibilita qualquer forma de regulação da atividade de imprensa no Brasil”.

74

Paula Costa e Silva, A Nova Face da Justiça – Os Meios Extrajudiciais de Resolução de Controvérsias, Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p. 19. Sobre o tema, ainda, Vincenzo Varano (coord.), *L’ Altra Giustizia*, Milano: Giuffrè, 2007; Fernanda Tartuce, Mediação nos Conflitos Cíveis, 2. ed, Rio de Janeiro: Método, 2015.

75

Cândido Rangel Dinamarco, “O Novo Código de Processo Civil Brasileiro e a Ordem Processual Vigente”, *Revista de Processo*, n. 247, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 75.

76

Fredie Didier Júnior, in Cabral e Cramer (coords.), *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 8-9.

77

Theodoro Júnior, Nunes, Bahia e Pedron, *Novo CPC – Fundamentos e Sistematização*, 3. ed, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 264-271.

78

STF, Pleno, AgRg na SE 5.206/EP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 12.12.2001, *DJ* 30.04.2004, p. 29.

79

A ação atípica e abstrata apenas poderá constituir um direito capaz de dar efetividade ao direito material, deixando de ser uma mera proclamação retórica, quando permitir ao autor, durante o seu exercício, a utilização das técnicas processuais adequadas à situação concreta.

80

Sobre o direito à duração razoável do processo, José Rogério Cruz e Tucci, *Tempo e Processo*, São Paulo: Ed. RT, 1997; Paulo Hoffman, *Razoável Duração do Processo*, São Paulo: Quartier Latin, 2006; Marco Jobim, *Direito à Duração Razoável do Processo: Responsabilidade Civil do Estado em Decorrente da Intempestividade Processual*, São Paulo: Conceito, 2011.

81

A Constituição Federal de 1934 dispunha, em seu art. 113, 35, primeira parte, que “a lei assegurará o rápido andamento dos processos nas repartições públicas ...”. Essa norma foi inserida no Capítulo dos “direitos e garantias individuais”, no título com a epígrafe “Declaração de Direitos”. Dirigida especialmente ao legislador (a lei assegurará), entendeu-se que a norma garantia o “rápido andamento” dos processos administrativos e jurisdicionais, compreendendo-se que o termo “repartições públicas” representava não só os órgãos administrativos, mas também as “repartições judiciais” (Cf. Samuel Miranda Arruda, *O direito fundamental à razoável duração do processo*, Brasília: Brasília Jurídica, 2006, p. 43).

82

Neste sentido Mario Chiavario, *Processo e garanzie della persona*, Milano: Giuffrè, 1982, v. 2, p. 153.

O critério básico para determinar o instante adequado para a solução do conflito e para a tutela jurisdicional do direito é o do exaurimento do contraditório. Quando os fatos litigiosos foram debatidos pelas partes e não mais precisam ser elucidados por prova, surge o momento para a definição do litígio e para a tutela do direito. Neste caso se pode dizer que o pedido está “maduro” para definição. A duração é desrazoável quando o pedido se torna maduro para julgamento e a sua definição é adiada. Se o pedido, depois de maduro, não é desde logo definido, a demora passa a violentar o direito fundamental à duração razoável. Como o direito à duração razoável exige que o julgamento do mérito e a tutela do direito ocorram quando o pedido se torna maduro para definição, e a maturação da demanda pode se dar em parte no curso do processo, não há como deixar de concluir que a estrutura técnica do processo civil, para responder ao direito fundamental à duração razoável e aos meios que garantam a celeridade da sua tramitação, deve necessariamente possuir uma técnica processual que permita a definição da parte incontroversa da demanda no curso do processo (conforme Luiz Guilherme Marinoni, *Abuso de defesa e parte incontroversa da demanda*, 2a. ed., São Paulo: ed. RT, 2012, p. 46-47).

O tempo do processo deve se voltar contra a parte que tem necessidade da instrução da causa para demonstrar a sua alegação. Se é preciso distribuir o tempo do processo de acordo com a necessidade da instrução probatória, esta distribuição pode ser feita através da concepção de um procedimento especial ou de uma técnica que atue no interior do procedimento comum. O procedimento especial, contudo, parte do pressuposto de que existe uma situação específica que requer tratamento processual diferenciado. Entretanto, se todos concordam que o autor não pode pagar pelo tempo que serve ao réu, não há como supor que apenas algumas situações específicas podem exigir técnica que permita a distribuição do ônus do tempo do processo. Melhor explicando: a necessidade de distribuição do ônus do tempo processual não constitui situação especial, mas sim algo absolutamente comum a toda e qualquer situação de direito substancial, motivo pelo qual o procedimento comum deve ser dotado de técnica processual capaz de permitir a distribuição do tempo do processo (conforme Luiz Guilherme Marinoni, *Abuso de defesa e parte incontroversa da demanda*, cit., p. 109 e ss.).

Não há dúvida de que o direito de ação é da titularidade de quem recebe, *ou não*, uma sentença favorável. O direito de ação, nesse sentido, é totalmente abstrato em relação ao direito material. Mas esse grau de abstração não responde ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, pois dele decorre o direito a uma ação que seja estruturada de forma tecnicamente capaz de permitir a tutela do direito material, isto é, o direito à ação adequada à tutela do direito material. O direito à ação adequada, embora independente de uma sentença favorável ou da efetiva realização do direito, requer que ao autor sejam conferidos os meios técnicos idôneos à obtenção da sentença favorável e da tutela do direito. Porém, o direito de ação, hoje, é muito mais do que o direito à ação adequada ao plano do direito material. O legislador não se limitou – nem poderia – a estabelecer técnicas processuais adequadas ao plano do direito material, mas instituiu cláusulas gerais, assim como técnicas processuais dotadas de conceitos indeterminados, *com o objetivo de dar ao cidadão o direito de construir a ação adequada ao caso concreto*.

Ver Andrea Genovese, *Contributo allo studio del danno da irragionevole durata del processo*, Milano: Giuffrè, 2012.

87

No direito italiano, sobre o art. 111 da Constituição da República e a ideia de “ragionevole durata” do processo, ver Giuseppe Tarzia, L’art. 111 Cost. e le garanzie europee del processo civile, *Rivista di Diritto Processuale*, 2001, p. 1 e ss.; Id., Il giusto processo di esecuzione, *Rivista di Diritto Processuale*, 2001, p. 329 e ss.; Id., Sul procedimento di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, *Giurisprudenza italiana*, 2001, p. 2430 e ss.; Sergio Chiarloni, Il nuovo art. 111 Cost. e il processo civile, *Rivista di Diritto Processuale*, 2000, p. 1010 e ss.; Vincenzo Caianiello, Riflessioni sull’art. 111 della Costituzione, *Rivista di Diritto Processuale*, 2001, p. 42 e ss.; e Mauro Bove, Art. 111 Cost. e “giusto processo civile”, *Rivista di Diritto Processuale*, v. 57, p. 479 e ss. No direito espanhol, acerca do art. 24, 2, da Constituição espanhola e o significado de “proceso público sin dilaciones indebidas”, ver Cristina Riba Trepas, *La eficacia temporal del proceso – El juicio sin dilaciones indebidas*, Barcelona: Bosch, 1997.

88

Ver Cristina Riba Trepas, *La eficacia temporal del proceso – El juicio sin dilaciones indebidas*, cit., p. 232.

89

Cf. Samuel Miranda Arruda, *O direito fundamental à razoável duração do processo*, cit., p. 270 e ss.

90

Cf. Nicolò Trocker, *Processo civile e costituzione*, Milano: Giuffrè, 1974, p. 370 e ss.

91

Vincenzo Vigoriti, *Garanzie costituzionali del processo civile*, Milano: Giuffrè, 1973, p. 64.

92

Súmula 304, Supremo Tribunal Federal: “Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso de ação própria”.

93

V. Luiz Guilherme Marinoni, *Antecipação da Tutela*, 12. ed., São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 35 e ss.

94

Nicolò Trocker, *Processo civile e costituzione*, cit., p. 406. No direito italiano, a Corte Constitucional já afirmou que a tutela de urgência representa um componente essencial e ineliminável da tutela jurisdicional, nos limites em que é necessária para neutralizar um perigo de dano irreparável. A necessidade da ouvida do réu pode comprometer a efetividade não só da tutela cautelar, mas também da

tutela antecipatória. V. Luiz Guilherme Marinoni, *Antecipação da Tutela*, cit., item 4.7.1; Vittorio Denti, “Intervento”, Atti del XV Convegno Nazionale, Bari, 4-5 ottobre 1985, *La tutela d’urgenza*, Rimini: Maggioli Editore, 1985, p. 164; Andrea Proto Pisani, “Intervento”, Atti del XV Convegno Nazionale, Bari, 4-5 ottobre 1985, *La tutela d’urgenza*, Rimini: Maggioli Editore, 1985, p. 118.

95

V. Luigi Paolo Comoglio, *La garanzia costituzionale dell’azione ed il processo civile*, Padova: Cedam, 1970.

96

“Si è detto che il principio del contraddittorio è rispettato anche quando il provvedimento è pronunciato *inaudita altera parte*, purché prima che il provvedimento diventi definitivo, la parte contro cui è emesso abbia la possibilità di proporre le sue difese” (Giuseppe Martinetto, “Contraddittorio (Principio del)”, *Novissimo digesto italiano*, v. 4, p. 461).

97

Pontes de Miranda, *Tratado das Ações*, São Paulo: Ed. RT, 1970, t. 1, p. 32.

98

Segundo Calamandrei, o condenado, “prima della condanna, non è altro che un obbligato: cioè il soggetto passivo di un rapporto giuridico sostanziale, vincolato, in forza di questo, a tenere volontariamente un certo comportamento. Finché egli resta un obbligato, la osservanza del suo obbligo è affidata alla sua volontà: nel campo del diritto sostanziale, anche quando al rapporto obbligatorio primario si sostituisce un rapporto obbligatorio sanzionatorio, l’adempimento volontario è l’unico mezzo su cui il creditore può contare per il soddisfacimento del suo diritto. Ma, dopo la condanna, la volontà del debitore, sulla quale finora il diritto sostanziale faceva affidamento per ottenere l’adempimento dell’obbligato, si trasforma, da soggetto attivo di volontà, in oggetto passivo di una volontà altrui. In questa trasformazione dell’obbligo, per il cui adempimento il diritto contava sulla volontà attiva dell’obbligato, in assoggettamento passivo alla forza altrui, contro la quale la volontà del condannato non conta più, mi pare che consista la caratteristica essenziale della condanna, comune alla condanna civile ed a quella penale” (Piero Calamandrei, *La Condanna, Opere giuridiche*, Napoli: Morano, 1972, p. 491, vol. V).

99

Enrico Tullio Liebman, *Processo de Execução*, São Paulo: Saraiva, 1968, p. 16.

100

Enrico Tullio Liebman, Il titolo esecutivo riguardo ai terzi, *Rivista di Diritto Processuale Civile*, 1934, p. 137.

101

Enrico Tullio Liebman, *Manual de direito processual civil*, Rio de Janeiro: Forense, 1985, v. 1, p. 162.

102

A doutrina espanhola, ao interpretar o art. 24 da sua Constituição, vem deixando de lado as velhas concepções de ação como mero direito de ir a juízo e como direito a uma sentença de mérito e frisando o significado de “tutela efectiva”. David Vallespín Pérez, por exemplo, assim escreve: “El derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el art. 24 CE no agota su contenido en la exigencia de que el interesado tenga acceso a los Tribunales de Justicia, pueda ante ellos manifestar y defender su pretensión jurídica en igualdad con las otras partes y goce de la libertad de aportar todas aquellas pruebas que procesalmente fueran oportunas y admisibles, ni se limita a garantizar la obtención de una resolución de fondo, fundada en derecho, sea o no favorable a la pretensión formulada, si concurren todos los requisitos procesales para ello. Exige también que el ‘fallo se cumpla’ y que el recurrente sea repuesto en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido. Lo contrario sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los derechos que ellas comportan en favor de alguna de las partes en meras declaraciones de intenciones” (David Vallespín Pérez, *El modelo constitucional de juicio justo en el ámbito del proceso civil*, Barcelona: Atelier, 2002, p. 142-143). Diz o art. 24, I, da Constituição Espanhola: “Todas las personas tienen *derecho a obtener la tutela efectiva* de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. V. também Álvaro Gil-Robles, *Los nuevos límites de la tutela judicial efectiva*, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1996, p. 85 e ss.

103

Corte Europeia de Direitos do Homem, Caso Scollo v. Itália, 1995, Caso Hornsby v. Grécia, 1997. Sobre o assunto, amplamente, Eugenio Dalmotto, *Diritto alla Equa Riparazione per l’Eccessiva Durata del Processo, Misure Acceleratorie e Riparatorie contro l’Irragionevole Durata dei Processi*, Torino: Giappichelli, 2002, p. 136-144.

104

Corte Europeia de Direitos do Homem, Caso Neumeister v. Áustria, 1968.

105

Corte Europeia de Direitos do Homem, Caso Comissão v. Dinamarca, 1996.

106

Corte Europeia de Direitos do Homem, Caso Laino v. Itália, 1999.

107

Corte Europeia de Direitos do Homem, Caso Zarmakoupis e Sakellaropoulos v. Grécia, 2000.

108

Cecilia Sanna, *La Durata Ragionevole dei Processi nel Dialogo tra Giudici Italiani ed Europei*, Milano: Giuffrè, 2008, p. 85.

109

A reparação do dano tem de ser integral. Sobre o assunto, em geral, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, *Princípio da Reparação Integral*, São Paulo: Saraiva, 2010.

110

David Vallespín Pérez, *El Modelo Constitucional de Juicio Justo en el Ámbito del Proceso Civil*, Barcelona: Atelier, 2002, p. 89. Sobre danos patrimoniais e extrapatrimoniais em geral, Sérgio Severo, *Os Danos Extrapatrimoniais*, São Paulo: Saraiva, 1996. Especificamente sobre a reparação dos danos oriundos da duração excessiva, com ampla análise da jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos e do direito italiano, Eugenio Dalmotto, *Diritto alla Equa Riparazione per l'Eccessiva Durata del Processo*. In: Chiarloni, Sergio (coord.), *Misure Acceleratorie e Riparatorie contro l'Irragionevole Durata dei Processi*, Torino: Giappichelli, 2002, p. 184-210.

111

Luigi Paolo Comoglio, *Etica e Tecnica del "Giusto Processo"*, Torino: Giappichelli, 2004, p. 88.

112

James Goldschmidt, *Der Prozess als Rechtslage*, Berlin: Springer, 1925, p. 292.

113

Michele Taruffo, "Abuse of Procedural Rights: Comparative Standards of Procedural Fairness", *Abuse of Procedural Rights: Comparative Standards of Procedural Fairness*, The Hague: Kluwer Law International, 1999, p. 5.

114

Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 91-93.

115

Para uma ligação entre boa-fé ("loyauté"), contraditório e igualdade, Marie-Emma Boursier, *Le Principe de Loyauté en Droit Processuel*, Paris: Dalloz, 2003, p. 320-336.

116

Antonio Menezes Cordeiro, *Da Boa Fé no Direito Civil*, Coimbra: Almedina, 2001, p. 226-283 e p. 325-370; Judith Martins-Costa, *A Boa-Fé no Direito Privado*, São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 411.

117

Monograficamente, Paula Costa e Silva, *A Litigância de Má Fé*, Coimbra: Coimbra Editora, 2008.

118

Brunela Vieira de Vincenzi, *A Boa-Fé no Processo Civil*, São Paulo: Atlas, 2003, p. 157-173; Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 91-93; Fredie Didier Júnior, *Fundamentos do Princípio da Cooperação no Direito Processual Civil Português*, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 84-85; Antonio do Passo Cabral, *Nulidades no Processo Moderno*, Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 215 e ss.

119

Judith Martins-Costa, *A Boa-Fé no Direito Privado*, São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 428-437; Fredie Didier Júnior, in Cabral e Cramer (coords.), *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 18.

120

Essa tipologia é devida a Antonio Menezes Cordeiro, *Da Boa Fé no Direito Civil*, Coimbra: Almedina, 2001, p. 719-860. Na doutrina brasileira, ainda, é comum sistematizar as hipóteses típicas de comportamentos contrários à boa-fé seguindo-se a tradicional lição de Walter Zeiss, *Die arglistige Prozesspartei*. Berlin: Duncker & Humblot, 1967, em quatro grandes grupos (“exceptio doli”, “tu quoque”, “nemo potest venire contra factum proprium” e “supressio”), conforme Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 93; Fredie Didier Júnior, *Fundamentos do Princípio da Cooperação no Direito Processual Civil Português*, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 84-85; aproveitando-se parcialmente da sistematização, Fabio Caldas de Araújo, *Curso de Processo Civil*, São Paulo: Malheiros, 2016, p. 188-190, tomo I, fala na proibição do “venire contra factum proprium” e na proibição do abuso do direito processual por força da “surrectio” e da “supressio”. Darci Guimarães Ribeiro, in Bueno, Cássio Scarpinella (coord.), *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 105, vol. I, acrescenta às quatro hipóteses tradicionais ainda a “inalegabilidade de nulidades formais”, a “surrectio” e a vedação ao “exercício desequilibrado do direito”. Para uma crítica da proposta de Zeiss, Gottfried Baumgärtel, “Treu und Glauben im Zivilprozess”, *Zeitschrift für Zivilprozess*, n. 86, Köln: Carl Heymanns, 1973, p. 353-372.

121

Tudo conforme Antonio Menezes Cordeiro, *Da Boa Fé no Direito Civil*, Coimbra: Almedina, 2001, p. 325-370.

122

O que normalmente é designado com o conceito de formalismo, que compreende a “delimitação dos poderes, faculdades e deveres dos sujeitos processuais, coordenação de sua atividade, ordenação do procedimento e organização do processo” (Alvaro de Oliveira, *Do Formalismo no Processo Civil – Proposta de um Formalismo-Valorativo*, 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 28).

123

A expressão é de José Carlos Barbosa Moreira, “O Problema da ‘Divisão do Trabalho’ entre Juiz e Partes: Aspectos Terminológicos”, *Temas de Direito Processual*, São Paulo: Saraiva, 1989, p. 35-44, Quarta Série.

Sobre o assunto na doutrina brasileira, Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015; Alvaro de Oliveira, “Poderes do Juiz e Visão Cooperativa do Processo”, *Revista da Ajuris*, n. 90, Porto Alegre; Fredie Didier Júnior, *Fundamentos do Princípio da Cooperação no Direito Processual Civil Português*, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 46; Id., “Os Três Modelos de Direito Processual: Inquisitivo, Dispositivo e Cooperativo”, *Revista de Processo*, n. 198, São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 219; Antonio do Passo Cabral, *Nulidades no Processo Moderno*, Rio de Janeiro: Forense, 2009; Id., “O Contraditório como Dever e a Boa-Fé Processual Objetiva”, *Revista de Processo*, n. 126, São Paulo: Ed. RT, 2005, p. 59-81; Leonardo Carneiro da Cunha, *A Atendibilidade dos Fatos Supervenientes no Processo Civil*, Coimbra: Almedina, 2012, p. 65 e ss.; Ronaldo Kochem, “Introdução às Raízes Históricas do Princípio da Cooperação (*Kooperationsmaxime*)”, *Revista de Processo*, n. 251, São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 75-111; Lorena Miranda Barreiros, *Fundamentos Constitucionais do Princípio da Cooperação Processual*, Salvador: JusPodivm, 2013; Lúcio Grassi, “Cognição Processual Civil: Atividade Dialética e Cooperação Intersubjetiva na Busca da Verdade Real”, *Revista Dialética de Direito Processual*, n. 6, São Paulo: Dialética, 2003; Id., “A Função Legitimadora do Princípio da Cooperação Intersubjetiva no Processo Civil Brasileiro”, *Revista de Processo*, n. 172, São Paulo: Ed. RT, 2009, p. 32-53; Humberto Theodoro Júnior, “Juiz e Partes dentro de um Processo Fundado no Princípio da Cooperação”, *Revista Dialética de Direito Processual*, n. 102, São Paulo: Dialética, 2011, p. 64; Igor Raatz dos Santos, “Processo, Igualdade e Colaboração: os Deveres de Esclarecimento, Prevenção, Consulta e Auxílio como Meio de Redução das Desigualdades no Processo Civil”, *Revista de Processo*, n. 192, São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 47-80; Artur César de Souza, “O Princípio da Cooperação no Projeto do Novo Código de Processo Civil”, *Revista de Processo*, n. 225, São Paulo: Ed. RT, 2013; Júlio Lanes, *Fato e Direito no Processo Civil Cooperativo*, São Paulo: Ed. RT, 2014. Na doutrina alemã, Rolf Stürner, *Die Aufklärungspflicht der Parteien des Zivilprozesses*, Tübingen: J. C. B. Mohr, 1976; Rudolf Wassermann, *Der Soziale Zivilprozess*. Neuwied und Darmstadt: Luchterhand, 1978, especialmente p. 97-125; Bernhard Hahn, *Kooperationsmaxime im Zivilprozeß? Grenzverschiebungen in der Verantwortung von Parteien und Gericht bei der Tatsachenbeschaffung und Sachverhaltseforschung im neuen Zivilprozeßrecht*, Berlin: Carl Heymanns, 1983; Reinhard Greger, “Kooperation als Prozessmaxime”, *Dogmatische Grundfragen des Zivilprozess im geeinten Europa*, Bielefeld: Gieseking, 2000, p. 77-84 (há versão disponível em português, „Cooperação como Princípio Processual“, tradução de Ronaldo Kochem, revisão de Daniel Mitidiero, *Revista de Processo*, n. 206, São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 123-134); na doutrina austríaca, Klaus Kugler, *Die Kooperationsmaxime – Richtermacht und Parteienherrschaft im Zivilprozess – der gemeinsame Weg zum richtigen Prozessergebnis*, Linz: Johannes-Kepler-Universität, 2002; na doutrina italiana, Eduardo Grasso, “La Collaborazione nel Processo Civile”, *Rivista di Diritto Processuale*, Padova: Cedam, 1966; na doutrina portuguesa, Miguel Teixeira de Sousa, *Estudos sobre o Novo Processo Civil*, 2. ed. Lisboa: Lex, 1997; Paula Costa e Silva, *Acto e Processo*, Coimbra: Coimbra Editora, 2003; José Lebre de Freitas, *Introdução ao Processo Civil*, Coimbra: Coimbra Editora, 1996.

Loïc Cadiet, Jacques Normand e Soraya Amrani Mekki, *Théorie Générale du Procès*, Paris: PUF, 2010, p. 385.

Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 52; Fredie Didier Júnior, in Cabral e Cramer (coords.), *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 18-21; Guilherme Rizzo Amaral, *Comentários às Alterações do Novo CPC*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 54-

127

Loïc Cadiet, “Avenir des Catégories, Catégories de l’Avenir: Perspectives”, *Common Law, Civil Law and the Future of Categories*, Markham: LexisNexis, 2010, p. 635-655.

128

Cândido Rangel Dinamarco, “O Novo Código de Processo Civil Brasileiro e a Ordem Processual Vigente”, *Revista de Processo*, n. 247, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 75.

129

STJ, 2ª Turma, REsp 1.676.027/PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.09.2017, *DJe* 11.10.2017.

130

Rudolf Wassermann, *Der Soziale Zivilprozess*, Neuwied und Darmstadt: Luchterhand, 1978, p. 97; Klaus Kugler, *Die Kooperationsmaxime – Richtermacht und Parteienherrschaft im Zivilprozess – der gemeinsame Weg zum richtigen Prozessergebnis*, Linz: Johannes-Kepler-Universität, 2002, p. 75.

131

Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 48-50.

132

José Joaquim Gomes Canotilho, *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*, 3. ed, Coimbra: Almedina, 1999, p. 89.

133

Sobre os modelos de processo isonômico e de processo assimétrico, Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 71-115, com ampla exposição bibliográfica, com destaque para as obras de Nicola Picardi e Alessandro Giuliani (de ambos, *La Responsabilità del Giudice*, Milano: Giuffrè, 1995; do primeiro, “Processo Civile: c) Diritto Moderno”. In: *Enciclopedia del Diritto*, Milano: Giuffrè, 1987, vol. XXXVI; “Audiatur et Altera Pars’ – Le Matrici Storico-Culturali del Contraddittorio”, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, Milano: Giuffrè, 2003; do segundo, *Il Concetto di Prova – Contributto alla Logica Giuridica*, Milano: Giuffrè, 1971; “L’Ordo Judiciarius Medioevale – Riflessioni su un Modello Puro di Ordine Isonomico”, *Rivista di Diritto Processuale*, Padova: Cedam, 1988). Adotando ainda expressamente a colaboração como modelo processual civil, Fredie Didier Júnior, *Fundamentos do Princípio da Cooperação no Direito Processual Civil Português*, Coimbra: Coimbra Editora, 2010, p. 46-49; Artur Carpes, *Ônus Dinâmico da Prova*, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 61-65.

134

E o caminho trilhado por Eduardo Grasso, “*La Collaborazione nel Processo Civile*”, *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1966, e Rudolf Wassermann, *Der Soziale Zivilprozess*. Neuwied und Darmstadt: Luchterhand, 1978, especialmente p. 97-125, em que se tem como pano de fundo o aspecto liberal e social das instituições processuais. No Brasil, pelo mesmo caminho, Fredie Didier Júnior, “Os Três Modelos de Direito Processual: Inquisitivo, Dispositivo e Cooperativo”, *Revista de Processo*, São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 219, n. 198. Igualmente, Dierle Nunes, *Processo Jurisdicional Democrático*. Curitiba: Juruá, 2008, p. 39-140, nada obstante não fale expressamente em colaboração. Embora a literatura sobre processo dispositivo e processo inquisitório seja imensa, é possível buscar bom panorama em Mauro Cappelletti, *La Testimonianza della Parte nell Sistema dell’ Oralità*, Milano: Giuffrè, 1962, p. 303-375, vol. I. No entanto, para uma acertada crítica da contraposição processos dispositivos (adversariais) e processos inquisitórios, Michele Taruffo, “*Il Processo Civile di Civil Law e di Common Law: Aspetti Fondamentali*”, *Sui Confini – Scritti sulla Giustizia Civile*. Bologna: Il Mulino, 2002, p. 67-97. Para uma acertada crítica da concepção da cooperação como superação do princípio dispositivo ou como uma fusão do princípio dispositivo e do princípio inquisitório, Reinhard Greger, “*Kooperation als Prozessmaxime*”, *Dogmatische Grundfragen des Zivilprozess im geeinten Europa*. Bielefeld: Giesecking, 2000, p. 79.

135

Com maior vagar, Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil – Pressupostos Sociais, Lógicos e Éticos*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 71-115.

136

Marie-Emma Boursier, *Le Principe de Loyauté en Droit Processuel*, Paris: Dalloz, 2003, p. 297; Antonio do Passo Cabral, *Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas*, Salvador: JusPodivm, 2013, p. 285-286.

137

Giovanni Tarello, *L’ Interpretazione della Legge*, Milano: Giuffrè, 1980, p. 75-99; Riccardo Guastini, *L’ Interpretazione dei Documenti Normativi*, Milano: Giuffrè, 2004, p. 123-136; *Interpretare ed Argomentare*, Milano: Giuffrè, 2011, p. 236-238; Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell’ Interpretazione Giuridica*, Bologna: Il Mulino, 2007, p. 11-12.

138

Michele Taruffo, “*Idee per una Teoria della Decisione Giusta*”, *Sui Confini – Scritti sulla Giustizia Civile*, Bologna: Il Mulino, 2002, p. 224., Para uma ampla discussão do problema da verdade na perspectiva do processo, Michele Taruffo, *La Semplice Verità – Il Giudice e la Costruzione dei Fatti*, Roma: Laterza, 2009, p. 74-134; *La Prova dei Fatti Giuridici*, Milano: Giuffrè, 1992, p. 1-66; Jordi Ferrer Beltrán, 2. ed., Madrid: Marcial Pons, 2005, p. 55-78; Daniel Mitidiero, *Antecipação da Tutela – Da Tutela Cautelar à Técnica Antecipatória*, São Paulo: Ed. RT, 2013, p. 92-111. Para um diálogo crítico, Daissou Flach, *A Verossimilhança no Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2009.

139

Por essa razão, em sentido similar, Klaus Kugler, *Die Kooperationsmaxime – Richtermacht und Parteienherrschaft im Zivilprozess – der gemeinsame Weg zum richtigen Prozessergebnis*, Linz: Johannes-

Kepler-Universität, 2002, p. 202-222, arrola como pontos-chaves da colaboração no processo a *confiança*, a *verdade* e a *justiça*. Sobre as condições para viabilização de uma decisão justa, Michele Taruffo, “*Idee per una Teoria della Decisione Giusta*”, *Sui Confini – Scritti sulla Giustizia Civile*, Bologna: Il Mulino, 2002.

140

Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 81; Fredie Didier Júnior, *Op. Cit.*, p. 48.

141

Alvaro de Oliveira, “Poderes do Juiz e Visão Cooperativa do Processo”, *Revista da Ajuris*, vol. 90, Porto Alegre, 2003, p. 62.

142

O diálogo é o instrumento apontado pela doutrina como sendo aquele que torna possível a cooperação no processo (Eduardo Grasso, “*La Collaborazione nel Processo Civile*”, *Rivista di Diritto Processuale*, Padova: Cedam, 1966, p. 587).

143

Alvaro de Oliveira, “A Garantia do Contraditório”, *Do Formalismo no Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 238; Cândido Rangel Dinamarco, “O Princípio do Contraditório e sua Dupla Destinação”. In: *Fundamentos do Processo Civil Moderno*, 4. ed., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 124-135, tomo I.

144

Miguel Teixeira de Sousa, *Estudos sobre o Novo Processo Civil*, 2. ed., Lisboa: Lex, 1997, p. 87-89. Sobre o sentido da palavra “*iudicium*” no âmbito do direito comum, consulte-se, por todos, Nicola Picardi, “*Processo Civile: c) Diritto Moderno*”, *Enciclopedia del Diritto*, Milano: Giuffrè, 1987, p. 101-106, vol. XXXVI. As Ordenações portuguesas, aliás, como típica coletânea de direito comum (conforme Enrico Tullio Liebman, “*Istituti del Diritto Comune nel Processo Civile Brasiliano*”, *Problemi del Processo Civile*, Napoli: Morano Editore, 1962, p. 498), não se furtaram de recolher a célebre definição atribuída a Búlgaro (“*iudicium est actus ad minus trium personarum: actoris, rei, iudicis*”), como se vê, por exemplo, nas Ordenações Afonsinas, Livro III, Título XX, § 1.º; Ordenações Manuelinas, Livro III, Título XV, proêmio; Ordenações Filipinas, Livro III, Título XX, proêmio.

145

Frédérique Ferrand, “Le Principe Contradictoire et l’Expertise en Droit Comparé Europeen”, *Revue Internationale de Droit Comparé*, Paris: Société de Législation Comparée, 2000, p. 348.

146

Reza o art. 16 do *Nouveau Code de Procédure Civile*: “Le juge doit, en tous circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les

explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”.

147

Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios*, 8. ed., São Paulo: Malheiros, 2008. Para uma detalhada exposição da colaboração como princípio jurídico, partindo igualmente da obra de Humberto Ávila, Fredie Didier Júnior, Op. Cit., p. 50-56; também situando a colaboração como princípio, Antônio do Passo Cabral, *Nulidades no Processo Moderno*, Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 215-236. Pela caracterização da colaboração como um princípio jurídico na doutrina alemã, por todos, Reinhard Greger, “Koooperation als Prozessmaxime”, *Dogmatische Grundfragen des Zivilprozess im geeinten Europa*, Bielefeld: Giesecking, 2000, p. 78.

148

Humberto Ávila, Op. Cit., p. 78-79.

149

Um dos fins do processo civil, conforme Alvaro de Oliveira, *Do Formalismo no Processo Civil*, p. 99.

150

Bernhard Hahn, *Kooperationsmaxime im Zivilprozeß? Grenzverschiebungen in der Verantwortung von Parteien und Gericht bei der Tatsachenbeschaffung und Sachverhaltseforschung im neuen Zivilprozeßrecht*, Berlin: Carl Heymanns, 1983, p. 297-302.

151

Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 114; Guilherme Rizzo Amaral, *Comentários às Alterações do Novo CPC*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 55; Reinhard Greger, “Koooperation als Prozessmaxime”, *Dogmatische Grundfragen des Zivilprozess im geeinten Europa*, Bielefeld: Giesecking, 2000, p. 79; Darci Guimarães Ribeiro, in Bueno, Cássio Scarpinella (coord.), *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 110, vol. I; contra, propondo a existência de deveres de colaboração entre as partes, Fredie Didier Júnior, *Curso de Direito Processual Civil*, 15. ed. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 95, vol. I.

152

Como propõe Rolf Stürner, *Die Aufklärungspflicht der Parteien des Zivilprozesses*, Tübingen: J. C. B. Mohr, 1976.

153

Clóvis do Couto e Silva, *A Obrigação como Processo*, São Paulo: José Bushatsky Editor, 1976, p. 5.

154

Assim, com as indicações bibliográficas pertinentes, Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 84-85.

155

Miguel Teixeira de Sousa, Op. Cit., p. 65.

156

Miguel Teixeira de Sousa, Op. Cit., p. 66-67; Antonio do Passo Cabral, “Il Principio del Contraddittorio come Diritto d’Influenza e Doveri di Dibattito”, *Rivista di Diritto Processuale*, Padova: Cedam, 2005, p. 449-464.

157

Miguel Teixeira de Sousa, Op. Cit., p. 66.

158

Miguel Teixeira de Sousa, Op. Cit., 1997, p. 67.

159

Reinhard Greger, “Kooperation als Prozessmaxime”. In: Gottwald, Peter; Greger, Reinhard; Prütting, Hans (coords.), *Dogmatische Grundfragen des Zivilprozess im geeinten Europa*, Bielefeld: Giesecking, 2000, p. 79.

160

Cândido Rangel Dinamarco, *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 105, vol. I.

161

Jesús González Pérez, *El Derecho a la Tutela Jurisdiccional*, 2. ed., Madrid: Civitas, 1989, p. 65-66.

162

Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 105; Fredie Didier Júnior, *Curso de Direito Processual Civil*, 18. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 137, vol. I.

163

Neil MacCormick, *Institutions of Law – An Essay in Legal Theory*, Oxford: Oxford Press University, 2008, p. 60.

José Joaquim Gomes Canotilho, op. cit., p. 245.

STF, Pleno, MC na ADC n. 1.753/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 16.04.1998, *DJ* 12.06.1998, p. 51.

Sobre a igualdade em geral, Humberto Ávila, *Teoria da Igualdade Tributária*, São Paulo: Malheiros, 2008; Jefferson Carús Guedes, *Igualdade e Desigualdade*, São Paulo: Ed. RT, 2014. Sobre a igualdade no âmbito do processo, especialmente do processo civil, Francisco Glauber Pessoa Alves, *O Princípio Jurídico da Igualdade e o Processo Civil Brasileiro*, Rio de Janeiro: Forense, 2003; Fernanda Tartuce, *Igualdade e Vulnerabilidade no Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2012; Rafael Abreu, *Igualdade e Processo – Posições Processuais Equilibradas e Unidade do Direito*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

Humberto Ávila, *Teoria da Igualdade Tributária*, São Paulo: Malheiros, 2008, p. 74.

BVerfGE 53, 313 [329].

Konrad Hesse, *Elementos de Direito Constitucional da República Federativa da Alemanha*, tradução de Luís Afonso Heck, Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998, p. 330.

Konrad Hesse, *Elementos de Direito Constitucional da República Federativa da Alemanha*, tradução de Luís Afonso Heck, Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998, p. 331.

Humberto Ávila, *Teoria da Igualdade Tributária*, São Paulo: Malheiros, 2008, p. 75.

A finalidade legítima é um dos elementos que a *Supreme Court* dos Estados Unidos da América utiliza para aferição da observância do direito à “equal protection”. Consulte-se, por exemplo, *Railways Express Agency v. New York*, 517 U.S. 620 (1996). Para desenvolvimento do tema, Erwin Chemerinsky, *Constitutional Law – Principles and Policies*, 3. ed., New York: Aspen Publishers, 2006, p. 680-685.

Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 139-145.

Giuseppe Tarzia, *Parità delle Armi tra le Parti e Poteri del Giudice nel Processo Civile*, *Problemi del Processo Civile di Cognizione*, Padova: Cedam, 1989, p. 317.

“Como está claro, não só há grande preocupação com a igualdade de tratamento dos litigantes no processo, mas também com a igualdade de acesso à justiça e com a igualdade aos procedimentos e às técnicas processuais. Nesta dimensão, se é possível falar, para facilitar a comunicação, em igualdade *no* processo e igualdade *ao* processo, é mais apropriado pensar em igualdade diante da jurisdição, tendo-se como espécies a igualdade de tratamento no processo, a igualdade de acesso e a igualdade ao procedimento e à técnica processual. Vê-se, a partir daí uma grave lacuna. Em que local está a igualdade diante das decisões judiciais? *Ora, o acesso à justiça e à participação adequada no processo só têm sentido quando correlacionados com a decisão. Afinal, esse é o objetivo daquele que busca o Poder Judiciário e, apenas por isso, tem necessidade de participar do processo.* Em outros termos, a igualdade de acesso, a igualdade à técnica processual e a igualdade de tratamento no processo são valores imprescindíveis para a obtenção de uma decisão racional e justa” (Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes Obrigatórios*, São Paulo: Ed. RT, 2010, p. 145, grifos nossos).

Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes Obrigatórios*, 4. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016; Daniel Mitidiero, *Precedentes – da Persuasão à Vinculação*, São Paulo: Ed. RT, 2016.

Sobre o assunto, Hartmut Maurer, *Direito Processual Estatal-Jurídico, Contributos para o Direito do Estado*, tradução de Luís Afonso Heck, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 210-211, com indicação de bibliografia alemã e jurisprudência do *Bundesverfassungsgericht* sobre o tema; Giuseppe Tarzia, *Parità delle Armi tra le Parti e Poteri del Giudice nel Processo Civile*, *Problemi del Processo Civile di Cognizione*, Padova: Cedam, 1989; Serge Guinchard, *Droit Processuel – Droit Commum et Droit Comparé du Procès Équitable*, 4. ed., Paris: Dalloz, 2007, p. 851-860, com indicação de vários julgamentos da Corte Europeia de Direitos do Homem sobre o tema.

Santi Romano, *L'Ordinamento Giuridico*. In: *L'Ultimo Santi Romano*, Milano: Giuffrè, 2013, p. 11, e *Principii di Diritto Costituzionale Generale*. In: *L'Ultimo Santi Romano*, Milano: Giuffrè, 2013, p. 291.

Eros Grau, *Por que Tenho Medo dos Juízes (a Interpretação/Aplicação do Direito e os Princípios)*, 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 84.

180

Marie-Emma Boursier, *Le Principe de Loyauté en Droit Processuel*, Paris: Dalloz, 2003, p. 403.

181

Nessa linha, Gerson Branco, *Função Social dos Contratos*, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 311 e 315. Embora essas conclusões do autor tenham sido formadas à luz do direito civil, especificamente levando em consideração a previsão normativa de interpretação contratual à luz da função social, essas são transponíveis para o âmbito do processo civil.

182

Ingo Sarlet, *Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988*, 3. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 77. Sobre o assunto, ainda, Ingo Sarlet (coord.), *Dimensões da Dignidade – Ensaio de Filosofia do Direito e Direito Constitucional*, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.

183

Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2014, p. 19-21.

184

Ingo Sarlet, *Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988*, 3. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 45.

185

Essa clássica passagem da obra de Bentham é reproduzida em inúmeros trabalhos: “When your dog does anything you want to break him of, you wait till he does it, and then beat him for it. This is the way you make laws for your dog; and this is the way the judges make law for you and for me. They won’t tell a man beforehand what it he should not do...they lie by till he has done something which they say he should not have done, and then they hang him for it (Bowring v, 235)” (citado a partir de Gerald Postema, *Bentham and the Common Law Tradition*, Oxford: Oxford University Press, 1986, p. 277). Ainda, Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes Obrigatórios*, 4. ed., São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 25; Daniel Mitidiero, *Precedentes – da Persuasão à Vinculação*, São Paulo: Ed. RT, 2016, p. 39.

186

Por todos, Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell’Interpretazione Giuridica*, Bologna: Il Mulino, 2007, p. 142.

187

STF, Pleno, RE 733.433/MG, em especial o voto do Min. Edson Fachin; STJ, 6ª Turma, HC n. 274.806/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, *DJe* 18.02.2014; STJ, 6ª Turma, HC 276.152/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, *DJe*

31.03.2014.

188

Para um exame abrangente do tema, Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios*, 15. ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 204-219.

189

Para um exame abrangente do tema, Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios*, 15. ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 194-203.

190

Assim, Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios*, 15. ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 195-197; Eros Grau, *Por que Tenho Medo dos Juízes (a Interpretação/Aplicação do Direito e os Princípios)*, 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 133-136.

191

Remo Caponi, Il Principio di Proporzionalità nella Giustizia Civile: Prime Note Sistematiche, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, Milano: Giuffrè, 2011; Sérgio Cruz Arenhart, *A Tutela Coletiva de Interesses Individuais*, São Paulo: Ed. RT, 2013. Sobre o tema, ainda, C. H. van Rhee (coord.), *Judicial Case Management and Efficiency in Civil Litigation*, Oxford: Intersentia, 2008; C. H. van Rhee e Alan Uzelac (coords.), *Civil Justice between Efficiency and Quality: from Ius Commune to the CEPEJ*, Oxford: Intersentia, 2008; Marco Jobim, *As Funções da Eficiência no Processo Civil Brasileiro*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018; Eduardo Luiz Cavalcanti Campos, *O Princípio da Eficiência no Processo Civil Brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

192

A observação é de Robert Wyness Millar, *The Formative Principles of Civil Procedure, A History of Continental Civil Procedure*, p. 6, New York: Little, Brown, and Company, 1927.

193

Nicola Picardi, *Audiat et Altera Pars – Le Matrici Storico-Culturale del Contraddittorio*, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, p. 21-22, Milano: Giuffrè, 2003.

194

Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*, vol I, São Paulo: Ed. RT, 2015.

195

Elio Fazzalari, *La Dottrina Processualistica Italiana: dall’Azione al “Processo” (1864-1994)*, *Rivista di Diritto Processuale*, p. 922, Padova: Cedam, 1994.

196

Andrea Proto Pisani, *Lezioni di Diritto Processuale Civile*, 4. ed., Napoli: Jovene, 2002, p. 202-203.

197

A propósito, essa é a dimensão do direito ao contraditório em um modelo assimétrico de processo, conforme Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 87-103.

198

STF, 2ª Turma, AgRg no RE 222.206/SP, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 30.03.1998.

199

Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*, vol. I, São Paulo: Ed. RT, 2015.

200

Antônio do Passo Cabral, Il Principio del Contraddittorio come Diritto d'Influenza e Dovere di Dibattito, *Rivista di Diritto Processuale*, Padova: Cedam, 2005; Alvaro de Oliveira, O Juiz e o Princípio do Contraditório, *Revista de Processo*, n. 71, São Paulo: Ed. RT, 1993; Dierle Nunes, *Processo Jurisdicional Democrático*, Curitiba: Juruá, 2009.

201

Essa é a ideia de contraditório, aliás, que conforma o modelo cooperativo de processo, Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 87-103.

202

Luigi Paolo Comoglio, *Etica e Tecnica del “Giusto Processo”*, Torino: Giappichelli, 2004, p. 71-74. Longamente, André Pagani de Souza, *Vedação das Decisões-Surpresa no Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 2014.

203

Rosenberg, Schwab e Gottwald, *Zivilprozessrecht*, 17. ed., München: C.H. Beck, 2010, p. 432; Frédérique Ferrand, *Droit Processuel – Droit Commum et Droit Comparé du Procès Équitable*, 4. ed., Paris: Dalloz, 2007, p. 894-904.

204

Nicolò Trocker, *Processo Civile e Costituzione – Problemi di Diritto Tedesco e Italiano*, Milano: Giuffrè, 1974, p. 657.

205

Luigi Paolo Comoglio, *La Garanzia Costituzionale dell'Azione ed il Processo Civile*, Padova: Cedam, 1970, p. 145-146; Miguel Teixeira de Sousa, *Estudos sobre o Novo Processo Civil*, 2. ed., Lisboa: Lex, 1997, p. 66-67.

206

Alvaro de Oliveira, A Garantia do Contraditório, *Do Formalismo no Processo Civil*, 2. ed., p. 237, São Paulo: Saraiva, 2003.

207

Nicolò Trocker, *Processo Civile e Costituzione – Problemi di Diritto Tedesco e Italiano*, Milano: Giuffrè, 1974, p. 645.

208

Alvaro de Oliveira, *Do Formalismo no Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 168.

209

Nicolò Trocker, *Processo Civile e Costituzione – Problemi di Diritto Tedesco e Italiano*, Milano: Giuffrè, 1974, p. 669.

210

STJ, 2ª Turma, REsp n. 1.676.027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 26.09.2017, Dje 11.10.2017.

211

Amplamente, Otávio Domit, *Iura Novit Curia e Causa de Pedir*, São Paulo: Ed. RT, 2016.

212

Michele Taruffo, *La Motivazione della Sentenza Civile*, Padova: Cedam, 1975, p. 407; Vittorio Denti, *La Giustizia Civile*, 2. ed., Bologna: Il Mulino, 2004, p. 104.

213

Sobre a fundamentação, Michele Taruffo, *La Motivazione della Sentenza Civile*, Padova: Cedam, 1975; Jürgen Brüggemann, *Die richterliche Begründungspflicht*, Berlin: Duncker & Humblot, 1971; Tomás-Javier Aliste Santos, *La Motivación de las Resoluciones Judiciales*, Madrid: Marcial Pons, 2011; José Rogério Cruz e Tucci, *A Motivação da Sentença no Processo Civil*, São Paulo: Saraiva, 1987; Sérgio Nojiri, *O Dever de Fundamentar as Decisões Judiciais*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2000; Beclaute Oliveira Silva, *A Garantia Fundamental à Motivação da Decisão Judicial*, Salvador: JusPodivm, 2010; Ana de Lourdes Coutinho Silva, *Motivação das Decisões Judiciais*, São Paulo: Atlas, 2012; Cristina Motta, *A Motivação das Decisões Cíveis*, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012; Rodrigo Ramina de Lucca, *O Dever de Motivação das Decisões*

Judiciais, Salvador: JusPodivm, 2015; Leonard Ziesemer Schmitz, *Fundamentação das Decisões Judiciais*, São Paulo: Ed. RT, 2015; Otávio Motta, *Justificação da Decisão Judicial – A Elaboração da Motivação e a Formação de Precedente*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

214

José Carlos Barbosa Moreira, A Motivação das Decisões Judiciais como Garantia Inerente ao Estado de Direito, *Temas de Direito Processual*, 2. ed., p. 83-95, Segunda Série, São Paulo: Saraiva, 1988.

215

Daí a razão pela qual a doutrina especializada enfatiza a ligação entre o *richterliche Begründungspflicht* e a *Anspruch auf rechtliches Gehör* (Jürgen Brüggemann, *Die richterliche Begründungspflicht – Verfassungsrechtliche Mindestanforderungen an die Begründung gerichtlicher Entscheidungen*, Berlin: Duncker & Humblot, 1971, p. 152-161), entre o *diritto di difesa* e a *motivazione della sentenza* (Michele Taruffo, *La Motivazione della Sentenza Civile*, Padova: Cedam, 1975, p. 401-405), entre o *derecho a la tutela judicial efectiva*, *derecho a la defensa* e *motivación judicial* (Tomás-Javier Aliste Santos, *La Motivación de las Resoluciones Judiciales*, Madrid: Marcial Pons, 2011, p. 145-148).

216

Sobre a ligação entre justificação da decisão e formação de precedente, Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes Obrigatórios*, São Paulo: Ed. RT, 2010; José Rogério Cruz e Tucci, *Precedente Judicial como Fonte do Direito*, São Paulo: Ed. RT, 2004, p. 295-304; Daniel Mitidiero, *Precedentes – da Persuasão à Vinculação*, São Paulo: Ed. RT, 2016; Otávio Motta, *Justificação da Decisão Judicial – A Elaboração da Motivação e a Formação de Precedente*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

217

Sobre a ligação entre o conceito de jurisdição e a necessidade de motivação das decisões judiciais, Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2015, vol. I.

218

Michele Taruffo, *La semplice verità*, p. 196 e ss. (há tradução para o português, *Uma simples verdade*, tradução de Vitor de Paula Ramos, *passim*).

219

Giovanni Tarello, *L'interpretazione della Legge*, p. 9-10.

220

Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Novo Curso de processo civil*, vol. I; mais extensamente, Riccardo Guastini, *Interpretare e argomentare*, p. 39 e ss.; Daniel Mitidiero, *Cortes superiores e cortes supremas – do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente*, p. 59-63 e p. 83-88.

221

Ovídio Baptista da Silva, *Processo e ideologia*, p. 274; Jerzy Wróblewski, *The judicial application of law*, p. 33.

222

Michele Taruffo, *La motivazione della sentenza civile*, p. 123 e ss.

223

Idem, ibidem.

224

Aulis Aarnio, *The rational as reasonable*, p. 120 e ss.

225

Richard Wasserstrom, *The judicial decision. Toward a theory of legal justification*, passim; Joseph Horowitz, *Law and logic*, p. 6; Michele Taruffo, *La motivazione della sentenza civile*, p. 214.

226

Humberto Ávila, *Teoria dos princípios*, p. 26; Enrico Dicitotti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, p. 523; Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, p. 142; Vittorio Villa, *Una teoria pragmaticamente orientata dell'interpretazione giuridica*, p. 175-180.

227

Gerhard Walter, *Libre apreciación de la prueba*, cit., p. 169.

228

Piero Calamandrei, *Verità e verosimiglianza nel processo civile*, cit., p. 190.

229

Michele Taruffo, *La semplice verità*, p. 85-88.

230

Gerhard Walter, *Libre apreciación de la prueba*, cit., p. 169-170.

231

Para uma análise histórico-comparada do problema, Michele Taruffo, Os poderes probatórios das partes e do juiz na Europa, *Processo civil comparado – ensaios*, p. 57 e ss.; Knut Wolfgang Nörr, *Zur Stellung des Richters im gelehrten Prozeß der Frühzeit: Iudex secundum allegata non secundum conscientiam iudicat*, *passim*; Joan Picó i Junoy, *El juez y la prueba*, *passim*; Sérgio Mattos, *Da iniciativa probatória do juiz no processo civil*, *passim*; Trícia Navarro Xavier Cabral, *Poderes instrutórios do juiz no processo de conhecimento*, *passim*.

232

Idem, p. 194-195.

233

Salvatore Patti, *Prove – Disposizioni generali*, cit., p. 158 e ss. No mais, anote-se que para manter a terminologia empregada pelos autores citados, estamos empregando o termo “verossimilhança” como sinônimo de “probabilidade”. Sobre a problemática envolvendo o conceito de verdade, probabilidade, verossimilhança, Luiz Guilherme Marinoni, *Antecipação da tutela*, *passim*; Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, *Prova*, *passim*; Daniel Mitidiero, *Antecipação da tutela*, *passim*; Daisson Flach, *A verossimilhança no processo civil*, *passim*. Ainda, Piero Calamandrei, *Verità e verosimiglianza nel processo civile*, cit.; Michele Taruffo, *La prova dei fatti giuridici*, *passim*.

234

Per Olof Ekelöf, *Beweiswürdigung, Beweislast und Beweis des ersten Anscheins*. ZJP, 75, 1962, p. 289 e ss.

235

Salvatore Patti, *Prove – Disposizioni generali*, cit., p. 160.

236

Idem, p. 161.

237

Idem, p. 162.

238

Idem, ibidem.

239

Cf. Salvatore Patti, *Prove – Disposizioni generali*, cit., p. 164.

240

Idem, p. 164.

241

Gerhard Walter, *Libre apreciación de la prueba*, cit., p. 160.

242

Idem, p. 165-166.

243

Idem, p. 167; p. 171; p. 173-177.

244

Idem, p. 173.

245

Idem, p. 173-174.

246

De acordo com Walter, embora deva ser refutada uma redução geral do módulo da prova no processo civil, isso não exclui que se examine, em certos campos ou em grupos de casos, se razões de direito material ou outros critérios não impõem uma redução desse módulo (Gerhard Walter, *Libre apreciación de la prueba*, cit., p. 211).

247

Idem, p. 240 e ss.

248

Idem, p. 288.

249

Idem, p. 172.

250

Idem, p. 210-211.

251

Juan Igartua Salaverría, *La motivación de las sentencias, imperativo constitucional*, p. 141.

252

Sobre o assunto, Michele Taruffo, *La prova nel processo civile, passim*; Jordi Ferrer Beltrán, *La valoración racional de la prueba, passim*; Massimo Nobili, *Il principio del libero convencimento, passim*; Gerhard Walter, *Libre apreciación de la prueba, passim*; Jordi Nieva Fenoll, *La valoración de la prueba, passim*; Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, *Prova, passim*; Danilo Knijnik, *A prova nos juízos cível, penal e tributário, passim*; Luís Alberto Reichelt, *A prova no direito processual civil, passim*.

253

Juan Igartua Salaverría, *La motivación de las sentencias, imperativo constitucional*, cit., p. 153.

254

Salaverría afirma que o contraditório obriga o juiz a indicar as razões que excluem a versão e as provas da parte perdedora (Juan Igartua Salaverría, *La motivación de las sentencias, imperativo constitucional*, cit., p. 158).

255

J. Normand, Le domaine du principe de motivation. In: VV.AA. *La motivation (travaux de l'Association H. Capitant)*, p. 18, nota 3, citado por Salaverría, *La motivación de las sentencias, imperativo constitucional*, cit., p. 159.

256

Michele Taruffo, *La motivazione della sentenza civile*, Pádua: Cedam, 1975, p. 407.

257

Idem, p. 161.

258

Ver Michele Taruffo, *Studi sulla rilevanza della prova*, p. 292 e ss.; Juan Igartua Salaverría, *La motivación de las sentencias, imperativo constitucional*, cit., p. 162 e ss.

259

Michele Taruffo, *La motivazione della Sentenza Civile*, *Revista de Direito Processual Civil*, v. 30, p. 674 e ss.

260

Michele Taruffo, Funzione della prova: la funzione dimostrativa, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1997, p. 555.

261

Idem, p. 555.

262

F. M. Iacoviello, La motivazione, apud Salaverría, *La motivación de las sentencias, imperativo constitucional*, cit., p. 154.

263

Taruffo advertiu, em conferência proferida na Faculdade de Direito da UFPR, que, quando se alude às regras de experiência, também se fala em “senso comum”, “cultura média” e em *background knowledges* (cf. Michele Taruffo, *Senso comum, experiência e ciência no raciocínio do juiz*, conferência proferida na Faculdade de Direito da UFPR, Curitiba, março de 2001, p. 17). Sobre as máximas de experiência, ainda, Francisco Rosito, *Direito probatório – As máximas de experiência em juízo, passim*.

264

Juan Igartua Salaverría, *La motivación de las sentencias, imperativo constitucional*, cit., p. 167.

265

Cf. Juan Igartua Salaverría, *La motivación de las sentencias, imperativo constitucional*, cit., p. 165.

266

Idem, p. 166.

267

Idem, ibidem.

268

Michele Taruffo, *Funzione della prova: la funzione dimostrativa*, cit., p. 561.

269

Idem, ibidem.

270

Idem, p. 562.

271

Juan Igartua Salaverría, *La motivación de las sentencias, imperativo constitucional*, cit., p. 168.

272

Idem, p. 169.

273

Assim, em termos, Juan Igartua Salaverría, *La motivación de las sentencias, imperativo constitucional*, cit., p. 182.

274

Michele Taruffo, *Funzione della prova: la funzione dimostrativa*, cit., p. 565.

275

Michele Taruffo, *La prova dei fatti giuridici*, cit., p. 281 e ss.; *Funzione della prova: la funzione dimostrativa*, cit., p. 566 e ss.

276

Funzione della prova: la funzione dimostrativa, cit., p. 567.

277

Michele Taruffo, *La prova dei fatti giuridici*, cit., p. 282.

278

Michele Taruffo, *Funzione della prova: la funzione dimostrativa*, cit., p. 568.

279

Michele Taruffo, *La prova dei fatti giuridici*, cit., p. 290.

280

“Il processo non è interessato ad acquisire narrazioni coerenti anche se false, ma narrazione vere (anche se incoerenti)” (Michele Taruffo, *La prova dei fatti giuridici*, cit., p. 287).

281

Sobre as teorias da verdade como coerência e como consenso, ver Anna Pintore, *Il diritto senza verità*, p. 143 e ss. e 188 e ss.

282

Michele Taruffo, *La prova dei fatti giuridici*, cit., p. 294.

283

Idem, ibidem.

284

Idem, p. 295.

285

Idem, p. 295-296.

286

Idem, p. 296.

287

Michele Taruffo, Il Controllo di Razionalità della Decisione fra Logica, Retorica e Dialettica, *Revista de Processo*, São Paulo: Ed. RT, 2007, n. 143.

288

Juan Igartua Salaverría, *La motivación de las sentencias, imperativo constitucional*, cit., p. 185.

289

Michele Taruffo, *La motivazione della sentenza civile*, p. 467.

290

Os termos vagos estão presentes tanto nos chamados conceitos jurídicos indeterminados como nas cláusulas gerais. De acordo com a doutrina, os primeiros são espécies normativas em que, no suporte fático, há previsão de termo indeterminado e há consequências jurídicas legalmente previstas; as segundas são espécies normativas em que há previsão de termo indeterminado no suporte fático e não há previsão de consequências jurídicas na própria proposição legal (Judith Martins-Costa, *A boa-fé no direito privado*, p. 273-348). Exemplo de conceito jurídico indeterminado: o conceito de “justa causa” para efeito de restituição de prazo processual (art. 223, CPC). Exemplo de cláusula geral: “aquele que de qualquer

forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5.º, CPC).

291

Por debaixo dessa visão do direito ao contraditório encontra-se a concepção cognitivista da interpretação judicial do direito, sobre o assunto Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*, vol. I, cit.

292

Por debaixo dessa visão do direito ao contraditório encontra-se a concepção não cognitivista da interpretação judicial do direito, sobre o assunto, Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*, vol. I, cit.

293

Karl Engisch, *Einführung in das juristische Denken*, p. 189.

294

Ronald Dworkin, *Law's Empire*, p. 225 e ss.

295

Cláudio Mello, *Verdade moral e método jurídico na teoria constitucional de Ronald Dworkin*, p. 285 e ss. Para uma crítica a Dworkin, ainda, Juliano Maranhão, *Positivismo jurídico lógico-inclusivo*, p. 79 e ss.

296

Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*, vol. I, cit. Ainda, Humberto Ávila, *Teoria dos princípios*, *passim*.

297

Sobre o conceito de postulado, também conhecido como norma de segundo grau e como metanorma, Humberto Ávila, *Teoria dos princípios*, p. 163 e ss.

298

Sobre o conceito de normas de primeiro grau, igualmente, Humberto Ávila, *Teoria dos princípios*, p. 163 e ss.

299

Consoante Humberto Ávila, *Teoria dos princípios*, p. 163-164: “a interpretação de qualquer objeto cultural submete-se a algumas condições essenciais, sem as quais o objeto não pode ser sequer apreendido. A essas condições essenciais dá-se o nome de postulados. Há os postulados meramente hermenêuticos, destinados

à compreensão geral do Direito, e os postulados aplicativos, cuja função é estruturar a sua aplicação concreta. Os postulados normativos aplicativos são normas imediatamente metódicas que instituem os critérios de aplicação de outras normas situadas no plano do objeto da aplicação. Assim, qualificam-se como normas sobre a aplicação de outras normas, isto é, como metanormas. Daí se dizer que se qualificam como normas de segundo grau. Nesse sentido, sempre que se está diante de um postulado normativo, há uma diretriz metódica que se dirige ao intérprete relativamente à interpretação de outras normas. Por trás dos postulados, há sempre outras normas que estão sendo aplicadas. Não se identificam, porém, com as outras normas que também influenciam outras, como é o caso dos sobreprincípios do Estado de Direito ou da segurança jurídica. Os sobreprincípios situam-se no nível das normas objeto da aplicação. Atuam sobre outras, mas no âmbito semântico e axiológico e não no âmbito metódico, como ocorre com os postulados. Isso explica a diferença entre sobrenormas (normas semântica e axiologicamente sobrejacentes, situadas no nível do objeto de aplicação) e metanormas (normas metodicamente sobrejacentes, situadas no metanível aplicativo). Os postulados funcionam diferentemente dos princípios e das regras. A uma, porque não se situam no mesmo nível: os princípios e as regras são normas objeto da aplicação; os postulados são normas que orientam a aplicação de outras. A duas, porque não possuem os mesmos destinatários: os princípios e as regras são primariamente dirigidos ao Poder Público e aos contribuintes; os postulados são frontalmente dirigidos ao intérprete e aplicador do Direito. A três, porque não se relacionam da mesma forma com outras normas: os princípios e as regras, até porque se situam no mesmo nível do objeto, implicam-se reciprocamente, quer de modo preliminarmente complementar (princípios), quer de modo preliminarmente decisivo (regras); os postulados, justamente porque se situam num metanível, orientam a aplicação dos princípios e das regras sem conflituosidade necessária com outras normas”.

300

Como observa Humberto Ávila, *Teoria dos princípios*, p. 204-205, o postulado da proporcionalidade aplica-se “apenas a situações em que há uma relação de causalidade entre dois elementos empiricamente discerníveis, um meio e um fim, de tal sorte que se possa proceder aos três exames fundamentais: o da adequação (o meio promove o fim?), o da necessidade (dentre os meios disponíveis e igualmente adequados para promover o fim, não há outro meio menos restritivo do(s) direito(s) fundamentais afetados?) e o da proporcionalidade em sentido estrito (as vantagens trazidas pela promoção do fim correspondem às desvantagens provocadas pela adoção do meio?). Nesse sentido, a proporcionalidade, como postulado estruturador da aplicação de princípios que concretamente se imbricam em torno de uma relação de causalidade entre um meio e um fim, não possui aplicabilidade irrestrita. Sua aplicação depende de elementos sem os quais não pode ser aplicada. Sem um meio, um fim concreto e uma relação de causalidade entre eles não há aplicabilidade do postulado da proporcionalidade em seu caráter trifásico”.

301

Humberto Ávila, *Teoria dos princípios*, p. 194: “relativamente à razoabilidade, dentre tantas acepções, três se destacam. Primeiro, a razoabilidade é utilizada como diretriz que exige a relação das normas gerais com as individualidades do caso concreto, quer mostrando sob qual perspectiva a norma deve ser aplicada, quer indicando em quais hipóteses o caso individual, em virtude de suas especificidades, deixa de se enquadrar na norma geral. Segundo, a razoabilidade é empregada como diretriz que exige uma vinculação das normas jurídicas com o mundo ao qual elas fazem referência, seja reclamando a existência de um suporte empírico e adequado a qualquer ato jurídico, seja demandando uma relação congruente

entre a medida adotada e o fim que ela pretende atingir. Terceiro, a razoabilidade é utilizada como diretriz que exige a relação de equivalência entre duas grandezas”.

302

Humberto Ávila, *Teoria dos princípios*, p. 185: “a ponderação de bens consiste num método destinado a atribuir pesos a elementos que se entrelaçam, sem referência a pontos de vista materiais que orientem esse sopesamento”.

303

Rosenberg, Schwab e Gottwald, *Zivilprozessrecht*, 17. ed., München: C. H. Beck, 2010, p. 113.

304

José Joaquim Gomes Canotilho, *Direito Constitucional e Teoria da Constituição*, 7. ed., Coimbra: Almedina, 2003, p. 98-100.

305

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 4. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997, t. III, p. 51, Robert Wyness Millar, *The Formative Principles of Civil Procedure, A History of Continental Civil Procedure*, Boston: Little, Brown, and Company, 1927, p. 69-70.

306

Sobre o assunto, longamente, Helena Abdo, *Mídia e Processo*, São Paulo: Saraiva, 2011.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. I - Marinoni - Ed. 2018

CAPÍTULO II - DA APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS

Art. 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte.

1. Normas Brasileiras

A jurisdição civil é regida pela Constituição e legislação brasileira. No entanto, também são invocáveis para disciplina do processo civil normas processuais civis internacionais previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte (art. 13, CPC).

Para que as normas processuais constantes em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja signatário possam ser aplicadas em nosso país é necessário que a norma internacional tenha sido devidamente internalizada¹. A rigor, os tratados, convenções ou acordos só podem ser aplicados depois de devidamente internalizados – vale dizer, constituem igualmente direito interno, direito brasileiro, de modo que a ressalva constante do art. 13, CPC, não faz sentido.

Os tratados, convenções ou acordos devem ser celebrados pelo Presidente da República, sendo posteriormente submetidos a referendo pelo Congresso Nacional (art. 84, VIII, CRFB) e incorporados mediante decreto legislativo. Se as normas internacionais, devidamente internalizadas, versarem sobre direitos humanos processuais, o respectivo *status* normativo interno é de emenda constitucional (art. 5.º, § 3.º, CRFB). Se, porém, não versarem sobre direitos humanos processuais, o respectivo *status* é supralegal, mas ainda assim infraconstitucional.

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

1. Direito Intertemporal

O art. 14, CPC, regula a sucessão de leis processuais no tempo e a sua aplicação aos processos pendentes – disciplina o direito intertemporal processual. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5.º, XXXVI, CRFB). Vale dizer: há direito fundamental à observância do direito processual adquirido, do ato processual perfeito e da coisa julgada.

O art. 14, CPC, densifica na legislação infraconstitucional o direito fundamental à segurança jurídica processual², especialmente no que tange à observância do direito processual adquirido, do ato processual perfeito e da coisa julgada. Existem, portanto, não apenas direitos adquiridos no plano do direito material, mas também direitos adquiridos processuais³.

2. Efeito Imediato e Efeito Retroativo

Não se confundem. A legislação processual civil superveniente impacta de maneira imediata os processos pendentes, desde que respeitados eventuais direitos adquiridos processuais e os atos processuais perfeitos. Há efeito retroativo quando a lei nova é aplicada a situações jurídicas já

consolidadas. O efeito retroativo é vedado pelo direito constitucional brasileiro (arts. 5.º, XXXVI, CRFB, e 14, CPC). Há efeito imediato quando a legislação é aplicada a partir do momento em que entra em vigor, regendo as situações jurídicas que lhe são posteriores⁴.

Interessa a distinção entre efeito imediato e efeito retroativo no plano processual no que tange às situações jurídicas pendentes. O processo, considerado globalmente, é uma situação pendente até que advenha o trânsito em julgado. É uma atividade, por definição, projetada no tempo. O processo é um procedimento em contraditório, um procedimento adequado à consecução dos fins do Estado Constitucional, formado por vários atos processuais. Alguns desses atos já foram realizados – consideram-se já praticados e imunes à eficácia da lei nova, sob pena de retroatividade e ofensa ao ato processual perfeito. Outros atos já foram praticados e há relativa independência com os demais atos que devem se seguir na cadeia procedimental. Nesse caso, a lei processual nova vincula a partir desse momento. Não há que se falar em irretroatividade em semelhante situação; há efeito imediato. Em outros, há um vínculo bastante acentuado entre o ato processual já praticado e o seu consequente. Esse vínculo advém da circunstância da prática desse ato processual outorgar direito a qualquer dos participantes do processo. Em situações que tais, a lei nova não pode vincular desde logo; tem-se que respeitar o direito processual adquirido. Respeita-se a situação jurídica *in fieri*. Tem-se que respeitar a eficácia do ato processual já praticado.

3. Isolamento dos Atos Processuais

A exata compreensão da distinção entre efeito imediato e efeito retroativo da legislação leva à necessidade de isolamento dos atos processuais a fim de que saiba se a aplicação da legislação nova importa efeito imediato ou efeito retroativo⁵. A observação ganha em importância a propósito da aplicação da lei nova a situações pendentes. O que interessa é saber se do ato processual advém ou não direito para qualquer dos participantes do processo. Vale dizer: releva saber se há ou não direito adquirido processual.

Nesse caso, a lei nova tem de respeitar a eficácia do ato processual já praticado. O exemplo clássico encontra-se no direito recursal. A lei do recurso é a lei do dia em que se tornou recorrível a decisão. A abertura de prazo recursal dá lugar a uma situação jurídica pendente – aguarda-se a interposição ou não do recurso. O recorrente tem direito à observação do direito vigente à época da abertura do prazo recursal. Fora daí há ofensa a direito processual adquirido e efeito retroativo da legislação.

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.

1. Supletiva e Subsidiariamente

Na ausência de disposições processuais que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições do Código de Processo Civil serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Nessa linha, na ausência de norma específica, a disciplina do processo civil tem caráter geral – isto é, transeletiva⁶.

Com o art. 15, CPC, o processo civil brasileiro assume positivamente o papel que a doutrina amíu sempre procurou lhe assinalar de “direito processual comum”⁷. Vale dizer: inexistindo incompatibilidade, as soluções dadas pelo processo civil são aproveitáveis nos demais setores processuais.

1

Guilherme Rizzo Amaral, *Comentários às Alterações do Novo CPC*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 71.

2

Leonardo Carneiro da Cunha, *Direito Intertemporal e o Novo Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 8.

3

Guilherme Rizzo Amaral, *Estudos de Direito Intertemporal e Processo*, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 17.

4

Galeno Lacerda, *O Novo Direito Processual Civil e os Feitos Pendentes*, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 1.

5

Guilherme Rizzo Amaral, *Estudos de Direito Intertemporal e Processo*, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 20-22; Leonardo Carneiro da Cunha, *Direito Intertemporal e o Novo Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 27.

6

Riccardo Guastini, *Teoria del Diritto – Approccio Metodologico*, Modena: Mucchi Editore, 2012, p. 29.

7

José Carlos Barbosa Moreira, *As Bases do Direito Processual Civil, Temas de Direito Processual*. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 4.

Comentários ao CPC - v. I - Marinoni - Ed. 2018**LIVRO II - DA FUNÇÃO JURISDICIONAL - TÍTULO I - DA JURISDIÇÃO E DA AÇÃO**

1. Críticas às teorias tradicionais da jurisdição. A doutrina que se formou com o Código Buzaid, de um modo geral, definia a jurisdição como a atuação substitutiva da vontade concreta da lei – ou do direito – ou como o poder de dizer o direito para solução de uma lide com força de coisa julgada.¹ Essas teorias, porém, não conseguem retratar a jurisdição no Estado Constitucional e, portanto, não podem servir de base para a compreensão do Código de 2015.

Ainda que não seja tarefa dos nossos *Comentários* tratar de forma mais aprofundada dessas questões teóricas, na medida em que entendemos que o local mais apropriado para tanto seja o nosso *Curso* e as nossas monografias, é imprescindível situar o leitor na evolução do tema. Além disso, para que se possa adotar uma chave de leitura apropriada do Código de 2015, é importante ter presente um conceito de jurisdição capaz de dar conta das especificidades da interpretação e da aplicação do direito no Estado Constitucional.

1.1. Crítica à teoria que afirma que o juiz atua a vontade concreta da lei. A teoria que afirma que o juiz atua a vontade concreta do direito, como visto, foi compartilhada por Chiovenda. O direito nada mais era do que a lei, isto é, do que a norma geral e preexistente a ser aplicada aos casos concretos. Ao juiz bastaria aplicar a norma geral criada pelo legislador. Criação e aplicação, aí, separavam-se nitidamente.

Essa teoria supunha que o juiz podia solucionar qualquer caso mediante a aplicação das normas gerais, uma vez que o ordenamento jurídico seria completo e coerente. Por isso, tal teoria pode ser explicada à luz do Código Napoleão – corolário da doutrina da divisão de poderes –, diante da sua preocupação de constituir uma legislação completa e coerente para as relações civis, comerciais, tributárias e por aí afora. Vale dizer: é uma teoria que supõe que o império do Direito poderia ser promovido com a simples declaração de normas preexistentes pela jurisdição, que nesse caso exerceria um poder que se limitaria à declaração da norma legal. No fundo, trata-se de um modelo de supremacia do Direito de legislação sem jurisdição.

Se a legislação era completa e coerente, e assim capaz de dar à jurisdição condições de solucionar qualquer caso, o juiz jamais precisaria cristalizar uma norma – mediante a interpretação da lei de acordo com a Constituição – para regular a situação litigiosa. Não precisaria e nem poderia delinear uma norma jurídica segundo os ditames da Constituição porque nessa época não se apresentava a ideia de que a validade da lei é vinculada aos princípios constitucionais e aos direitos fundamentais. Como a lei também não podia considerar a realidade, as desigualdades sociais e o pluralismo, bastava à jurisdição aplicar a lei genérica e abstrata, típica do Estado liberal.

Por outro lado, os casos conflitivos continham características homogêneas, o que não exigia do juiz uma especial compreensão das suas particularidades. Na verdade, o caso sobre o qual o magistrado devia se debruçar era encoberto pela lógica da subsunção, para quem os fatos eram considerados a premissa menor e a norma geral a premissa maior. Tais fatos, ou simplesmente o caso, porque vinham de uma sociedade compreendida a partir de um ângulo igualizador, não exigiam qualquer esforço interpretativo ou de atribuição de sentido, o que dava à tarefa do juiz uma qualidade quase mecânica. Era suficiente relacionar o caso, sem a necessidade da sua compreensão, com a norma geral, cujo conteúdo era claro e indiscutível.

1.2. Crítica à teoria de Carnelutti e à teoria que sustenta que o juiz cria a norma individual que dá solução ao caso concreto. Já vimos que a teoria de Carnelutti, ao afirmar que

a função do juiz é a composição da lide, aceita a ideia de que o juiz, ao *compor a lide*, cria a norma individual que regula o caso concreto. A sentença, ou a norma individual, faz concreta a norma geral, passando a integrar o ordenamento jurídico; a composição da lide ocorre quando a sentença torna a norma geral particular para as partes.

Mas a diferença entre a teoria que supõe que a função do juiz é declaratória – limita-se a aplicar a norma geral – e a teoria que afirma que o juiz cria a norma individual ao resolver o litígio *não está na tese de que o juiz – na segunda e não na primeira teoria – pode esculpir ou criar a norma geral*.

Isso porque Kelsen deixou claro que o juiz cria a norma individual *com base na norma geral*, até porque, segundo a sua teoria, toda norma tem fundamento em uma norma superior, até se chegar à norma fundamental, que estaria no ápice do ordenamento. Ou seja, o legislador, subordinado à Constituição, cria as normas gerais, e o juiz, vinculado à lei, cria as normas individuais ao proferir as sentenças.² Nesse sentido, afirma-se que, para Kelsen, a diferença entre as funções do legislador e do juiz é apenas quantitativa, na medida em que, apesar de o juiz estar mais limitado que o legislador, ambos criam normas com fundamento em normas superiores.³

As duas teorias, vistas nessa perspectiva, variam apenas porque em uma o juiz declara a norma geral sem produzir uma norma individual e na outra o juiz cria uma norma individual com base na norma geral declarada na sua fundamentação (da sentença). *De modo que as duas teorias estão igualmente subordinadas ao princípio da supremacia da lei*.

É certo que se pode dizer que a sentença é produto de um ato de vontade – e não de mero conhecimento – e, nesse ponto, está de acordo com Kelsen. Mas isso não pode permitir a conclusão, encontrada pelo próprio Kelsen, de que o juiz cria direitos.⁴ Isso em razão de uma simples constatação: o juiz não cria propriamente direito quando atua com base em uma norma superior geral.⁵

Concorda-se, também, que a sentença considera particularidades do caso individual inimagináveis na norma geral, uma vez que essa última apenas pode formular em abstrato aquilo que deve ser considerado no caso concreto. Mas, diante disso, não parece existir substancial diferença entre a declaração da norma geral *no caso concreto* e a criação da norma individual mediante a *particularização da norma geral para as partes*.

O que identifica os dois conceitos é a necessidade de se tomar em conta as particularidades da situação litigiosa. Tanto a declaração da lei, quanto a criação da norma individual exigem que sejam levadas em conta as peculiaridades do caso concreto. De modo que uma substancial diferenciação entre as duas teorias exigiria uma distinção em relação *ao modo de apreciação* de tais particularidades. Porém, a teoria kelseniana jamais pretendeu se diferenciar da teoria clássica da jurisdição por considerar a realidade do caso concreto *a partir de outro ângulo visual ou de forma mais aprofundada*. Na verdade, aqui as duas teorias *mais uma vez se aproximam*, limitando-se a exprimir teórica e linguisticamente diversas situações que, em substância, não são aptas para permitir a diferenciação de uma diante da outra.⁶

É fácil perceber que em uma sociedade legalmente igualizada, em que as relações têm características definidas como homogêneas, não há dificuldade na visualização das particularidades dos casos conflitivos. Por esse motivo, na época em que se falava de *lei genérica e abstrata*, não se podia sequer imaginar que um dia o juiz teria de *compreender* e atribuir *sentido e valor* aos casos concretos.⁷ O caso era visto como algo quase que predefinido e, nessa linha, a função do juiz era apenas preencher as suas particularidades. Como a jurisdição não precisava outorgar *sentido* ao caso, bastava a sua subsunção à norma geral mediante mera aplicação lógica.

É verdade que a norma individual, ou a sentença, outorga características ao caso, mas é impossível ignorar que, na atualidade – diante do pluralismo da sociedade e da constante transformação dos fatos sociais –, *é necessário muito mais do que isso, uma vez que a interpretação da lei, ou a norma formulada pelo juiz, depende do sentido do caso concreto*.

Portanto, nenhuma dessas teorias responde aos valores do Estado Constitucional. Não só porque ambas são escravas do princípio da supremacia da lei, mas também porque as duas negam lugar à *compreensão* do caso concreto no raciocínio decisório, isto é, no raciocínio que leva à prestação da tutela jurisdicional.

2. Bases para uma teoria da jurisdição no Estado Constitucional. Uma vez que se percebe a inadequação das teorias anteriores sobre a jurisdição, impõe-se a consideração dos elementos necessários para uma nova compreensão do fenômeno jurisdicional. É somente a partir da consideração desses dados é que se pode esboçar um conceito de jurisdição compatível com o Estado Constitucional.

2.1. O pluralismo e a necessidade de compreensão dos casos concretos. Quando se insiste na necessidade de o juiz atribuir sentido⁸ ao caso levado à sua análise, deseja-se, antes de tudo, dizer que ele não pode se afastar da realidade em que vive. Se a percepção das novas situações, derivadas do avanço cultural e tecnológico da sociedade, é fundamental para a atribuição de sentido aos casos que não estão na cartilha do judiciário, a apreensão dos novos fatos sociais, que atingem a família, a empresa, o trabalho etc., é igualmente imprescindível para a atribuição de um sentido contemporâneo aos velhos modelos capazes de ser estratificados em casos.

Embora essas duas atitudes também importem para desvendar a necessidade de uma nova elaboração legislativa, o seu peso maior recai sobre o juiz, uma vez que é evidente que o legislador não pode andar na mesma velocidade da evolução social – o que, aliás, já constitui ditado vulgarizado. Por isso, o surgimento de novos fatos sociais dá ao juiz legitimidade para construir novos casos e para reconstruir o significado dos casos já existentes ou simplesmente para atribuir sentido aos casos concretos.

2.2. A conformação da lei exige a prévia atribuição de sentido ao caso concreto, mas a definição do caso concreto requer a consideração da lei. Essa necessidade de atribuição de sentido aos casos concretos significa que os novos fatos sociais são vitais para a compreensão do direito ou para a conformação da lei.

Porém, essa atribuição de sentido obviamente não dispensa a prévia análise da lei. Vale dizer que, para se dar sentido ao caso, é necessário pensar na lei, ou melhor, é necessário considerar de que modo o caso se insere em face da lei e da interpretação que lhe é dada pelos tribunais.

2.3. A jurisdição, após delinear o caso concreto, deve conformar a lei. Uma vez delineado o caso concreto, resta ao juiz regulá-lo através da lei. Contudo, como foi amplamente demonstrado, a concepção de direito no Estado Constitucional é completamente diferente da que lhe foi atribuída pelo Estado liberal. Não mais prevalece o princípio da supremacia da lei e essa não é mais vista como um produto perfeito e acabado.

Hoje a lei se submete às normas constitucionais, devendo ser conformada pelos princípios constitucionais de justiça e pelos direitos fundamentais. É correto dizer, aliás, que uma das mais importantes características do constitucionalismo contemporâneo está na definição normativo-constitucional de princípios materiais de justiça, cuja função é iluminar a compreensão do ordenamento jurídico.

Dizer que a lei tem a sua substância moldada pela Constituição implica admitir que o juiz não é mais um funcionário público burocrata que objetiva solucionar os casos conflitivos mediante a afirmação do texto da lei, mas sim um agente do poder que, através da adequada interpretação da lei e do controle da sua constitucionalidade, tem o dever de definir os litígios fazendo valer os princípios constitucionais de justiça e os direitos fundamentais.⁹

2.4. A decisão a partir dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais. Já se deixou claro que a lei, no Estado contemporâneo, tem a sua substância condicionada aos princípios constitucionais de justiça e aos direitos fundamentais. Compreender a lei a partir dos direitos fundamentais significa inverter a lógica da ideia de que esses direitos dependem da lei, pois hoje são as leis que têm a sua validade circunscrita aos direitos fundamentais, além de só

admitirem interpretações que a eles estejam adequadas.¹⁰

Isso obviamente representa uma reação contra o princípio da supremacia da lei e contra o absolutismo do legislador. A força normativa dos direitos fundamentais, ao impor o dimensionamento do produto do legislador, faz com que a Constituição deixe de ser encarada como algo que foi abandonado à maioria parlamentar. A vontade do legislador, agora, está submetida à vontade suprema do povo, ou melhor, à Constituição e aos direitos fundamentais.¹¹

A lei deve ser interpretada de acordo com a Constituição. Isso significa que o juiz, após encontrar mais de uma solução a partir dos critérios de interpretação da lei, deve obrigatoriamente escolher aquela que outorgue a maior efetividade à Constituição.¹² Trata-se, desse modo, de uma forma de filtrar as interpretações possíveis da lei, deixando passar apenas a que melhor se ajuste às normas constitucionais.¹³ Aí se está diante de uma regra de interpretação da lei e não de uma regra para o controle da constitucionalidade da lei. A regra da *interpretação de acordo* importa quando um texto de lei abre oportunidade a várias interpretações constitucionais e não para a hipótese em que a norma, diante de uma primeira compreensão, apresenta-se como inconstitucional. O objetivo não é descartar uma interpretação que faz a lei inconstitucional ou mesmo conferir à lei que, em uma primeira perspectiva é inconstitucional, uma determinada interpretação que a torne constitucional.

A lei inconstitucional ou a lei cuja aplicação literal conduz a um juízo de inconstitucionalidade deve ser declarada inconstitucional. A lei que, em princípio, sugere interpretação inconstitucional, não deve ser declarada inconstitucional se puder ser salva mediante o emprego da técnica da *interpretação conforme*. A técnica da *interpretação conforme* não visa a permitir a escolha da interpretação que melhor se ajusta à Constituição, mas a excluir a interpretação inconstitucional e a definir a interpretação que confere constitucionalidade à norma. Trata-se de técnica de controle de constitucionalidade.

Alguém poderia dizer que, interpretando-se de acordo, elimina-se a interpretação inconstitucional e que, portanto, não há diferença entre *interpretação de acordo* e *interpretação conforme*. Porém, a distinção entre a regra da *interpretação de acordo* e a técnica da *interpretação conforme* não está em sua operacionalidade interna, mas nos específicos problemas com que se defrontam e, assim, na feição que assumem diante das diferentes metodologias que se apresentam para resolver cada um dos distintos problemas. A *interpretação de acordo* coloca-se diante de um problema de interpretação, diante de várias interpretações possíveis a exigir uma interpretação que melhor se ajuste ao sentido da Constituição. Constitui, assim, uma regra de hermenêutica. De outra parte, a *interpretação conforme* se apresenta em face de uma norma a que se confere interpretação inconstitucional e, portanto, diante de um problema de constitucionalidade que, por desafiar controle jurisdicional, requer o emprego de técnica de controle de constitucionalidade.

Há, ainda, casos em que uma norma constitucional é aplicada em situações que a tornam inconstitucional. Assim, no caso em que se impugna a aplicação de norma em determinada situação, o juiz, ainda que reconhecendo a sua inconstitucionalidade nessa situação, deve preservar a norma ao perceber a sua constitucionalidade diante de outras situações. Há aí emprego da técnica da *declaração parcial de nulidade sem redução de texto*. A nulidade – ou a inconstitucionalidade – é pronunciada para a específica situação, preservando-se a norma ou o texto legal.

Lembre-se que as leis que criam ou aumentam tributo, diante do princípio constitucional da anterioridade (art. 150, III, *b*, CF), não podem ser aplicadas no mesmo exercício financeiro, embora possam e devam ser aplicadas no exercício financeiro seguinte. De modo que, defrontando-se o tribunal com hipótese em que se pretende aplicar a norma no mesmo exercício financeiro, a solução será a de declarar a inconstitucionalidade da aplicação da norma, preservando-se a validade da lei.

Perceba-se que aí há controle de constitucionalidade. A técnica permite a preservação da norma ou do texto legal ainda que a decisão pronuncie, para a específica situação, a sua inconstitucionalidade. Não há redução da validade do dispositivo, que resta com plena força

normativa, mas restrição do seu âmbito de aplicação.

Diante disto, a diferença entre as técnicas de controle de constitucionalidade conhecidas como *interpretação conforme* e *declaração parcial de nulidade sem redução de texto* está em que, na primeira, evita-se a declaração de inconstitucionalidade da norma, conferindo-se a ela interpretação que a torna inconstitucional, e, na segunda, preserva-se a constitucionalidade ou a validade da norma, haja vista que a inconstitucionalidade se dá apenas na situação impugnada. Nos dois casos, porém, declara-se inconstitucionalidade; no primeiro a inconstitucionalidade da interpretação ou das interpretações originariamente propostas e, no segundo, a inconstitucionalidade da aplicação da norma na situação específica.

A *interpretação conforme* exclui a interpretação proposta e impõe outra, conforme a Constituição, enquanto a *declaração parcial de nulidade* revela a ilegitimidade da aplicação da norma na situação proposta, ressaltando a sua aplicabilidade em outras. Em um caso limita-se o âmbito de validade da *interpretação* e, no outro, o âmbito de validade da *aplicação*.

Igualmente de grande importância, para uma nova concepção de jurisdição, é a possibilidade de o juiz controlar a inconstitucionalidade por omissão no caso concreto. Como já foi dito, há normas constitucionais que impõem dever de legislar e há direitos fundamentais que, embora decorrentes de normas que se calam sobre essa espécie de dever, dependem, para a sua efetivação ou proteção, de regramento infraconstitucional.

Como os direitos fundamentais devem ser protegidos ou tutelados pelo *Estado* e, assim, não apenas pelo legislador, é possível verificar, no caso concreto, se a omissão normativa implicou negação de tutela ao direito fundamental para, na hipótese positiva, admitir que o juiz supra a omissão de proteção devida pelo legislador.

Ademais, há situações em que não se reclama a ausência de lei necessária para a proteção do direito fundamental, mas há conflito entre dois direitos fundamentais no caso concreto. Assim, por exemplo, a situação em que direito da personalidade, como o direito à honra, coloca-se em rota de colisão com direito de liberdade, como o direito à liberdade de expressão. Aqui não se lamenta a inexistência de lei que deveria ter sido editada para dar proteção ao direito fundamental (de personalidade), porém se questiona a amplitude do direito fundamental de liberdade frente ao direito fundamental de personalidade, ou melhor, a possibilidade de o direito fundamental de personalidade ser diretamente invocado para conter o direito fundamental de liberdade. Nesse caso, tem-se que saber se a restrição ao direito de liberdade é *proporcional* em relação à proteção ao direito de personalidade, o que exige a aplicação do postulado da *proporcionalidade* como meio para *adequada estruturação da aplicação* de direitos fundamentais, o que leva à pergunta sobre a *adequação, necessidade e proporcionalidade* da restrição.¹⁴

Nesse sentido, os princípios e os direitos fundamentais podem ser vistos não apenas como a substância que orienta o modo de ser do ordenamento jurídico, mas também como as ferramentas que servem para: i) a interpretação de acordo; ii) a não aplicação da lei inconstitucional (declaração de inconstitucionalidade da lei); iii) a preservação da norma mediante a definição de determinada interpretação constitucional (interpretação conforme); iv) a preservação da norma mediante a declaração da constitucionalidade da sua aplicação em outras situações, que não a impugnada (declaração parcial de nulidade sem redução de texto); v) a geração da regra necessária para que o direito fundamental seja feito valer (controle da omissão inconstitucional); e vi) a proteção de um direito fundamental diante de outro (o que pode ser estruturado argumentativamente a partir da aplicação de postulados normativos, como a ponderação, a concordância prática, a proporcionalidade e a razoabilidade).

2.5. Conformação da lei e sentido da criação da norma jurídica pelo juiz. A reconstrução da ordem jurídica pela interpretação. Como restou claro no último parágrafo, por *conformação da lei* não se pode entender simplesmente interpretação de acordo ou adequação da lei à Constituição. Nas hipóteses de declaração de inconstitucionalidade e de supressão de omissão constitucional há uma *conformação da legislação* (embora não exatamente da lei) às normas constitucionais.

Mas a conformação da lei ou da legislação faz com que o juiz, de certo modo, crie, mediante a interpretação ou o controle da constitucionalidade, uma *norma jurídica* para justificar a sua decisão. Na verdade, mais precisamente, o juiz opera uma verdadeira *reconstrução* da ordem jurídica ao outorgar um significado aos textos da Constituição e da legislação infraconstitucional.¹⁵

Trata-se de propor, na verdade, a conhecida distinção entre *dispositivo*, visto como *texto* da lei, e *norma jurídica*, compreendida como o *resultado* da interpretação do texto legal,¹⁶ deixando-se claro, no entanto, que tal norma jurídica *não é apenas a expressão da interpretação da lei, mas também o resultado do controle de constitucionalidade*.

Porém, esse sentido de criação da norma jurídica nada tem a ver com aquele que lhe foi atribuído pelos teóricos que viam a sentença como *norma individual* que particulariza a norma geral. A norma jurídica, no presente contexto, não almeja ser a parte dispositiva (que define o litígio) da sentença. A norma jurídica destina-se a *fundamentar* a parte dispositiva e assim não pretende ser pensada como uma norma individual que regula o caso concreto, nem mesmo quando é fruto do controle da constitucionalidade. Ademais, a norma jurídica que agora importa está muito longe de significar apenas uma particularização da norma geral (da lei), pois, como está claro, é o resultado da interpretação e do controle de constitucionalidade da lei.

De modo que a criação da norma jurídica mediante a conformação da lei e da legislação pode ser caracterizada como uma *norma jurídica criada diante do caso concreto, mas não uma norma individual que regula o caso concreto*. Ou seja, há necessidade de distinguir a cristalização da interpretação e do controle de constitucionalidade da criação de uma norma individual que, particularizando a norma geral, *é voltada especificamente à regulação de um caso concreto*.¹⁷

Porém, o que importa é evidenciar que esse novo significado de criação da norma jurídica serve para explicar a conformação da lei e da legislação aos princípios constitucionais de justiça e aos direitos fundamentais, assim como para evidenciar que a tarefa empreendida com a interpretação judicial não é meramente cognitiva, declaratória de uma norma preexistente, nem tampouco uma atividade que implique propriamente sua criação judicial, mas é uma atividade que colabora com a própria conformação da norma, outorgando significado ao seu texto.

2.6. O significado da norma jurídica que tutela um direito fundamental diante de outro direito fundamental. Retorne-se, agora, ao exemplo referido linhas atrás, em que um direito de personalidade é tutelado diante de um direito de liberdade. Nesse caso, não é correto afirmar que a norma jurídica é criada para conformar *a legislação* às normas constitucionais. O que ocorre, na verdade, é a utilização de uma ferramenta normativa específica – *postulado* normativo, que constitui precisamente uma *metanorma* – que soluciona um conflito *concreto e contingente* entre dois direitos fundamentais.¹⁸

O significado da norma jurídica concreta que tutela um direito fundamental diante do outro pode ser descortinado a partir do momento em que se percebe que a tarefa dos postulados normativos não está em promover propriamente a conformação da lei ou da legislação, servindo antes para dar concretude direta e imediata à própria Constituição, ou melhor, a uma efetividade dos direitos fundamentais que não toma em conta o plano da legislação.

Perceba-se que há situações em que se questiona *a omissão do legislador* em dar proteção a um direito fundamental (omissão inconstitucional) e há casos em que se afirma, diante da força que se pretende dar a um direito fundamental de liberdade, *a existência de outro direito fundamental* que também exige proteção estatal (o que evidencia a necessidade de aplicação estruturada argumentativamente dos direitos fundamentais no caso concreto). No primeiro caso há *omissão da legislação* a partir do direito fundamental e, no segundo, *necessidade de fazer valer o direito fundamental* que requer proteção diante de um direito fundamental de liberdade.

Quando a prestação jurisdicional indica o resultado (não importa qual seja) da atuação dos direitos fundamentais, *a norma jurídica está atuando apenas em nome dos direitos fundamentais, sem se preocupar com a conformação da legislação*. Além de dar efetividade ao direito fundamental no *caso concreto*, a jurisdição permite a convivência dos direitos fundamentais em

abstrato.

2.7. A criação da norma jurídica em face das teorias clássicas da jurisdição. Em face do que se expôs nos itens precedentes, certamente não há como sustentar que a jurisdição atua a vontade da lei, nos termos propostos por Chiovenda. Também não é cabível dizer que há a “criação da norma individual do caso concreto”, ao menos quando esse argumento é pensado com base na lógica de que a sentença deve simplesmente aplicar a norma geral.

A impropriedade dessas teorias – estranhamente ainda dominantes na doutrina brasileira – torna-se ainda mais marcante diante da declaração da inconstitucionalidade da lei, do controle da inconstitucionalidade da sua omissão e da tutela de um direito fundamental mediante o afastamento de outro no caso concreto, quando a sentença não afirma *positivamente* lei ou norma geral alguma.¹⁹

Se nas teorias clássicas o juiz apenas *declarava a lei* ou criava *a norma individual a partir da norma geral*, agora ele reconstrói a *norma jurídica* a partir da interpretação de acordo com a Constituição, do controle da constitucionalidade e da adoção de postulados normativos para a harmonização dos direitos fundamentais no caso concreto. O significado dessa mudança não pode ser subvalorizado: sem uma adequada percepção do papel da jurisdição diante da nova teoria das normas, o que implica perceber o novo significado da interpretação judicial, do controle de constitucionalidade existente no sistema jurídico brasileiro, das técnicas com que esse controle se realiza e dos direitos fundamentais, dificilmente se pode conceber um papel crítico à doutrina e à jurisdição. Afirmar que a jurisdição simplesmente declara a vontade concreta da lei ou particulariza uma norma geral para composição de uma lide significa ignorar a necessidade de o Estado Constitucional dar tutela aos direitos e solapar a função da doutrina e da jurisdição como instâncias críticas de controle da adequada tutela dos direitos.

2.8. A teoria de que a jurisdição pode criar a norma geral. Eugenio Bulygin, sucessor de Carlos Santiago Nino na cátedra de Filosofia do Direito da Universidade de Buenos Aires, sustenta a tese de que os juízes podem criar o direito em determinadas situações excepcionais.²⁰

Bulygin contesta a doutrina de Kelsen, no sentido de que o juiz, ao criar a norma individual do caso concreto, cria o direito. Segundo Bulygin, ainda que se aceite a ideia de que o juiz dita a norma individual nos termos kelsenianos, não se pode admitir que o juiz cria o direito, pois tal norma individual se funda em uma norma geral criada pelo legislador. De acordo com seu raciocínio, a conclusão de Kelsen somente estaria certa se o juiz criasse a própria norma geral.²¹

Bulygin afirma que Kelsen não aceitou a ideia de que o juiz *cria* a norma geral quando valora a norma legislativa ou a sua ausência como muito inadequada ou injusta. Nesse caso, o juiz aplicaria a norma geral que lhe parece justa e adequada.²² Embora Kelsen entenda que a norma individual (a sentença) somente pode ser justificada por uma norma geral, ele não chega a admitir, de forma clara e explícita, que o juiz pode criá-la quando a norma geral é injusta, falando, nessa situação, em “*aplicação de norma geral não positiva*”.

Bulygin afirma que isso é uma inconsequência de Kelsen, pois, se a positividade do direito resulta do fato de que as normas são criadas por atos humanos – *como reconhece o próprio Kelsen* –, não há razão para se falar em “*aplicação de norma geral não positiva*”.²³

No raciocínio de Kelsen, essa norma geral *seria aplicada, ao invés de criada*, em razão de que o juiz não pode criar a norma geral, e seria *não positiva* por não ter sido criada pelo legislador. Mas, se a positividade decorre de a norma ter sido criada por ato humano, nada poderia impedir a conclusão de que o juiz, em tal caso, na realidade cria a norma geral e que essa, por consequência, é dotada de positividade.²⁴

2.9. A teoria de que a jurisdição pode criar o direito diante do constitucionalismo contemporâneo. Considerando-se as teorias clássicas da jurisdição – atuação da vontade da lei e criação da norma individual –, não há dúvida de que o juiz somente pode proferir a sentença com base em uma norma geral criada pelo legislador. Embora, em princípio, a ausência de norma geral

sequer pudesse ser cogitada em relação a essas, não há motivo para não se indagar o que poderia ser feito pelo juiz de tais teorias se admitida fosse a ausência de lei. Nessa situação não restaria ao juiz qualquer alternativa senão criar a norma geral,²⁵ sob pena de infirmada a própria ideia de que o sistema jurídico é dotado de *completude*.

Atualmente, entretanto, com a transformação do conceito de direito e com a nova dimensão da função jurisdicional, o que realmente interessa saber é como o juiz opera a reconstrução interpretativa de uma *norma jurídica* para o caso concreto quando a *norma geral* não existe ou é incompatível com os princípios constitucionais de justiça e com os direitos fundamentais.

A reconstrução dessa *norma jurídica* não significa criação de *norma individual* para regular o caso concreto ou criação de *norma geral*, nos moldes anteriormente vistos. A *norma jurídica* cristalizada mediante a conformação da lei e da legislação ou da aplicação estruturada por postulados normativos dos direitos fundamentais pode ser dita uma *norma jurídica* criada diante das peculiaridades do caso concreto, mas está longe de ser uma *simples norma individual voltada a concretizar a norma geral*, ou mesmo de representar pura *criação de um direito*.

Como já foi demonstrado, o juiz no Estado Constitucional deve interpretar a norma geral de acordo com a Constituição, controlar a inconstitucionalidade da lei – inclusive mediante as técnicas da interpretação conforme e da declaração parcial de nulidade sem redução de texto –, a inconstitucionalidade da sua omissão e dar tutela aos direitos fundamentais que entram em colisão no caso concreto.

Nos casos de interpretação de acordo, de interpretação conforme e de declaração parcial de nulidade sem redução de texto, a norma geral é visivelmente conformada – *em menor (no primeiro caso) ou maior medida (nos demais casos)* – pelas normas constitucionais. Nessas três hipóteses o juiz reconstrói a norma jurídica considerando a relação entre o caso concreto, o texto da lei e as normas constitucionais.

Nas situações de declaração de inconstitucionalidade, de controle de inconstitucionalidade por omissão e de tutela de um direito fundamental diante do outro no caso concreto, também não se pode falar em criação do direito pelo juiz, embora a situação certamente seja mais delicada. Esses três casos, se não permitem a conformação da norma geral à Constituição, conferem ao juiz a possibilidade de fazer valer a Constituição mediante a eliminação da norma inconstitucional, do preenchimento do vazio normativo que impede a tutela do direito fundamental e da proteção de um direito fundamental que se choca com outro no caso concreto.

Em nenhuma dessas situações o juiz cria o direito. A jurisdição apenas está zelando para que os direitos sejam tutelados de acordo com as normas constitucionais, para que os direitos fundamentais sejam protegidos e efetivados ainda que ignorados pelo legislador e para que os direitos fundamentais sejam tutelados no caso concreto mediante a aplicação de normas voltadas para a sua adequada concretização.

O juiz, ao atuar dessa forma, não apenas cumpre a tarefa que lhe foi atribuída no constitucionalismo contemporâneo, como também, *diante da transformação do próprio conceito de direito*, apenas o *aplica mediante sua adequada interpretação*. Ou seja, no Estado Constitucional não há qualquer motivo para a doutrina enxergar aí uma exceção à função de aplicação do direito, como se a aplicação do direito ou a atuação jurisdicional não estivesse subordinada aos princípios constitucionais e aos direitos fundamentais.

2.10. Poder judicial de reconstruir interpretativamente o direito e força obrigatória dos precedentes. Por outro lado, não é correto supor que a jurisdição, diante do impacto do constitucionalismo, cria o direito quando os seus precedentes têm força obrigatória.

O sistema judicial, cujos precedentes têm força obrigatória, vincula a interpretação dos juízes e tribunais inferiores. Nos países que não adotam precedentes obrigatórios, a jurisprudência tem sempre força persuasiva, embora essa nem sempre seja devidamente respeitada pelos tribunais que as criam e pelos órgãos judiciais inferiores.²⁶

No Brasil, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal têm força obrigatória.²⁷ Tais precedentes são, em sua maioria, de natureza interpretativa. Não obstante, ainda que considere um precedente instituído para definir o modo de se concretizar uma norma de caráter aberto, isto não quer dizer que esse precedente possa ser considerado destituído de fundamento no direito. Na verdade, essa questão é próxima à de se saber se o juiz do *common law*, em virtude do *stare decisis*, cria o direito.

Seria possível argumentar que a decisão do *common law*, por ter força obrigatória, constitui direito. O *common law* considera o precedente como fonte primária de direito.²⁸ Note-se, contudo, que, quando um precedente interpreta a lei ou a Constituição, como acontece especialmente nos Estados Unidos, *há evidentemente direito preexistente com força normativa*, de modo que seria absurdo pensar que o juiz, neste caso, cria um direito novo. Na realidade, também no caso em que havia apenas costume, existia direito preexistente, o direito costumeiro. Daí a razão pela qual é mais apropriado falar em *reconstrução* da ordem jurídica mediante adequada interpretação do Direito do que propriamente em *construção* do Direito pelos juízes (*judge-made law*).

A circunstância de o precedente ser admitido como fonte de direito está muito longe de constituir um indício de que o juiz cria o direito. Nesta perspectiva, a força obrigatória do precedente não significa que o judiciário tem poder para criar o direito.

2.11. A grande peculiaridade da norma reconstruída pelo juiz: a necessidade da sua fundamentação. A sentença é composta por três partes: i) o relatório; ii) a fundamentação e iii) a parte dispositiva. No relatório o juiz expõe a situação conflitiva, o pedido do autor e os argumentos das partes, as provas produzidas e tudo mais que possa interessar para a formulação da decisão. A parte dispositiva expressa a decisão, afirmando, por exemplo, que o réu é condenado a pagar x.

A parte dispositiva da sentença pode ser pensada como a norma individual do caso concreto nos termos kelsenianos, não obstante os termos *norma* e *individual* pareçam repelentes ou inconciliáveis, uma vez que tradicionalmente a norma requer a condição de generalidade, ao menos no que tange ao seu destinatário.²⁹

Porém, ainda que a ideia de norma individual não convença, porque ela nada mais é do que a parte que expressa a decisão jurisdicional, seria imprescindível a sua *fundamentação* (como ocorre em relação à sentença), pois o juiz, como agente do poder não legitimado pelo voto, *não pode deixar de justificar as decisões* que prolata. Aliás, não se pode esquecer que, enquanto a decisão legislativa (a lei) expressa o resultado do embate parlamentar, a decisão jurisdicional, embora possa ser aperfeiçoada mediante o sistema recursal e de formação jurisprudencial, pode ser tomada apenas por um juiz.

A legitimidade da decisão jurisdicional depende não apenas de estar o juiz convencido, mas também de o juiz justificar a racionalidade da sua decisão com base no caso concreto, nas provas produzidas e na convicção que formou sobre as situações de fato e de direito. Ou seja, não basta o juiz estar convencido – deve ele demonstrar as *razões de seu convencimento a partir do diálogo entretido com as partes* ao longo do processo, como, aliás, frisam os arts. 7.º, 9.º, 10 e 489, § 1.º, IV, CPC. Isso permite o controle da atividade do juiz pelas partes ou por qualquer cidadão, já que a sentença deve ser o resultado de um raciocínio lógico-argumentativo capaz de ser demonstrada mediante a relação entre o relatório, a fundamentação, a parte dispositiva, as alegações formuladas e as provas produzidas pelas partes no processo.

A fundamentação da sentença, diante da sua essencialidade, foi tornada obrigatória pela Constituição (arts. 93, IX, CF, e 11 e 489, CPC). Isso evidencia uma absoluta diferença entre a norma criada pelo legislador e a sentença. A norma geral não é justificada. A chamada *exposição de motivos*, que por vezes a acompanha, não integra a lei.

2.12. O impacto da distinção entre texto e norma sobre o conceito de jurisdição e de fundamentação. A necessidade de racionalidade da jurisdição. O fato de o poder legislativo ofertar apenas documentos normativos, em que se encontram os *dispositivos*, os *textos* dotados de autoridade, mas não ainda as *normas*, evidencia o fato de a *norma jurídica* não constituir mais o

objeto, consubstanciando-se antes no *resultado* da interpretação. Dito de outro modo, o *discurso do legislativo* depende necessariamente do *discurso judicial* para promoção do império do Direito. A relação existente entre esses poderes é de *colaboração*.

Esse novo significado da interpretação tem um grande impacto sobre o conceito de jurisdição – cuja existência depende de um *adequado discurso justificativo* – e sobre o conceito de fundamentação – que depende de uma *adequada formulação*. A jurisdição diferencia-se da legislação não mais por ter que aplicar a norma por essa criada, mas por colaborar com a realização do Direito mediante a *justificação* de suas *decisões interpretativas* diante de um determinado caso concreto. E essa *fundamentação* tem de apresentar *determinadas características* para ser considerada adequada no Estado Constitucional. Essa tem de ser *racional*, sob pena de não ser *intersubjetivamente controlável*, e tem de ser fruto do *contraditório*, sob pena de não ser *democraticamente aceitável*.

Em primeiro lugar, diante do fato de a jurisdição colaborar com a reconstrução da norma mediante a apropriada outorga de razões, explicitando o porquê de suas opções interpretativas, surge a necessidade de a fundamentação ser dotada de *racionalidade*, sem o que não pode ser aceita como adequada. A racionalidade é uma marca da interpretação – seja da *atividade* interpretativa, seja do *resultado* interpretativo – que deve estar devidamente estampada na fundamentação da decisão. Em segundo lugar, surge a necessidade dessa interpretação ser precedida de *adequado contraditório* com as partes, o que tem de ser aferido na própria justificação da decisão, de modo que não se prolate qualquer decisão definitiva sobre a causa a partir de *elementos não previamente submetidos ao conhecimento* das partes – isto é, surge a necessidade de o *juiz dialogar com as partes* e de a sua decisão *espelhar as razões* ofertadas pelas partes (arts. 5.º, LV, 93, IX, CRFB, e 7.º, 9.º, 10, 11 e 489, § 1.º, IV, CPC).

Como já observamos, a atividade interpretativa só é racional se justificada interna e externamente. O resultado interpretativo só é racional se pautado pelo ideal regulativo da unidade do direito, o que implica necessidade de hierarquização, coerência, universalização e replicabilidade. Para que se tenha um adequado exercício da jurisdição no Estado Constitucional, tudo isso deve estar evidenciado na fundamentação da decisão, que deve resultar de um amplo diálogo com as partes. Fora daí há exercício ilegítimo da jurisdição.

2.13. A teoria de que a jurisdição se define pelo seu dever de concretizar os valores públicos constitucionalizados. Owen Fiss, nos Estados Unidos, tem produzido importantes estudos sobre a jurisdição. Segundo Fiss, a função da jurisdição – *adjudication* – é atribuir significado concreto e aplicação aos valores constitucionais.³⁰

A doutrina de Fiss – como não é incomum nos Estados Unidos – é preocupada com a proteção das minorias. Ele parte do princípio de que nenhum regime constitucional pode se legitimar apenas pela obediência à regra da maioria e, conseqüentemente, por meio do predomínio das instituições político-representativas majoritárias em detrimento dos órgãos jurisdicionais. Nessa linha, Fiss critica a teoria que coordena a relação entre os tribunais e as outras agências de governo com base na ideia de *defeito legislativo* (*legislative failure*). Segundo a teoria do defeito legislativo – cuja principal referência consta da famosa nota de rodapé n. 4 da decisão da Suprema Corte norte-americana no caso *United States versus Carolene Products* –³¹, os tribunais devem deferência ao Poder Legislativo, em questões constitucionais, a menos que haja alguma razão para assumir que o processo legislativo esteja funcionando de forma inadequada.³² De acordo com Fiss, essa teoria tem duas insuficiências. A primeira é a sua incapacidade de explicar por que os defeitos legislativos devem ser corrigidos pela ação judicial. A segunda é a falta de justificação da sua premissa normativa fundamental: a afirmação da supremacia dos órgãos políticos majoritários mesmo quando os valores constitucionais são postos em questão.

A teoria do *defeito legislativo* limita-se a identificar as ocasiões em que o Poder Judiciário deve atuar, mas não prescreve o que deve ser feito nestas ocasiões. Como essa teoria é incompleta, além de estar baseada numa premissa majoritária incompatível com um regime constitucional, Fiss propõe-se a resgatar o seu ponto mais atraente: a tese de que os tribunais devem atuar quando o processo político produz a vitimização de minorias isoladas e sem voz. Essa tese não é

devidamente explicada pela teoria do *defeito legislativo*, simplesmente porque essa teoria preocupa-se apenas em assegurar que todos os grupos sociais tenham suas preferências computadas no processo político. Muitas vezes, porém, a preferência majoritária que vitimiza um determinado grupo pode ser mantida ainda que as preferências desse grupo sejam consideradas. Como anota Fiss, ainda quando se apresenta uma ocasião de desconfiança quanto ao bom funcionamento do processo legislativo, “não há razão para pensar que a decisão oposta prevaleceria se o processo legislativo estivesse funcionando perfeitamente; não há razão para supor que o grupo isolado e sem voz iria vencer ao invés de perder”.³³

Ou seja, não basta assegurar a todos os grupos sociais a adequada participação no processo legislativo. A minoria, ainda que possa ter as suas preferências computadas, pode ser vitimada no processo de produção da lei. De modo que a proteção da minoria deve ser buscada em outra dimensão e não em eventual defeito de participação no processo legislativo. Tal dimensão, como não poderia deixar de ser, é a da Constituição.

Para tanto, nos termos da doutrina de Fiss, o juiz não precisa nem deve falar em nome das minorias, mas apenas conferir significado aos valores constitucionais. Não há sentido em dar ao juiz a função de representante das minorias. Como diz Fiss, não há como tornar o juiz um participante na política de grupos de interesse. Cabe à jurisdição, isto sim, interpretar a Constituição a fim decidir o que é justo a partir do seu texto, da história e dos ideais sociais,³⁴ e assim, se for o caso, dar tutela à minoria.³⁵

Embora agora não importe outra preocupação de Fiss, no sentido de saber como a interpretação pode atingir um grau de objetividade consentâneo com a função do direito,³⁶ não há como negar que não se pode reduzir a função da jurisdição à simples *descoberta* do significado dos valores constitucionais ou dos valores públicos contidos na Constituição.³⁷

Se é certo que o juiz deve compreender a lei na medida da Constituição, isso não quer dizer que lhe basta *declarar* os valores constitucionais. Para realizar a função jurisdicional, o juiz, consciente do significado da Constituição, deve atribuir sentido aos textos constitucionais, legais e ao caso concreto e a partir daí dar tutela efetiva ao direito. Por isso, é fundamental compreender adequadamente o que Owen Fiss entende por “dar sentido aos valores públicos”.

Para ele, “os tribunais existem para dar sentido aos nossos valores públicos, não para resolver disputas. A jurisdição constitucional é a mais viva manifestação dessa função, mas ela também parece verdadeira para a maior parte dos casos civis e criminais”.³⁸ Dar sentido aos valores públicos, todavia, não é somente conferir significados específicos para esses valores – é, ademais, dar-lhes conteúdo operacional.³⁹ Aliás, é apenas por causa desse entendimento amplo do que seja “dar sentido aos valores públicos” – concretizá-los, efetivá-los, atualizá-los – que Fiss consegue abarcar nesta definição, aparentemente estreita, de jurisdição o que chama de “reforma estrutural” mediante a ação dos tribunais.⁴⁰ A *reforma estrutural* é uma modalidade de exercício da jurisdição que se distingue pelo fato de envolver um encontro entre o judiciário e as burocracias estatais. Nela, o juiz tenta dar sentido aos valores constitucionais na operação dessas organizações, agindo segundo a premissa de que “valores constitucionais não podem ser plenamente assegurados sem que se efetuem mudanças básicas nas estruturas dessas organizações”.⁴¹ Um processo judicial de reforma estrutural é aquele em que um juiz, confrontando a burocracia estatal com respeito a valores de dimensão constitucional, encarrega-se de reestruturar a organização, para, assim, eliminar a ameaça àqueles valores posta pelos atuais arranjos institucionais.⁴²

Por meio dessa compreensão mais ampla da função judicial de dar sentido aos valores públicos, Fiss, a um só tempo, enfatiza um aspecto essencial da jurisdição – a necessidade de dar efeito concreto ao conteúdo substancial do ordenamento jurídico – e escapa da crítica – que pode ser corretamente dirigida a versões menos elaboradas da teoria de que a jurisdição deve identificar valores públicos – de que somente definir o significado dos valores públicos é muito pouco, uma vez que à jurisdição é indispensável implementar esses valores. Embora o juiz, para conferir sentido ao caso, interpretar a lei e dar tutela ao direito material, tenha de estar consciente do

significado do texto constitucional, certamente a jurisdição não se resume a *declarar os valores* constitucionais. Como bem pontua Fiss: “A tarefa não é apenas declarar quem está certo e quem está errado (...) a tarefa é remover a condição que ameaça os valores constitucionais”.⁴³ Mais propriamente: a tarefa da jurisdição está nessa perspectiva em atuar os *valores* encampados pelas *normas* constitucionais.

2.14. A ideia de que a jurisdição tem por objetivo a pacificação social. Fala-se, também, que a jurisdição tem por objetivo a pacificação social. Tal fim não resultaria apenas do fato de que os cidadãos buscam solução para os seus conflitos no Poder Judiciário e de que esse, ao solucioná-los, permite a pacificação de específicas situações litigiosas.

Na verdade, a ideia do fim de pacificação social da jurisdição está relacionada com três questões: i) a existência do juiz dá aos litigantes a consciência de que os seus conflitos têm uma forma de resolução instituída e estatal, o que elimina as tentativas de soluções privadas arbitrárias e violentas; ii) a jurisdição acomoda as disputas, evitando a potencialização e o agravamento das discussões; iii) ainda que um dos litigantes não se conforme com a decisão, ele sabe que, diante da impossibilidade de levar novamente ao juiz a situação conflitiva já solucionada, nada mais lhe resta fazer e que, portanto, seria improdutivo e ilógico continuar alimentando a sua posição.

Acontece que essas três características, que serviriam para identificar um fim de pacificação social na jurisdição, são completamente neutras e indiferentes à substância da função ou da decisão jurisdicional. E definir jurisdição sem saber como a pacificação é alcançada pode conduzir à admissão de que qualquer poder instituído, mesmo que atuando de forma ilegítima e de modo contrário aos princípios materiais de justiça, exerce jurisdição.

Na realidade, como não é difícil perceber, a pacificação social é uma mera consequência da existência de um poder de resolução dos conflitos que se sobreponha sobre os seus subordinados e não um resultado particular e próprio do Estado Constitucional.⁴⁴ Na verdade, a expectativa de soluções dos conflitos sociais por uma ordem institucionalizada constitui o próprio escopo do Direito,⁴⁵ não sendo por essa razão um objetivo direto da jurisdição no Estado Constitucional.

Por isso, no atual estágio dos nossos estudos, parece não ser adequado concluir que a jurisdição se caracteriza pelo fim da pacificação social. É preciso, antes de tudo, analisar de que forma esse fim é obtido, ou melhor, verificar a legitimidade do poder de resolução dos conflitos e das decisões destinadas a regulá-los. Sem isso estaríamos aceitando que todo poder direcionado à pacificação social é um poder jurisdicional e, assim, para dizer o mínimo, igualizando a jurisdição do Estado legislativo com a jurisdição do Estado Constitucional.⁴⁶

2.15. A jurisdição deve responder às necessidades do direito material. Como o juiz deve dar sentido ao caso diante da lei, da realidade social e da Constituição, ele obviamente não pode formular a norma jurídica do caso concreto *olhando apenas para a Constituição*. Para a prestação da tutela jurisdicional é imprescindível a consideração das *necessidades do direito material*.

Isso é mais fácil de evidenciar do que a própria ideia de que a lei deve ser conformada segundo os princípios constitucionais de justiça e os direitos fundamentais. É que a tutela – ou a proteção – jurisdicional tem uma óbvia natureza instrumental em relação ao direito material. A tutela jurisdicional, além de tomar em conta a Constituição, deve considerar o caso e as necessidades do direito material, uma vez que as normas constitucionais devem iluminar a tarefa de tutela jurisdicional *dos direitos*.

É por isso mesmo que a ideia de dar sentido aos valores previstos nas normas constitucionais pode, em uma primeira leitura, mostrar dificuldade para explicar a complexidade da função do juiz. Na verdade, a jurisdição tem o objetivo de dar tutela *às necessidades do direito material*, compreendidas à luz das normas constitucionais.

Por outro lado, há nítida diferença entre dar tutela às necessidades do direito material e exercer a função de pacificação social. Como essa última é neutra e indiferente ao direito material e aos próprios valores previstos nas normas constitucionais, ela apenas pode ser vista como

consequência da atividade jurisdicional voltada à efetiva, adequada e tempestiva tutela jurisdicional dos direitos. Ou melhor, a jurisdição tem por objetivo reconstruir a norma jurídica capaz de dar conta das necessidades do direito material e, apenas por consequência dessa sua missão, pode gerar o efeito da pacificação social.

2.16. A tutela dos direitos transindividuais. O Estado Constitucional realçou a existência de direitos transindividuais, assim compreendidos os direitos de natureza indivisível, pertencentes a pessoas indeterminadas ou a uma coletividade. O Código de Defesa do Consumidor, ao tratar dessa modalidade de direitos, definiu direitos *difusos e coletivos*. Afirmou que ambos são “*transindividuais, de natureza indivisível*”, mas, enquanto os *difusos* são pertencentes a “*pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato*”, os *coletivos* são do “*grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base*” (art. 81, parágrafo único, I e II, CDC).

Para a proteção desses direitos, o legislador instituiu técnicas ou modelos processuais diferenciados, isto é, voltados a atender as suas especificidades. Como não poderia ser de outra forma, deferiu a determinados entes, como as associações de defesa do meio ambiente e dos consumidores, legitimidade para a propositura da ação e ao mesmo tempo concebeu a sentença de procedência como capaz de produzir efeitos benéficos a todos os titulares do direito afirmado pelo ente legitimado (arts. 82 e 103, CDC).⁴⁷

Mas, para o efeito da compreensão da “jurisdição”, mais do que a constatação da existência de tais direitos e de técnicas processuais voltados à sua tutela, importa identificar a *razão de ser da idealização* desses novos modelos processuais dirigidos à tutela jurisdicional.

As *ações coletivas* – como podem ser chamados os modelos concebidos para a tutela dos direitos transindividuais – têm importante relação com os direitos fundamentais prestacionais. Tais ações permitem a tutela jurisdicional dos direitos fundamentais que exigem prestações sociais (direito à saúde e direito à educação, por exemplo) e adequada proteção – inclusive contra os particulares (direito ambiental, por exemplo) –, mas, além disso tudo, constituem condutos vocacionados a permitir ao povo reivindicar os seus direitos fundamentais materiais.

As ações coletivas, ainda que vistas apenas como módulos processuais organizados pelo legislador, representam muito mais do que simples procedimentos concebidos para a tutela jurisdicional, pois são verdadeiros instrumentos de uma faceta muito especial dos direitos fundamentais. Ora, os direitos fundamentais exigem a possibilidade da participação na estrutura social e no poder mediante instrumentos e procedimentos adequados.⁴⁸ Essa participação deve ser oportunizada e incentivada não só mediante a reserva de locais de participação em órgãos públicos ou em procedimentos voltados a decisões públicas, mas também mediante procedimentos judiciais aptos à tutela dos direitos transindividuais.⁴⁹

A ação coletiva, mesmo quando compreendida apenas como instrumento para a tutela dos direitos fundamentais – como o direito ambiental e o direito do consumidor –, é, por si só, uma resposta a esses direitos, constituindo-se ela mesma em uma prestação do legislador destinada a viabilizar a participação na reivindicação dos direitos fundamentais.

Se a ação coletiva é via ou conduto, a jurisdição torna-se, inegavelmente, um local que acolhe a participação, viabilizando a realização de uma prestação estatal imprescindível aos direitos fundamentais.

Além disso, algumas ações coletivas, quando endereçadas contra o Poder Público – assim como a ação popular –,⁵⁰ permitem ao povo participar no poder, apontando desvios na gestão da coisa pública. Nesse sentido, a ação jurisdicional configura mecanismo de participação popular, participação essa que pode ser deferida individualmente ao cidadão – como acontece com a ação popular –⁵¹ ou reservada a entes que fazem as vozes dos titulares dos direitos ecoarem nos tribunais – como acontece com as ações coletivas.

Nessa última perspectiva a jurisdição é um poder que permite a participação do cidadão na

correção dos eventuais desvios na administração do bem público e, mais do que expressar um local para a participação na reivindicação dos direitos fundamentais, revela um lugar imprescindível para otimizar a participação e, assim, para democratizar a democracia através da participação.⁵²

Portanto, a jurisdição fomenta a participação para a tutela dos direitos fundamentais e para o controle das decisões tomadas pelo Poder Público. Mas não é certo concluir que a jurisdição *apenas colabora* para a participação, pois ela *decide*, vale dizer, *exerce o seu poder ao decidir* sobre os direitos transindividuais e sobre a lisura na gestão do bem público.

De modo que as ações processuais que garantem a participação, seja na tutela dos direitos fundamentais, seja no controle das decisões públicas, conferem um *plus* à função jurisdicional. E não apenas porque o juiz deixa de proteger exclusivamente os direitos individuais e passa a tutelar os direitos transindividuais e o patrimônio público, mas, sobretudo, porque a jurisdição toma o seu lugar para a efetivação da democracia, que necessita de técnicas de participação *direta* para poder construir uma sociedade mais justa.

2.17. Dar tutela aos direitos não é simplesmente editar a norma jurídica do caso concreto. Não basta ao juiz compreender e conformar a lei de acordo com as normas constitucionais, concluindo que o autor tem um direito *que deve* ser tutelado. Cabe à jurisdição *dar tutela* aos direitos – e não apenas *dizer quais direitos merecem proteção*. De maneira que agora interessa saber *o que significa dar tutela jurisdicional aos direitos*.

Dar tutela a um direito nada mais é do que lhe outorgar proteção. Mas, exceto quando o autor postula uma sentença declaratória da existência ou inexistência de uma relação jurídica ou sentença desconstitutiva de determinada situação jurídica e, assim, além da sentença não é necessária qualquer *atividade de complementação (executiva) da prestação jurisdicional*, não há como admitir que a sentença *é suficiente* para o juiz se desincumbir do seu dever de prestar a tutela jurisdicional.

É fácil perceber que a discussão em torno do significado de tutela jurisdicional *obriga a uma ruptura com a ideia de que a função jurisdicional é cumprida com a edição da sentença (da declaração do direito ou da criação da norma individual)*, exigindo *que se caminhe um pouco além*.

Frise-se que em determinado contexto histórico o direito de ação – visto como contrapartida da proibição da autotutela e da reserva do poder de dirimir os conflitos ao Estado – foi concebido como direito a uma sentença de mérito.⁵³ Acontece que a sentença que reconhece a existência de um direito, *mas não é suficiente para satisfazê-lo*, não é capaz de expressar uma prestação jurisdicional efetiva, uma vez que não tutela o direito e, por isso mesmo, não representa uma resposta que permita ao juiz se desincumbir do seu dever perante a sociedade e os direitos. A tutela do direito é a realização concreta do direito reconhecido pela jurisdição e não se esgota, portanto, com a sua simples proclamação.

Diante disso, não há dúvida de que a tutela jurisdicional só se aperfeiçoa, nesses casos, com a atividade executiva. Portanto, a jurisdição não pode significar mais apenas *iuris dictio* ou *dizer o direito*, como desejavam os juristas que enxergam na atividade de execução uma mera função administrativa ou uma “função menor”.⁵⁴ Na verdade, mais do que direito à sentença, o direito de ação hoje tem como corolário o direito ao meio executivo adequado.⁵⁵

A tutela jurisdicional do direito é prestada quando o direito é tutelado e, dessa forma, realizado, seja através da sentença (quando ela é bastante para tanto), seja através da execução. De modo que passa a importar, nessa perspectiva, a maneira como a jurisdição deve se comportar para realizar os direitos ou implementar a sua atividade executiva. Ou melhor, o modo como a legislação e o juiz devem se postar para que os direitos sejam efetivamente tutelados (ou executados).

Trata-se, na verdade, de trilhar dois caminhos que se cruzam: um primeiro, que aponta para a necessidade de a técnica processual executiva ser estruturada pela lei conforme o direito material,

e um segundo, que obriga o juiz a pensar a norma processual definidora das técnicas processuais com base no direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e segundo as necessidades de direito material evidenciadas pelo caso concreto.

2.18. A jurisdição a partir do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva incide sobre o legislador e o juiz, ou seja, sobre a estruturação legal do processo e sobre a conformação dessa estrutura pela jurisdição.⁵⁶

Assim, como já observamos, obriga o legislador a instituir procedimentos e técnicas processuais capazes de permitir a realização das tutelas prometidas pelo direito material e, inclusive, pelos direitos fundamentais materiais, mas que não foram alcançadas à distância da jurisdição. Nesse sentido se pode pensar, por exemplo: i) nos procedimentos que restringem a produção de determinadas provas ou a discussão de determinadas questões, ii) nos procedimentos dirigidos a proteger os direitos transindividuais, iii) na técnica antecipatória, iv) na distribuição do ônus da prova, inclusive prevendo-se a possibilidade de sua inversão e dinamização; v) nas sentenças e vi) nos meios de execução diferenciados. Na mesma dimensão devem ser visualizados os procedimentos destinados a permitir a facilitação do acesso ao Poder Judiciário das pessoas menos favorecidas economicamente, com a dispensa de advogado, custas processuais etc. – como é o caso do procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

Porém, não basta parar na ideia de que o direito fundamental à tutela jurisdicional incide sobre a estruturação técnica do processo, pois supor que o legislador sempre atende às tutelas prometidas pelo direito material e às necessidades sociais de forma perfeita constitui ingenuidade inescusável.

Aliás, se o legislador sempre atuasse de maneira ideal, jamais haveria necessidade de subordinar a compreensão da lei à Constituição. Ou seja, é justamente porque se teme que a lei possa se afastar dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais que se afirma que o direito fundamental à tutela jurisdicional incide sobre a compreensão judicial das normas processuais.⁵⁷

A obrigação de compreender as normas processuais a partir do direito fundamental à tutela jurisdicional e, assim, considerando as várias necessidades de direito substancial, dá ao juiz o poder-dever de encontrar a técnica processual idônea à proteção (ou à tutela) do direito material.

O encontro da técnica processual adequada exige a interpretação da norma processual *de acordo* com o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e, também, para se evitar a declaração da sua inconstitucionalidade, o seu tratamento através das técnicas da interpretação *conforme* e da declaração parcial de nulidade sem redução de texto.⁵⁸

A interpretação *de acordo* pressupõe que a interpretação da lei segundo os métodos apropriados tenha conduzido a duas ou mais interpretações viáveis. Nesse caso, deve-se buscar a interpretação que permita a efetiva tutela do direito – identificado no caso concreto. É nesses termos que se diz que a interpretação é feita *de acordo* com o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva.

No caso de normas abertas, à espera de concretização judicial, é óbvia a imprescindibilidade de o juiz se pautar no direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. O legislador é hoje consciente da necessidade de dar aos jurisdicionados e ao juiz maior poder para a utilização do processo. É por isso que institui normas processuais abertas, isto é, normas que oferecem um leque de instrumentos processuais, dando ao cidadão o poder de construir o modelo processual adequado e ao juiz o poder de utilizar a técnica processual idônea à tutela da situação concreta. Ao fixar tais normas, o legislador parte da premissa de que, por ser impossível predizer todas as necessidades futuras e concretas,⁵⁹ é imprescindível dar poder às partes para a identificação e a utilização dos meios processuais adequados às variadas situações. É correto falar, nesse sentido, em concretização da norma processual, isto é, na aplicação da norma processual no caso concreto ou, ainda, na identificação e utilização da técnica processual – apenas autorizada pela norma – adequada às necessidades concretas.

Nessas hipóteses, a concretização da norma processual deve tomar em conta as necessidades de direito material reveladas no caso, mas a sua instituição decorre, evidentemente, do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, que, portanto, deve iluminar o raciocínio judicial. O legislador atua porque é ciente de que a jurisdição não pode dar conta das variadas situações concretas sem a outorga de maior poder e mobilidade, ficando o autor incumbido da identificação das necessidades concretas para modelar a ação processual e o juiz investido do poder-dever de, mediante argumentação própria e expressa na fundamentação da sua decisão, individualizar a técnica processual capaz de lhe permitir a efetiva tutela do direito.

Em outros casos, quando determinada interpretação se revela inconstitucional, o juiz pode dar-lhe interpretação conforme a Constituição. Assim, se o legislador eventualmente diz, por exemplo, que a técnica antecipatória não pode ser utilizada quando trouxer danos irreversíveis ao demandado (art. 300, § 3.º, CPC), a norma que assim afirmar só terá constitucionalidade quando o dano que puder ser trazido ao autor pela falta da tutela não justificar o risco de prejuízo ao réu. Em princípio, o risco de prejuízo irreversível não pode impedir a concessão da tutela urgente, pois essa tem como requisito o risco de lesão a um direito *mais provável* que o do réu. De modo que não há dúvida que a não admissão da tutela jurisdicional, nesse caso, viola o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva.

Além disso, as necessidades do caso concreto podem reclamar técnica processual não prevista em lei, quando o juiz poderá suprir a omissão obstaculizadora da realização do direito fundamental à tutela jurisdicional mediante o que se pode denominar de técnica de controle da inconstitucionalidade por omissão.

É fácil perceber que, em todas essas situações, a lei processual é pensada segundo as necessidades de direito material evidenciadas no caso concreto. A compreensão do processo à luz do direito fundamental à tutela jurisdicional requer a percepção da natureza instrumental da norma processual, isto é, de que essa deve permitir ao juiz encontrar uma técnica processual idônea à tutela das necessidades do caso conflitivo.⁶⁰

2.19. As regras processuais abertas como decorrência do direito fundamental à tutela jurisdicional. Na época do Estado liberal clássico, vigorava no processo civil o chamado princípio da tipicidade das formas executivas, que tinha o significado de impedir a utilização, pelas partes e pelo juiz, de meios executivos não expressamente previstos na lei. Esse princípio objetivava garantir a liberdade dos litigantes diante da jurisdição. Medindo-se o poder de atuação do juiz pela lei, eram garantidas as formas mediante as quais a atividade jurisdicional poderia ser exercida. Dava-se ao litigante a garantia de que, no caso de sua eventual condenação, a jurisdição não poderia ultrapassar os limites dos meios executivos tipificados.

Acontece que, com o passar do tempo, tornou-se necessário munir os litigantes e o juiz de uma maior latitude de poder, seja para permitir que os jurisdicionados pudessem utilizar o processo de acordo com as novas situações de direito material e com as realidades concretas, seja para dar ao juiz a efetiva possibilidade de tutelá-las.

Tal necessidade levou o legislador não só a criar uma série de institutos dependentes do preenchimento de conceitos indeterminados – caso, por exemplo, da técnica sumária –, admitindo o seu uso na generalidade dos casos, mas também a fixar normas processuais abertas.

Essas normas decorrem da aceitação da ideia de que a lei não pode atrelar as técnicas processuais a cada uma das necessidades do direito material ou desenhar tantos procedimentos especiais quantos forem supostos como necessários à tutela jurisdicional dos direitos.

A lei processual não pode antever todas as verdadeiras necessidades de direito material, uma vez que essas não apenas se transformam diariamente, mas igualmente assumem contornos variados conforme os casos concretos. Diante disso, chegou-se naturalmente à necessidade de uma norma processual destinada a dar aos jurisdicionados e ao juiz o poder de identificar, ainda que dentro da sua moldura, os instrumentos processuais adequados à tutela dos direitos.

Acontece que as normas processuais abertas não apenas conferem maior poder para a utilização dos instrumentos processuais, mas também outorgam ao juiz o dever de demonstrar a idoneidade do seu uso, em vista da obviedade de que todo poder deve ser exercido de maneira legítima. Se antes o controle do poder jurisdicional era feito a partir do princípio da tipicidade, ou da definição dos instrumentos que podiam ser utilizados, hoje esse controle é mais complexo e sofisticado. A legitimidade do uso dos instrumentos processuais depende da espécie de tutela do direito e das particularidades do caso, da consideração do direito de defesa e, obviamente, da racionalidade da argumentação expressa na fundamentação da decisão ou da sentença.

A norma que dá ao juiz o poder de impor o meio processual adequado, fazendo referência apenas às técnicas processuais que podem ser utilizadas, mas não precisando em que situações de direito material, e muito menos em que casos concretos, essas podem ser aplicadas, obriga à identificação das *necessidades de direito material particularizadas no caso concreto*. Ou seja, não há como conceder tutela antecipatória sem antes compreender a razão pela qual se está atuando, ou melhor, sem antes se identificar a espécie de tutela do direito solicitada (inibitória, de remoção de ilícito, ressarcitória etc.) e os seus pressupostos (ameaça de ilícito, prática de ato contrário ao direito, dano etc.).

Os procedimentos e as técnicas processuais somente adquirem substantividade quando relacionados ao direito material e às situações concretas, e por isso podem ser ditos neutros em relação ao direito substancial e à realidade social quando pensados como procedimentos ou técnicas voltados, por exemplo, simplesmente à imposição de um fazer ou à busca e apreensão. Ora, não é preciso muito esforço para evidenciar que impor um fazer, ou determinar a busca e apreensão, não tem qualquer significado no plano do direito material ou concreto.

Não é por outra razão que se fala em tutela inibitória, ressarcitória, do adimplemento na forma específica etc. Perceba-se que “tutela” significa o resultado jurídico-substancial do processo, representando o impacto do processo no plano do direito material. *Quando se teoriza o tema das “tutelas”, tem-se em mira exatamente a imprescindibilidade da identificação das situações de direito material para a compreensão crítica da lei processual e para o delineamento das técnicas processuais capazes de outorgar efetividade à prestação jurisdicional e, assim, colocá-la em uma dimensão realmente capaz de concretizar o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva.*

Contudo, quando se pensa na técnica processual capaz de garantir a efetividade da tutela do direito, não é possível esquecer da esfera jurídica do réu. Se é possível escolher a técnica processual capaz de dar proteção ao direito, não há como admitir que essa escolha possa prejudicar o demandado. Isso quer dizer que a utilização da técnica processual, diante da norma processual aberta, tem a sua legitimidade condicionada a um prévio controle, que considera tanto o direito do autor quanto a esfera jurídica do demandado.

Esse controle deve ser feito a partir de um dos critérios do postulado da proporcionalidade,⁶¹ isto é, a partir do critério da necessidade (meio idôneo e menor restrição possível). A providência jurisdicional deve ser idônea à tutela do direito e, ao mesmo tempo, a que traz a menor restrição possível à esfera jurídica do réu. É claro que, antes de tudo, a providência deve ser idônea à tutela do direito. O juiz somente deve se preocupar com a menor restrição possível após ter identificado o meio idôneo à tutela do direito.

Porém, a necessidade de raciocinar a partir da consideração da tutela no plano do direito material e do postulado da necessidade não teria significado sem a devida justificativa, isto é, sem a motivação capaz de expressar adequadamente o raciocínio judicial. A justificativa permite o controle crítico sobre o poder do juiz⁶² e, portanto, o equívoco da justificativa evidencia a ilegitimidade do uso da técnica processual.

A ampliação do poder do juiz, ocorrida para dar maior efetividade à tutela dos direitos, possui como contrapartida a necessidade de que o controle da sua atividade seja feito a partir da compreensão do significado das tutelas no plano do direito material, dos postulados do meio idôneo e da menor restrição e mediante a sua indispensável exteriorização: a justificação judicial. Em outros termos: pelo fato de o juiz ter poder para a determinação da melhor maneira de

efetivação da tutela jurisdicional, exige-se dele, por consequência, a *adequada* justificação das suas escolhas. Nesse sentido se pode dizer que *a justificativa é a outra face do incremento do poder do juiz*.

Na justificativa o juiz deve dizer a razão pela qual preferiu uma determinada técnica processual ou modalidade de execução e não outra. Porque preferiu, por exemplo, ordenar a instalação de um equipamento antipolvente em vez de ordenar a cessação das atividades da empresa ré. Tal opção deve configurar o meio *mais* idôneo ou *apenas necessário* à tutela do direito, concretizando o meio que, além de ser obviamente capaz de dar tutela efetiva ao direito, é o menos restritivo.

Os critérios ligados ao postulado da proporcionalidade, embora façam parte do *raciocínio decisório*, pois viabilizam a decisão, obviamente não podem ser ignorados quando da justificativa. Até porque tais normas não servem apenas para facilitar a decisão, mas muito mais para que se possa justificá-la de modo racional, permitindo o seu controle pelas partes.

O crescimento do poder de atuação do juiz e a consequente necessidade de outros critérios de controle da decisão judicial nada mais são do que reflexos das novas situações de direito substancial e da tomada de consciência de que o Estado tem o dever de dar proteção efetiva aos direitos.

2.20. A ausência de regra processual capaz de viabilizar a realização do direito fundamental à tutela jurisdicional. Resta ainda tratar dos casos de ausência de regra ou técnica processual. Tome-se como exemplo o caso da execução da antecipação da tutela de soma em dinheiro. A *não previsão* de meio de execução adequado a essa tutela – ou *qualquer interpretação da legislação que vise a suprimi-lo* – configura insuficiência de tutela normativa ao direito fundamental à tutela efetiva.

Esse tipo de omissão, no entanto, pode ser seguramente suprida quando se tem consciência de que a técnica processual depende apenas da individualização das necessidades do caso concreto. Quer dizer que, se o juiz identifica a necessidade de antecipação de soma em dinheiro, e por isso mesmo concede a tutela antecipada, acaba lhe sendo fácil identificar a necessidade de um meio executivo capaz de dar efetivo atendimento à antecipação da tutela. Esse meio executivo, quando a técnica antecipatória é fundada na urgência, obviamente não pode ser aquele que foi pensado para dar atuação à sentença que condena ao pagamento de dinheiro. Como as necessidades de direito material que têm relação com a tutela antecipada e a sentença condenatória são aberrantemente distintas, é pouco mais do que evidente que os meios executivos devem ser com essas compatíveis.

Note-se que se o objetivo da multa é dar maior tempestividade e efetividade à realização das decisões judiciais, não há racionalidade em admiti-la apenas em relação às decisões que determinam fazer, não fazer ou entrega de coisa. No caso de soma em dinheiro, a multa, além de *livrar* a administração da justiça de um procedimento oneroso e trabalhoso e beneficiar as partes com a eliminação dos custos e dos entraves da execução por expropriação, confere à tutela antecipada a tempestividade necessária para que ela possa dar efetiva proteção ao direito material e, assim, realizar o direito fundamental à tutela jurisdicional.⁶³

O exemplo importa apenas para evidenciar que a falta de técnica processual deve sempre ser suprida com base no direito fundamental. O juiz pode e deve, ao deparar-se com ausência de previsão de modalidade executiva idônea, suprir a omissão considerando as circunstâncias do caso concreto e a regra da necessidade, precisamente em nome do controle da insuficiência de tutela normativa ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva.

Como esse direito fundamental incide sobre o Estado e, portanto, sobre o legislador e o juiz, é *evidente que a omissão do legislador não justifica a omissão do juiz*. Melhor explicando: se tal direito fundamental, para ser realizado, exige que o juiz esteja munido de poder suficiente para a proteção – ou tutela – dos direitos, a ausência de regra processual instituidora de instrumento processual idôneo para tanto constitui evidente obstáculo à atuação da jurisdição e ao direito

fundamental à tutela jurisdicional. Diante disso, para que a jurisdição possa exercer a sua missão – que é tutelar os direitos – e para que o cidadão realmente possa ter garantido o seu direito fundamental à tutela jurisdicional, não há alternativa a não ser admitir ao juiz a supressão da omissão inconstitucional.

Por essa razão, o art. 139, IV, CPC, tem de ser interpretado como supressor dessa lacuna normativa existente no revogado Código Buzaid. Atualmente, é possível empregar multa coercitiva para execução da tutela antecipada de soma em dinheiro. Quando o legislador refere que o juiz tem o dever de determinar todas as medidas coercitivas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias, ele obviamente está autorizando o órgão jurisdicional a empregar a multa coercitiva para forçar ao pagamento de somas em dinheiro.

2.21. A subjetividade do juiz e a necessidade de explicitação da correção da tutela jurisdicional mediante a argumentação jurídica. A controlabilidade intersubjetiva das razões. É evidente que a necessidade de compreensão da lei a partir da Constituição aumenta o risco de subjetividade das decisões judiciais, o que vincula a legitimidade da prestação jurisdicional à sua precisa justificação. Como explica Jerzy Wróblewski, justificar uma decisão judicial consiste em dar-lhe as razões apropriadas.⁶⁴ Assim, o problema da legitimidade da tutela jurisdicional, no Estado Constitucional, está em verificar se é possível justificar a decisão do juiz, ou melhor, encontra-se na definição daquilo que assegura a aceitabilidade racional dessa decisão.⁶⁵

Isso quer dizer que a passagem de uma perspectiva *cognitivista* da interpretação (a norma como seu *objeto*, em que a tarefa interpretativa está em *descrever* o único significado correto, prévio e intrínseco da norma, declarando-o) para uma perspectiva *adscritiva* da interpretação (a norma como seu *resultado*, em que a tarefa interpretativa está em *reconstruir* argumentativamente os possíveis significados dos textos em seus respectivos contextos, outorgando-lhes um significativo normativo) fez com que se tornassem personagens históricos o juiz *bouche de la loi*⁶⁶, *Sklave des Gesetzes*⁶⁷ e *slot machine*.⁶⁸ Daí que o problema da interpretação e da aplicação do Direito converte-se em um problema de maior ou menor vinculação aos termos da Constituição e da legislação, em que se reconhece como inevitável um espaço de subjetividade da jurisdição que é sempre chamada a *reconhecer* significados possíveis dos textos, *valorá-los* argumentativamente e *decidir* por uma das alternativas interpretativas: reconhecer, valorar e decidir são tarefas inerentes à jurisdição no Estado Constitucional.

Lembre-se que em Oitocentos a cultura jurídica negava a existência de qualquer espaço de subjetividade para a jurisdição, acentuando a existência de uma única resposta correta para todo e qualquer problema interpretativo, cumprindo ao juiz buscá-la na legislação. Com Kelsen, semelhante solução para o problema cai por completo, na medida em que ele reconhece “o Direito a aplicar como uma moldura dentro da qual há várias possibilidades de aplicação” em todo e qualquer caso.⁶⁹ Mais moderado, Hart sugere que apenas determinados casos não encontram uma resposta unívoca a partir do Direito (os chamados *hard cases*), comportando os demais uma única resposta correta (*easy cases*).⁷⁰ A crítica de Dworkin a Hart, a propósito, incide justamente sobre esse espaço de discricionariedade judicial.⁷¹

Entretanto, no quadro atual das relações entre a legislação e a jurisdição, a questão não está em *negar o espaço de subjetividade do juiz* – que inquestionavelmente existe a partir do reconhecimento da *equivocidade da linguagem* e da *vagueza das normas* e será maior ou menor de acordo com a espécie normativa com que disciplinada determinada situação (princípio ou regra) e de acordo com a técnica legislativa empregada (técnica casuística ou técnica aberta). A questão está em tornar as decisões judiciais *intersubjetivamente controláveis* a partir de um *método adequado* de interpretação e aplicação do Direito.

Esse método adequado de interpretação e aplicação é o método da *justificação racional*, já abordado brevemente, que envolve uma compreensão *lógico-argumentativa* do Direito e a utilização de ferramentas capazes de tornar a aplicação dos princípios e das regras uma atividade estruturalmente controlável – os *postulados normativos*.

2.22. Os postulados normativos para aplicação do Direito e dos direitos fundamentais, a interpretação de acordo e as técnicas de controle da constitucionalidade diante da argumentação jurídica. Ao lado das normas de primeiro grau (princípios, regras e sobreprincípios), que têm por objeto comportamentos humanos, existem normas que têm por objeto a aplicação de outras normas, que são as chamadas normas de segundo grau, também conhecidas como metanormas ou como postulados normativos. Essas espécies normativas visam a estruturar a aplicação de outras normas diante de antinomias *contingentes* e *concretas*. São postulados dessa ordem a ponderação, a proibição de excesso, a concordância prática, a igualdade, a razoabilidade e a proporcionalidade. Pela importância que ganharam no cotidiano forense, merecem destaque os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

A *razoabilidade* serve para a estruturação da aplicação de princípios e regras, especialmente das regras, e visa a promover a *harmonização de uma norma geral com um caso particular*. É um postulado que pressupõe, portanto, especificamente uma relação do geral para com o particular – daí a razão pela qual serve muitas vezes como instrumento para metódica superação de regras. A razoabilidade basicamente grava o intérprete com deveres de *equidade*, *congruência* e *equivalência*. A uma, a razoabilidade impõe um *dever de equidade* (razoabilidade como equidade), o que exige na aplicação das normas a consideração daquilo que *normalmente acontece* e a consideração de *particularidades* do caso concreto flagrantemente desconsideradas pela generalidade normativa. A duas, impõe um *dever de congruência* (razoabilidade como congruência), o que vincula a aplicação das normas com as suas condições externas de aplicação, proibindo-se a consideração de um suporte empírico inexistente como se existente fosse (vinculação à *realidade*) e impõe a existência de uma relação de congruência entre o critério de diferenciação escolhido e a medida normativamente adotada (necessidade de *congruência*). A três, impõe um *dever de equivalência* (razoabilidade como equivalência), o que exige uma *relação de equivalência* entre a medida adotada e o critério que a dimensiona.⁷²

A *proporcionalidade* serve para a estruturação da aplicação de princípios e regras, especialmente de princípios, e tem por objetivo aferir a *justa relação entre meio e fim*. Sem relação entre meio e fim a proporcionalidade não tem qualquer utilidade: determinada restrição (meio) é sempre proporcional em relação à promoção de determinado estado de coisas (fim). Essa é a razão pela qual a proporcionalidade serve muitas vezes para estruturar a aplicação de princípios colidentes. O exame da proporcionalidade na aplicação das normas exige a consideração dos três elementos que a compõem: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. É preciso saber se o *meio escolhido promove o fim* (adequação), se existem *meios concorrentes* que promovem igualmente o fim sem promover de forma tão intensa a *restrição* dos direitos fundamentais envolvidos no caso (necessidade) e se a *importância da realização do fim justifica a intensidade da restrição* aos direitos fundamentais (proporcionalidade em sentido estrito).⁷³

A aplicação do Direito e especialmente dos direitos fundamentais depende do emprego de postulados normativos, sem os quais a interpretação e a aplicação do Direito correm o risco de se tornar empresas incontrolláveis do ponto de vista intersubjetivo. Daí que a utilização dos postulados normativos serve para evitar o arbítrio na aplicação do Direito e para tornar, mediante a *argumentação* despendida, intersubjetivamente controláveis as escolhas decisórias realizadas ao longo do processo interpretativo.

Por outro lado, quando são encontradas, a partir dos métodos interpretativos, duas ou mais interpretações, o raciocínio deve buscar a que melhor se ajusta às normas constitucionais. Ou melhor, o resultado preferido pelo intérprete deve ser o que melhor realize o programa da norma constitucional ou ainda o que dê a maior efetividade possível aos direitos fundamentais.⁷⁴

Como nesse último caso não se questiona a validade da lei, mas apenas se afirma a melhor solução diante dos direitos fundamentais, não se argumenta contra ou a favor da lei, *mas em prol da sua melhor interpretação*, isto é, da solução que confira a maior efetividade à Constituição. O mesmo não ocorre em se tratando de controle de constitucionalidade. Para se declarar lei inconstitucional é preciso demonstrar que ela interferiu sobre bem que foi excluído da disposição do Parlamento. Argumenta-se que ela assim não incidiu para se demonstrar a sua constitucionalidade. Quando a interpretação proposta à norma é inconstitucional, mas é possível

interpretá-la de forma constitucional, argumenta-se que a norma tem um sentido conforme a Constituição e que, assim, não há necessidade de declará-la inconstitucional. Quando a norma, aplicada em determinada situação, revela-se inconstitucional, mas apresenta-se constitucional em outra, argumenta-se no sentido de que a norma, embora em certo local não possa ser aplicada, tem aplicação constitucional.

No caso de omissão inconstitucional é necessário argumentar que o direito fundamental necessita de uma lei para concretizá-lo ou para protegê-lo. Assim, é preciso demonstrar que o direito fundamental necessita de uma norma legal para lhe dar efetividade. Como é óbvio, não se trata de argumentar contra a lei – pois essa não existe –, porém de demonstrar que a ausência de lei impede a realização do direito fundamental segundo o mínimo constitucionalmente exigido. Nesse caso, como a amplitude da prestação jurisdicional não é circunscrita pela lei (que não existe), a tutela jurisdicional, ainda que necessária para a tutela do direito fundamental não protegido pelo legislador, deve configurar a menor restrição possível à esfera jurídica do demandado, o que acaba também fazendo parte da carga de argumentação necessária para a supressão da omissão inconstitucional. Mas não basta apenas demonstrar de que forma a argumentação incide diante da estrutura dos postulados, da interpretação de acordo e das técnicas de controle da constitucionalidade, sendo também necessário precisar em que termos a lei e os direitos fundamentais sujeitam a argumentação.

É claro que os métodos de interpretação dos direitos fundamentais são em parte diferentes daqueles que servem para dar significado à lei. Mas isso aqui não importa. O que interessa é constatar que o texto da lei coarcta a argumentação com mais intensidade do que o texto da norma de direito fundamental e, igualmente, que o texto da norma de direito fundamental também vincula a argumentação.

As normas de direito fundamental são em grande medida abertas e, assim, é certo dizer que a lei é inúmeras vezes mais objetivável do que os direitos fundamentais. De modo que é mais fácil, ao menos como regra geral, atribuir significado a uma lei do que a um direito fundamental, o que faz com que o texto da lei goze, nessa dimensão, de uma posição de vantagem em relação ao texto da norma de direito fundamental.

Porém, é óbvio que dos textos das normas de direito fundamental podem ser retirados significados e que esses têm evidente impacto sobre a argumentação. Por esse motivo, o texto da norma de direito fundamental, assim com o texto da lei, também coarcta a argumentação. Não se quer dizer, evidentemente, que o texto da norma de direito fundamental não admita argumento contrário.⁷⁵ Nesse caso, é necessário que a argumentação tenha um peso capaz de justificar, a partir da própria Constituição, a possibilidade de o intérprete se afastar da norma.

O texto da norma de direito fundamental, da mesma maneira que o texto da lei, faz com que o peso da argumentação recaia sobre aquele que tem interesse em demonstrar um resultado que é a ele contrário. Nesse sentido, é possível dizer que o texto da norma possui, por assim dizer geneticamente, o peso da argumentação do seu lado.⁷⁶

Por outro lado, sabe-se que a lei, em princípio, é considerada de acordo com a Constituição. Por isso, a declaração da inconstitucionalidade da lei exige que a argumentação tenha um peso capaz de demonstrar a sua incompatibilidade com os direitos fundamentais. Quer dizer que, quando da comparação dos significados da lei e do direito fundamental, o peso da lei sempre prepondera no plano estático, obrigando a argumentação sempre a demonstrar, no plano dinâmico, que o direito fundamental invalida a lei.

2.23. A argumentação jurídica em prol da técnica processual adequada ao direito fundamental à tutela jurisdicional. Quando se trata da argumentação em prol da técnica processual adequada ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, é preciso relacionar a argumentação com a: i) interpretação de acordo, ii) interpretação conforme, iii) declaração parcial, iv) concretização de norma de caráter aberto e v) supressão da omissão inconstitucional.

Na interpretação de acordo, argumenta-se em prol de uma interpretação que, sendo *capaz de*

atender às necessidades de direito material, confira a devida efetividade ao direito fundamental e à tutela jurisdicional efetiva. Na interpretação conforme, argumenta-se que, embora a interpretação proposta seja inconstitucional, determinada interpretação é conforme a Constituição. Na declaração parcial de nulidade argumenta-se que, não obstante a aplicação da norma seja inconstitucional em determinada situação, não é no caso concreto.

A questão complica-se quando se pensa na concretização das normas processuais abertas e na supressão da omissão legal inviabilizadora da realização do direito fundamental à tutela jurisdicional.

No caso de concretização de norma processual aberta, a necessidade de justificar a utilização da técnica processual é, antes de tudo, decorrência da própria estrutura dessa modalidade de norma, instituída para dar ao juiz poder necessário para atender às variadas situações concretas.

Lembre-se que as normas processuais abertas devem ser concretizadas a partir das necessidades reveladas no caso concreto, pois se destinam a dar ao juiz poder para dar efetividade ao direito material. Isso quer dizer que, ao aplicar essas normas, *o juiz tem o dever* de encontrar uma técnica processual ou um “modo” processual que seja capaz de atender ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Mas, como esse “modo” é a expressão da concretização de uma norma aberta – que obviamente não se preocupa apenas com o direito do autor, mas igualmente com o direito do réu –, o juiz deve argumentar que o “modo” encontrado, além de dar efetividade ao direito fundamental à tutela jurisdicional, é o que gera a menor restrição possível ao demandado.

Na hipótese de omissão de regra processual ou de inexistência de técnica processual adequada ao caso concreto, a diferença, em termos de argumentação, é a de que o juiz deverá demonstrar que as necessidades de direito material exigem uma técnica *que não está prevista na legislação processual*. Porém, ao juiz não bastará demonstrar a imprescindibilidade de determinada técnica processual não prevista na lei, mas também argumentar, considerando o direito de defesa, que a técnica processual identificada como capaz de dar efetividade à tutela do direito é a que traz a menor restrição possível à esfera jurídica do réu.

Nos casos de concretização de normas abertas e de supressão de omissão inconstitucional, a identificação das necessidades dos casos concretos e a adequação das técnicas processuais para lhes dar proteção obviamente devem ser precisamente justificados. Na verdade, o juiz deve estabelecer uma relação racional entre o significado da tutela jurisdicional no plano substancial (tutela inibitória, ressarcitória etc.), as necessidades do caso concreto e a técnica processual (sentença, multa, busca e apreensão etc.). Em outros termos, deve demonstrar que determinada situação de direito material deve ser protegida por certo tipo de tutela jurisdicional e que, para que essa modalidade de tutela jurisdicional possa ser concretizada, deve ser utilizada uma precisa técnica processual.

Antes de partir para o encontro da técnica processual adequada, o juiz deve demonstrar as necessidades de direito material, indicando como as encontrou no caso concreto. Em outras palavras, isso quer dizer que primeiro é necessário identificar a tutela do direito para depois se cogitar a respeito da técnica processual. Nessa linha, a argumentação relativa à técnica processual se desenvolve sobre um discurso de direito material já justificado. Nesse caso existem dois discursos: um primeiro sobre o direito material e outro, incidente sobre o primeiro, a respeito do direito processual. O discurso de direito processual é um segundo discurso, no sentido de que recai sobre um primeiro discurso que lhe serve de base para o desenvolvimento. O discurso jurídico processual é, em outros termos, um discurso que tem a sua base em um discurso de direito material.

A ideia de segundo discurso obviamente não pretende significar que o discurso de direito processual seja um discurso acerca das regras do discurso de direito material. Vale dizer: não se pretende situar o direito processual no nível sobrenormativo (próprio dos sobreprincípios) nem no nível metanormativo (próprio dos postulados normativos). Esses planos sobrenormativo e metanormativo, rigorosamente, interessam como problemas de metodologia do direito ou da

teoria do discurso jurídico. A noção de segundo discurso aqui tem outro objetivo. Pretende apenas demarcar o território de operatividade do discurso processual, demonstrando que os discursos de direito material e processual, apesar de operarem em planos diversos, são reciprocamente dependentes.⁷⁷

É certo que a idoneidade desses dois discursos se vale dos benefícios gerados pela realização e pela observância das normas do processo judicial. Mas, ainda assim, *não se pode deixar de perceber a nítida distinção entre um discurso de direito material legitimado pela observância do processo judicial e um discurso de direito processual que, além de se beneficiar das normas do processo judicial, sustenta-se sobre um diferente discurso (de direito material).*

O discurso de direito processual, ou seja, o que elege a técnica processual adequada em razão da exigência de uma norma aberta ou o que identifica a necessidade de uma técnica processual não prevista na lei, não representa qualquer ameaça à segurança jurídica, compreendida em sua *perspectiva dinâmica de segurança interpretativa*, na medida em que parte de um discurso que se apoia nos fatos e no direito material. O discurso processual objetiva atender a uma situação já demonstrada pelo discurso de direito material e não pode esquecer que a técnica processual eleita deve ser a mais suave, ou seja, a que, tutelando o direito, cause a menor restrição possível ao réu.

A justificação, obedecendo a esses critérios, dá às partes a possibilidade de controle da decisão jurisdicional. A diferença é a de que, em tais situações, o controle da atividade do juiz é muito mais complexo e sofisticado do que aquele que ocorria com base no princípio da tipicidade, quando o juiz apenas podia usar os instrumentos processuais definidos na lei. Mas essa mudança na forma de pensar o controle jurisdicional é apenas reflexo da *necessidade de se dar maior poder ao juiz* – em parte a ele já entregue pelo próprio legislador ao fixar as normas abertas – e da transformação do próprio conceito de direito, que submete a compreensão da lei aos direitos fundamentais.

2.24. A inevitável reação do sistema: a autoridade dos precedentes judiciais. O modelo de jurisdição, próprio ao juiz da tradição romano-canônica do Estado constitucional, impõe uma contrapartida em nome da liberdade, segurança jurídica, da coerência do direito e da igualdade perante as decisões judiciais.⁷⁸

A mudança no conceito de interpretação, a força do constitucionalismo e a atuação judicial mediante a concretização das regras abertas fez surgir um modelo de juiz completamente distinto do desejado pela tradição romano-canônica.⁷⁹ A evolução da tradição de *civil law* é a história da superação de uma ideia instituída para viabilizar a realização de um desejo revolucionário e que, portanto, nasceu com a marca da utopia. Como dogma, essa noção manteve-se viva ainda que a evolução do *civil law* a descaracterizasse.

Imaginou-se, na tradição de *civil law*, que a lei seria suficiente para garantir a igualdade. A segurança jurídica dependeria da estrita aplicação da lei. Porém, é curioso perceber que a certeza jurídica adquiriu feições antagônicas no *civil law* e no *common law*, tendo sido utilizada, no primeiro, para negar a importância dos tribunais e das suas decisões e, no último, para fundamentar o *stare decisis*.

Para a Revolução Francesa, a lei seria indispensável para a realização da liberdade e da igualdade. Por este motivo, entendeu-se que a certeza jurídica seria igualmente indispensável diante das decisões judiciais, uma vez que, caso os juízes pudessem produzir decisões que não se limitassem a declarar a lei, os propósitos revolucionários estariam perdidos ou seriam inalcançáveis. Imaginou-se que a segurança jurídica seria a segurança do sentido prévio e intrínseco do texto legislativo.

Assim, manter o juiz preso à lei seria sinônimo de segurança jurídica. O próprio Montesquieu fez coro pela segurança jurídica fundada na estrita aplicação da lei quando disse que, se os julgamentos “fossem uma opinião particular do juiz, viver-se-ia na sociedade sem saber precisamente os compromissos que nela são assumidos”.⁸⁰ Essa passagem da doutrina de Montesquieu, segundo adverte Giovanni Tarello, evidencia uma ideologia que sugere que a liberdade política, entendida como segurança psicológica do indivíduo, realiza-se mediante a

certeza do direito.⁸¹

A certeza do direito estaria na impossibilidade de o juiz interpretar a lei ou, melhor dizendo, na própria lei. O ponto tem enorme relevância. Note-se que o *civil law* não apenas imaginou, utopicamente, que o juiz apenas atuaria a vontade da lei, como ainda supôs que, em virtude da certeza jurídica que daí decorreria, o cidadão teria segurança e previsibilidade no trato das relações sociais. Além do mais, entendeu que a lei seria o suficiente para garantir a igualdade dos cidadãos. Não por acaso consta cravada na parede da *Corte di Cassazione* – fruto dessa cultura jurídica – que “*la legge è uguale per tutti*”.

Isto significa, portanto, que nos países que não precisaram se iludir com o absurdo de que o juiz não poderia interpretar a lei naturalmente aceitou-se que a segurança e a previsibilidade teriam que ser buscadas em outro lugar. E que lugar foi esse? Ora, exatamente nos precedentes ou, mais precisamente, no *stare decisis*. A segurança e a previsibilidade obviamente são valores almejados por ambos os sistemas. Mas supôs-se no *civil law* que tais valores seriam realizados por meio da lei e da sua estrita aplicação pelos juízes, enquanto que, no *common law*, por se ter tido a consciência de que os juízes interpretam a lei e, por isto, podem proferir decisões diferentes, enxergou-se na força vinculante dos precedentes o instrumento capaz de garantir a segurança e a previsibilidade de que a sociedade precisa para se desenvolver.⁸²

Não há dúvida que o papel do atual juiz da tradição de *civil law* e, principalmente, o do juiz brasileiro, a quem é deferido o dever-poder de controlar a constitucionalidade da lei no caso concreto, muito se aproxima da função exercida pelo juiz do *common law*, especialmente a da realizada pelo juiz estadunidense. Já se disse que o *civil law* passou por um processo de transformação das concepções de direito e de jurisdição. O juiz da nossa tradição não tem mais a mera função de declarar a vontade da lei, cabendo-lhe conformar a lei aos direitos contidos na Constituição. Tanto é verdade que as jurisdições da Europa continental não resistiram à necessidade do controle da constitucionalidade da lei, embora tenham reservado esta função a órgãos que, inicialmente, foram concebidos como não jurisdicionais, exatamente em homenagem ao princípio de que o juiz não poderia se imiscuir na tarefa do legislativo.⁸³

O juiz que trabalha com conceitos indeterminados e regras abertas está muito longe daquele concebido para unicamente aplicar a lei. Como advertem Merryman e Pérez-Perdomo, não se exige muita imaginação para perceber que cláusulas como a da boa-fé dão ao juiz de *civil law* grande porção de poder equitativo indefinido, deixando-lhe quase que sem responsabilidade diante da formulação legislativa.⁸⁴

Os teóricos do *common law* reconhecem, quando olham para o *civil law*, que nas decisões acerca de matéria constitucional, assim como nas que envolvem a aplicação de cláusulas gerais, em que é frequente a necessidade de dar concretude ao significado de conceitos jurídicos, não há sequer como admitir a distinção entre precedentes interpretativos e precedentes de solução (que criam o direito). Alega-se que, nesses casos, a interpretação tem tamanho alcance e é guiada por argumentos tão frágeis e vagos da lei escrita que a decisão poderia ser explicada tanto pela teoria interpretativista quanto pela teoria positivista da criação judicial do direito – próprias ao *common law*.⁸⁵

No livro *Interpreting Precedents*, em que se faz amplo debate comparatístico sobre os precedentes no *common law* e no *civil law*, encontra-se o capítulo intitulado *Rationales for Precedent*, protagonizado por Bankowski, MacCormick, Morawski e Ruiz Miguel. Estes juristas, ao se depararem com a influência das decisões da Corte Europeia de Justiça em face das Cortes dos Estados membros, inclusive sobre as suas Cortes Constitucionais, observam que, nas decisões relativas a questões constitucionais e cláusulas gerais, a prestação judicial opera construindo princípios e dando-lhes efeitos concretos, quando se torna artificial, ou até mesmo fictício, tentar desenhar uma linha demarcatória entre os precedentes interpretativos e os de criação do direito.⁸⁶

Na verdade, não há unanimidade no *common law* acerca da natureza da jurisdição, se criadora de direitos ou não. Lembre-se que a questão de se os juízes criam direito foi um dos focos principais do célebre debate travado entre Herbert Hart – que sustenta em parte o papel criativo

da jurisdição – e Ronald Dworkin – que o nega.⁸⁷ Enquanto aquele afirma, sem titubear, que o juiz cria o direito na falta de regra que permita a solução ao caso,⁸⁸ esse, ao tratar dos *hard cases* no conhecido *Taking Rights Seriously*, argumenta que, “mesmo quando nenhuma regra regula o caso, uma das partes pode, ainda assim, ter o direito de ganhar a causa” e “o juiz continua tendo o dever, mesmo nos casos difíceis, de *descobrir* quais são os direitos das partes, e não de inventar novos direitos retroativamente”.⁸⁹

O *insight* do referido grupo de juristas, aliado à disputa teórica entre Hart e Dworkin, demonstra que a evolução do *civil law*, certamente em virtude do impacto das novas perspectivas da teoria da interpretação e do constitucionalismo contemporâneo, aproximou sensivelmente o que antes poderia ser visto como criação judicial do direito e interpretação judicial.

Pois bem, é exatamente essa aproximação entre os sistemas de *civil law* e de *common law* que aponta para a necessidade de o sistema de *civil law* conter a possibilidade de arbítrio judicial e dar segurança jurídica aos seus jurisdicionados. O incremento do poder judicial exige, em nosso sistema, realce à autoridade dos precedentes judiciais das Cortes Supremas – do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional federal. Pense-se, apenas a título de exemplo, no poder judicial de suprir a falta de técnica processual e de identificar o meio executivo necessário à tutela do direito.

Os precedentes constitucionais, vistos como os precedentes do Supremo Tribunal Federal, não podem deixar de ter força obrigatória perante os demais juízes e tribunais, pouco importando o local em que brotem, seja em controle abstrato ou em sede de controle difuso. O mesmo se pode dizer em relação aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, cuja missão constitucional é definir a interpretação da lei federal. É completamente irracional o sistema que possui Cortes Supremas para definir o sentido da lei federal e da Constituição e, ainda assim, convive com decisões discrepantes dos tribunais ordinários. Isto não apenas é irracional, como nega a coerência do direito, a segurança jurídica, a liberdade e a igualdade perante as decisões judiciais.⁹⁰

Inexiste coerência num direito que se expressa mediante decisões que tratam de casos iguais de maneira desigual.⁹¹ Note-se que isso é extremamente grave quando se tem consciência de que o direito conta com a colaboração do Judiciário para ser produzido e que o Estado de Direito depende de um direito coerente. Como adverte Neil MacCormick, no Estado moderno, “com muitos juízes e muitas cortes e uma hierarquia estruturada de recursos, as mesmas regras e soluções devem orientar a decisão independente do juiz do caso. Fidelidade ao Estado de Direito requer que se evite qualquer variação frívola no padrão decisório de um juiz ou corte para outro”.⁹² Nessa linha, Earl Maltz, em ensaio publicado na *North Carolina Law Review*, adverte que um dos valores mais importantes do sistema político americano é o de que os princípios que orientam a sociedade devem constituir “regras de Direito” e não simples opiniões de alguns homens que, temporariamente, ocupam relevantes cargos no Poder.⁹³

2.25. O Código de 2015 e a força dos precedentes. O novo Código de Processo Civil tem como sua principal novidade o realce outorgado ao tema dos precedentes. Enganam-se aqueles, contudo, que imaginam que o novo Código de Processo Civil *outorgou* força obrigatória aos precedentes. E também se enganam aqueles que imaginam que a compreensão do tema dos precedentes no direito brasileiro passa por uma *importação acrítica* dos conceitos da tradição do *Common Law*.

Na verdade, o núcleo duro do tema do precedente judicial sequer poderia ser pensado como um tema propriamente de processo civil. É claro que as técnicas de reconhecimento do precedente (identificação da *ratio decidendi* e daquilo que constitui *obiter dictum* em determinado decisão) e de seu manejo (elaboração de *distinções*, de *superações* e do modo como essas devem ser realizadas e com que efeitos) são temas de direito processual civil. Saber, contudo, se um precedente constitui *fonte primária do Direito* e se, portanto, tem *eficácia obrigatória* é uma questão de teoria do Direito – especificamente, de teoria da interpretação.

Daí que a questão essencial está em perceber a *razão* pela qual o precedente ganhou autoridade no nosso Direito. E a resposta é de fácil compreensão: desde o momento em que se percebe que a *interpretação* do Direito não é simplesmente *declaratória* – *descritiva* – de uma

norma legal preexistente, sendo *reconstrutiva – adscritiva – de sentidos possíveis* que podem ser reconduzidos aos textos jurídicos, tornou-se inescapável o reconhecimento de que as razões extraíveis de determinadas decisões judiciais constituem *precedentes obrigatórios*, na medida em que *incrementam a ordem jurídica*, oferecendo dados novos de concentração de significado normativo. Isso evidencia que os precedentes não existem apenas para solucionar casos em que se percebem *lacunas* na ordem jurídica e casos que evidenciam *antinomias* (campo normalmente chamado de *interpretação integrativa*). Os precedentes cobrem não só o campo da interpretação integrativa, mas também o da *interpretação em geral* – se de um modo geral os textos jurídicos são *equivocos* e as normas são *vagas* (daí a *dupla indeterminação* do Direito), então é forçoso reconhecer que *todo e qualquer ato interpretativo enfrenta problemas de equivocidade*. O precedente judicial, nessa dimensão, afasta-se do debate tradicional do mundo do *Common Law*, na medida em que esses eram vistos como a “prova” da existência do *Common Law*, sendo os juízes os seus “oráculos”. O precedente judicial em um sistema que conta com legislação consubstancia-se no símbolo maior da colaboração entre o legislativo e o judiciário para a promoção do império do Direito – o legislador oferece textos ao juiz, que reconhece os seus significados possíveis, valora-os argumentativamente e escolhe um desses significados para adscriver ao texto e reconstruir a norma. Daí a razão pela qual a distinção entre *precedentes persuasivos* e *precedentes obrigatórios*, conhecida no mundo do *Common Law*, rigorosamente não interessa para o direito brasileiro – dadas as suas condições de aparecimento, todos os precedentes são obrigatórios.

A distinção que interessa é a de *jurisprudência* e *precedente*. Embora o novo Código utilize essas expressões indistintamente, essas obviamente não se confundem. Tradicionalmente, o termo *jurisprudência* era utilizado para designar um conjunto reiterado de decisões no mesmo sentido de quaisquer tribunais. Esse significado foi forjado a partir de uma compreensão cognitivista do ato interpretativo, que pressupunha que a atividade interpretativa era meramente declaratória e descritiva e que o seu resultado era sempre unívoco. A *jurisprudência* pressupunha univocidade interpretativa. Essa maneira de entendê-lo obviamente cedeu quando se percebeu que a interpretação não era um ato meramente cognitivista e que o seu resultado admitia mais de uma resposta possível. A partir daí começou a ser necessário falar em *jurisprudência dominante*.

A *jurisprudência* em um sistema de *precedentes* tem um papel da mais alta relevância. Ela *evidencia as possíveis interpretações* a partir do julgamento de casos concretos e com isso contribui para a unidade do Direito, permitindo que os precedentes possam trabalhar contando com esse rico manancial de significados. A *jurisprudência* revela as tendências interpretativas.

A *jurisprudência* é produto do trabalho das *Cortes de Justiça* – isto é, dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais. A função dessas Cortes não é formar precedentes – é prolatar *decisões justas* e, em sendo o caso, *efetivá-las adequada e tempestivamente*. As Cortes de Justiça são Cortes de controle e de *jurisprudência*: interpretam e aplicam o Direito, controlando o trabalho realizado pelos juízes de primeiro grau, e produzem *jurisprudência*. Ao julgar os casos, porém, essas cortes evidenciam possíveis soluções para os problemas interpretativos nesses encerrados.

Os *precedentes* não se confundem com a *jurisprudência*, assim como as *Cortes Supremas* não se confundem com as Cortes de Justiça. Os precedentes constituem *razões generalizáveis* que podem ser extraídas dos julgamentos dos casos pelas Cortes Supremas – razões necessárias e suficientes para a solução de determinados problemas interpretativos. As Cortes Supremas existem não para efetuar controle de cada decisão prolatada pelas Cortes de Justiça – existem, pelo contrário, para interpretar o direito constitucional (Supremo Tribunal Federal) e o direito federal (Superior Tribunal de Justiça), outorgando adequado sentido aos textos, e para orientar a interpretação dos demais órgãos do Poder Judiciário e da sociedade civil. São Cortes de interpretação e de precedentes.

É a partir dessas linhas que o Código de 2015 tem de ser interpretado.

2.26. O processo civil como meio para tutela dos direitos a partir da jurisdição. O duplo discurso. Levando-se em consideração a transformação do conceito de interpretação (do cognitivismo descritivo ao adscritivismo reconstrutivo), do conceito de norma (princípios, regras,

sobreprincípios e postulados), da incorporação e incremento da técnica legislativa aberta (conceitos indeterminados e cláusulas gerais), a existência do controle difuso de constitucionalidade e a eficácia dos direitos fundamentais, fica fácil perceber a razão pela qual a doutrina aponta um eloquente deslocamento a partir dessa verdadeira virada conceitual: da *vocação do nosso tempo para legislação e para ciência do direito* (vom Beruf unser Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft)⁹⁴ para a *vocação do nosso tempo para jurisdição* (vocazione del nostro tempo per la giurisdizione)⁹⁵ ou, mais precisamente, para o processo.⁹⁶ A partir dessa passagem, o processo civil passou a responder não só pela necessidade de *resolver casos concretos* mediante a prolação de uma *decisão justa para as partes*,⁹⁷ mas também pela promoção da *unidade do direito* mediante a formação de *precedentes*.⁹⁸ Daí que a jurisdição no processo civil do Estado Constitucional tem por função dar *tutela aos direitos*⁹⁹ mediante a prolação de decisão justa para o caso concreto e a formação de precedente para promoção da unidade do direito para a sociedade em geral.¹⁰⁰

Partindo-se dessas significativas transformações do pano de fundo com que trabalha o processo civil, é possível visualizar esses *dois importantes discursos* que o processo civil deve ser capaz de empreender na nossa ordem jurídica a fim de que essa se consubstancie em uma *ordem* realmente idônea para *tutela dos direitos*. A jurisdição não tem compromisso apenas com a *resolução de casos concretos* (prolação de uma decisão justa e adequada e tempestivamente efetivável), mas também tem compromisso com a cognoscibilidade, com a estabilidade e com a confiabilidade da *ordem jurídica como um todo* (formação e superação de precedentes).¹⁰¹

2.27. A definitividade. As decisões jurisdicionais que julgam os conflitos, e assim colocam fim aos processos, são revestidas do atributo da *definitividade* ou são dotadas das características da *indiscutibilidade* e da *imutabilidade*.

A existência de conflitos entre os membros da sociedade, e a impossibilidade de os próprios envolvidos tomarem conta da sua resolução, obriga o Estado a manifestar o seu poder de *aplicação da justiça* ou o seu poder jurisdicional. Esse poder é indispensável para a estabilidade da vida social, que de outra forma seria entregue a contendas intermináveis.

Note-se que a sociedade precisa da jurisdição não apenas porque os cidadãos não têm condições de autorresolver os seus conflitos, mas especialmente porque a sociedade necessita de harmonia para poder se desenvolver.¹⁰² Por isso, a jurisdição não é apenas um meio de resolver litígios, mas fundamentalmente uma manifestação estatal voltada a *eliminá-los*, ou melhor, a solucioná-los *definitivamente*, fazendo com que os envolvidos reconheçam o seu *fim*.

De nada adiantaria a jurisdição caso os conflitos, uma vez resolvidos, pudessem ser rediscutidos, ou se a solução do juiz pudesse ser negada. De modo que a decisão jurisdicional, além de resolver os conflitos, deve se impor, tornando-se imutável e indiscutível. Isso quer dizer que, havendo decisão de mérito da qual não caiba mais recurso no processo, há direito à formação da coisa julgada. Isso não apenas para que a autoridade do Estado possa se afirmar, mas também porque os cidadãos têm a necessidade de ver os seus conflitos solucionados de forma definitiva.¹⁰³

Direito fundamental à tutela jurisdicional não significa apenas direito fundamental à resolução adequada do litígio, mas também direito fundamental à tutela jurisdicional que ponha término à contenda ou que finalize a disputa. Uma solução que não se torna imutável e indiscutível é uma mera opinião sobre um conflito, que poderia – guardadas as proporções – ser emitida por qualquer parecerista. Portanto, como seria fora de propósito, e até mesmo bizarro, transformar o direito fundamental à tutela jurisdicional em um direito a uma *opinião* do juiz, é fora de qualquer dúvida que esse direito tem como corolário o direito à definitividade da solução do conflito, que de seu turno se assenta no direito fundamental à segurança jurídica no processo.¹⁰⁴

Para se dizer que a decisão jurisdicional que resolve os litígios não pode ser negada ou rediscutida, afirma-se que ela produz coisa julgada.¹⁰⁵ A coisa julgada obviamente não é mera regra de processo. Ademais, embora certamente protegida pela Constituição (art. 5.º, XXXVI), ela é muito mais do que um princípio constitucional. Trata-se de uma regra indispensável à existência

do discurso jurídico e, por conseguinte, ao exercício da própria jurisdição.

A decisão judicial é o elemento final do discurso jurídico, realizado para que o Estado possa exercer a sua função de tutelar os direitos e, por consequência, as pessoas. Todo discurso, como é sabido, necessita de regras para poder se desenvolver de maneira adequada. É assim que o processo, para permitir a formação do convencimento do juiz e o desenvolvimento do discurso judicial, exige regras relativas ao tempo, ao modo e ao conteúdo da participação das partes e do juiz. Tais regras dizem respeito ao conteúdo do discurso e estão preocupadas com a sua legitimidade, imprescindível para a legitimação da jurisdição.

Porém, todo discurso, para valer enquanto discurso, precisa terminar. O recrudescimento da decisão judicial é imprescindível para que o discurso jurídico tenha razão de ser e, assim, realmente exista enquanto discurso jurídico.

A coisa julgada, portanto, não é uma regra preocupada com o conteúdo do discurso, mas uma condição para que esse seja um discurso institucional limitado no tempo e, destarte, um discurso jurídico propriamente dito. Na verdade, se a discussão jurídica não tiver um termo a partir do qual a decisão não possa ser questionada, não haverá sentido em falar em discurso jurídico nem muito menos em realizá-lo.

Ora, um discurso jurídico incapaz de se estabilizar é uma contradição em termos, já que o poder não pode prescindir do recrudescimento. É por isto que um discurso aberto à eterna discussão jamais será um discurso jurídico ou um discurso do poder estatal, mas tão somente um discurso prático-geral.¹⁰⁶

Quer isto dizer que a coisa julgada, antes de ser uma regra destinada a legitimar o conteúdo do discurso, é uma regra imprescindível à sua própria existência. Bem por isso, a Constituição Federal, sabedora da necessidade do recrudescimento para a caracterização do Estado e para a plena conformação do direito fundamental à tutela jurisdicional, estabelece no seu art. 5.º, XXXVI, que a lei não prejudicará a coisa julgada.

A norma constitucional não apenas impede o legislador de modificar o conteúdo de decisão judicial que produziu coisa julgada, mas também proíbe lei que estabeleça a possibilidade de descon sideração ou relativização da coisa julgada material. A coisa julgada material é, além de regra imprescindível à existência de discurso jurídico, corolário do direito fundamental à tutela efetiva e elemento insuprimível do Estado Democrático de Direito.¹⁰⁷ Assim, está o Judiciário obrigado a tutelá-la e o legislativo proibido de descaracterizá-la.¹⁰⁸

Como dizem Rosenberg, Schwab e Gottwald, a “coisa julgada material é uma consequência do direito à proteção legal pelos tribunais. Sua ancoragem constitucional é encontrada no princípio do Estado de Direito”.¹⁰⁹ Na Alemanha, onde não há proteção constitucional expressa à coisa julgada, o seu fundamento constitucional está ancorado no princípio do Estado Constitucional (*Verfassungsstaat*). O *Bundesverfassungsgericht* foi o principal responsável por essa elaboração, frisando que o princípio do Estado Constitucional tem como componente essencial a garantia da certeza do direito, que exige não apenas o desenvolvimento regular do processo, como também a estabilidade da sua conclusão.¹¹⁰

Da caracterização do discurso jurídico como um caso especial do discurso prático geral, res sai a necessidade de ver a jurisdição e o seu resultado como algo dotado de uma específica autoridade: as decisões judiciais não são apenas dotadas de definitividade no sentido de que são imutáveis e indiscutíveis, mas também são decisões *institucionalmente irrevisíveis*. Vale dizer: gozam de *irrevisibilidade externa*, de modo que não é possível revisá-las fora dos quadros da própria jurisdição.¹¹¹ Mesmo quando há autorização para rescisão da coisa julgada (ação rescisória, art. 966, CPC), o que é absolutamente excepcional no direito brasileiro, essa revisão ocorre dentro do Poder Judiciário. A irrevisibilidade das decisões judiciais fora dos quadros da própria jurisdição é uma característica da jurisdição que decorre da própria necessidade de segurança jurídica e da caracterização do discurso jurídico como um discurso prático.

2.28. Jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Na esteira da tradição, o novo Código de Processo Civil prestigia a divisão entre a *jurisdição contenciosa* e a *jurisdição voluntária*, notadamente quando distingue entre procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e procedimentos especiais de jurisdição voluntária. No passado, semelhante separação visava a distinguir atividades efetivamente jurisdicionais desenvolvidas pelo Poder Judiciário de atividades meramente administrativas atribuídas à jurisdição.¹¹²

A distinção nos termos em que posta na doutrina clássica não tem qualquer razão de ser atualmente. Na jurisdição voluntária há interpretação e aplicação do Direito e há oferta de decisões revestidas de autoridade institucional, isto é, dotadas de definitividade e irrevisibilidade, tanto quanto na jurisdição contenciosa. Do ponto de vista prático, a distinção serve apenas para apontar que nos casos de jurisdição contenciosa existe um *conflito entre as partes* que deve ser resolvido pela jurisdição, ao passo que nos casos de jurisdição voluntária inexistia qualquer conflito, havendo *consenso entre as partes* a respeito da tutela jurisdicional postulada.¹¹³

2.29. Conclusões acerca da concepção contemporânea de jurisdição. Diante da transformação da concepção de direito, não há mais como sustentar as antigas teorias da jurisdição, que reservavam ao juiz a função de declarar o direito ou de criar a norma individual, submetidas que eram ao princípio da supremacia da lei e ao positivismo acrítico.¹¹⁴ A cabal superação da suposição de que a norma jurídica é sempre anterior à interpretação – sendo o seu objeto – enterrou em termos teóricos as teorias da jurisdição como declaração da vontade concreta da lei ou como justa composição da lide.

O Estado constitucional inverteu os papéis da lei e da Constituição, deixando claro que a legislação deve ser compreendida a partir dos princípios constitucionais de justiça e dos direitos fundamentais. Expressão concreta disso são os deveres de o juiz interpretar a lei de acordo com a Constituição, de controlar a constitucionalidade da lei, especialmente atribuindo-lhe adequado sentido para evitar a declaração de inconstitucionalidade, e de suprir a omissão legal que impede a proteção de um direito fundamental. Isso para não falar do dever, também atribuído à jurisdição pelo constitucionalismo contemporâneo, de tutelar os direitos fundamentais que se chocam no caso concreto e de superar metodicamente regras gerais que desprezam sobremaneira as particularidades do caso concreto.

Mas se o juiz, ao cumprir tais funções, fica muito longe das ideias de declaração da lei e de criação da norma individual a partir da norma geral, isso não quer dizer que passou a ter o poder de criar o direito. O juiz está sujeito às normas constitucionais e, conquanto possa conformar a lei e a legislação ou mesmo tutelar os direitos que colidem no caso concreto e excepcionalmente superar regras jurídicas, a sua atividade não implica *criação do direito*. A jurisdição no Estado Constitucional, embora não seja *descritiva* de uma norma jurídica, não é *criativa* de normas jurídicas – a jurisdição implica atividade de *reconstrução interpretativa* mediante um *processo estruturalmente guiado pela argumentação jurídica*. É uma atividade que conta necessariamente com a colaboração da Constituição e da legislação para ser legítima, não criando *ex novo* normas jurídicas.

Porém, quando se compreende a distinção entre *texto* e *norma*, vendo-se essa última como o *resultado* da interpretação do texto legal (portanto, não mais como seu *objeto*), torna-se fácil atribuir ao juiz a missão de reconstruir a norma jurídica que espelha a compreensão da lei na medida das normas constitucionais – ou mesmo, na hipótese específica de tutela de direitos fundamentais colidentes, a razão jurídica determinante, diante do caso concreto, da prioridade de um direito fundamental sobre o outro.

Contudo, dizer que a jurisdição objetiva apenas *declarar* os valores constitucionais normatizados, não permite abarcar toda a complexidade da função jurisdicional. Isso porque, ainda que o juiz tenha como parâmetro as normas constitucionais, cabe-lhe, antes de tudo, dar tutela concreta ao direito material. Tanto é verdade que lhe incumbe atribuir sentido aos textos jurídicos e ao caso, definindo as suas necessidades concretas, para então buscar no sistema jurídico a regulação da situação que lhe foi apresentada, ainda que tudo isso obviamente deva ser feito sempre a partir da Constituição.¹¹⁵ Nada disso pode ser caracterizado como simples

declaração.

A importância da perspectiva de direito material fica ainda mais nítida quando se percebe que a função do juiz não é apenas a de *editar a norma jurídica*, mas sim a de *tutelar concretamente* o direito material, se necessário mediante meios de execução.

O direito fundamental à tutela jurisdicional, além de ter como corolário o direito ao meio executivo adequado, exige que os procedimentos e a técnica processual *sejam estruturados pelo legislador* segundo as necessidades do direito material e *compreendidos pelo juiz* de acordo com o modo como essas necessidades se revelam no caso concreto.

Note-se que os direitos fundamentais materiais, além de servirem para iluminar a compreensão do juiz sobre o direito material, conferem à jurisdição o dever de protegê-los (ainda que o legislador tenha se omitido), ao mesmo tempo em que o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva incide *sobre a atuação do juiz como diretor do processo*, outorgando-lhe o dever de extrair das normas processuais a potencialidade necessária para dar efetividade a *qualquer direito material* (e não apenas aos direitos fundamentais materiais) e, ainda, a obrigação de suprir as lacunas que impedem que a tutela jurisdicional seja prestada de modo efetivo a *qualquer espécie de direito*.

O juiz tem o dever de utilizar o procedimento e a técnica idônea à efetiva tutela do direito material. Por isso deve interpretar a norma processual de acordo, tratá-la com base nas técnicas da interpretação conforme e da declaração parcial de nulidade sem redução de texto ou suprir a omissão legal que, ao inviabilizar a tutela das necessidades concretas, impede a realização do direito fundamental à tutela jurisdicional.

Porém, diante da maior subjetividade outorgada ao magistrado para a tutela dos direitos – natural a uma lógica que faz as normas constitucionais preponderarem sobre a legislação e a uma compreensão metodológica do Direito que parte da separação entre texto e norma – e da impossibilidade de se encontrar uma teoria capaz de sustentar a existência de uma decisão correta para cada caso concreto, é preciso atribuir ao juiz o dever de demonstrar que a sua decisão é a melhor possível mediante uma argumentação fundada em critérios racionais. Em primeiro lugar, isso deve ser feito a partir da justificação da atividade interpretativa e da coerência e universabilidade de seu resultado. Em segundo lugar, isso deve ser promovido mediante o respeito à autoridade dos precedentes das Cortes Supremas, rigorosamente meio que assegura a universabilidade das decisões, preservando-se daí a liberdade e o respeito à igualdade mediante a outorga de segurança jurídica, sem o que não há Estado de Direito.

Não há dúvida de que a jurisdição, atualmente, tem a função de tutelar (ou proteger) os direitos, especialmente os direitos fundamentais. Porém, isso não quer dizer, como é óbvio, que a jurisdição não se preocupe em garantir a idoneidade da defesa ou a adequada participação do réu. *O que se deseja evidenciar é que a função jurisdicional de tutela dos direitos é uma consequência natural do dever estatal de proteger os direitos, o qual constitui a essência do Estado Constitucional.*¹¹⁶ O exercício dessa função abarca a tutela dos direitos fundamentais e viabiliza a participação do povo na reivindicação dos direitos transindividuais e na correção dos desvios na gestão da coisa pública, além de garantir a razão de ser do ordenamento jurídico, dos direitos e das suas próprias formas de tutela ou proteção.

Quando se diz que a jurisdição tem o fim de dar tutela aos direitos se está muito longe das antigas concepções privatistas, próprias do século XIX, especialmente do conceito de direito subjetivo, característico ao espírito dessa época e desenvolvido particularmente por Windscheid. Ao escrever *A ação do direito romano do ponto de vista do direito civil*,¹¹⁷ inaugurando a célebre polêmica sobre a ação que travou com Muther, Windscheid apresentou as linhas de uma nova concepção de direito subjetivo, caracterizado pelo poder (do sujeito ativo) de exigir uma conduta e pelo dever (do sujeito passivo) de prestá-la. Esse conceito de direito subjetivo, como não poderia deixar de ser – diante da evidente relatividade histórica das doutrinas jurídicas –, recebeu forte influência do princípio da autonomia da vontade, sabidamente a base de todo o sistema individualista que marcou o século XIX.¹¹⁸

O dever de proteção ou de tutela dos direitos, que identifica o Estado constitucional, nada tem a ver com a noção clássica de direito subjetivo. O Estado possui o dever de tutelar determinados direitos, mediante normas e atividades fático-administrativas, em razão da sua *relevância social e jurídica*. Trata-se do dever de tutelar os direitos fundamentais. Mas não é só. O Estado também tem o dever de tutelar *jurisdicionalmente* os direitos fundamentais, inclusive suprindo eventuais omissões de tutela *normativa*, além de ter o dever de dar tutela *jurisdicional* a toda e qualquer espécie de direito – em razão do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva (art. 5.º, XXXV, CF).

Assim, por exemplo, o Estado tem o dever de tutelar, através de normas e atividades fático-administrativas, o meio ambiente. Contudo, também tem o dever de dar-lhe tutela *jurisdicional*, conforme as necessidades derivadas da situação concreta. Isso porque determinada situação concreta pode demonstrar a necessidade de tutela jurisdicional inibitória, outra de tutela jurisdicional ressarcitória na forma específica, e assim por diante. *O Estado tem o dever de prestar a tutela jurisdicional prometida pelos direitos – transindividuais ou individuais.*

Em face de uma situação de direito material, o cidadão – ou mesmo o Estado – assume uma posição jurídica, da qual decorre um complexo de direitos e deveres. Do mesmo modo que, na sociedade comercial, o sócio assume direitos e deveres, o empresário, diante de sua atividade e das normas de proteção ao meio ambiente, fica encarregado de observar uma série de deveres. Mas não basta atentar para a obviedade de que de uma posição jurídica decorrem direitos e deveres. *Mais importante do que isso é perceber que toda posição jurídica deve ser devidamente protegida ou tutelada.* Nesse sentido é correto falar em posição juridicamente protegida. Uma posição jurídica é protegida quando tem ao seu dispor formas de tutela dos direitos, especialmente formas de tutela jurisdicional.

Os empresários, em razão das normas relativas à concorrência, obviamente têm direitos e deveres. Porém, caso um pratique atos de concorrência desleal diante do outro, surge para o lesado o direito à tutela jurisdicional capaz de impedir a reiteração dos atos praticados. O empresário X tem direito à tutela jurisdicional do seu direito não porque tem um *poder sobre a conduta* do empresário Y, mas porque *é titular de uma posição jurídica que lhe dá o direito de obter a tutela jurisdicional do seu direito*. E nesse caso se está falando de um *direito à tutela que decorre do próprio direito material*. Se o direito material deve ser protegido ou tutelado, *é dele que deflui o direito à sua tutela*. A jurisdição aí entra apenas para viabilizar o exercício do direito à tutela do direito. Como a tutela do direito material não pode ser buscada privadamente, ela é postulada jurisdicionalmente, através do exercício da ação. É nessa dimensão que se afirma que o Estado tem o dever de dar tutela jurisdicional aos direitos. A jurisdição tem o dever de prestar a tutela prometida pelo direito material. Ou melhor: *a jurisdição tem o dever de prestar ao cidadão a tutela que decorre da sua posição jurídica*. Essa tutela jurisdicional tem de ser necessariamente adequada, pois toda posição jurídica deve ser devidamente protegida.

Como se vê, o direito à tutela jurisdicional do direito não pode ser equiparado com a noção clássica de direito subjetivo.¹¹⁹ Nenhum particular tem poder para vincular a outro com essa mesma intensidade. O direito à tutela do direito não resulta de um vínculo estabelecido entre sujeitos, em que um deles pode exigir do outro certa prestação, mas da existência de uma posição jurídica protegida. Ademais, o Estado tem o dever de tutelar os direitos em razão do seu poder, assim como o juiz possui deveres porque exerce poder jurisdicional. Nada disso deriva de poderes dos sujeitos ou das partes. Por isso mesmo, a tese de que a jurisdição tem a função de tutelar os direitos está a quilômetros de distância da antiga ideia de jurisdição como função voltada à tutela dos direitos subjetivos privados violados.

Por outro lado, é preciso deixar claro que a jurisdição cumpre a sua função mesmo que o direito material não seja reconhecido ao final do processo. Ainda que nesse caso não exista tutela do direito material, é inegável que a jurisdição é sempre exercida com o objetivo de proteger os direitos. A jurisdição atua em nome da tutela dos direitos mesmo quando o direito material não é reconhecido.

Do mesmo modo que se dizia que a jurisdição tinha a função de atuar a vontade concreta da lei,

e não se negava o seu exercício ainda que o direito material não fosse reconhecido, entende-se, em face do Estado constitucional, que a jurisdição tem a função de dar tutela aos direitos, mesmo que o direito material não seja demonstrado. A diferença básica é a de que, na nova concepção de jurisdição, a lei é atuada em uma dimensão *mais profunda, complexa e sofisticada*, e com a meta de permitir a tutela ou a proteção dos direitos, a qual decorre de uma *posição jurídica* e é devida pelo Estado *a partir do direito material* – note-se bem.

Embora seja conhecido o *slogan* chiovendiano, no sentido de que o processo deve dar a quem tem um direito tudo aquilo e exatamente aquilo que tem o “direito de obter”, esse “direito de obter” nunca foi relacionado com uma posição jurídica e, muito menos, com uma posição juridicamente protegida e com o dever estatal de prestar as tutelas dos direitos, mas apenas com aquilo que o autor teria o “direito de exigir” do réu. Ou seja, *a frase de Chiovenda é intimamente ligada ao conceito clássico de direito subjetivo, sendo completamente distante, nessa perspectiva, da concepção de jurisdição aqui proposta.*

Além disso, embora tal frase realce a necessidade de se dar “*exatamente aquilo*”, o próprio Chiovenda admite expressamente, nas suas *Instituições*, que o direito material pode deixar de ser efetivamente tutelado por ausência ou inadequação de técnica processual. Ele confessa: “Se, por sua natureza ou por falta de meios de sub-rogação, não se pode conseguir um bem senão com a execução por via coativa, e os meios de coação *não estão autorizados na lei*, aquele bem *não é conseguível no processo*, salvo a atuação (se possível, por sua vez) da vontade concreta de lei que deriva da lesão ou inadimplemento do direito a uma prestação; salvo, por exemplo, o direito ao ressarcimento do dano”.¹²⁰

Como é fácil perceber, a concepção chiovendiana de jurisdição é bastante diferente daquela que está sendo defendida neste momento, uma vez que Chiovenda admite, de maneira clara e inescandível, que a tutela específica do direito material pode ser transformada em tutela ressarcitória pelo equivalente quando meios executivos necessários e adequados não estiverem “*autorizados na lei*”. Essa forma de compreender a jurisdição dá maior valor à técnica processual do que ao direito material, permitindo a conclusão de que o processo é o único responsável pelas tutelas que devem ser dadas aos direitos.

Ora, *aqui se propõe exatamente o contrário, ou seja, a ideia de que as tutelas dos direitos derivam das posições jurídicas e não do processo.* O processo se apresenta aí como algo que *necessariamente* deve viabilizar a tutela *autorizada e prometida pelo direito material*. Nessa perspectiva, como amplamente demonstrado nos itens que estão acima, não há como admitir que a técnica processual possa ser incapaz de permitir a tutela do direito. Na ausência de técnica processual adequada, o juiz deve suprir a omissão da legislação processual com base no direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. De outra forma teria que se aceitar, conforme fez Chiovenda, que uma tutela prometida pelo direito material pode não ser “*obtenível no processo*” pela circunstância de a técnica processual idônea não estar “*autorizada na lei*”. E aí seria necessário concluir que a *falta de lei* pode negar ao juiz a técnica processual capaz de lhe permitir o *exercício da jurisdição* e, além disso, desconsiderar o *direito fundamental* de ação ou à tutela jurisdicional efetiva, o qual é um direito essencial para a proteção de todos os demais direitos, inclusive os fundamentais.¹²¹

Na realidade, essa última distinção entre as concepções de jurisdição está centrada na premissa de que a lei, no Estado contemporâneo, tem a sua substância condicionada aos princípios constitucionais de justiça e aos direitos fundamentais, o que significa uma inversão da lógica de que os direitos fundamentais dependem da lei e uma reação ao princípio que afirma a sua supremacia, próprio à época em que a teoria chiovendiana foi estruturada.

Quando se afirma que a jurisdição tem o dever de tutelar os direitos se quer dizer que a jurisdição tem o dever de aplicar a lei na dimensão dos *direitos fundamentais*, fazendo sempre o *resgate dos valores substanciais neles contidos*. Tutelar os direitos, em outros termos, é aplicar a lei, diante das situações concretas, a partir dos *direitos fundamentais*. É o atuar a lei na medida das normas constitucionais e dos valores nelas encerrados. Há aí um nítido *plus* em relação à teoria chiovendiana e uma intenção que nem sequer passava pela cabeça dos antigos doutrinadores que viam na jurisdição uma função voltada à tutela dos direitos subjetivos privados violados.

Ao se dizer que a jurisdição tem o dever de tutelar os direitos, deseja-se igualmente pôr às claras que ela tem o dever de viabilizar as tutelas prometidas pelo direito material e pela Constituição. Em termos concretos, *o que se deseja evitar é que a inidoneidade técnica do processo ou a falta de compreensão constitucional do juiz impeçam a efetiva proteção das diferentes necessidades do direito material – como, por exemplo, a tutela preventiva (a tutela inibitória)* ¹²² *de um direito da personalidade.*

Porém, mais uma vez é preciso descer a esclarecimentos que beiram à superfície para impedir que alguém caia no erro de imaginar que a concepção de jurisdição ora proposta confunde as ideias de tutela dos direitos e de tutela jurisdicional. É pouco mais do que evidente que os conceitos de dever estatal de tutela e de tutela dos direitos *se destinam a fundamentar o que se entende por tutela jurisdicional no Estado constitucional.* Os dois primeiros conceitos são fundantes do último, na medida em que servem para demonstrar que o legislador e o juiz estão submetidos, no Estado constitucional, ao dever estatal de tutela dos direitos e ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, e, assim, *que o conceito de tutela jurisdicional tem o seu conteúdo nitidamente influenciado pelos conceitos de dever estatal de proteção e de tutela dos direitos.*

É óbvio que o conceito de tutela dos direitos deita raízes no plano do direito material. Jamais se pretendeu sustentar – nem se poderia – o inverso. Acontece que, na decisão jurisdicional, há uma inquestionável integração e complementação entre os planos do direito material e do direito processual, mediante a visualização das necessidades do direito material a partir da Constituição. Portanto, o que se insiste em propor é a ideia de que a estrutura técnica do processo e a função jurisdicional devem viabilizar as tutelas prometidas pelo direito material. Trata-se, para se dar a última palavra, de costurar os planos do processo e do direito material mediante as linhas da Constituição e dos direitos fundamentais, utilizando-se especialmente o instrumento conceitual das “tutelas dos direitos”, e sem evidentemente negar que a jurisdição faz a integração entre as esferas material e processual.

3. As teorias da ação e a posição do Código de 2015. O Código Buzaid, como é amplamente sabido, partia do pressuposto de que a ação constituía direito a um processo e a um julgamento do mérito. Só teria direito de ação, ainda, quem preenchesse as suas condições – legitimidade para a causa, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido. O Código de 2015 não abraça essa teorização. Para o legislador, ter direito de ação significa ter direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva mediante processo justo. A sua existência, de outro lado, não pressupõe o preenchimento de quaisquer condições. Embora o Código de 2015 permaneça falando em legitimidade e interesse (arts. 17 e 485, VI, CPC), fá-lo apenas para qualificá-los como requisitos para a análise do mérito da causa.

Para bem compreender esse debate – e a tomada de posição do Código de 2015 a respeito – é preciso situar a sua evolução histórica, bem como os seus principais personagens. É tão somente a partir daí que se poderá compreender o significado do direito de ação a partir do qual o Código de 2015 deve ser interpretado.

3.1. A época em que a ação se confundia com o direito material. Sempre houve muita polêmica a respeito da ação. Várias são as teorias que, ao longo da história e dos diferentes ordenamentos jurídicos, tentaram explicá-la. Todas foram tocadas pelas características do ordenamento jurídico, dos valores do Estado e da cultura em que foram concebidas.

Deixe-se claro, em primeiro lugar, que a ação é a contrapartida natural da proibição da tutela privada, ou seja, é o instrumento de que o particular passou a fazer uso diante da eliminação da *justiça de mão própria.*

Quando ainda não havia separação científica entre direito material e direito processual, a ação era envolta na mesma massa do direito material. Até meados dos Oitocentos não se vislumbrava a possibilidade de a ação ser colocada em um plano distinto do plano do direito material.

A doutrina recorria a conhecidas distinções romanistas, como a de Celso, que dizia que “a ação nada mais é que do que o direito de alguém perseguir em juízo o que lhe é devido” (*actio autem*

nihil aliud est quam ius persequendi in iudicio quod sibi debetur). Na Itália e na França a doutrina admitia a perfeição do ditado de Celso, limitando-se alguns a colocar o dedo sobre a expressão “o que lhe é devido” (*quod sibi debetur*) para advertir a necessidade da sua complementação com “ou o que é seu” (*vel quod suum est*). A finalidade desse acréscimo era explicitar que “a ação não é apenas o direito de alguém de perseguir em juízo o que lhe é devido, *mas também o que é seu*”, deixando claro que a definição também abrangia os direitos reais¹²³ e não apenas os direitos obrigacionais ou prestacionais.

Nessa época, alguns doutrinadores viam a ação como uma face do direito material ou como o direito material violado em estado de reação,¹²⁴ enquanto outros a explicavam como um direito novo, derivado da violação do direito material, tendo por conteúdo uma obrigação do adversário de fazê-la cessar. Esse *direito novo* era concebido como um direito que, nascendo da violação do direito material, deveria ser exercido contra o violador e assim estava muito longe de constituir um direito autônomo em relação ao direito material. Por isso, a conformação desse *direito novo*, uma vez que tinha por conteúdo uma obrigação do sujeito passivo do direito material, foi acusada de ser uma inútil duplicação do próprio conceito de direito.¹²⁵

Porém, embora a doutrina, ao aludir à definição de Celso, tenha admitido a indistinção da ação frente ao direito material, leu essa definição grifando a relação entre *nada mais é* (*nihil aliud est*) e *perseguir em juízo* (*persequendi in iudicio*), daí retirando a consequência de que a *ação moderna*, ao contrário da antiga ação privada – derivada da força privada –, *nada mais é* do que o direito de *perseguir em juízo*. Ou melhor: a compreensão da definição de Celso pela doutrina que não viu qualquer distinção entre a ação e o direito material ao menos permitiu o esclarecimento de que a ação privada não mais existia, e então *nada mais era* do que o direito de perseguir o direito por intermédio do juiz.¹²⁶

3.2. A polêmica entre Windscheid e Muther. Quando Windscheid publicou na Alemanha o trabalho intitulado *A ação do direito civil romano do ponto de vista do direito moderno*, no ano de 1856,¹²⁷ o estado da doutrina acerca da ação era exatamente o referido no item anterior.

Porém, ao contrário do que acontecia na Itália e na França, na Alemanha não importava apenas a *actio* romana, mas também a *Klage* ou *Klagerecht*, que pode ser compreendida como direito de queixa ou direito de ação. A *actio* e a *Klage*, embora ligadas à busca da realização do direito por intermédio do juiz, permitiam diferenciação, pois a *actio* era voltada contra o obrigado e a *Klage* se dirigia contra o Estado.¹²⁸

Savigny, ainda que sem desvincular o direito material do direito de ação, via esse último (*Klagerecht*) como o direito à tutela judicial nascido da lesão de um direito material, compreendendo-o como o direito no qual o direito material se transforma ao ser lesado. Para Savigny o direito de ação era um direito resultante da *transformação* pela qual o direito material passaria após ter sido lesado. Daí o motivo pelo qual propôs o conceito de “metamorfose” para ilustrar tal situação.¹²⁹

Ou seja, mesmo que admitisse a *Klage*, a doutrina anterior à polêmica entre Windscheid e Muther não vislumbrava qualquer separação entre a ação e o direito material.¹³⁰

Windscheid, após argumentar que o direito romano não dizia que alguém tinha um direito, mas sim que alguém possuía uma *actio* – ou seja, que a *actio* romana não era um meio de defesa de um direito, mas sim o próprio direito –, afirma que a *actio* nada mais era do que o direito subjetivo é no direito moderno. Não era um novo direito que surgia em razão da violação e estava muito longe de constituir um direito de agir ou um direito de se queixar dirigido contra o Estado (o *Klagerecht*). A *actio*, no seu entender, era a faculdade de realizar a própria vontade através de uma *persecução em juízo*.¹³¹ Por outro lado, o *Klagerecht* seria um conceito criado pelos juristas sem qualquer consistência no direito romano e no direito moderno.¹³²

Porém, ao se voltar aos direitos reais, Windscheid faz um ajuste em relação à premissa de que a *actio*, para os romanos, entrava no lugar do direito, concluindo que a *actio* não coincidia com o direito real. A *actio* – diz ele – é expressão do direito de crédito, pressupondo um obrigado

determinado; portanto, tinha relação com aquilo que A pode exigir de B.¹³³

Afirmou Windscheid que o que nasce da violação do direito de propriedade não é um direito de agir, mas, por exemplo, o direito à restituição da coisa contra o possuidor, e que essa obrigação, como qualquer outra, somente abre oportunidade para um agir enquanto não satisfeita. Isso significa que a *actio* não nascia da ofensa, pois a violação da propriedade fazia surgir um direito obrigacional, cujo não cumprimento é que dava origem à ação.¹³⁴

Segundo Windscheid, se alguém exige que outra pessoa o reconheça como proprietário, ou que reconheça a existência de alguma outra relação de direito ou de fato, está lhe exigindo algo, e, na medida em que se lhe concede tutela judicial para obter o que exige, lhe é atribuída a *actio*. Diz Windscheid: “*Actio es la persecución judicial, pudiendo concebírsela tanto por el lado de su existencia efectiva, como por el lado de su realización potencial, ínsita en las facultades de la respectiva persona. En este segundo caso los romanos dicen en su lenguaje lo mismo que nosotros cuando atribuimos a alguien una pretensión; mas por ello no dejan de referirse a la persecución judicial*”.¹³⁵

Portanto, *actio* era o termo para designar o que se podia exigir de outro; “para caracterizar esto en forma breve, podemos decir atinadamente que *actio* es el vocablo para designar la pretensión”.¹³⁶

Windscheid concluiu que a pretensão é o equivalente moderno da *actio*, delineando-a como uma situação jurídica substancial, distinta tanto do direito de se queixar em juízo quanto do próprio direito subjetivo, do qual é uma emanação que funda a possibilidade de o autor exigir a realização judicial do seu direito.¹³⁷

O trabalho de Muther (Sobre la doctrina de la *actio* romana, del derecho de accionar actual, de la *litiscontestatio* y de la sucesión singular en las obligaciones),¹³⁸ embora crítico – e às vezes muito rigoroso e até mesmo deselegante – em relação à obra de Windscheid, não foi capaz de apagar a importância das teses nela formuladas, embora tenha permitido o enfrentamento de outras questões, relacionadas à obra que lhe serviu de objeto de crítica, também relevantes para o desenvolvimento da teoria da ação.¹³⁹

Muther sustentou a ideia de um direito de agir contra o Estado – na pessoa dos seus órgãos jurisdicionais –, e também que a própria *actio* seria um direito do autor para que o pretor lhe outorgasse a “fórmula” – que constituía, na sua época, a tutela jurídica.¹⁴⁰

Diversamente de Windscheid, que partiu da ideia de que a ordenação romana não era – como é a moderna – uma ordenação de direitos, mas sim uma ordenação de pretensões que podem ser *perseguidas judicialmente*, Muther argumentou que a ordenação romana era de direitos, dizendo que aquele que pedia a fórmula ao pretor também devia ter um direito subjetivo, o qual, no seu raciocínio, seria o próprio fundamento do direito à fórmula.¹⁴¹

Afirmou Muther que o direito à concessão da fórmula nasce de um “direito originário”, e que, enquanto o obrigado perante o “direito originário” é o particular, o obrigado diante do direito à fórmula somente pode ser o pretor ou o Estado. Existiriam, portanto, dois direitos, sendo o direito privado o pressuposto do direito contra o Estado; os dois direitos coexistiriam, ainda que o direito contra o Estado existisse para proteger o direito privado.¹⁴²

De acordo com Muther, desde o direito romano se podia conceber que, ligado a um “direito originário”, havia um direito contra o Estado, de modo que também no direito moderno, diante da ideia de *Klagerecht*, existiria um direito de agir autônomo em relação ao direito originário, ainda que a ele vinculado.¹⁴³

Esse direito de agir, além de gerar ao Estado o dever de prestar a tutela ao autor, fundaria o direito de o Estado exercer contra o réu a coação necessária para alcançar o cumprimento da sua obrigação. O direito de agir se destina a fazer com o que o Estado exerça o seu direito contra o obrigado e, por mais essa razão, tem uma clara ligação com o direito material do autor contra o

réu.¹⁴⁴

Para Muther, o direito de agir, embora não se confundindo com o direito material, tem ele como pressuposto. Assim, a sua construção, ainda que isolando o direito de agir do direito material, tem uma base de direito privado.¹⁴⁵

Contudo, as ponderações de Muther foram aceitas, ainda que em parte, por Windscheid, levando-o a admitir a existência de uma ação processual ao lado da pretensão de direito material. Embora deixando claro que a existência de uma ação dirigida contra o Estado, tal como delineada por Muther, não infirmava a tese de que a *actio* romana estava no plano do direito privado – e, por isso mesmo, no direito moderno deveria ser vista como uma pretensão de direito material –, Windscheid acabou concluindo que a categoria da pretensão de direito material convive, no direito moderno, com o que ele denominou de “direito à tutela do Estado”.¹⁴⁶

Como se vê, um dos importantes frutos da polêmica foi o de demonstrar a separação entre os planos do direito material e do direito processual, deixando para trás a antiga concepção que unia o direito material e a ação.

3.3. O direito de agir abstrato. Firmada a autonomia do direito de agir em relação ao direito material, alguns juristas passaram a pensar sobre a situação do autor que, movimentando o juízo, chega a uma sentença que nega a existência do direito material. Plósz¹⁴⁷ e Degenkolb¹⁴⁸ entenderam que o direito de agir não excluiu a possibilidade de uma sentença desfavorável, que então restou qualificado por Plósz como “direito abstrato”. Para esses juristas, o direito de agir é, além de autônomo, independente do reconhecimento do direito material.¹⁴⁹

Degenkolb argumenta que é necessário construir uma base teórica para a ação favorável e para a ação desfavorável. Diz que, em face de qualquer conflito, um dos litigantes tem o poder de levar o outro para diante do juiz e, assim, que o réu tem a obrigação de participar do processo. O que obriga o réu a participar do processo é o direito de agir, que nada tem a ver com o direito material. O fundamento desse direito de agir é a própria personalidade do autor, porque dessa vem a *consciência* ou a convicção subjetiva ao direito, ou mais precisamente a aspiração ao direito, o direito ao direito, em relação ao qual a efetiva existência do direito material é meramente acidental.¹⁵⁰

Plósz, de forma semelhante, entendeu que o direito abstrato de ação, ou o *Klagerecht*, exige apenas a boa-fé do autor, embora tenha sustentado a existência de dois direitos de ação, um processual, de caráter público, e outro material, identificado com a pretensão de direito material.¹⁵¹

Tais juristas sustentaram a ideia de que o direito de agir é antecedente ao seu exercício, que se daria através da demanda. Mas somente tem esse direito aquele que afirma uma lei ou aquele que, segundo o exemplo de Chiovenda, reclama a restituição de um mútuo e não o pagamento de uma dívida de jogo.¹⁵² Note-se que o autor que reclama a restituição de um mútuo se baseia na lei, ao passo que não há lei que autorize a cobrança de dívida de jogo.¹⁵³

3.4. Ainda a ação como direito abstrato. A teoria de Mortara. A teoria de Mortara¹⁵⁴ assemelha-se às de Degenkolb e Plósz. Mortara também sustenta que o direito de agir não reclama o reconhecimento da existência do direito material e, nesse ponto, coloca-se ao lado das teorias de Degenkolb e de Plósz. Porém entende que a ação se funda na mera afirmação de existência do direito e, portanto, que não é preciso dizer que a ação somente existe quando exercida conscientemente ou de boa-fé.

Mortara inicia argumentando que o direito subjetivo necessita, para ser reconhecido, da vontade do sujeito que poderia ter interesse em negá-lo. Havendo a negação por parte desse sujeito, surge a necessidade da ação e da relação jurídica processual, quando então aparecem duas pretensões, ambas aspirando à respectiva transformação em direito subjetivo.¹⁵⁵ Nenhuma dessas pretensões é direito, pois esse apenas se apresentará àquele que obtiver a sentença favorável.¹⁵⁶ Mas, para o exercício do direito de agir, basta que a realização do direito subjetivo tenha sido

obstaculizada por alguém, que então passa a ser réu. A afirmação dessa oposição é o bastante para configurar a ação.

Mortara anuncia, assim, que o direito de agir, além de nada ter a ver com o reconhecimento do direito material, dispensa a ideia de boa-fé do autor, fundando-se em uma afirmação de direito que decorre do contraste de duas posições ou da negação da vontade indispensável ao reconhecimento do direito subjetivo.

3.5. A pretensão à tutela jurídica. A teoria de Wach. Wach não acatou integralmente a tese do direito de agir contra o Estado – adotada por Plósz e Degenkolb –, construindo a teoria da pretensão à tutela jurídica (*Rechtsschutzanspruch*), que unia elementos de direito material e processual.¹⁵⁷ A pretensão à tutela jurídica voltava-se contra o Estado – obrigado a concedê-la – e contra o adversário – que deveria suportá-la.¹⁵⁸ Tal teoria parte da contribuição de Muther, que afirmou que o cidadão tem direito à tutela jurídica contra o Estado. Wach, porém, desenvolveu a sua teoria tomando em consideração especialmente a ação declaratória.¹⁵⁹

A ação declaratória, ao contrário de objetivar a realização de um direito subjetivo, tem por meta a declaração da existência ou da inexistência de uma relação jurídica. Se o autor pode propor uma ação para declarar a inexistência de uma relação jurídica, é lógico que a ação não tem como pressuposto um direito material insatisfeito. Na verdade, a ação declaratória, seja da declaração da existência ou da inexistência de uma relação jurídica, requer apenas um interesse na declaração. Isso permitiu a Wach concluir que *o direito material não é um pressuposto necessário do direito à tutela jurídica*.¹⁶⁰ Com base nessa lógica, afirmou que o réu tem direito à rejeição de uma demanda infundada e, assim, também à tutela jurídica.¹⁶¹

Mas a tutela jurídica apenas é prestada pela sentença favorável. Ela é prestada ao autor, na ação declaratória de existência e na ação declaratória de inexistência, quando a sentença reconhecer, respectivamente, a existência e a inexistência da relação jurídica, isto é, quando a sentença for de procedência, mas será prestada ao réu quando a sentença for de improcedência. Ou seja, o direito à tutela jurídica requer uma sentença favorável. Na verdade, Wach distinguia a pretensão à tutela jurídica da pretensão à sentença, sendo a primeira devida a uma das partes e a segunda a ambas. Ainda que o autor e o réu tivessem pretensão à sentença, a pretensão à tutela jurídica dependia de uma sentença favorável.¹⁶²

3.6. A ação como poder em face do adversário. A teoria de Chiovenda. Chiovenda apresentou a sua teoria da ação em *prolusione* (aula inaugural) proferida no início do século passado. Essa *prolusione*, como registra a primeira nota de rodapé do seu texto – publicado nos *Saggi di diritto processuale civile* – foi lida na Universidade de Bolonha em 3 de fevereiro de 1903.¹⁶³ O texto, intitulado *L'azione nel sistema dei diritti*,¹⁶⁴ tornou-se um dos pontos cardeais da dogmática processual civil, tendo influenciado toda uma geração de processualistas italianos e brasileiros, que ficou conhecida como chiovendiana ou pós-chiovendiana.

Trata-se, depois da teoria de Mortara, da primeira tentativa genuinamente italiana de conceber a ação. Chiovenda fez grandes elogios à teoria de Wach, declarando que essa evidenciou, melhor do que as suas antecedentes, a autonomia do direito de agir em relação ao direito material.¹⁶⁵ Mas entendeu que Wach não conseguiu demonstrar que a ação se dirige contra o Estado.

Para Chiovenda, a ação destina-se a provocar um efeito jurídico contra o adversário, derivado da sentença de procedência que faz atuar a lei.¹⁶⁶ Segundo Chiovenda, somente é investido da ação aquele cuja demanda é acolhida. Portanto, a ação é um poder em face do adversário que depende de uma *sentença favorável*, isto é, que necessita de uma sentença que declare a vontade da lei, uma vez que é dela que serão projetados efeitos jurídicos.¹⁶⁷

A ação, ao levar à atuação da lei (na hipótese de sentença de procedência) e, por consequência, fazer produzir efeitos jurídicos sobre o réu, estabelece uma relação de poder entre o autor e o réu. Ao precisar o seu conceito de ação, Chiovenda esclarece que a ação é um poder *em face* do adversário, mais do que um poder *contra* o adversário. Com isso quer dizer que a ação não exige obrigação alguma, pois o adversário, diante da ação, não é obrigado a nada, *mas apenas fica sujeito*

aos efeitos jurídicos da atuação da lei (em caso de sentença favorável).

Conclui Chiovenda que a ação é um *direito potestativo*, ou seja, um direito que não tem como conteúdo uma obrigação alheia; a ação é *um poder que sujeita o adversário*, portanto um poder *em face* do adversário.¹⁶⁸

3.7. A ação como direito de petição. A teoria de Couture. Muito tempo depois, por volta da metade dos anos 40 do século passado, a ação é apresentada como uma forma típica do direito de petição. Trata-se da teoria elaborada por Eduardo Couture, processualista uruguaio que fez merecida fama em todo o mundo. Santiago Sentis Melendo, em seu *prólogo* à 3.^a edição dos *Fundamentos del derecho procesal civil* de Couture, publicada em Buenos Aires no ano de 1958, advertiu que a edição brasileira dos *Fundamentos*, publicada em 1946, continha uma abordagem de conceitos fundamentais – como o da ação – bem distinta da realizada na 1.^a edição publicada em 1942 em Buenos Aires. O próprio Couture confessa que, na edição brasileira, o conceito de ação foi apresentado, com maior clareza, “como uma forma típica de direito constitucional de petição”, para o que teria contribuído um curso que proferiu, entre 1943 e 1944, em algumas universidades americanas.¹⁶⁹

Sustenta Couture que o direito de petição, configurado como garantia individual na maioria das Constituições escritas, e considerado pelos escritores clássicos de direito constitucional como uma expressão formal, é inseparável de toda organização em forma de Estado, e exerce-se indistintamente diante de todas e quaisquer autoridades.¹⁷⁰

Argumenta que a ação civil não difere, em sua essência, do direito de petição em relação à autoridade. O direito de petição é o gênero do qual a ação civil é a espécie. Outras espécies de direito de petição, caracterizadas por formas e modalidades especiais, são “*la apelación de ciertos actos del gobierno municipal ante el Parlamento, el contencioso administrativo, la querrela criminal, el ejercicio judicial de los derechos de rectificación y de respuesta en materia de imprenta etc. Las diferencias no pertenecen a la esencia sino a la técnica de este derecho*”.¹⁷¹

Porém – diz o saudoso jurista uruguaio –, quando o direito de petição é exercido diante do Poder Judiciário sob a forma de ação civil, esse poder jurídico não só resulta virtualmente coativo para o demandado, que tem de comparecer para se defender se não deseja sofrer as consequências prejudiciais da confissão ficta (da ausência de defesa), como também resulta coativo para o juiz, que deve obrigatoriamente se pronunciar, de uma forma ou outra.¹⁷²

Couture entende que a ação é o direito de o cidadão exigir, sobre aquilo que afirma ser seu direito, um pronunciamento do Poder Judiciário. O direito de ação não tem qualquer dependência do reconhecimento do direito material e, assim, é um direito de agir abstrato. Couture deixa claro, aliás, que a tese de que, para o exercício da ação, o autor deve supor, dotado de boa-fé, que o seu direito material foi violado (sustentada por Degenkolb e Plósz) não tem qualquer procedência, pois mesmo os que conscientemente sabem que não possuem qualquer direito têm abertas as vias de acesso à jurisdição.¹⁷³

De modo que, na teoria de Couture, o direito de ação é assegurado pela Constituição – é uma espécie de direito de petição –, gerando ao cidadão um direito de acesso à jurisdição – que nada tem a ver com o reconhecimento do direito material – e ao Estado o dever de prestar a tutela jurisdicional.

A teoria de Couture, ao apresentar o direito de ação como espécie do direito de petição, teve o intuito de frisar que a ação deve ser vista como uma garantia individual do cidadão diante do Estado.

3.8. As condições da ação. A teoria de Liebman. 1949 é o ano em que Liebman, em *prolusione* (aula inaugural) na Universidade de Turim, traça a sua teoria a respeito da ação.¹⁷⁴

Liebman também dá destaque à existência de um direito constitucional que garante que todos os cidadãos podem levar as suas pretensões ao Poder Judiciário. Refere-se ao art. 24, 1.^a parte, da

Constituição da República italiana, o qual diz que todos podem agir em juízo para a tutela dos seus direitos e interesses legítimos.¹⁷⁵

Tal garantia constitucional, segundo Liebman, é o reflexo da instituição dos tribunais pelo Estado: “eles têm a tarefa de dar justiça a quem a pedir e por isso uma das regras fundamentais do nosso ordenamento constitucional assegura a todos a possibilidade de levar-lhes a sua pretensão a obtê-la, com isso fazendo que o juiz venha a examinar o seu caso”.¹⁷⁶

Porém, esse direito de agir, garantido constitucionalmente, não se confunde com a ação, pois essa, embora se funde no direito constitucional de acesso aos tribunais (no direito de agir), em si mesma “nada tem de genérico: ao contrário, guarda relação com uma situação concreta, decorrente de uma alegada lesão a direito ou a interesse legítimo do seu titular e identifica-se por três elementos bem precisos: os sujeitos (autor e réu), a *causa petendi* (i.e., o direito ou relação jurídica indicada como fundamento do pedido) e finalmente o *petitum* (que é o concreto provimento judicial postulado para a tutela do direito lesado ou ameaçado)”.¹⁷⁷

Isso não quer dizer que a ação dependa do reconhecimento do direito material ou de uma sentença favorável. A ação constitui apenas *direito ao processo* e a um *juízo de mérito* e, portanto, é satisfeita com uma sentença favorável ou desfavorável ao autor. O que importa, para a *existência* da ação, é a *presença das suas condições*, a princípio delineadas por Liebman como legitimação para agir, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido,¹⁷⁸ e posteriormente por ele reduzidas apenas à legitimidade para agir e ao interesse.¹⁷⁹

O interesse de agir, segundo Liebman, é “um interesse processual, secundário e instrumental com relação ao interesse substancial primário; tem por objeto o provimento que se pede ao juiz como meio para obter a satisfação de um interesse primário lesado pelo comportamento da parte contrária, ou, mais genericamente, pela situação de fato objetivamente existente. Por exemplo, o interesse primário de quem se afirma credor de 100 é obter o pagamento dessa importância; o interesse de agir surgirá se o devedor não pagar no vencimento e terá por objeto a sua condenação e, depois, a execução forçada à custa do seu patrimônio. O interesse de agir decorre da necessidade de obter através do processo a proteção do interesse substancial; pressupõe, por isso, a assertiva de lesão desse interesse e a aptidão do provimento pedido a protegê-lo e satisfazê-lo. Seria uma inutilidade proceder ao exame do pedido para conceder (ou negar) o provimento postulado, quando na situação de fato apresentada não se encontrasse afirmada uma lesão ao direito ou interesse que se ostenta perante a parte contrária, ou quando os efeitos jurídicos que se esperam do provimento já tivessem sido obtidos, ou ainda quando o provimento pedido fosse em si mesmo inadequado ou inútil a remover a lesão, ou, finalmente, quando ele não pudesse ser proferido, porque não admitido pela lei (p. ex., a prisão por dívidas). Naturalmente, o reconhecimento da ocorrência do interesse de agir ainda não significa que o autor tenha razão: quer dizer apenas que o seu pedido se apresenta merecedor de exame. Ao mérito, e não ao interesse de agir, pertence toda e qualquer questão de fato e de direito relativa à procedência do pedido, ou seja, à juridicidade da proteção que se pretende para o interesse substancial. Em conclusão, o interesse de agir é representado pela relação entre a situação antijurídica denunciada e o provimento que se pede para debelá-la mediante a aplicação do direito; deve essa relação consistir na utilidade do provimento, como meio para proporcionar ao interesse lesado a proteção concedida pelo direito”.¹⁸⁰

Ao tratar da legitimação para agir, assim se expressa Liebman: “Legitimação para agir (*legitimatío ad causam*) é a titularidade (ativa e passiva) da ação. O problema da legitimação consiste em individualizar a pessoa a quem pertence o interesse de agir (e, pois, a ação) e a pessoa com referência à qual [*nei cui confronti*] ele existe (...). Também quanto à ação, prevalece o elementar princípio segundo o qual apenas o seu titular pode exercê-la; e tratando-se de direito a ser exercido necessariamente com referência a uma parte contrária, também esta deve ser precisamente a pessoa que, para os fins do provimento pedido, aparece como titular de um interesse oposto, ou seja, aquele em cuja esfera jurídica deverá produzir efeitos o provimento pedido. A legitimação, como requisito da ação, é uma condição para o pronunciamento sobre o mérito do pedido: indica, pois, para cada processo, *as justas partes*, as *partes legítimas*, isto é, as

pessoas que devem estar presentes para que o juiz possa julgar sobre determinado objeto. Entre esses dois requisitos, ou seja, a existência do interesse de agir e a sua pertinência subjetiva, o segundo é que deve ter precedência, porque só em presença dos dois interessados diretos é que o juiz pode examinar se o interesse exposto pelo autor efetivamente existe e se ele apresenta os requisitos necessários”.¹⁸¹

Liebman entende que as condições da ação são requisitos para a sua existência. Quando tais condições estão ausentes há carência da ação.¹⁸² As condições da ação “são os requisitos constitutivos da ação”, sendo que, “na sua presença, esta deve ser considerada existente, como direito a provocar o exame e a decisão do mérito; depois, essa decisão poderá ser, conforme os resultados do processo, tanto favorável como desfavorável, no sentido de que o pedido poderá ser acolhido ou rejeitado e conseqüentemente a medida postulada poderá ser concedida ou negada”.¹⁸³

Liebman tentou se colocar na metade do caminho daqueles que, de um lado, entendem que a ação depende do efetivo reconhecimento do direito material, e daqueles outros que sustentam que a ação é um direito de agir totalmente abstrato, decorrente da mera capacidade jurídica. Ou seja, a ação não depende de uma sentença favorável, mas requer a presença das condições da ação.

Liebman ainda concluiu que, quando o juiz reconhece que as condições da ação não estão presentes, e assim se nega a julgar o mérito, não há “*vero esercizio della giurisdizione*”, pois entre a ação e a jurisdição existe exata correlação, não podendo existir uma sem a outra.¹⁸⁴

Porém, a teoria de Liebman não se limitou a dizer que não há jurisdição no caso de carência de ação, mas também disse que só tem direito à tutela jurisdicional aquele que tem razão.¹⁸⁵

3.9. A posição adotada pelo Código de 2015. O Código de 2015 afirma que a ação se considera proposta com o protocolo da petição inicial (art. 312) e que uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2.º). O pedido não se confunde com a ação, constituindo simplesmente o requerimento de tutela jurisdicional do direito.

O Código de 2015 compreendeu a necessidade – por nós há muito tempo advertida – de se outorgar ao juiz poder para julgar parcela de um pedido ou um dos pedidos cumulados quando estiverem maduros para julgamento no curso de procedimento que tem que prosseguir para a elucidação de fato pertinente à outra parcela do pedido ou ao outro pedido cumulado.¹⁸⁶ Há cisão do julgamento do mérito, rompendo-se com o princípio chiovendiano da unidade e unicidade do julgamento em nome da tempestividade e efetividade da tutela jurisdicional (art. 356). Compreendeu igualmente a necessidade de a ação ser vista não simplesmente como direito a um julgamento de mérito, mas como direito à tutela adequada, efetiva e tempestiva dos direitos. Vale dizer: a propositura da ação deve dar lugar, em sendo julgado procedente o pedido, à efetiva realização do direito da parte, adotando-se as técnicas processuais necessárias e idôneas para a sua promoção (art. 497). Para prestar a tutela específica do direito, por exemplo, pode o juiz determinar as *medidas necessárias* à satisfação do demandante – mesmo que não requeridas –, o que significa, como é óbvio, que a própria parte não é vinculada à lei processual para se valer dos meios executivos hábeis a permitir a tutela efetiva do seu direito (arts. 139, IV, e 536 e ss.).

Não se fala mais em condições da ação. Há apenas advertência de que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17, CPC). Diz o art. 485, VI, CPC, que o órgão jurisdicional não resolverá o mérito em diversas hipóteses, entre essas quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Trata-se, assim, de *requisitos para a apreciação do mérito*, estando muito distante a ideia de que tais elementos poderiam ter a ver com a *existência da ação*.

A possibilidade jurídica do pedido não mais constitui categoria autônoma capaz de obstaculizar o julgamento do mérito. O Código de 2015 afastou-se da regulação das condições da ação, peculiar ao Código de 1973, que não só falava em condições da ação, mas também previa, ao lado da legitimidade para a causa e do interesse de agir, a possibilidade jurídica do pedido. Contudo, a

impossibilidade jurídica do pedido, além de rara, pode ser encartada na ausência de interesse de agir.

A legitimidade pergunta sobre a identificação entre o autor e o réu com o direito material em litígio. É legitimado ativo o titular do direito material e legitimado passivo aquele que, também no plano do direito material, contra esse direito pode se opor. Diz o art. 18, CPC, que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Quer isso dizer que ninguém pode propor ação para pedir a proteção de direito alheio, salvo em hipóteses excepcionais em que o ordenamento jurídico autoriza alguém a ir a juízo em nome de direito que não lhe pertence, como acontece quando se defere a qualquer cidadão a possibilidade de propor ação popular para a defesa do patrimônio público¹⁸⁷ ou legitimidade a um ente – como uma associação de defesa do meio ambiente ou dos consumidores – para propor ação coletiva para a proteção do meio ambiente ou de direito dos consumidores.¹⁸⁸

De outro lado, o autor tem interesse quando necessita da jurisdição para a tutela do direito. Como essa necessidade diz respeito à proteção de determinada situação concreta, é preciso que o modelo procedimental escolhido ou apresentado como apto para tutelá-la ou protegê-la seja realmente adequado a tanto. Daí a razão pela qual se diz que o interesse processual pode ser bem representado pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.

Tudo isso quer dizer que, diante do Código de 2015, é possível afirmar que o *direito de ação é direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva mediante processo justo*. Esse direito não se submete às *velhas condições* para sua existência. É um direito de natureza processual totalmente *abstrato* e *independente* da efetiva existência do direito material alegado em juízo.

3.10. Primeira apreciação crítica. O significado conceitual do debate sobre as teorias da ação. É intuitivo que a ação não se confunde com o direito material. Hoje, ao contrário do que ocorria à época em que tal confusão era feita, qualquer leigo sabe que propor uma ação não significa ter o direito que através dela se busca, pois não é difícil ouvir alguém falar que o juiz *não percebeu a existência do direito* ou que as provas *não foram produzidas* de forma a *evidenciá-lo*, embora ele fosse de fácil demonstração. De modo que a antiga ideia de que a ação e o direito material constituem uma coisa só atualmente não merece sequer cogitação.

A separação entre ação e direito material começou a ser delineada com a polêmica entre Windscheid e Muther. Windscheid concluiu que a pretensão é o equivalente moderno da *actio*, afirmando que a pretensão é distinta do direito subjetivo, do qual é uma simples emanção que confere ao autor a possibilidade de exigir a sua realização, e do próprio direito de agir contra o Estado (direito de acionar ou *Klagerecht*).¹⁸⁹

A primitiva tese de Windscheid, no sentido de que a ação é o exercício da pretensão de direito material perante o juiz, ainda que possa separar a pretensão do direito subjetivo material, mantém a ação totalmente presa ao plano do direito material, identificando-a como uma ação de direito material e não como uma ação processual.

Muther, ao se contrapor à tese de Windscheid, sustentou a existência de um direito de agir contra o Estado.¹⁹⁰ Lembre-se que Windscheid e Muther também divergiram em relação ao que ocorria no direito romano. Enquanto Windscheid entendeu que a ordenação romana era uma ordenação de pretensões que podem ser perseguidas judicialmente, Muther sustentou que a ordenação romana, assim como a moderna, era uma ordenação de direitos. É por isso que Muther disse que aquele que pedia a fórmula ao pretor também devia ter um direito subjetivo, que, no seu raciocínio, seria o próprio fundamento do direito à fórmula.¹⁹¹ De acordo com Muther, *desde o direito romano se podia conceber que, ligado ao direito privado, havia um direito contra o Estado, de modo que também no direito moderno, diante da ideia de Klagerecht, existiria um direito de agir autônomo em relação ao direito privado, ainda que a ele vinculado*.¹⁹²

Windscheid, ao contrário, partindo da premissa de que o ordenamento romano não era de

direitos, mas sim de pretensões passíveis de persecução judicial, dizia que, se alguém *exige* que outrem o reconheça como proprietário, ou reconheça a existência de alguma outra relação de direito ou de fato, está *exigindo-lhe* algo e, na medida em que se lhe concede *tutela judicial para obter o que exige*, lhe é atribuída a *actio*,¹⁹³ que deveria ser compreendida, no direito moderno como a exigência judicial da realização de um direito.

Segundo Muther, o direito à concessão da fórmula nasce de um “direito originário”, mas, enquanto o obrigado perante o “direito originário” é o particular, o obrigado diante do direito à fórmula somente pode ser o pretor ou o Estado. Na concepção de Muther, portanto, existem nitidamente dois direitos: o direito material e o direito de agir contra o Estado.¹⁹⁴

Esse direito de agir, de acordo com Muther, dá ao Estado o direito de exercer contra o réu a coação necessária para alcançar o cumprimento da sua obrigação diante do autor. Isso revela de modo bastante claro que, embora Muther tenha delineado um direito de agir contra o Estado, esse direito restou absolutamente vinculado à realização do direito material. Isso para não falar no equívoco de se supor que o Estado tem um direito contra o réu criado pelo direito de agir do autor.¹⁹⁵

Porém, alguns argumentos de Muther foram aceitos por Windscheid, que acabou admitindo uma ação processual ao lado da pretensão de direito material. Windscheid, após a obra de Muther, afirmou a existência de um “direito à tutela do Estado”, que se colocaria ao lado da pretensão de direito material.¹⁹⁶

De modo que a polêmica foi muito importante para evidenciar a separação entre os planos do direito material e do direito processual.¹⁹⁷

As teorias de Degenkolb e Plósz, arquitetadas cerca de 20 anos mais tarde, pretenderam elaborar uma base para justificar as ações que levam não apenas a sentenças favoráveis, como também a sentenças desfavoráveis ao autor. Tanto Degenkolb quanto Plósz partiram da premissa de que o direito de agir não exclui a possibilidade de uma sentença desfavorável e, com base nesse argumento, Plósz concluiu que esse direito de agir seria um direito não somente “autônomo”, mas também “abstrato”.

Esses juristas, para explicarem a possibilidade de alguém ter direito de agir contra o Estado ainda que sem direito material, recorrem às ideias de boa-fé e de consciência da existência do direito, para com isso se livrarem da acusação de que estariam criando um direito sem conteúdo e limites.

Essas duas teorias, ao se preocuparem com a boa-fé, ainda vinculam a ação com o direito material. É que o direito de ação não tem qualquer relação com o fato de a afirmação da existência do direito ser de boa ou de má-fé. Tal qualidade apenas poderia ter ligação com a responsabilidade pelo exercício da ação – e isso se fosse possível detectar quando o autor exerce a ação de má-fé ou com a consciência de que não possui direito.

Por essa razão, é possível dizer que a teoria de Mortara é mais consentânea com a própria ideia de um direito abstrato, pois desvincula completamente o direito de agir do direito material, baseando-o apenas na afirmação (ou na opinião) da existência do direito material, no que mais tarde foi seguido por Couture, que argumentou que, mesmo os que conscientemente sabem que não possuem qualquer direito material, têm abertas as vias de acesso à jurisdição.¹⁹⁸

Aliás, é importante destacar que a doutrina de Mortara¹⁹⁹ é reconhecida no direito italiano como precursora dos estudos publicistas do processo, tendo Chiovenda chegado a afirmar que Mortara teve o grande mérito de ter colocado o processo civil na sua justa luz de instituto de direito público, o qual foi o ponto de partida para os posteriores desenvolvimentos da doutrina processual civil italiana.²⁰⁰

As teorias de Degenkolb, Plósz e Mortara são ligadas às concepções de direito e de jurisdição das suas épocas e, assim, tiveram apenas o cuidado dogmático de separar a ação do direito

material, demonstrando que, ao lado da relação de direito material, existe uma relação de direito público. Sublinhe-se que Degenkolb e Plósz disseram expressamente que somente tem direito de agir aquele que afirma uma lei, enquanto Mortara ligou nitidamente o direito de agir à estrutura dos direitos subjetivos, o que demonstra que tais teorias – como, aliás, não poderia ser diferente – estavam subordinadas aos valores do Estado legislativo.

Wach elaborou a teoria da pretensão à tutela jurídica, o qual se dirige contra o Estado – obrigado à sua concessão – e contra o adversário – obrigado a suportar os efeitos da tutela jurídica estatal. Mas Wach demonstrou que o direito material não é um pressuposto necessário do direito à tutela jurídica, como deixam claro as ações declaratórias de existência e de inexistência de relação jurídica, nas quais não se pede a satisfação de um direito subjetivo, exigindo-se apenas um interesse na declaração. Aliás, para Wach o próprio réu tem direito à tutela jurídica.

Porém, o direito à tutela jurídica, no raciocínio de Wach, significa direito à sentença favorável ou à execução ou à cautela, todos representando atos de proteção jurídica. Ou seja, o autor ou o réu que não obtivesse sentença favorável não seria digno de tutela jurídica. A teoria de Wach, embora frise a necessidade de o Estado dar proteção ao cidadão, demonstrando que o direito a essa proteção em muitos casos nada tem a ver com o direito material, vincula tal proteção a um ato de proteção concreta, como a sentença favorável, a execução e a cautela.

Wach distinguiu a pretensão à tutela jurídica da pretensão à sentença, sendo a primeira devida à parte que tem direito material e a segunda a ambas. Ainda que o autor e o réu tivessem pretensão à sentença, a pretensão à tutela jurídica dependia de uma sentença favorável. Mas, ao afirmar que só a sentença favorável seria capaz de outorgar tutela jurídica, Wach parece ter negado importância ao direito à obtenção da sentença e ao significado da atividade estatal, que, mesmo sem reconhecer o direito material, dá uma resposta à parte. Isso significa que a pretensão à tutela jurídica, na concepção de Wach, não tinha a dimensão de um direito à tutela jurisdicional, que também é concedida a quem não consegue demonstrar que tem direito a uma sentença favorável.

Chiovenda, contrapondo-se a Wach, disse que a ação, mais do que provocar o Estado à prestação da tutela jurídica, constitui um poder em face do réu. Segundo Chiovenda, a ação requer uma sentença favorável e, nesse caso, produz os efeitos da atuação da lei em face do adversário. Portanto, o réu, diante da ação, fica sujeito aos efeitos jurídicos derivados da sentença favorável ao autor. Essa sentença ou tais efeitos jurídicos dependem do exercício da ação, vista como um poder em face do adversário, isto é, como uma ação que, quando acolhida, sujeita o adversário a determinados efeitos. De modo que a ação, para Chiovenda, está muito longe de constituir um direito contra o Estado, sendo um poder (ou, mais propriamente, um direito potestativo) em face do réu.²⁰¹

Tal efeito jurídico, entretanto, é o resultado de uma sentença de procedência proferida pelo Estado e, assim, da existência de técnicas processuais elaboradas pelo legislador e do desenvolvimento da atividade jurisdicional voltada a aferir a presença do direito material. Isso quer dizer que a ação não pode ser reduzida a um poder capaz de gerar um efeito em face do réu, pois esse efeito depende do Estado e não apenas da vontade do autor. Aliás, se é certo que o autor não pode sujeitar o réu, mas apenas criar os pressupostos para a sua sujeição perante o Estado, é evidente que o autor tem um *direito contra* o Estado e não um *poder em face* do réu. Nesse sentido se pode dizer que a ação, antes de ser um direito a um fim, é um direito a um meio.²⁰² Antes de alcançar diretamente o réu, dirige-se contra o Estado, para que esse, reconhecendo o direito material, atue diante do réu.

Para que a sentença de procedência seja proferida ou um ato executivo emanado, é necessário que o autor se dirija contra o Estado, exercendo um direito seu (o direito de ação) contra ele. Contudo, tal direito exige não apenas que o Estado pratique atos que façam gerar os efeitos da lei sobre o réu, mas antes de tudo que o Estado verifique qual das partes tem razão. Por isso, ao contrário do que sustentou Chiovenda, *a ação é um direito do autor contra o Estado, que atinge o réu apenas na hipótese de sentença de procedência, mas é exercido em caso de sentença de procedência ou de improcedência.*

Couture concluiu que o direito de ação é assegurado pela Constituição como uma espécie de direito de petição, sendo dirigido contra o Estado e sendo independente do reconhecimento do direito material.²⁰³ Mas faltou a Couture acrescentar ao direito de ação atributos capazes de lhe dar o *status* de direito a uma efetiva tutela jurisdicional. Ou seja, não basta dizer que o direito de ação é garantido constitucionalmente a todos sem lhe atribuir um perfil que o torne efetivamente capaz de proteger o direito material. Para tanto, além de contornar os eventuais obstáculos de natureza social que podem impedir o acesso à justiça, é preciso oportunizar uma adequada participação em juízo – para que o autor realmente possa influir sobre o convencimento do juiz – e instituir e adotar as técnicas processuais capazes de permitir a adequada, efetiva e tempestiva tutela do direito material.

Liebman distingue o direito de ação, garantido constitucionalmente, e a ação delineada pela legislação ordinária, ambas voltadas contra o Estado. Conforme demonstrado, Liebman inicialmente afirmou que essa última tem como requisitos a legitimidade para agir, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido, tendo posteriormente inserido esse último requisito na categoria do interesse de agir. A ação seria um direito ao processo – a todos assegurado constitucionalmente – e a um julgamento de mérito – assegurado apenas a quem preencher as suas condições.

A ação, na sua concepção, não depende de uma sentença favorável, mas existe apenas quando as condições da ação estão presentes.²⁰⁴ Na falta de uma das condições da ação não há ação e exercício de jurisdição, pois entre a ação e a jurisdição, segundo Liebman, existe exata correlação, não podendo existir uma sem a outra.²⁰⁵

Contudo, não há fundamento algum para se admitirem duas modalidades de ação, uma com assento na Constituição e outra na legislação. A ação é uma só, sendo as suas supostas condições apenas requisitos para a apreciação do pedido de tutela jurisdicional do direito.

Portanto, mesmo quando verificada a ausência de uma das chamadas *condições da ação*, é inegável que a jurisdição atuou e a ação foi exercida. Aliás, a jurisdição atuou porque a ação foi proposta, o que se dá no momento em que a petição inicial é protocolada. Isso significa que não é correto dizer, como afirmou Liebman, que só existe ação e jurisdição quando estão presentes as chamadas *condições da ação*.

Na verdade, caso as condições da ação pudessem ser admitidas como requisitos da *existência* da ação, seria necessário explicar o que teria provocado a jurisdição e determinado a instauração do processo. E mais: seria necessário explicar qual a natureza da atividade desempenhada pelo juiz no processo na ausência das suas condições. Somente poderia ser a ação fundada na Constituição. Nesse caso a Constituição serviria apenas para garantir o ingresso em juízo, isto é, garantir propriamente apenas a *demand*a, já que o prosseguimento da atividade do autor dependeria de outra ação, isto é, daquela cuja existência requer a presença das condições da ação. *Com isso, a função da Constituição seria severamente reduzida, podendo-se dizer que o direito fundamental à tutela jurisdicional perderia praticamente quase todo o seu conteúdo.*

A base constitucional do direito de ação não pode ser limitada a um ato de provocação da jurisdição, pois deve dar ao cidadão a possibilidade de obter a adequada, efetiva e tempestiva proteção do direito material violado ou ameaçado de lesão. Porém, para que o autor possa obter a tutela do direito material, ele deve *exercer* a ação – *ou atuar ou agir em juízo*. Nesse sentido, a ação não é meramente *proposta*, tendo um perfil meramente *estático*, mas sim *exercida*, sendo dotada de um perfil *dinâmico*, desenvolvendo-se com o fim de permitir a adequada participação das partes em juízo e a obtenção do julgamento da causa e, no caso de reconhecimento do direito material, o alcance da sua efetiva tutela.²⁰⁶

De modo que as condições da ação somente podem ser requisitos para a viabilização do exame do pedido. Esses requisitos têm relação com o mérito e, dessa forma, não podem ser considerados requisitos para a *existência da ação*. Tais requisitos são os *primeiros graus ligados à apreciação do mérito* – e, nessa direção, para a tutela do direito.

As condições da ação, no entendimento de Liebman, não resultam da simples alegação do autor, mas da verdadeira situação trazida a julgamento. De acordo com Liebman, as condições da ação não devem ser aferidas apenas em razão da *afirmação* do autor (*in status assertionis*), cabendo também a sua análise diante das provas, pouco importando a fase processual em que isso possa ocorrer no processo. Atente-se, entretanto, ao exemplo da ação em que o legitimado ativo deve ser o proprietário do imóvel. Se o juiz, após o desenrolar do processo – com a produção de prova etc. –, chega à conclusão de que o autor não é o proprietário, deve ele extinguir o processo sem julgamento do mérito por falta de legitimidade para a causa ou julgar improcedente o pedido porque o autor não tem direito material?

Não há lógica e utilidade em admitir uma sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito ao final do processo, quando o juiz pode reconhecer que o autor não é o titular do direito material (legitimidade para a causa) ou que o autor não pode exigir o pagamento de uma dívida por ela não estar vencida (ausência de interesse de agir). Se a ação se desenvolve até a última fase do processo, chega-se a um momento em que o juiz está apto para reconhecer a existência ou a inexistência do direito material ou para julgar o mérito ou o pedido, de modo que não há racionalidade em sustentar que a sentença, nessa ocasião, pode simplesmente deixar de resolver o mérito. Daí a razão pela qual fez bem o Código de 2015 em omitir-se em arrolar legitimidade e interesse como *condições da ação*.

Quando se percebe que os *requisitos* para a apreciação do mérito têm a sua função ligada ao princípio da economia processual – ou precisamente com a necessidade de impedir o desenvolvimento do processo de modo inútil –, não há qualquer lógica em admitir que o juiz declare a ausência de um *requisito* ao final do processo, pois nesse caso se estará admitindo a sua inutilidade após dois ou três anos do seu início.

É por isso que os *requisitos* devem ser aferidos com base na *afirmação* do autor, ou seja, no início do desenrolar do procedimento.²⁰⁷ Não se trata de fazer um julgamento sumário (fundado em conhecimento sumário) da presença da legitimidade e do interesse, como se eles pudessem voltar a ser apreciadas mais tarde, com base em outras provas. O que importa é a *afirmação* do autor e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já é problema de mérito. Melhor explicando: a legitimidade para a ação de reivindicação deve ser aferida segundo o que é afirmado na petição inicial, mas, quando as provas e os argumentos trazidos ao processo demonstram que o autor não é proprietário, o seu pedido deve ser julgado improcedente.

Liebman afirma, ainda, que só tem direito à *tutela jurisdicional* aquele que tem razão, porque distingue *direito à sentença* e *direito à tutela jurisdicional*.²⁰⁸ Mesmo que Liebman entenda que a ação constitui direito ao julgamento do mérito e que, portanto, não depende de uma sentença de procedência, vincula o direito à tutela jurisdicional ao reconhecimento do direito material. Assim, no caso de sentença de improcedência, inexistiria tutela jurisdicional – haveria ação, jurisdição, mas o autor não obteria tutela jurisdicional.

É correto dizer que, no caso de improcedência, não se presta tutela jurisdicional ao *direito material* – uma vez que esse não é reconhecido.²⁰⁹ Mas a sentença de improcedência constitui resposta ao pedido de tutela jurisdicional do autor. Caso o direito à tutela jurisdicional dependesse do reconhecimento do direito material, ele seria um direito *concreto*. Ou melhor, agora a *ação seria abstrata*, mas o *direito à tutela jurisdicional concreto*. Contudo, as mesmas razões que conferem natureza abstrata à ação impõem natureza abstrata ao direito à tutela jurisdicional. Vale dizer: *o autor tem direito à tutela jurisdicional efetiva ainda que o seu direito material não exista ou não seja reconhecido*.

Qual o significado, portanto, de todas essas teorias e discussões a respeito do conceito de ação? Todas essas teorias desde Windscheid e Muther – elaboradas ao longo de um período que não por acaso coincide com o período de aparecimento e afirmação da autonomia do direito processual civil – têm em um comum o objetivo de bem equacionar as relações entre direito e processo, isto é, de delimitar as fronteiras e o relacionamento entre o plano do direito material e o plano do direito processual. É, portanto, um debate que tem acentuado significado conceitual. A teoria de Liebman sobre a ação, nesse sentido, é a última expressão de uma compreensão eminentemente conceitualista

do direito processual civil.

Como já afirmamos, porém, o direito de ação é antes de qualquer coisa direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva mediante processo justo, interessando atualmente o seu ângulo teleológico. Nesse sentido, a rica literatura formada a respeito do conceito de ação na segunda metade dos Oitocentos e na primeira metade dos Novecentos, com o advento das transformações do Estado e da incorporação de direito fundamentais nas constituições do pós-guerra, ganha um novo significado – o foco é deslocado do conceito para o resultado propiciado pelo seu exercício. Vale dizer: a ação passa a ser teorizada como meio para prestação da tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva.²¹⁰

4. O direito de ação como direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva mediante processo justo. O art. 5.º, XXXV, CF, diz que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Logo em seguida, o art. 5.º, LIV, refere que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. A combinação desses dispositivos abre a oportunidade para que se afirme o direito de ação não mais como direito a uma sentença, como as teorias clássicas sobre a ação supunham, mas como *direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva mediante processo justo*.

Quando o dispositivo fala em lesão e em ameaça a direito, obviamente está se referindo a *afirmação* de lesão e de ameaça a direito, uma vez que, quando se invoca a jurisdição, *afirma-se* um direito. Vale dizer: não é necessário ser titular de um *direito* para ser possível propor uma *ação*. Quando se diz que a lei não excluirá afirmação de direito, não se garante apenas que esse possa ser *afirmado*. Ora, como consequência lógica, esse direito de afirmação traz implícita a possibilidade da sua *efetiva apreciação* pelo Poder Judiciário (daí a razão pela qual existe uma simetria entre o *direito ao contraditório*, essencial à organização de um *processo justo*, e o *dever de fundamentação* das decisões judiciais, arts. 5.º, LIV e LV, 93, IX, Constituição, e 7.º, 9.º, 10, 11 e 489, § 1.º, IV, CPC).

Deixe-se claro, porém, que o direito de ação não é apenas o direito de afirmar um direito material em juízo ou o direito de formular um pedido de tutela do direito material com base em fundamentos de fato e direito. A ação não se resume ao *ato estático* que invoca a jurisdição. Não é um *ato solitário*, uma simples *demand*, como se o direito de ação pudesse ser restringido ao *requerimento inicial* de tutela jurisdicional, sendo antes um *complexo de posições jurídicas* previstas ao longo de todo o procedimento que visa tendencialmente à tutela do direito mediante uma decisão justa e passível de adequada efetivação.²¹¹ É por essa razão que se afirma que a ação não se confunde com a demanda, sendo antes um *direito composto e dinâmico*, contendo em si um *complexo de posições jurídicas*²¹².

A ação é *exercida* e, portanto, *desenvolve-se* com o objetivo de permitir o julgamento do mérito (do pedido), e, no caso de reconhecimento do direito material, ainda se mantém presente para exigir que os meios executivos da sentença de procedência propiciem a efetividade da tutela do direito material. O direito de ação, portanto, não constitui *direito a uma sentença* – a um *ato processual*. É um direito que também é composto, em sendo o caso, pelas *técnicas processuais adequadas para efetivação* do direito material.

Considerando-se que a ação é exercida dinamicamente e, por isso, passa por várias fases até chegar ao julgamento do mérito e da concessão da tutela jurisdicional, resta natural a pergunta sobre o modo como ela se desenvolve, isto é, sobre os *corolários* do direito de apresentar o pedido de apreciação da afirmação do direito. Em outras palavras, resta natural a pergunta a respeito da adequação da ação – isto é, das técnicas processuais que marcam o seu desenvolvimento – para a tutela do direito alegado em juízo.

4.1. Da ação abstrata e uniforme à ação adequada à tutela do direito material e ao caso concreto. Como diante da Constituição e do Código de 2015 o ângulo pelo qual a ação deve ser vista não é apenas o conceitual, mas também o funcional, importa registrar a necessidade de a

ação ser pensada como ação adequada à tutela do direito material. A ação deixa de ser qualificada simplesmente como abstrata – qualificativo que visa a responder ao problema conceitual das relações entre direito e processo – e deixa de seguir apenas um único procedimento rígido para ser pensada à luz das necessidades de tutela evidenciadas pelos casos a que se destina tutelar, adquirindo para tanto maior elasticidade em termos de técnica processual.

4.2. A repercussão da dicotomia “tutela pelo equivalente”-“tutela específica” sobre a efetividade da ação. Não há dúvida que o direito de ação garante a tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva. O direito de ação, quando assim visto, deve ser relacionado com as formas de tutela jurisdicional do direito material. Essas podem ser divididas em tutela específica e tutela pelo equivalente monetário. A tutela específica do direito material é a que está preocupada com a integridade do direito e assim não objetiva dar o seu equivalente monetário ao lesado. É o contrário de tutela pelo equivalente monetário, ou melhor, da tutela jurisdicional que protege o direito mediante a entrega de indenização em pecúnia ou da entrega do valor equivalente ao da obrigação descumprida ou cumprida de modo imperfeito.

É claro que, *na época das ações típicas*, a tutela específica e a tutela ressarcitória pelo equivalente somente podiam ser obtidas através das *ações que lhes fossem correspondentes*. Ou seja, houve época em que a tutela específica e a tutela ressarcitória pelo equivalente dependiam das ações que estivessem tipificadas. Essa época estendeu-se desde o processo civil romano clássico²¹³ – não por acaso chamado num primeiro momento de período das *legis actiones* e logo em seguida de período em que se agia *per formulas* – até meados do século XIX, tendo como seu ponto mais alto a elaboração teórica das *ações de direito material* de Savigny.²¹⁴

Contudo, o surgimento do conceito de direito autônomo de ação eliminou a possibilidade de se pensar que a tutela específica fosse viável apenas diante de algumas espécies de ação. Ora, como a ação, há mais de um século, é indiscutivelmente aceita como *autônoma e atípica*, é pouco mais do que evidente que o direito de propor a ação ou de invocar a jurisdição não é – nem nunca foi nos últimos 150 anos – obstáculo para a obtenção da tutela específica.

O que pode constituir óbice à atipicidade da tutela específica, ou seja, à possibilidade de sua obtenção para qualquer situação de direito substancial, é a suposição de que ela *é privilégio apenas de alguns direitos, como os direitos reais*, e também a falta de técnicas processuais capazes de dar à ação a efetividade necessária para alcançar a tutela específica, *como acontecia na época em que a forma processual era disposta apenas para atender ao ressarcimento pelo equivalente monetário*.

A tutela ressarcitória pelo equivalente tem relação com os valores do Estado liberal clássico. Em um Estado preocupado com as liberdades formais e não com as necessidades concretas do cidadão, e que objetivava garantir tais liberdades fingindo não perceber as diferentes posições sociais, nada poderia ser mais adequado – ou conveniente – como forma de proteção jurisdicional do que o ressarcimento em dinheiro.

Essa espécie de tutela jurisdicional seguia a lógica de que todos os bens e direitos tinham igual valor e que assim não só podiam ser medidos através do metro da pecúnia, como possuíam na expressão monetária a melhor forma de identificação da necessidade de proteção dos direitos.

Na lógica do Estado liberal havia uma íntima relação entre as ideias de abstração das pessoas e dos bens, de igualdade formal, de autonomia privada e de ressarcimento em pecúnia.²¹⁵ Ora, *se todos são iguais independentemente das suas diferenças concretas, e para a preservação da liberdade é imprescindível não constranger a autonomia privada, a tutela ressarcitória torna-se ideal, pois, além de neutralizar o valor do direito material, não constrange a vontade do obrigado*.

Sendo os sujeitos livres para contratar e as normas contratuais estabelecidas a partir da premissa da igualdade formal, basta verificar se elas são observadas, sem qualquer consideração de natureza social.²¹⁶ Quando as normas não são cumpridas, a sanção está na nulidade e no ressarcimento em dinheiro, sendo impossível compelir o obrigado a cumprir o que contratou – ainda que isso fosse faticamente possível.

Não se obrigava o sujeito do contrato a adimpli-lo na forma específica não apenas porque a sua obrigação, como qualquer outra, podia ser expressa em dinheiro, mas também porque não era possível, diante dos princípios de liberdade e de defesa da personalidade, que o juiz obrigasse o contratante a fazer ou a não fazer alguma coisa.²¹⁷

Na economia liberal, a função do ressarcimento em dinheiro, ao outorgar um equivalente, muito mais do que dar tutela ao direito violado, visava a proteger o “mercado” – para o qual os cidadãos não importavam –, mantendo os seus mecanismos inalterados.²¹⁸

De modo que a tutela ressarcitória pelo equivalente não apenas partia da ideia de que todos os direitos eram iguais e de que todas as pessoas tinham as mesmas necessidades, como também a reproduzia, servindo como um meio de igualização das pessoas e dos direitos e de afirmação da economia de mercado²¹⁹ – que, sem a outorga de sanção ao descumpridor do contrato, não poderia sobreviver. E isso tudo sem constranger a liberdade do obrigado, que não se via compelido a cumprir uma obrigação, mas tinha contra si imposta apenas uma sanção de *natureza negativa*, ou seja, o pagamento do *equivalente* ao valor do dano ou da obrigação.

Não há dúvida que o ressarcimento em pecúnia, como única forma de proteção jurisdicional dos direitos, não está de acordo com os valores do Estado constitucional. O dever estatal de proteger os direitos, especialmente os direitos fundamentais, obviamente demonstra a preocupação com a proteção da integridade dos direitos – com a tutela da integridade do meio ambiente,²²⁰ do direito do consumidor, do direito à saúde,²²¹ do direito à propriedade industrial²²², do direito à educação e por aí afora. Na verdade, tais direitos têm uma natureza que não admite sua transformação em dinheiro. Bem por isso exigem a tutela jurisdicional na forma específica e não a tutela ressarcitória pelo equivalente.

O CPC/1973 foi estruturado com base em técnicas processuais que não permitiam que a ação alcançasse a tutela específica. Não se dava ao juiz poder para, na sentença, ordenar sob pena de multa ou determinar “medida executiva necessária”. Apenas em 1994, com a nova redação dada ao antigo artigo 461, é que se estabeleceu essa possibilidade, que, no Código de 2015 felizmente é repetida nos arts. 139, IV, e 536 a 538.

Isso significa que a ação, em razão das técnicas processuais inidôneas que estavam presentes no CPC/1973 até a reforma processual de 1994, não era capaz de permitir a obtenção da tutela inibitória, que é a mais importante de todas as tutelas específicas, pois necessária para manter incólume e íntegro o direito (como o direito da personalidade), evitando a sua degradação em pecúnia.²²³

Da mesma forma, a sentença condenatória seguida da ação de execução, único modelo de tutela que poderia ser pensado para as tutelas de remoção do ilícito e ressarcitória na forma específica dos antigos arts. 461 e 461-A do CPC/1973, com elas era totalmente incompatível.

Não se pode imaginar que a tutela do direito que exige a remoção dos efeitos concretos derivados da violação de uma norma possa se contentar com uma estrutura processual desse tipo. Quando o contraditório permite a conclusão de que houve a prática de ilícito, não há racionalidade em condenar ou exortar o réu à remoção, devendo o juiz determinar que seu auxiliar judiciário pratique os atos executivos necessários para a remoção dos efeitos do ilícito – por exemplo, a busca e apreensão dos produtos nocivos à saúde do consumidor por parte do oficial de justiça.

Isso para não falar que a tutela de remoção, diante da iminência de dano que naturalmente decorre de um ato que viola uma norma de proteção – como, por exemplo, a ameaça de dano proveniente da exposição à venda de produto nocivo à saúde do consumidor –, não pode prescindir de uma técnica processual autorizadora da sua antecipação, isto é, da antecipação da tutela de remoção do ilícito.

A primeira feição do CPC/1973 também era inadequada ao ressarcimento na forma específica. Como essa forma de ressarcimento exige a eliminação do estrago provocado pelo fato danoso, e isso em regra requer um fazer do infrator, a única técnica processual que poderia ser imaginada

para lhe dar tutela seria a sentença condenatória seguida da ação de execução de obrigação de fazer.²²⁴ Nesse caso seria necessária uma ação de conhecimento com pedido de tutela ressarcitória na forma específica: a sentença, ao conceder essa tutela, condenaria o réu a fazer. Não observada a sentença, seria necessária a ação de execução, que, em caso de novo descumprimento pelo infrator – agora executado –, exigiria que a reparação (ou o fazer) fosse feita por um terceiro. A nomeação de um terceiro para fazer o que deveria ter sido feito pelo infrator não só acarretava grande demora, como também acabava obrigando o próprio lesado a pagar pela reparação.

Se a vítima, mesmo depois de vários anos até alcançar a sentença, deve pagar para que um terceiro faça o que sentença condenatória disse que o infrator já deveria ter feito; ela evidentemente não tem ao seu dispor técnica processual – ou ação adequada – capaz de lhe outorgar a tutela ressarcitória na forma específica.²²⁵

De modo que a técnica processual que se expressa através do binômio “sentença condenatória”-“ação” de execução tem ligação direta com os valores que fizeram supor que a tutela ressarcitória pelo equivalente poderia substituir a tutela específica do direito material. A tutela específica exige sentenças e meios executivos diferenciados. Por isso, *é possível fazer uma relação entre a neutralidade da tutela ressarcitória pelo equivalente com a sentença condenatória e entre as várias necessidades de tutela dos direitos com as técnicas processuais destinadas a permitir a prestação das tutelas específicas.*

Proto Pisani, ao alertar para a importância da distinção entre tutela específica e tutela ressarcitória pelo equivalente, também a relaciona com as teorias da ação, ou, mais precisamente, com a história das teorias da ação, dizendo que, na época em que as ações eram típicas, as tutelas específicas e ressarcitórias ficavam a elas vinculadas, mas, depois da conquista da autonomia da ação – da sua desvinculação do direito material –, as tutelas específicas, porque ficaram subordinadas a uma ação autônoma e atípica – passível de ser utilizada para a obtenção de qualquer tipo de tutela –, passaram a depender apenas das técnicas processuais.²²⁶

O ilustre professor titular da Universidade de Florença reconhece que, diante da autonomia e da atipicidade da ação, a tutela específica pode ser requerida para a proteção de qualquer direito, mesmo os obrigacionais, e que a sua efetividade depende apenas das técnicas processuais, especialmente da “*esecuzione forzata in forma specifica*”, da “*tutela inibitoria*”, das “*misure coercitive*” e da “*tutela sommaria*”.²²⁷

Ou seja, quando Pisani argumenta que a tutela específica dos direitos não está mais amarrada às ações típicas – pois a ação autônoma abre oportunidade para a tutela específica de qualquer espécie de direito (daí a razão pela qual se fala em ação atípica) –, dependendo apenas da adequação das técnicas processuais, ele admite que a ação, ainda que autônoma e atípica, obviamente não pode ser reduzida ao ato solitário em que se faz o pedido de tutela jurisdicional, *mas concretiza-se em uma sequência de atos que dependem de técnicas processuais adequadas*, como é o caso, por exemplo, das medidas coercitivas, apontadas por ele como um dos “*ponti critici*” que ainda não foram solucionados, no direito italiano, para se atribuir efetividade à tutela específica.²²⁸

Porém, se Proto Pisani constrói um raciocínio contemporâneo para a ação, relacionando a sua utilidade com a necessidade de proteção do direito material – e, por isso, desenhando-a como um ente que se desenvolve e constitui um complexo de técnicas processuais –, acaba cometendo um erro interno ao seu raciocínio ao vincular a efetividade da ação com técnicas processuais – a “*esecuzione forzata in forma specifica*”, as “*misure coercitive*” e a “*tutela sommaria*” – e com uma única forma de tutela do direito material, a “*tutela inibitoria*”.

Como é óbvio, *Pisani raciocina como se a tutela inibitória fosse uma técnica processual, nos moldes das medidas de coerção e das técnicas processuais de execução.* Na verdade, o ilustre processualista italiano coloca a tutela inibitória no mesmo patamar das técnicas processuais, dando-lhe a mesma importância do que a essas últimas para a efetividade da ação.

E é nesse ponto que é necessário discordar. A tutela inibitória não é uma técnica processual,

como é a multa ou uma medida coercitiva. Se a multa é necessária para permitir a execução da decisão do juiz, essa (a decisão judicial), atrelada à multa (ao meio executivo adequado), é imprescindível para viabilizar a tutela inibitória. Melhor explicando: os meios executivos e a técnica de tutela sumária ou de antecipação da tutela são instrumentos capazes de viabilizar as tutelas prometidas pelo direito material, sendo que a tutela inibitória é apenas uma espécie entre elas.²²⁹ Enquanto sentença e multa são *técnicas processuais*, a tutela inibitória é uma *tutela do direito*.

As sentenças (condenatória, mandamental etc.) e os meios executivos são técnicas que servem à prestação da tutela jurisdicional. Porém, quando se pergunta sobre o significado da tutela jurisdicional perante o direito material, de nada adianta saber se foi proferida uma sentença *x* ou utilizado um meio de execução *y*, pois esses são incapazes de refletir *o resultado* que o processo proporciona no plano do direito material, mas apenas *o modo* (a técnica) pelo qual o direito processual tutela os diversos casos conflitivos concretos.²³⁰

A diferença *da sentença e dos meios de execução* para as *tutelas* é tão grande que a sentença mandamental (que ordena sob pena de multa), além de idônea à tutela inibitória, também pode permitir, por exemplo, a tutela ressarcitória na forma específica – quando o dano pode ser reparado mediante um fazer. Não há como negar que a sentença e os meios de execução *são apenas técnicas* para a efetiva prestação da tutela jurisdicional dos direitos (inibitória, ressarcitória na forma específica etc.).

A correção é fundamental, pois é indispensável a separação entre *tutela do direito e técnica processual para o desenvolvimento do raciocínio preocupado em dar efetividade à primeira a partir da segunda – ou em externar, de forma crítica, a impossibilidade de se obter a efetividade da tutela do direito diante de eventual estruturação inadequada da técnica processual*.²³¹

Como se vê, a separação entre técnica processual e tutela dos direitos dá ao direito processual a *possibilidade de criticar* a efetividade do direito de ação, que então deixa de ser algo abstrato e indiferente à proteção das pessoas e dos direitos e, assim, pode ser *coerentemente* colocado no posto de direito fundamental garantidor de todos os direitos.

Perceba-se que a conversão da tutela específica em tutela pelo equivalente em dinheiro faz com que a ação não tenha motivo para se diferenciar. Se as tutelas dos direitos perdem as suas características quando são transformadas em tutela pelo equivalente monetário, imediatamente deixa de existir razão para técnicas processuais diferenciadas. A redução das tutelas dos direitos a uma única tutela (pelo equivalente) faz com que passe a ser suficiente um único modelo de ação – a ação que, muito mais do que autônoma, é indiferente ao que acontece no plano do direito material. A diferenciação das técnicas processuais e, por consequência, da ação é uma decorrência da existência de distintas necessidades no plano do direito material.

Se a ação, vista como entidade totalmente abstrata, não pode identificar as necessidades de quem a propõe, é preciso encontrar algo que seja capaz de apontá-las, pois apenas assim será possível verificar se a ação pode realmente atender aos desígnios do direito material. Ou seja, para analisar a efetividade da ação e, desta forma, sua concordância com o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, é imprescindível tomar consciência das necessidades que vêm do direito material, as quais traduzem diferentes desejos de tutela, especialmente de tutelas específicas.

A crítica da efetividade da ação (por exemplo, da insuficiência da sentença condenatória) tem como base a distinção entre tutela específica e tutela pelo equivalente, uma vez que somente a partir do momento em que se constata que a tutela específica deve preferir à tutela pelo equivalente é que se pode indagar se a ação está adequadamente estruturada para viabilizar a obtenção das várias tutelas específicas.

A sequência natural do raciocínio que vem sendo desenvolvido exigiria, à primeira vista, a imediata consideração das formas de tutela dos direitos e das técnicas processuais dispostas na legislação processual. Porém, antes de tal análise é preciso tratar de outro problema, tão importante quanto o da distinção entre tutela específica e tutela pelo equivalente monetário.

Trata-se da questão da *tipicidade das formas ou das técnicas processuais*, que por muito tempo vinculou e subordinou a ação abstrata e atípica, engessando-a a formas preconcebidas pelo legislador.

4.3. A ação única como decorrência do princípio da tipicidade das formas processuais. Quando se fala em tipicidade das *formas processuais* se está longe do tema da tipicidade das *ações*. A tipicidade das ações tem a ver com a época em que os direitos estavam subordinados à existência de ações ou dependiam de ações típicas para se realizarem.

O princípio da tipicidade das formas processuais não quer significar que as tutelas dos direitos estão subordinadas às ações típicas, *mas sim que as técnicas processuais, capazes de dar corpo à ação autônoma e atípica, são apenas as que estão tipificadas na legislação. Tal princípio aceita a ideia de ação atípica, mas vincula a sua realização e desenvolvimento às formas processuais expressamente definidas na lei.*

A aproximação da ação ao princípio da tipicidade das formas processuais, aqui realizada, obviamente não foi feita pela doutrina que viveu o momento histórico da afirmação desse princípio, até porque a discussão sobre a ação, no final do século XIX, era restrita ao problema da sua autonomia e da sua abstração, estando muito longe da questão relativa à sua efetividade. O princípio da tipicidade das formas processuais, em outras palavras, poderia no máximo ser relacionado com a efetividade do procedimento e das próprias técnicas processuais.

Contudo, diante de uma leitura histórica e crítica desse princípio e do direito de ação, é possível dizer que a tipicidade das formas processuais constituiu a expressão do princípio de liberdade, próprio ao jusnaturalismo e ao racionalismo iluminista – garantia de liberdade totalmente compreensível em um contexto preocupado em proteger as liberdades do arbítrio dos juízes e das suas relações espúrias com o chamado Antigo Regime.²³²

Se o juiz dessa época não merecia qualquer confiança, e, portanto, o seu poder deveria ser nenhum²³³ – como disse Montesquieu –,²³⁴ era natural que o desenvolvimento do procedimento ficasse atrelado às formas previstas na lei. Afinal, tal juiz era visto como um “ser inanimado”, incumbido de proclamar o “texto exato da lei”.²³⁵

Vittorio Denti, ao tratar de forma crítica da história do processo de conhecimento, fez ver a razão de ser do princípio da tipicidade das formas processuais no Estado liberal, lembrando que Chiovenda, em conferência proferida em 1901,²³⁶ insistiu para a necessidade das formas como garantia contra a possibilidade de arbítrio do juiz, deixando absolutamente clara “a estreita ligação entre a liberdade individual e o rigor das formas processuais”.²³⁷

Seguindo essa linha, Denti advertiu que a antiga concepção burocrática da função jurisdicional, marcada pela excessiva racionalização do exercício dos poderes do juiz, *foi a responsável pela ideia de criar um modelo único de procedimento, ²³⁸ de modo que o próprio conceito de procedimento único deita raízes nessa concepção primitiva e liberal de jurisdição.*

Esse conceito, como é fácil perceber, tinha razão de ser nesse momento da história, pois, se a forma protege a liberdade, nada melhor do que criar uma forma capaz de atender a todos os homens e a todas as situações, particularmente quando o Estado está proibido de se preocupar com as diferenças sociais e concretas entre os indivíduos e os bens.

O procedimento único, idealizado para um mero burocrata, responsável pela aplicação mecânica da lei, culminava em uma sentença que só poderia permitir a sua declaração (no sentido lato). Ao declarar a lei o juiz poderia desconstituir um contrato, condenar o réu e declarar a existência ou a inexistência de uma relação jurídica. Nesse último caso a lei era declarada com a função de declarar a existência ou a inexistência de uma relação jurídica, ao passo que no primeiro o juiz declarava a lei para desconstituir um contrato e, no segundo, para condenar o réu. Quer dizer que a sentença, como disse de maneira figurada Carnelutti,²³⁹ era sempre feita com o metal da declaração, ainda que pudesse ter uma das três funções antes lembradas, isto é, ser declaratória (em sentido estrito), constitutiva ou condenatória. Aliás, o Estado liberal clássico tinha

a sentença declaratória (em sentido estrito) como ideal, pois através dela o juiz apenas declarava a existência de uma relação jurídica *já formada pela autonomia de vontade*.²⁴⁰ Na verdade, as sentenças declaratória e constitutiva satisfazem por si mesmas a tutela jurisdicional buscada pelo autor, tornando desnecessária a prática de qualquer ato de execução. A mera prolação dessas sentenças é suficiente para que a tutela jurisdicional seja integral.²⁴¹

No contexto das sentenças da classificação trinária, apenas a sentença condenatória exige meios executivos para que a tutela do direito possa ser prestada. Tanto é verdade que a doutrina italiana, ao considerar o conceito de condenação, exprimiu a ideia de que a sentença condenatória constitui apenas *uma fase* da tutela jurisdicional, sendo a execução a responsável pela tutela do direito de crédito.²⁴²

Portanto, se existia apenas um procedimento até as três sentenças, variava o que podia acontecer apenas em relação à sentença condenatória. O não cumprimento da condenação por parte do réu abria oportunidade ao uso de meios para a sua execução.

Acontece que a sentença condenatória também foi moldada nos ares do Estado liberal, estando presa aos valores da liberdade e da segurança jurídica.²⁴³ Por isso, as mesmas razões que levaram à definição de um único procedimento até a sentença conduziram à tipificação dos meios para a sua execução.

Se a sentença condenatória é ligada às modalidades executivas tipificadas na lei, elimina-se a possibilidade de o juiz utilizar qualquer outro meio de execução, controlando-se, dessa forma, a sua possibilidade de arbítrio. Na mesma linha, deixando-se claro que a esfera jurídica do réu não pode ser invadida por meio executivo não previsto na lei, garante-se a liberdade ou a segurança psicológica do cidadão. Essa segurança seria derivada da *certeza do direito* ou da garantia de que somente poderiam ser utilizados os meios executivos tipificados na lei.

Tal necessidade de segurança ou de garantia de liberdade é que levou a doutrina a fixar o princípio da tipicidade dos meios de execução. Aliás, há não muito tempo Mandrioli observou, no direito italiano, que “a precisa referência às formas previstas no Código de Processo Civil implica reconhecimento da regra fundamental da intangibilidade da esfera de autonomia do devedor, a qual somente poderia ser invadida nos modos e através das formas tipicamente previstas pela lei processual”.²⁴⁴

Em suma, a definição de uma forma processual única e invariável, característica à *certeza do direito* e voltada a conferir *segurança jurídica*, fundou-se na necessidade de proteção da liberdade contra o arbítrio estatal.

É claro que a ideia de um procedimento único também foi legitimada pela desnecessidade, decorrente dos valores da liberdade e da economia liberal, de tratamento diferenciado dos direitos, assim como pelo desejo da escola (chamada sistemática, histórico-dogmática ou chiovendiana) que se estabeleceu no início da afirmação do direito autônomo de ação, *de eliminar do processo qualquer mancha do direito material*.

A imunização do processo em relação ao direito material, proposta pelos teóricos da escola sistemática, atingiu a ação – vista como ato isolado através do qual se pede a tutela jurisdicional – e todos os demais institutos que a rodeavam, como se a ação fosse o centro do universo e as sentenças e meios de execução os seus satélites. A ação, como entidade autônoma e abstrata diante do direito material, obviamente era circundada por sentenças e meios de execução identificados a partir de critérios unicamente processuais. Nessa dimensão, como é óbvio, não há como pensar em *efetividade* da ação ou das técnicas processuais perante o *direito material*.

Note-se, aliás, *que a tarefa de separar a ação do procedimento*, isto é, de ver a ação apenas como ato mediante o qual se pede a tutela jurisdicional e o procedimento como o canal que leva ao julgamento do mérito, *certamente contou com o auxílio da tese de que o processo nada tem a ver com o direito material*.

Ora, se o processo é totalmente indiferente ao direito material, não há razão para ligar a ação ao procedimento, dando-se à ação a dimensão de um instituto que se desenvolve com a finalidade de permitir a obtenção da tutela efetiva do direito, e que por isso é totalmente dependente das técnicas processuais. A ação somente pode ser dita dependente do procedimento e das técnicas processuais quando o processo, como um todo, é associado ao direito material.

Ou melhor, para se falar em efetividade da ação é preciso partir da premissa, atualmente indiscutível, de que o processo deve responder ao direito material e chegar à consequência, daí natural, de que o direito de ação, por ser a contrapartida da proibição da tutela privada, é exercido pelo autor para a obtenção da tutela efetiva do direito e, assim, inegavelmente exige procedimento e técnicas processuais idôneos.

Portanto, a crítica endereçada ao procedimento único é a mesma que se pode fazer à ação que se desenvolve através de apenas um procedimento. Se o procedimento único é expressão de uma garantia de liberdade própria de um Estado que não mais existe, o mesmo pode ser dito da ação que somente pode ser exercida mediante um único procedimento. Prefere-se criticar o procedimento, e não a ação, pela simples razão de que não se dá à ação um conteúdo que abarca o procedimento e as técnicas processuais.

O princípio da tipicidade das formas processuais, ou a existência de um procedimento único, elimina qualquer possibilidade de vinculação da ação com o direito material e com o procedimento e as técnicas processuais, proibindo que se fale em “efetividade da ação”.

4.4. O escopo de tutela dos direitos. A necessidade de isolamento do direito processual em face do direito material levou a doutrina a afastar das suas preocupações a *principal finalidade da jurisdição: a tutela dos direitos*.

A escola processual italiana do início do século XX teve o grande mérito de reconstruir o processo a partir de bases publicistas, mas iniciou a história que permitiu ao processo se afastar perigosamente dos seus compromissos com o direito material.

A ação abstrata, preocupada – de maneira excessiva – em se despir de toda e qualquer mancha de direito material, não se ligou a qualquer forma processual que pudesse indicar uma relação do processo com as necessidades do direito material. A escola italiana clássica não só negou à ação qualquer vínculo com um procedimento que pudesse apontar para as necessidades do direito material, como também organizou as formas processuais que necessariamente deveriam estar ao redor da ação a partir de critérios unicamente processuais.

Seguindo a lógica da *neutralidade* em relação ao direito material, que já caracterizava a ação – posta no centro do sistema processual –, ²⁴⁵ os processualistas imaginaram que deveriam criar um universo de sentenças igualmente abstrato. Tal lógica supunha que a resposta jurisdicional ao direito de ação também deveria ser isenta em relação ao plano do direito material. Por essa razão, as sentenças obviamente não foram vistas como tutelas aos direitos, ou como instrumentos capazes de propiciar a tutela dos direitos, mas apenas como provimentos processuais de fecho do processo.

Pensou-se que o processo poderia existir sem qualquer compromisso com o direito material e com a realidade social. Porém, como não é difícil constatar, *houve uma lamentável confusão entre autonomia científica, instrumentalidade e neutralidade do processo em relação ao direito material*. Se o direito processual é cientificamente autônomo e o processo possui natureza instrumental, isto está muito longe de significar que ele possa ser neutro em relação ao direito material e à realidade da vida. Aliás, justamente por ser instrumento é que o processo deve estar atento às necessidades dos direitos. ²⁴⁶

O mais grave é que a pretendida indiferença do processo em relação ao direito material faz com que o sistema jurídico, que obviamente depende do processo para que os textos jurídicos ganhem significado normativo, as normas sejam atuadas e os direitos sejam efetivados, não tenha a possibilidade de atender às necessidades reveladas pelo direito material. Ora, os institutos do processo dependem da estrutura não apenas das normas que instituem direitos, mas também das

formas de proteção ou de tutela que o próprio direito substancial lhes confere.

No Estado constitucional, pretender que o processo seja neutro em relação ao direito material é o mesmo que lhe negar qualquer significado. Isso porque ser indiferente ao que ocorre no plano do direito material *é ser incapaz de atender às necessidades de proteção ou de tutela reveladas pelos novos direitos e, especialmente, pelos direitos fundamentais.*

Nossa Constituição exige a colocação da *tutela dos direitos* como fim do processo civil. Sendo o Estado constitucional ancorado na pessoa humana e o Estado de Direito, nele implicado, fundamentado na segurança jurídica, a finalidade óbvia colimada ao processo civil só pode estar na *efetividade dos direitos* proclamados pela ordem jurídica. *O Estado constitucional existe para promover os fins da pessoa humana – e isto quer dizer que o processo civil no Estado constitucional existe para dar tutela aos direitos.*

É preciso perceber, todavia, que afirmar a *tutela dos direitos* como escopo do processo civil obviamente não implica retroceder à compreensão do processo como simples meio para *realização de direitos subjetivos*, nem em negar o *caráter público* do processo civil. Na verdade, a postura dogmática preocupada em apontar a tutela dos direitos como fim do processo visa a resgatar o devido “*collegamento tra diritto sostanziale e processo*”,²⁴⁷ sem, no entanto, perder de vista o seu caráter autônomo. Nada obstante a “*interdipendenza tra diritto sostanziale e diritto processuale*”²⁴⁸ no plano da efetividade, é evidente que o processo não se confunde com o direito material. E mais: como parece inquestionável, a efetiva tutela dos direitos não pode ser vista como fim estranho ao Estado. O deslocamento do escopo do processo para o seu campo, portanto, longe de negar o caráter público do direito processual civil, visa apenas a cortar os “*eccessi pubblicistici*”²⁴⁹ do seu período de formação e apontar para necessidade de a tutela dos direitos constituir condição de sua legitimação social. *No fundo, a colocação da tutela dos direitos como finalidade do processo corresponde, na dogmática processual civil, à proeminência reconhecida à pessoa humana diante do Estado no plano constitucional.*

Portanto, outorgar à jurisdição o escopo de tutela dos direitos é imprescindível para dar efetividade aos direitos fundamentais, inclusive ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. Como é óbvio, essa forma de conceber a função jurisdicional faz com que a ação neutra (única) perca sustentação, já que *essa ação é completamente incapaz de atentar para o papel que o direito hegemônico desenvolve diante da sociedade e do Estado.*

4.5. Técnica processual e tutela dos direitos. É preciso advertir que, além da tutela jurisdicional, os direitos encontram outras formas de tutela ou proteção por parte do Estado. Lembre-se que os direitos fundamentais, quando enquadrados em uma dimensão multifuncional, exigem prestações de proteção. Isso quer dizer, em poucas palavras, que os direitos fundamentais fazem surgir ao Estado o dever de protegê-los. Ora, essa proteção ou tutela devida pelo Estado certamente não se resume à tutela jurisdicional.

O Estado, antes de tudo, tem o dever de proteger os direitos fundamentais mediante normas de direito. É o que ocorre, por exemplo, quando se pensa na legislação de proteção ao meio ambiente e na legislação de defesa do consumidor.

A norma que proíbe a construção em determinado local e a norma que proíbe o despejo de lixo tóxico em certo lugar constituem normas de proteção ou de tutela do direito fundamental ao meio ambiente sadio.

Embora o Estado tenha o dever de proteger os direitos fundamentais, o art. 5.º, XXXII, CF, não se limitou a dizer que o direito do consumidor é um direito fundamental. Ele disse que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”, deixando expresso que o Estado tem o dever de proteger, mediante normas, o consumidor. Trata-se de um dever de proteção ou de tutela que chamamos de dever de “*tutela normativa dos direitos*”.

Porém, como a edição da norma não basta, o Estado também tem o dever de fiscalizar o seu cumprimento, impor a sua observância, remover os efeitos concretos derivados da sua

inobservância, além de sancionar o particular que a descumpriu. Recorde-se das atividades dos fiscais da saúde pública e dos direitos do consumidor e da figura do guarda florestal. Temos, nesse caso, evidente proteção ou tutela administrativa.

Quando o administrador, em processo administrativo, decide que houve infração a uma norma de proteção, o seu dever passa a ser – quando não lhe restar apenas o mero sancionamento do particular pela conduta reprovada – o de fazer valer o desejo da norma, seja no caso de ato comissivo ou de ato omissivo. Assim, por exemplo, nas hipóteses em que o administrador determina a paralisação da construção de obra, a instalação de determinado equipamento antipoluinte ou a retirada de remédio ou produto nocivo do mercado – nessas situações, a proteção, dada pela norma, é mais uma vez afirmada pelo administrador. Aliás, não se pode negar que, mesmo quando o administrador impõe multa ao particular, ele presta tutela ou proteção ao direito fundamental.

No caso em que o legislador se omite diante do dever de proteção normativa, o juiz deve supri-la, admitindo a incidência direta do direito fundamental sobre o caso conflitivo.²⁵⁰ A questão da incidência direta do direito fundamental sobre os particulares é uma das mais tormentosas da atualidade. Porém, não é preciso pensar em incidência direta do direito fundamental sobre os particulares quando se dá ao juiz o poder de suprir a omissão do dever de proteção do legislador, uma vez que nesse caso o direito fundamental estará incidindo sobre o sujeito privado mediante a participação da jurisdição, e assim a sua incidência estará sendo mediatizada pelo Estado. Nessa situação, a tutela normativa estará sendo substituída pela tutela jurisdicional.

Não se quer dizer que a jurisdição, na tutela dos direitos fundamentais, apenas apareça no caso de omissão de tutela do legislador. A compreensão da tutela jurisdicional exige esforço e concentração no plano do significado normativo. As normas de proteção de direitos fundamentais, como os do consumidor e ao meio ambiente sadio, não são atributivas de direitos, mas impositivas ou proibitivas de condutas, partindo da consideração de que determinadas condutas devem ser impostas ou proibidas para que os direitos fundamentais sejam tutelados. Portanto, tais normas, quando violadas, não exigem as formas de tutela que costumam ser dadas ao cidadão diante do ilícito danoso. Como é evidente, a simples exposição à venda de produto nocivo à saúde não dá a consumidor algum o direito de pedir tutela jurisdicional ressarcitória. A única forma de tutela jurisdicional que se pode ter na hipótese de violação de norma de proteção é exatamente aquela que, de forma similar ao que acontece no plano administrativo, impõe a observância da norma ou remove os efeitos concretos derivados da sua violação. Ora, qual seria a forma de tutela jurisdicional diante da violação de norma de proteção a direito fundamental senão aquela capaz de fazer valer o próprio comando da norma descumprida? Nesse caso, a forma de tutela decorre da própria natureza da norma violada. A violação exige a atuação da norma, e não um remédio capaz de garantir proteção ao sujeito que sofreu dano, isto é, a tutela ressarcitória.

Isso não significa que a violação de norma de proteção não possa acabar acarretando danos aos cidadãos ou mesmo a direitos transindividuais, como o direito ambiental. Nesse caso há duas formas de tutela ressarcitória: pelo equivalente e na forma específica. Quando não há alternativa senão a consideração do valor do dano em dinheiro ou quando o cidadão prefere o ressarcimento em pecúnia ainda que seja possível a tutela específica, impõe-se a tutela jurisdicional ressarcitória pelo equivalente.²⁵¹ No caso de direito transindividual, sendo faticamente viável a reparação *in natura*, a tutela ressarcitória deve ser prestada na forma específica.²⁵²

O Estado tem o dever de tutelar ou proteger os direitos fundamentais através de normas, da atividade administrativa e da jurisdição. Por isso, *há tutela normativa, tutela administrativa e tutela jurisdicional dos direitos*.

A jurisdição tem o dever de proteger ou tutelar todos os direitos, sejam fundamentais ou não. Porém, dizer que a jurisdição deve atender ao direito material pode significar, simplesmente, que o processo deve acudir aos direitos atribuídos aos cidadãos pelas normas materiais, o que não expressa algo muito relevante, a não ser um clichê que vem sendo utilizado pelos processualistas para dizer algo que é correto, porém óbvio e destituído de importância, *especialmente quando se almeja uma dogmática capaz de permitir a efetiva retomada dos laços entre o processo civil e o*

direito material.

Esse clichê pode ser identificado no ditado de Chiovenda, hoje celebrizado pela doutrina processual, que diz que o processo deve dar a quem tem um direito tudo aquilo e exatamente aquilo que tem o direito de obter. *Além de Chiovenda não ter construído essa frase com a mesma boa vontade e intenção dos processualistas que a repetem,*²⁵³ *ela é insuficiente para identificar uma dogmática adequada aos nossos dias.*

A preocupação com a tutela dos direitos não diz respeito apenas à idoneidade do processo para atender aos direitos, pois é uma questão que se coloca, já em um primeiro momento, no âmbito do direito material. E, *no plano do direito material, implica adoção de uma postura dogmática que retira o foco das normas ditas atributivas de direitos para jogar luz sobre a esfera das tutelas, local em que se encontram as formas de tutela ou de proteção que os direitos reclamam quando são violados ou expostos a ameaças de violação.*²⁵⁴

As *formas de tutela* são garantidas pelo *direito material*, mas não equivalem aos direitos ou às suas necessidades. É possível dizer, considerando-se um desenvolvimento linear lógico, que as *formas de tutela* estão em um local mais avançado: é preciso partir dos direitos, passar pelas suas necessidades, para então encontrar as *formas* capazes de atendê-las.

Assim, por exemplo: a Constituição Federal afirma que “são *invioláveis* a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, *assegurado o direito* a indenização pelo *dano material ou moral* decorrente de sua violação” (art. 5.º, X), e que “é assegurado o *direito de resposta*, proporcional ao agravo, além da *indenização por dano material, moral ou à imagem*” (art. 5.º, V). Nesse caso, a Constituição garante de maneira expressa várias *formas de proteção ou de tutela* aos direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas.²⁵⁵

Ou seja, tais normas não se limitam a atribuir ou a proclamar direitos, mas consideram as suas necessidades e afirmam as *formas imprescindíveis à sua proteção*. Quando a Constituição diz que tais direitos são *invioláveis*, afirma que eles exigem uma forma de proteção jurisdicional capaz de impedir a sua violação. Mas, além disso, confere a tais direitos, no caso de violação, indenização, deixando claro que eles devem ser protegidos ou tutelados mediante ressarcimento nos casos de dano material e moral.

Perceba-se, porém, que a primeira parte do inc. V do artigo 5.º, ao dizer que “é assegurado o *direito de resposta*, proporcional ao agravo”, garante uma forma de proteção ao direito que não se confunde com a inibitória ou com a ressarcitória pelo equivalente. Trata-se da tutela ressarcitória na forma específica, já que destinada a reparar o dano de modo específico, e não mediante o pagamento do equivalente em dinheiro ao seu valor.²⁵⁶

Como se vê, a postura dogmática preocupada com as tutelas é atenta para as *formas de proteção ou de tutela dos direitos*. Ela não está preocupada em saber se os cidadãos têm este ou aquele direito, ou mesmo com a identificação de direitos difusos e coletivos. É que, na perspectiva das “*formas de tutela dos direitos*”, a atribuição de titularidade de um direito fica na dependência de que lhe seja garantida a disponibilidade de uma *forma de tutela* que seja adequada à necessidade da sua proteção. Ou melhor, o sujeito só é titular de um direito, ou de uma posição juridicamente protegida, quando esse direito disponha de uma *forma de tutela* que seja adequada à necessidade de proteção que esta posição exija.²⁵⁷ Como está claro, há aí um proposital desvio de rota dirigido a permitir a *diferenciação entre a atribuição – ou, como dizem alguns, a proclamação – de direitos e a existência de posições jurídicas protegidas*.

Note-se que ter direito à imagem é algo muito diferente do que ter uma *forma de tutela adequada à sua proteção*, como a tutela inibitória. Ter direito ao meio ambiente sadio não quer dizer ter direito à tutela ressarcitória na forma específica. O direito do consumidor deve ter ao seu dispor a tutela capaz de remover os efeitos concretos derivados do ato que violou a norma de proteção, e assim por diante.

Ademais, a questão das *formas de tutela*, por dizer respeito ao plano do direito material, não

deve se confundir com o problema de se saber se o processo civil é capaz de dar efetividade aos direitos, ou melhor, às formas de tutela prometidas pelo direito material. Pergunta-se sobre as formas de tutela na esfera do direito material, portanto antes de se analisar a efetividade do processo. Aliás, caso a questão das *formas de tutela* pudesse ser confundida com a da *efetividade do processo*, estaria negada a obviedade de que a pergunta sobre a forma de tutela é um degrau que necessariamente deve ser ultrapassado para se chegar à problematização da efetividade do processo.

O processo deve se estruturar de maneira tecnicamente capaz de permitir a prestação das *formas de tutela* prometidas pelo direito material. De modo que, entre as *tutelas dos direitos* e as *técnicas processuais* deve haver uma relação de adequação. Mas essa relação de adequação não pergunta mais sobre as *formas de tutela*, porém sim a respeito das *técnicas processuais*.

Ou melhor, quando se indaga sobre a efetividade do processo já se identificou a *forma de tutela* prometida pelo direito material, restando verificar se as *técnicas processuais* são capazes de propiciar a sua efetiva prestação. Não é por outro motivo que não se pode misturar tutela inibitória com sentença mandamental ou tutela ressarcitória pelo equivalente com sentença condenatória. Também por essa razão não há como deixar de constatar que a tutela antecipada não é uma técnica processual, mas a antecipação da forma de tutela capaz de atender ao direito material. Na realidade, como agora é fácil perceber, há uma *técnica* para a *antecipação da tutela*. Assim como a sentença e os meios executivos servem para viabilizar a tutela final, a decisão antecipatória e os meios executivos a ela adequados têm o objetivo de permitir a antecipação da tutela.

Quando se propõe o binômio “técnica processual”-“tutela dos direitos” não se quer simplesmente reafirmar a velha estória da necessidade de adequação do processo ao direito material. Deseja-se, isto sim, a partir de uma postura dogmática preocupada com as posições jurídicas protegidas e com as *formas de tutela necessárias para lhes dar proteção* – e não mais apenas com as normas atributivas de direitos –, chegar a uma verdadeira análise crítica da ação e do processo, mediante a verificação da idoneidade das *técnicas processuais* para prestar as *formas de tutela* prometidas pelo direito material.

Deixe-se claro que o significado de “técnica”, aqui empregado, está muito longe daquele que se costuma atribuir à “técnica” despreocupada com a realidade da vida. Ao se falar em técnica processual, não se pretende – nos termos das teorias ditas tecnicistas – elaborar um sistema imune ou neutro, como se o processo civil não fosse destinado a atender aos conflitos dos homens de carne e osso. Ao inverso, a única razão para relacionar a técnica processual e as tutelas dos direitos é demonstrar que o processo não pode ser pensado de forma isolada ou neutra, pois só possui sentido quando puder atender às tutelas prometidas pelo direito material, para o que é imprescindível compreender a técnica processual (ou o processo) a partir dos direitos fundamentais e da realidade do caso concreto. De modo que, ao contrário das doutrinas e dos sistemas desprovidos de paixão pelo homem e pela vida, e que procuram encontrar sustentação em conceitos abstratos que tanto são melhores quanto mais *limpos e transparentes* – isto é, neutros –, a nossa teoria não tem outra preocupação a não ser evidenciar a falácia da teoria processual clássica, que ignorava a própria razão de ser da jurisdição, da ação, da defesa e do processo.

O Código de 2015 em parte atendeu à necessidade de estruturação da técnica processual à luz do discurso da tutela dos direitos, na medida em que em várias passagens alude ao conceito de tutela do direito e às suas formas para promover uma *adequada ancoragem do processo civil* em relação ao direito material (por exemplo, art. 139, VI, e 498). Em pontos cruciais, porém, continuou insistindo na alusão às *velhas categorias privatistas* das prestações de fazer, não fazer, entregar coisa e pagar quantia como *eixo para viabilizar a prestação da tutela jurisdicional dos direitos* (por exemplo, os arts. 497 e 498 – nada obstante o parágrafo único do art. 497 tenha bem apreendido a necessidade de trabalhar com os conceitos ligados à tutela dos direitos). Essas categorias, porém, nada obstante possam designar os comportamentos que são devidos para realização de determinadas prestações, nada dizem a respeito da *natureza da tutela do direito* que deve ser prestada e, portanto, de como o processo tem de se organizar do ponto de vista técnico para bem fazê-lo – vale dizer, elas não têm o condão, por exemplo, de circunscrever o debate processual à ameaça de ilícito, como é capaz de indicar, ao invés, a utilização do conceito de tutela inibitória.

Por essa razão, o discurso preocupado em relacionar técnicas processuais e tutela dos direitos em nada se confunde com o surrado esquema das prestações de dar, fazer e não fazer como meio de promover o relacionamento entre o direito material e o processo em termos de efetiva tutela jurisdicional – imaginá-lo constitui ingenuidade indesculpável ou escuso compromisso com um modo totalmente ultrapassado e seletivamente inefetivo de encarar o processo civil. Daí a razão pela qual o ideal teria sido permear textualmente todo o novo Código de Processo Civil a partir da categoria da tutela do direito.

4.6. As tutelas jurisdicionais dos direitos. Como é intuitivo, a forma ideal de proteção do direito é a que impede a sua violação. Ter direito, ou ter uma posição jurídica protegida, é, antes de tudo, ter direito a uma forma de tutela que seja capaz de impedir ou inibir a violação do direito. Essa forma de tutela é importante, sobretudo, para os direitos não patrimoniais, isto é, para os direitos que não podem ser reparados por um equivalente monetário.

Não há como pensar em direito à honra ou à intimidade sem tutela inibitória.²⁵⁸ Do mesmo modo, o direito ambiental simplesmente não existe na ausência dessa forma de tutela. Não há exagero em dizer que tais direitos dependem da tutela inibitória. Isso porque, como dito no item antecedente, as normas atributivas de direitos nada valem sem a disposição de formas de tutela dos direitos. Uma norma que atribui ou afirma um direito *inviolável* obviamente só tem sentido quando tem ao seu lado uma forma de tutela capaz de impedir a violação.

Não é por outra razão que a Constituição Federal afirma que “são *invioláveis* a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas” (art. 5.º, X), e que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o *dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações*” (art. 225, *caput*).

A tutela inibitória não depende do direito processual para existir. Ela decorre do direito material; não há direito que, quando ameaçado de lesão, não detenha uma forma de proteção contra a sua violação. E isso fica mais evidente em se tratando de direitos não patrimoniais, como o direito ao meio ambiente.

*É equivocado imaginar que as formas de tutela dos direitos dependem do processo.*²⁵⁹ A legislação processual apenas institui procedimento e técnicas processuais que sejam capazes de viabilizar a obtenção da tutela do direito prometida pelo direito material. Ou seja, a legislação processual deve se preocupar com os procedimentos e as técnicas processuais – p. ex., técnica antecipatória e sentença mandamental – e não com as tutelas dos direitos – p. ex., tutela inibitória.

A tutela inibitória é uma forma de proteção do direito material e pode objetivar impedir ou inibir a violação do direito, a sua repetição ou a continuação de uma atividade ilícita.²⁶⁰

A exposição didática recomenda acompanhar a trajetória dos atos de agressão dos direitos. Se a tutela inibitória se destina a impedir a lesão do direito, o próximo passo na visualização das formas de tutela deve parar no instante em que um ato viola uma norma, mas não acarreta um fato danoso. E aqui nos encontramos novamente em situação que exige uma reelaboração dos conceitos da dogmática clássica.

Trata-se da necessidade de repensar o conceito de ilícito civil e, especialmente, de tutela contra o ilícito. O ilícito civil tem sido pensado como o ato contrário ao direito que produz dano. O elemento dano, em outras palavras, vem sendo exigido como um componente essencial para a configuração do ilícito civil. Argumenta Orlando Gomes, por exemplo, que “o ilícito civil só adquire substantividade se é fato danoso”.²⁶¹

Note-se que há aí uma mistura entre o ato contrário ao direito e o dano ou uma falta de distinção entre o ato em si (o ilícito) e a sua consequência (o dano). Nem sempre o ato contra o direito e o dano ocorrem no mesmo instante, sendo possível que o dano surja após a prática do ilícito, sendo até mesmo frequentes os casos em que o dano se intensifica com o passar do tempo. Aliás, é possível que exista ato contrário ao direito que não provoque dano. O dano não é apenas

uma consequência, mas na verdade uma consequência *eventual* do ilícito.²⁶² Por isso, não há como negar a separação entre ilícito e dano.

O que seria possível dizer é que o dano, apesar de não se confundir com o ato contrário ao direito, é imprescindível para se outorgar *tutela* ao direito. Na verdade, o entendimento de Orlando Gomes evidencia a confusão entre o conceito de ilícito e os pressupostos para a tutela ressarcitória. Segundo Orlando Gomes, “não interessa ao direito civil a atividade ilícita de que não resulte prejuízo. Por isso, o dano integra-se na própria estrutura do ilícito civil. Não é de boa lógica, seguramente, introduzir a função no conceito. Talvez fosse preferível dizer que a produção do dano é, antes, um requisito da responsabilidade, do que do ato ilícito. Seria este simplesmente a conduta *contra jus*, numa palavra, a injúria, fosse qual fosse a consequência. Mas, em verdade, o Direito perderia seu sentido prático se tivesse de ater-se a conceitos puros”.²⁶³

Orlando Gomes supõe que o conceito de ilícito que não considera o dano é um “conceito puro”. Essa sua conclusão parte da premissa de que “não interessa ao direito civil a atividade ilícita de que não resulte prejuízo”. Porém, o que diz Orlando Gomes é que o ilícito que não gera prejuízo não abre oportunidade para a tutela ressarcitória. Como a proteção ou a tutela ressarcitória devem ser buscadas através do processo civil, afirma-se, em outros termos, que o ilícito não danoso não deve ser objeto de preocupação do processo civil, ou ainda que jamais haverá interesse de agir em uma ação civil voltada a proteger um direito contra a prática de um ilícito que não produziu dano.

Acontece que Orlando Gomes, além de colocar um elemento que diz respeito à configuração do direito à tutela ressarcitória no conceito de ilícito, deixando de distinguir ilícito de tutela do direito, traz um problema mais grave, uma vez que o dano é imprescindível *apenas para uma das tutelas do direito*, isto é, para a tutela ressarcitória. Ora, não é possível admitir, dentro da realidade contemporânea, que o ressarcimento *seja a única forma de tutela contra o ilícito*.

É certo que a admissão de outra forma de tutela contra o ilícito implica superação de um dogma que vem desde o direito romano.²⁶⁴ A assimilação entre ilícito e dano é o resultado de um processo histórico que levou a doutrina a admitir que a tutela contra o ilícito seria apenas o pagamento do equivalente ao valor da lesão ou, quando muito, a aceitar que determinados danos poderiam ser reparados *in natura*.

Contudo, na dimensão do Estado constitucional, em que avulta o dever de o Estado proteger os direitos fundamentais mediante a proibição ou a imposição de condutas, a necessidade de tutela contra o ilícito *exige uma nova postura dogmática, voltada a explicar a necessidade de outra forma de tutela, derivada da existência de normas de natureza protetiva, características a um Estado ciente do seu dever de proteção*.

Lembre-se que o Estado tem o dever de proteger os direitos fundamentais, entre outras maneiras mediante a instituição de normas de proteção. Por isso, edita normas que proíbem ou exigem condutas para dar proteção ao meio ambiente ou aos consumidores, por exemplo. Parte-se da premissa de que determinadas condutas comissivas podem gerar danos, ou que certas práticas ou condutas são imprescindíveis para se evitarem danos ou prejuízos.

As normas que proíbem a construção ou o despejo de lixo em determinada zona, exigem a instalação de equipamento antipolvente e impedem a venda de produto ou remédio com determinada composição, objetivam dar proteção aos direitos fundamentais. São normas proibitivas ou impositivas de condutas, tendo a finalidade de proteger os direitos fundamentais. A violação dessas normas expõe os direitos fundamentais aos prejuízos que o legislador deseja evitar quando estabelece proibições ou imposições. De modo que, contra a violação da norma, deve existir uma forma de tutela do direito que é por ela protegido ou uma forma de tutela que faça atuar o próprio desejo da norma violada.

A prática de ato contrário a uma norma de proteção, ainda que não traga dano, exige uma forma de tutela jurisdicional do direito e por isso, obviamente, não pode ser indiferente ao processo civil. *Não há como admitir, no Estado constitucional, que a única função do processo civil*

contra o ilícito continue a ser a de dar ressarcimento pelo dano. Num Estado preocupado com a proteção dos direitos fundamentais, o processo civil também deve ser utilizado como instrumento capaz de garantir a observância das normas de proteção, para o que a ocorrência de dano não tem importância alguma.

Nesse caso só há interesse na tutela do direito quando os efeitos concretos da ação ilícita perduram no tempo. Quando da violação da norma não decorrem danos ou efeitos concretos configuradores de uma situação antijurídica, obviamente não há qualquer interesse na provocação da jurisdição. Esse interesse, no caso em que não há dano, reclama a tutela jurisdicional *para que os efeitos concretos do ilícito sejam removidos ou eliminados*.

É o que ocorre, por exemplo, no caso de exposição à venda de produto nocivo ao consumidor ou de remédio com composição capaz de causar dano à saúde, ou mesmo de venda de produto ou de remédio desprovido das informações necessárias ao seu uso ou ingestão. Nessas hipóteses, qualquer ente legitimado à defesa dos direitos transindividuais²⁶⁵ pode pedir a tutela de remoção dos efeitos concretos do ilícito, requerendo, como técnica processual, a busca e apreensão dos produtos ou dos remédios.

Não existindo dano, mas uma simples situação antijurídica, a tutela jurisdicional deve estabelecer a situação que lhe era anterior. Daí por que essa forma de proteção do direito constitui uma tutela jurisdicional de remoção do ilícito, a qual também é uma tutela específica, na medida em que não se conforma com a transformação do direito em dinheiro.²⁶⁶

A tutela de remoção do ilícito é imprescindível para a jurisdição dar atuação específica às normas de proteção dos direitos fundamentais. Aliás, sem esta espécie de tutela jurisdicional, o dever de proteção estatal aos direitos se tornaria impossível e o direito de proteção normativa dos direitos fundamentais quase que inútil.

Porém, a tutela de remoção também é imprescindível aos direitos individuais. Basta lembrar, por exemplo, das situações em que produtos evidenciam contrafação de marca comercial ou em que cartazes publicitários configuram concorrência desleal. Nessas hipóteses, ainda que os ilícitos possam ter gerado danos, e para eles a tutela ressarcitória seja adequada, isso obviamente não basta, uma vez que não elimina a necessidade da tutela de remoção do ilícito.

A tutela de remoção, *em vez de remediar o dano, elimina a sua fonte*,²⁶⁷ impedindo o prolongamento da situação antijurídica que expõe o titular do direito violado a danos. Assim, não importa se algum dano já foi produzido, pois há sempre interesse em remover a situação que constitui a sua causa, ou melhor, que abre oportunidade a eventuais outros danos.

Enquanto a probabilidade da prática de ato contrário ao direito é pressuposto da tutela inibitória,²⁶⁸ para a tutela de remoção basta a ocorrência da violação da norma, sendo desnecessário cogitar, em relação a ambas as tutelas, não apenas sobre a probabilidade e a ocorrência de dano, mas também a respeito de culpa ou dolo, até porque a exigência do elemento subjetivo se presta apenas a legitimar a imposição da sanção ressarcitória.²⁶⁹

A passagem do ato contrário ao direito ao fato danoso faz a ponte entre a tutela de remoção do ilícito e a tutela ressarcitória. Porém, é preciso separar o dano, o ressarcimento e as *duas formas de tutela ressarcitória*. Quem sofre um dano tem direito ao ressarcimento, mas pode se valer, conforme a sua situação concreta, de uma das duas formas de tutela ressarcitória.

A tutela ressarcitória pode ser prestada pelo equivalente ou na forma específica. Ao se admitir que os bens jurídicos podem ser reduzidos a pecúnia, há assimilação entre ressarcimento e pagamento de dinheiro e, dessa maneira, falta de motivo para a preocupação com uma forma de tutela capaz de permitir a reparação *in natura*.

Porém, há direitos que, pela sua natureza, não podem ser transformados em dinheiro. É o caso, por exemplo, do direito ao meio ambiente sadio. A própria Constituição Federal afirma, em seu art. 225, que o “meio ambiente ecologicamente equilibrado” deve ser preservado “para as

presentes e futuras gerações”. Não há como dar tutela ao meio ambiente, preservando-o para as presentes e futuras gerações, mediante o ressarcimento pelo equivalente. Isso seria o mesmo do que aceitar que, no lugar do meio ambiente sadio, a sociedade pode se contentar com dinheiro. Na realidade, seria o mesmo que admitir a expropriação do direito ao meio ambiente.

Daí a imprescindibilidade da tutela ressarcitória na forma específica. Enquanto a tutela ressarcitória em pecúnia visa a dar ao lesado o valor equivalente ao da diminuição patrimonial sofrida ou o valor equivalente ao do custo para a reparação do dano, ou ainda pode constituir uma resposta contra o dano acarretado a um direito não patrimonial (a chamada indenização por dano moral), *a tutela ressarcitória na forma específica objetiva estabelecer a situação que existiria caso o dano não houvesse sido produzido.*²⁷⁰

A prioridade do ressarcimento na forma específica é imposição que decorre do próprio direito material. Na realidade, se o lesado tem direito ao ressarcimento, cabe-lhe escolher a forma de reparação, que pode ser na forma específica ou pelo equivalente. Apenas quando, diante da situação concreta, o ressarcimento na forma específica for impossível ou configurar uma forma excessivamente onerosa é que o ressarcimento deverá ser pelo equivalente monetário. Isso quer dizer que, nos casos em que a tutela ressarcitória na forma específica for concretamente possível, ela somente será excluída por opção do próprio lesado ou quando o ressarcimento na forma específica, ainda que possível, não for justificável ou racional em vista da sua excessiva onerosidade. Deixe-se claro, contudo, que se o lesado sempre tem a *opção* do ressarcimento na forma específica, o legitimado à tutela dos direitos transindividuais dela não pode abrir mão em troca de ressarcimento em dinheiro.

Ademais, o ressarcimento na forma específica pode ser cumulado com o ressarcimento em dinheiro, uma vez que o primeiro, em determinadas situações, pode representar apenas parte da integralidade do ressarcimento. Assim, por exemplo, no caso de corte indevido de árvores. Se é possível determinar o plantio de árvores semelhantes às indevidamente cortadas, isso certamente é incapaz de ressarcir a totalidade do dano, pois as árvores e o próprio ecossistema estariam em uma situação diversa caso o dano não houvesse sido produzido. Em um caso como esse, o ressarcimento na forma específica deve ser cumulado com o ressarcimento em dinheiro.

O ressarcimento na forma específica pode ser prestado não apenas através de um fazer, mas igualmente mediante a entrega de uma coisa capaz de substituir a destruída ou a roubada. Note-se que a tutela ressarcitória na forma específica objetiva proteger o direito mediante uma reparação que se aproxime da reconstituição do estado que era anterior ao dano, tendo como oposto o ressarcimento, que dá ao lesado um *valor em dinheiro* equivalente ao da lesão. De modo que o ressarcimento na forma específica não depende apenas de um fazer, pois também pode ser prestado com a entrega de coisa.

Supor que a tutela ressarcitória pelo equivalente é a única resposta ao dever de reparar o dano, além de admitir que todo bem ou direito pode ser expresso em pecúnia, conduz à ideia de que o infrator pode se liberar da sua responsabilidade mediante o pagamento de dinheiro – quando então ter patrimônio seria o mesmo que ter a responsabilidade atenuada. Porém, o lesado não tem um mero direito de crédito sobre o patrimônio do infrator, mas sim o poder de obrigá-lo à reparação. A existência de um poder de obrigar à reparação implica na possibilidade de usar a ação para coagir o infrator a fazer ou a entregar coisa equivalente à destruída.²⁷¹

Após a tutela ressarcitória, cabe analisar a tutela contra o inadimplemento da obrigação contratual. No sistema que ignora a tutela específica da obrigação, aquele que necessita do bem, e por isso realiza o contrato, jamais tem efetivamente assegurado o seu direito, ao passo que o detentor do capital ou do bem possui a possibilidade de, a qualquer momento e inclusive em razão de uma *variação de mercado* que não lhe é benéfica, liberar-se da sua obrigação mediante o simples pagamento de dinheiro.

A negação de tutela específica à obrigação contratual reveste-se de evidente contradição, pois admite que as partes se obrigam ao contratar, mas, logo após, estão livres para não atender à prestação assumida, como se o adimplemento fosse um *dever livre* ou um puro ato potestativo e

não algo devido.²⁷²

A vontade das partes somente é efetivamente considerada quando o contrato produz os seus efeitos normais ou previamente desejados.²⁷³ “O credor acredita no normal desenvolvimento da relação, segundo a vontade das partes e a função econômica tida em vista no momento inicial.”²⁷⁴ As obrigações que nascem com o contrato, como acrescenta Calvão da Silva, “nascem para ser cumpridas, sendo o seu cumprimento, sem dúvida, o essencial e principal efeito querido pelas partes ao concluírem o contrato. Daí poder falar-se do programa obrigacional como programa de cumprimento e do interesse do credor nesse programa como interesse existencial do cumprimento”.²⁷⁵

O pagamento do equivalente, como resposta jurisdicional ao não cumprimento da obrigação contratual, supõe a obrigação como um poder do credor sobre o patrimônio do devedor, e não a obrigação como um direito à prestação. Por isso, a inexistência de tutela específica contra o inadimplemento nega a própria natureza da obrigação, cujo fim é o de dar ao credor uma prestação, e não a de lhe conferir um valor em dinheiro.²⁷⁶

Na sociedade de massa, em que é imprescindível a proteção da posição do consumidor, não há como deixar de conferir ao jurisdicionado a tutela do adimplemento na forma específica para se garantir o bem objeto do contrato ou o bem tal como foi contratado, sem vícios ou defeitos.

Lembre-se que, além de o inadimplemento poder ser total ou parcial, ele pode ser imperfeito. As duas primeiras hipóteses dizem respeito, respectivamente, ao não cumprimento da obrigação na sua totalidade e em parte, enquanto a última se refere ao cumprimento imperfeito da obrigação, isto é, ao cumprimento realizado com vícios.

Os arts. 18, 19 e 20 do CDC tratam dos chamados vícios de qualidade e quantidade dos produtos e dos serviços, ou seja, dos vícios ou imperfeições no cumprimento das obrigações de entregar produto e prestar serviço. A responsabilidade pelos vícios inerentes aos produtos ou serviços deriva da obrigação do fornecedor em assegurar o cumprimento perfeito, colocando o produto ou o serviço no mercado com a qualidade e a quantidade garantidas.

Quando a obrigação é cumprida de modo imperfeito, surge ao credor o direito de exigir a correção do defeito no cumprimento (a sanção do vício, a complementação do peso ou medida, a substituição do produto ou a reexecução do serviço – arts. 18, 19 e 20 do CDC). O direito a essa tutela se funda na própria obrigação, ou melhor, na garantia de qualidade que lhe é inerente.

Nos casos de inadimplemento total e parcial, assim como nos de adimplemento com vícios de quantidade e qualidade, há direito à tutela do adimplemento na forma específica, seja com o fim de obrigar ao adimplemento – diante de inadimplemento total ou parcial –, seja com o objetivo de permitir a sanção do vício, que pode se dar até mesmo mediante a substituição do produto ou a reexecução do serviço.

A tutela do adimplemento na forma específica cabe no caso de obrigação de fazer (prestar serviço) e de entregar coisa (entregar um produto). Mas, no caso de cumprimento imperfeito de obrigação de entregar coisa, a tutela do adimplemento da obrigação de entrega de coisa pode ser prestada mediante uma técnica processual que imponha um fazer (sentença que ordene um fazer sob pena de multa, por exemplo).²⁷⁷

Quando a obrigação não puder mais ser cumprida, a tutela deverá prestar o equivalente *ao valor da prestação inadimplida*. Note-se, porém, que essa tutela se diferencia da tutela pelo equivalente *ao valor do dano*. A primeira tem a ver com a *obrigação inadimplida* e a segunda com o *dano*. Por isso, a primeira é tutela da *obrigação* pelo equivalente ou tutela pelo equivalente ao valor da obrigação e a segunda é tutela *ressarcitória* pelo equivalente.

Além disso, é preciso perceber que nem toda tutela prestada em dinheiro é tutela pelo equivalente. Quando alguém se obriga a pagar quantia em dinheiro, a tutela que confere pecúnia ao outro sujeito do contrato obviamente não é tutela pelo equivalente, mas sim tutela do

adimplemento na forma específica.

Tudo isso indica que o direito à tutela específica da obrigação decorre do próprio direito material. A ideia de que a tutela específica não é devida às obrigações, mas apenas aos direitos reais, é devedora da época das ações típicas ou da fase em que a proteção dos direitos reais era mais incisiva do que a das obrigações, o que ocorreu por uma série de motivações políticas e econômicas, que faziam entender que o cumprimento do contrato não possuía a mesma importância da tutela dos direitos reais. A separação entre tutela específica e tutela pelo equivalente a partir da relação “direitos reais”-“obrigações” não tem qualquer sentido na sociedade contemporânea, uma vez que, conforme dito acima, o credor de uma obrigação não tem apenas direito de crédito sobre o patrimônio do devedor, mas sim direito à prestação por ele prometida.

Contudo, não há como deixar de mencionar as tradicionais tutelas específicas voltadas à obtenção da coisa com base no direito à posse, no domínio e na posse esbulhada, assim como as tutelas de manutenção de posse e interdito proibitório.

No caso de obrigação de entregar coisa móvel, ocorrida a tradição simbólica, mas não entregue a posse concreta do bem, a tutela a ser exigida não é de adimplemento da obrigação, mas sim *de imissão na posse da coisa com base no direito à posse* – derivado do documento que expressou a tradição simbólica.

Tratando-se de coisa imóvel, é possível que alguém tenha o direito de haver a posse da coisa de quem se obrigou a transferi-la. Nesse caso, o titular do direito à posse – que pode ser o adquirente – tem direito à tutela de imissão na posse. A exigência da imissão na posse depende da *existência de obrigação de transferência da posse e, portanto, de direito à posse*.

A coisa também pode ser pedida com base no *domínio*. O proprietário sem posse pode pedir a coisa contra o possuidor que não é proprietário. A tutela objetiva a coisa com base no domínio, mas somente pode ser concedida quando o réu exerce a posse de forma injusta. Tal tutela é pedida através da ação tradicionalmente conhecida como reivindicatória.

Quando o possuidor tem a sua posse *roubada* ou esbulhada, cabe-lhe a tutela de reintegração na posse. Essa tutela permite ao autor recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho. Além da tutela de reintegração de posse, há a tutela de manutenção de posse e a tutela de interdito proibitório, tidas como tutelas possessórias. A manutenção de posse é devida ao possuidor que tem a sua posse turbada, ao passo que o interdito proibitório se destina a impedir moléstia à posse.

Até agora se falou apenas das tutelas jurisdicionais dos direitos que não dependem de sentenças autossuficientes, mas sim de sentenças que necessariamente se relacionam com meios de execução para prestar a tutela do direito material. A distinção entre sentença autossuficiente e sentença não autossuficiente, realizada por doutrina de relevo,²⁷⁸ permite o isolamento das sentenças que não são, por si, suficientes para a tutela dos direitos – porque necessitam de meios de execução para que o direito possa ser efetivamente tutelado –, das sentenças em que a tutela do direito se “exaure frutuosamente”.²⁷⁹ Trata-se da separação entre as sentenças condenatória, mandamental e executiva, de um lado, e as sentenças declaratória e constitutiva, de outro.

Como é evidente, as sentenças declaratória e constitutiva não podem ser enquadradas na classificação das *tutelas dos direitos*, uma vez que, assim como as sentenças condenatória, mandamental e executiva, constituem *técnicas* para a tutela do direito material.

O problema é que, se as tutelas dos direitos podem ser facilmente separadas das sentenças condenatória, mandamental e executiva, o mesmo não acontece quando se está diante das *tutelas* declaratória e constitutiva e das *sentenças* declaratória e constitutiva. Isso porque, se não existe tutela condenatória, mandamental e executiva, há tutela declaratória e tutela constitutiva. Ou melhor: as *sentenças* declaratória e constitutiva prestam *tutelas* declaratória e constitutiva.

Se alguém pode ter, no plano do direito material, direito à tutela pelo equivalente ao valor do

dano ou da obrigação, e, no plano do direito processual, direito à técnica condenatória, isso não significa que não se possa ter direito a uma tutela do direito que possa ser prestada mediante uma sentença satisfativa, cujo nome seja idêntico ao da tutela devida na órbita do direito material.

O fato de não ser possível obrigar alguém a reconhecer uma relação jurídica ou a desconstituir um contrato, ou mesmo a circunstância de não ser possível constituir determinadas situações jurídicas fora da jurisdição, obviamente não interfere no problema,²⁸⁰ pois não descarta a possibilidade de alguém ter direito e pretensão às tutelas declaratória e constitutiva no plano do direito material e, assim, exigir tais tutelas, através da ação, mediante as técnicas processuais das sentenças declaratória e constitutiva.

4.7. A influência da tutela do direito sobre a ação. Vistas as formas de tutela imprescindíveis para que as pessoas possam ser consideradas como titulares de um direito ou de uma posição juridicamente protegida, importa relacioná-las com o direito de ação.²⁸¹

Ter direito a uma forma de tutela do direito é simplesmente ter direito material, pois ninguém tem direito sem ter à sua disposição formas de tutela capazes de protegê-lo diante de ameaça ou de violação. Mas a pretensão à tutela do direito é uma potencialidade, no sentido de que não precisa ser exercida ou reconhecida para ser dita existente.

Todos têm direito à tutela jurisdicional inibitória em caso de ameaça de violação. Do mesmo modo, toda e qualquer pessoa tem direito a ser ressarcida se a sua integridade física for atingida por um ilícito danoso, ou todo titular de um direito obrigacional, em caso de inadimplemento, tem o direito ao cumprimento da obrigação – obviamente quando isso for faticamente possível, ainda que, na outra hipótese, tenha o direito ao equivalente em pecúnia ao valor da prestação obrigacional inadimplida.

Porém, para que o sujeito possa obter uma dessas formas de tutela do direito material, deve exercer o direito de ação. O direito de ação não se confunde com o direito e com a pretensão à tutela do direito, pois essa última é uma potencialidade que, para ser exigida, depende da ação e diante dela pode ser reconhecida ou não.

Quando a ação é proposta, formula-se o pedido e são expostos os fundamentos de fato e de direito que o embasam. O autor, ao realizar o pedido, apresenta a sua pretensão à tutela *jurisdicional* do direito e, no mesmo momento, pede a sentença que reputa capaz de prestá-la, requerendo, por exemplo, tutela inibitória e sentença mandamental (ordem sob pena de multa).

Ao pedir determinada tutela jurisdicional do direito, o autor espera um provimento que, apreciando o mérito, a reconheça. Ou melhor, a pretensão à tutela jurisdicional do direito não se contenta com qualquer sentença de mérito, porém só com a sentença de procedência; a sentença de improcedência não presta tutela jurisdicional *ao direito*.

Daí a distinção entre a ação e a pretensão à tutela jurisdicional do direito. O direito de ação tem como corolários o direito de influir sobre o convencimento do juiz e o direito às técnicas processuais capazes de permitir a efetiva tutela do direito material. É o direito à ação *adequada*, garantido pelo art. 5.º, XXXV, CF. O autor tem o direito de exercer a ação que lhe permita obter – *em sendo o caso* – a tutela jurisdicional do direito. Mas isso não quer dizer que a ação adequada seja dependente da existência do direito material, *uma vez que todos têm direito à ação adequada à tutela do direito, sejam ou não titulares do direito material reclamado*.

Mas, embora a ação seja independente do reconhecimento da pretensão à tutela do direito, é evidente a sua influência sobre aquela. Ao propor a ação, o autor afirma o direito e a existência de uma situação de ameaça ou de lesão. Com base em tais afirmações, que configuram a causa de pedir, pede a tutela do direito (pedido mediato) e a técnica processual (pedido imediato) que reputa adequada à sua prestação. Porém, cabe-lhe demonstrar a relação de adequação dessas afirmações com a tutela do direito e a espécie de sentença reclamadas. Vale dizer que, das afirmações de direito e de lesão ou ameaça, deve logicamente decorrer a tutela do direito solicitada.

A ação adequada é a ação conformada a partir da pretensão à tutela do direito. Ou melhor, assim como existem várias formas de tutela dos direitos – como a tutela inibitória etc. –, devem existir ações adequadas para a viabilização de cada uma dessas tutelas. O ponto mais importante para a construção da ação adequada é o da tutela do direito. Quando, por exemplo, pede-se tutela de remoção do ilícito, a causa de pedir não deve se referir a dano e a culpa, ou mesmo a probabilidade de dano, limitando-se a deixar claro que foi praticado um ato contrário ao direito que produziu efeitos concretos que devem ser removidos. Ou seja, a tutela do direito requer a exposição da causa de pedir que com ela é compatível. Nesse sentido, a causa de pedir e o pedido de tutela do direito têm importância para a *definição dos limites da cognição judicial*, bem como dos pressupostos da técnica antecipatória e da adequação dos meios executivos.

A ação, garantida de forma abstrata e atípica pela Constituição, concretiza-se no momento em que se volta à tutela de uma situação concreta. Como é evidente, essa concretização nada tem a ver com a ideia de proteção concreta ou de ação que requer uma sentença favorável. A concretização aqui reclamada diz respeito à necessidade de a ação se adequar à tutela da situação conflitiva concreta. *Trata-se, em outras palavras, não de abrir mão da ação abstrata e atípica, mas a ela acrescentar o plus, também garantido pela Constituição, de adequação à tutela do direito material e do caso concreto.*

Nessa linha, parece desnecessária e até mesmo forçada a tese de que a ação, quando concretizada, passa a ser uma demanda.²⁸² Se é a demanda, e não a ação, que possui partes, causa de pedir e pedido, e que conduz à obtenção da tutela jurisdicional do direito, não há qualquer diferença entre a ideia de demanda e de *ação adequada*. De modo que se teria de concluir que o direito de ação garante a *demandada adequada*, quando o objetivo da distinção seria apenas o de manter desligado o direito de ação do direito material e do caso concreto.²⁸³ Acontece que, como demonstrado, a separação entre os planos do direito de ação e do direito material, que ninguém mais contesta, não elimina, mas na realidade impõe a aproximação da ação com as tutelas prometidas pelo direito material e com o caso concreto.

A ação garantida pela Constituição concretiza-se a partir da *tutela jurisdicional do direito* que constitui objeto do pedido.²⁸⁴ Vale dizer: *a dimensão da extensão da cognição do juiz, dos limites do debate e da produção probatória, assim como a definição da espécie de sentença e do meio executivo idôneos – que são as características que tornam a ação adequada –, dependem da natureza da tutela do direito.*

4.8. Tutela jurisdicional do direito e tutela jurisdicional. A tutela do direito é prestada, assim como a modalidade de sentença que a deve acompanhar é entregue, apenas quando o juiz reconhece a procedência do pedido de tutela do direito. Na hipótese de improcedência, não se presta – nem se poderia – a tutela do direito. Também por uma razão lógica, a negação da tutela do direito impede a concessão da modalidade de sentença postulada. Ora, se uma espécie de sentença é requerida para permitir a efetividade da tutela do direito, é natural que a não prestação da tutela elimine a possibilidade – e por que não se dizer a necessidade – de se outorgar a sentença solicitada.

Assim, por exemplo, se o pedido de tutela inibitória é julgado improcedente, não se concede uma sentença mandamental. Nessa hipótese, como não há tutela do direito, e sim declaração de que o autor a ela não tem direito, a sentença é declaratória negativa.

A sentença que julga improcedente o pedido não presta tutela do direito ao réu. Isso apenas poderia acontecer se o réu formulasse pedido de tutela do direito (mediante, por exemplo, reconvenção, art. 343, CPC) ou quando houver *contraditório prévio e efetivo* sobre determinada *questão prejudicial* apreciada incidentemente na sentença (art. 503, § 1.º, CPC). Como em regra ele apenas oferece contestação (art. 335, CPC), pleiteando a não concessão da tutela requerida pelo autor, não há como pensar que a sentença de improcedência lhe presta tutela ao direito material.

Porém, há casos – das chamadas “ações dúplices” – em que o simples debate de determinada questão, pela natureza da relação jurídica posta em juízo, e em que o réu pode formular pedido de tutela jurisdicional *do direito* ao invés de simplesmente se defender do pedido feito pelo autor.

Assim, por exemplo, na ação de prestação de contas, na ação possessória e na ação revisional de aluguel. Na ação de exigir contas (arts. 550 e seguintes, CPC), dada a natureza comum da questão posta em juízo, define-se simultaneamente o direito de haver contas e o correlato dever de prestá-las. Nas ações possessórias (arts. 554 e seguintes, CPC), o réu pode, na contestação, além de apresentar defesa ao pedido, formular pedidos de tutela possessória e de tutela ressarcitória em face do autor. Nessa ação o réu não está limitado a poder se defender, tendo a possibilidade de contra-atacar, pedindo a tutela jurisdicional possessória em seu favor. Na ação de reintegração de posse, por exemplo, o réu pode negar o direito do autor à reintegração e, ainda, pedir tutela de manutenção de posse sob o argumento de que a sua posse foi turbada pelo autor. Na ação revisional de aluguel, da mesma forma, o réu pode não apenas se defender do pedido de revisão formulado pelo autor, mas também pedir, em seu favor, a revisão do contrato de aluguel (arts. 68 a 70, Lei 8.245/1991). Se, por hipótese, o autor-locatário pede a redução do valor do aluguel, o réu-locador, além de se defender, argumentando que o aluguel não deve ter o seu valor reduzido, pode ainda pedir que seja estabelecida outra periodicidade ou fixado indexador diverso para o reajustamento do aluguel. Nessas situações excepcionais, em que o réu não apenas se defende, a sentença obviamente pode prestar tutela jurisdicional *do direito ao réu*, negando-a ao autor.

Até aqui se falou de tutela do direito ou de tutela jurisdicional do *direito material*. Contudo, como o autor inegavelmente exerce o seu direito de ação – praticando todos os atos necessários para influir sobre o convencimento do juiz e tendo à disposição todas as técnicas processuais capazes de lhe permitir alcançar a tutela de direito almejada – ainda que a sentença seja de improcedência, é evidente que essa sentença lhe presta *tutela jurisdicional*, não importando se não concede a *tutela do direito*. Em outras palavras, é preciso ter presente a distinção entre *tutela jurisdicional* e *tutela do direito*.

Ou seja, o juiz, ao proferir a sentença, qualquer que seja o seu resultado, necessariamente confere tutela jurisdicional ao autor e ao réu. A sentença de improcedência dá *tutela jurisdicional* ao autor e ao réu. A sentença de procedência presta a *tutela jurisdicional do direito* solicitada pelo autor e *tutela jurisdicional* ao réu.

Vale dizer que não se aceita aqui a ideia de que a tutela jurisdicional somente é outorgada pela sentença favorável ou a afirmação de que a tutela jurisdicional apenas é concedida quando a sentença é procedente. A *tutela jurisdicional* é a resposta da jurisdição ao direito de participação em juízo das partes – é ao mesmo tempo a resposta e a norma de encerramento do direito ao processo justo das partes. Mas o juiz apenas presta a *tutela jurisdicional do direito* quando a sentença é de procedência. Isso porque a tutela jurisdicional é a *preordenação* de um processo justo, substancializado pelo direito de participação das partes em juízo, pelas técnicas processuais adequadas para a condução do processo e por todos os direitos fundamentais que o compõem, e é também a *resposta* da jurisdição ao direito de ação, mas não é *reconhecimento* de que uma das partes tem razão do ponto de vista do direito material.

Perceba-se que para uma necessidade de direito material há uma forma de tutela idônea (p. ex., ressarcimento pelo equivalente). Com o exercício da ação, essa forma de tutela é requerida mediante o pedido, que também indica uma sentença adequada (p. ex., condenação). Porém, a tutela do direito somente é concedida, e a sentença requerida outorgada, quando o pedido de tutela é acolhido, isto é, quando a sentença é de procedência – nesse caso há tutela jurisdicional do direito. Contudo, a forma de tutela do direito solicitada, muito mais do que apontar para a sentença devida, constitui a base para a construção da ação adequada. Dito de outro modo, o pedido de tutela do direito é *parâmetro* que permite tornar o processo rente às necessidades do direito material, viabilizando a sua adequação ao caso concreto.

4.9. O exercício da ação para a obtenção da tutela do direito. Ao propor a ação, o autor formula o pedido, afirmando a pretensão de tutela jurisdicional do direito. Porém, após apresentar o pedido, *o autor continua atuando, ou seja, prossegue exercendo poderes e faculdades com o fim de convencer o juiz da existência do direito material e com a finalidade de obter a tutela do direito*.

O autor, ao exercer tais poderes e faculdades, pratica atos processuais concretos, fazendo alegações, produzindo provas, participando de audiências, tudo com a finalidade de obter o

reconhecimento da sua pretensão à tutela jurisdicional do direito. Mas o exercício da ação também se estende a eventual requerimento de tutela satisfativa ou cautelar mediante provimentos provisórios de cognição sumária (arts. 294 e seguintes, CPC), pois mediante a sua concessão se antecipa a tutela do direito material ou se assegura a possibilidade de sua obtenção ao final do processo. Da mesma forma, a utilização de meio executivo adequado igualmente é imprescindível para a efetiva prestação da tutela jurisdicional do direito. Ou melhor, o exercício da ação, além de implicar prática de atos voltados a *influir sobre o convencimento* do julgador (exercício do *direito ao contraditório* e do *direito à prova*, arts. 7.º, 9.º e 10, CPC) e de *viabilizar o controle sobre a sua correção* (*dever de fundamentação como dever de diálogo judicial*, arts. 11 e 489, § 1.º, IV, CPC), concretiza-se no uso de técnicas processuais capazes de propiciar a efetiva tutela do direito material.

Deixe-se claro, porém, que, se o autor exerce a ação para obter a tutela jurisdicional do direito, isso não quer dizer que a sentença que não reconhece a pretensão a tal tutela deixa de responder ao direito de ação. Como demonstrado nos dois itens antecedentes, o direito à ação adequada não depende do reconhecimento do direito material.

Contudo, nessa nova perspectiva em que a ação é vista, surge uma nova questão, cuja solução pode impor a negação de validade, diante da atual realidade normativa brasileira, de todas as teorias que até o momento trataram da ação. O problema, em poucas palavras, consiste em saber *se o direito de ação é apenas o direito a uma sentença de mérito*.

Há alguns anos, quando as sentenças se resumiam a declarar, constituir e condenar (classificação trinária), a única sentença que não era bastante à tutela jurisdicional do direito era a condenatória. A sentença condenatória não prestava tutela ao direito material, restringindo-se a exortar o réu a observar o direito do autor. A condenação, ao impor a sanção executiva, abria oportunidade à propositura da ação de execução, fazendo surgir uma artificial necessidade de duas ações para a obtenção de apenas uma forma de tutela jurisdicional do direito (uma ação condenatória seguida de uma ação executiva, cada qual dando lugar a diferentes processos, para obtenção da reparação de um dano, por exemplo).

Como é óbvio, ninguém possui, no plano do direito material, pretensão à tutela condenatória. Aliás, tal suposição, por si só, é uma heresia, pois a sentença condenatória não é uma forma de tutela do direito. Há contrariedade entre sentença e forma de tutela. A sentença é uma técnica processual a serviço da efetiva prestação da tutela do direito. Ou seja, assim como técnica processual e tutela dos direitos estão em campos distintos, sentença e tutela dos direitos não têm a mínima condição de se misturar na mesma massa, porque simplesmente pertencem a planos distintos.

A pessoa, no plano do direito material, pode ter pretensão à tutela ressarcitória, mas jamais pretensão à tutela condenatória. Contudo, justamente porque aquele que tem pretensão à tutela ressarcitória pode exercer pretensão à tutela *jurisdicional* ressarcitória, não há racionalidade em lhe dar o direito de obter apenas uma sentença condenatória. Como essa sentença não é capaz de proporcionar o alcance da tutela ressarcitória, a ação que culmina na sentença condenatória é uma ação inefetiva, mutilada, caduca ou “pela metade”, estando muito longe de ser uma ação adequada à tutela do direito material.

A doutrina processual clássica construiu a necessidade de duas ações (ação condenatória + ação de execução) para a obtenção de uma única forma de tutela prometida pelo direito material. A sentença condenatória foi vista como uma resposta ao direito de ação em razão de uma forma equivocada de se relacionar a técnica processual com a tutela dos direitos. O direito de ação não pode se contentar com a condenação, uma vez que essa, na hipótese de não ser adimplida pelo réu, exige a prática de atos de execução capazes de permitir a tutela do direito. Ou melhor, a pretensão ao ressarcimento pelo equivalente não é satisfeita pela condenação, razão pela qual a ação que a veicula deve prosseguir para permitir o alcance da tutela do direito material. *Frise-se que a pretensão à tutela do direito pode ser satisfeita apenas quando o réu observa voluntariamente a sentença condenatória, o que equivale a dizer que não é a sentença que presta a tutela do direito*. É por essa razão, a propósito, que o Código de 2015 disponibilizou um *procedimento ordinário* – que

é o nosso *procedimento padrão* para a tutela jurisdicional dos direitos – cujo início ocorre com a *propositura da ação* e cujo fim tendencialmente se dá com a realização do direito reconhecido na sentença mediante o seu *cumprimento*.

A necessidade de duas ações para o alcance de uma única tutela de direito foi negada pelo Código de 2015. As sentenças que reconhecem a exigibilidade das prestações de fazer, de não fazer e de entrega de coisa têm executividade intrínseca (arts. 536 e 537, CPC), ao passo que a sentença que reconhece a exigibilidade do dever de pagar quantia certa depende apenas de requerimento, dispensando a ação de execução (art. 513, § 1.º, CPC). Tais sentenças, embora não autossuficientes – como as sentenças declaratória e constitutiva – viabilizam o próprio *cumprimento* no mesmo processo em que prolatadas.

Portanto, considerando-se a teoria da ação, é importante deixar claro que *a ação não se exaure com a sentença de procedência* e, por isso, *o direito de ação não pode mais ser visto como direito a uma sentença de mérito*. Frise-se que, se a sentença não é voluntariamente adimplida, “*a ação continua a ser exercida*” em nome do alcance da “*tutela do direito material*”. *O juiz ao prolatar a sentença de mérito não cumpre e acaba o ofício jurisdicional – o seu ofício termina apenas quando essa é devidamente cumprida.*

O direito de ação é o direito à ação “*capaz de permitir*” a *obtenção da tutela do direito*. Por ser o direito a uma ação “*capaz de permitir*”, o direito de ação não exige uma sentença de procedência ou que a execução satisfaça o direito material. Nesse sentido, é um *direito abstrato* e não um *direito concreto*. Trata-se do direito a uma ação que, *na hipótese de sentença de procedência, permita o uso dos meios executivos capazes de propiciar a efetiva tutela do direito material*.

Por isso mesmo, não há como pensar em julgamento da ação. O que se julga, como é evidente, é a pretensão à tutela jurisdicional do direito. A ação é exercida para permitir o julgamento do pedido e o reconhecimento da pretensão à tutela jurisdicional do direito, assim como para exigir o uso dos meios executivos capazes de propiciar a obtenção da tutela do direito reconhecida pela sentença como devida ao autor. *A ação é meio – meio adequado à tutela da situação carente de proteção evidenciada pelo caso concreto.*

4.10. O direito de ação como direito ao procedimento próprio à participação e ao plano do direito material. O direito de ação como direito ao processo justo. Como a ação exige técnicas processuais capazes de permitir a tutela do direito material, e por isso não há mais como submetê-la ao princípio da tipicidade das formas processuais, é chegado o momento de iniciar a investigação da relação de adequação entre a ação e as tutelas jurisdicionais dos direitos.

Neste momento importará o direito ao procedimento, compreendido como via capaz de garantir os direitos à participação e à efetividade do direito material. Vale dizer: como direito ao processo justo (art. 5.º, LIV, CRFB). Objetiva-se demonstrar que o autor tem o direito de *participar* de forma plena no processo – influenciando sobre o convencimento do juiz, atuando para obter a tutela do direito e controlando a racionalidade da atividade estatal – e, por consequência, o direito ao procedimento *idôneo às necessidades do direito material*.

A participação efetiva tem relação com a possibilidade de alegar, provar, participar da produção da prova, falar sobre o seu resultado e controlar a racionalidade da resposta ao pedido de tutela jurisdicional do direito. O direito de participar – que cabe ao autor através da ação e ao réu da defesa – está ancorado na ideia de que, quando se objetiva uma decisão estatal, é imprescindível abrir aos interessados a oportunidade à participação, direito que decorre da própria noção de democracia, ou melhor, de legitimação do poder mediante a participação democrática.

Essa possibilidade de participação é outorgada ao autor e ao réu mediante o que se denomina *direito ao contraditório*, que nada mais é do que o direito que confere às partes a possibilidade de atuar no processo com o objetivo de obter uma tutela jurisdicional, dialogando ao longo de todo o procedimento com o juiz a fim de influir nos rumos do processo e no conteúdo da decisão judicial.

O contraditório é garantido no art. 5.º, LV, CF, que diz que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos *acusados* em geral são assegurados o contraditório e *ampla defesa*, com os meios e recursos a ela inerentes”. Como o contraditório é um direito que pertence às partes, é equivocada a sua expressão nos termos ditados, como se tivesse maior importância ao réu ou vínculo mais intenso com a defesa. Note-se que o art. 5.º, LV, CF, alude a “meios e recursos *a ela [defesa]* inerentes”.

Na verdade, o contraditório não se liga apenas à defesa, mas sim à possibilidade, conferida a ambas as partes, de influir sobre o desenvolvimento e o resultado do processo.²⁸⁵ Ou seja, deriva do contraditório o direito ao uso dos meios adequados para influir sobre o convencimento do juiz, como os meios de prova. Fala-se, nessa dimensão, em direito à prova, reconhecido no direito estadunidense como *right to evidence*.²⁸⁶ Ainda, rigorosamente, o direito ao contraditório, embora seja titularizado pelas partes, tem como *destinatário* o próprio juiz, que tem o *dever de dialogar* com as partes e de decidir levando em consideração apenas o material fático-jurídico já submetido ao debate processual (art. 10, CPC) – isso quer dizer que o juiz é um dos *sujeitos* do contraditório. O juiz em um processo pautado pela *colaboração* é um juiz que o conduz em uma *posição isonômica* pelo diálogo com as partes, ocupando uma *posição assimétrica* apenas no momento em que decide e impõe a tutela jurisdicional (art. 6.º). O fato de o juiz ser destinatário do direito ao contraditório autoriza a sua inserção como um dos seus sujeitos – ele é *parte* no contraditório justamente porque *participa* do diálogo em que esse se consubstancia no processo.²⁸⁷

Embora a norma constitucional garantidora do contraditório aluda a “meios” e “recursos” inerentes à *defesa*, o certo é que o direito à prova e o direito ao recurso podem ser limitados em face de certas situações.

O direito à participação no processo e suas decorrências incidem sobre o legislador, obrigando-o a traçar normas que deem às partes oportunidade de participar, o que não quer dizer, como é óbvio, que essa participação deva ser ilimitada. O direito à participação no processo incide sobre o legislador ainda a fim de viabilizar ao juiz adequada participação no processo, instrumentalizando-o com poderes que abram oportunidade para a efetiva tutela dos direitos. Nessa perspectiva, os arts. 5.º, 6.º, 7.º, 9.º, 10, CPC, entre outros, constituem respostas do legislador ao seu dever constitucional de desenhar uma ação capaz de outorgar tutela adequada, efetiva e tempestiva mediante processo justo – isto é, mediante um processo capaz de viabilizar uma *participação equilibrada* de todos os seus sujeitos.

Ademais, o direito ao contraditório e seus corolários igualmente incide sobre o juiz, que tem o dever de interpretar os dispositivos processuais à luz do direito de ação como direito ao processo justo – vale dizer, como direito capaz de permitir a adequada participação das partes e a adequada percepção do seu próprio papel na direção do processo.

Porém, quando se pensa na incidência da garantia de participação sobre o juiz ou no caso concreto, torna-se evidente a necessidade de vincular o direito de participação com a situação de direito material. A aferição do direito de participação no caso concreto deve ser feita a partir da tutela jurisdicional *do direito* almejada, sendo esse o seu parâmetro de adequação.

O *autornão* tem o *ônus de fazer alegações e produzir provas* sobre pontos que não importam para o juiz se convencer de que a tutela do direito deve ser concedida. Mas, para que a tutela do direito possa ser efetivamente prestada, também *não se pode permitir ao réu alegar e provar* em torno de questões não relativas à situação de direito substancial objeto de tutela, o que afasta do juiz, por consequência lógica, a possibilidade de conhecê-las, *gerando-lhe o dever de não conhecer de alegações impertinentes e de proibir a produção de provas ao seu redor* (art. 370, parágrafo único, CPC).

A restrição da cognição judicial às questões que dizem respeito à espécie de tutela do direito ambicionada em juízo é fundamental para a efetividade das tutelas dos direitos e ponto a ser observado para o delineamento dos procedimentos especiais. Determinadas formas de tutela do direito necessitam de procedimentos que excluam a discussão de certos pontos, sob pena destes serem utilizados para impedir a obtenção da própria tutela.

Assim, por exemplo, o procedimento da ação possessória, ao impedir o réu de se defender alegando questões relativas ao domínio, constitui um procedimento cuja cognição judicial fica restrita ao terreno da posse (art. 557, CPC). Entende-se que o réu não pode se defender alegando o domínio, pois se isso fosse viável não seria possível outorgar efetividade à tutela jurisdicional da posse. O mesmo se passa atualmente com a ação que visa à prestação da tutela inibitória ou da tutela de remoção do ilícito no procedimento comum: em ambos os casos, diz acertadamente o parágrafo único do art. 497 que “para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo”.

A ação de remoção, ainda que posterior à prática do ato contrário ao direito, não obriga o autor a alegar dano e culpa, pois através dela não se objetiva obter ressarcimento, mas somente a remoção dos efeitos concretos do ato ilícito (não danoso). Porém, justamente porque não importa se o ato ilícito provocou dano é que se impede o réu de alegar que isso não ocorreu ou poderá ocorrer e, por consequência, também ao juiz de indagar ou determinar prova sobre a questão do dano e da culpa.

A restrição da possibilidade de discussão de uma questão é legítima quando necessária para permitir a tutela jurisdicional que decorre do direito material. A tutela jurisdicional de remoção do ilícito deflui da norma de direito material que proíbe a prática de determinada conduta – por exemplo, a norma que proíbe a venda de produto nocivo à saúde do consumidor. Como da razão de ser dessa norma – do seu desejo de dar proteção ao direito do consumidor – decorre a necessidade de remover os efeitos concretos do ilícito, e para tanto importa apenas saber se a norma foi agredida, e não se a violação da norma gerou dano ou o fato danoso – que é uma consequência meramente eventual do ilícito (ato contrário ao direito) –, é evidente que o juiz, para prestar a tutela jurisdicional prometida pelo próprio direito material, não pode permitir o debate sobre o dano e a culpa, lembrando-se, aliás, que essa última é apenas um critério para a imputação da sanção ressarcitória ou para a definição da responsabilidade pelo dano, e, assim, não tem relevância quando se deve ter em conta apenas o ato contrário ao direito.

Portanto, a restrição da possibilidade de *discussão* não implica, por si só, lesão ao direito de participação. *Ao contrário, admitir que o processo seja congestionado por questões múltiplas, sem nenhuma conexão com a tutela jurisdicional pretendida e seus pressupostos, é que impede que a jurisdição seja exercida de modo a cumprir com a sua missão diante do direito material.* Daí a legitimidade da restrição no debate nas ações que visam à tutela inibitória e à tutela de remoção do ilícito.

4.11. O direito à técnica processual adequada à tutela do direito e ao caso concreto. O direito de ação tem como corolário o direito às técnicas processuais adequadas à tutela das várias necessidades do direito material. Entre essas técnicas estão não só os procedimentos construídos para permitir o acesso da população economicamente menos favorecida à jurisdição (Leis dos Juizados Especiais – Leis 9.099/1995, 10.259/2001 e 12.153/2009)²⁸⁸ e os procedimentos voltados à tutela de específicas situações de direito substancial (p. ex., procedimentos das ações possessórias) e dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos (p. ex., Lei da Ação Civil Pública e Código de Defesa do Consumidor, Título III),²⁸⁹ mas especialmente as técnicas de distribuição do ônus da prova (art. 373, CPC), as técnicas de antecipação da tutela (arts. 294 e seguintes, CPC),²⁹⁰ as técnicas de julgamento imediato do pedido no todo ou em parte (arts. 355 e 356, CPC), as sentenças diferenciadas (mandamental e executiva, arts. 139, IV, 497 e 498, CPC) e os vários meios de execução (multa, busca e apreensão e outros, arts. 139, IV, 536, 537 e 538, CPC).

É preciso levar em consideração as *peculiaridades do caso concreto* para se distribuir de forma adequada o ônus da prova. Existem basicamente duas maneiras de fazê-lo: de maneira *fixa* e de maneira *dinâmica*. O Código de 2015 alça mão dessas duas técnicas de distribuição (art. 373, *caput*, e § 1.º). Partindo-se da presunção de que normalmente quem alega determinado fato tem melhor acesso às fontes de prova, a regra no processo civil brasileira é a da *distribuição fixa do ônus da prova*, tradicional em nosso processo civil: quem alega tem o ônus de provar (art. 373, distribuição que pode ser objeto de *inversão* quando presentes determinados pressupostos legais, artigo 6.º, VIII, CDC). Pode ocorrer, porém, dessa presunção não se verificar e de a parte que alega o fato não

ter acesso às fontes de prova, que de outro lado são facilmente acessíveis à parte contrária. Nesse caso, o juiz deve aplicar a regra da *distribuição dinâmica do ônus da prova*, que parte justamente do pressuposto que a prova das alegações incumbe a quem tem melhores condições de provar (art. 373, § 1.º).

De outra parte, é preciso considerar que o tempo necessário para o juiz apurar a verdade das alegações de fato e formar a sua convicção pode obstaculizar a efetiva tutela do direito material. A antecipação da tutela contra o perigo derivado da demora do processo objetiva propiciar a efetividade da tutela preventiva (inibitória), isto é, da tutela que tem por fim evitar a violação do direito, assim como a efetividade das próprias tutelas posteriores ao ato contrário ao direito (de remoção do ilícito) e ao dano (ressarcitória).

É interessante destacar que, antes da Constituição de 1988, a ideia de que o direito de ação garantia o direito à tutela preventiva não era clara. Ou ao menos não se admitia que as liminares cautelares ou de determinados procedimentos especiais, como a do mandado de segurança, constituíam manifestações imprescindíveis à realização do direito de ação.

Aliás, essa posição chegou a ser expressa pelo Supremo Tribunal Federal mesmo após a Constituição de 1988, o que torna a questão ainda mais nebulosa. Torna-se importante fazer referência à celebre ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a medida provisória – depois transformada em lei – que proibiu a concessão de liminar e a execução provisória nas ações cautelares e nos mandados de segurança cujos pedidos se voltassem contra o plano de estabilização econômica instituído pelo Governo Collor, que impediu que fossem feitos saques acima de determinada quantia nas contas correntes e de poupança.

O Supremo Tribunal Federal não concedeu a liminar – que objetivava a suspensão dos efeitos dessa medida provisória – requerida na ação direta de inconstitucionalidade, argumentando que a solução do problema estaria no manejo do sistema de controle difuso da constitucionalidade, deixando-se ao juiz a possibilidade de controlar a constitucionalidade da medida provisória diante das circunstâncias do caso concreto. Embora essa solução não nos pareça acertada, o que importa, nesse momento, é outro aspecto da questão, expressamente consignado no voto proferido pelo Min. Moreira Alves, nesses termos: “A inovação que a atual Constituição introduziu no inciso XXXV do artigo 5.º [alusão expressa à ameaça a direito: ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’] dificilmente poderá levar à conclusão de que a lei não poderá restringir a utilização de medidas liminares porque, com isso, se estaria suprimindo parcialmente uma das espécies de processo (o processo cautelar) e, portanto, de certa maneira, excluindo da apreciação do Poder Judiciário a ameaça ao direito. Com efeito, para que não houvesse dúvida de que a vedação da exclusão da apreciação por parte do Poder Judiciário alcançava não apenas o direito já violado (lesão de direito), mas também o direito apenas ameaçado (o que dá margem inclusive a ações como as de mandado de segurança, declaratória, relativas à ameaça à posse, para aqueles que consideram esta como direito, ações essas que não pertencem ao âmbito do processo cautelar), esse inciso da atual Constituição mencionou, expressamente, a ameaça a direito. Mas, com isso, teria impedido que se restringisse o uso de medidas liminares ou de procedimentos especiais outros, desde que não se obstasse a que, *no mínimo por ação ordinária*, o Poder Judiciário apreciasse lesão ou ameaça a direito, pois o que é vedado é excluir de apreciação, é eliminar, não admitir, privar, *o que não sucede, evidentemente, se por meio ordinário se admite tal apreciação*”.²⁹¹

A ideia que parecia evidente ao Min. Moreira Alves é insustentável na atualidade. Afirmou o Ministro que com o art. 5.º, XXXV, “*o que é vedado é excluir de apreciação, é eliminar, não admitir, privar, o que não sucede, evidentemente, se por meio ordinário se admite tal apreciação*”. Ora, a norma do art. 5.º, XXXV, não teve apenas a finalidade de proibir a exclusão da apreciação de lesão e de ameaça a direito, mas especialmente o objetivo de outorgar ao cidadão o direito às técnicas necessárias para que a sua ação possa viabilizar a efetiva tutela do direito material. Ou seja, como a norma constitucional não apenas garante o cidadão contra a possibilidade de exclusão, mas essencialmente o seu direito à tutela jurisdicional efetiva, a interpretação conferida pelo Min. Moreira Alves ao art. 5.º, XXXV, está muito longe da concepção contemporânea de ação.

O raciocínio é muito simples: se a ação deve garantir a proteção jurisdicional contra a ameaça de violação, e a sentença ou a tutela final – ou ainda o “meio ordinário”, como prefere o Min. Moreira Alves – *não é capaz de tempestivamente propiciar a apreciação da afirmação da ameaça*, uma vez que se teme que o ilícito seja praticado de forma iminente e, portanto, *antes que se possa chegar ao fim do processo ou à sentença*, é pouco mais do que evidente que a única forma de se permitir a proteção jurisdicional contra a ameaça se dá mediante liminar ou mais precisamente através da técnica da antecipação da tutela (art. 294 e ss., CPC).

Contudo, a técnica da antecipação fundada em perigo não é necessária apenas para dar ao juiz oportunidade de apreciar a ameaça de lesão de modo tempestivo, mas também para permitir a tempestividade da tutela de remoção do ilícito e até mesmo da tutela ressarcitória.

A remoção do ilícito é necessária quando um ato ilícito produz efeitos que se prolongam no tempo, como ocorre no caso de exposição à venda de produto nocivo à saúde do consumidor. A tutela de remoção se volta contra a conduta que viola a norma, mas não produz dano, sendo imprescindível para atuar o desejo de proteção da norma violada, exatamente o de evitar a prática da conduta presumida pela norma como capaz de produzir dano. Como a prática de uma conduta proibida pode trazer danos imediatos, não há como esperar o término do processo para se obter a apreciação da afirmação de violação da norma, restando a técnica antecipatória como única alternativa para a tempestividade da tutela jurisdicional.

Já a antecipação do ressarcimento na forma específica poderá ser necessária para evitar o agravamento do dano que se busca ressarcir através da ação. Assim, por exemplo, quando alguém polui um rio e o dano pode aumentar com o passar dos dias e das horas.

De outra parte, o ressarcimento do dano pelo equivalente, ou seja, a antecipação de soma em dinheiro em ação ressarcitória, não poderá ser descartada quando o autor precisar imediatamente de verba alimentar – alimentos indenizatórios – para suprir uma necessidade primária, seja relativa à saúde, seja ao sustento pessoal ou dos filhos.

Por sua vez, a tutela cautelar tem a finalidade de assegurar a efetividade da *eventual* tutela final do *direito*. Tal tutela é necessária para garantir que a *eventual tutela do direito* seja prestada de forma efetiva ao final do processo.

Por outro lado, a técnica de antecipação da tutela com base em abuso do direito permite a distribuição do ônus do tempo do processo, impedindo que esse corra em prejuízo do autor e em benefício do réu. Essa técnica não se relaciona com o perigo de dano em razão da demora, mas apenas com o ônus do tempo.

A norma que trata da tutela antecipatória em caso de abuso do direito de defesa viabiliza a distribuição do ônus do tempo do processo de acordo com a tradicional regra que divide o ônus da prova, considerando os fatos constitutivos e os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Isso quer dizer que, se o autor se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos, mas o processo deve prosseguir para elucidar uma defesa *infundada* que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo, não há racionalidade em obrigar o autor a continuar suportando o ônus do tempo do processo. Em um caso como esse, a tutela deve ser antecipada, pois o tempo para a produção de prova, em nome de uma defesa indireta infundada, constitui uma dilação desarrazoada. Se, após a produção da prova, a defesa de mérito indireta for acolhida, a tutela antecipada será revogada.

Note-se que, como também ocorre com as sentenças e meios executivos, *a técnica antecipatória possui íntima ligação com o plano do direito material e com as particularidades do caso concreto*.

A tutela antecipatória contra o perigo de dano exige que o juiz se convença da probabilidade do direito. Porém, essa só pode ser *identificada com base na tutela pretendida e nos fundamentos invocados para a sua obtenção. De modo que o direito de obter a antecipação da tutela não se contenta com a mera constatação de probabilidade ou de “fumus boni iuris”, como se uma ou outro fossem destituídos de conteúdo. A probabilidade somente pode ser compreendida a partir das diferentes necessidades do direito material (tipos de tutela e variedade dos seus pressupostos)*.

Ou seja, a tutela antecipatória contra o perigo requer a compreensão da natureza da tutela que se deseja antecipar e dos pressupostos invocados para a sua obtenção. A urgência necessária para a antecipação impõe a análise da tutela requerida no plano do direito material (inibitória ou de remoção do ilícito, por exemplo) e dos seus fundamentos (seguindo-se o exemplo, probabilidade de vir a ser praticado ato contrário ao direito ou probabilidade de ter sido praticado ato contrário ao direito).

Diante dessas considerações, torna-se claro que a antecipação da tutela deve ser analisada a *partir da natureza da tutela de direito* requerida através da ação, e não como se fosse uma simples técnica de aceleração do processo, indiferente ao plano do direito material.

Por outro lado, a própria noção de “urgência” (art. 300, CPC) evidencia a característica de “adequação concreta” da técnica antecipatória, pois dá ao autor o poder de requerê-la *conforme as necessidades* do caso conflitivo. Na verdade, as noções de “urgência” e de “evidência” apontam em si mesmas *para uma necessidade de atribuição de significado posterior, diante do caso concreto*. Ou melhor, ainda que tais noções possam ser dotadas de significado em abstrato – pois se pode conceituar o que é fundado na urgência ou na evidência –, *elas somente servem para permitir a identificação de uma ocorrência no caso concreto*. Nesse sentido, portanto, *tais conceitos podem ser vistos como de significado a ser concretizado*.

Contudo, é importante frisar que tais técnicas não apenas contêm conceitos indeterminados, *mas podem ser utilizadas diante de qualquer situação conflitiva concreta*. Nesse sentido, a técnica antecipatória é atípica.

Uma técnica de antecipação da tutela, em tese, pode se valer das expressões “perigo de dano”, “perigo na demora” ou “ineficácia do provimento final”, porém fazer parte de um procedimento especial, reservado para uma específica situação de direito substancial. Nesse caso, a técnica antecipatória, ainda que dependente das circunstâncias do caso concreto, somente pode ser utilizada em face da situação de direito substancial própria ao procedimento especial que a instituiu.

Tal técnica antecipatória, entretanto, não é uma resposta ao direito à técnica processual adequada ao caso concreto, já que não pode ser utilizada para dar efetividade *a qualquer ação, mas apenas à ação que pode ser estruturada com base no procedimento especial que prevê a possibilidade de antecipação da tutela*. Note-se que a restrição da tutela antecipatória, ou a sua instituição em um procedimento especial, *de certa forma retoma a ideia de ação típica, já que o legislador passa a viabilizar a oportunidade de antecipação da tutela apenas para determinada situação de direito substancial*.

Isso não quer dizer que a instituição de procedimento especial não seja algo adequado para determinadas situações de direito material. O procedimento da ação de reintegração de posse, por exemplo, prevê a possibilidade de liminar, mas deixa claro que ela independe de qualquer alegação de receio de dano. Nesse caso, a previsão da possibilidade de antecipação da tutela, independentemente de perigo de dano, *decorre das particularidades da própria situação de direito substancial, que impõem um procedimento especial*.²⁹²

Porém, a *ação atípica* – capaz de dar proteção a qualquer situação – apenas tem sentido quando conjugada às técnicas processuais capazes de permitir a efetiva tutela do direito material. Vale dizer: *técnicas processuais igualmente atípicas*. Assim, não há racionalidade em viabilizar a liminar no mandado de segurança, instituído para a tutela dos direitos ameaçados ou violados por *ato de autoridade pública*,²⁹³ e a negar no procedimento em que se busca a tutela dos direitos ameaçados ou violados por *ato de particular*. A lógica do mandado de segurança somente teria sentido em uma dimensão em que importassem apenas os direitos de liberdade e fossem temidos somente os atos do Estado. Acontece que, na sociedade contemporânea, aqueles que frequentemente ameaçam ou violam os direitos fundamentais – como o direito ambiental e o direito do consumidor, por exemplo – são os sujeitos privados. Contra eles, portanto, deve haver a possibilidade de serem utilizadas técnicas tão eficientes quanto aquelas previstas no procedimento do mandado de segurança.²⁹⁴

As alegações de fato formuladas no processo pelas partes podem também se caracterizar do ponto de vista do comportamento das partes ou do ponto de vista probatório de diferentes maneiras, o que pode determinar a necessidade de adequação concreta do processo para bem atendê-las. A desnecessidade de prova diversa da documental para o julgamento do feito – ou mesmo a desnecessidade de qualquer prova para tanto – pode determinar o julgamento imediato do pedido (art. 355, CPC). Pode ocorrer, igualmente, que apenas parte da causa esteja madura para julgamento, enquanto o restante depende ainda de prova para o esclarecimento das alegações de fato. Nesse caso, é certamente injusto do ponto de vista da gestão temporal do processo fazer com que a parte espere para ver julgado aquilo que já se encontra *incontroverso*, atrelando-se necessariamente o seu enfrentamento ao amadurecimento da causa como um todo.²⁹⁵ Por essa razão, o Código de 2015 viabiliza a tutela definitiva da parcela incontroversa da demanda, abrindo oportunidade para um julgamento parcial de procedência do pedido ou de parcela do pedido (art. 356, CPC).

O juiz, mediante a sentença, aprecia o pedido do autor e, ao reconhecê-lo como procedente, presta a tutela jurisdicional *do direito material*. As sentenças se diferenciam exatamente para possibilitar a adequada e efetiva prestação da tutela jurisdicional dos direitos, classificando-se em declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental e executiva.

O autor requer a sentença declaratória quando necessita obter, como bem jurídico, a declaração da existência, da inexistência ou do *modo de ser* de uma relação jurídica, porque pairava sobre ela uma situação de incerteza ou dúvida objetiva.

A sentença constitutiva cria, modifica ou extingue uma situação jurídica. Por isso é dita positiva e negativa – essa última também chamada de desconstitutiva. A sentença que interdita o demente é constitutiva positiva, ao passo que a sentença que anula um contrato é constitutiva negativa.

A mera prolação das sentenças declaratória e constitutiva é suficiente para atender ao direito material, ao passo que as sentenças condenatória, mandamental e executiva se ligam a meios executivos, visando com isso à tutela do direito.

A sentença condenatória impõe o cumprimento de uma prestação de pagar quantia, abrindo oportunidade para o autor requerer a execução no caso do seu inadimplemento. A sentença de condenação, ao determinar o cumprimento, já cria os pressupostos que viabilizam a sua execução. Em razão da sentença condenatória, a jurisdição fica autorizada a praticar atos executivos, o autor fica investido do poder de requerer a execução e o réu fica submetido ao poder executivo da jurisdição. A executividade da sentença condenatória é *extrínseca*, justamente porque apenas permite a adoção das técnicas executivas para a obtenção da tutela do direito.

Outras sentenças, embora também dependentes de meios executivos, têm *executividade intrínseca*, ou seja, *prestam a tutela do direito* mediante determinada modalidade executiva. Basicamente, essas modalidades executivas podem atuar sobre a vontade do demandado, visando *convencê-lo* a cumprir, *ou substituir* a sua vontade, atuando em seu lugar para que a tutela do direito seja prestada. Vale anotar, como exemplos, a multa – que visa convencer ao adimplemento – e o desfazimento de obra – que remove algo que não deveria ter sido feito (arts. 536 a 538, CPC).

As sentenças de executividade intrínseca são ditas mandamental (atuam sobre a vontade mediante meios como a multa) e executiva (substituem a vontade mediante meios como a busca e apreensão e o desfazimento de obra). Embora as duas sentenças não sejam autossuficientes – como as sentenças declaratória e constitutiva – e tenham executividade intrínseca, a sentença mandamental atua para convencer o demandado e a sentença executiva de modo a substituir a sua própria vontade.

As sentenças de executividade intrínseca, embora no atual sistema processual possam se relacionar com o inadimplemento de prestações obrigacionais, têm o seu devido lugar diante dos deveres legais. Quem viola dever legal de não fazer ou de fazer não se torna devedor de uma prestação em face da sentença de procedência. A sentença que reconhece dever de fazer ou não fazer deve atuar para eliminar os efeitos concretos deixados pelo fazer ou não fazer ilícito, sem ter

que *condenar* o demandado a remover o ilícito ou a desfazer algo que não deveria ter feito. O mesmo ocorre diante dos direitos reais. A sentença que julga procedente a ação de reintegração de posse não faz do esbulhador um devedor de prestação de entrega de coisa. Daí porque a sentença deve determinar a reintegração, a ser cumprida por oficial de justiça.

A tutela jurisdicional do direito, com o passar do tempo, *tornou-se cada vez mais execução e menos declaração*. A sentença condenatória não contém execução – é uma declaração que abre oportunidade à execução. Trata-se, assim, de técnica processual que constitui uma fase da tutela jurisdicional do direito. Ao contrário, as sentenças mandamental e executiva prestam a tutela do direito. Ao impor a multa para evitar a violação de direito, a sentença mandamental presta tutela inibitória. A sentença executiva, ao determinar busca e apreensão para a remoção da situação ilícita, presta tutela de remoção do ilícito.

Por todas essas razões que se está falando em direito à tutela jurisdicional adequada ao caso concreto. A ação atípica e abstrata apenas poderá constituir um direito capaz de dar efetividade ao direito material, deixando de ser uma mera proclamação retórica, caso permita ao autor, durante o seu exercício, a utilização das técnicas processuais adequadas à situação concreta.

É por isso que o direito de ação depende da possibilidade do uso de técnicas adequadas de distribuição do ônus da prova, de técnicas de antecipação de tutela, de julgamento imediato do pedido no todo ou em parte, das sentenças e dos meios executivos idôneos *qualquer que seja a situação conflitiva concreta*.

4.12. O direito à construção da ação adequada ao caso concreto. A ação é um direito que concentra uma série de posições jurídicas, como o direito de influir sobre o convencimento do juiz, para que o direito material seja reconhecido e realizado. A ação, muito mais do que um simples direito de pedir a prestação jurisdicional, é um direito de agir diante da jurisdição para obter a tutela jurisdicional. Nesse sentido, a ação – como também acontece com a defesa – realiza-se com base no direito de participação, expressão de um princípio político fundamental do Estado constitucional – o *princípio democrático*. O direito à participação, imprescindível à legitimação do próprio poder jurisdicional, ajunta-se ao primitivo direito de ir a juízo para dar conteúdo ao direito contemporâneo de ação.

Mas, para que o autor possa participar adequadamente, atuando de modo a realmente poder exigir a efetiva tutela do direito material, há a necessidade de que o procedimento aberto à participação seja estruturado de maneira idônea. Ou melhor, não basta imaginar que a proclamação do direito de ação e do direito à participação é suficiente para legitimar a proibição da tutela privada e do monopólio estatal de distribuição de justiça. É preciso que o autor possa se valer das técnicas processuais hábeis à efetiva tutela do direito material.

A ideia de que o cidadão tem um direito de ação que se apresenta como espécie do direito de petição – que, por ser inseparável de toda organização em forma de Estado, se exerce indistintamente diante de todas e quaisquer autoridades²⁹⁶ – serve apenas para expressar o direito de ação como garantia formal e por isso foi importante em determinado contexto histórico, em que era imprescindível delimitar a liberdade do cidadão diante da autoridade estatal.

Lembre-se que essa teoria foi desenvolvida por volta de 1940, época de inacreditáveis violências aos direitos de liberdade não apenas na Europa, mas também no Brasil. Nesse momento era importante afirmar o direito de ação como garantia formal contra o Estado, tendo chegado Couture a dizer que “*el derecho de petición es un precioso instrumento de relación entre el gobierno y el pueblo*”.²⁹⁷

A teoria de Liebman, isto é, a teoria das condições da ação, que durante muito tempo gozou dos favores do direito positivo brasileiro, veio à luz nesse mesmo período. Vale a pena destacar que Liebman se transferiu para o Brasil um pouco antes da segunda guerra mundial em razão dos horrores do fascismo e do nazismo. Ao retornar à Itália, após o término da guerra, Liebman escreveu o texto publicado sob o título “*L'azione nella teoria del processo civile*”, representativo da aula inaugural da disciplina de direito processual civil da Universidade de Turim, proferida em 24

de novembro de 1949.²⁹⁸ Embora esse texto contenha argumentos que já haviam sido por ele antecipados em trabalhos publicados na Itália (1936),²⁹⁹ no Uruguai (1940)³⁰⁰ e no Brasil (1945, 1946 e 1947),³⁰¹ é óbvio que todas as suas ideias estavam mergulhadas nas preocupações que, em 1949, ainda pulsavam daquele lamentável momento da história.

É importante registrar, aliás, que em 1949 já estava em vigor a Constituição da República Italiana de 1948, que afirmou, no seu art. 24, primeira parte, que *“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”*. Liebman disse, no seu texto de 1949, que o direito do cidadão ir a juízo simplesmente afirmando a existência do direito material nada mais era do que o reflexo da instituição dos tribunais por parte do Estado, encontrando base na referida norma da Constituição italiana. Liebman concluiu, inclusive citando Couture, que esse direito abstrato e genérico teria um lugar bem definido no direito constitucional, desenvolvendo uma função de grande importância.

Porém, ao contrário de Couture, Liebman elaborou dois direitos de ação, sendo um fundado na Constituição e outro no CPC italiano. Após admitir a relevância do direito de ação de base constitucional, Liebman advertiu que, na sua extrema abstração e indeterminação, esse direito não tem relevância alguma na vida e no funcionamento prático do processo. Foi então que apontou para a necessidade de a ação ser condicionada aos requisitos do interesse de agir (art. 100 do CPC italiano),³⁰² da legitimação para a causa (art. 81 do CPC italiano)³⁰³ e da possibilidade jurídica do pedido.

Liebman, ao destacar a base constitucional do direito de ação, concordou com a teoria de Couture, vendo-o como uma garantia do cidadão diante do Estado. Atualmente, porém, o direito de ação está muito mais ligado à necessidade de efetividade na tutela dos direitos do que à garantia de apreciação de qualquer afirmação de direito. A ação não pode mais ser pensada como mera garantia formal, pois deve dar ao autor não apenas a chance de reclamar diante do juiz, mas também a possibilidade de atuar diante da jurisdição para obter a efetiva tutela do direito material.

Daí a imprescindibilidade de retirar do direito de ação o direito de influir sobre o convencimento do juiz e de utilizar o procedimento e as técnicas processuais adequadas ao plano do direito material. Portanto, enquanto o direito de ação, na época das teorias de Couture e de Liebman, tinha a natureza de um direito a um não fazer, no sentido de não permitir ao Estado excluir da apreciação do Poder Judiciário uma afirmação de direito, ou de um direito a um fazer que seria a mera apreciação do pedido de tutela jurisdicional, *atualmente ele exige do Estado uma série de prestações, como a edição de procedimentos e técnicas processuais idôneas às variadas situações de direito substancial (devida pelo legislador), assim como a compreensão – por parte da jurisdição – das normas processuais e da própria função do processo a partir do direito material e da situação concreta, obviamente que sempre a partir dos direitos fundamentais processuais*.

A ideia de Liebman, de estabelecer um direito de ação apartado do direito de ação de base constitucional, relacionando-o com as chamadas condições da ação, teve o mérito de demonstrar que o direito de ação não pode se desligar do plano do direito material e das situações concretas. A posição de Liebman, portanto, pode ser considerada como uma tentativa de vincular o direito abstrato de ação com o direito material.

Com a sua teoria, Liebman quis dizer que a ação, por ser proposta diante de uma situação de direito material determinada e individualizada, deve conter certos requisitos, isto é, o interesse de agir, a legitimidade para a causa e a possibilidade jurídica do pedido.

Note-se que a teoria de Liebman objetivou dar utilidade à ação, pois, na sua concepção, a ação para a qual bastava a mera afirmação de um direito era dotada de uma abstração e generalidade que a tornavam uma simples decorrência da capacidade jurídica.

Acontece que o direito condicionado de ação, ainda que tenha limitado o direito abstrato de ação sem torná-lo dependente da efetiva existência do direito material, *não se preocupou em dar ao cidadão a possibilidade de exercer a ação de modo a realmente poder obter a tutela do seu direito*.

Liebman jamais procurou extrair do direito condicionado de ação as técnicas processuais adequadas ao direito material, mas apenas limitar a abstração e a generalidade do direito de ação fundado na Constituição.

Mas Liebman também não deu ao direito constitucional de ação a amplitude capaz de garantir as técnicas processuais adequadas. Aliás, caso tivesse pretendido tal extensão ao direito constitucional de ação, não poderia tê-lo separado do direito condicionado, atribuindo ao direito de base constitucional *a função de mera garantia de ir a juízo ou de propor a ação*.

A teoria de Liebman, ao individualizar duas ações, teve a preocupação de, sem abrir mão da garantia constitucional de ir a juízo, impedir que a ação fosse utilizada de forma indiscriminada. Como dito, essa teoria esteve atenta ao art. 24 da Constituição italiana – que garante a todos o direito de ir a juízo – e aos arts. 81 e 100 do CPC italiano, que afirmam, respectivamente, que o autor deve ser legitimado para a causa e ter interesse de agir. Não foi por outro motivo que Liebman afirmou que a “ação fundada no CPC” deveria cumprir certos requisitos para ser admissível, os quais representariam laços entre o direito de ir a juízo e a situação conflitiva concreta.

A nossa história é diferente, pois não há uma teoria brasileira que parta do ordenamento jurídico nacional. Ao contrário, o CPC de 1973, hoje revogado, é que se inspirou na teoria de Liebman. Este CPC instituiu três condições para a ação, seguindo exatamente o modelo inicialmente traçado por Liebman – embora esse, pouco tempo antes da edição do CPC de 1973, houvesse excluído das condições da ação a possibilidade jurídica do pedido como categoria autônoma, inserindo-a no interesse de agir.

O CPC de 2015 não fala em condições da ação. Apresenta o interesse e a legitimidade como requisitos para a apreciação do mérito. A existência da ação obviamente não é subordinada a estes requisitos. Aliás, *se o CPC dissesse que a ação somente existe quando estão presentes as suas condições ou tais requisitos, estaria admitindo que a ação fundada na Constituição somente serve para garantir a invocação da atividade jurisdicional, constituindo-se apenas no ato introdutório da ação e de instauração do processo*.

Porém, a norma constitucional (art. 5.º, XXXV, CF) institui o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e, dessa forma, confere a devida oportunidade da prática de atos capazes de influir sobre o convencimento judicial, assim como a possibilidade do uso das técnicas processuais adequadas à situação conflitiva concreta.

A ideia de separar a base constitucional da base processual da ação, supondo que a primeira se destina apenas a garantir um direito de liberdade ou de ir a juízo, *implica negar que a Constituição garante a efetividade da tutela jurisdicional. Não há como admitir, no Estado constitucional, que o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva possa se limitar ao ato que instaura o processo, como se esse direito fundamental pudesse ser apenas o direito de propor a ação ou de pedir a tutela jurisdicional. O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva é o direito de agir em juízo em busca da tutela jurisdicional efetiva do direito material, e isso está a quilômetros de distância dos antigos conceitos de direito de ir a juízo e de direito de pedir a tutela jurisdicional*.

Como o direito de ação é exercido diante de uma situação de direito material, a legitimidade e o interesse são elementos capazes de demonstrar a adequação da ação ao plano concreto. Servem para impedir que a ação se desenvolva de forma arbitrária e inútil e, por essa razão, são *requisitos para o julgamento do pedido* e não *elementos constitutivos da ação*, como propôs Liebman. Ou seja, porque objetivam impedir que a ação se desenvolva de forma desnecessária, a aferição desses requisitos deve ser feita segundo a *afirmação* do autor, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.³⁰⁴

Se o direito de ação é marcado pela sua relatividade histórica e, portanto, a sua conceituação deve considerar os valores do Estado, os princípios constitucionais e a legislação infraconstitucional, é natural que, após a sua compreensão à luz da Constituição, a sua identificação seja feita a partir da legislação processual. Diante dos avanços da legislação processual, torna-se imprescindível

reconstruir o conceito de ação. Na realidade, é chegado o momento de elaborar um conceito genuinamente brasileiro de direito de ação.

Para tanto, é imprescindível lembrar as normas processuais que consistem em cláusulas gerais antecipatória e executiva – que dão às partes e ao juiz ampla latitude de poder para a utilização das técnicas antecipatória e executiva conforme as necessidades dos casos –, ou seja, as normas infraconstitucionais mais comprometidas com o direito fundamental de ação do ordenamento brasileiro. Os arts. 83 e 84 do CDC, além de objetivarem a efetiva tutela do consumidor, destinam-se a viabilizar a tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Ambos são voltados à tutela *específica* do consumidor e à tutela *específica e adequada* dos direitos *transindividuais (difusos e coletivos)* e dos chamados “*direitos individuais homogêneos*”, *característicos ao Estado e à sociedade contemporâneos*. Por sua vez, as normas dos arts. 139, IV, 497, 498, 536, 537 e 538, CPC/2015, na mesma linha da do art. 84 do CDC, prendem-se à necessidade de instrumentalizar a ação de modo a lhe permitir alcançar a tutela *específica dos direitos*.

Tais normas têm amplitude enorme, cobrindo quase a totalidade das novas necessidades de tutela jurisdicional. Abrangem a tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos e a tutela específica dos direitos individuais, deixando escapar apenas as tradicionais formas de proteção dos direitos individuais.

Diz o art. 83 do CDC que, “para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este Código são admissíveis todas as *espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela*”. Cabe decompor a norma em duas partes para demonstrar com maior precisão o seu significado.

Em primeiro lugar é preciso olhar para a sua parte final, que fala em “*adequada e efetiva tutela*”. A preocupação é com a adequada e efetiva tutela *dos direitos*. A ação deve abrir oportunidade para a obtenção da tutela do direito material, e não apenas viabilizar o julgamento do mérito, como pensa ser essencial o conceito clássico de direito de ação. Como é óbvio, não se quer afirmar, com isso, que a ação só existe quando a tutela do direito for prestada, ou quando a sentença reconhecer a existência do direito material, mas sim que a ação deve se realizar através de um procedimento adequado e, no caso de reconhecimento do direito material, permitir a utilização dos meios executivos idôneos à sua efetiva tutela.

Além disso, a primeira parte do art. 83 afirma que, para a adequada e efetiva tutela dos direitos, “são admissíveis todas as *espécies de ações*”. Portanto, *desde logo temos o dado de que o art. 83 admite a existência de várias “espécies de ações”, todas decorrentes do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva* (CF, art. 5.º, XXXV).

Alguém poderia supor que, quando a norma aceita a existência de “espécies de ações”, refere-se, por exemplo, às ações de conhecimento, de execução e cautelar e às ações declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental e executiva, tomando como base, respectivamente, os *processos* (de conhecimento e de execução) e as *sentenças* (declaratória etc.).

Mas o intuito da norma vai muito além, pois, quando fala em “*ações capazes de propiciar*” a efetiva tutela dos direitos, expressa a necessidade de a ação se estruturar de modo a viabilizar a prestação da tutela do direito, valendo-se do procedimento, da técnica antecipatória, da sentença e do meio executivo adequados. A “ação capaz de propiciar” é a ação adequada à tutela do direito, que deve ser uma ação que culmine em uma sentença idônea à prestação da tutela jurisdicional do direito.

Contudo, a estruturação técnica da ação depende da espécie da tutela de direito desejada, já que é a tutela do direito que influi sobre a estrutura da ação. As ações são tantas quantas forem as necessidades do direito material, uma vez que devem se diferenciar na medida dos resultados que são objetivados no plano do direito material.

A ação, porque tem de ser capaz de dar tutela efetiva ao direito, garante o procedimento, a técnica antecipatória, a sentença e os meios executivos adequados. A sentença é apenas um dos corolários da ação, podendo ser aferida como idônea apenas a partir do que se deseja na esfera do

direito material. De modo que não é correto afirmar que a “ação mandamental” (por exemplo) é capaz de propiciar a efetiva tutela do direito, mas sim que a tutela ressarcitória na forma específica (ainda, por exemplo) exige uma modalidade de ação que incorpore a sentença mandamental. Ou seja, a espécie de sentença não permite a identificação ou a qualificação de uma ação, pois essa obviamente não se caracteriza apenas pela sentença. A ação é estruturada, e assim combina com certa sentença (por exemplo, mandamental), em razão da tutela almejada no plano do direito material (por exemplo, ressarcitória na forma específica ou inibitória).

A norma do art. 83 do CDC, portanto, ao falar de ações capazes de propiciar a tutela efetiva dos direitos, quer dizer que o autor tem o direito de propor uma ação estruturada com técnicas processuais capazes de permitir o efetivo encontro da tutela do direito material.

Como a ação é o agir para a obtenção da tutela do direito, ela não se exaure com o julgamento do mérito e, assim, não pode ser indiferente aos meios de execução da sentença, pois esses são imprescindíveis para a efetiva tutela do direito material. Como o autor não pode se dar por satisfeito quando é proferida uma sentença de procedência que necessita ser executada, é fácil entender por que o direito ao meio executivo adequado é corolário do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva.

A ação adequada ao plano do direito material, contudo, está muito longe da ação concreta, isto é, da ação que depende de uma sentença favorável. Não há dúvida de que o direito de ação é da titularidade de quem recebe, *ou não*, uma sentença favorável. O direito de ação, nesse sentido, é totalmente abstrato em relação ao direito material.

Mas esse grau de abstração não responde ao direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, pois dele decorre o direito a uma ação que seja estruturada de forma tecnicamente capaz de permitir a tutela do direito material, ou seja, o direito à ação adequada à tutela do direito material. *O direito à ação adequada, embora independente de uma sentença favorável ou da efetiva realização do direito, requer que ao autor sejam conferidos os meios técnicos idôneos à obtenção da sentença favorável e da tutela do direito.*

O autor deve poder agir através dos meios técnicos adequados à tutela do direito material e, por isso, tem o direito ao procedimento adequado à situação substancial afirmada, ainda que a sentença seja de improcedência. Da mesma forma, tem o direito ao meio executivo idôneo para o caso de vir a ser proferida a sentença de procedência, embora isso não signifique que o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva lhe garanta a *satisfação* do direito material, uma vez que o uso do meio executivo adequado nem sempre lhe proporcionará a *satisfação* do seu direito. Basta pensar na hipótese em que o demandado não tem patrimônio para suportar a execução e, assim, satisfazer o direito de crédito do autor. A efetividade da tutela jurisdicional possui limites relacionados com o patrimônio e a liberdade do réu, pois a realização do direito material pode encontrar obstáculos na falta de higidez patrimonial e na impossibilidade de coerção da vontade.

Mas o direito à ação adequada também é algo completamente distinto do direito de ir a juízo ou do tradicional direito abstrato de ação. O direito abstrato de ação, visto como garantia de liberdade, tem um valor muito reduzido no Estado constitucional. Garantir que o Estado não vai excluir da apreciação judiciária ou negar o direito de ir a juízo significa quase nada quando se vê o direito de ação como direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, do qual decorrem vários direitos ao autor e uma série de deveres prestacionais ao Estado.

O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva obriga o juiz a garantir todos os seus corolários, como o direito ao meio executivo capaz de permitir a tutela do direito, além de obrigar o legislador a desenhar os procedimentos e as técnicas processuais adequadas às diferentes situações de direito substancial.

Como mera garantia de liberdade, o direito abstrato de ação poderia, no máximo, impedir o legislador de excluir uma lesão ou ameaça a direito da apreciação do Poder Judiciário e proibir o juiz de deixar de julgar. Além dessas possibilidades serem quase cerebrinas no Estado constitucional – e estarem, de qualquer forma, também abarcadas pelo direito fundamental de

ação –, tal conceito impediria que o autor se valesse do direito constitucional de ação para agir adequadamente em juízo em busca da efetiva tutela jurisdicional do seu direito. Ou melhor, o direito constitucional de ação, em termos de garantia de efetividade da tutela jurisdicional, simplesmente não existiria.

Isso demonstra que o conceito tradicional de ação, que é do final do século XIX (Degenkolb, Plósz e Mortara) e de meados do século passado (Couture e Liebman),³⁰⁵ *está muito longe daquele que resulta do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, atualmente expresso no art. 83 do CDC.*

Não obstante, o direito de ação, hoje, é ainda mais do que o direito à ação adequada ao plano do direito material. O legislador não se limitou – nem poderia – a estabelecer técnicas processuais adequadas ao plano do direito material, mas instituiu cláusulas gerais *com o objetivo de dar ao cidadão o direito de construir a ação adequada ao caso concreto.*

A legitimidade da jurisdição depende dos direitos de o autor influir sobre o convencimento do juiz e utilizar as técnicas processuais adequadas à proteção do direito material. Acontece que, além de não se poder exigir do legislador a estruturação de tantos procedimentos especiais quantas sejam as situações carentes de tutela, jamais seria possível criar procedimentos ou técnicas processuais que se ajustassem perfeitamente às variadas situações de direito material, pois essas, ainda que pudessem ser visualizadas em abstrato, sempre estariam na dependência das circunstâncias do caso concreto.

Já passou a época em que o direito era visto como uma ciência lógico-formal, que trabalhava apenas com derivações dedutivas, ao gosto do positivismo clássico e do jusnaturalismo racionalista. Sabe-se que o direito, atualmente, não pode se apartar da realidade. As normas processuais relativas ao direito de ação, especialmente em razão da sua natureza instrumental, não podem se desligar dos vários casos concretos, e assim devem ser lidas à luz do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva. A norma processual civil, quando iluminada pelo direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, obriga o juiz a lhe dar a inteligência capaz de permitir a efetiva tutela do direito material.

O ordenamento jurídico, ao dispor das normas, exatamente porque sabe que não pode atender a todas as situações, diante da riqueza e multiplicidade das particularidades que as formam, trabalha com normas abertas e com normas com significados abertos. Ambas devem ser concretizadas conforme as peculiaridades do caso concreto e, assim, respondem a um direito voltado à realidade, expressando um ordenamento jurídico marcado pelos princípios e pelos direitos fundamentais.

Os arts. 139, IV, 497, 498, 536, 537 e 538, CPC/2015 outorgam ao autor o direito, e ao juiz o dever, de utilizar a sentença e os meios executivos adequados ao caso concreto. Basta lembrar que essa norma diz que o juiz poderá determinar as *medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial*. Essa norma não institui um conceito dependente de atribuição de significado, mas expressa, nele mesmo, que o modelo adequado apenas pode ser determinado no caso concreto.

As normas que tratam da técnica antecipatória, ao contrário, não conferem direito ou poder de determinação de uma técnica entre várias – como acontece quando se dá a possibilidade de escolha da medida executiva necessária –, mas o direito à utilização da técnica quando os pressupostos da tutela sumária possam ser afirmados diante do caso concreto. Assim ocorre quando se pensa em “urgência” e “evidência”.

Não obstante, a diferença entre tais normas não apaga a sua característica principal, que é a de *abrir o ordenamento processual ao direito fundamental de ação, permitindo ao autor exercer a ação adequada ao caso concreto*. A partir do momento em que as normas relativas à ação passam a se voltar à realidade ou ao caso concreto, rompe-se o gesso da época em que o seu exercício ficava restrito aos meios processuais previamente disponibilizados a hipóteses específicas.

O direito brasileiro impõe a tese do direito à construção da ação adequada ao caso concreto.

Além dos vários artigos do CPC de 2015 e do art. 84 do CDC, que expressamente dão ao autor o poder de agregar à sua ação a técnica processual idônea, o art. 83 do CDC – ao dizer que “são admissíveis *todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela*” – não apenas reafirma o dever de o legislador instituir as técnicas processuais capazes de permitir a *efetiva tutela dos direitos, como evidencia o direito de o autor construir a ação adequada às necessidades do caso concreto*.

As normas processuais contemporâneas, partindo do pressuposto de que o direito de ação não pode ficar na dependência de técnicas processuais ditadas de maneira uniforme para todos os casos ou para algumas hipóteses específicas, incorporam conceitos abertos, voltados para a realidade, deixando claro que a ação pode ser construída conforme as necessidades do caso conflitivo. O art. 5.º, XXXV, CF, ao garantir o direito à preordenação de técnicas processuais adequadas ao alcance da tutela do direito, não pode ficar à distância destas espécies de normas processuais e, além disso, da compreensão judicial da técnica processual à luz das necessidades carentes de tutela e do direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva.

4.13. Legitimidade da construção da ação segundo a tutela jurisdicional do direito. Como a ação pode ser construída segundo as necessidades do caso concreto, torna-se natural a preocupação com a sua legitimidade diante dos direitos do réu. Se o autor pode se valer dos meios adequados para a consecução do seu objetivo, evidentemente não lhe é possível utilizá-los além da estrita necessidade para a obtenção da tutela do direito material.

Ou seja, não é porque o autor, valendo-se das cláusulas processuais abertas, pode escolher o meio executivo mais adequado à sua situação concreta que isso pode ser feito sem considerar a esfera jurídica do demandado. Como é óbvio, o autor deve optar pelo meio executivo idôneo à tutela do direito material. Contudo, diante da eventualidade de dois meios idôneos a propiciar a tutela do direito, necessariamente deve utilizar o que cause a menor restrição possível ao réu.

Fala-se, assim, de meio mais suave, como resultante da conjugação entre o meio efetivo ou idôneo à tutela do direito e o meio que causa o menor gravame possível ao demandado. É nesse sentido que se deve compreender o significado de “meio necessário”.

Os arts. 139, IV, 497, 498, 536, 537 e 538 do CPC/2015 e 84 do CDC dão ao autor o poder de requerer a sentença e o meio executivo idôneos à tutela jurisdicional do direito. No caso em que necessita da imposição de um fazer ou de um não fazer e, especialmente, nos casos de ação inibitória e de remoção do ilícito, o autor pode requerer ordem sob pena de multa ou qualquer outra medida executiva necessária. Do mesmo modo, tratando-se de ação para obtenção de coisa, confere-se ao autor a possibilidade de se valer da busca e apreensão, da imissão na posse ou da multa.

Se não há dúvida de que o meio executivo deve ser idôneo, o problema está na escolha do meio mais suave ou necessário, isto é, daquele que, além de efetivo à tutela do direito, é o menos prejudicial ao réu. Porém, somente as particularidades do caso poderão indicar a medida executiva necessária, vale dizer, aquela que, sendo efetiva, é a melhor para quem está no polo passivo. Chegou-se a pensar que o meio executivo que permite a tutela do direito sem considerar a vontade do réu (p. ex., busca e apreensão) é sempre mais idôneo do que a multa, que então restou reservada aos casos de obrigações infungíveis. Hoje, contudo, não há mais como sustentar a ideia de que a multa somente pode ser utilizada nos locais em que as medidas de execução direta são inidôneas, isto é, nos lugares em que é necessário atuar sobre a vontade do demandado. Não cumprida a “obrigação de entregar coisa”, não há dúvida de que a imissão na posse e a busca e apreensão são, respectivamente, os meios executivos idôneos à tutela de bem imóvel e à tutela de bem móvel.³⁰⁶ Porém, a multa pode preferir a busca e apreensão por ser mais econômica ao autor, e por isso constituir a medida idônea diante do caso concreto. Basta imaginar a hipótese em que a coisa devida constitui uma grande máquina, que exige gasto considerável de dinheiro para o seu desmonte e transporte.³⁰⁷ Nesse caso, como é evidente, a multa constitui o meio realmente idôneo para a tutela do direito. Ora, *não há qualquer racionalidade em supor que o meio idôneo é aquele que obriga o autor a despendar dinheiro para obter aquilo que, segundo a própria decisão jurisdicional, é devido pelo executado*.

Deixe-se claro que o meio executivo, antes de tudo, deve ser idôneo, e, portanto, o exequente não pode ser obrigado a renunciar a meio executivo apenas pela razão de outro ser menos gravoso. O meio executivo escolhido apenas pode ser rejeitado pelo juiz quando o outro meio, que traz menor restrição, é igualmente idôneo ao exequente.

4.14. Ação de direito material, formas de tutela dos direitos e ação adequada. Imagina-se que ninguém, ainda que falando em ação de direito material, nega a existência de um direito de ação autônomo em relação ao direito material.³⁰⁸ A ideia de ação de direito material é interessante e generosa quando utilizada para evidenciar a necessidade de a ação processual se moldar a partir do direito material.³⁰⁹

Porém, para se garantir a *ação adequada* ao direito material é melhor tomar em consideração a categoria das *formas de tutela do direito material*, mais consentânea ao direito contemporâneo. Tanto as formas de tutela do direito material, quanto as ações de direito material, estão no plano do direito material. Mas a preocupação com as formas de tutela dos direitos se funda na ideia de que a atribuição de titularidade de um direito fica na dependência de que lhe seja garantida a disponibilidade de uma *forma de tutela* que seja adequada à necessidade da sua proteção. Ou melhor, o sujeito só é titular de um direito quando tem uma posição juridicamente protegida, isto é, quando o direito proclamado pela norma atributiva dispõe de uma *forma de tutela* que seja adequada à sua proteção.³¹⁰

Essa forma de tutela – como, p. ex., a ressarcitória – é inegavelmente garantida pelo direito material, pouco importando o fato de a ação de direito material ter sido proibida. A ação de direito material foi proibida, mas as formas de tutela dos direitos constituem um atributo indispensável à própria existência do direito material.

Não é preciso sustentar, para evidenciar que a ação deve se adequar ao plano do direito material, que a ação de direito material é exercida ou afirmada através da ação, pois através dessa se exerce a pretensão à tutela jurisdicional do direito. Se a titularidade de um direito decorre da existência de uma posição juridicamente protegida, e essa proteção se dá através de *formas de tutela do direito*, todos têm pretensão à tutela jurisdicional do direito material – como, p. ex., pretensão à tutela inibitória.

O autor, ao propor a ação, exerce a pretensão à tutela jurisdicional do direito. Ninguém pode exigir e obter ressarcimento (por exemplo) contra a vontade do obrigado, a não ser mediante a ação processual. Isso não é exercício de ação de direito material, mas sim exercício de pretensão à tutela jurisdicional do direito material mediante o exercício da ação processual.

Deixe-se claro, porém, que não se está negando a existência da categoria da pretensão de direito material e a *possibilidade teórica* de se sustentar que, *ainda que a autotutela privada tenha sido proibida*, a ação de direito material é afirmada ao se propor a ação processual. O que se está dizendo é que a categoria do direito à tutela dos direitos permite a elaboração de uma *dogmática capaz de responder mais adequadamente às relações entre o direito material e o direito de ação*. Essa nova construção teórica, *além de preocupada com a proteção do direito material*, evidencia que a ação, embora abstrata, *deve estar adequada às formas de tutela prometidas pelo direito material*. Trata-se, assim, de uma concepção de ação fundada na *teoria dos direitos fundamentais, fixando-se nas ideias de dever de proteção (ou de tutela) estatal e de direito fundamental de ação*.

De qualquer forma, é preciso chegar ao que interessa, ou melhor, no que levou a doutrina a pensar em ação de direito material ainda que consciente da autonomia da ação processual. Isso ocorreu em razão da excessiva abstração que se tentou conferir à ação processual, negando-se-lhe qualquer tipo de relação com as situações concretas. De modo que a teorização da ação de direito material teve o propósito de permitir que a ação processual pudesse realmente servir à proteção das diversas situações de direito substancial.

Ora, se é inquestionável que o autor tem o direito de exercer pretensão à tutela do direito através da ação, é evidente o seu direito de *exercera ação processual* que lhe permita obter a tutela jurisdicional *do direito*. Quer dizer que o autor tem, ao lado do direito à tutela jurisdicional do

direito – decorrente do próprio direito material –, o direito à *ação adequada* à tutela do *direito* (ou o direito à tutela jurisdicional efetiva), garantido pelo art. 5.º, XXXV, CF. Portanto, tem os direitos de influir sobre o convencimento do juiz e de utilizar as técnicas processuais capazes de permitir a efetiva tutela do direito material.

Isso certamente está longe de significar que a *ação adequada* seja dependente da existência do direito material, pois todos têm direito à *ação adequada* à tutela do direito, sejam ou não titulares do direito material afirmado. A ação é o meio através do qual se pede a tutela jurisdicional do direito. A sentença, qualquer que seja ela, responde ao direito de ação, apesar de a tutela jurisdicional do direito, como é natural, apenas poder ser prestada pela sentença de procedência.³¹¹

Porém, parece ocioso voltar a argumentar que a ação deve ser conformada a partir da tutela jurisdicional do direito. Ao propor a ação, o autor afirma o direito e a existência de uma situação de ameaça ou de lesão para, com base nela, pedir a tutela jurisdicional do direito e o provimento (a espécie de sentença) que reputa adequado à sua prestação. Além disso, como já demonstrado, os limites da extensão da cognição do juiz – que dão dimensão ao procedimento –, assim como a necessidade de técnica antecipatória, a espécie de sentença e de meio executivo também dependem da tutela do direito reclamada.

Não há exercício de ação de direito material, mas exercício de pretensão à tutela jurisdicional do direito. Mas também não há apenas direito de ir a juízo, mas sim direito à ação adequada à tutela do direito material – que deve ser construída conforme as necessidades do caso concreto.

4.15. Classificações das ações, das sentenças e das tutelas jurisdicionais dos direitos. Pontes de Miranda, um dos principais idealizadores da teoria moderna da ação de direito material, classifica as ações em cinco – declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental e executiva –, afirmando que “o direito processual tem de atender à eficácia das ações segundo o direito material”. Escreve que “a ação declarativa é ação a respeito de ser ou não ser a relação jurídica; de regra, a ação constitutiva prende-se à pretensão constitutiva, *res deducta*, quando se exerce a pretensão à tutela jurídica. Quando a ação constitutiva é ligada ao direito, imediatamente, não há, no plano da *res in iudicium deducta*, pretensão constitutiva (há-a, no plano do direito subjetivo à tutela jurídica, que é a especialização, pelo exercício da pretensão à tutela jurídica em pretensão constitutiva; a ação de condenação supõe que aquele ou aqueles, a quem ela se dirige, tenham obrado contra o direito, que tenham causado dano e mereçam, por isso, ser condenados (*condamnare*); a ação mandamental prende-se a atos que o juiz ou outra autoridade deve mandar que se pratique. O juiz expede o mandado, porque o autor tem pretensão ao mandamento e, exercendo a pretensão à tutela jurídica, propôs ação mandamental; a ação executiva é aquela pela qual se passa para a esfera jurídica de alguém o que nela devia estar, e não está”.³¹²

Contudo, essa classificação das ações não guarda coerência com a própria ideia de ação de direito material, pois a eficácia de uma ação de direito material não pode ser balizada pelas *formas processuais* de proteção dos direitos. Pontes observa, como se viu acima, que o “direito processual tem de atender à eficácia das ações segundo o direito material”. Acontece que a ação de direito material não tem – nem pode ou poderá ter – eficácia condenatória, por exemplo. Na verdade, embora Pontes tenha percebido a necessidade de o processo se conformar ao direito material, utilizou categorias processuais para aludir às eficácias das ações de direito material, o que é uma contradição.

Ainda que aceitássemos a utilidade da categoria de ação de direito material, jamais poderíamos admitir, como fez Pontes de Miranda, uma ação de direito material condenatória ou mandamental. Note-se que Pontes, ao classificar as ações, invoca fundamentos que não estão em um mesmo plano lógico, ora fazendo referência ao seu conteúdo (“a ação declarativa é ação a respeito de ser ou não ser a relação jurídica”), ora justificando-as com base no comportamento do réu (“a ação de condenação supõe que aquele ou aqueles, a quem ela se dirige, tenham obrado contra direito, que tenham causado dano”), ora caracterizando-as a partir do que o juiz faz (“a ação mandamental prende-se a ato que o juiz ou outra autoridade deve mandar que se pratique”).

Como é evidente, o dano jamais poderia justificar a eficácia da ação de direito material. O dano somente poderia ser o seu fundamento. Ou melhor, o dano é um dos fundamentos da pretensão à tutela ressarcitória. Portanto, mesmo que se desconsidere o fato de que não se exerce ação de direito material, mas sim pretensão à tutela jurisdicional do direito material, a ação de direito material fundada em dano jamais poderia ter sido concebida como condenatória. Ora, a condenação é uma categoria de direito processual, e não de direito material. Ninguém tem direito à tutela condenatória contra quem praticou dano, mas sim direito à tutela ressarcitória. A condenação é apenas uma técnica afirmada pelo direito processual para viabilizar a tutela ressarcitória.

Parece que a classificação de Pontes de Miranda tentou conjugar as eficácias das ações de direito material com o processo, pois, embora tenha se baseado apenas na força da ação de direito material para admitir a ação executiva (“a ação executiva é aquela pela qual se passa para a esfera jurídica de alguém o que nela devia estar, e não está”), *curvou-se à sentença condenatória para negar a devida eficácia à ação ressarcitória*.

Por outro lado, se é verdade que o juiz pode expedir mandado em atenção a uma determinada circunstância de direito material, *isso não quer dizer que não possa expedir ordens para viabilizar outros tantos resultados no plano do direito material*. Melhor explicando: os resultados ou as eficácias no plano do direito material nada têm a ver com o mandado, pois esse é um modo de proteção de uma série de situações de direito substancial.

Ademais, o conteúdo sobre o qual uma ação versa não pode qualificar a sua eficácia, de maneira que a circunstância de a ação dizer respeito à existência ou à inexistência de uma relação jurídica não permite a conclusão de se tratar de ação de direito material com *eficácia* declaratória. O que importa, também nesse caso, é o resultado da ação. Admitindo-se a ação de direito material, essa ação poderia ser declaratória apenas em razão do seu *resultado* no plano do direito material, embora nessa hipótese – ao contrário do que acontece quando se pensa na sentença condenatória – o resultado esperado no plano do direito material estivesse sendo *plenamente* outorgado pela *sentença* declaratória.

De qualquer forma, a classificação das ações segundo as suas eficácias perante o direito material apenas pode ser aceita por quem admite que o autor exerce ação de direito material. Para quem não aceita o exercício de ação de direito material, mas sim o exercício de pretensão à tutela jurisdicional do direito, o que se deve classificar são as tutelas jurisdicionais dos direitos.

São as tutelas jurisdicionais dos direitos que expressam os resultados que o processo produz no plano do direito material. E aí se apresenta uma distinção fundamental entre as duas classificações. A classificação das ações de direito material, como proposta, não é uma classificação *que toma em conta o que o direito material exige do processo*. Tanto é verdade que propõe o conceito de ação condenatória, o que constitui evidente confissão de que a forma processual está participando de uma classificação que, segundo o que se afirma como premissa, deveria atender apenas as eficácias das ações no plano do direito material. Note-se que a ação material de ressarcir obviamente não pode se contentar com a condenação; ela pressupõe uma ação processual mediante a qual se exija (se execute) o ressarcimento.

Ao contrário da classificação que parte do conceito de ação de direito material, a classificação das tutelas jurisdicionais dos direitos se preocupa apenas com os resultados do processo no plano do direito material – assim, por exemplo, com as tutelas ressarcitória e inibitória e não com as ações condenatória e mandamental. O objetivo da classificação das tutelas jurisdicionais dos direitos é demonstrar quais formas de tutela o autor tem o direito de obter e, como consequência disso, *a maneira como a ação e o processo devem se estruturar para permitir a sua prestação*. Não é por outro motivo que se diz que a ação processual deve se conformar – ou se fazer adequada – a partir da tutela jurisdicional do direito.

A razão de ser da classificação das tutelas tem um objetivo concreto e prático bem definido, pois parte da premissa de que as normas atributivas de direitos não bastam, já que a titularidade de um direito depende da existência de formas para a sua tutela, para deixar claro que a ação, como meio

através do qual se pode exigir uma dessas formas de tutela, deve se estruturar de maneira adequada a permitir a sua obtenção.

Perceba-se, além disso, que o conceito de ação de direito material é imprestável para explicar o que acontece diante dos direitos difusos.³¹³ Quando se dá ao Ministério Público (por exemplo) *poder para tutelar* os direitos difusos, isso é feito, em primeiro lugar, porque todos têm o *direito à sua proteção*, e, em segundo lugar, porque o Estado, que possui o *dever de protegê-los*, também tem o *dever de viabilizar a participação* do cidadão na reivindicação da sua *tutela*. Como tais direitos são indivisíveis, e, portanto, o cidadão não pode pedir a sua tutela jurisdicional, institui-se um modelo procedimental (a ação coletiva) para viabilizar a sua participação, conferindo-se legitimidade para entes que o fazem presente.³¹⁴ O direito à tutela jurisdicional dos direitos difusos,³¹⁵ *que é de todos e de cada um*, somente pode ser exercido pelo ente legitimado.

A categoria da ação de direito material, ao contrário da categoria do direito à tutela jurisdicional *do direito*, é inadequada ao fenômeno dos direitos difusos, pois todos têm direito à tutela do meio ambiente (por exemplo) – embora ele tenha de ser exercido, na forma jurisdicional, por um ente legitimado –, mas ninguém possui pretensão de direito material ou ação de direito material contra o poluidor. Lembre-se que o direito à tutela dos direitos tem o Estado como devedor,³¹⁶ enquanto a pretensão e a ação de direito material são exercidas contra o obrigado.

No Estado constitucional, mais importante do que teorizar sobre as ações de direito material é pensar a respeito das formas de tutela devidas pelo Estado para a proteção dos direitos, especialmente dos direitos fundamentais.

Porém, é necessário também esclarecer que a tutela do direito não se confunde com as técnicas processuais destinadas a permitir a sua prestação. É preciso estabelecer, de uma vez por todas, a separação entre as tutelas prometidas pelo direito material e as técnicas processuais. A tutela jurisdicional ressarcitória e a sentença condenatória estão em *planos diferentes*, assim como *distintas são todas as espécies de tutelas jurisdicionais dos direitos em face das espécies de sentenças*.³¹⁷

Entre as tutelas dos direitos e as técnicas processuais deve haver uma *relação de adequação*. Frise-se que há direito à tutela do direito material e direito de ação. Quem deve tutela jurisdicional ao direito, assim como resposta ao direito de ação, é o Estado.

Mas o direito de ação, porque é o direito através do qual se pode exercer a pretensão à tutela jurisdicional do direito material, é o direito a uma *ação adequada*, vale dizer, é o direito que, entre outras técnicas processuais, exige a sentença capaz de permitir a tutela do direito material.

Ora, se a ação adequada, inclusive a sentença, destina-se a viabilizar a tutela do direito, *é pouco mais do que evidente que o resultado do processo no plano do direito material não pode ser expresso pelas sentenças, mas apenas pelas tutelas dos direitos*.

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira afirma que a “constitucionalização do direito ao processo e à jurisdição (...) determina também uma garantia de *resultado*”. Segundo ele, a “tipicidade e a classificação tipológica constituem atributos ou prerrogativas sistemáticas do *resultado de mérito* (e não do meio processual garantido pela norma constitucional)”. Dessa forma, de acordo com o ilustre processualista, colocam-se “em destaque os *efeitos jurídicos e os conteúdos variáveis das diversas formas de tutela jurisdicional*, que dão resposta ao objeto variável da demanda jurisdicional”.³¹⁸

Não obstante, Carlos Alberto não atribui às tutelas jurisdicionais qualquer significado de resultado capaz de expressar os seus “efeitos jurídicos e *conteúdos variáveis*” idôneos para dar “resposta ao *objeto variável* da demanda jurisdicional”. Isso porque conclui que os tipos ou formas de tutela jurisdicional são representados por condenar, declarar, constituir, mandar ou executar.³¹⁹

Carlos Alberto, em sua classificação, não expressa os resultados de mérito ou as respostas aos

objetos variáveis das demandas jurisdicionais, esquecendo-se do que havia prometido em seus fundamentos. Portanto, ainda que Carlos Alberto esteja certo ao propor uma classificação das tutelas jurisdicionais, e não das ações, *o problema da sua teoria está na classificação das tutelas jurisdicionais, ou melhor, no significado que atribui à tutela jurisdicional*.

A classificação de Carlos Alberto pode servir como classificação das *sentenças de procedência*, mas jamais como classificação das *formas de tutela jurisdicional dos direitos*. Ao concluir o ensaio intitulado O problema da eficácia da sentença, publicado na *Revista de Direito Processual Civil* (Genesis), resume o eminente processualista: “Cumpra ainda sublinhar que as cinco espécies de tutela (declaratória, condenatória, constitutiva, mandamental e executiva *lato sensu*) constituem todas fenômenos jurídicos, mas é preciso considerar que as sentenças declaratórias e constitutivas *satisfazem por si mesmas a pretensão processual*, sem necessidade de qualquer ato material futuro; a condenatória *fica a meio caminho*, criando apenas as condições jurídicas, com a constituição do título executivo, para que tal possa ocorrer em processo autônomo e independente, dito de execução; as duas últimas *satisfazem no mesmo processo*, por meio de atos materiais, realizados depois da sentença, aptos a produzir alterações no mundo fático”.³²⁰

Como está claro, a classificação das tutelas de Carlos Alberto constitui uma explicação das formas pelas quais as sentenças satisfazem as pretensões processuais, constituindo, assim, uma classificação das sentenças de procedência. Diz Carlos Alberto que a *tutela* “condenatória fica a meio caminho, criando apenas as condições jurídicas, com a constituição do título executivo”, para que a satisfação possa ocorrer no processo de execução. Ora, se a condenação fica a “meio caminho”, e a satisfação ocorre através da execução, não há como entender a *condenação como tutela*, mas apenas como um *meio técnico processual* destinado a viabilizar a *satisfação, ou seja, a tutela ressarcitória*.

Carlos Alberto ainda afirma, ao referir-se ao que chama de “tutelas mandamental e executiva”, que essas duas “*satisfazem no mesmo processo, por meio de atos materiais, realizados depois da sentença, aptos a produzir alterações no mundo fático*”. O eminente professor volta a falar de como e onde as “*tutelas satisfazem*”, quando na verdade está discorrendo sobre como e onde as “*sentenças satisfazem*”.

O significado de tutela somente pode ser encontrado quando se pergunta o que a sentença satisfaz, ou melhor, o que a sentença presta como forma de tutela do direito. A sentença mandamental, por exemplo, pode prestar tutela inibitória ou tutela ressarcitória na forma específica, pois o juiz pode ordenar, sob pena de multa, para alguém não violar um direito ou para alguém reparar um dano na forma específica. Ora, é evidente que a sentença mandamental não constitui uma forma de tutela do direito, até porque, se fosse assim, teríamos uma única forma de tutela produzindo resultados substanciais completamente diferentes. Na verdade, a técnica processual estaria sendo chamada de tutela jurisdicional, esquecendo-se os resultados do processo no plano do direito material – esses, sim, as formas de tutela. Formas de tutela, como é pouco mais do que óbvio, são as tutelas inibitória e ressarcitória na forma específica (por exemplo), e não as sentenças (condenatória etc.).

Sublinhe-se que a pretensão processual tem duas faces, constituindo a tutela jurisdicional do direito uma resposta à pretensão à tutela jurisdicional do direito, e não resposta à pretensão à sentença. *Apenas a pretensão à tutela jurisdicional do direito, e não a pretensão à sentença, possui um conteúdo variável capaz de influir sobre a utilização das técnicas processuais – por exemplo, das sentenças e dos meios executivos.*

Porém, o que realmente importa é que as formas de tutelas jurisdicionais dos direitos são exigidas e prometidas pelo direito material, nada tendo a ver com as sentenças e com os procedimentos. Falar em tutela jurisdicional dos direitos implica assumir uma postura dogmática preocupada com uma forma peculiar de pensar o direito material e a sua relação com o direito processual. Nessa dimensão, frisa-se que a titularidade de um direito deve significar uma posição juridicamente protegida, para a qual são imprescindíveis formas de tutela ao direito. Vale dizer que importa mais do que afirmar que existe direito ao meio ambiente sadio saber que há direito à tutela inibitória e à tutela ressarcitória na forma específica, assim como vale mais do que

estabelecer que há direito à honra deixar claro que há direito à tutela inibitória e à tutela ressarcitória em razão de dano moral. *Apenas depois é que entra em cena o problema da adequação das técnicas processuais para a prestação de tais tutelas.* Em suma, *não há como pensar em tutela jurisdicional sem separar as várias formas de tutela dos direitos exigidas e prometidas pelo direito material das técnicas processuais que devem viabilizar a sua prestação.*

A importância da relação entre as formas de tutela dos direitos, que se inserem no processo como pretensões à tutela jurisdicional dos direitos, e a ação processual está em garantir o direito à ação adequada à prestação das tutelas exigidas pelo direito material. Por isso não há como imaginar que as tutelas jurisdicionais são as *formas processuais* de prestação das tutelas dos direitos.³²¹

Aliás, a ideia de que a tutela jurisdicional é a sentença *implicaria negação de todo o esforço de se ter uma ação adequada ao plano do direito material.* Ora, se existe direito à ação adequada é porque há, também, direito à sentença adequada à tutela do direito material. Como a ação adequada, isto é, as técnicas processuais idôneas devem ser conformadas a partir da tutela jurisdicional pleiteada, *é evidente que a sentença não pode ser confundida com a tutela jurisdicional do direito, uma vez que deve se pautar a partir dela.*

A não aceitação da teoria da ação de direito material implica assumir a responsabilidade pela construção de outra que possa explicar de forma dogmaticamente coerente as relações entre o processo e o direito material. Tal teoria, além de ter de dar conta do que se garante no plano do direito material, deve evidenciar o modo como o direito material influi sobre o processo para permitir a obtenção do que é por ele prometido. *Daí a razão pela qual se entende que o conceito de tutela jurisdicional deve ser buscado nas formas de tutela do direito material, e que a pretensão à tutela jurisdicional do direito deve influir na conformação da ação adequada. Há pretensão à tutela jurisdicional do direito – isto é, à tutela inibitória e não à sentença mandamental, por exemplo – e há direito à construção da ação adequada à tutela do direito e ao caso concreto.*

Se não se pode aceitar a perfeição dogmática da ideia de ação de direito material, também é indiscutível que a teoria da ação abstrata e única – ou de demanda indiferente ao direito material, caso se prefira – não está de acordo com o Estado constitucional, os direitos fundamentais e a própria legislação processual. O que se propõe, em outras palavras, é a existência de um direito à construção da ação adequada à tutela do direito material e ao caso concreto, o qual é obviamente autônomo em relação ao direito material, mas tem a sua legitimidade dependente da tutela jurisdicional de direito reclamada.

4.16. O significado do direito de ação no Estado constitucional. Visto em uma perspectiva histórica, fica fácil perceber que o direito de ação sofreu de forma muito significativa os influxos da cultura processual civil. De uma perspectiva preocupada apenas com a *separação conceitual entre direito e processo* – que dominou o debate doutrinário desde a célebre polêmica entre Windscheid e Muther na metade do Oitocentos na Alemanha até a derradeira manifestação na *prolusione torinese* de Liebman na metade dos Novecentos na Itália –, passou-se a um debate cada vez mais preocupado com os *resultados* que o exercício do direito de ação seria capaz de produzir. Vale dizer: o direito de ação deixou de ser pensado apenas em uma *perspectiva conceitual* e passou a ser pensado também em uma *perspectiva funcional*.

Esse trajeto do *conceito à função* impactou profundamente a maneira de compreender o direito de ação: de uma *compreensão estática*, que confundia o simples *ato de demandar* com o direito de ação, passou-se a uma *compreensão dinâmica*, que vê a demanda como apenas um dos atos que compõem o direito de ação, cujo conteúdo abarca *todas as posições jurídicas que estruturam proceduralmente* o direito ao processo justo. Isso significa que o direito de ação deixou de ser confundido com o direito de demandar e passou a ser compreendido como direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva mediante processo justo. Com isso, abriu-se a oportunidade para o direito de ação incorporar técnicas processuais capazes de viabilizar a *tutela específica dos direitos* (técnicas de distribuição do ônus da prova, técnicas antecipatórias, técnicas de julgamento, sentenças diferenciadas e técnicas executivas idôneas), com o que se relegou a *tutela pelo equivalente monetário* a um lugar secundário no quadro da tutela jurisdicional dos

direitos. Tudo isso significa que pensar o direito de ação como simples direito à sentença constitui página virada na história da cultura processual civil. É preciso compreendê-lo como direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva mediante processo justo.

Art. 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código.

1. Jurisdição. Jurisdição é o poder do Estado de interpretar e aplicar o direito de maneira autoritativa mediante a atuação de um terceiro imparcial com irrevisibilidade externa de seus provimentos. No Estado Constitucional, essa atividade deve ser levada a efeito na dimensão da Constituição (art. 1º, do CPC), sem descuidar da eficácia direta dos direitos fundamentais materiais e processuais sobre o problema debatido em juízo, da possibilidade de controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos em geral pelo Poder Judiciário e da possibilidade de controle de convencionalidade da legislação interna (art. 14, do CPC).

2. Jurisdição civil. No Brasil, a jurisdição civil abarca toda jurisdição não penal. Essa solução data do Código de 1939. O direito processual civil disciplinado no Código de Processo Civil é o nosso direito processual geral, servindo de fonte subsidiária para solução de eventuais lacunas na legislação processual extravagante e ainda para os processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos. Toda justiça não penal é considerada civil para efeitos de aplicação do Código de Processo Civil.

3. Unidade da jurisdição. A jurisdição é una, porque igualmente uno é o poder do Estado de que se serve. A jurisdição é deferida a todos os juízes em todo o território nacional. O poder jurisdicional não é fracionável. O que se reparte é a competência, que com aquela não se confunde: jurisdição é poder, competência é capacidade para exercer poder. A jurisdição concerne à existência dos atos decisórios; a competência, à validade.

4. Juízes e Tribunais. A jurisdição é exercida pelos juízes e tribunais que compõem o Poder Judiciário (arts. 92, da CRFB, e 16, do CPC). Embora nem o art. 16 e nem o art. 926, do CPC, façam distinção entre as funções dos juízes e tribunais em nossa ordem jurídica, fazê-lo é da mais alta relevância para que a Justiça Civil possa funcionar efetivamente entre nós.

Uma adequada organização das cortes judiciárias em determinada organização judicial é de fundamental importância por inúmeras razões. Duas, no entanto, merecem desde logo menção.

A uma, desde uma perspectiva interna, uma adequada distribuição das competências entre as cortes judiciárias promove a *economia processual* ao viabilizar a *racionalização* da própria atividade judiciária. Importa que os tribunais trabalhem apenas na medida em que necessário o seu trabalho para consecução dos fins a que se encontram vinculados do ponto de vista da estrutura judiciária. *É preciso que as cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor.* ³²² A duas, desde uma perspectiva externa, a *tempestividade da tutela jurisdicional*, já que a abertura de determinadas instâncias judiciárias – que obviamente consome tempo para o seu percurso – só se justifica à luz do escopo para que foram pensadas dentro da organização dos tribunais.

Seja do ponto de vista daqueles que *integram o sistema judiciário*, seja do ponto de vista daqueles para os quais esse *existe*, é fácil perceber, portanto, que o ponto crucial para uma idônea organização das cortes judiciárias está centrado na *função* que essas devem desempenhar na ordem jurídica. Vale dizer: o parâmetro a partir do qual é possível aferir a *pertinência de determinadas atividades* desempenhadas pelas cortes – e, bem assim, analisar o *grau de adequação da respectiva estruturação* – está na perfeita individualização do escopo que essas devem perseguir.

É claro, no entanto, que esse escopo não é assinalado às cortes por elas mesmas. Não é a organização judiciária que impõe a si mesma a finalidade que tem de ser por ela buscada – *é o direito processual civil que o faz*. E sendo a finalidade do processo civil no Estado Constitucional dar tutela aos direitos, é natural que esse fim seja o mesmo perseguido pelas cortes encarregadas de aplicá-lo. Assim, a questão está em saber se todos os juízes e tribunais que integram o sistema

judiciário devem promover concomitantemente a tutela dos direitos nas suas duas dimensões ou se, do contrário, deve haver uma distribuição interna de tarefas entre os tribunais que integram a Justiça Civil.

A solução que melhor atende à necessidade de economia processual e tempestividade da tutela jurisdicional é a que partilha a tutela dos direitos em dois níveis judiciais distintos, correspondentes às duas dimensões da tutela dos direitos. O ideal é que apenas determinadas cortes sejam vocacionadas à prolação de uma decisão justa e que outras cuidem tão somente da formação de precedentes. Assim, uma organização judiciária ideal parte do pressuposto da necessidade de uma cisão entre *cortes para decisão justa* e *cortes para formação de precedentes* – ou, dito mais sinteticamente, entre *Cortes de Justiça* e *Cortes de Precedentes*.

Trata-se, de resto, de uma distinção normalmente traçada pela doutrina, que reconhece basicamente duas funções às cortes: i) resolver controvérsias (“*resolution of disputes*”) e ii) enriquecer o estoque de normas jurídicas (“*enrichment of the supply of legal rules*”).³²³ Vale dizer: i) prolatar decisões justas – e efetivá-las adequadamente, em sendo o caso – e ii) dar unidade ao direito mediante a formação de precedentes.

Em um sistema que distribui adequadamente as tarefas entre as cortes que integram a Justiça Civil, pode-se dizer que os *órgãos jurisdicionais ordinários* devem cuidar da produção de *decisões justas* (art. 6.º, do CPC), sendo responsabilidade dos *órgãos jurisdicionais extraordinários* a promoção da *unidade do Direito* mediante a formação de precedentes (art. 926, do CPC)³²⁴. De resto, essa é razão pela qual é possível afirmar que rigorosamente “*le vere ‘corti di precedente’ sono le corti supreme*”.³²⁵

É claro que, em ambos os níveis, o material com que trabalham os juízes é muito semelhante – o processo civil, sendo meio para tutela dos direitos, depende sempre da afirmação de um *caso* sobre o qual discordam as partes a respeito da adequada solução. A distinção se estabelece, porém, nas diferentes maneiras com que os *casos ganham relevo* e *colocam-se no influxo* da atividade das cortes. Quando a corte está pré-ordenada para tutela dos direitos mediante decisão justa, a *interpretação normativa é meio* para obtenção do *fim justa decisão do caso*. Do contrário, quando está direcionada para tutela do direito mediante precedente, o *caso concreto é apenas um meio* – um verdadeiro “*pretexto*”³²⁶ – para *formulação da adequada interpretação das normas nele envolvidas*. E são justamente essas *diferentes direções* que podem ser estabelecidas entre o caso e suas dimensões fático-normativas que justificam a divisão de tarefas entre as Cortes de Justiça e as Cortes de Precedentes.

Tendo diferentes funções, é natural que se valham igualmente de diferentes meios para bem desempenhá-las. Para ficarmos apenas com um exemplo: as Cortes de Justiça – Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais – têm a função de resolver casos com justiça (inclusive questões repetitivas, valendo-se da regra do *collateral estoppel*, art. 976 e ss.) e de uniformizar a jurisprudência (mediante incidente de assunção de competência, art. 947, do CPC), ao passo que as Cortes Supremas – o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça – têm a função de dar unidade ao direito mediante a formação de precedentes (arts. 926 e 927, do CPC).

5. Território Nacional. A regra é que todas as pessoas que se encontram no território nacional são suscetíveis à jurisdição brasileira. Excepcionalmente, contudo, Estados estrangeiros, diplomatas e quejandos, em se tratando da prática de atos de império, encontram-se imunes à jurisdição nacional. Atos de mera gestão são, todavia, sindicáveis perante a jurisdição brasileira.

Assim, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “o novo quadro normativo que se delineou no plano do direito internacional, e também no âmbito do direito comparado, permitiu – ante a realidade do sistema de direito positivo dele emergente – que se construísse a teoria da imunidade jurisdicional relativa dos Estados soberanos, tendo-se presente, para esse específico efeito, a natureza do ato motivador da instauração da causa em juízo, de tal modo que deixa de prevalecer, ainda que excepcionalmente, a prerrogativa institucional da imunidade de jurisdição, sempre que o Estado estrangeiro, atuando em matéria de ordem estritamente privada, intervier em domínio estranho àquele em que se praticam os atos *jure imperii*”.³²⁷

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

1. Ação como direito à tutela adequada, efetiva e tempestiva mediante processo justo. O direito de ação não pode mais ser visto obviamente com um perfil estático (em que se confunde com a demanda, isto é, com o ato inicial do processo) e ligado apenas à entrega da sentença de mérito (que desconsidera a necessidade de realização do direito proclamado na sentença como considerar-se cumprido e acabado o ofício jurisdicional, art. 4.º, do CPC). O direito de ação é um direito dinâmico, porque é exercido ao longo de todas as fases que compõem o direito ao processo justo, e preordenado à tutela adequada, efetiva e tempestiva dos direitos, com o que não se limita à prolação da sentença de mérito, englobando necessariamente todas as técnicas processuais que se fizerem necessárias para realização dos direitos. Daí porque hoje se entende que o direito de ação constitui direito à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva mediante processo justo.

2. Interesse e legitimidade. O interesse de agir concerne à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional postulada pelo demandante.³²⁸ A legitimidade para causa (ou *legitimitatio ad causam*), que não se confunde com a legitimidade para o processo (ou *legitimitatio ad processum*, conhecida ainda como capacidade para estar em juízo), concerne à pertinência subjetiva da ação, atine à titularidade (ativa e passiva) da ação.

Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Houve um tempo em que se chegou a imaginar que o conceito de interesse processual seria um conceito inoportuno³²⁹ ou mesmo supérfluo, como “*la quinta ruota del carro*”.³³⁰ O conceito de interesse de agir, porém, aparece nas principais legislações processuais modernas (por exemplo, art. 100, *Codice di Procedura Civile* italiano), servindo para evidenciar a *necessidade* (isto é, se existe outro meio *igualmente efetivo*, para além do exercício da ação, para a tutela do direito) e a *utilidade* (isto é, a *adequação* da ação para promoção do fim visado pelo demandante) da tutela jurisdicional.

A legitimidade para agir é a individualização do interesse: é a pertinência subjetiva da ação em face da existência do interesse.³³¹ É legítimo para causa quem tem interesse ou quem está autorizado pelo ordenamento jurídico a atuar em seu benefício. A legitimação pode ser ordinária, quando a ordem jurídica reconhece o direito de ação a quem se alega titular do direito material postulado em juízo, ou extraordinária, quando a ordem jurídica reconhece o direito de ação ser exercido por terceiro em benefício daquele a que se atribui a existência do direito material (art. 18, do CPC).

Interesse e legitimidade não são mais considerados condições da ação no direito brasileiro. Como já observamos, são requisitos para a concessão da tutela jurisdicional ao direito – a ação existe, ainda que inexista interesse e legitimidade. Nada obstante, ausente o interesse ou a legitimidade, a tutela jurisdicional ao direito não pode ser prestada.

3. Aferição do Interesse e de Legitimidade. O interesse e a legitimidade para causa representam requisitos para o julgamento do pedido e devem ser aferidos *in status assertionis*, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.³³² Havendo manifesta ilegitimidade para causa ou quando o autor carecer de interesse processual, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 330, II e III, do CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).

Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte ou da ausência de interesse do autor, há resolução de mérito (art. 487, I, do CPC). No primeiro caso, não há que se pensar na formação de coisa julgada (art. 502, do CPC). Nada obstante, mesmo inexistindo sentença de mérito e coisa julgada, porque o pronunciamento judicial é capaz de obstar nova propositura da demanda, caberá ação rescisória (art. 966, § 2.º, I, do CPC). No segundo, há resolução de mérito e formação de coisa julgada, seguindo-se a regra geral da possibilidade de propositura de ação rescisória.³³³

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando

autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

1. Substituição Processual. A legitimação para agir pode ser ordinária (quando há coincidência entre a legitimação para causa e a titularidade do direito afirmado em juízo) ou extraordinária (quando não há essa identidade), sendo espécie dessa última a substituição processual. Embora equívoca, a expressão tem largo uso na doutrina e no foro.³³⁴ Não se confunde de modo nenhum com a representação, em que o representante atua em nome do representado, invocando direito do representado; na substituição processual, há invocação de direito alheio, propondo o substituto a ação em nome próprio.

É instituto do direito processual civil individual, sem pertinência ao direito processual civil coletivo, em que não há sentido em aludir-se à dicotomia “direito próprio-direito alheio”. A utilização dos termos “legitimação extraordinária” e “substituição processual” no processo coletivo tem finalidade exclusivamente didática, já que não se pode conceber o processo coletivo à luz de conceitos do processo individual.

Quando se pensa em “direito alheio”, raciocina-se a partir de uma visão individualista, obviamente contrária à filosofia do processo coletivo. A alusão à propositura de ação em nome próprio para tutela de direito alheio como algo excepcional não só parte da premissa de que apenas aquele que se afirma titular do direito material está autorizado a defendê-lo em juízo, mas também supõe que só existem direitos individuais.

As noções de direitos essencialmente coletivos (direitos coletivos e direitos difusos) e de direitos acidentalmente coletivos (direitos individuais homogêneos), como é óbvio, rompe com a noção de que o direito ou é próprio ou é alheio. Se o direito é da comunidade ou da coletividade, não satisfaz mais a clássica dicotomia. Se o direito pertence a um grupo de pessoas e existem vários legitimados para proteção em nome de todos os titulares, então também não é mais possível imaginar que tão somente aquele que se afirma titular do direito tem legitimidade para atuá-lo em juízo.

2. Excepcionalidade. Só se admite a substituição processual se existe expressa autorização no ordenamento jurídico para tanto. Daí a tipicidade das hipóteses de substituição processual em nosso ordenamento.

Embora só se admita a substituição processual nos casos em que há expressa autorização, o que denota a sua excepcionalidade, é certo que existe uma diferença muito significativa entre o Código de 1973 e o Código de 2015 nesse particular: enquanto o art. 6.º, Código de 1973, requeria a autorização “por lei”, o art. 18, Código de 2015, autoriza a substituição quando prevista no “ordenamento jurídico”. Em outras palavras, o Código autoriza a possibilidade de criação de legitimação extraordinária por negócios jurídicos – que obviamente integram o conceito de ordem jurídica.³³⁵

3. Poderes. No plano processual, o substituto tem todos os poderes inerentes à ação, podendo alegar, postular a admissão de provas, recorrer e outros, sendo-lhe vedado, todavia, prestar depoimento pessoal. Não pode, contudo, praticar atos que importem em disposição do direito material afirmado em juízo (renúncia ao direito, reconhecimento do pedido, transação), salvo com prévia e expressa anuência do substituído.

4. Assistente litisconsorcial. Havendo substituição, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial (arts. 18, parágrafo único, e 124, do CPC). Vale dizer: como litisconsorte do substituto, na medida em que a intervenção como assistente litisconsorcial significa na verdade intervenção como litisconsorte.

5. Coisa julgada. A coisa julgada vincula tanto o substituto como, por excelência, o substituído.³³⁶ Como o direito debatido em juízo é do substituído, o endereço substancial da tutela

jurisdicional – e, portanto, a indiscutibilidade do dispositivo em que veiculada – é a sua esfera jurídica.³³⁷

6. Substituição processual, cooperativa e ato cooperativo. A cooperativa tem legitimidade para substituir os seus cooperados tanto quando litiga em juízo a respeito de atos-fins como quando litiga a propósito de atos-meios. Uns e outros integram o conceito de ato cooperativo.

A cooperativa é entidade que apresenta natureza comunitarista: a sua finalidade está em prestar serviços aos seus próprios sócios. Para alcançar os seus objetivos, a sociedade cooperativa tem de praticar atos cooperativos. A Lei 5.764/1971, define o ato cooperativo como aquele praticado entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais (art. 79). A legislação nesse passo apenas alude aos chamados atos-fins, que são necessariamente atos-internos, que encarnam a prestação de serviços pela cooperativa aos seus próprios sócios.

Ocorre que para realização dos atos-fins, muitas vezes a cooperativa tem de praticar uma série de atos-meios, que são por ela praticados com terceiros, os chamados de atos-externos. Esses atos também devem ser considerados atos cooperativos, porque sem eles não há que se falar na possibilidade da prática dos atos-fins. São atos cooperativos por conexão. A cooperativa é substituta processual de seus cooperados tanto no que concerne aos atos-fins como no que atine com os atos-meios.

Art. 19. O interesse do autor pode limitar-se à declaração:

I – da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica;

II – da autenticidade ou da falsidade de documento.

1. Ação declaratória. A condenação sempre polarizou a atenção dos juristas. No direito romano, por exemplo, chegou-se a supor que a condenação poderia dar conta de todas as situações passíveis de tutela.³³⁸ Nada obstante, é certo que a declaração não é um conceito estranho à experiência jurídica romana.³³⁹ panoramicamente, as *praeiudicialis formula* evoluíram para as *actio praeiudicialis*, cobrindo toda a sua extensão unicamente a *intentio*.³⁴⁰ Era a partir desses remédios que o direito romano procurava outorgar certeza jurídica.

No período do *jus commune*, a doutrina procurou identificar nas *provocationes ad agendum* (juízos provocatórios, de jactância), de origem germânica e inspiração romana,³⁴¹ uma maneira incipiente de prover a certeza jurídica, viabilizando-se mediante o seu exercício uma declaração a respeito da existência de determinada situação jurídica.³⁴² Nada obstante, essas ações mais se parecem com ações voltadas à tutela preventiva do que propriamente ações limitadas à declaração.³⁴³ Nesse período, tiveram maior relevo as *provocationes ex lege diffamari e si contendat*.³⁴⁴

O direito lusitano comum conheceu e praticou os processos provocatórios, tendo em conta o Alvará de 30.08.1564, Lei III, que passou para as Ordenações Filipinas, Livro III, Título 11, § 4.º. No direito brasileiro, porém, pouco se exerceram as *provocationes*, haja vista expressa proibição veiculada na Resolução Imperial de 28.12.1876.³⁴⁵

Com os contornos que conhecemos, a ação declaratória remonta ao direito alemão (§ 231, ZPO de 1877), revisto em 1898 (§ 256),³⁴⁶ inspirada no modelo francês das *actions en reconnaissance*.³⁴⁷ O Código de 1939 cuidava da ação declaratória no parágrafo único do art. 2.º e no art. 290,³⁴⁸ ao passo que o Código de 1973 o fazia em seus arts. 4.º (ação declaratória) e 5.º (ação declaratória incidental).

Com a propositura de ação declaratória, busca-se a prestação de tutela capaz de gerar certeza, terminando-se com eventual estado de dúvida a respeito da existência, inexistência ou modo de ser de determinada relação jurídica ou da autenticidade ou falsidade documental. O bem da vida que se pretende é a obtenção de certeza – a ação declaratória, portanto, constitui instrumento para

a promoção da segurança jurídica.

2. Interesse do autor. O interesse que autoriza a propositura de ação declaratória é o interesse jurídico, objetivo e atual. O interesse é jurídico quando, de alguma forma, a conduta de alguém possa ofender ou ofenda a esfera jurídica do demandante, apanhando direito, pretensão ou exceção, gerando incerteza ou insegurança. Objetivo, no sentido de que deve ter matriz em alguma conduta (ou fato exterior) de alguém capaz de incutir, no homem médio, incerteza ou insegurança. Atual, sendo efetivamente existente o interesse, e não meramente possível.

3. Existência, inexistência ou modo de ser de relação jurídica. A ação declaratória pode ter por objeto a certificação da existência, inexistência ou do modo de ser de determinada relação jurídica (vale dizer, do modo como se manifestam direitos, deveres, pretensões, obrigações e exceções que a caracterizam). Quaisquer relações jurídicas são declaráveis, desde que se alegue a sua ocorrência ou inoccorrência concreta e precisa.³⁴⁹

Admite-se igualmente ação declaratória para obtenção de certeza “quanto à exata interpretação de cláusula contratual” (Súmula 181, do STJ) e para “reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários” (Súmula 242, do STJ). Admite-se ainda ação declaratória para certificação da existência de direito à compensação tributária, o que pode ser levado a efeito, ainda, pela via do mandado de segurança (Súmula 213, do STJ).

4. Autenticidade ou falsidade de documento. De regra, a ação declaratória não pode ser proposta tendo por objeto fatos. A tanto impede o direito fundamental à ampla defesa (art. 5.º, LV, da CRFB). Nosso Código de Processo Civil excepcionalmente possibilita, contudo, ação para declaração de autenticidade ou falsidade de documento. A autenticidade concerne à autoria do documento; a falsidade, ao seu conteúdo. Havendo dúvida sobre uma ou outra, cabe ação declaratória.

5. Ação declaratória e título executivo. A sentença declaratória oriunda do exercício de ação declaratória não dá lugar à formação de título executivo judicial e consequente acesso à execução forçada. Limita-se a prestar certeza.³⁵⁰

6. Demais ações declaratórias. O artigo em comento não exclui a existência de outras ações declaratórias. A ação de consignação em pagamento, assim como a ação de demarcação de terras e outras são igualmente declaratórias.

Art. 20. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito.

1. Ação declaratória e violação do direito. O Código de 1939 referia no parágrafo único do seu art. 2.º que “o interesse do autor poderá limitar-se à declaração da existência ou inexistência de relação jurídica ou à declaração de autenticidade ou falsidade de documento”. O Código de 1973, apesar das críticas lançadas,³⁵¹ continuou a empregar a expressão “limitar-se à declaração”.

Sob a vigência do Código de 1939, a doutrina procurou explicar que a expressão “poderá limitar-se à declaração” funcionava como um limite à propositura da ação declaratória: “se a relação de direito já estiver, por assim dizer, *madura*, de forma a autorizar a proposição da ação condenatória, isto é, se o direito já houver sido violado, não poderá o seu titular, *por falta de interesse*, recorrer à ação declaratória”.³⁵² O Código de 1973, porém, procurou precisamente responder a essa interpretação, desautorizando-a (art. 4.º, parágrafo único).

A doutrina procurou desde logo justificar a opção legal: “tendo o ocorrido a violação do direito, pode o autor propor ação condenatória; mas se se contenta com ‘os limitados efeitos da sentença declaratória’, não lhe nega a lei o direito de escolha; e porque é lícito ao autor restringir os efeitos jurídicos justamente no ponto em que a lei lhe faculta ampliá-los”,³⁵³ dando conta, assim, da interdependência existente entre o *caput* do art. 4.º e seu parágrafo único, justificando o emprego da locução “pode limitar-se (...)”.

O Código de 2015, na esteira do Código de 1973, tomando partido a respeito da discussão doutrinária havida ao tempo do Código de 1939 a respeito do assunto, explicitou que é possível a propositura de ação declaratória ainda que já tenha ocorrido a violação do direito. A justificativa reside no prestígio que se deve reconhecer à autonomia individual, sendo lícito ao demandante escolher a espécie de tutela que melhor atende à sua necessidade e ao seu interesse no plano do direito material.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Amplamente, Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*. São Paulo: Ed. R T, 2015, p. 27-184, vol. I.

2

Segundo Kelsen: “Tanto quanto se possa distingui-las, a diferença entre função jurisdicional e função legislativa consiste antes de mais nada em que esta cria normas gerais, enquanto aquela cria unicamente normas individuais” (Jurisdição constitucional, p. 151).

3

Eugenio Bulygin, ¿Los jueces crean derecho?, cit., p. 10; ver Ulises Schmill Ordóñez, Observaciones..., cit., p. 86: “Kelsen siempre ha enfatizado esta dimensión creadora de normas. La norma creada de grada inferior no repite el contenido de la norma que la determina, el de la norma que es su fundamento; por el contrario, visto el contenido de la norma inferior, abstraída de los actos de su creación, etc., y comparado con el contenido de la norma condicionante, puede comprobarse que siempre hay un incremento en el contenido, que no hay una relación analítica entre ellos, sino más bien de carácter sintético. Con esto quiero decir que la actividad creadora de normas tiene por función esencial incrementar el contenido normativo que comienza en la constitución, se continúa en las leyes, reglamentos, circulares, disposiciones administrativas y sentencias, todas las cuales colaboran para dotar de significado al último acto de ejecución”. Sobre o tema da criação judicial do Direito, igualmente, Riccardo Guastini, *Lezioni di Teoria del Diritto e dello Stato*, p. 95-104.

4

Eugenio Bulygin, ¿Los jueces crean derecho?, cit., p. 13-14.

5

Essa observação é válida mesmo diante do fato de Kelsen ter chegado à conclusão de que existem várias possibilidades de aplicação de determinada norma e que todas essas alternativas são igualmente válidas desde que situadas dentro da moldura normativa (*Teoria Pura do Direito*, p. 390-391), porque ainda assim, para Kelsen, a jurisdição está apenas aplicando uma norma preexistente outorgada pelo legislador.

6

É claro, no entanto, que não se pretende equiparar a visão de Kelsen sobre o Direito em geral com a visão clássica a seu respeito existente em Oitocentos, cultura jurídica da qual decorre diretamente o pensamento de Chiovenda. A questão aqui analisada limita-se obviamente à relação entre a legislação e a jurisdição. Para uma comparação geral do pensamento kelseniano com a cultura jurídica dos Oitocentos, Pierluigi Chiassoni, *L'Indirizzo Analitico nella Filosofia del Diritto*, p. 303-376.

7

Ver Gustavo Zagrebelsky, *El derecho dúctil*, cit., p. 136-139.

8

Idem, *ibidem*..

9

Ver Mirjan R. Damaška, *The faces of justice and state authority*, p. 10-20.

10

Lembre-se que os direitos fundamentais fundam princípios objetivos orientadores do modo de ser do ordenamento jurídico.

11

John Rawls aponta que um dos princípios do constitucionalismo reside na distinção entre lei mais alta e a lei comum: “A lei mais alta é expressão do poder constituinte do povo e tem a autoridade mais alta da vontade de ‘Nós, o Povo’, ao passo que a lei ordinária tem a autoridade do poder ordinário do parlamento e do eleitorado, e é uma expressão desse poder. A lei mais alta restringe e guia esse poder ordinário” (*Political liberalism*, cit., p. 231).

12

Ver José Joaquim Gomes Canotilho, *Direito constitucional e teoria da constituição*, cit., p. 1.225: “O princípio da interpretação conforme a Constituição é um princípio geral de interpretação que, no domínio específico da jurisdição constitucional, remonta ao velho princípio da jurisprudência americana, segundo a qual os juízes devem interpretar as leis in harmony with the constitution. (...) o princípio da interpretação conforme a constituição é um instrumento hermenêutico de conhecimento das normas constitucionais que impõe o recurso a estas para determinar e apreciar o conteúdo intrínseco da lei”. Note-se que o mesmo termo, interpretação conforme a Constituição, é utilizado pela literatura para descrever duas coisas: um princípio geral de interpretação e uma técnica específica de decisão judicial em sede controle de constitucionalidade.

13

Ver Javier Jiménez Campo, *Derechos fundamentales – Concepto y garantías*, p. 51.

Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios*, p. 204-217. Observe-se, porém, que a proporcionalidade não é o único meio possível para estruturar a aplicação de outras normas – mesmo que se trate de normas que preveem direitos fundamentais. Todos os postulados normativos aplicativos (ponderação, concordância prática, razoabilidade etc.) são capazes, a princípio, de colaborar para a solução de conflitos normativos. Sobre o assunto, v. Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios*, p. 163 e ss.

Idem, p. 50-55. Contra, entendendo que a jurisdição cria direitos e que a ordem jurídica é uma ordem monista, Darci Ribeiro, *La Pretensión procesal y la tutela judicial efectiva – Hacia una teoría procesal del derecho*, p. 207; igualmente, Esboço de uma teoria processual do direito, *Da Tutela Jurisdicional às Formas de Tutela*, p. 17-34. É preciso perceber, contudo, que o direito objetivo não se limita a hierarquizar os interesses sociais. As proposições textuais – em que muitas vezes vão implicadas preferências sobre necessidades, bens e interesses – obviamente não são ainda normas, mas inequivocamente oferecem grande parte da sua matéria-prima. Talvez aí resida o equívoco de Darci Guimarães Ribeiro: afirmar que o papel do juiz é criativo porque os dispositivos ainda não são normas. É certo que a norma que irá disciplinar o caso concreto aparece com a interpretação do Direito. Se esse momento é judicial, então o seu aparecimento ocorre no processo. Isso não autoriza, contudo, a afirmação de que antes do processo inexistem direitos – ou, dito de outro modo, que o direito objetivo não cria direitos. O papel do juiz no processo é de reconstrução da ordem jurídica a partir de dados preexistentes. Até meados do século XX existiam basicamente duas alternativas para o problema: entendia-se a jurisdição como atividade declaratória da norma preexistente e então se caracterizava a ordem jurídica como uma ordem dualista ou então se entendia a jurisdição como atividade criativa da norma e então se caracterizava o monismo do ordenamento jurídico. A percepção, contudo, de que texto e norma não se confundem, de que a interpretação é adscritiva de sentido e que a aplicação da norma não é meramente lógico-indutiva fizeram com que aparecesse uma nova maneira de compreender o dualismo da ordem jurídica – não mais a simples e ingênua declaração, mas a reconstrução da ordem jurídica no processo.

Nessa linha, diferenciando texto (dispositivo) e norma, Giovanni Tarello, *L' Interpretazione della Legge*, pp. 9/10; Riccardo Guastini, *Interpretare e Argomentare*, p. 8-9; Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell' Interpretazione Giuridica*, p. 142; Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios*, p. 50-51.

A diferença entre essas duas situações pode ser bem captada mediante os conceitos de justificação interna e justificação externa, desenvolvidos pelo jusfilósofo polonês Jerzy Wróblewski (*Legal syllogism and rationality of judicial decision. Rechtstheorie*, vol. 5, parte 1, p. 33-46). A justificação interna de uma decisão judicial ocorre quando uma decisão é inferida de suas premissas em conformidade com uma regra de inferência aceita. É o que ocorre na particularização da norma geral através de uma subsunção. Já na justificação externa, o que está em jogo não é a validade da inferência, mas a validade das premissas. A justificação externa de uma decisão exige demonstração de que suas premissas são consistentes. A cristalização da interpretação e o controle de constitucionalidade lidam exatamente com isso. Essa distinção mostra que o resultado de uma justificação externa nunca é suficiente para produzir a

norma individual do caso. Ela é bastante apenas para formular a premissa que servirá para a inferência dessa norma.

18

O conflito é concreto, porque surge diante de um caso e não se coloca em abstrato; é contingente, porque não ocasional e, portanto, não é constante (Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios*, p. 175-176).

19

Segundo Sérgio Moro, quando é declarada a inconstitucionalidade de uma lei, o grau de interferência da jurisdição sobre o legislativo é maior do que quando se faz o controle da inconstitucionalidade por omissão no caso concreto (Jurisdição constitucional como democracia, p. 244).

20

Eugenio Bulygin, ¿Los jueces crean derecho?, cit., p. 8.

21

Idem, p. 11. Perceba-se, em abono à análise de Bulygin, que Kelsen, quando trata da anulação judicial da lei em sede de controle abstrato de constitucionalidade, afirma que o tribunal constitucional atua na espécie como “legislador negativo”. Essa é a expressão que ele encontrou para sustentar, de forma um tanto ambígua, que o controle judicial de constitucionalidade não atenta contra a separação de poderes. Após reconhecer que “anular uma lei é estabelecer uma norma geral, porque a anulação de uma lei tem o mesmo caráter de generalidade que sua elaboração, nada mais sendo, por assim dizer, que a elaboração com sinal negativo e, portanto, ela própria uma função legislativa” (Jurisdição constitucional, cit., p. 151-152), Kelsen volta-se à distinção entre a elaboração e a simples anulação das leis, para dizer que um tribunal constitucional realiza uma atividade efetivamente jurisdicional: “A anulação de uma lei se produz essencialmente como aplicação das normas da Constituição. A livre criação que caracteriza a legislação está aqui quase completamente ausente. Enquanto o legislador só está preso pela Constituição no que concerne a seu procedimento – e, de forma totalmente excepcional, no que concerne ao conteúdo das leis que deve editar, e, mesmo assim, apenas por princípios ou diretivas gerais –, a atividade do legislador negativo, da jurisdição constitucional, é absolutamente determinada pela Constituição. E é precisamente nisso que a sua função se parece com a de qualquer outro tribunal em geral: ela é principalmente aplicação e somente em pequena medida criação do direito. É, por conseguinte, efetivamente jurisdicional” (idem, p. 153). Lembre-se que, de acordo com Kelsen, a diferença entre função jurisdicional e função legislativa consiste em que esta cria normas gerais enquanto aquela cria unicamente normas individuais.

22

Eugenio Bulygin, ¿Los jueces crean derecho?, cit., p. 12.

23

Idem, p. 12. Ver Carlos Nino, *El concepto...*, cit., p. 7-27.

Ressalte-se que a discussão sobre a questão de se os juízes criam direito foi um dos focos principais do célebre debate travado entre Herbert Hart – que afirmava o papel criativo da jurisdição em determinados casos – e Ronald Dworkin – que o negava –, o qual permite um amplo aprofundamento dessa matéria. Ver, a esse respeito, Herbert Hart, *O conceito de direito*, cit. (esp. Formalismo e cepticismo acerca das regras e Pós-escrito), e Ronald Dworkin, *Taking rights seriously*, cit. (esp. *The model of rules e Hard cases*, há tradução para o português, *Levando os direitos a sério*).

Essa é uma colocação que o positivismo de Hart põe a toda evidência: “Haverá sempre certos casos juridicamente não regulados em que, relativamente a determinado ponto, nenhuma decisão em qualquer dos sentidos é ditada pelo direito e, nessa conformidade, o direito apresenta-se como parcialmente indeterminado ou incompleto. Se, em tais casos, o juiz tiver de proferir uma decisão, em vez de, como Bentham chegou a advogar em tempos, se declarar privado de jurisdição, ou remeter os pontos não regulados pelo direito existente para a decisão do órgão legislativo, então deve exercer o seu poder discricionário e criar direito para o caso, em vez de aplicar meramente o direito estabelecido preexistente” (Herbert Hart, *O conceito de direito*, cit., p. 335).

Esta situação traz perplexidade por dois motivos. O primeiro é que há uma forma da regra de reconhecimento – aquela regra que, na formulação de Hart, serve para identificar as demais normas válidas do ordenamento jurídico – inseparável do exercício da jurisdição. Como explica Hart, “se os tribunais tiverem poderes para proferir determinações dotadas de autoridade quanto ao fato de uma regra ter sido violada, estas não podem deixar de ser tomadas como determinações dotadas de autoridade daquilo que as regras são. Por isso, a regra que atribui jurisdição será também uma regra de reconhecimento que identifica as regras primárias através das sentenças dos tribunais e estas sentenças tornar-se-ão uma ‘fonte’ de direito” (Herbert Hart, *The concept of Law*, Oxford: Clarendon Press, 1993, p. 96 e ss.). O segundo é o princípio, tratado por alguns como princípio de justiça, mas de qualquer modo comumente reconhecido como um princípio geral do direito, que determina que casos iguais sejam decididos igualmente (Neil MacCormick, *Legal reasoning and legal theory*, Oxford: Clarendon Press, 1987, p. 73 e ss.). Considerando-se esses dois motivos, é equivocado dizer que, num sistema que não adota a regra do stare decisis, os juízes podem se apartar sem mais das decisões anteriormente tomadas por outros juízes. Esses dois motivos impõem aos juízes um ônus de argumentação. Eles não podem pura e simplesmente passar por alto os precedentes judiciais, devendo sempre levá-los em conta.

Ver Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes Obrigatórios*, 2. ed., cit., p. 75 e ss. e p. 97 e ss.; Luiz Guilherme Marinoni, *o STJ enquanto Corte de Precedentes*, 2. ed., Ed. RT, 2014; Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas*, 2. ed.; Ed. RT, 2014 e *Precedentes – da persuasão à vinculação*, cit.

Ao menos, esta é a regra geral. Mary G. Algeo (The sources of law and the value of precedent: a

comparative and empirical study of a civil law state in a common law nation, *Louisiana Law Review*, vol. 65, 2005, p. 775-785), citada por Jordan Wilder Connors, assinala que, com exceção do Estado da Louisiana, todos os demais 49 Estados que compõem os Estados Unidos da América, tal qual o sistema de cortes federais, seguem um modelo próximo àquele operado na Inglaterra no que toca ao *stare decisis*, o qual toma o precedente como fonte de direito (no original: “*The forty-nine states in the United States, other than Louisiana, as well as the United States federal court system follow a version of the doctrine of stare decisis that is similar to the English respect for precedent and its consideration of precedent as a source of Law*”) (CONNORS, Jordan Wilder. Treating like subdecisions alike: the scope of stare decisis as applied to judicial methodology. *Columbia Law Review*, vol. 108, n. 3, p. 681-715, abr. 2008).

29

Eugenio Bulygin, ¿Los jueces crean derecho?, cit., p. 12. Como esclarece Frederick Schauer, as normas são necessariamente gerais: “Nós dizemos que há uma norma proibindo as pessoas de andar sobre o gramado se um sinal proíbe várias pessoas ao longo do tempo de andar sobre o gramado, mas nós não descreveríamos como uma ‘norma’ uma instrução particular de um pai a um filho para que ele não ande sobre este gramado neste momento. (...) Normas prescrevem tipos e não particulares. A menos que queiramos prescrever (...) para múltiplas ações é simplesmente errado usar a palavra ‘norma’” (Playing by the rules: a philosophical examination of rule-based decision-making in law and life, p. 18).

30

“*The function of a judge is to give concrete meaning and application to our constitutional values*” (Owen Fiss, The forms of justice. *Harvard Law Review*, vol. 93, p. 4). Tais valores são aqueles que “dão a nossa sociedade uma identidade e coerência interna – sua moralidade pública distintiva”. Ver Owen Fiss, Um novo processo civil (apresentação de Carlos Alberto de Salles).

31

304 U.S. 144, 152, n. 4 (1938).

32

V. John Hart Ely, *Democracy and Distrust*. Cambridge: Harvard University Press, 1980.

33

Owen Fiss, The forms of justice, cit., p. 9.

34

“The task of the judge is to give meaning to constitutional values, and he does that by working with the constitutional text, history, and social ideals” (idem, p. 4).

35

Will Kymlicka (Multicultural citizenship. A liberal theory of minority rights), embora em outro plano,

afirma que o Estado deve instituir direitos diferenciados em benefício de alguns grupos – peculiarizados pela raça ou classe ou caracterizados por culturas minoritárias –, advertindo que a proteção dos direitos das minorias não fere os princípios liberais básicos, como o da igualdade (cf. Roberto Gargarella, *Las teorías de la justicia...*, cit., p. 151). Ver também Roberto Gargarella, *Crisis de la representación política*, p. 49-76.

36

Ver Owen Fiss, *Objectivity and interpretation*. *Stanford Law Review*, vol. 34, p. 739-763.

37

Em outra parte do seu artigo *The forms of justice*, Fiss afirma: “*Judges have no monopoly on the task of giving meaning to the public values of the Constitution, but neither is there reason for them to be silent. They too can make a contribution to the public debate and inquiry. Adjudication is the social process by which judges give meaning to our public values*” (p. 1). Como diz Fallon, identificar o significado da Constituição não é a única função da Corte. Uma missão crucial da Corte é a de pôr a Constituição em execução com êxito – “*Identifying the ‘meaning’ of the Constitution is not the Court’s only function. A crucial mission of the Court is to implement the Constitution successfully*” (*Implementing the constitution*, cit., p. 58).

38

Owen Fiss, *The forms of justice*, cit., p. 29.

39

“*The values that we find – liberty, equality, due process, freedom of speech (...) – in our Constitution are ambiguous. They are capable of a great number of different meanings. They often conflict. There is a need – a constitutional need – to give them specific meaning, to give them operational content, and, where there is a conflict, to set priorities*” (idem, p. 1).

40

“*At the core of structural reform is the judge, and his effort to give meaning to our public values*” (idem, p. 17).

41

Idem, p. 2.

42

De acordo com Fiss, como um gênero de litígio constitucional, a reforma estrutural tem suas raízes no período da Corte de Warren e no extraordinário esforço de traduzir a decisão de *Brown versus Board of Education* na prática (decisão de 1954 que determinou a dessegregação das escolas norte-americanas, pondo fim à doutrina dos separados, mas iguais, que regia as relações entre brancos e negros nos Estados Unidos até então). Este esforço exigiu que os tribunais transformassem radicalmente o status quo,

reconstruindo a realidade social (idem, p. 2). Sobre o tema, consulte-se ainda Marco Jobim, *Medidas Estruturantes*, cit.

43

Idem, p. 28.

44

Ver Rolf Stürner, *Einwirkungen Rechtsschutz. Procedural law in Europe*, p. 2.336.

45

Helmut Coing, *Grundzüge der Rechtsphilosophie*, p. 144 (há tradução para o português, *Elementos fundamentais da filosofia do direito*, p. 188).

46

A pacificação social pode ser vista como um objetivo que deve ser perseguido *secundariamente* pela jurisdição, mas não serve para caracterizá-la, nem para caracterizar o seu escopo no Estado constitucional. Indicando a pacificação como escopo da jurisdição, Cândido Dinamarco, *A Instrumentalidade do Processo*, p. 159 e seguintes; Alvaro de Oliveira, *Do Formalismo no Processo Civil*, p. 107-110.

47

Ada Pellegrini Grinover, *Ações coletivas para a defesa do ambiente e dos consumidores: a Lei 7.347, de 20.07.1985, Novas tendências do direito processual*; Rodolfo de Camargo Mancuso, *Interesses difusos e ação civil pública*; Antônio Gidi, *Coisa julgada e litispendência em ações coletivas*; Pedro da Silva Dinamarco, *Ação civil pública*; Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, *Ações coletivas*; Elton Venturi, *Execução da tutela coletiva*; Rony Ferreira, *Coisa julgada nas ações coletivas*; Sérgio Cruz Arenhart, *Perfis da Tutela Inibitória Coletiva e A Tutela Coletiva de Interesses Individuais*; Fredie Didier Júnior e Hermes Zaneti Júnior, *Curso de Direito Processual Civil*, vol. IV.

48

Ver Alvaro Pérez Ragone, *¿Necesitamos los procesos colectivos? En torno a la justificación y legitimidad jurídica de la tutela de intereses multisubjetivos. Procesos colectivos e Prolegómenos de los amparos colectivos – Tutela de las incumbencias multisubjetivas. Parte General. Revista de Derecho Procesal*, vol. 1, n. 4, p. 81-95.

49

Ver H. Koch, *Prozessführung bei komplexen Verfahren in Europa. Procedural laws in Europe*, p. 337.

50

Ver Lei 4.717/1965, que regula a ação popular.

51

Segundo o art. 1.º, caput, da Lei 4.717/1965, é legitimado para a ação popular “qualquer cidadão”. O § 3.º deste artigo diz que “a prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda”.

52

Canotilho, quando alude às técnicas diretas de participação democrática, fala em democratizar a democracia através da participação (Direito constitucional, cit., p. 366).

53

Isso para não falar em teorias ainda mais insustentáveis, como as que afirmavam que o direito de ação depende da existência do direito material ou de uma sentença de procedência.

54

O que não quer dizer que esse não seja um problema fundamental para a jurisdição. Sobretudo numa sociedade complexa, marcada pelo “desacordo interpretativo razoável” – ou seja, pela condição de que pessoas que concordam abstratamente em torno de direitos fundamentais e princípios de justiça discordam acerca de qual o sentido que esses direitos e princípios devem assumir diante de situações concretas (ver Frank Michelman, *Constitutional authorship. Constitutionalism: philosophical foundations*, p. 88-89) –, não há como deixar de lado o problema de como se deve “dizer o direito” de forma aceitável para todos. Esse problema é particularmente agudo em sede de controle judicial de constitucionalidade das leis.

55

No direito português, reconhece Canotilho: “A existência de uma protecção jurídica eficaz pressupõe o direito à execução das sentenças (‘fazer cumprir as sentenças’) dos tribunais através dos tribunais (ou de outras autoridades públicas), devendo o Estado fornecer todos os meios jurídicos e materiais necessários e adequados para dar cumprimento às sentenças do juiz. Esta dimensão da protecção jurídica é extensiva, em princípio, à execução de sentenças proferidas contra o próprio Estado (CRP, art. 205./2 e 3, e, em termos constitucionalmente claudicantes, o Decreto-lei 256/A/77, de 17 de junho, art. 5. e ss., e Decreto-lei 267/85, de 12 de julho, art. 95. e ss.). Realce-se que, no caso de existir uma sentença vinculativa reconhecedora de um direito, a execução da decisão do tribunal não é apenas uma dimensão da legalidade democrática (‘dimensão objectiva’), mas também um direito subjectivo público do particular, ao qual devem ser reconhecidos meios compensatórios (indemnização), medidas compulsórias ou ‘acções de queixa’ (cfr. Convenção Europeia dos Direitos do Homem, art. 6.), no caso de não execução ilegal de decisões dos tribunais (cfr. o caso *Hornsby*, de 19.03.1997, em que o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem sublinha o momento de execução como dimensão intrínseca da Declaração do Processo)” (Direito constitucional e teoria da constituição, cit., p. 496).

Ver Luiz Guilherme Marinoni, *Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nella prospettiva della teoria dei diritti fondamentali*. Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, vol. 1, p. 93-162.

Sobre a utilização das regras processuais como estratégia de poder, ver Carlos Augusto Silva, *O processo civil como estratégia de poder: reflexo da judicialização da política no Brasil*.

Diz Kirchhof: “As declarações lapidadas em partes fragmentárias da Lei Fundamental requerem complemento e integração. Se a Constituição Federal é formada e aperfeiçoada mais de perto pela lei, então é a jurisdição ordinária a primeira garante jurisdicional deste direito. Abre-se aqui um amplo campo de atribuição de competência esclarecedora e renovadora. O ponto de partida é o dever da Corte Constitucional (BVerfG) dar aos tribunais a interpretação e a aplicação da lei positiva, simplesmente examinando se as leis conservam os valores normativos fundamentais e se observam os efeitos expansivos dos direitos fundamentais. Então são aplicadas cautelosamente cláusulas gerais de atos constitucionais, como a proibição de arbitrariedade e o princípio da proporcionalidade”. Seguindo essa linha, mas voltando-se especialmente à situação em que os juízos ordinários se deparam com questões processuais de dimensão constitucional, Kirchhof fez a seguinte ponderação antes da reforma processual ocorrida na Alemanha em 2002: “Assim, quando as posições jurídicas constitucionais reclamam unicamente a consideração de simples leis positivas, seja na concessão do direito a ser ouvido (art. 103, II, GG), na consideração do juiz natural (art. 101, I 2, GG), ou na garantia à proteção judicial (art. 19, IV, GG), é de se considerar se o legislador não deveria ceder este controle aos tribunais ordinários especializados mais próximos” (Die Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts in Zeiten des Umbruchs. NJW, 1996, p. 1.497). Os juízos ordinários não fazem controle da constitucionalidade na Alemanha. O controle de constitucionalidade é feito com exclusividade pelo Tribunal Constitucional. Entretanto, como a análise da constitucionalidade de normas processuais pelo Tribunal Constitucional mitigava muito a efetividade do processo, diante da demora e do acúmulo de serviço trazido a esse Tribunal, parte da doutrina – aí incluído Kirchhof – passou a sustentar que o juiz ordinário poderia decidir sobre violação de direito fundamental processual por parte de norma processual. Tal discussão – frise-se – ocorreu antes da reforma processual de 2002. Nesse ano foi inserido no ZPO (CPC alemão) o § 321.a, que trata do remédio por violação ao direito de ser ouvido. Nessa nova hipótese, o juiz pode entender que a parte recorrente tem razão ou que ocorreu violação ao direito fundamental. Porém, se o juiz entender que não houve violação, o remédio não terá que ser necessariamente encaminhado ao Tribunal Constitucional. Isto somente ocorrerá se o juízo ordinário chegar à conclusão de que o tema tem importância e relevância e, por estes motivos, deve ser apreciado pelo Tribunal Constitucional (ver Alvaro Pérez Ragone, *El nuevo proceso civil alemán: principios y modificaciones al sistema recursivo*. Revista de Direito Processual Civil, vol. 32, p. 357 e ss.). Discute-se se o remédio deve se limitar ao direito de ser ouvido ou deve alcançar outros direitos fundamentais processuais (ver A. Vokuhle, *Bruch mit einem Dogma: die Verfassung garantiert Rechtsschutz gegen den Richter*. NJW, 2003, p. 2.193-2.264; Hanns F. Müller, *Abhilfemöglichkeiten bei der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach der ZPO-Reform*. NJW, 2002, p. 2747; I. Kropfenger, *Zum Rechtsschutzbereich der Rüge gemäß § 321 a ZPO*. ZfP, vol. 116, p. 421-445). Decisão plenária do Primeiro Senado do Tribunal Constitucional (BVerfG), de 30.04.2003, ordenou ao legislador a demarcação dos limites, pressupostos e detalhes do remédio do § 321.a. Afirmou-se que este parágrafo não consegue conciliar na prática a correta distribuição de tarefas entre a justiça constitucional

e a ordinária e, assim, conferiu-se ao legislador prazo para corrigir o defeito ou a falha. Respondendo à ordem do Tribunal Constitucional (BVerfG), o Legislativo editou a Gesetz über die Rechtsbehelfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör. De qualquer forma, o objetivo da alusão ao sistema alemão é o de apenas demonstrar a importância do controle da constitucionalidade das regras processuais e de como o sistema do controle incidental, ao considerar essas normas, pode contribuir para a efetividade do processo.

59

Karl Engisch, *Einführung in das juristische Denken*, p. 218 (há tradução para o português, *Introdução ao Pensamento Jurídico*, p. 233-234).

60

Canotilho revela com exatidão essa preocupação: “O direito de acesso aos tribunais é um direito fundamental formal que carece de densificação através de outros direitos fundamentais materiais. A interconexão entre ‘direito de acesso aos tribunais’ e ‘direitos materiais’ aponta para duas dimensões básicas de um esquema referencial: (1) os direitos e interesses do particular determinam o próprio fim do direito de acesso aos tribunais, mas este, por sua vez, garante a realização daqueles direitos e interesses; (2) os direitos e interesses são efetivados através dos tribunais mas eles que fornecem as medidas materiais de proteção por esses mesmos tribunais” (Direito constitucional e teoria da constituição, cit., p. 464).

61

Sobre o postulado da proporcionalidade, ver, no direito brasileiro, Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios*, p. 204-217; Paulo Bonavides, Curso de direito constitucional, p. 314 e ss.; Luís Roberto Barroso, Interpretação e aplicação da constituição; Wilson Steinmetz, Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade; Virgílio Afonso da Silva, O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, vol. 798.

62

Ver Michele Taruffo, La motivazione della sentenza civile, p. 194-195; Funzione della prova: la funzione dimostrativa. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1997, p. 553-554; Il controllo di razionalità della decisione fra logica, retorica e dialettica, *Revista de Processo*. n. 143. São Paulo: Ed. RT, 2007; La motivazione della sentenza. Revista de Direito Processual Civil, vol. 30, p. 674 e ss.; Senso comum, experiência e ciência no raciocínio do juiz (conferência), p. 17.

63

Ver Marcelo Lima Guerra, Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil, p. 150 e ss.

64

Jerzy Wróblewski, Legal syllogism..., cit., p. 39.

65

Ver Frank Michelman, Justification (and justifiability) of law in a contradictory world. Nomos XXVIII: Justification, p. 71-99.

66

É a clássica imagem de Montesquieu: o juiz como simples “boca da lei” (“*la bouche qui prononce les paroles de la loi*”, *De L’Esprit des Lois*, Liv. XI, Cap. VI, p. 149).

67

O “juiz escravo da lei” é uma expressão de Bockelmann, conforme a notícia de Karl Engisch, *Einführung in das juristische Denken*, p. 190.

68

Fala criticamente em juiz como “*mere judicial slot machine*” (máquina judicial que funciona a partir da inserção de moedas), Jerome Frank, *Courts on Trial – Myth and Reality in American Justice*, p. 147; sobre o assunto, ainda, Richard Wasserstrom, *The Judicial Decision – Toward a Theory of Legal Justification*, p. 14-22.

69

Teoria Pura do Direito, p. 390-391.

70

The Concept of Law, p. 124 e ss., 238 e ss.

71

Taking Rights Seriously, p. 14 e ss., 81 e ss.

72

Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios*, p. 194-201.

73

Idem, p. 204-217.

74

Ingo Sarlet, *Curso de Direito Constitucional*, p. 230-232, com Marinoni e Mitidiero; Luís Roberto Barroso, *Curso de Direito Constitucional Contemporâneo*, p. 301-302.

Peter Häberle, *Die Wesensgehaltgarantie...*, cit., p. 117: “Inúmeras limitações a direitos fundamentais têm a finalidade de manter os direitos fundamentais como institutos. Elas não colocam em perigo a liberdade, mas sim a fortalecem, enquanto lhe proporcionam sua ‘realidade social’” (“*Zahlreiche Grundrechtsbegrenzungen erfolgen zu dem Zweck, die Grundrechte ‘als Institute’ aurechtszuhalten. Sie gefährden nicht die Freiheit, sondern stärken sie, indem sie ihr zur ‘sozialen Wirklichkeit’ verhelfen*”).

“Com o texto das disposições jusfundamentais é conciliável muito, porém não tudo. O fato de que o texto exija ou exclua uma determinada interpretação é um argumento muito forte em favor ou contra essa interpretação (...). O fato de que o argumento semântico seja muito forte não significa que se imponha sempre (...) não basta expor que a solução contrária ao texto é melhor do que a conforme ao texto; as razões em favor de uma solução contrária ao texto têm que ter um peso tal que, do ponto de vista da Constituição, justifiquem um afastamento do texto (...). Portanto, o texto das disposições jusfundamentais vincula a argumentação jusfundamental porque existe em seu favor a carga da argumentação” (Robert Alexy, *Teoría de los derechos fundamentales*, cit., p. 534). Ver também Robert Alexy, *Teoria da argumentação jurídica*, cit., p. 182 e ss.

Andrea Proto Pisani, *Lezioni di Diritto Processuale Civile*, p. 5.

V. Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes Obrigatórios*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011; Daniel Mitidiero, *Precedentes – da Persuasão à Vinculação*, cit.; Hermes Zaneti Júnior, *O valor vinculante dos precedentes*, *passim*. Sobre a legitimidade de um sistema de precedentes para o direito brasileiro, Paula Pessoa, *Legitimidade dos precedentes*, *passim*.

A tradição de *civil law* vive, atualmente, a contradição entre o juiz real e o juiz das doutrinas acriticamente preocupadas apenas em justificar que a nova função do juiz cabe dentro do modelo do princípio da separação dos poderes. É preciso admitir que o juiz da Revolução Francesa nasceu natimorto e que o princípio da estrita separação dos poderes sofreu mutação com o passar do tempo, tendo, nos dias que correm, outra figura. V. Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes obrigatórios*, cit., p. 23; Luiz Guilherme Marinoni, *O STJ enquanto Corte de Precedentes*; Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas*.

Secondat, Charles-Louis de (Barão de Montesquieu). *Do espírito das leis*. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 158; ver Tarello, Giovanni. *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*. Bologna: Il Mulino, 1976, p. 194.

Tarello, Giovanni. *Storia della cultura...*, op. cit., p. 294.

Para se compreender a razão pela qual o *common law*, ao contrário do *civil law*, não fez coro à ideia de que o juiz deveria apenas declarar a lei, importa perceber os diferentes significados da Revolução Inglesa de 1688 e da Revolução Francesa. Na Revolução Inglesa os juízes sempre estiveram ao lado dos legisladores, chegando a com eles se misturar e habitar uma mesma Casa. Assim, aí não houve qualquer necessidade de afirmar a prevalência da lei – como produto do *Parliament* – sobre os magistrados, mas sim a força do direito comum em face do poder real. A Revolução Inglesa não quis destruir o direito antigo, mas, ao contrário, pautou-se pela afirmação do *common law* – o direito da história e das tradições do povo inglês – para conter o poder real. De modo que toda e qualquer norma elaborada pelo legislativo estaria inserida dentro do *common law*, na busca de afirmação dos direitos e liberdades do povo inglês contra o rei – para o que os juízes colaboraram. A Revolução, bem por isto, não teve a pretensão de calar os magistrados ou a intenção de dotar o Parlamento de um poder absoluto mediante a produção de um direito novo. Ver Argüelles, Juan Ramón de Páramo; Roig, Francisco Javier Ansuátegui. Los derechos en la Revolución Inglesa. In: *Historia de los derechos fundamentales. Transito a la modernidad: siglos XVI y XVII*. t. 1, Madrid: Dykinson, 2003, p. 786 e ss.

Ver Nicola Picardi, La Vocazione del Nostro Tempo per la Giurisdizione, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 2004.

“É verdade que o legislador agiu e que sua ação é expressa como uma regra de direito material, mas os termos são tão amplos (‘boa-fé’, que não é definida no código, possui uma área quase ilimitada de potencial aplicação) que o juiz quase não é condicionado pela formulação legislativa. O que aquela norma significa depende do uso que o juiz dela faz no caso concreto. O que eles fazem com ela nos casos concretos se torna o direito factual [*law in fact*], apesar de não teórico [*law in theory*]” (Merryman, John Henry; Pérez-Perdomo, Rogelio. *The civil law tradition: an introduction to the legal systems of Europe and Latin American*. Stanford: Stanford University Press, 2007, p. 53).

Ver Bankowski, Zenon; McCormick, Neil; Morawski, Lech; Miguel, Alfonso Ruiz. Rationales for precedent. In *Interpreting precedents; a comparative study*. London: Dartmouth, 1997, p. 485.

Bankowski, Zenon; McCormick, Neil; Morawski, Lech; Miguel, Alfonso Ruiz. Rationales for precedent. In: *Interpreting precedents*, cit., p. 485.

Ver, a esse respeito, Hart, Herbert L.A. *The concept of law*. Oxford: Clarendon Press, 1993 (esp. *Formalism and rule-scepticism* e *Postscript*); Dworkin, Ronald. *Taking rights seriously*. Cambridge: Harvard University Press, 1978 (esp. *The model of rules* e *Hard cases*).

88

Hart, Herbert L. A. *The concept of law*, cit., p. 135.

89

Dworkin, Ronald. *Taking rights seriously*, cit., p. 12 e ss.

90

Luiz Guilherme Marinoni, *O STJ enquanto Corte de Precedentes*, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014; Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes obrigatórios*, cit., p. 459 e ss.; Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas*, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.

91

Em *Rationales for Precedent*, Bankowski, Neil MacCormick, Lech Morawski e Alfonso Ruiz Miguel afirmam o seguinte: “Uma vez que (ou na medida em que) nós estamos aqui tratando de sociedades caracterizadas pela fidelidade à ideologia e à prática da ordem legal ‘racional’ no sentido proposto por Max Weber (1967), podemos certamente dizer que a coerência na interpretação das disposições específicas sobre muitos casos, e práticas interpretativas que visam garantir uma coerência global do sistema jurídico, são absolutamente fundamentais para elas. Coerência em ambos os sentidos é da própria essência da ordem jurídica racional, assim como é crucial para a ideia de um discurso legal racional. Não é surpresa que, em todos os sistemas legais estudados, o valor da coerência da lei é um dos elementos-chave na compreensão da lógica local para a prática de tratar o precedente como vinculante em qualquer que seja o sentido particular ou sentidos localmente atribuídos à sua impositividade (ou, mais geralmente, sua força normativa). Isto é compreensível como uma razão independente para o precedente, enraizado na própria natureza da argumentação racional, essencial para a ordem jurídica racional. Num ponto de vista diferente, o papel unificador do precedente pode também ser visto simplesmente como aspecto do caráter unitário do sistema legal de um Estado bem organizado, o qual é papel principal das cortes sustentar. Coerência legal, em conjunto com a uniformidade da decisão, é realmente um valor reconhecido em todos os lugares, servido pelo respeito à força do argumento a partir do precedente, e o qual é função principal das cortes, em seu papel interpretativo, atingir. O valor da uniformidade pode ser tomado como um desiderato técnico-jurídico, assim como a coerência talvez possa ser considerada um aspecto da *elegantia juris*; mas ambos também concorrem para a integridade global do Estado como garante de um sistema jurídico único” (Bankowski, Zenon; Maccormick, Neil; Morawski, Lech; Miguel, Alfonso Ruiz. *Rationales for precedent*. In: *Interpreting precedents*, cit., p. 479 e ss.).

92

Neil MacCormick, *Rethoric and the Rule of Law. A theory of legal reasoning*. New York: Oxford University Press, 2005, p. 178.

93

“One of the most widely shared values in the American political system is that principles governing society should be ‘rules of law and not merely the opinions of a small group of men who temporarily occupy high office’” (Earl Maltz, *The nature of precedent*, *North Carolina Law Review*, 1988, p. 371).

94

Savigny, *Vom Beruf unser Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*.

95

Nicola Picardi, *La Vocazione del Nostro Tempo per la Giurisdizione*, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*.

96

Sobre a passagem da jurisdição ao processo como polo metodológico do processo civil, Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, p. 48-50.

97

Michele Taruffo, *Idee per una Teoria della Giusta Decisione*, *Sui Confini – Scritti sulla Giustizia Civile*, p. 219-234.

98

Amplamente, Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes Obrigatórios*.

99

Apontando a tutela dos direitos a partir do caso concreto como fim do processo civil, Vittorio Denti, *La Giustizia Civile – Lezioni Introduttive*, p. 115-117; Andrea Proto Pisani, *Lezioni di Diritto Processuale Civile*, p. 5-6; Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela Inibitória*, p. 363-373; *Curso de Processo Civil*, p. 240-241, vol. I; Daniel Mitidiero, *Antecipação da Tutela – Da Tutela Cautelar à Técnica Antecipatória*, p. 54-55.

100

Michele Taruffo, *La Corte di Cassazione e la Legge*, *Il Vertice Ambiguo – Saggi sulla Cassazione Civile*, p. 90-91.

101

Daniel Mitidiero, *Fundamentação e Precedente – Dois Discursos a partir da Decisão Judicial*, *Revista de Processo*, p. 61-78, n. 206; *A Tutela dos Direitos como fim do Processo Civil no Estado Constitucional*, *Revista de Processo*, p. 51-74, n. 229; *Cortes Superiores e Cortes Supremas – do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente*, p. 13-32.

“Em uma sociedade política complexa e numerosa, os tribunais realizam uma função essencial. Nenhum sistema de direito – seja ele baseado no precedente judicial ou nas leis – pode ser tão perfeitamente moldado de forma a não deixar qualquer espaço para disputas. Quando surge uma disputa concernente ao sentido de uma norma particular, alguma provisão para a resolução dessa disputa é necessária. (...). Para agir confiantemente segundo normas, os homens devem não apenas ter a oportunidade de aprender quais são as normas, mas devem também ter assegurado que, em caso de uma disputa sobre o significado dessas normas, haverá algum método disponível para resolvê-las” (Lon Fuller, *The morality of law*, p. 56-57). “As disputas sobre se uma regra admitida foi ou não violada ocorrerão sempre e continuarão interminavelmente em qualquer sociedade, excepto nas mais pequenas, se não houver uma instância especialmente dotada de poder para determinar, de forma definitiva e com autoridade, o facto da violação” (Herbert Hart, *O conceito de direito*, cit., p. 103).

A existência de decisões públicas, coercitivas e estáveis acerca da aplicação das normas comuns de cooperação social, como é o caso das normas jurídicas, é uma exigência racional de pessoas que querem estabelecer para si mesmas um grau máximo de liberdade igual. Como leciona John Rawls, desenvolvendo um argumento que ele atribui a Thomas Hobbes: “É razoável supor que mesmo numa sociedade bem ordenada, os poderes coercitivos do governo são até certo ponto necessários para a estabilidade da cooperação social. Pois, embora os homens saibam que partilham um senso comum de justiça e que cada um quer aderir às ordenações existentes, eles todavia podem não ter plena confiança uns nos outros. Podem suspeitar que alguns não estejam fazendo sua parte, e assim podem sentir-se tentados a não fazer a deles. A generalização dessa tendência pode eventualmente causar o colapso do esquema. A suspeita de que outros não estejam honrando seus deveres e obrigações aumenta com o fato de que, na ausência da interpretação autoritária e da imposição das regras, é particularmente fácil encontrar desculpas para infringi-las. Assim, mesmo em condições razoavelmente boas, é difícil imaginar, por exemplo, um sistema voluntário de imposto sobre a renda que funcione bem. Esse tipo de ordenação é instável. O papel de uma interpretação pública das leis legítimas, apoiada em sanções coletivas, é precisamente o de superar essa instabilidade. Impondo um sistema público de penalidades, o governo afasta os motivos para se pensar que os outros não estão observando as regras” (Uma teoria da justiça, p. 262-263).

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, *Curso de Direito Constitucional*, p. 759-762, com Ingo Sarlet.

Ver Eduardo Talamini, *Coisa julgada e sua revisão*; Antônio do Passo Cabral, *Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas*.

V. Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, p. 261 e ss.

107

A Corte Europeia de Direitos Humanos tem ressaltado a importância da coisa julgada no Estado Democrático de Direito. Ver Mario Chiavario, *Diritto ad un processo equo*, *Commentario alla Convenzione Europea per la Tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali*, Padova, Cedam, 2001, p. 170 e ss. Como não poderia deixar de ser, o direito comunitário europeu também exige o respeito à coisa julgada. Como ensinam Paolo Biavati e Federico Carpi, “*l'avere conferito ai giudici la giurisdizione su determinate materie comporta necessariamente l'attribuzione non solo dell'efficacia obbligatoria, ma anche della stabilità dei contenuti delle relative pronunce*.” (Paolo Biavati e Federico Carpi, *Diritto processuale comunitario*, 2. ed. Milano, Giuffrè, 2000, p. 240). Sobre o direito processual civil europeu em geral, entre outros, Taruffo e Varano (coords.), *Manuale di Diritto Processuale Civile Europeo*; Burkhard Hess, *Europäisches Zivilprozessrecht*.

108

Para aprofundar, ver Luiz Guilherme Marinoni, *Coisa julgada inconstitucional*, 2. ed., cit.

109

“*Materielle Rechtskraft ist notwendige Folge des Rechts auf Rechtsschutz durch die Gerichte. Sie findet ihre verfassungsgemäße Verankerung im Rechtsstaatsprinzip*” (Rosenberg, Schwab e Gottwald, *Zivilproßrecht*, 15. ed., München, Beck, 1993, p. 915). É preciso deixar claro que o princípio do Estado de Direito, como qualquer princípio jurídico, tende à sua realização dentro daquilo que é faticamente possível, atuando como mandato de otimização (Robert Alexy, *Teoria de los derechos fundamentales*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 86). Assim, não é porque tal princípio deve proteger os direitos fundamentais do cidadão e, consequentemente, evitar decisões injustas que se deve aceitar sua incompatibilidade com a tese da prevalência da coisa julgada material.

110

BVerfG 7, 194 (190).

111

Daniel Mitidiero, *Elementos para uma teoria contemporânea do processo civil brasileiro*, p. 80-88; Alvaro de Oliveira e Daniel Mitidiero, *Curso de processo civil*, p. 123-131, vol. I; Fredie Didier Júnior, *Curso de direito processual civil*, p. 114-115, vol. I; Hermes Zaneti Júnior, *A constitucionalização do processo*, p. 177.

112

Assim, José Frederico Marques, *Ensaio sobre a jurisdição voluntária*, e Alfredo Araújo Lopes da Costa, *A administração pública e a ordem jurídica privada*.

113

Assim, Pontes de Miranda, *Comentários ao código de processo civil*, p. 5, t. XVI; Ovídio Baptista da Silva, *Curso de processo civil*, p. 41, vol. I; José Tesheiner, *Jurisdição voluntária*; Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, p. 319-323; Cássio Scarpinella Bueno, *Curso sistematizado de direito processual*

civil, p. 250, vol. I; João Paulo Lucena, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 25-61, vol. XV; Leonardo Greco, *Jurisdição voluntária moderna*; Fredie Didier Júnior, *Curso de direito processual civil*, vol. I; Alvaro de Oliveira e Daniel Mitidiero, *Curso de processo civil*, p. 131-132, vol. I.

114

Aludindo a um “positivismo includente”, ver Pablo Martín Perrot, Inconstitucionalidad, legalidad y orden jurídico. Discusiones, ano II, n. 2, p. 121: “*En definitiva un positismo incluyente sostiene que en ciertos sistemas jurídicos la existencia y contenido del derecho puede depender de valoraciones y principios morales, como sería el caso de las democracias contemporáneas en las que la validez de las leyes depende de su conformidad con ciertos principios morales básicos tutelados por sus constituciones*”. Ver, ainda, W. J. Waluchow, Inclusive legal positivism; na doutrina brasileira, Juliano Maranhão, *Positivismo jurídico lógico-inclusivo*.

115

Sobre a importância do método tópico – que parte do caso particular para alcançar os padrões gerais para a atividade jurisdicional –, ver a obra fundamental de Theodor Viehweg, *Tópica e jurisprudência*, cit., bem como Michele Taruffo, *La Motivazione della Sentenza Civile*, p. 170-191, 203, 225.

116

Essência essa que é afirmada desde os primórdios do constitucionalismo moderno e que tem uma expressão clássica no contratualismo de John Locke – logicamente, dentro da concepção do “individualismo possessivo” que o caracterizava –, para quem “o grande e principal fim dos homens se unirem em sociedade, e de se constituírem debaixo de um governo, é a conservação da sua propriedade, para cujo fim se exigem muitas coisas que faltam no estado natural” (Ensaio sobre a verdadeira origem, extensão e fim do governo civil, § 124). Compare-se esta passagem com a seguinte de Robert Alexy: “A renúncia ampla a direitos a uma efetiva autoproteção, condicionada pela transição (construída) da situação pré-estatal à situação estatal, pode ser justificada racionalmente somente se o indivíduo, em troca dessa renúncia, obtém uma efetiva proteção estatal” (Teoría de los derechos fundamentales, cit., p. 440).

117

Bernhard Windscheid, *Die Actio des römischen Civilrechts, vom Standpunkte des heutigen Rechts*.

118

No âmbito da teoria dos direitos subjetivos, Windscheid é um dos clássicos formuladores da “teoria da vontade”, à qual se opôs a “teoria do interesse”, formulada, na doutrina alemã, por Jhering (direito subjetivo como interesse juridicamente protegido). A “teoria do interesse” reclama que o essencial para a constituição de um direito é a proteção ou promoção legal dos interesses de uma pessoa contra os interesses de alguma outra ou de todos os outros, pela imposição sobre os últimos de deveres, impedimentos ou responsabilidades com respeito à parte favorecida. A “teoria da vontade”, em contraste, afirma que o fato de um indivíduo ter um direito de algum tipo depende do reconhecimento legal (ou moral) da sua vontade como sendo preeminente sobre a vontade de outrem em relação a algum objeto dado e dentro de uma dada relação intersubjetiva. Para um panorama mais atual desse debate, e uma

defesa consistente da “teoria do interesse”, podem-se consultar as opiniões de Neil MacCormick (Rights in legislation. Law, morality and society: essays in honor of H. L. A. Hart, p. 189-209) e Joseph Raz (The morality of freedom, p. 165-192).

119

O direito à tutela jurisdicional confere ao seu titular o poder de desencadear o exercício da tutela jurisdicional do Estado. Esse é propriamente um poder, pois situa-se integralmente no domínio da vontade do titular, que decide livremente se irá ou não exercê-lo. Como anota Carlos Santiago Nino, “o direito de demandar é em si mesmo um direito que é distinguível, ainda que seja parasitário, do direito principal que se demanda” (Ética..., cit., p. 29). Ao fim e ao cabo, essa observação demonstra apenas o fato de que aquilo que se denomina direito fundamental à tutela jurisdicional, como os demais direitos fundamentais, constitui-se de um leque de posições jurídicas (poder, liberdade, direito a algo, imunidade), não podendo ser devidamente compreendido por nenhuma perspectiva reducionista. Por isso, é absolutamente inviável tentar compreender esse direito a partir de qualquer abordagem purista, seja ela baseada na teoria da vontade, seja baseada na teoria do interesse. Acerca do caráter complexo dos direitos, ver Wesley N. Hohfeld (Fundamental legal conceptions..., cit.) e Robert Alexy (Teoría de los derechos fundamentales, cit., p. 173 e ss.).

120

Giuseppe Chiovenda, Instituições..., cit., vol. 1, p. 290.

121

Ver Luiz Guilherme Marinoni, Técnica processual..., cit.

122

Ver Luiz Guilherme Marinoni, Tutela inibitória, cit.

123

Giuseppe Chiovenda, *L'azione nel sistema dei diritti* (1903), cit., p. 7, esp. nota 13.

124

Por muito tempo a ação não se distinguiu do direito que o litigante pretendia ver reconhecido judicialmente. Os autores clássicos consideravam que a ação e o direito eram somente uma e a mesma coisa sob ângulos diferentes. Era nesse sentido a fórmula, que ficou célebre, de Demolombe: a ação “é o direito posto em movimento, é o direito em estado de ação em vez de ser o direito em estado de descanso, o direito em guerra em vez de o direito em paz”. Assim como a de Garsonnet, embora mais sucinta: “A ação não é outra coisa que não o próprio direito”. Tais conceitos são heranças da concepção processual do direito romano (cf. L. Cadet e Emmanuel Jeuland, *Droit judiciaire privé*, p. 344).

125

Giuseppe Chiovenda, *L'azione nel sistema dei diritti* (1903), cit., p. 6. Para ampla discussão a respeito do tema na perspectiva romanista, Giovanni Pugliese, *Actio e Diritto Subiettivo*.

126

No sistema da common law, o desenvolvimento das variações dos writs é que gerou o que se passou a chamar de “formas de ação”. Havia uma forma de ação para a recuperação das *terras* deixadas como herança e outra forma de ação para os danos às *terras* resultantes de invasão ou de uso ilícito; outra no caso de interferência ilícita com a propriedade imobiliária; outra para a resolução do contrato etc. A forma de ação era, também, a base para se intimar o demandado a responder e para os remédios auxiliares e acessórios. A forma de ação também determinou as defesas que poderiam ser apresentadas pelo réu. A common law foi constituída por vários procedimentos, geralmente similares e com diferenças pontuais, correspondendo aos vários agravos legais substantivos. Sem dúvida, a sua lógica fundamental era a mesma (cf. Geoffrey C. Hazard Jr. e Michele Taruffo, *American civil procedure*, p. 10). Na common law, o primeiro pedido do autor era uma declaração que deveria ser apropriada à forma de ação (form of action) através da qual aquele se afirmava. A ação era em forma de documento, que expressava um tipo básico de demanda. Por outro lado, cada forma de ação tinha incidentes processuais próprios. A forma da ação determinava, por exemplo, a jurisdição da Corte, a maneira para se obter o comparecimento do réu, o procedimento em caso de não comparecimento, o modo do juízo (se por jurados etc.), as defesas permitidas e a forma da execução, isto é, se o autor podia ser imitado na posse do bem objeto da demanda, se o demandado podia ser preso etc. (cf. Fleming James Jr., Geoffrey C. Hazard Jr. e John Leubsdorf, *Civil procedure*, p. 142). Sobre o desenvolvimento do sistema de writs (processual) – similar ao clássico das ações romanas – até se chegar ao sistema substancial ou de rights (direitos), ver Daniel Hulsebosch, *Writs to rights: “navigability” and the transformation of the common law in the nineteenth century*, *Cardozo Law Review*, vol. 23, p. 1.049 e ss. V., ainda, Hans Peter, *Actio und Writ – Eine vergleichende Darstellung römischen und englischer Rechtsbehelfe*.

127

Bernhard Windscheid, *Die Actio des römischen Civilrechts...*, cit.

128

Giuseppe Chiovenda, *L'azione nel sistema dei diritti* (1903), cit., p. 7.

129

Friedrich C. Savigny, *System des heutigen römischen Rechts*, V, §§ 204, 205; v. A. Kollmann, *Begriffs- und Problemgeschichte des Verhältnisses von formellem und materiellem Recht*, p. 532.

130

Amplamente, Alvaro de Oliveira, *Teoria e Prática da Tutela Jurisdicional*, p. 23-31.

131

“Así como la actio no es el derecho a la tutela de otro derecho, nacido de la lesión de éste, tampoco es la

facultad de requerir tutela para el derecho en caso de lesión. La actio es la facultad de imponer la propia voluntad mediante la persecución judicial” (Bernhard Windscheid, La actio del derecho civil romano, desde el punto de vista del derecho actual, Polémica sobre la actio, p. 7).

132

Giuseppe Chiovenda, *L'azione nel sistema dei diritti* (1903), cit., p. 7.

133

“Dije que la actio estaba en lugar del derecho. Esto no es del todo exacto. No está en lugar del derecho real, que no se resuelve en ella. La actio no ordena relaciones entre personas y cosas, sino únicamente entre personas. Presupone siempre un adversario determinado. Desde el punto de vista de la actio, la cuestión es siempre qué puede exigir el uno del otro? Como se ve, es la expresión inmediata y exhaustiva del derecho creditorio, de la obligatio...” (Bernhard Windscheid, La actio del derecho civil romano..., cit., p. 10-11).

134

Giuseppe Chiovenda, *L'azione nel sistema dei diritti* (1903), cit., p. 7.

135

Bernhard Windscheid, *La actio del derecho civil romano...*, cit., p. 14.

136

Idem, p. 11-12. O BGB (Código Civil alemán), no seu § 194, parece ter acolhido o conceito de pretensão de Windscheid. V. Jakobs/Schubert, *Die Beratung des BGB*, AT 2/Berlin, 1985, p. 1.003 e 1.090. Sobre as dúvidas que o conceito de pretensão desperta e acerca de uma eventual contradição entre o BGB e CPC alemán, ver R. Leonard, *Der Anspruchsbegriff des Entwurfs eines bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich*, ZZP, vol. 15, p. 331; Moon-Hyuck Ho, *Zum Anspruchsbegriff der Feststellungsklage*, p. 49.

137

“Decir que alguien tiene una actio significa, traducido al lenguaje de nuestra concepción jurídica, para la cual la perseguibilidad jurídica es sólo consecuencia del derecho, que alguien tiene una pretensión jurídicamente reconocida o, simplemente, que tiene una pretensión” (Bernhard Windscheid, La actio del derecho civil romano..., cit., p. 12).

138

Theodor Muther, *Zur Lehre von der Römischen Actio, dem heutigen Klagrecht, der Litiscontestatio und der Singularsuccession in Obligationen – Eine Kritik des Windscheid'schen Buchs Die Actio des römischen Civilrechts, vom Standpunkte des heutigen Rechts.*

139

Após o trabalho de Muther, escreveu Brinz: “... intrínseca à reivindicação de direitos move-se a pretensão, a qual se denomina nas fontes *petitio*. Ela pode somente significar uma certa exigência ou o poder de exigir algo. É certo, ao menos, que a ‘pretensão’ e a ‘ação’ não podem ser a mesma coisa” (Alois Brinz, *Lehrbuch der Pandekten*, vol. 1, p. 251).

140

Theodor Muther, *Sobre la doctrina de la actio romana...*, cit., p. 199 e ss.

141

“Vimos que el ordenamiento jurídico romano no era el ordenamiento de las pretensiones judicialmente perseguibles, sino el ordenamiento de los derechos, y que solamente éstos (en su sentido subjetivo) eran susceptibles de persecución judicial. Por consiguiente, quien tenía derecho a que se le confiriera la fórmula debía tener también un derecho subjetivo, que era presupuesto y fundamento del primero” (idem, p. 241).

142

“Tenemos pues dos derechos distintos, de los cuales el uno es el presupuesto del otro, pero que pertenecen a campos distintos, ya que el uno es un derecho privado, y el otro de naturaleza pública” (idem, ibidem).

143

“Ese derecho público, el derecho de accionar o *actio* así entendida, puede imaginarse como vinculado desde un comienzo con el derecho primitivo, aun mientras éste siga ileso; puede concebirse como un derecho condicionado, no como un ‘anexo’ o ‘añadidura’ al contenido del otro, pero sí como un derecho especial, condicionado, existente junto a ese otro derecho, al efecto de tutelarlos” (idem, ibidem).

144

Idem, p. 203 e ss.

145

Giuseppe Chiovenda, *L'azione nel sistema dei diritti* (1903), cit., p. 9.

146

Bernhard Windscheid, *La actio del derecho civil romano...*, cit., p. 299 e ss.

147

Plósz, *Beiträge zur Theorie des Klagerechts*.

148

Degenkolb, Einlassungszwang und Urteilsnorm. Beiträge zur materiellen Theorie der Klagen, insbesondere der Anerkennungsklagen.

149

Giuseppe Chiovenda, *L'azione nel sistema dei diritti* (1903), cit., p. 10.

150

Disse Degenkolb: “Por que o demandante materialmente destituído de fundamento pode acionar em face de quem não está obrigado; como se esclarece o direito de ação material quando a demanda é rejeitada?” (Einlassungszwang und Urteilsnorm, cit., p. 4). “A capacidade para demandar nunca ou jamais é idêntica à pretensão material, ao direito material. O direito de demandar, em seu sentido público, identifica a relação daquele que procura a proteção jurídica junto ao Estado, detentor da jurisdição e do dever judicial. Esse direito designa, em termos teóricos, a pretensão à proteção jurídica ou a pretensão à justiça. Hoje, quando a palavra ‘direito de demandar’ é utilizada – e com frequência –, essa não significa que o direito de demandar deva ser reduzido à pretensão material, pois é pensada em relação ao direito de demandar público” (p. 14).

151

Giuseppe Chiovenda, *L'azione nel sistema dei diritti* (1903), cit., p. 64, notas 36 e 38.

152

Idem, p. 10.

153

Segundo o art. 814, caput, do CC/2002, “as dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento; mas não se pode recobrar a quantia, que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou se o perdente é menor ou interdito”.

154

Lodovico Mortara, *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*, vol. 2.

155

É preciso observar aqui um problema terminológico: embora a tradução dos termos *Anspruch* (do alemão) e *pretesa* (do italiano) seja feita pela mesma palavra em português (pretensão), o *significado* atribuído a esses termos normalmente é diferente: enquanto na Alemanha o termo *Anspruch* (pretensão) significa poder exigir uma prestação ou um bem *fundado em direito*, na Itália o termo *pretesa* (pretensão) significa simplesmente aspirar a um bem, *não necessariamente direito de obtê-lo*. Daí a variação com que o termo é utilizado no texto.

Cf. Giuseppe Chiovenda, *L'azione nel sistema dei diritti* (1903), cit., p. 65-69, nota 40.

Adolf Wach, *Handbuch des deutschen Civilprozessrechts*, vol. 1. Especificamente sobre a teoria da pretensão à tutela jurídica de Wach e sobre a teoria da ação como direito potestativo de Chiovenda, v. Fernando Henning, *Ação Concreta* – Relendo Wach e Chiovenda.

Essa visão foi compartilhada, de certa forma, por Dernburg, que assim concluiu: “O direito de ação (actio) possui um duplo significado: um processual, pertencente ao direito público, e outro de direito privado. Quem alegar a existência de um poder de demanda possui processualmente um direito de ação para exigir justiça. Mas o direito de ação, em seu sentido de direito privado, é o direito de um autor a uma sentença favorável contra o demandado” (Pandekten, vol. 1, § 127, p. 290 e ss.)

Giuseppe Chiovenda, *L'azione nel sistema dei diritti* (1903), cit., p. 11. V. Karl Heinz Schwab, *Zur Wiederbelebung des Rechtsschutzanspruchs*, ZZP, vol. 81, p. 412 e ss.

Esse momento da doutrina de Wach é por muitos considerado como decisivo para o distanciamento da pretensão processual da pretensão material. V. Moon-Hyuck Ho, *Zum Anspruchs begriff...*, cit., p. 81.

Giuseppe Chiovenda, *L'azione nel sistema dei diritti* (1903), cit., p. 12.

Segundo Wach, a pretensão à tutela jurídica é “o direito a uma proteção processual civil, a um ato de administração da justiça, que constitui o objetivo do processo. Dirige-se contra o Estado, que deve conceder a proteção, e também contra o oponente, perante o qual a proteção é concedida. É de natureza pública, não constituindo o produto do direito privado subjetivo. Todavia, não é um poder público aberto a todos que afirmem possuir uma pretensão a uma proteção jurídica” (Der Feststellungsanspruch, n. 15, p. 10).

Nessa ocasião, disse Chiovenda: “O direito processual de grande parte das nações modernas é devido substancialmente a Bolonha, como o direito civil a Roma”.

165

“É verdade que a ação pode ser dirigida à satisfação de um direito subjetivo, mas não necessariamente. Aqui interessa expor sumariamente os casos nos quais o poder de pedir a atuação da lei aparece dirigido a um simples interesse, portanto como um direito em si mesmo, independente de algum outro direito (...). O mesmo ocorre nas ações declaratórias positiva e negativa, admitidas também em nossa lei, seja em casos particulares, seja como figura geral, em virtude do art. 36 do CPC, e que constituem figuras distintas seja dos ‘giudizi preventivi’, seja dos abolidos ‘giudizi di giattanza’. Quando alguém pede que se declare a existência de uma relação jurídica, sem aspirar a outros efeitos jurídicos, que não aqueles imediatamente derivados da declaração, não afirma algum direito subjetivo contra o adversário que não o próprio direito de ação, coordenado a um interesse de declaração; qualquer tentativa de dar um outro conteúdo a este direito é inútil, porque precisamente a declaração judicial a que se tende não é prestação que se possa pretender do réu. E isto por razões mais fortes, quando a ação é dirigida a um interesse de declaração negativa, isto é, à declaração da não existência de uma relação jurídica” (idem, p. 16).

166

“Noi concepiamo l'azione appunto come un diritto contro l'avversario, consistente nel potere di produrre di fronte a questo l'effetto giuridico della attuazione della legge” (idem, p. 14).

167

Idem, p. 14 e ss.

168

“L'azione è un potere di fronte all'avversario più che contro l'avversario. Vorremmo con questa distinzione rendere l'idea che l'azione non suppone alcuna obbligazione. Il preconconcetto che il diritto subbiettivo presupponga di necessita un dovere, ha sempre allontanato da questa concezione dell'azione, ch'è la più semplice. L'azione è un potere, di fronte al quale l'avversario non è tenuto ad alcuna cosa (...). Nè all'azione corrisponde alcun dovere processuale dell'avversario: ma puramente e semplicemente la sua soggezione agli effetti giuridici a cui l'azione intende. I quali effetti giuridici, come si è affermato da principio, scendono dal verificarsi della condizione per l'attuazione della legge, sono l'attuazione della legge” (idem, p. 15).

169

Prólogo aos Fundamentos del derecho procesal civil, de Eduardo Couture, 3. ed., 1958, p. XI-XII.

170

Eduardo Couture, Fundamentos..., cit., p. 74-75.

171

Idem, p. 77-78.

172

Idem, p. 78.

173

Idem, p. 79.

174

Essa “prolusione” foi apresentada por Liebman, na Universidade de Turim, em 24 de novembro de 1949, e depois publicada nos Scritti giuridici in onore de F. Carnelutti, Padova, Cedam, 1950, vol. 2, na Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1950, p. 47 e ss., e nos Problemi del processo civile, Napoli, Morano, 1962, p. 22 e ss.

175

Enrico Tullio Liebman, Manual de direito processual civil, vol. 1, p. 150.

176

Idem, ibidem.

177

Idem, p. 151.

178

“Nel suo significato pieno e vero, l'azione non compete infatti a chiunque e non ha contenuto generico. Al contrario, essa si riferisce ad una fattispecie determinata ed esattamente individuata, ed è il diritto ad ottenere che il giudice provveda a suo riguardo, formulando (od attuando) la regola giuridica speciale che la governa. Essa è perciò condizionata ad alcuni requisiti (che devono verificarsi caso per caso in via preliminare, anche se di solito per implicito) vale a dire all'interesse ad agire, che è l'interesse dell'attore ad ottenere il provvedimento domandato (art. 100 Cod. Proc. Civ.); alla legittimazione ad agire, che è l'appartenenza dell'azione a colui che la propone e in confronto alla controparte (art. 81 Cod. Proc. Civ.); e alla possibilità giuridica, che è l'ammissibilità in astratto del provvedimento chiesto, secondo le norme vigenti nell'ordine giuridico nazionale” (Enrico Tullio Liebman, L'azione nella teoria del processo civile, Problemi del processo civile, p. 46).

179

Na 3.^a edição do seu Manuale di diritto processuale civile, Liebman abandonou a categoria da “impossibilidade jurídica do pedido”. A partir daí, ao tratar do interesse de agir, passou a dizer que “seria uma inutilidade [faltaria interesse de agir] proceder ao exame do pedido para conceder ou negar o provimento postulado” quando o provimento “não pudesse ser proferido, porque não admitido por lei”

(Manual..., cit., vol. 1, p. 155). Como está claro, Liebman inseriu a ideia da impossibilidade jurídica do pedido na ausência de interesse de agir.

180

Idem, p. 155.

181

Idem, p. 147.

182

“Mancando una di queste condizioni, si ha quella che, con esatta espressione tradizionale, si qualifica di carenza di azione, e il giudice deve rifiutarsi di provvedere sul merito della domanda” (Enrico Tullio Liebman, *L'azione...*, cit., p. 46-47).

183

Enrico Tullio Liebman, *Manual...*, cit., vol. 1, p. 162.

184

Enrico Tullio Liebman, *L'azione...*, cit., p. 47.

185

“Naturalmente, só tem direito à tutela jurisdicional aquele que tem razão, não quem ostenta um direito inexistente” (Enrico Tullio Liebman, *Manual...*, cit., vol. 1, p. 147).

186

Demonstramos tal necessidade em livro publicado em 1996 (Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata da sentença*, São Paulo: Ed. R T, 1996).

187

Art. 1.º da Lei 4.717/1965 (Lei da Ação Popular).

188

Art. 5.º da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) e art. 82 do C D C.

189

Bernhard Windscheid, *La actio del derecho civil romano...*, cit., p. 12, 299.

190

Theodor Muther, Sobre la doctrina de la *actio* romana, del derecho de accionar actual, de la *litiscontestatio* y de la sucesión singular en las obligaciones, *Polémica sobre la actio*, p. 199 e ss.

191

Idem, p. 241.

192

Idem, ibidem.

193

Bernhard Windscheid, *La actio del derecho civil romano...*, cit., p. 14.

194

Theodor Muther, *Sobre la doctrina de la actio romana...*, cit., p. 242.

195

O réu está sujeito ao poder estatal.

196

Bernhard Windscheid, *La actio del derecho civil romano...*, cit., p. 299 e ss.

197

Os próprios romanistas contemporâneos, a propósito, costumam explicar o direito romano a partir das diferenças entre a *actio* em um sentido processual (“*Prozeßhandlung*”, “*Klage*”) e a *actio* em um sentido material (“*Anspruch*”), beneficiando-se claramente das distinções oriundas da polêmica Windscheid Muther (conforme, por todos, Max Kaser e Rolf Knütel, *Römisches Privatrecht*, p. 396 – há tradução para a língua portuguesa, Max Kaser, *Direito Privado Romano*, trad. Samuel Rodrigues e Ferdinand Hämmerle e rev. Maria Armanda de Saint-Maurice, p. 427).

198

Eduardo Couture, *Fundamentos...*, cit., p. 79.

199

Ver, de autoria de Lodovico Mortara, *Comentario...*, cit., p. 18 e ss.; *Manuale della procedura civile*, p. 48 e ss.

Disse Chiovenda: *“Il Mortara diffuse nel nostro mondo giuridico la sensazione della insufficienza dei metodi in vigore e degli strumenti usati e con la sua critica penetrante ed inesorabile gettò il discredito sopra idee, definizioni e figure prima adottate come vangelo. Il fatto stesso che un giurista di così grande statura facesse oggetto principale dei suoi studi una materia come la procedura civile prima negletta e quasi dispreziata, giovò sommamente ad elevare nella considerazione dei nostri teorici e dei nostri pratici la dignità della scienza processuale ed a porne in evidenza l'autonomia. (...) Fu grande merito del Mortara aver collocato (come la sua preparazione nel diritto pubblico sola poteva permettere di fare) il processo civile nella sua giusta luce di istituto di diritto pubblico, ciò che fu il punto di partenza dei progressi successivamente realizzati nel nostro campo”* (Giuseppe Chiovenda, Lodovico Mortara, cit., p. 101-102). Calamandrei também realçou a importância do pensamento de Mortara no surgimento da escola sistemática: *“Il passaggio dal metodo esegetico al metodo storico-dogmatico fu segnato dal Commentario di Ludovico Mortara, nel quale, specialmente nel primo volume, già si trova nettamente affermato il principio della unità della giurisdizione e della natura pubblica del processo (...) Intorno a Giuseppe Chiovenda si è formata ed affermata una nuova scuola che, in contrapposto a quella esegetica, culminata e implicitamente superata nel Commentario del Mortara, è stata denominata sistematica, o anche storico-dogmatica, per indicare che nell'indirizzo partito dal maestro la dogmatica non è mai fine a sé stessa, ma è sempre considerata come un mezzo per interpretare la realtà storica del proprio tempo”* (Piero Calamandrei, Gli studi di diritto processuale in Italia nell'ultimo trentennio, *Opere giuridiche*, vol. 1, p. 524-526). Ver, ainda, Piero Calamandrei, Lodovico Mortara, *Studi sul processo civile*, vol. 4, p. 211 e ss.; Francesco Carnelutti, Scuola italiana del processo, *Rivista di Diritto Processuale*, 1947, p. 233-247; Giovanni Tesorieri, Appunti per una storia della scienza del processo civile in Italia dall'unificazione ad oggi (i pre-chiovendiani), *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1972, p. 1.340-1.348; Michele Taruffo, *La giustizia civile...*, cit., p. 187; Elio Fazzalari, Lodovico Mortara nella cultura processualistica italiana, *Rivista di Diritto Processuale*, vol. 52, p. 303 e ss.; Vittorio Colesanti, Lodovico Mortara e le riforme processuali. La prima fase (1901-1912), *Rivista di Diritto Processuale*, 1997, p. 675 e ss.; Cristina Rapisarda, *Profili...*, cit., p. 14 e ss. Registre-se, aliás, que em 17 de abril de 1997 a *Accademia dei Lincei* e a *Associazione Italiana per gli Studi del Processo Civile* promoveram um congresso para recordar Lodovico Mortara e a sua obra (cf. Gabriella Rubino, L'Accademia dei Lincei celebra Lodovico Mortara, *Rivista di Diritto Processuale*, 1997, p. 573 e ss.).

Giuseppe Chiovenda, *L'azione nel sistema dei diritti* (1903), cit., p. 14 e ss.

V. Enrico Tullio Liebman, *L'azione...*, cit., p. 31; Francesco Carnelutti, Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni, *Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda*, p. 54.

Eduardo Couture, *Fundamentos...*, cit., p. 74-75.

Enrico Tullio Liebman, *L'azione...*, cit., p. 46-47.

205

Idem, p. 47.

206

Para uma contraposição entre as perspectivas estática e dinâmica do direito de ação, Luigi Paolo Comoglio, Note Riepilogative su Azione e Forme di Tutela, nell' Ottica della Domanda Giudiziale, *Rivista di Diritto Processuale*, p. 465-490.

207

É certo que, por lapso, o juiz poderá deixar de constatar a ausência de legitimidade ou de interesse, mesmo que essa constatação seja dependente apenas da afirmação do autor, e assim permitir que o procedimento ultrapasse a fase de produção de provas. Mas essa é uma hipótese excepcional. O que importa é deixar claro que o juiz deve aferir os requisitos para a apreciação do mérito no início do desenrolar do procedimento, com base nas próprias afirmações do autor.

208

Enrico Tullio Liebman, *Manual...*, cit., vol. 1, p. 147.

209

Para uma análise crítica do tema, Heitor Sica, *O direito de defesa no processo civil brasileiro*.

210

Robert Alexy, *Theorie der Grundrechte*, p. 444; Nicolò Trocker, *Processo Civile e Costituzione*, p. 186.

211

Corretamente, Kurt Eichenberger (*Die richterliche Unabhängigkeit als staatsrechtliches Problem*, p. 83 ss.) vê o direito de ação como uma pretensão a uma *decisão materialmente justa*. Igualmente, Robert Alexy, *Theorie der Grundrechte*, p. 444.

212

Assim, sublinhando a perspectiva compósita e dinâmica do direito de ação, Elio Fazzalari, *Note in Tema di Diritto e Processo*, p. 109-161; Id., La Dottrina Processualistica Italiana: dall' 'Azione' al 'Processo' (1864-1994), *Rivista di Diritto Processuale*, p. 922; Luigi Paolo Comoglio, Note Riepilogative su Azione e Forme di Tutela, nell' Ottica della Domanda Giudiziale, *Rivista di Diritto Processuale*, p. 469-473; Alvaro de Oliveira, *Teoria e prática da tutela jurisdicional*, p. 70.

213

Sobre o assunto, Giovanni Pugliese, *Istituzioni di Diritto Romano*, p. 58-78 e p. 266-347; Max Kaser e Karl Hackl, *Das römische Zivilprozessrecht*, p. 34-37 e p. 151-171; José Rogério Cruz e Tucci e Luiz Carlos de Azevedo, *Lições de História do processo civil romano*, p. 51-52 e p. 73-74.

214

Sobre a passagem da doutrina das ações de direito material (cuja figura icônica é inquestionavelmente Savigny) para a doutrina da ação processual na doutrina alemã dos Oitocentos, Knut Wolfgang Nörr, *Zum Historischen Schule im Zivilprozeß- und Aktionenrecht, Iudicium est Actus Trium Personarum – Beiträge zur Geschichte des Zivilprozeßrechts in Europa*, p. 73-89, especialmente p. 80-89. Em seu clássico *System des heutigen römischen Rechts*. Berlin: Veit und Comp., 1841, t. V, Savigny, depois de definir a “*Klage*” (p. 4-11), arrola as “*Arten der Klagen*” (p. 11-150) – todas fundadas em distinções ligadas ao direito material (por exemplo, “*in persona*” e “*in rem*”). Daí a razão pela qual o seu pensamento a respeito da ação ficou conhecido como direito das ações (*Aktionensrecht*) – como já sabemos, a ação não é um conceito abstrato e único em Savigny, pertencente ao direito processual, mas sim um conceito de direito material, que admite tantas variações quantos são os direitos subjetivos reconhecidos pela ordem jurídica civil.

215

V. Salvatore Mazzamuto, *L’attuazione degli obblighi di fare*, p. 37 e ss.; Adolfo di Majo, *La tutela civile dei diritti*, p. 156.

216

Salvatore Mazzamuto, *L’attuazione...*, cit., p. 38.

217

Afirma-se que o artigo 1.142 do Código Napoleão – segundo o qual toda obrigação de fazer e de não fazer resolve-se em perdas e danos em caso de inadimplemento – reflete os princípios de liberdade e de defesa da personalidade, próprios do jusnaturalismo e do racionalismo iluminista (cf. *idem*, , p. 36).

218

Como escreve Mazzamuto, a imposição de um custo econômico do inadimplemento, ainda que adequado às novas exigências de reprodução do capital, repristina os mecanismos de mercado, mas não pressupõe qualquer programa de sustento do sujeito econômica ou socialmente mais fraco; na verdade, visando a tratar todos da mesma forma, ignora as características e as necessidades socialmente diversificadas dos contratantes, limitando-se a exprimir, em nível de sanção, a equivalência das mercadorias (*idem*, p. 38).

219

Adolfo di Majo, *La tutela civile...*, cit., p. 156.

220

Luciane Tessler, *Tutelas jurisdicionais do meio ambiente*.

221

V. Clayton Maranhão, *Tutela jurisdicional do direito à saúde*.

222

Luiz Fernando Pereira, *Tutela jurisdicional da propriedade industrial*.

223

V. Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela inibitória*, cit., p. 66 e ss.

224

O ressarcimento na forma específica, no caso de a reparação exigir um fazer fungível, deve ser prestado mediante a imposição de um fazer. Quando o dano houver destruído a coisa, o ressarcimento na forma específica é prestado mediante a entrega de coisa da mesma espécie e estado da danificada. Nesse último caso, aliás, ainda que não tenha ocorrido a destruição total da coisa, será possível o ressarcimento na forma específica mediante a entrega de coisa equivalente. Ou seja, quem *teve coisa de sua propriedade parcialmente ou inteiramente danificada pode postular o ressarcimento na forma específica mediante a entrega de coisa*.

225

Portanto, é correto afirmar que o CPC de 1973 transformou o direito à reparação do dano em direito à obtenção de dinheiro. Isso pelo motivo de que o modelo que foi por ele estruturado para o ressarcimento é completamente inidôneo para a prestação da tutela ressarcitória na forma específica, e assim para atender aos direitos que exigem tal forma de ressarcimento.

226

Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, p. 832 e ss.

227

Idem, p. 837 e ss.

228

Idem, *ibidem*.

229

Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual...*, cit., p. 145 e ss.

230

Idem, p. 146.

231

Por essa razão que é necessário pensar a técnica processual na perspectiva da tutela dos direitos, conforme Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual e tutela dos direitos*.

232

Mauro Cappelletti, *Repudiando Montesquieu?...*, cit., p. 268.

233

Montesquieu concluiu que o “poder de julgar” era, de qualquer modo, um “poder nulo” (*en quelque façon, nulle*) (Montesquieu, *Do espírito das leis*, cit., p. 160).

234

V. Giovanni Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna...*, cit., p. 291.

235

Montesquieu, *Do espírito das leis*, cit., p. 158. M. Tropper, *La función judicial, Ética y democracia*, p. 213: “Para negar que los jueces dispongan de un poder discrecional habitualmente se fundamenta en una o otra de las variantes del silogismo judicial, cuyo origen se encuentra en Montesquieu. Esta teoría, por tanto, no está ligada exclusivamente con la teoría democrática, aun si ciertas teorías democráticas se sirven de ella. No es necesario exponer la teoría del silogismo, la cual es bien conocida. Se conoce las célebres fórmulas de Montesquieu: ‘Si los tribunales no deben ser fijos, las sentencias deben serlo de tal manera que sean siempre más que un texto preciso de la ley’ (*El espíritu de las leyes*, XI, 11). La teoría del silogismo ha sido retomada por Beccaria en términos muy claros. ‘En presencia de todo delito, el juez debe formar un silogismo perfecto: la premisa mayor debe ser la ley general; la menor el acto conforme o no conforme con la ley; la conclusión sería la absolución o la condena’”.

236

Giuseppe Chiovenda, *Le forme nella difesa giudiziale del diritto. Saggi di diritto processuale civile*.

237

Vittorio Denti, *Il processo di cognizione nella storia delle riforme. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1993, p. 808.

238

Idem, *ibidem*.

“Não é possível esquecer, ademais, que a escola sistemática formou-se sob a influência de um modelo de Estado de Direito de matriz liberal, o que significa que a doutrina chiovendiana de certa forma ainda estava sob a influência da orientação que inspirou os juristas do século XIX. Esse modelo institucional de Estado, marcado por uma acentuação dos valores da liberdade individual em relação aos poderes de intervenção estatal, reflete-se sobre a concepção de sentença declaratória, enquanto sentença que regula apenas formalmente uma relação jurídica já determinada em seu conteúdo pela autonomia privada” (Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela inibitória*, cit., p. 240). Vittorio Denti reconhece a ligação da ação declaratória com o modelo institucional liberal: “*Altro punto che va tenuto fermo è il carattere preventivo dell’azione inibitoria. La dottrina processualistica ha, per lunga tradizione, risolto la tutela giurisdizionale preventiva nel mero accertamento, con una scelta che non ha avuto – come è stato recentemente dimostrato – soltanto carattere concettuale, poiché era condizionata dalla tendenza a delimitare rigidamente i poteri di ingerenza statale nella sfera giuridica privata. Si trattava, quindi, della adesione al modello istituzionale liberale, chiaramente presente nel maggiore teorizzatore dell’azione di mero accertamento e della sua funzione preventiva, Giuseppe Chiovenda*” (Diritti della persona e tecniche di tutela giudiziale. *L’informazione e i diritti della persona*, p. 267). V. também Cristina Rapisarda, *Profili...*, cit., p. 70-72; e Premesse allo studio della tutela civile preventiva. *Rivista di Diritto Processuale*, 1980, p. 128 e ss.

V. Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual...*, cit., p. 149.

Crisanto Mandrioli, *L’azione esecutiva*. Satta também disse que a tutela do direito de crédito não está na sentença condenatória, mas sim na execução forçada sobre o patrimônio do devedor (Premesse generali alla dottrina della esecuzione forzata, *Rivista di Diritto Processuale Civile*, p. 368, 1932). Na mesma direção escreveu Alessandro Rasseli: “*Nelle sentenze di accertamento l’attestazione autoritativa dell’esistenza di una concreta volontà di legge – che stabilisce quale sia la tutela degli interessi delle parti in un dato rapporto giuridico – esaurisce i provvedimenti che le parti possono o vogliono chiedere al giudice, dato il modo con cui si è determinata la situazione di insoddisfazione dei loro interessi (...). Tale elemento nelle sentenze di condanna è la pronunzia sulla possibilità di un’ulteriore attività giurisdizionale per assicurare la tutela degli interessi protetti: nelle sentenze costitutive è un’ulteriore attività del giudice che addirittura realizza nella stessa sentenza quella soddisfazione degli interessi cui è stato accertato che una parte ha diritto. Questa soddisfazione è data da un cambiamento della preesistente situazione di diritto materiale*” (Sentenze determinative e classificazione delle sentenze. *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*, vol. 2, p. 580). Cristina Rapisarda, ao tentar classificar as sentenças a partir do efeito que é por elas declarado no plano do direito material, concluiu que determinados provimentos (o declaratório e o constitutivo) *realizam autônoma e integralmente a tutela concedida pela norma à fattispecie substancial declarada*, podendo, assim, receber a designação de “satisfativos” (*Profili...*, cit., p. 231 e ss.).

243

Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela inibitória*, cit., p. 342 e ss. Sobre a relação entre a segurança, a legalidade e a liberdade à época do Estado liberal, assim se expressa Tropper: “*Su justificación reside en el principio de legalidad, igualmente ligado estrechamente a la concepción que se tenía de la libertad en el Siglo de las Luces. La expresión ‘libertad política’ tiene, en efecto, dos sentidos en esta época. En sentido amplio, es la libertad de aquel que se encuentra sometido únicamente a la ley. Es libre porque, en la sociedad, como en el mundo físico, está en posibilidad, si conoce las leyes, de saber, por lo mismo, todas las consecuencias de sus acciones y, así, de tomar decisiones con claridad. La libertad es pues, simplemente, la previsibilidad o seguridad jurídica*” (*La función judicial*, cit., p. 214).

244

Crisanto Mandrioli, L'esecuzione specifica dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro. *Rivista di Diritto Processuale*, 1975, p. 23.

245

Michele Taruffo, Sistema e funzione del processo civile nel pensiero di Giuseppe Chiovenda, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1.133-1.168.

246

O BGH alemão já afirmou expressamente que o processo civil possui o escopo de realizar o direito material, esclarecendo que as suas normas não têm um fim em si mesmo, uma vez que são dirigidas a um fim (BGHZ 10, 359).

247

Adolfo di Majo, *La Tutela Civile dei Diritti*, p. 5.

248

Andrea Proto Pisani, *Lezioni di Diritto Processuale Civile*, p. 5.

249

A feliz expressão é de Eduardo Grasso, La Dottrina del Processo Civile alla Fine del Secolo, *Rivista di Diritto Civile*, p. 387.

250

V. Claus-Wilhelm Canaris, *Direitos fundamentais e direito privado*, cit., esp. p. 101 e ss.

251

O art. 927, *caput*, do CC/2002 afirma textualmente que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Quase no mesmo sentido, dizia o art. 159 do CC/1916: “Aquele

que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.

252

Segundo Pontes de Miranda, na ação que objetiva reparar o ato ilícito, “*o pedido pode dirigir-se à restauração em natura, e somente quando haja dificuldade extrema ou impossibilidade de se restaurar em natura é que, em lugar disso, se há de exigir a indenização em dinheiro*” (Pontes de Miranda, *Tratado de direito privado*, vol. 26, p. 28).

253

E não vai aqui nenhuma crítica à doutrina que se vale do ditado chiovendiano. Nós chegamos a usá-lo expressamente em um dos itens do livro *Tutela inibitória*, ainda que assim advertindo: “Cabe lembrar, porém, que Chiovenda, apesar de ter dito que o processo deve dar a quem tem um direito tudo aquilo e exatamente aquilo que tem o direito de obter, afirmou, nas suas *Instituições*, o seguinte: ‘Se, por sua natureza ou por falta de meios de sub-rogação, não se pode conseguir um bem senão com a execução por via coativa, e os meios de coação não estão autorizados na lei, aquele bem não é conseguível no processo, salvo a atuação (se possível, por sua vez) da vontade concreta de lei que deriva da lesão ou inadimplemento do direito a uma prestação; salvo, por exemplo, o direito ao ressarcimento do dano’” (Giuseppe Chiovenda, *Instituições de direito processual civil*, vol. 1, cit., p. 290)” (*Tutela inibitória*, cit., p. 364).

254

Adolfo di Majo, *Forme e tecniche di tutela. Processo e tecniche di attuazione dei diritti*, vol. 1, p. 11 e ss.

255

V. Sérgio Cruz Arenhart, *A tutela inibitória da vida privada*.

256

Muito embora a reparação do dano não seja plena, seja porque a publicação ou a transmissão podem não atingir todos aqueles que tiveram ciência do fato danoso, seja porque tal ciência não elimina a dor moral gerada pela imputação ofensiva, o certo é que a tutela colabora para a reparação do dano, que ficaria sem tutela adequada caso somente pudesse ser sancionado em pecúnia. Lembre-se, para exemplificar, que, de acordo com o art. 120 do CPC italiano, nos casos em que a publicação da sentença *puder contribuir para reparar o dano*, o juiz, a requerimento da parte, poderá ordená-la aos cuidados e às expensas do sucumbente, mediante a inserção por extrato em um ou mais jornais por ele designados. A doutrina italiana entende que a publicação da sentença, prevista no referido art. 120, assim como a publicação da retificação relativa a notícias veiculadas por meio de periódicos, *colaboram para reparar o dano*. Como percebeu Grazia Ceccherini (*Risarcimento del danno e riparazione in forma specifica*, p. 72), o recurso a formas de tutela *lato sensu* específicas é, sem dúvida, *mais adequado e, portanto, preferível em relação a uma sentença que se limite a condenar o autor do dano ao direito da personalidade ao ressarcimento em dinheiro* (Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual...*, cit., p. 434 e ss.).

257

Adolfo di Majo, *La tutela...*, cit., p. 43 e ss.

258

V. Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela inibitória*, 4. ed., cit.; Luiz Guilherme Marinoni, Tutela inibitoria: la tutela de prevención del ilícito, *Revista de Derecho Procesal (Argentina)*, 1999, n. 3, p. 557-574; Luiz Guilherme Marinoni, La prueba en la acción inibitoria. *La prueba – Homenaje al maestro Hernando Devís Echandía*, Bogotá: Universidad Libre, 2003, p. 313-332.

259

V. Luiz Guilherme Marinoni, La efectividad de los derechos y la necesidad de un nuevo proceso civil. *Libro de ponencias del II Congreso Internacional de Derecho Procesal*. Lima: Universidad de Lima, 2002, p. 94-103.

260

Sobre o tema da tutela inibitória, v. Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela inibitória*, cit.; Sérgio Cruz Arenhart, *Perfis da tutela inibitória coletiva*.

261

Orlando Gomes, *Obrigações*, cit., p. 314.

262

Aldo Frignani, *L'injunction nella common law e l'inibitoria nel diritto italiano*, p. 423 e ss.; Cristina Rapisarda, *Profili...*, cit., p. 108 e ss.

263

Orlando Gomes, *Obrigações*, cit., p. 313.

264

Ovídio Baptista, *Jurisdição e execução na tradição romano-canônica*.

265

Art. 5.º da Lei da Ação Civil Pública e art. 82 do CDC.

266

V. Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual...*, cit., p. 268 e ss.

No que diz respeito à tutela inibitória, é preciso esclarecer que a invocação de dano é *desnecessária*, uma vez que basta a demonstração de ameaça de ato contrário ao direito. Porém, como o dano pode se associar cronologicamente ao ato contrário ao direito, vindo ambos a ocorrer no mesmo instante, é inegável que o autor *pode alegar e demonstrar a probabilidade de dano para caracterizar de forma mais fácil a ameaça*.

E isso quando para a imposição da sanção ressarcitória não for dispensada a culpa, como acontece nos casos de responsabilidade sem culpa.

Ao tratar da tutela ressarcitória na forma específica, o § 249 do CC alemão fala em obrigação de reconstituir a situação que existiria caso o dano não houvesse ocorrido. Se a tutela ressarcitória na forma específica deve proporcionar um resultado equivalente ao da situação que existiria caso o dano não tivesse acontecido, pode não ser suficiente o restabelecimento da situação que era anterior ao dano, pois o dano primitivo pode ter acarretado outros, como acontece quando se pensa nos “lucros cessantes”. Como o bem protegido deve ser integralmente tutelado, é necessário que se estabeleça uma situação equivalente à que existiria caso o dano não houvesse sido praticado. *Se isso não for possível, a tutela ressarcitória na forma específica deverá ser cumulada à tutela ressarcitória pelo equivalente* (Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual...*, cit., p. 426 e ss.).

João Calvão da Silva, *Cumprimento...*, cit., p. 153-154; Jorge Musset Iturraspe, *Responsabilidad por daños*, p. 379-380.

João Calvão da Silva, *Cumprimento...*, cit., p. 173.

Por isso mesmo, entendemos que a tutela inibitória também é uma forma de proteção contra o inadimplemento. “Diante de certas obrigações, é possível pensar em violações suscetíveis de se repetirem no tempo. Ou melhor, na hipótese de obrigação dita de ‘trato sucessivo’, a obrigação pode ser violada por atos suscetíveis de repetição. Ainda que possa haver interesse em impedir a violação quando a obrigação exige somente uma prestação, o fato é que, no caso de obrigação que exige prestações periódicas, torna-se mais fácil, diante do inadimplemento de uma primeira prestação, demonstrar a probabilidade do inadimplemento da seguinte. Não há cabimento em não admitir a tutela jurisdicional anterior ao inadimplemento, entendendo que o contratante somente pode agir após a violação da obrigação. Isso seria o mesmo que supor que o contrato é suficiente para impedir a violação. Ora, assim como a lei, o

contrato obviamente não é capaz de impedir a violação do direito. *Dessa forma, impedir a tutela inibitória do inadimplemento também é negar valor ao direito ao cumprimento da obrigação na forma específica, aceitando-se não só a desconsideração do contrato, como também a transformação da obrigação de prestar em obrigação de pagar o seu equivalente*” (Técnica processual..., cit., p. 397-398).

274

João Calvão da Silva, *Cumprimento...*, cit., p. 147.

275

Idem, p. 187.

276

Idem, p. 173-174.

277

É o que ocorre quando, em razão de vício do produto, abre-se oportunidade para o pedido de substituição das partes viciadas do bem. Lembre-se que o consumidor, em caso de vício de qualidade do produto, *deve reclamar* a substituição das partes viciadas e, se não for atendido, *pode pedir ao juiz, por meio de ação, que tais partes viciadas sejam substituídas* (art. 18, CDC). Pedir a substituição das partes viciadas do produto implica em solicitar um fazer. Desse modo, embora a obrigação originária não seja de fazer, admite-se que o consumidor requeira, com base no art. 84, § 4.º, CDC, ordem de fazer sob pena de multa.

278

Alessandro Rasseli, *Sentenze determinative...*, cit., p. 580; Salvatore Satta, *Premesse generali...*, cit., p. 368; Crisanto Mandrioli, *L'azione esecutiva*, cit., p. 310; Cristina Rapisarda, *Profili...*, cit., p. 136.

279

A expressão é de Mandrioli (*L'azione esecutiva*, cit., p. 310).

280

V., nesse exato sentido, Ovídio Baptista da Silva, *Processo e ideologia*, p. 171 e ss.; Daniel Mitidiero, *Polêmica sobre a teoria dualista da ação*, *Revista de Direito Processual Civil*, vol. 34, p. 693.

281

Sobre o indevido esquecimento do direito material ou da pretensão de direito material diante da pretensão processual, anotou Hölder: “Por meio da ação o demandante não exige nada do demandado, mas sim do órgão estatal provocado. Exige o demandante do juízo. Entretanto, o demandante também exige algo perante o demandado. *No processo, a pretensão de direito material não desaparece. Ela desempenha uma função de grande importância nas sombras da pretensão processual. Mas essa verdade foi*

desconsiderada pela doutrina dominante” (Uber Ansprüche und Einreden Ansprüche. *AcP*, vol. 93, p. 9 e ss.).

282

Eduardo Couture, ao inserir a ação no gênero direito de petição e frisar a sua importância como garantia constitucional, alertou para a impropriedade de distinguir ação de demanda. Eis o que disse o saudoso processualista uruguaio: “*El derecho de demandar (rectius: el derecho a promover y llevar adelante el proceso) es, justamente, la acción. Todo sujeto de derecho tiene, como tal, junto con sus derechos que llamamos, por comodidad de expresión, materiales o sustanciales (en el ejemplo, la propiedad), su poder jurídico de acudir a la jurisdicción. Denominamos acción a este poder jurídico, y el derecho de demandar no es sino el ejercicio concreto del derecho de acudir a la jurisdicción, ya que el proceso civil se halla regido por la máxima nemo iudex sine actore. La acción civil se hace efectiva mediante una demanda en sentido formal, y ésta no es sino el ejercicio de aquélla. No creemos que quede, dentro de la estructura del derecho, luego de haber distinguido entre el derecho material y el derecho procesal de acción, sitio para un tercer derecho, que no sería otra cosa que la acción puesta en ejercicio. Un tercer poder jurídico intermedio, entre el derecho material y el derecho procesal, ya sea que se incluya en el primero, ya sea que se incluya en el segundo, constituye un innecesario desdoblamiento*” (Fundamentos..., cit., p. 73-74).

283

Por outro lado, se a demanda é compreendida apenas como o primeiro ato da ação, o conceito nada acrescenta, pois não elimina a tese de que a ação é exercida para viabilizar a obtenção da tutela jurisdicional do direito e, portanto, deve ser uma ação adequada à tutela do direito.

284

Sobre a questão da tutela jurisdicional, ver, no direito brasileiro, Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela cautelar e tutela antecipatória; Antecipação de tutela; Tutela inibitória; Tutela específica; Técnica processual e tutela dos direitos*; Sérgio Cruz Arenhart, *Tutela inibitória da vida privada; Perfis da tutela inibitória coletiva*; Daniel Mitidiero, *Antecipação da tutela*; Flávio Yarshell, *Tutela jurisdicional*; Alvaro de Oliveira, *Teoria e prática da tutela jurisdicional*; Cândido Rangel Dinamarco, *Tutela jurisdicional. Revista de Processo*, vol. 81, p. 54 e ss; Leonardo Santana de Abreu, *Direito, ação e tutela jurisdicional*, p. 135 e ss.

285

Cf. Nicolò Trocker, *Processo civile e costituzione*, p. 371.

286

Como escreve Vigoriti, “a estreita conexão entre as alegações dos fatos, com que se exercem os direitos de ação e de defesa, e a possibilidade de submeter ao juiz os elementos necessários para demonstrar o fundamento das próprias alegações, tornou clara a influência das normas em tema de prova sobre os direitos garantidos pelo *due process of law*. E a mesma conexão impôs o reconhecimento, em nível constitucional, de um verdadeiro e próprio direito à prova (*right to evidence*) em favor daqueles que têm o direito de agir ou de se defender em juízo” (*Garanzie costituzionali del processo civile*, p. 86).

Para uma interessante crítica a respeito, Lúcio Delfino e Fernando Rossi, Juiz Contraditor?, *Revista brasileira de direito processual*, p. 229-254, n. 82.

A universalização do acesso à justiça tem a ver com a necessidade de se conferir ao cidadão não dotado de recursos a possibilidade de pedir a proteção jurisdicional dos seus direitos. Para tanto o legislador institui procedimentos que têm a missão de atender causas de menor valor econômico e com conteúdos que presumivelmente sejam próprios às pessoas de menor poder financeiro (Lei 9.099/1995, art. 3.º; Lei 10.259/2001, art. 3.º), tornando-os mais informais e céleres, e dispensando, em determinada medida, as custas processuais (ver art. 13, 14, 31, 35, 43, 54 e 55 da Lei 9.099/1995 e art. 8.º, 9.º, 10, 13, 16 e 17 da Lei 10.259/2001). Ver, ainda, Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009).

Para a tutela desses direitos é fundamental dar legitimidade à propositura da ação coletiva a determinados entes, como as associações, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Procon (art. 82, CDC), bem como estender os efeitos das sentenças a toda a coletividade (direitos difusos), aos grupos (direitos coletivos) e aos detentores de direitos individuais homogêneos (art. 103, CDC).

Essas técnicas estão presas aos seguintes pontos: i) universalização do acesso à justiça; ii) tutela jurisdicional dos direitos transindividuais e individuais homogêneos; iii) cognição judicial adequada das diferentes situações de direito material; iv) realização concreta da tutela jurisdicional; e v) distribuição do ônus do tempo do processo.

STF, ADIn 236/DF, acórdão de 05.04.1990, p. 80-81.

Isso porque se presume que os direitos à reintegração e à manutenção de posse trazem em si a urgência. Ou seja, quando tais direitos são evidenciados, ainda que sumariamente, logo após a violação do direito (a turbacão ou o esbulho), presume-se a necessidade de sua realização urgente. É por esse motivo que a tutela antecipatória, nesses casos, exige que a ação tenha sido proposta dentro de ano e dia. É que, se a ação foi proposta depois de ano e dia, há a presunção contrária, isto é, de que não há necessidade de tutela imediata do direito.

Segundo o art. 1.º, *caput*, da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por *habeas corpus* ou *habeas data*, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções

“A lógica subjacente à afirmação de que o mandado de segurança é a tutela do particular contra o Estado deita raízes em uma *visão superada das relações entre o Estado e o particular*. O mandado de segurança, visto como instrumento de tutela das liberdades públicas, tem íntima correlação com os valores liberais, que expressavam uma compreensível preocupação com a ingerência do poder político sobre a vida das pessoas. Atualmente, já operada a transformação que culminou na criação de um novo ‘Estado de Direito’, não há mais razão para contrapor o indivíduo ao Estado, mas sim para zelar por sua justa inserção na vida social e pelo exercício concreto dos novos direitos. Como o objetivo do Estado não é mais apenas proteger os ‘direitos naturais e imprescritíveis do homem’, ocorreu o abandono da política inicial de mera defesa das liberdades, tendo o Estado passado a interferir sempre de modo mais incisivo na esfera dos particulares para a satisfação das necessidades sociais. Essa mudança de escopos do Estado deveria estar refletida não só na predisposição das tutelas jurisdicionais, mas sobretudo na mentalidade dos processualistas, que necessariamente devem pensar o direito processual à luz dos valores do Estado em que vivem. Não é apenas o Estado que atenta contra os direitos dos particulares, como não são somente as ‘liberdades públicas’ que necessitam de tutela jurisdicional célere e efetiva. Basta lembrar os direitos difusos e coletivos, cuja efetiva e concreta realização é muito importante para o Estado contemporâneo alcançar seus fins. A ‘ideia’ de que o mandado de segurança somente pode ser utilizado contra o Estado esteve presente no veto ao art. 85 do CDC, que assim estabelecia: ‘Contra atos ilegais ou abusivos *de pessoas físicas ou jurídicas* que lesem direito líquido e certo, individual, coletivo ou difuso, previsto neste Código, caberá ação mandamental que se regerá pelas normas e lei do mandado de segurança’. Essa norma foi vetada com base na seguinte fundamentação: ‘As ações de mandado de segurança e de *habeas data* destinam-se, por sua natureza, à defesa de direitos subjetivos públicos e têm, portanto, por objetivo precípuo os atos de agentes do Poder Público. Por isso, a sua extensão ou aplicação a outras situações ou relações jurídicas é incompatível com sua índole constitucional. Os artigos vetados, assim, contrariam as disposições dos incs. LXXI e LXXII do art. 5.º da Carta Magna’. Esse veto não tem qualquer sustentação jurídica, pois não há qualquer razão para se pensar que o procedimento do mandado de segurança não possa ser utilizado contra o particular. A proposição que admite o uso do mandado de segurança apenas contra atos do Poder Público somente pode fixar como premissa a tese absurda de que apenas os agentes do Poder Público são capazes de cometer atos que justifiquem o emprego de um procedimento célere e expedito. Imaginar que o processo é uma arma contra o Estado constitui uma ideia sem qualquer coerência com os postulados da moderna doutrina do processo, atualmente tão preocupada com a adequação das tutelas às diferentes situações de direito substancial e com a efetividade dos novos direitos. Na verdade, faltou vontade política para se munir o consumidor de um instrumento efetivo para a tutela dos seus direitos e, dessa forma, é possível dizer que o veto constituiu uma armadilha conservadora. Aliás, já se disse que, quanto mais intensamente uma lei protege os interesses populares e emergentes, maior é a probabilidade de não ser aplicada. Lembre-se de que a intenção do art. 85 não era simplesmente predispor um ‘mandado de segurança’ para a tutela individual do consumidor em juízo, mas também tornar viável o uso do mandado de segurança para a tutela dos direitos difusos e coletivos desconsiderados pelo particular. O veto do art. 85 reflete uma total incapacidade de compreensão da necessidade de tutela jurisdicional célere e efetiva para a proteção dos novos direitos” (Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela inibitória*, cit., p. 299-300). *A tese que ora se propõe elimina problemas como esse, pois, se o autor tem o direito à técnica processual adequada ao caso concreto, sempre lhe será possível exercer a ação com técnicas processuais idôneas, pouco importando se estiverem expressamente previstas apenas em procedimento especial voltado para outra situação específica.*

295

Amplamente, Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata da sentença; Abuso de defesa e parte incontroversa da demanda*.

296

Eduardo Couture, *Fundamentos...*, cit., p. 75.

297

Idem, p. 77.

298

Enrico Tullio Liebman, *L'azione...*, cit., p. 22 e ss.

299

Enrico Tullio Liebman, *Opposizioni di merito nel processo di esecuzione*, p. 166 e ss.

300

Enrico Tullio Liebman, Concepto de la acción civil. *Revista del Centro de Estudiantes de Derecho*, 1940, p. 217 e ss.

301

Enrico Tullio Liebman, O despacho saneador e o julgamento do mérito. *Revista Forense*, vol. 104, p. 216 e ss.; *Processo de execução*, p. 95 e ss. e 127 e ss; *O despacho saneador...*, cit., p. 107 e ss.

302

Art. 100. Para propor uma demanda ou para contestar a mesma *é necessário ter interesse*.

303

Art. 81. Fora dos casos expressamente previstos na lei, ninguém poderá “tutelar no processo” (*far valere nel processo*) em nome próprio direito alheio.

304

É equivocado admitir uma sentença de extinção do processo quando o juiz pode reconhecer, *a partir das provas produzidas*, que o autor não é o titular do direito material (legitimidade para a causa?) ou não pode exigir o pagamento de uma dívida por não estar vencida (ausência de interesse de agir?). A racionalidade do reconhecimento de inexistência de condição da ação está em impedir o seu desenvolvimento inútil,

com gasto de tempo e de dinheiro sem razão de ser. Por isso, o juiz apenas deve aferir as condições da ação com base na *afirmação* do autor. Assim, por exemplo, se o autor *afirma* que o direito material objeto de tutela pertence a outra pessoa, há ausência de legitimidade para a causa.

305

Lembre-se que Liebman, apesar de ter construído a ideia de ação condicionada, não retirou da Constituição da República italiana, ao estabelecer ao lado dessa ação condicionada a ação constitucional, outra coisa que não o direito de ir a juízo.

306

Não é possível esquecer que, em alguns casos, obstáculos podem ser superados mediante a utilização da multa. Assim, por exemplo, no caso em que não se pode localizar a coisa móvel para a busca e apreensão. Ou na hipótese em que o réu impede o acesso do oficial de justiça à coisa, a esconde ou se nega a informar dados fundamentais para o seu desmonte.

307

Luiz Guilherme Marinoni, *Técnica processual...*, cit., p. 587 e ss.

308

“De modo nenhum se pode aceitar que se afirme categoricamente que a ‘ação’ processual depende, para sua existência, da verificação da ação de direito material, porque *é um dado incontestável entre os defensores da teoria dualista da ação* [refere-se a Pontes de Miranda e Ovídio Baptista da Silva] *a abstração da ‘ação’ processual*” (Daniel Mitidiero, *Polêmica...*, cit., p. 692).

309

A respeito, conferir a extensa e importante obra de Ovídio Baptista da Silva, especialmente, para uma compreensão mais didática, o vol. 1 do seu *Curso de processo civil*.

310

Adolfo di Majo, *La tutela...*, cit., p. 43 e ss.

311

Fábio Cardoso Machado, em artigo versando o problema da tutela dos direitos, faz importante ponderação: “Se a tutela jurisdicional socorre o réu, quando o Estado a ele reconhece razão e permanece inerte, socorre também o autor, e para tanto deve agir no sentido de tutelar o seu direito. Pode-se, contudo, inverter a perspectiva e simplesmente dizer que o Estado permanece inerte ao reconhecer razão ao réu porque no caso o direito material não exige a tutela do autor, ou não exige tutela porque não há direito. Ou seja, não se trata apenas de tutelar o réu com razão, mas de negar tutela ao autor porque não havia direito digno de tutela. Este é o escopo jurídico fundamental: tutelar os direitos. O que não se dará quando direito não houver, e isto não deve mudar a perspectiva para considerar que houve então tutela

ao réu. O processo não visa tutelar quem tenha razão, e sim o autor que tenha razão. Isso não implica esquecer as garantias do réu, mas coloca a função jurisdicional num lugar mais adequado às exigências atuais” (Sobre o escopo jurídico do processo: o problema da tutela dos direitos. *Revista de Direito Processual Civil*, vol. 32, p. 260).

312

F. C. Pontes de Miranda, *Tratado das ações*, t. I, p. 32.

313

De acordo com o art. 81, parágrafo único, I, CDC, entende-se por direitos difusos “os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”.

314

Segundo o art. 82 do CDC, são legitimados para a tutela dos direitos difusos (e também dos direitos coletivos e individuais homogêneos – v. art. 81, parágrafo único, II e III) o Ministério Público, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, as entidades e órgãos da administração pública direta ou indireta e as associações. Para maiores detalhes, v. os arts. 81 e 82 do CDC.

315

Lembre-se que a tutela dos direitos também pode ser prestada mediante normas e atividade fáticas administrativas. Ver o item 4.5 “Técnica processual e tutela dos direitos”.

316

Fábio Cardoso Machado reconhece que o escopo jurídico do processo é a tutela dos direitos, advertindo que “não se pode esquecer que o direito material institui direitos, cuja tutela compete à jurisdição” (Sobre o escopo jurídico do processo..., p. 260).

317

Um dos motivos da referida confusão está em que algumas sentenças são *bastantes* para a prestação da tutela jurisdicional do direito. Trata-se das sentenças chamadas de “satisfativas”, ou seja, das sentenças declaratória e constitutiva. Essas sentenças prestam *tutelas* declaratória e constitutiva. Como se vê, nesses casos as sentenças e as tutelas têm o mesmo nome. Mas isso não impede que se separe a técnica processual e o bem da vida por ela outorgado, ou seja, a sentença declaratória da tutela declaratória e a sentença constitutiva da tutela constitutiva. Todas as outras formas de tutela não se identificam com os nomes das sentenças que as prestam.

318

Alvaro de Oliveira, *Efetividade e tutela jurisdicional*, cit., p. 679.

Guilherme Rizzo Amaral, em ensaio sobre a polêmica em torno da ação de direito material, refutou as posições de Pontes de Miranda e Ovídio Baptista da Silva e aderiu aos argumentos de Alvaro de Oliveira para rejeitar a teoria da ação de direito material. *Não obstante, percebeu de maneira bastante clara a importância da distinção entre técnica processual e tutela do direito*: “Ora, a formulação de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira é a de que ‘a eficácia se apresenta apenas como uma forma da tutela jurisdicional, outorgada a quem tenha razão, seja o autor, seja o réu (sentença declaratória negativa). *Está, portanto, no plano processual*, mas não atrelada diretamente à ação processual *senão aos provimentos jurisdicionais*. Esta ideia é consentânea, embora não o afirme expressamente o seu autor, à de técnica de tutela, exposta por Luiz Guilherme Marinoni. Para este último, quando ‘se percebe, contudo, a necessidade de distinguir os meios (que permitem a prestação da tutela) do fim a ser obtido (o resultado no plano do direito material), apresenta-se como adequada a distinção entre tutela jurisdicional stricto sensu e técnicas de tutela jurisdicional’. Assim, classifica Luiz Guilherme Marinoni as sentenças (condenatória, mandamental etc.) como ‘técnicas de tutela’. Estas técnicas de tutela, uma vez adotadas, no plano processual, terão como objetivo buscar a produção de um resultado, este no plano material” (A polêmica em torno da ação de direito material. *Revista de direito processual civil*, vol. 33, p. 542). Como está claro, após evidenciar que Carlos Alberto constrói a sua ideia de tutela jurisdicional a partir dos “provimentos jurisdicionais” ou do que chamamos de “técnicas processuais”, Rizzo percebeu a distinção entre a nossa posição e a de Carlos Alberto. Enquanto Carlos Alberto está preocupado com os “provimentos jurisdicionais”, entendemos que a identificação da tutela jurisdicional deve ser encontrada no plano do direito material, ou melhor, no plano das formas de tutela dos direitos e dos resultados que as técnicas processuais devem proporcionar para que o processo possa responder à sua missão perante o direito material.

Michele Taruffo, “Linee per una Riforma della Cassazione Civile”, *Il Vertice Ambiguo – Saggi sulla Cassazione Civile*, Bologna: Il Mulino, 1991, p. 173.

Melvin Eisenberg, *The Nature of the Common Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1991, p. 4. Aliás, como refere J. A. Jolowicz, “The Role of the Supreme Court at the National and International Level”, *The Role of the Supreme Courts at the National and International Level – Reports for the Thessaloniki International Colloquium*, Thessaloniki: Sakkoulas Publications, 1998, p. 39, “the observation that the decisions of Supreme Courts contribute to the law in one way or another by interpretation, the clarification and, sometimes, the development of the law, whether the doctrine of stare decisis is formally recognised or not, is by now banal”.

Sobre o assunto, Daniel Mitidiero, Por uma Reforma da Justiça Civil no Brasil – Um Diálogo entre Mauro Cappelletti, Vittorio Denti, Ovídio Baptista e Luiz Guilherme Marinoni, *Revista de Processo*, São Paulo: Ed. RT, 2011, n. 199.

Michele Taruffo, Precedente e Giurisprudenza, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, Milano: Giuffrè, 2007, p. 718. A propósito, essa é a razão pela qual o clássico *Interpreting Statutes – A Comparative Study*, Aldershot: Dartmouth, 1991, coordenado por Neil MacCormick e Robert Summers, é centrado sobre a “operative interpretation” e, especificamente, sobre a “interpretation in the Higher Courts” (Zenon Bankowski, Neil MacCormick, Robert Summers e Jerzy Wróblewski, “On Method and Methodology”, *Interpreting Statutes – A Comparative Study*, Aldershot: Dartmouth, 1991, p. 11-16). Não por acaso, a esse trabalho seguiu-se o igualmente clássico *Interpreting Precedents – A Comparative Study*, Aldershot: Dartmouth, 1997, também coordenado por Neil MacCormick e Robert Summers.

Michele Taruffo, “Il Controllo del Diritto e del Fatto in Cassazione”, *Il Vertice Ambiguo – Saggi sulla Cassazione Civile*, Bologna: Il Mulino, 1991, p. 123; Vittoria Barsotti, *L’Arte di Tacere – Strumenti e Tecniche di non Decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti*, Torino: Giappichelli, 1999, p. 292; André Tunc, “La Cour Suprême Idéale”, *La Cour Judiciaire Suprême – Une Enquête Comparative*, Paris: Economica, 1978, p. 437.

STF, AI – AGR 139.671/DF, 1.^a Turma, rel. Min. Celso de Mello, j. 20.06.1995, *DJ* 29.03.1996, p. 9348). O Superior Tribunal de Justiça tem igualmente precedentes nesse sentido (por exemplo, STJ, RO 42/RJ, 3.^a Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 07.12.2006, *DJ* 23.04.2007, p. 251). Quanto ao problema da imunidade à jurisdição executiva dos Estados estrangeiros e seus corpos diplomáticos, consulte-se STF, ACO – AGR 543/SP, Pleno, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 30.08.2006, *DJ* 24.11.2006, p. 61, em que prevaleceu, por maioria, a ideia de imunidade absoluta dos Estados estrangeiros à jurisdição executiva nacional.

É a clássica formulação que remonta à doutrina de Aldo Attardi, *L’Interesse ad Agire*, Padova: Cedam, 1955, p. 204. Entre nós, Rodrigo da Cunha Lima Freire, *Condições da Ação – Enfoque sobre o Interesse de Agir no Processo Civil Brasileiro*, São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 77-119; Leonardo Carneiro da Cunha, *Interesse de Agir na Ação Declaratória*, Curitiba: Juruá, 2002, p. 79-101.

Francesco Invrea, Interesse e Azione, *Rivista di Diritto Processuale Civile*, Padova: Cedam, 1928, p. 321.

331

Amplamente, Donaldo Armelin, *Legitimidade para Agir no Direito Processual Civil Brasileiro*, São Paulo: Ed. RT, 1979.

332

Por todos, José Carlos Barbosa Moreira, Legitimação para Agir. Indeferimento da Petição Inicial, *Temas de Direito Processual*, São Paulo: Saraiva, 1977, p. 199-200.

333

STJ, REsp 21.544/MG, 3ª Turma, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 19.05.1992, DJ 08.06.1992, p. 8.619.

334

A expressão é devida a Giuseppe Chiovenda, *Instituições de Direito Processual Civil*, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1969, p. 252-253, vol. II.

335

Fredie Didier Júnior, *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 67-70.

336

STJ, REsp 44.925/GO, 4.ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 21.06.1994, DJ 15.08.1994, p. 20.339.

337

Waldemar Mariz de Oliveira Júnior, *Substituição Processual*, São Paulo: Ed. RT, 1971, p. 167-170.

338

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 103, t. V; Adroaldo Furtado Fabrício, *A Ação Declaratória Incidental*, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 8; Leonardo Prieto Castro y Ferrandiz, *La Acción Declarativa*, Madrid: Editorial Réus, 1932, p. 9.

339

Giuseppe Chiovenda, *Instituições de Direito Processual Civil*, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1969, p. 211, vol. I; Alfredo Buzaid, *A Ação Declaratória no Direito Brasileiro*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1986, p. 13/18; Celso Agrícola Barbi, *A Ação Declaratória no Processo Civil Brasileiro*, 2. ed., Belo Horizonte: Livraria Oscar Nicolai, 1962, p. 19/21; Torquato Castro, *Ação Declaratória*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1942, p. 31-34.

340

Alfredo Buzaid, *A Ação Declaratória no Direito Brasileiro*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1986, p. 14/18; Adroaldo Furtado Fabrício, *A Ação Declaratória Incidental*, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 22; Ada Pellegrini Grinover, *Ação Declaratória Incidental*, São Paulo: Ed. RT, 1972, p. 18.

341

Alfredo Buzaid, *A Ação Declaratória no Direito Brasileiro*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 1986, p. 19-20.

342

Giuseppe Chiovenda, *Instituições de Direito Processual Civil*, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1969, p. 213-214, vol. I; Torquato Castro, *Ação Declaratória*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1942, p. 39.

343

Adroaldo Furtado Fabrício, *A Ação Declaratória Incidental*, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 16; Celso Agrícola Barbi, *A Ação Declaratória no Processo Civil Brasileiro*, 2. ed., Belo Horizonte: Livraria Oscar Nicolai, 1962, p. 23.

344

Alfredo Buzaid, *A Ação Declaratória no Direito Brasileiro*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1986, p. 24.

345

Pontes de Miranda, *Tratado das Ações*, São Paulo: Ed. RT, 1971, p. 14-17, t. II.

346

Rosenberg, Schwab e Gottwald, *Zivilprozessrecht*, 17. ed., München: C. H. Beck, 2010, p. 493-500.

347

Giuseppe Chiovenda, *Instituições de Direito Processual Civil*, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1969, p. 215-216, vol. I.

348

Celso Agrícola Barbi, *A Ação Declaratória no Processo Civil Brasileiro*, 2. ed., Belo Horizonte: Livraria Oscar Nicolai, 1962, p. 44-49.

349

STJ, REsp n. 16.513/SP, 2ª Turma, rel. Min. Ari Pargendler, j. 18.12.1995, DJ 18.03.1996, p. 7.554.

350

Contra, todavia, possibilitando a execução por créditos a partir de sentença declaratória, o que hoje se sustenta inclusive à vista do art. 515, I, CPC, STJ, EREsp 609.266/RS, 1.^a Seção, rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.08.2006, *DJ* 11.09.2006, p. 223.

351

José Carlos Barbosa Moreira, Ação Declaratória e Interesse, *Direito Processual Civil*, Rio de Janeiro: Borsoi, 1971, p. 9/20.

352

Machado Guimarães, Do Interêsse à Simples Declaração, *Estudos de Direito Processual Civil*, Rio de Janeiro: Editora Jurídica e Universitária, 1969, p. 164.

353

Alfredo Buzaid, *A Ação Declaratória no Direito Brasileiro*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1986, p. 271.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. I - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO II - DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO NACIONAL - E DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL - CAPÍTULO I - DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO NACIONAL

1. Jurisdição e Competência. Jurisdição é poder; competência é capacidade de exercer poder, outorgada pela Constituição e pela legislação infraconstitucional. Embora seja comum a definição da competência como “medida da jurisdição”,¹ é certo que semelhante definição leva à confusão entre jurisdição e competência: dizer que o juiz não tem “medida da jurisdição” significa ao fim e ao cabo afirmar a inexistência de jurisdição “naquela medida”. É por essa razão que é preciso definir a competência em termos qualitativos – é uma capacidade para exercer poder – e não em termos quantitativos – como medida de poder.²

O direito fundamental ao juiz natural implica juiz imparcial e investido de competência absoluta (art. 5.º, XXXVII e LIII, da CRFB), daí a razão pela qual não há processo justo diante de juiz absolutamente incompetente (art. 5.º, LIV, da CRFB). A competência absoluta é um requisito de validade do processo, razão pela qual decisão proferida por órgão jurisdicional absolutamente incompetente é passível de ação rescisória (art. 966, II, do CPC).

2. Limites da Jurisdição Nacional. Os arts. 21, 22 e 23, do CPC, tratam da concorrência entre jurisdições nacional e estrangeira e da exclusividade da jurisdição brasileira.³ Razões ligadas à soberania nacional, a questões diplomáticas e à necessidade de prestar-se uma tutela jurisdicional efetiva e adequada são levadas em consideração pelo nosso Código de Processo Civil para a organização dos limites da jurisdição brasileira.

A alusão à competência internacional concorrente ou exclusiva, presente em algumas passagens do Código (por exemplo, nos arts. 25, § 1.º e 30, II), claramente trata de problemas de limites da jurisdição brasileira e não propriamente de competência. Ainda assim, por seu uso corrente, mantém-se o emprego desses termos na lei e em doutrina.

3. Competência Internacional Concorrente e Competência Internacional Exclusiva. O Código de 2015 prevê hipóteses em que a jurisdição brasileira pode concorrer com eventuais jurisdições estrangeiras (competência internacional concorrente, arts. 21 e 22) e outras em que tão somente ao juiz brasileiro é dado examinar e julgar determinados assuntos (competência internacional exclusiva, art. 23). Se a competência internacional é concorrente, pode haver homologação da decisão estrangeira no Brasil; se a competência é exclusiva, eventual decisão estrangeira é ineficaz perante a nossa ordem jurídica.

Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que:

I – o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;

II – no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;

III – o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.

Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, considera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal.

1. Competência Internacional Concorrente. O art. 21, do CPC, prevê casos em que há competência internacional concorrente (concurso de jurisdições), deles podendo conhecer tanto a justiça brasileira como a justiça estrangeira. Nada obstante, é admissível a cláusula de eleição de

foro estrangeiro, com o poder de afastar a incidência da jurisdição brasileira em casos de “competência concorrente” (art. 25, do CPC).

Existindo decisão estrangeira que se enquadre em quaisquer das hipóteses do artigo em comento, pode-se postular a sua homologação pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, i, da CRFB) para que tenha eficácia e efeitos na ordem jurídica interna (art. 960 e ss., CPC). São requisitos indispensáveis para homologação de sentença estrangeira constam dos arts. 963, do CPC, 216-C e 216-D, Regimento Interno do STJ. A sentença estrangeira tem de ter sido proferida por autoridade competente, as partes têm de ter sido regularmente citadas ou haver-se legalmente verificado a revelia, a sentença estrangeira tem de ter transitado em julgado e estar autenticada pelo cônsul brasileiro, acompanhada de tradução por tradutor oficial ou juramentado no Brasil.

Não será homologada sentença estrangeira que ofenda a ordem pública, aí obviamente incluída a ofensa à soberania e à dignidade da pessoa humana (arts. 963, VI, do CPC, e 216-F, Regimento Interno do STJ).⁴ Daí que a defesa no processo de homologação encontra-se limitada ao não preenchimento dos requisitos indispensáveis à homologação (arts. 216-C, 216-D e 216-E do Regimento Interno do STJ) e à existência de ofensa à soberania nacional, a dignidade da pessoa humana ou à ordem pública (art. 216-F, Regimento Interno do STJ).

Como a defesa é limitada, também a cognição o é – assim, ao Superior Tribunal de Justiça é vedado reexaminar o mérito da decisão homologanda – “o ato homologatório da sentença estrangeira limita-se à análise dos seus requisitos formais”.⁵ Atendidos os requisitos dos arts. 963, do CPC, e 216-B, 216-C e 216-F, *a contrario sensu*, Regimento Interno do STJ, a homologação da decisão estrangeira impõe-se.⁶ Em sendo o caso, à Justiça Federal incumbe concretizar as decisões estrangeiras depois de homologadas pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 109, X, da CRFB).

Art. 22. Compete, ainda, à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações:

I – de alimentos, quando:

a) o credor tiver domicílio ou residência no Brasil;

b) o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos;

II – decorrentes de relações de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil;

III – em que as partes, expressa ou tacitamente, se submeterem à jurisdição nacional.

1. Alimentos. Estando o credor domiciliado no Brasil, a justiça brasileira é competente para a ação de alimentos, ainda quando o devedor esteja residindo e domiciliado no exterior. Nesse caso, porém, a competência não é da Justiça Federal – já que o art. 26, Lei 5.478/1968, só atribui à Justiça Federal a competência para julgar ação de alimentos quando o devedor esteja domiciliado no Brasil –, mas sim da Justiça Comum do domicílio do alimentante.⁷

Eventualmente, nesse caso, a execução da sentença ocorrerá no exterior, na forma prevista pela Convenção de Nova Iorque sobre Alimentos Internacionais, ao menos para os signatários (Dec. Legislativo 10/1958 e Dec. 56.826/1965). Caso ambos os sujeitos (alimentante e alimentando) tenham domicílio no exterior, mas o devedor possua, no Brasil, bens ou rendas passíveis de execução, porque aqui pode ocorrer a execução da sentença, a Justiça brasileira também se torna competente para a causa.

2. Relações de Consumo. Sendo o consumidor domiciliado no Brasil, a Justiça brasileira é competente para a causa, eventualmente concorrendo com outros países.⁸ A propósito, já concluiu o Superior Tribunal de Justiça que “se a economia globalizada não tem fronteiras rígidas e estimula e favorece a livre concorrência, é preciso que as leis de proteção ao consumidor ganhem maior expressão em sua exegese, na busca do equilíbrio que deve reger as relações jurídicas, dimensionando-se, inclusive, o fator risco, inerente à competitividade do comércio e dos negócios

mercantis, sobretudo quando em escala internacional, em que presentes empresas poderosas, multinacionais, com sucursais em vários países, sem alar nas vendas hoje efetuadas pelo processo tecnológico da informática e no mercado consumidor que representa o nosso País”.⁹ Tratando-se de países pertencentes ao Mercosul, aplica-se à causa o Protocolo de Santa Maria sobre Relações de Consumo (art. 4.º, Dec. 10/1996, Mercosul).

3. Cláusula de Eleição de Foro. Tendo em conta o ordenamento jurídico brasileiro acolhe a possibilidade de eleição de foro internacional, por cláusula em contrato, admitindo, salvo nos casos do art. 23, do CPC, a renúncia à jurisdição brasileira em favor da de outro país, também deve admitir a situação inversa: a eleição da jurisdição brasileira para julgar controvérsias oriundas do exterior. Logicamente, o art. 22, III, do CPC, depende da existência de cláusula de eleição de foro que escolha a jurisdição brasileira como competente ou, ao menos, a não oposição de cláusula de eleição de foro que escolha outra jurisdição para certa controvérsia, “prorrogando-se” a jurisdição nacional. Trata-se de solução apoiada ainda na atipicidade das convenções processuais (art. 190, do CPC). A imunidade à jurisdição brasileira também pode ser renunciada, sujeitando o país ou o ente à Justiça nacional.¹⁰

Art. 23. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra:

I – conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil;

II – em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional;

III – em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional.

1. Competência Internacional Exclusiva. Nos casos arrolados no art. 23, do CPC, há “competência internacional” exclusiva da autoridade judiciária brasileira. Vale dizer: o Brasil não reconhece autoridade à jurisdição estrangeira para conhecer de demandas com aquele conteúdo, entendendo que só a jurisdição nacional pode produzir efeitos em território brasileiro sobre tais questões.

Eventual decisão estrangeira que se enquadre em quaisquer dessas hipóteses não tem qualquer eficácia e efeito no Brasil. Nesses casos, a jurisdição brasileira não concorre com nenhuma outra para a apreciação da controvérsia.

2. Não Homologação de Sentença Estrangeira. Eventual decisão de tribunal estrangeiro nos casos do art. 23, do CPC, não é passível de homologação perante o direito nacional, não surtindo efeitos no país, nem se autoriza *exequatur* a cartas rogatórias expedidas por outras nações em tais casos (art. 964, e parágrafo único, do CPC).

3. Cláusula de eleição de foro. Em se tratando das matérias enumeradas no art. 23, do CPC, eventual cláusula de eleição de foro em contrato internacional não é reconhecida para a jurisdição brasileira, não afastando a competência nacional para conhecer dessas causas (art. 25, § 1.º, do CPC).

Art. 24. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil.

Parágrafo único. A pendência de causa perante a jurisdição brasileira não impede a homologação de sentença judicial estrangeira quando exigida para produzir efeitos no Brasil.

1. Ineficácia da Litispendência Estrangeira. A ação intentada perante órgão jurisdicional estrangeiro não tem a eficácia de obstar o exame da mesma causa e das que lhe são conexas pela

jurisdição nacional. Se há concurso de jurisdições e há duas ações idênticas tramitando simultaneamente no Brasil e no estrangeiro há, por óbvio, litispendência. Essa, contudo, não determina a extinção do segundo processo sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC). Vale dizer: há litispendência, mas não há eficácia de litispendência.

À jurisdição brasileira é indiferente que se tenha ajuizado ação em país estrangeiro, ainda que idêntica à outra que aqui tramite.¹¹ Ressalva-se, porém, a hipótese de haver tratado ou outro instrumento internacional que preveja a litispendência internacional com eficácia extintiva. O preceito, porém, não faz represtinar o Código Bustamante (Dec. 18.871/1929), que previa a litispendência internacional, tendo em conta que o art. 394 daquele diploma contrastava com o art. 90 do Código de 1973, tendo sido por esse revogado.

2. Ineficácia da Coisa Julgada Estrangeira. Ainda que já tenha transitado em julgado a decisão estrangeira, não tem o juiz brasileiro de extinguir o processo em que tem curso a causa lá decidida, porque a coisa julgada estrangeira só é eficaz no Brasil depois de homologada pelo Superior Tribunal de Justiça (arts. 105, I, i, CRFB e 961, do CPC). Se, enquanto pendente o pedido de homologação, transita em julgado a decisão brasileira, o processo de homologação tem de ser extinto sem resolução de mérito, haja vista a existência de coisa julgada (art. 963, IV, do CPC). Ao contrário, homologada a decisão estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça e pendente processo no Brasil sobre a mesma causa, tem o juiz brasileiro de extingui-lo sem resolução de mérito em face da existência de coisa julgada (art. 485, V, do CPC).

3. Pendência de Processo no Brasil. Em casos de concurso de jurisdições, porque não se reconhece, em princípio, a litispendência internacional, a existência de processo instaurado no Brasil não impede que se requeira a homologação de sentença estrangeira (art. 24, parágrafo único, do CPC). Obviamente, isso não se aplica em casos de “competência internacional exclusiva”, nem quando haja cláusula em tratado ou instrumento internacional que preveja a litispendência internacional com eficácia extintiva do segundo processo.

Art. 25. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguida pelo réu na contestação.

§ 1º Não se aplica o disposto no *caput* às hipóteses de competência internacional exclusiva previstas neste Capítulo.

§ 2º Aplica-se à hipótese do *caput* o art. 63, §§ 1º a 4º.

1. Cláusula de eleição de foro estrangeiro. É admissível, desde que não se trate de “competência internacional exclusiva”. Para que surta efeito no Brasil, afastando a jurisdição brasileira, nas hipóteses em que cabível, além de sua regularidade formal (observadas as prescrições da legislação aplicável), é preciso que o interessado manifeste, na contestação (sob pena de preclusão) o interesse em excluir a jurisdição brasileira, invocando o pacto celebrado. Do contrário, torna-se ineficaz a cláusula de eleição de foro e a jurisdição nacional passa a ser competente para a controvérsia.

2. Requisitos da Cláusula. Quando a legislação brasileira for aplicável à cláusula de eleição de foro internacional, é necessário que ela conste de instrumento escrito, com alusão expressa a certo negócio jurídico. Sua eficácia estende-se aos herdeiros e sucessores das partes.

3. Abusividade da Cláusula. O juiz pode, de ofício, recusar aplicação à cláusula de eleição de foro internacional se a reputar abusiva. Caso o réu pretenda fazer valer a cláusula de eleição de foro, invocando-a em sua contestação (art. 25, do CPC), poderá o autor, no prazo para a réplica, invocar também essa abusividade, sob pena de preclusão (art. 63, § 4.º, do CPC, por analogia). Findo o prazo da réplica, sem manifestação do autor, a questão da abusividade fica superada, não podendo mais o juiz conhecer da questão, de ofício ou por provocação, devendo extinguir o processo, para que a causa tramite perante a jurisdição eleita pelas partes.

4. Forum shopping. Considera-se abusiva a cláusula de eleição de foro estrangeiro que busca exclusivamente, por meio oblíquo, a obtenção de vantagem no julgamento de certa causa. Apenas se considera abusiva essa cláusula, se a eleição se faz de forma ardilosa, com vantagem exclusiva para uma das partes contratantes.

5. Mercosul. No âmbito do Mercosul, o Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdição Internacional em Matéria Contratual regula a eleição de foro (art. 4.º, Dec. Legislativo 129/1995, Dec. 2.095/1996).

NOTAS DE RODAPÉ

1

Trata-se de conceito que remonta à doutrina francesa do início dos Oitocentos, na medida em que já Giuseppe Pisanelli em 1855 indicava-o como pacífico entre os autores franceses da sua época (*Commentario del Codice di Procedura Civile per gli Stati Sardi con la Comparazione degli altri Codici Italiani, e delle Principali Legislazioni Straniere*, Torino: Società Editrice, 1855, p. 16-17, vol. I). Na mesma linha, Luigi Mattiolo (*Trattato di Diritto Giudiziario Civile Italiano*, 4. ed., Torino: Fratelli Bocca Editori, 1892, p. 24, vol. I), Adolf Wach, *Handbuch des deutschen Civilprozessrecht*, Berlin: Duncker & Humblot, 1885, p. 347; Giuseppe Chiovenda, *Instituições de Direito Processual Civil*, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1969, p. 155, vol. II.

2

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 197, t. III; Celso Neves, *A Estrutura Fundamental do Processo Civil*, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 56; Araken de Assis, *Processo Civil Brasileiro*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1.021, vol. I.

3

Ao alocar a “competência internacional concorrente” e a “competência internacional exclusiva” como questões ligadas aos limites da jurisdição brasileira, o Código de 2015 corretamente reconhece que o problema aí envolvido não diz respeito à competência (nada obstante mantenha a terminologia tradicional), mas à jurisdição, atendendo à crítica da doutrina (Donaldo Armelin, *Competência Internacional*, *Revista de Processo*, São Paulo: Ed. RT, 1976, p. 134, n. 2; Vera Maria Barrera Jatahy, *Do Conflito de Jurisdições*, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 12; Alvaro de Oliveira e Daniel Mitidiero, *Curso de Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 252, vol. I).

4

Sobre o conceito de ordem pública no processo civil, com ampla indicação bibliográfica, Ricardo Aprigliano, *Ordem Pública e Processo*, São Paulo: Atlas, 2011.

5

STJ, Corte Especial, EDcl na SEC 507/EX, rel. Min. Gilson Dipp, j. 06.12.2006, *DJ* 05.02.2007, p. 173.

6

STJ, Corte Especial, SEC 573/EX, rel. Min. José Delgado, j. 01.08.2006, *DJ* 04.09.2006, p. 198.

7

STJ, 2ª Seção. CC 20.175/SP. Rel. Min. Menezes Direito. *DJU* 07.12.98, p. 38.

8

STJ, 4.ª Turma, REsp 1.021.987/RN, Rel. Min. Fernando Gonçalves, *DJe* 09.02.2009.

9

STJ, 4.ª Turma, REsp 63.981/SP, Rel. p/ acórdão Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, *DJU* 20.11.2000, p. 296.

10

STJ, 3.ª Turma, RO 57/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Aldir Passarinho Jr., *DJe* 14.09.2009.

11

STJ, 4.ª Turma, REsp 251.438/RJ, rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.08.2000, *DJ* 02.10.2000, p. 173.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. I - Marinoni - Ed. 2018

CAPÍTULO II - DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

Seção I

Disposições Gerais

Art. 26. A cooperação jurídica internacional será regida por tratado de que o Brasil faz parte e observará:

I – o respeito às garantias do devido processo legal no Estado requerente;

II – a igualdade de tratamento entre nacionais e estrangeiros, residentes ou não no Brasil, em relação ao acesso à justiça e à tramitação dos processos, assegurando-se assistência judiciária aos necessitados;

III – a publicidade processual, exceto nas hipóteses de sigilo previstas na legislação brasileira ou na do Estado requerente;

IV – a existência de autoridade central para recepção e transmissão dos pedidos de cooperação;

V – a espontaneidade na transmissão de informações a autoridades estrangeiras.

§ 1º Na ausência de tratado, a cooperação jurídica internacional poderá realizar-se com base em reciprocidade, manifestada por via diplomática.

§ 2º Não se exigirá a reciprocidade referida no § 1º para homologação de sentença estrangeira.

§ 3º Na cooperação jurídica internacional não será admitida a prática de atos que contrariem ou que produzam resultados incompatíveis com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro.

§ 4º O Ministério da Justiça exercerá as funções de autoridade central na ausência de designação específica.

1. Cooperação internacional e tratados. Cabe aos tratados internacionais disciplinar a cooperação internacional, não sendo atribuição do Judiciário analisar a conveniência da extensão oferecida a essa cooperação. Embora o art. 26, do CPC, preveja requisitos para essa cooperação, descabe ao Judiciário brasileiro recusar a cooperação prevista em tratado, sob a alegação de violação a algum dos requisitos ali indicados. Excetua-se dessa regra a eventual violação a normas fundamentais do Estado brasileiro (arts. 1.º a 17, da CF).

2. Autoridade central. É a designada no tratado. Na sua ausência, será o Ministério da Justiça.

Art. 27. A cooperação jurídica internacional terá por objeto:

I – citação, intimação e notificação judicial e extrajudicial;

II – colheita de provas e obtenção de informações;

III – homologação e cumprimento de decisão;

IV – concessão de medida judicial de urgência;

V – assistência jurídica internacional;

VI – qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira.

1. Objeto da cooperação internacional. Pode ter por fim qualquer dos atos indicados no art. 27, do CPC, e qualquer outro não vedado expressamente pelo direito nacional.

Seção II

Do Auxílio Direto

Art. 28. Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil.

1. Auxílio direto. É técnica de cooperação internacional que dispensa a prévia homologação do Superior Tribunal de Justiça para ser eficaz no território nacional. Esses pedidos são feitos diretamente à Autoridade Central brasileira (designada segundo cada tratado). Trata-se de técnica menos formal e com tramitação mais ágil do que a carta rogatória e, por isso, vem-se disseminando no direito internacional.

Auxílio direto ativo é aquele em que o Brasil pretende a cooperação de outro país. Auxílio direto passivo é aquele em que outro país requer a cooperação internacional do Brasil.

2. Desnecessidade de delibação. Somente se admite o pedido de auxílio direto se o ato a ser praticado no Brasil não depender de juízo de delibação pelo Superior Tribunal de Justiça. Em regra, toda decisão judicial estrangeira precisa de homologação para surtir efeito no Brasil, não sendo passível de pedido de auxílio direto.

Art. 29. A solicitação de auxílio direto será encaminhada pelo órgão estrangeiro interessado à autoridade central, cabendo ao Estado requerente assegurar a autenticidade e a clareza do pedido.

1. Autoridade central. Autoridade central é o ente responsável por dar tramitação e cumprimento aos pedidos de cooperação internacional, ativos e passivos. É designada em cada tratado específico ou em cada acordo de cooperação internacional. Não havendo indicação, será o Ministério da Justiça (normalmente representado pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional). As autoridades centrais não necessitam da via diplomática para a comunicação ou para a tramitação de pedidos de auxílio.

Art. 30. Além dos casos previstos em tratados de que o Brasil faz parte, o auxílio direto terá os seguintes objetos:

I – obtenção e prestação de informações sobre o ordenamento jurídico e sobre processos administrativos ou jurisdicionais findos ou em curso;

II – colheita de provas, salvo se a medida for adotada em processo, em curso no estrangeiro, de competência exclusiva de autoridade judiciária brasileira;

III – qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida pela lei brasileira.

1. Matéria de auxílio direto. Só pode ser objeto de auxílio direto, ativo e passivo, atos que não exijam prévio juízo de delibação perante o Superior Tribunal de Justiça. Em regra, todo ato de conteúdo decisório, tomado em processo judicial, exige prévia homologação perante o direito nacional, não admitindo auxílio direto. Excepcionalmente, porém, admite o direito brasileiro a prática de atos com conteúdo estritamente jurisdicional por meio de auxílio direto (a exemplo da Convenção sobre os Aspectos Cíveis do Sequestro Internacional de Crianças, Dec. 3.413/2000).

Art. 31. A autoridade central brasileira comunicar-se-á diretamente com suas congêneres e, se necessário, com outros órgãos estrangeiros responsáveis pela tramitação e pela execução de pedidos de cooperação enviados e recebidos pelo Estado brasileiro, respeitadas disposições

específicas constantes de tratado.

1. Dispensa de intermediação diplomática. O auxílio direto dispensa a intervenção das vias diplomáticas para a comunicação entre a autoridade central brasileira e a de outro país. Basta o respeito aos requisitos previstos em cada tratado, para que o ato seja legítimo.

Art. 32. No caso de auxílio direto para a prática de atos que, segundo a lei brasileira, não necessitem de prestação jurisdicional, a autoridade central adotará as providências necessárias para seu cumprimento.

1. Atos não jurisdicionais. No pedido de auxílio direto passivo, para a prática de atos que não exijam a intervenção da jurisdição brasileira (notificações, obtenção de informação etc.), deve a Autoridade Central praticar o ato de forma autônoma, independentemente da intervenção judicial. Se necessário, pode adotar as providências administrativas cabíveis ou buscar, perante os órgãos competentes, a satisfação do pedido de auxílio direto.

Art. 33. Recebido o pedido de auxílio direto passivo, a autoridade central o encaminhará à Advocacia-Geral da União, que requererá em juízo a medida solicitada.

Parágrafo único. O Ministério Público requererá em juízo a medida solicitada quando for autoridade central.

1. Intervenção do órgão de atuação jurídica. O art. 33, do CPC, limita-se a tratar, no *caput*, das hipóteses em que a autoridade central brasileira, no auxílio direto passivo, é órgão da União (em regra, o Ministério da Justiça, art. 26, § 4.º, do CPC). Porém, como mostra o parágrafo único, desse artigo, em se tratando de outra autoridade central, como é o caso do Ministério Público, caberá a ela a adoção dos atos necessários à satisfação do pedido de auxílio direto. A regra vale tanto para pedidos de auxílio que tenham conteúdo jurisdicional – quando o pedido será formulado perante a autoridade judiciária federal brasileira (art. 34, do CPC) – como para casos que não demandem a intervenção jurisdicional (art. 32, do CPC).

Art. 34. Compete ao juízo federal do lugar em que deva ser executada a medida apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional.

1. Auxílio direto com conteúdo jurisdicional. Se o pedido de auxílio direto passivo tem conteúdo jurisdicional, será competente o juízo federal do local em que deva ser efetivada a medida buscada (arts. 109, I ou III, da CF e 34, do CPC).

Seção III

Da Carta Rogatória

Art. 35. (*Vetado.*)

Art. 36. O procedimento da carta rogatória perante o Superior Tribunal de Justiça é de jurisdição contenciosa e deve assegurar às partes as garantias do devido processo legal.

§ 1º A defesa restringir-se-á à discussão quanto ao atendimento dos requisitos para que o pronunciamento judicial estrangeiro produza efeitos no Brasil.

§ 2º Em qualquer hipótese, é vedada a revisão do mérito do pronunciamento judicial estrangeiro pela autoridade judiciária brasileira.

1. Carta rogatória. É mecanismo de comunicação internacional, utilizado quando não haja previsão, em tratado ou acordo de cooperação, do emprego de auxílio direto e, eventualmente, quando expressamente indicado pelo ato internacional. Pode ter por objeto qualquer ato processual que deva ser executado no Brasil, de conteúdo decisório ou não (art. 7.º, Resolução 9/05).

2. Decisões finais. Podem ser objeto de carta rogatória, além dos atos descritos no art. 27, do CPC, os pedidos de execução de sentenças estrangeiras, em matéria civil, comercial, trabalhista e administrativa, no âmbito do Mercosul (art. 19, Dec. 2.067/1996).

3. Exequatur. A carta rogatória deve ser objeto de homologação (*exequatur*) perante o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 960 e ss., do CPC. O *exequatur* é processo de jurisdição contenciosa, que deve garantir o devido processo legal e todos os seus direitos fundamentais processuais a ele inerentes, aí obviamente incluídos o contraditório e a ampla defesa. A discussão, porém, não pode adentrar na análise do mérito da decisão judicial, mas apenas envolverá os requisitos para a homologação dessa decisão perante a jurisdição nacional (arts. 36, § 2.º e 963, do CPC).

4. Pedidos de urgência. Em havendo urgência insuperável, ou quando a prévia oitiva da parte contrária possa frustrar a eficácia da medida cujo *exequatur* se pretende, é possível o cumprimento em caráter provisório da carta rogatória, mesmo antes de ouvida a parte contrária. A propósito, já considerou o Superior Tribunal de Justiça que “é certo que o contraditório nos instrumentos de cooperação faz respeitar o mandamento constitucional, entretanto esta intimação prévia não pode ser aberta indiscriminadamente, devendo ser observada a utilidade da medida solicitada pela autoridade estrangeira de modo a torná-la eficaz”.¹

Seção IV

Disposições Comuns às Seções Anteriores

Art. 37. O pedido de cooperação jurídica internacional oriundo de autoridade brasileira competente será encaminhado à autoridade central para posterior envio ao Estado requerido para lhe dar andamento.

1. Tramitação. O pedido de auxílio direto ativo e a carta rogatória originária do Brasil serão encaminhados à autoridade central, para remessa ao Estado estrangeiro. Cabe à autoridade central tomar as providências necessárias para dar o encaminhamento adequado ao pedido de cooperação.

Art. 38. O pedido de cooperação oriundo de autoridade brasileira competente e os documentos anexos que o instruem serão encaminhados à autoridade central, acompanhados de tradução para a língua oficial do Estado requerido.

1. Formalização. O pedido de cooperação internacional deve ser encaminhado à autoridade central já com a devida tradução para a língua do país requerido, salvo quando o tratado em que se basear o pedido dispense essa formalidade. Também deve estar acompanhado da documentação adequada, conforme a previsão do instrumento específico de cooperação (tratado, acordo de cooperação etc.), sob pena de não se dar seguimento ao pedido.

Art. 39. O pedido passivo de cooperação jurídica internacional será recusado se configurar manifesta ofensa à ordem pública.

1. Recusa. Em paralelo com o que ocorre com as decisões estrangeiras sujeitas a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 963, VI, do CPC), não se deve admitir pedido de auxílio direto passivo que viole a ordem pública.

Art. 40. A cooperação jurídica internacional para execução de decisão estrangeira dar-se-á por meio de carta rogatória ou de ação de homologação de sentença estrangeira, de acordo com o art. 960.

1. Procedimento para homologação de sentença estrangeira e para exequatur à carta rogatória. É aquele previsto no art. 960 e ss., do CPC, e nos arts. 216-C, 216-E e 216-G a 216-N (homologação) e arts. 216-Q a 216-X (*exequatur*), Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Sem a devida homologação, essas decisões não têm eficácia no direito nacional. Trata-se de problema de eficácia e não de validade.

A homologação de sentença estrangeira será requerida pela parte interessada, devendo a petição inicial conter as indicações constantes da lei processual (art. 319, do CPC), e ser instruída com a certidão ou cópia autêntica do texto integral da sentença estrangeira e com outros documentos indispensáveis, devidamente traduzidos e autenticados (art. 216-C, Regimento Interno do STJ). Não preenchendo os requisitos, tem o órgão jurisdicional o dever de viabilizar a emenda (art. 216-E, Regimento Interno do STJ). A parte interessada será citada para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar o pedido de homologação de sentença estrangeira (art. 216-H, Regimento Interno do STJ), sendo que a defesa só poderá versar sobre a “inteligência da decisão alienígena e a observância dos requisitos indicados nos arts. 216-C, 216-D e 216-F” (art. 216-H, parágrafo único, Regimento Interno do STJ). Havendo contestação à homologação de sentença estrangeira, o processo será distribuído para julgamento pela Corte Especial, cabendo ao relator os demais atos relativos ao andamento e à instrução do processo, admitindo-se réplica e tréplica (arts. 216-J e 216-K, Regimento Interno do STJ). Revel ou incapaz o requerido, dar-se-lhe-á curador especial que será pessoalmente notificado (art. 216-I, Regimento Interno do STJ). O Ministério Público terá vista dos autos nas homologações de sentenças estrangeiras, pelo prazo de 10 (dez) dias, podendo impugná-las (art. 216-L, Regimento Interno do STJ). Das decisões do Presidente na homologação de sentença estrangeira cabe agravo (art. 216-M, Regimento Interno do STJ). Cumpre ao juízo federal competente, em sendo o caso, executá-la (art. 216-N, Regimento Interno do STJ).

A concessão do *exequatur* será requerida pela parte interessada ao presidente do Superior Tribunal de Justiça. Acaso seja formulado, a título de *exequatur*, pedido de cooperação jurídica internacional insuscetível de juízo de delibação do STJ, esse será devolvido ao Ministério da Justiça para as providências necessárias para o seu cumprimento como auxílio direto (arts. 28, do CPC, e 216-O, Regimento Interno do STJ). A parte contrária será intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar o pedido (art. 216-Q, Regimento Interno do STJ). Nada obsta, porém, que o *exequatur* seja concedido *inaudita altera parte*, desde que o contraditório possa resultar em ineficiência da medida (art. 216-Q, § 1.º, Regimento Interno do STJ). A defesa só poderá versar sobre a “autenticidade dos documentos, a inteligência da decisão e a observância dos requisitos previstos neste Regimento” (art. 216-Q, § 2.º, Regimento Interno do STJ). “Revel ou incapaz a parte requerida, dar-se-lhe-á curador especial” (art. 216-R, Regimento Interno do STJ). Assim como ocorre no processo de homologação de decisão estrangeira, “o Ministério Público Federal terá vista dos autos nas cartas rogatórias pelo prazo de dez dias, podendo impugnar o pedido” (art. 216-S, Regimento Interno do STJ). Havendo impugnação ao pedido, o presidente poderá determinar a sua distribuição à Corte Especial (art. 216-T, Regimento Interno do STJ). “Das decisões do presidente ou do relator na concessão de *exequatur* à carta rogatória caberá agravo” (art. 216-U, Regimento Interno do STJ). Devidamente internalizada, a carta rogatória será remetida para o juízo federal competente para o cumprimento (art. 216-V, Regimento Interno do STJ). No juízo federal será admitida defesa mediante embargos (art. 216-V, §§ 1.º e 2.º, Regimento Interno do STJ). Da decisão caberá agravo (art. 216-W, Regimento Interno do STJ). Cumprida a carta ou verificada a impossibilidade de seu cumprimento, essa será devolvida ao presidente do STJ, que a remeterá mediante o Ministério da Justiça ou o Ministério das Relações Exteriores à autoridade estrangeira de origem (art. 216-X, Regimento Interno do STJ).

Art. 41. Considera-se autêntico o documento que instruir pedido de cooperação jurídica internacional, inclusive tradução para a língua portuguesa, quando encaminhado ao Estado brasileiro por meio de autoridade central ou por via diplomática, dispensando-se ajuramentação, autenticação ou qualquer procedimento de legalização.

Parágrafo único. O disposto no *caput* não impede, quando necessária, a aplicação pelo Estado brasileiro do princípio da reciprocidade de tratamento.

1. Autenticação de documentos. Os documentos encaminhados ao Estado Brasileiro com pedido de cooperação podem ser autenticados por meio diplomático ou pela autoridade central, dispensando-se qualquer outro procedimento de legalização.

2. Reciprocidade. Sempre, porém, que no outro país se exija outra forma de autenticação, o princípio da reciprocidade permitirá ao Brasil que exija o mesmo requisito.

NOTAS DE RODAPÉ

¹

STJ, Presidência, RCDESP na Carta Rogatória 999-EX, Presidente Min. Edson Vidigal, *DJe* 16.08.2005.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. I - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO III - DA COMPETÊNCIA INTERNA - CAPÍTULO I - DA COMPETÊNCIA

Seção I

Disposições Gerais

1. Critérios para Definição de Competência. Uma vez definida a jurisdição brasileira (arts. 21 a 23, do CPC), cumpre estabelecer a competência (arts. 42 a 53, do CPC).

É interessante perceber antes de qualquer coisa, porém, que rigorosamente o Título III do Livro II da Parte Geral deveria se chamar apenas competência (e não “competência interna”), na medida em que no Título I o legislador não trabalha a “competência internacional”, mas sim os limites entre a jurisdição nacional e a estrangeira. A alusão à competência “interna” é um resquício da sistemática do Código de 1973 que o legislador do Código de 2015 não soube eliminar. Se o Título III aludisse corretamente apenas à competência, seria supérflua a ulterior especificação do Capítulo I – que estranhamente é mais abrangente que o Título III: da “competência interna” passa-se à “competência”.

Partindo de conhecida lição, o Código de 2015 procura definir a competência a partir de três critérios: o objetivo, o funcional e o territorial.¹ O primeiro critério desdobra-se em objetivo i) em razão do valor, ii) em razão da matéria e iii) em razão da pessoa; o segundo, em: i) funcional horizontal e ii) funcional vertical (também conhecido como critério hierárquico ou por graus). A aplicação desses critérios visa a determinar qual é o juízo competente.

2. Multiplicidade de Juízos Competentes: Foros Concorrentes, Forum Shopping e Forum non Conveniens. Pode ocorrer, em face da multiplicidade de juízos eventualmente competentes ao mesmo tempo para conhecer de determinada causa (como ocorre nos processos transnacionais,² nas ações coletivas em que o ilícito ou o dano tem abrangência nacional, art. 93, do CDC, e ainda em outras situações, arts. 47, § 1.º, 51, parágrafo único, 53, V, e 516, parágrafo único, do CPC), de o demandante poder escolher o juízo no qual pretende litigar: é o que a doutrina vem chamando de *forum shopping*.³

A princípio, quando a legislação permite ao demandante a escolha por determinado juízo, confere ao titular do direito de ação um direito potestativo. Em outras palavras, é uma faculdade reservada ao demandante escolher pelo foro que melhor aprouver ao seu interesse. Nada obstante, essa escolha não pode ser motivada por fins diversos daqueles assinalados pela ordem jurídica: se é verdade que a concorrência de foros visa a facilitar o acesso à justiça, também é verdade que a sua escolha deve respeitar a boa-fé (art. 5.º, do CPC).

Isso quer dizer que, se o *forum shopping* for orientado apenas à criação de uma *dificuldade para o exercício da defesa*, poderá o demandado arguir a inconveniência do foro – isto é, o *forum non conveniens*. O fundamento para neutralizar a escolha do demandante é a boa-fé, porque a escolha do juízo não pode ser motivada apenas para a criação de um obstáculo à defesa: quem assim age exerce o seu direito fora dos seus propósitos, dele abusando.

O *forum non conveniens* pode ser arguido pelo demandado na contestação (art. 337, II, do CPC) e pode ser conhecido de ofício pelo juiz, tendo em conta que esse deve dirigir o processo de modo a velar pela justiça do processo (arts. 5.º, LIV, da CRFB, e 139, IX, do CPC). Sendo o juiz da causa o primeiro juiz da sua própria competência (*Kompetenz-Kompetenz*), nada obsta inclusive que decline da competência por força do *forum non conveniens* mesmo antes do deferimento da citação

do demandado.

3. Competência Absoluta e Competência Relativa. Uma vez determinada a competência, no entanto, é preciso saber qual é o regime jurídico a que se submete a competência – vale dizer, quais são as normas que disciplinam a competência no que tange aos poderes do juiz e das partes e às consequências concernentes à sua observação ou violação. Dois são os regimes jurídicos a que se submete a competência: o da competência absoluta e o da competência relativa, organizados segundo a maior ou menor disponibilidade da vontade das partes sobre as normas determinadoras da competência.⁴

Pelo primeiro, o juiz pode conhecer de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição a incompetência, não há preclusão de alegação pelas partes, a competência não se prorroga, não se modifica e não pode ser alterada pela vontade das partes. Pelo segundo, não pode conhecer de ofício a incompetência (Súmula 33, do STJ), há preclusão de alegação se a parte não oferece a alegação de incompetência no prazo legal, prorrogando-se a competência, existindo ainda a possibilidade de sua modificação e alteração pela vontade das partes.

No Código de Processo Civil, são casos de competência absoluta as hipóteses em que a competência é fixada em face do critério objetivo em razão da matéria, do critério objetivo em razão da pessoa, do critério funcional horizontal (salvo no caso do art. 516, parágrafo único, do CPC) e do critério funcional vertical (hierárquico); de competência relativa, aquelas hipóteses em que há fixação pelo critério objetivo em razão do valor e do território.

Todavia, é importante perceber que existem algumas situações em que, nada obstante a competência seja definida a partir do critério objetivo em razão do território, há um regime de competência *sui generis* – essas são precisamente as hipóteses dos arts. 47, §§ 1.º e 2.º e 63, § 3.º, do CPC. A competência é *sui generis* justamente porque não se deixa caracterizar integralmente nem pelo regime da competência absoluta, nem pelo regime da competência relativa: note-se que o critério é objetivo em razão do território, mas o juiz tem o poder de conhecer de ofício da própria incompetência.

Art. 42. As causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência, ressalvado às partes o direito de instituir juízo arbitral, na forma da lei.

1. Causas Cíveis. No direito brasileiro, são cíveis as causas que não são penais nem trabalhistas. Submetem-se à jurisdição civil e entram na competência dos juízos cíveis, pois, tanto as causas de direito privado como aquelas ligadas ao direito administrativo, tributário, concorrencial, previdenciário e por aí afora. O direito brasileiro utiliza a expressão em sentido amplo. A competência atribui ao órgão jurisdicional a capacidade para processar e julgar as causas cíveis nos limites assinalados pela Constituição e pela legislação infraconstitucional.

2. Juízo Arbitral. A Lei 9.307/1996, possibilita a instituição de arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis (art. 1.º). A previsão da possibilidade de juízo arbitral no direito brasileiro não fere, em tese, o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.º, XXXV, da CRFB).⁵ Todavia, não se pode homologar sentença arbitral estrangeira se não há inequívoca submissão convencional da parte à arbitragem estrangeira, sob pena de ofensa à ordem pública interna.⁶

No Brasil, é possível instituir o juízo arbitral por convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral (art. 3.º). Resistindo uma das partes à arbitragem, poderá essa ser instituída judicialmente (art. 7.º).⁷ Havendo processo, nada obstante a existência de convenção de arbitragem válida e eficaz entre as partes, tem o juiz de extingui-lo sem resolução de mérito (art. 485, VII, do CPC).

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

1. Perpetuação da Competência. Determina-se a competência no momento em que a demanda é ajuizada, assim considerada a data do registro ou da distribuição da petição inicial (arts. 43 e 312, do CPC). Obviamente, embora aqui se aluda a “registro ou distribuição” e no outro preceito se fale em “protocolo”, trata-se de etapas de um mesmo ato judicial, de modo que qualquer um deles (o que ocorrer primeiro) é apto a fixar o termo inicial do processo e, consequentemente, determinará competência para a causa.

A fim de que o processo se desenvolva da maneira mais estável possível, possibilitando-se um deslinde mais célere para a causa, nossa legislação estabelece que eventuais modificações no estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente à propositura da ação não têm o condão de deslocar a competência do órgão jurisdicional, ressalvadas as exceções legais. Há determinação e perpetuação da competência (*perpetuatio jurisdictionis*, como por vezes se alude) com a propositura da ação. Assim é que, “proposta a execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada” (Súmula 58, do STJ). Todavia, a mudança na sede da empresa, antes da propositura da execução fiscal, evidentemente não enseja a aplicação da Súmula 58, do STJ.⁸ Ao lado dos arts. 108 (estabilidade de partes) e 329 (estabilidade objetiva), o art. 43 compõe a regra da estabilidade do processo.

2. Incompetência Superveniente e Translatio Iudicii. Suprimido o órgão judiciário perante o qual tramitava a ação ou sobrevindo incompetência absoluta do órgão jurisdicional, tem a causa de ser redistribuída para o juízo competente. A supressão do órgão judiciário e a incompetência superveniente devem ser conhecidas de ofício e tem o juiz de declinar oficiosamente de sua competência para o novo juízo competente, após permitir às partes manifestação prévia (art. 64, §§ 1.º e 2.º, do CPC).

Todos os atos processuais praticados sob o abrigo da lei antiga devem ser considerados obviamente válidos e eficazes perante o novo juízo. Isso quer dizer que a incompetência superveniente determina a *translatio iudicii*, isto é, a preservação dos efeitos oriundos da litispendência, ainda que determinada a remessa da causa para outro juízo por força do reconhecimento da incompetência.⁹

Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados.

1. Fontes para Determinação de Competência. As fontes básicas para a determinação dos critérios de competência são a legislação constitucional, federal, estadual e, em um segundo momento, as normas administrativas de organização judiciária. A Constituição, por exemplo, apresenta regras para determinar a competência do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Federal nos arts. 102, I, e e f, e 109, I e II.

2. Em Razão do Valor. A competência em razão do valor é disciplinada nas normas de organização judiciária da União, de cada Estado-membro e do Distrito Federal. No Código de Processo Civil, a competência fixada em função do critério objetivo em razão do valor é relativa, não pode ser conhecida de ofício, sendo modificável, prorrogável e alegável em preliminar à contestação (arts. 65 e 337, II, do CPC). No Juizado Especial Federal, ao contrário, a competência fixada em função do critério objetivo em razão do valor é absoluta (art. 3.º, § 3.º, Lei 10.259/2001), podendo ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo passível de modificação e prorrogação. O demandado pode argui-la como preliminar de contestação (art. 337, II, do CPC), podendo qualquer das partes fazê-lo por mero requerimento nos autos.

3. Em Razão da Matéria. A competência em razão da matéria é prevista na Constituição e no Código de Processo Civil, podendo as normas de organização judiciária ainda estabelecer internamente a distribuição dos feitos organizando varas judiciárias e órgãos fracionários nos Tribunais com competência especializada em razão da natureza das causas a julgar. A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, contudo, não altera a competência territorial resultante das leis de processo (Súmula 206, do STJ). Vara privativa não importa foro privativo. Já se decidiu que “o Estado-membro não tem foro privilegiado, mas juízo privativo (vara

especializada), nas causas que devem correr na comarca da capital, quando a Fazenda for autora, ré ou interveniente. Nas causas pertencentes à competência territorial de qualquer outra comarca não pode a lei de organização judiciária atrair causas para o foro da capital”.¹⁰

A competência em razão da matéria afere-se pela análise da causa de pedir e do pedido.¹¹ A competência fixada em função do critério objetivo em razão da matéria é absoluta, pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, não pode ser modificada e é inderrogável pela vontade das partes. As partes podem argui-la a qualquer tempo, mesmo depois do prazo para a contestação (art. 64, § 1.º, do CPC).

4. Em Razão da Pessoa. A competência em razão da pessoa está prevista na Constituição. Entra no regime da competência absoluta, pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, não pode ser modificada e é inderrogável pela vontade das partes. As partes podem argui-la a qualquer tempo, mesmo depois do prazo para a contestação (art. 64, § 1.º, do CPC).

5. Em Razão da Função. A competência em razão do critério funcional é fixada em face de determinadas funções especiais que se acometem aos juízes em dados processos. A competência funcional pode ser vertical (hierárquica ou por graus), atribuída levando em conta a coordenação hierárquica entre os órgãos jurisdicionais, regida pela Constituição e pelas normas de organização judiciária, ou horizontal, distribuída entre juízes do mesmo grau de jurisdição, disciplinada no Código de Processo Civil.

As competências recursais são competências funcionais verticais. São exemplos de competências funcionais horizontais a competência para o cumprimento da sentença condenatória (art. 516, do CPC), a competência para conhecer das ações acessórias (art. 61, do CPC) e a competência do local do dano na ação civil pública (art. 2.º, Lei 7.347/1985),¹² embora, a rigor, aqui se trate de competência territorial absoluta e não de competência funcional). A competência funcional é absoluta, pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, não pode ser modificada e é inderrogável pela vontade das partes. As partes podem argui-la a qualquer tempo.

Caso especial de competência fixada em face do critério funcional, todavia, é o da competência para o cumprimento da sentença condenatória, porque aí concorrem com o juízo da prolação da decisão o juízo onde se encontram os bens sujeitos à expropriação, o juízo onde deve ser realizada a prestação de fazer ou não fazer e o juízo do domicílio do executado (art. 516, parágrafo único, do CPC). Há, nesse caso, competência determinada pelo critério funcional, mas disciplinada pelo regime da competência relativa, sujeitando-se à preclusão.

6. Em Razão do Território. A competência em razão do território é fixada em consideração à porção territorial do domicílio, da coisa ou do local do ato ou fato. A competência territorial é relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz é derogável pela vontade das partes e é prorrogável, acaso não arguida na contestação.

Art. 45. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier a União, suas empresas públicas, entidades autárquicas e fundações, ou conselho de fiscalização de atividade profissional, na qualidade de parte ou de terceiro interveniente, exceto as ações:

I – de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho;

II – sujeitas à justiça eleitoral e à justiça do trabalho.

§ 1º Os autos não serão remetidos se houver pedido cuja apreciação seja de competência do juízo perante o qual foi proposta a ação.

§ 2º Na hipótese do § 1º, o juiz, ao não admitir a cumulação de pedidos em razão da incompetência para apreciar qualquer deles, não examinará o mérito daquele em que exista interesse da União, de suas entidades autárquicas ou de suas empresas públicas.

§ 3º O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo.

1. Competência da Justiça Estadual em Razão da Matéria. Cumprido ao juiz de direito, inclusive ao juiz de direito substituto (art. 22, § 2.º, LC 35/1979), processar e julgar de maneira principal o processo de recuperação judicial, de falência e de insolvência civil (art. 109, I, da CRFB). A competência da Justiça Estadual não é afastada para processar e julgar o processo de insolvência ainda que demande em juízo, por exemplo, empresa pública federal.¹³ “O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa” (Súmula 480, do STJ). As ações concernentes à nacionalidade, inclusive no que tange à respectiva opção, e à naturalização são causas que são sempre processadas e julgadas pela Justiça Federal (art. 109, X, da CRFB).

2. Jurisdição voluntária. Ainda que a causa não envolva conflito de interesses, se envolver algum dos entes sujeitos à jurisdição federal (art. 109, I, da CRFB), a causa é da competência da Justiça Federal. “Compete à Justiça Federal processar justificações judiciais destinadas a instruir pedidos perante entidades que nela têm exclusividade de foro, ressalvada a aplicação do art. 15, II, da Lei 5.010/1966” (Súmula 32, do STJ). “Compete à Justiça Federal, excluídas as reclamações trabalhistas, processar e julgar os feitos relativos à movimentação do FGTS” (Súmula 82, do STJ).

3. Remessa dos autos entre Justiça Estadual e Federal. A simples intervenção dos entes arrolados no art. 109, I, da CRFB, em causa que tramita perante a Justiça Estadual, é suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal. “A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) desloca a competência para a Justiça Federal ainda que a sentença tenha sido proferida por Juízo estadual” (Súmula 365, do STJ). Só a Justiça Federal tem a competência para decidir se o ente federal tem ou não interesse em determinada causa. “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas” (Súmula 150, do STJ). Por isso, só ela pode excluir esses entes do processo, razão pela qual, diante do pedido de intervenção dos entes arrolados no art. 109, I, da CRFB, deve o processo ser remetido à Justiça Federal, para apreciação do interesse federal e, consequentemente, para a fixação da competência. “A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual” (Súmula 254, do STJ). Excluído o ente federal pela Justiça Federal, deve-se restituir os autos à Justiça Estadual e não suscitar conflito de competência. “Excluído do feito o ente federal, cuja presença levou o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito” (Súmula 224, do STJ). O interesse que permite a intervenção de ente federal (art. 109, I, da CF) em processo é sempre o interesse jurídico.

4. Pendência de Pedido da Competência da Justiça Estadual e Intervenção de Entidade Sujeita à Competência Federal. Caso o interesse do ente federal diga respeito apenas à parte do litígio, o juiz estadual não deve encaminhar os autos à Justiça Federal. O juiz estadual, nesse caso, deve recusar a cumulação de pedidos, deixando de analisar o pedido que envolva interesse federal.

5. Intervenção da União depois da apelação. “A intervenção da União, em feito já julgado pela segunda instância e pendente de embargos, não desloca o processo para o Tribunal Federal de Recursos” (Súmula 518, do STF, recordando que o Tribunal Federal de Recursos, aí mencionado, equivale atualmente ao Superior Tribunal de Justiça).

6. Anulação de Multa Eleitoral. “Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar a ação para anular débito decorrente de multa eleitoral” (Súmula 374, do STJ).

7. Acidente de Trabalho. “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional 45/04” (Súmula Vinculante 22, do STF).

8. Greve e ação possessória. “A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação

possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada” (Súmula Vinculante 23, do STF).

9. Descumprimento de Normas Trabalhistas. “Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores” (Súmula 736, do STF).

10. Juízo da Recuperação Judicial e Constrição de Bens. “O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa” (Súmula 480, do STJ).

11. Intervenção anômala. A intervenção anômala, prevista no art. 5.º, Lei 9.469/1997, que permitia à União e às pessoas jurídicas de direito público em geral a intervenção em processos alegando meros reflexos econômicos, por não ter sido repetida pelo CPC, foi implicitamente revogada. Não existe mais, por isso, a possibilidade de intervenção da União ou de pessoas de direito público em processos, salvo quando demonstrar interesse jurídico, ou quando a intervenção ocorrer na condição de *amicus curiae* (art. 138, do CPC).

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

§ 1º Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles.

§ 2º Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor.

§ 3º Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.

§ 4º Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.

§ 5º A execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado.

1. Critério Territorial para Determinação de Competência. A competência fixada em face do critério territorial entra no regime da competência relativa, não podendo dela conhecer o juiz de ofício (Súmula 33, do STJ), sendo modificável e derogável pela vontade das partes. A sua alegação tem de se dar em preliminar à contestação, sob pena de preclusão e consequente prorrogação do juízo. Excepcionalmente, porém, a competência determinada pelo critério territorial dá lugar a um regime *sui generis* de competência. Permite-se que o juiz conheça de ofício da invalidade de cláusula de foro (art. 63, do CPC) prevista em contrato de adesão, devendo declinar de sua competência oficiosamente para o foro de domicílio do réu (art. 63, § 3.º, do CPC). Não sendo declinada pelo juízo de ofício, a parte poderá argui-la em preliminar à contestação; não o fazendo, dar-se-á a preclusão, prorrogando-se a competência (art. 63, § 4.º, do CPC).

2. Auctor Sequitur Forum Rei. As ações fundadas em direito pessoal e as ações fundadas em direito real sobre móveis serão propostas, em regra, no foro domicílio do réu. Os direitos de personalidade e os direitos obrigacionais, por exemplo, ingressam no conceito de direito pessoal; os direitos reais estão arrolados expressamente em lei (art. 1.225, do CC). O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo (art. 70, do CC). Se o demandado é pessoa jurídica, considera-se seu domicílio o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos (art. 75, IV, do CC). A pessoa jurídica, pois, é demandada do lugar em que está a sua sede (art. 53, III, *a*, do CPC). Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele será demandado onde for encontrado. Não tendo o demandado domicílio nem residência no Brasil, a ação será proposta no foro do domicílio do demandante. Se o demandante também não residir no Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Havendo dois ou mais réus, com diferentes domicílios, serão

demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.

3. Execução Fiscal. A Fazenda Pública não pode escolher o foro onde ajuizará a execução fiscal. O art. 46, § 5.º, do CPC, prevê, na verdade, gradação legal impositiva, de modo que a existência de domicílio certo afasta o da residência; e a residência certa afasta o local em que for encontrado. Só assim o art. 46, § 5.º, do CPC, se harmoniza com o art. 109, § 1.º, da CRFB.

Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

1. Forum Rei Sitae. As ações reais imobiliárias devem ser propostas no foro da situação da coisa. Se o litígio recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova o foro da coisa é determinado pelo critério funcional,¹⁴ entrando no regime da competência absoluta¹⁵ (STJ, CC 46.771/RJ, 1.ª Seção, rel. Min. Denise Arruda, j. 24.08.2005, DJ 19.09.2005, p. 177). Versando sobre qualquer outro tema, pode o demandante optar pelo foro do domicílio do demandado ou, havendo, pelo foro de eleição. A competência então é relativa. A ação de desapropriação indireta tem natureza real. Já se decidiu que não é de se considerar real a ação que visa a desconstituir determinado contrato ou pré-contrato, ainda que, em decorrência da procedência do pedido, resulte a reintegração do demandante na posse de determinado bem.¹⁶

Art. 48. O foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro.

Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente:

I – o foro de situação dos bens imóveis;

II – havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes;

III – não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.

1. Foro do Autor da Herança. O foro do domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Já se decidiu que a competência fixada em face do foro do autor da herança é relativa.¹⁷ Pode ser derogado, portanto, sobre eventual foro de eleição,¹⁸ não prevalecendo sobre eventual foro da coisa em ação de desapropriação¹⁹ e em ação de usucapião.²⁰

2. Foros Subsidiários. Não sendo conhecido o domicílio do autor da herança, será competente o foro da situação de qualquer dos bens imóveis ou, se não houver bem imóvel, o foro de qualquer dos bens do espólio.

Art. 49. A ação em que o ausente for réu será proposta no foro de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias.

1. Foro do Ausente. Ausência é a falta de presença de alguém em seu domicílio aliada à falta de notícias e à não constituição de representante a quem caiba administrar-lhe os bens (art. 22, do

CC). Também há ausência quando o ausente deixa mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar a exercer o mandato, ou deixa mandatário com poderes insuficientes (art. 23, do CC). A ausência tem de ser decretada judicialmente (arts. 24, do CC e 744, do CPC). O processo é de jurisdição voluntária (arts. 744 e 745, do CPC).

As ações em que o ausente for réu correm no foro de seu domicílio, que é também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Se a ação em que o ausente é demandado versar sobre direitos reais imobiliários, notadamente sobre propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, então o foro competente é o do lugar da coisa, que prevalece sobre o foro do último domicílio do ausente (art. 47, §§ 1.º e 2.º, do CPC). Se o ausente é o demandante, a ação segue as normas comuns de competência, não incidindo o art. 49, do CPC.

Art. 50. A ação em que o incapaz for réu será proposta no foro de domicílio de seu representante ou assistente.

1. Foro do Incapaz. O absolutamente e o relativamente incapaz têm domicílio necessário (art. 76, do CC), que é o de seu representante e o de seu assistente (art. 76, parágrafo único, do CC). Qualquer ação em que o incapaz figure como demandado, salvo se incidir o art. 47, §§ 1.º e 2.º, do CPC, tem de ser proposta no domicílio de seu representante ou assistente.

Art. 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União.

Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal.

1. Foro da União. O art. 51, do CPC, praticamente, repete o texto constitucional, que dispõe que “as causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte” (art. 109, § 1.º, da CRFB) e que “as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal” (art. 109, § 2.º, da CRFB).

A Justiça Federal tem competência para julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho” (art. 109, I, da CRFB). Há possibilidade de delegação de competência (art. 109, § 3.º, da CRFB).

2. Usucapião. “A presença da União ou de qualquer de seus entes, na ação de usucapião especial, não afasta a competência do foro da situação do imóvel” (Súmula 11, do STJ).

3. Justificação Judicial. “Compete à Justiça Federal processar justificações judiciais destinadas a instruir pedidos perante entidades que nela têm exclusividade de foro, ressalvada a aplicação do art. 15, II, da Lei 5.010/66” (Súmula 32, do STJ).

4. Sociedades de Economia Mista Federal. “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.” (Súmula 508, do STF). “As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal quando a União intervém como assistente ou oponente” (Súmula 517, do STF). “É competente a Justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista” (Súmula 556, do STF). “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento” (Súmula 42, do STJ).

5. FGTS. “Compete à Justiça Federal, excluídas as reclamações trabalhistas, processar e julgar os feitos relativos a movimentação do FGTS” (Súmula 82, do STJ).

6. Reintegração de servidor federal. “Compete à Justiça Federal processar e julgar o pedido de

reintegração em cargo público federal, ainda que o servidor tenha sido dispensado antes da instituição do Regime Jurídico Único” (Súmula 173, do STJ).

7. Fundação Habitacional do Exército. “Compete à Justiça Federal processar e julgar ações de que participa a Fundação Habitacional do Exército, equiparada à entidade autárquica federal, supervisionada pelo Ministério do Exército” (Súmula 324, do STJ).

8. RFFSA. “A intervenção da União como sucessora da Rede Ferroviária Federal S/A (RFFSA) desloca a competência para a Justiça Federal ainda que a sentença tenha sido proferida por Juízo estadual” (Súmula 365, do STJ).

9. Retificação de Dados Cadastrais da Justiça Eleitoral. “Compete à Justiça comum estadual processar e julgar os pedidos de retificação de dados cadastrais da Justiça Eleitoral” (Súmula 368, do STJ).

10. Seguro Marítimo. “Compete à Justiça Federal, em ambas as instâncias, o processo e o julgamento das causas fundadas em contrato de seguro marítimo” (Súmula 504, do STF).

11. COBAL e CIBRAZEM. “É competente a Justiça Federal para julgar as causas em que são partes a COBAL e a CIBRAZEM” (Súmula 557, do STF).

12. Concessionária de Telefonia e Relação de Consumo. “Compete à Justiça estadual julgar causa entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente” (Súmula Vinculante 27, do STF).

13. Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social. “A competência para processar e julgar as demandas que têm por objeto obrigações decorrentes dos contratos de planos de previdência privada firmados com a Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social – REFER é da Justiça estadual” (Súmula 505, do STJ).

14. Natureza constitucional. Porque o art. 51, do CPC, tem origem no art. 109, da CF, essa regra prevalece sobre qualquer outra do CPC, inclusive sobre o art. 47, §§ 1.º e 2.º, do CPC. Há, porém, entendimento jurisprudencial (v.g., Súmula 11, do STJ) que faz prevalecer regras infraconstitucionais sobre o preceito constitucional, o que obviamente não se pode mais admitir – é o Código de que deve ser interpretado à luz da Constituição, não o contrário (art. 1.º, do CPC).

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

1. Foro dos Estados e do Distrito Federal. As ações propostas pelo Estado ou pelo Distrito Federal devem ser ajuizadas no domicílio do réu. Já aquelas propostas em face do Estado ou do Distrito Federal podem ser ajuizadas no domicílio do autor, no local da ocorrência do ato ou fato que deu origem à demanda, no local da situação da coisa ou na capital do ente federado. A regra deve estender-se também para as autarquias e fundações públicas federais.

Art. 53. É competente o foro:

I – para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável:

a) de domicílio do guardião de filho incapaz;

b) do último domicílio do casal, caso não haja filho incapaz;

c) de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal;

II – de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos;

III – do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu;

c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica;

d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;

e) de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto;

f) da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício;

IV – do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;

b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios;

V – de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.

1. Foro do Divórcio, Separação, Anulação de Casamento e Reconhecimento ou Dissolução de União Estável. Será o do domicílio do guardião de filho incapaz, se houver. Se não houver, será do último domicílio do casal ou, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal, do domicílio do réu. “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda” (Súmula 383, do STJ).

2. Foro do Alimentando. O foro competente para ação em que se pedem alimentos é o foro do domicílio ou da residência do alimentando, ainda que cumulada com ação de investigação de paternidade (Súmula 1, do STJ). O foro competente para ação de alimentos provisionais também é o foro do domicílio ou da residência do alimentando, sendo igualmente para ação de prestação de alimentos (art. 24, Lei 5.478/1968).

Tanto as ações de alimentos fundadas em casamento, como aquelas baseadas em parentesco e em união estável atraem a incidência do art. 53, II, do CPC. As ações alimentares fundadas em ato ilícito ou devidas em face de disposição testamentária ou por convenção, no entanto, seguem as normas comuns de competência (art. 46, do CPC). Já se decidiu que se o devedor de alimentos reside no exterior cumpre à Justiça Estadual do foro do domicílio ou da residência do alimentando processar e julgar a ação de alimentos.²¹ Igualmente já se decidiu que se o alimentando for domiciliado ou residir no exterior será competente para processar e julgar a ação de alimentos a Justiça Federal (art. 109, III, da CRFB, e art. 26, Lei 5.478/968).²²

3. Foro do Lugar. É competente o foro do lugar (a) onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica, (b) onde se acha a agência, sucursal ou filial, quanto às obrigações que ela contraiu, (c) onde exerce as suas atividades, para a ação em que for ré a sociedade ou a associação sem personalidade jurídica, (d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para ações que pretendam seu cumprimento (*forum contractus*, art. 78, do CC), (e) de residência do idoso, nas causas referentes a direito previsto na Lei 10.741/2003, e (f) da serventia notarial ou de registro, para demandas que pretendam a reparação de dano por ato praticado por estas. Já se decidiu que o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita é o foro competente tanto para as ações em que se exige pagamento como para aquelas em que se questiona a existência, a validade ou a eficácia de determinado negócio jurídico ou de alguma de suas cláusulas.²³

4. Foro do Lugar do Ato ou Fato. É competente o foro do lugar do ato ou fato (a) para a ação de reparação de dano e (b) para a ação em que for réu o administrador ou gestor de negócios alheios. O art. 53, IV, *b*, do CPC, pressupõe que a ação aponte responsabilidade pessoal do administrador ou do gestor de negócios alheios.

5. Foro do Domicílio do Autor ou do Lugar do Fato. É competente o foro do domicílio do autor ou do lugar do fato para as ações que visam à reparação por dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículo, aí incluídas as aeronaves. A opção é do demandante (art. 53, V, do CPC).

Seção II

Da Modificação da Competência

1. Modificações da Competência. A conexão no direito brasileiro serve para o legislador desde logo modificar a competência para determinadas causas (por exemplo, art. 61, do CPC) e para deferir ao juiz a faculdade de reunir ações semelhantes propostas em separado (arts. 55, 56 e 57, do CPC). Em ambos os casos, modifica-se a competência pela conexão: no primeiro, derrogam-se as normas comuns de competência, modificando-as para um determinado grupo de casos à vista da conexão; no segundo, altera-se a competência fixada com a propositura da ação. Defere-se também às partes a possibilidade de derrogar em certos casos normas de competência (art. 63, do CPC).

A prevenção (arts. 58, 59 e 60, do CPC), contudo, não modifica a competência; a prevenção fixa a competência em função do elemento temporal. Rigorosamente, é assunto estranho à Seção II. A conexão não dá lugar a uma prorrogação: prorrogação há quando um juízo a princípio incompetente se torna competente.²⁴ Na conexão há dois juízes igualmente competentes, mas questões concernentes à coordenação dos julgados e à eficiência judiciária sugerem a reunião das causas conexas propostas em separado. O Código de 2015 não ouviu nesse particular as críticas da doutrina que foram endereçadas ao mesmo equívoco existente no Código de 1973.²⁵

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

1. Competências Modificáveis pela Conexão. A competência relativa pode ser modificada em razão da conexão. Há impossibilidade, contudo, de modificar-se por normas de conexão a competência absoluta.²⁶

No Código de 1973, o art. 102 referia que a “competência, em razão do valor e do território, poderá modificar-se pela conexão ou continência”. O Código de 2015 preferiu aludir ao regime da competência do que aos seus critérios, na medida em que nada obsta a que excepcionalmente o legislador atribua a determinado critério regime diverso daquele ligado à regra geral (arts. 62 e 63, do CPC).

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no *caput*:

I – à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II – às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

1. Conexão. A conexão é um nexo de semelhança entre duas ou mais causas. Ao ancorar tanto o

conceito de conexão como os conceitos de coisa julgada e litispendência à identificação da causa pelo critério da tríplice identidade (art. 337, §§ 1.º a 4.º, do CPC), nosso legislador procurou se ensartar em uma prestigiosa tradição doutrinária.²⁷

Como reconhece a doutrina, porém, o art. 55, do CPC, limita-se a conceituar apenas uma espécie de conexão – a chamada conexão própria simples objetiva.²⁸ Vale dizer: existe um campo significativo do conceito que escapa do dispositivo, ora comparecendo tipicamente em outros (como, por exemplo, nos arts. 56 e 61, do CPC), ora aparecendo atipicamente (art. 55, § 3.º, do CPC).²⁹

Isso quer dizer que persiste no direito brasileiro a possibilidade de reconhecer-se a conexão fora dos casos do *caput* do art. 55, do CPC. Já se decidiu que “a conceituação legal admite certo grau de maleabilidade no exame dos casos concretos pelo juiz, à luz do critério da utilidade da reunião dos processos como forma de evitar a coexistência de decisões judiciais inconciliáveis sob o ponto de vista prático”.³⁰

Como observa a doutrina, o “espírito que permeia todas as hipóteses de conexão é evitar provimentos contraditórios ou conflitantes em razão de as demandas reclamarem a solução de questões comuns ou idênticas”.³¹ Não por acaso, ao procurar trabalhar atipicamente o instituto da conexão, o art. 55, § 3.º, do CPC, recorre precisamente a essa razão. Nada obstante, a conexão também serve para a concretização do princípio da economia processual e, portanto, de um eficiente *case management* dos recursos estatais na condução dos processos: sempre que for possível, sem violação dos direitos fundamentais processuais de quaisquer das partes, reunir as causas propostas em separado, deverá o juiz fazê-lo a fim de aproveitar o mesmo processo para dar solução a tantas lides quanto possível.³² Com isso, haverá não só uma tendencial duração razoável do processo, mas também uma otimização dos recursos humanos voltados à solução dos processos como um todo, melhorando-se a alocação dos esforços estatais para a promoção de uma justiça mais eficiente – sem, ao mesmo tempo, que se perca de vista a necessidade de preservação de todos os direitos inerentes ao processo justo.³³

2. Classificação da Conexão. A conexão pode ser própria ou imprópria.³⁴ Há conexão própria quando há semelhança entre causas ou ações; imprópria, quando existem duas ações ou causas diferentes, mas que dependem total ou parcialmente da resolução de questões idênticas.

A conexão própria subdivide-se em simples ou qualificada. A conexão própria simples pode ser subjetiva (art. 56, do CPC) ou objetiva (art. 55, do CPC). A conexão própria pode ser qualificada por acessoriedade (art. 61, do CPC), por prejudicialidade, por reconvenção, por garantia ou por compensação. Tanto a conexão própria como a imprópria podem dar lugar à reunião dos processos (art. 55, § 3.º, do CPC).

3. Faculdade Judicial. O órgão jurisdicional não tem o dever de reunir as causas conexas. Trata-se de faculdade judicial.³⁵

4. Julgamento de uma das ações conexas. Se uma das causas conexas já foi julgada, a conexão não determina mais a reunião dos processos (art. 55, § 1.º, do CPC). “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado” (Súmula 235, do STJ).

5. Reunião de processo de execução e processo de conhecimento. O art. 55, § 2.º, I, do CPC, não deve aplicar-se ao caso do art. 785, do CPC. Nesse caso, tendo o credor título extrajudicial, mas optando por ajuizar ação de conhecimento, não é o caso de reunião de eventual processo de conhecimento e de execução. Simplesmente, o credor, tendo optado por ajuizar o processo de conhecimento, renuncia à executividade do título extrajudicial (que se transforma em simples prova da obrigação) e não tem mais o pressuposto processual hábil a iniciar o processo de execução (título com força executiva, que representa obrigação líquida, certa e exigível – art. 783, do CPC).

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

1. Continência. Continência é espécie de conexão.³⁶ Trata-se de conexão própria simples subjetiva. Para que se dê a continência entre duas ou mais ações tem de haver as mesmas partes e a mesma causa de pedir. O que difere é o pedido que, em uma delas, é mais amplo, abarcando os pedidos formulados nas outras ações. “Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça estadual” (Súmula 489, do STJ).

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

1. Reunião das Causas. Na continência, o Código optou por dar tratamento intermediário, situado entre a conexão e a litispendência. Assim, se a ação continente (mais ampla) tiver sido deduzida anteriormente, a ação seguinte (contida), porque discute as mesmas questões já apresentadas na outra causa, deve ser extinta sem resolução do mérito. Se a primeira demanda proposta é a contida (menos ampla), então se aplica o regime da conexão, devendo as causas ser reunidas perante o juiz prevento (art. 58, do CPC).

2. Obrigatoriedade. Na continência, a reunião de causas, quando cabível, é obrigatória. Excetua-se, porém, a hipótese em que uma das causas já foi julgada.

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

1. Prevenção. A prevenção fixa a competência em função de determinado elemento temporal. É critério de determinação da competência, que impõe a reunião das causas e seu julgamento conjunto.

2. Prevenção e produção antecipada de prova. A medida de produção antecipada de prova não induz prevenção para eventual ação que venha a ser posteriormente ajuizada com base na prova obtida (art. 381, § 3.º, do CPC).

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.

1. Momento da prevenção. A prevenção ocorre com o registro ou a distribuição da petição inicial (arts. 284 e ss., do CPC), pouco importando as atividades subsequentes. Ocorrendo, porém, posterior cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), torna-se ineficaz a prevenção.

2. Prevenção e Juízo Incompetente. Se o juízo é incompetente para a causa que foi ajuizada perante ele, não há fixação de prevenção. A prevenção pressupõe juízo competente.³⁷

Art. 60. Se o imóvel se achar situado em mais de um Estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel.

1. Imóvel Situado em Mais de um Estado, Comarca ou Subseção Judiciária. Para conhecer de ações referentes a imóveis situados em mais de um Estado (ainda que os limites entre os Estados sejam imprecisos),³⁸ comarca, seção ou subseção judiciária será competente o juízo do lugar em que ocorreu a distribuição ou o registro da primeira demanda (art. 59, do CPC). Uma vez fixada a competência, o órgão jurisdicional prevento não precisa expedir carta precatória para a outra comarca ou subseção judiciária para praticar atos processuais na causa, porque com a prevenção a sua competência se alarga para alcançar todo o imóvel objeto do litígio.

Art. 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal.

1. Competência e Conexão Qualificada por Acessoriedade. Se entre duas ou mais ações existe conexão qualificada por acessoriedade, a ação acessória tem de ser proposta perante o juiz competente para a ação principal. Ação acessória é aquela dependente de outra, sendo aquela que exige complementação posterior ou que é oriunda de outra ação. Os embargos de terceiro,³⁹ os embargos do executado e a ação de restauração de autos,⁴⁰ por exemplo, são ações acessórias. O mesmo se diga da ação anulatória de ato processual da parte (art. 966, § 4.º, do CPC) – trata-se de

ação oriunda de outra, na medida em que a lide anulatória surge de um ato processual praticado no processo da lide originária.

2. Competência e Conexão Qualificada por Reconvenção, Prejudicialidade, Garantia e Compensação. Embora não possam ser qualificadas, exatamente, como ações acessórias, trata-se de hipóteses em que há também conexão, que implicam reunião dos processos. O que determina a competência é a ligação – mais ou menos intensa – existente entre essas causas, a justificar o exame conjunto pelo mesmo órgão jurisdicional.

Art. 62. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes.

1. Competências Não Modificáveis pela Vontade das Partes. A competência absoluta não pode ser modificada pela vontade das partes; apenas a competência relativa pode ser modificada por essa.⁴¹

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.

§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

§ 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.

1. Forum Electionis e Forum Contractus. O foro de eleição é aquele eleito pelas partes para dirimir eventuais conflitos oriundos dos mais diversos atos da vida civil (art. 63, do CPC). Não se confunde com o foro contratual, que é o foro que os contratantes especificaram para o cumprimento do contrato (art. 78, do CC).

O Código de Processo Civil confundiu o *forum electionis* e o *forum contractus*, como se vê do teor do art. 63, § 2.º. O foro contratual serve no direito brasileiro como critério territorial de competência (art. 53, III, *d*, do CPC). Havendo foro de eleição, esse prevalece sobre o foro contratual⁴² e sobre o foro do autor da herança.⁴³ É possível a eleição de foro para o ajuizamento de ações de despejo (art. 58, II, Lei 8.245/1991).⁴⁴

2. Forma do Foro de Eleição. O foro de eleição tem de constar de cláusula escrita para que seja válido e eficaz. Pode-se prever foro de eleição para dirimir conflitos de negócios jurídicos unilaterais, bilaterais ou plurilaterais, assim como para resolver conflitos advindos de atos-fatos jurídicos ou de atos jurídicos em senso estrito. Além de cláusula escrita, o foro de eleição deve prender-se especificamente a determinado ato-fato, ato em senso estrito ou negócio jurídico para que seja válido e eficaz.

3. Transmissibilidade do Foro de Eleição. O foro de eleição é transmissível aos herdeiros e sucessores das partes, obrigando-os.

4. Nulidade da Cláusula de Eleição de Foro. Fixado foro de eleição em contrato de adesão (art. 63, do CPC), e sendo essa cláusula nula, pode o juiz decretar de ofício a sua invalidade, declinando o feito para o juízo de domicílio do réu. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é, em tese, válida e eficaz, salvo: “a) se, no momento da celebração, a parte aderente não dispunha de inteligência suficiente para compreender o sentido e as consequências da estipulação contratual; b) se da prevalência de tal estipulação resultar inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Judiciário; c) se se tratar de contrato de obrigatória adesão, assim entendido o que tenha por objeto produto ou serviço fornecido com exclusividade por determinada empresa”.⁴⁵

Além de poder o juiz agir de ofício, também o requerido pode, uma vez citado, arguir esse defeito da cláusula, na contestação. Havendo nulidade e não declinando de logo, pelo juiz, ou não tendo o requerido, depois de citado, apontado esse defeito, prorroga-se a competência (art. 63, § 4.º, do CPC), precluindo a questão.

Seção III

Da Incompetência

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

§ 2º Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

1. Incompetência Relativa. A incompetência relativa não pode ser conhecida de ofício pelo juiz (Súmula 33, do STJ). Querendo, a parte tem de arguir a incompetência relativa, em preliminar à contestação, para ver examinada a questão (arts. 64, 337, II, e 340, do CPC). Não exercida a *exceptio declinatori fori* (exceção aqui entendida como simples “defesa” e não como “forma processual de arguição da questão”), prorroga-se a competência (art. 65, do CPC).

2. Incompetência Absoluta. A incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício pelo órgão jurisdicional e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição pela parte. Já se decidiu, no entanto, que não se pode conhecer de ofício da incompetência absoluta das instâncias ordinárias em sede de recurso especial.⁴⁶

Tem o demandado de arguir a incompetência absoluta como preliminar de contestação (art. 337, II, do CPC) ou, posteriormente, por mero requerimento nos autos. A incompetência absoluta não se prorroga pela sua não arguição pela parte. Reconhecida a incompetência, tem o juiz de declinar os autos para o juízo competente (art. 64, § 1.º, do CPC).

3. Procedimento. Trata-se de simples alegação, a ser inserida na contestação, indicando-se preferencialmente o foro para o qual se pretende a remessa dos autos. Se necessário, junto com a peça contestatória deve a parte apresentar documentos capazes de demonstrar os argumentos de incompetência que aponta. No caso da incompetência absoluta, a arguição pode ser feita posteriormente, por simples requerimento.

Em qualquer caso, arguida a incompetência, deve o juiz ouvir a parte contrária, no prazo de quinze dias (art. 351, do CPC), que também pode produzir prova em sentido contrário, se for o caso. Posteriormente, deve o juiz decidir a questão, eventualmente remetendo os autos ao juízo competente.

4. Recurso. Embora o Código não indique o cabimento de agravo de instrumento quanto à decisão sobre competência – indicando que a parte deva insurgir-se sobre a questão na apelação (art. 1.009, § 1.º, do CPC) –, parece evidente que essa decisão merece ser recorrível de imediato. O risco de decisões invalidadas, ou que precisem ser substituídas (art. 64, § 3.º, do CPC) somado à gravidade das consequências da tramitação de causa perante juízo absolutamente incompetente (passível até de ação rescisória – art. 966, II, do CPC) não apenas demonstram que o rol do art. 1.015 deve ser admitir exceções, mas ainda sugere que se deva admitir agravo de instrumento contra a decisão que decide sobre a incompetência. O Superior Tribunal de Justiça, a propósito,

acertada e expressamente decidiu pela possibilidade de imediato recurso da decisão sobre a competência⁴⁷.

5. Decisões do Juízo Incompetente. São válidas, salvo decisão posterior em sentido contrário do juízo competente. O juízo competente pode ratificar a decisão do juízo incompetente, ou proferir outra em seu lugar, uma vez recebendo os autos depois da declinação da competência. Não havendo declinação da competência absoluta, porém, e transitando em julgado eventual sentença por ele proferida, sujeita-se o ato a ação rescisória (art. 966, II, do CPC).

Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.

Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar.

1. Prorrogação de Competência. Prorroga-se a competência quando um juízo inicialmente incompetente de maneira relativa se torna competente. A prorrogação pode ser legal (art. 60, do CPC) ou voluntária. Essa pode ser ainda expressa (art. 63, do CPC) ou tácita (em virtude da omissão da parte em arguir a incompetência, art. 65, do CPC, ou do juízo em conhecer de ofício a nulidade da cláusula de foro prevista em contrato de adesão, art. 63, §§ 3.º e 4.º, do CPC).

Com a prorrogação, preclui a possibilidade de alegação de incompetência relativa.⁴⁸ Apenas a competência relativa pode ser prorrogada.⁴⁹ A competência absoluta não se prorroga.

2. Legitimidade para arguir a incompetência. É da parte. Nas causas em que o Ministério Público atua, como parte ou fiscal da lei, também ele pode alegar a incompetência relativa. Os assistentes litisconsorciais também podem arguir o defeito.

Art. 66. Há conflito de competência quando:

I – 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II – 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III – entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo.

1. Conflito de Competência. Todo juiz é o primeiro juiz de sua própria competência (*Kompetenz-Kompetenz*).⁵⁰ Havendo discordância entre dois ou mais juízos a respeito da competência para determinada causa, todavia, surge a necessidade de um órgão jurisdicional superior decidir qual é o juízo competente. O incidente processual que serve para tanto é o conflito de competência.

Para que haja conflito de competência tem de haver real e efetiva discordância entre os juízes devidamente revelada nos autos.⁵¹ Não há no direito brasileiro conflito de competência em face de potencial discordância entre juízes no que concerne à competência. O conflito de competência só pode se dar entre juízos com a mesma hierarquia, podendo ocorrer conflito entre juízos de hierarquia diferente apenas quando entre eles não houver vinculação. Há vinculação, por exemplo, entre o juiz de direito do Estado do Rio Grande do Sul e o Tribunal de Justiça desse mesmo Estado. Não há vinculação entre o juiz federal da subseção judiciária de Porto Alegre e o Tribunal Regional Federal da 5.ª Região, assim como não há vinculação entre o juiz de direito do Estado do Paraná e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

O conflito pode ser positivo (art. 66, I, do CPC) ou negativo (art. 66, II, do CPC). A rigor, quando entre dois ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos (art. 66, III, do CPC), o que há é dois ou mais juízes que se “declaram competentes” (art. 66, I, do CPC) ou

que se “consideram incompetentes” (art. 66, II, do CPC), sendo absolutamente desnecessária essa previsão em separado. Já se decidiu que “não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes” (Súmula 59, do STJ), “excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito” (Súmula 224, do STJ) e que “compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas” (Súmula 150, do STJ).

2. Objeto do Conflito de Competência. No conflito de competência o órgão jurisdicional pode tão somente decidir qual dos juízos conflitantes é o juízo competente. Não lhe é dado conhecer de outras questões que não digam respeito com o incidente,⁵² sendo-lhe vedado, por exemplo, conhecer do mérito do processo.⁵³

NOTAS DE RODAPÉ

1

Adolf Wach, *Handbuch des deutschen Civilprozessrechts*, Leipzig: Duncker & Humblot, 1885, p. 347/350; Giuseppe Chiovenda, *Instituições de Direito Processual Civil*, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1969, p. 154, vol. II.

2

Linda Silberman, *Civil Litigation in Comparative Context*, St. Paul: Thomson/West, 2007, p. 529-531.

3

Fredie Didier Júnior, *Curso de Direito Processual Civil*, 18. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 207, vol. I.

4

Trata-se de divisão consagrada na doutrina: Athos Gusmão Carneiro, *Jurisdição e Competência*, 4. ed., São Paulo: Saraiva, 1991, p. 59; Patrícia Miranda Pizzol, *A Competência no Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2003, p. 249-254; Daniel Amorim, *Competência no Processo Civil*, São Paulo: Método, 2005, p. 21/54; Leonardo Carneiro da Cunha, *Jurisdição e Competência*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2013, p. 112-118.

5

STF, Pleno, Ag na SE 5.206/EP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.12.2001, *DJ* 30.04.2004, p. 29.

6

STJ, Corte Especial, SEC 866/EX, rel. Min. Félix Fischer, j. 17.05.2006, *DJ* 16.10.2006, p. 273.

7

STJ, REsp 450.881/DF, 3ª Turma, rel. Min. Castro Filho, j. 11.04.2003, *DJ* 26.05.2003, p. 360.

8

STJ, EREsp 178.233/SE, 1ª Seção, rel. Min. Luiz Fux, j. 13.08.2003, *DJ* 15.09.2003, p. 229.

9

Leonardo Carneio da Cunha, *Jurisdição e Competência*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2013, p. 131/135; Fredie Didier Júnior, *Curso de Direito Processual Civil*, 18. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 204-205, vol. I.

10

STJ, REsp 192.896/RS, 1.ª Turma, rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 22.05.2001, *DJ* 18.02.2002, p. 241.

11

STJ, CC 67.488/RS, 1.ª Seção, rel. Min. Humberto Martins, j. 13.12.2006, *DJ* 12.02.2007, p. 220.

12

STF, Pleno, RE 228.955/RS, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 10.02.2000, *DJ* 24.03.2001, p. 70.

13

STJ, CC 32.013/BA, 2ª Seção, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 15.04.2005, *DJ* 26.04.2005.

14

STJ, REsp 150.902/PR, 4.ª Turma, rel. Min. Barros Monteiro, j. 21.05.1998, *DJ* 28.09.1998, p. 65.

15

STJ, REsp 124.010/SP, 2.ª Turma, rel. Min. Adhemar Maciel, j. 04.12.1997, *DJ* 16.03.1998, p. 82.

16

STJ, REsp 19.992/SP, 4.ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 13.03.1995, *DJ* 17.04.1995, p. 9.581.

17

STJ, CC 19.334/MG, 2.ª Seção, rel. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira, j. 28.11.2001, *DJ* 25.02.2002, p. 195.

18

STJ, REsp 420.394/GO, 3.ª Turma, rel. Min. Nancy Andrichi, j. 19.02.2002, *DJ* 04.11.2002, p. 203.

19

STJ, CC 5.579/RJ, 1.^a Seção, rel. Min. Peçanha Martins, j. 23.11.1993, *DJ* 13.12.1993, p. 27.370.

20

STJ, CC 699/RS, 2.^a Seção, rel. Min. Fontes de Alencar, j. 13.12.1989, *DJ* 12.03.1990, p. 1.697.

21

STJ, CC 20.175/SP, 2.^a Seção, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 14.10.1998, *DJ* 07.12.1998, p. 38.

22

STJ, CC 13.093/RJ, 2.^a Seção, rel. Min. Costa Leite, j. 26.04.1995, *DJ* 22.05.1995, p. 14.330.

23

STJ, REsp 119.383/DF, 3.^a Turma, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 17.02.1998, *DJ* 27.04.1998, p. 154.

24

Contra, entendendo que a conexão é um caso de prorrogação legal de competência, Araken de Assis, *Processo Civil Brasileiro*, São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1.177, vol. I.

25

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 199, t. II; Ovídio Baptista da Silva, *Curso de Processo Civil*, 5. ed., São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 60, vol. I; Athos Gusmão Carneiro, *Jurisdição e Competência*, 4. ed., São Paulo: Saraiva, 1991, p. 64; José Rogério Cruz e Tucci, *A Causa Petendi no Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2001, p. 220.

26

STJ, AgRg no CC 43.922/RS, 1.^a Seção, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 25.08.2004, *DJ* 13.09.2004, p. 166.

27

Matteo Pescatore, *Sposizione Compendiosa della Procedura Civile e Criminale nelle Somme sue Ragioni e nel suo Ordine Complemento sui Temi Principali di Tutto il Diritto Giudiziario*, Torino: UTET, 1864, p. 168, vol. I, t. I; Giuseppe Chiovenda, *Instituições de Direito Processual Civil*, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1969, p. 216-221, vol. II; Piero Calamandrei, *Istituzioni di Diritto Processuale Civile, Opere Giuridiche*, Napoli: Morano Editore, 1970, p. 142-149, vol. IV; Enrico Tullio Liebman, *Manual de Direito Processual Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 196-199, vol. I; José Carlos Barbosa Moreira, *A Conexão de Causas como Pressuposto da Reconvenção*, São Paulo: Saraiva, 1979, p. 123 e ss.; Paulo Lucon, *Relação entre Demandas*, Brasília: Gazeta Jurídica, 2016, p. 80 e ss.

28

Paulo Lucon, *Relação entre Demandas*, Brasília: Gazeta Jurídica, 2016, p. 83.

29

A positivação de uma espécie de regra aberta a respeito da conexão deve-se à doutrina de José Carlos Barbosa Moreira, *A Conexão de Causas como Pressuposto da Reconvenção*, São Paulo: Saraiva, 1979, p. 125.

30

STJ, REsp 594.748/RS, 1ª Turma, rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.08.2006, *DJ* 31.08.2006, p. 201.

31

Paulo Lucon, *Relação entre Demandas*, Brasília: Gazeta Jurídica, 2016, p. 83-84.

32

Amplamente, Bruno Silveira de Oliveira, *Conexidade e Efetividade Processual*, São Paulo: Ed. RT, 2007.

33

Amplamente, Remo Caponi, *Il Principio di Proporzionalità nella Giustizia Civile: Prime Note Sistematiche*, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, Milano: Giuffrè, 2011; Sérgio Cruz Arenhart, *A Tutela Coletiva de Interesses Individuais*, São Paulo: Ed. RT, 2013.

34

Trata-se de clássica classificação, José Carlos Barbosa Moreira, *A Conexão de Causas como Pressuposto da Reconvenção*, São Paulo: Saraiva, 1979, p. 123.

35

STJ, REsp 305.835/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 03.10.2002, *DJ* 11.11.2002, p. 245; contra, Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 11. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 347, vol. I; Antônio Dall'agnol, *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 36, vol. II.

36

Paulo Lucon, *Relação entre Demandas*, Brasília: Gazeta Jurídica, 2016, p. 89.

37

STJ, CC 133.426/DF, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, *DJe* 17.11.2014.

38

STJ, CC 39.766/BA, 2ª Seção, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 25.08.2004, *DJ* 06.10.2004, p. 171.

39

STJ, CC 55.630/SP, 1.ª Seção, rel. Min. Eliana Calmon, j. 22.03.2006, *DJ* 29.05.2006, p. 148.

40

STJ, CC 19.229/MG, 2.ª Seção, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 09.03.2005, *DJ* 21.03.2005, p. 211.

41

STJ, REsp 255.076/MG, 3.ª Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 15.12.2000, *DJ* 12.03.2001, p. 142.

42

STJ, REsp 379.949/PR, 4.ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 26.02.2002, *DJ* 15.04.2002, p. 230.

43

STJ, REsp 420.394/GO, 3.ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.09.2002, *DJ* 04.11.2002, p. 203.

44

STJ, REsp 200.459/SP, 5.ª Turma, rel. Min. Gilson Dipp, j. 23.11.1999, *DJ* 13.12.1999, p. 171.

45

STJ, REsp 379.949/PR, 4.ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 26.02.2002, *DJ* 15.04.2002, p. 230.

46

STJ, REsp 155.482/AL, 5.ª Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 16.03.2000, *DJ* 02.05.2000, p. 156.

47

STJ, 4ª Turma, REsp 1.679.909/RS, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 14.11.2017, *DJe* 01.02.2018. Contra, STJ, 2ª Turma, REsp 1.700.308/PB, rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.2018, *DJe* 23.05.2018. A questão hoje se encontra afetada à Corte Especial do STJ (Proposta de Afetação no REsp 1.704.520/MT, rel. Min. Nancy Andrighi).

48

STJ, REsp 485.536/PR, 2.ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.08.2006, *DJ* 18.08.2006, p. 370.

49

STJ, CC 15.297/SC, 2.^a Seção, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 13.12.1995, *DJ* 26.02.1996, p. 3.915.

50

Rosenberg, Schwab e Gottwald, *Zivilprozessrecht*, 17. ed., München: 2010, p. 55.

51

STJ, CC 77.818/RJ, 3.^a Seção, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 25.04.2007, *DJ* 14.05.2007, p. 247.

52

STJ, CC 50.560/SP, 1.^a Seção, rel. Min. Eliana Calmon, j. 23.08.2006, *DJ* 11.09.2006, p. 215.

53

STJ, CC 34.536/CE, 1.^a Seção, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 08.05.2002, *DJ* 17.06.2002, p. 183.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. I - Marinoni - Ed. 2018

CAPÍTULO II - DA COOPERAÇÃO NACIONAL

Art. 67. Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, por meio de seus magistrados e servidores.

1. Dever de Cooperação. Os órgãos jurisdicionais têm o dever de cooperação recíproca, para a condução de atos jurisdicionais. Esse dever se estende inclusive a tribunais superiores que, em que pese sua hierarquia, também devem cooperar com outras instâncias para fins jurisdicionais. O dever é imposto a todo Poder Judiciário, inclusive entre ramos diferentes, da Justiça estadual e federal.

2. Cooperação e Arbitragem. A cooperação jurisdicional também abrange pedidos de juízos arbitrais (art. 69, § 1.º, do CPC), embora nesse caso a cooperação não inibe o controle, pelo Poder Judiciário, da legitimidade do pedido de colaboração formulado.

Art. 68. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para prática de qualquer ato processual.

1. Cooperação e Atos Processuais. O pedido de cooperação nacional entre juízos pode ser utilizado para a prática de qualquer ato jurisdicional.

Art. 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como:

I – auxílio direto;

II – reunião ou apensamento de processos;

III – prestação de informações;

IV – atos concertados entre os juízes cooperantes.

§ 1º As cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código.

§ 2º Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para:

I – a prática de citação, intimação ou notificação de ato;

II – a obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos;

III – a efetivação de tutela provisória;

IV – a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas;

V – a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial;

VI – a centralização de processos repetitivos;

VII – a execução de decisão jurisdicional.

§ 3º O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário.

1. Cooperação e Forma. O pedido de cooperação entre órgãos do Poder Judiciário não exige forma específica. Pode e a princípio deve tramitar por via eletrônica (arts. 193, 232, 236, § 3.º e 264, do CPC).

2. Cooperação Judicial e Solicitação de Tribunal Arbitral. Se o tribunal arbitral necessitar da intervenção judicial para a prática de determinado ato (arts. 22, 22-A e 22-B, Lei 9.307/1996), também pode solicitar, por qualquer meio, a colaboração. Esse pedido, porém, não impede que o Judiciário aprecie a legitimidade do pedido de colaboração e, se for o caso, reaprecie os requisitos para a outorga da medida jurisdicional buscada. Afinal, o Judiciário detém a exclusividade da jurisdição, e não pode ficar incondicionalmente sujeito às deliberações arbitrais. Na jurisprudência, porém, a opinião prevalente é outra, no sentido de que cabe somente à esfera arbitral a decisão dos pressupostos para a prática do ato, devendo o Judiciário limitar-se a cumprir o decidido pelo juízo arbitral.¹

3. Atos Concertados. Atos concertados implicam o prévio ajuste, entre juízes, para a prática de atos que interessam a vários processos. Podem consistir em qualquer ato, não estando limitados àqueles indicados nos incs. I a VII, do art. 69, § 2.º, do CPC. Não se pode, porém, delegar atividades que possuam caráter decisório, sob pena de violação do princípio do juiz natural (art. 5.º, XXXVII e LIII, da CF).

NOTAS DE RODAPÉ

1

STJ, AgRg no CC 116.395/RO, 2.ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, *DJe* 17.06.2013.

© desta edição [2018]

Referências Bibliográficas

AARNIO, Aulis. *The Rational as Reasonable – A Treatise on Legal Justification*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1987.

ABDO, Helena. *Mídia e processo*. São Paulo: Saraiva, 2011.

ABREU, Leonardo Santana de. *Direito, ação e tutela jurisdicional*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.

ABREU, Rafael. *Igualdade e processo – posições processuais equilibradas e unidade do direito*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

ALEIXO, Pedro Scherer de Mello. O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva na ordem jurídica brasileira – a caminho de um “Devido Processo Proporcional”. In: MONTEIRO, António Pinto; NEUNER, Jörg; SARLET, Ingo (coord.). *Direitos fundamentais e direito privado – uma Perspectiva de Direito Comparado*. Coimbra: Almedina, 2007.

ALEXY, Robert. *Theorie der juristischen Argumentation*. Frankfurt im Main: Suhrkamp, 1983.

_____. *Theorie der Grundrechte*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1985.

ALISTE SANTOS, Tomás-Javier. *La Motivación de las Resoluciones Judiciales*. Madrid: Marcial Pons, 2011.

ALMEIDA, Estevam de. O Direito processual civil brasileiro em face da Constituição – Arts. 34, n. 23, 35 e 65, n. 2. *Revista dos Tribunais*. n. 26. São Paulo: Ed. RT, 1918.

ALMEIDA COSTA, Mario Júlio. *História do direito português*. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1992.

_____. Fundamentos históricos do direito brasileiro, *Estudos de direito civil brasileiro e português* (I Jornada Luso-Brasileira de Direito Civil). São Paulo: Ed. RT, 1980.

ALPA, Guido. *Trattato di Diritto Civile – Storia, Fonti, Interpretazione*. Milano: Giuffrè, 2000. vol. I.

ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. *Do formalismo no processo civil*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

_____. _____. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

_____. *Teoria e prática da tutela jurisdicional*. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

_____. O Juiz e o princípio do contraditório. *Revista de Processo*. n. 71. São Paulo: Ed. RT, 1993.

_____. A garantia do contraditório. *Do formalismo no processo civil*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

_____. O Processo civil na perspectiva dos direitos fundamentais. *Do formalismo no processo*

civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

_____. Poderes do juiz e visão cooperativa do processo. *Revista da Ajuris*. n. 90. Porto Alegre, 2003.

_____. Os direitos fundamentais à efetividade e à segurança em perspectiva dinâmica. *Revista Forense*. vol. 395. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

_____. Procedimento e ideologia no direito brasileiro atual. *Ajuris*. n. 33. Porto Alegre, 1985.

_____. Efetividade e tutela jurisdicional, *Revista da Ajuris*. n. 98. Porto Alegre, 2005.

_____. O problema da eficácia da sentença. *Revista de Direito Processual Civil*. n. 29. Curitiba: Gênese, 2003.

_____. (coord.). *A nova execução*. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

_____. (coord.). *A nova execução de títulos extrajudiciais*. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

_____; MITIDIERO, Daniel. *Curso de processo civil*. São Paulo: Atlas, 2010, vol. I.

ALVES, Francisco Glauber Pessoa. *O princípio jurídico da igualdade e o processo civil brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2003.

AMARAL, Francisco. *Direito civil – introdução*. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

AMARAL, Guilherme Rizzo. *Comentários às alterações do Novo CPC*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

_____. Estudos de direito intertemporal e processo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

_____. A polêmica em torno da ação de direito material. *Revista de Direito Processual Civil*. vol. 33. Curitiba, Genesis, 2004.

ANDOLINA, Italo. *“Cognizione” ed “Esecuzione Forzata” nel Sistema della Tutela Giurisdizionale*. Milano: Giuffrè, 1983.

_____; VIGNERA, Giuseppe. *Il Modello Costituzionale del Processo Civile Italiano*. Torino: Giappichelli, 1997.

APRIGLIANO, Ricardo. *Ordem pública e processo*. São Paulo: Atlas, 2011.

ARAÚJO, Fábio Caldas de. *Curso de processo civil*. São Paulo: Malheiros, 2016. t. I.

ARENHART, Sérgio Cruz. *Tutela inibitória da vida privada*. São Paulo: Ed. RT, 2000.

_____. *Perfis da tutela inibitória coletiva*. São Paulo: Ed. RT, 2003.

_____. *A tutela coletiva de interesses individuais*. São Paulo: Ed. RT, 2013.

_____. A prisão civil como meio coercitivo. In: TESHEINER, José; MILHORANZA, Mariângela Guerreiro; PORTO, Sérgio Gilberto (coord.). *Instrumentos de coerção e outros temas de direito processual civil – estudos em homenagem aos 25 anos de docência do Professor Dr. Araken de Assis*. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

_____; MARINONI, Luiz Guilherme. *Curso de processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2008. vol. IV.

_____; _____. *Prova*. São Paulo: Ed. RT, 2009.

_____; _____. MITIDIERO, Daniel. *Novo curso de processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015. vol. I.

_____; _____. _____. São Paulo: Ed. RT, 2015, vol. II.

- ____; ____; _____. _____. São Paulo: Ed. RT, 2015, vol. III.
- ____; ____; _____. *Novo Código de Processo Civil comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- ARGÜELLES, Juan Ramón de Páramo; ROIG, Francisco Javier Ansuátegui. Los derechos en la Revolución Inglesa. *Historia de los derechos fundamentales*. Transito a la modernidad: siglos XVI y XVII. Madrid: Dykinson, 2003. t. 1.
- ARMELIN, Donaldo. Legitimidade para agir no Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Ed. RT, 1979.
- _____. Competência internacional. *Revista de Processo*. n. 2. São Paulo: Ed. RT, 1976.
- ARONNE, Ricardo. Sistema jurídico e unidade axiológica: os contornos metodológicos do Direito Civil-Constitucional, *Direito civil-constitucional e teoria do caos* – Estudos preliminares. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.
- ARRUDA, Samuel Miranda. *O direito fundamental à razoável duração do processo*. Brasília: Brasília Jurídica, 2006.
- ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito civil* – teoria geral. 2. ed. Coimbra: Coimbra, 2003, vol. II.
- ASSIS, Araken de. *Processo Civil Brasileiro*. São Paulo: Ed. RT, 2015, vol. I.
- ATTARDI, Aldo. *L' Interesse ad Agire*. Padova: Cedam, 1955.
- AUSTIN, John. *The Uses of the Study of Jurisprudence, The Province of Jurisprudence Determined and The Uses of the Study of Jurisprudence*. Indianapolis: Hackett, 1998.
- ÁVILA, Humberto. *Teoria dos princípios*. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.
- _____. *Teoria da igualdade tributária*. São Paulo: Malheiros, 2008.
- _____. *Segurança jurídica*. São Paulo: Malheiros, 2011.
- _____. O que é devido processo legal? *Revista de Processo*. n. 163. São Paulo: Ed. RT, 2008.
- _____. *Teoria Giuridica dell' Argomentazione, Analisi e Diritto*. Madrid: Marcial Pons, 2012.
- AZEVEDO, Luiz Carlos; CRUZ E TUCCI, José Rogério. *Lições de história do processo civil romano*. 1. ed. 2. tir. São Paulo: Ed. RT, 2001.
- BAHIA, Alexandre; THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; PEDRON, Flávio. *Novo CPC – Fundamentos e sistematização*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.
- BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. *Jurisdição e execução na tradição romano-canônica*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1997.
- _____. *Processo e ideologia* – o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
- _____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2000, vol. I.
- _____. *Procedimentos especiais* – exegese do Código de Processo Civil (arts. 890 a 981). Rio de Janeiro: Aide Editora, 1993.
- _____. *Curso de processo civil*. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2000, vol. I.
- _____. _____. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2000, vol. II.
- _____. _____. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2000, vol. III.

- BARBERIS, Mauro. *Manuale di Filosofia del Diritto*. Torino: Giappichelli, 2011.
- BARBI, Celso Agrícola. *A ação declaratória no processo civil brasileiro*. 2. ed. Belo Horizonte: Livraria Oscar Nicolai, 1962.
- _____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I.
- BARBOSA MOREIRA, José Carlos. *Ação declaratória e interesse, Direito processual civil*. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971.
- _____. As bases do direito processual civil, In: _____. *Temas de direito processual*. São Paulo: Saraiva, 1977.
- _____. Legitimação para agir. Indeferimento da petição inicial, In: _____. *Temas de direito processual*. São Paulo: Saraiva, 1977.
- _____. Os Códigos de Processo Civil de 1973 e de 1939: contrastes e confrontos, *Estudos sobre o Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1974.
- _____. *A conexão de causas como pressuposto da reconvenção*. São Paulo: Saraiva, 1979.
- _____. Tutela sancionatória e tutela preventiva. In: _____. *Temas de direito processual – Segunda Série*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988.
- _____. A motivação das decisões judiciais como garantia inerente ao estado de direito. In: _____. *Temas de direito processual – Segunda Série*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988.
- _____. A garantia do contraditório na atividade de instrução. In: _____. *Temas de direito processual – Terceira Série*. São Paulo: Saraiva, 1984.
- _____. O problema da “divisão do trabalho” entre juiz e partes: aspectos terminológicos. In: _____. *Temas de direito processual – Quarta Série*. São Paulo: Saraiva, 1989.
- _____. O Código Civil e o direito processual. In: _____. *Temas de direito processual – Nona Série*. São Paulo: Saraiva, 2007.
- BARREIROS, Lorena Miranda. *Fundamentos constitucionais do princípio da cooperação processual*. Salvador: JusPodivm, 2013.
- BARROSO, Luís Roberto. *Curso de direito constitucional contemporâneo*. São Paulo: Saraiva, 2009.
- _____. *Interpretação e aplicação da Constituição*. São Paulo: Saraiva, 1996.
- BARSOTTI, Vittoria. *L’Arte di Tacere – Strumenti e Tecniche di non Decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti*. Torino: Giappichelli, 1999.
- BAUMGÄRTEL, Gottfried. Treu und Glauben im Zivilprozess. *Zeitschrift für Zivilprozess*. n. 86. Köln: Carl Heymanns, 1973.
- BEDAQUE, José Roberto dos Santos. *Direito e processo – Influência do direito material sobre o processo*. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2009.
- BENTHAM, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Oxford University Press, 1996.
- BEVILÁQUA, Clóvis. *Teoria geral do direito civil*. 2. ed. rev. e atual. por Caio Mário da Silva Pereira. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1976.
- BIAVATI, Paolo; CARPI, Federico Carpi. *Diritto processuale comunitario*. 2. ed. Milano: Giuffrè,

2000.

BÖCKENFÖRD, Ernst-Wolfgang. *Stato, Costituzione, Democrazia* – Studi di Teoria della Costituzione e di Diritto Costituzionale. a cura di Michele Nicoletti e Omar Brino. Milano: Giuffrè, 2006.

BOMSDORF, Falk. *Prozeßmaximen und Rechtswirklichkeit* – Verhandlungs- und Untersuchungsmaxime im deutschen Zivilprozeß – Vom gemeinen Recht bis zur ZPO. Berlin: Duncker & Humblot, 1971.

BONAVIDES, Paulo. *Curso de direito constitucional*. São Paulo: Malheiros, 1993.

BONICIO, Marcelo. *Princípios do processo no Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2016.

BOURSIER, Marie-Emma. *Le Principe de Loyauté en Droit Processuel*. Paris: Dalloz, 2003.

BOVE, Mauro. Art. 111 Cost. e “giusto processo civile”. *Rivista di Diritto Processuale*. vol. 57.

BRANCO, Gerson. *Função social dos contratos*. São Paulo: Saraiva, 2009.

BRIEGLEB, Hans Karl. *Eileitung in die Theorie der summarischen Processe*. Leipzig: Bernhard Tauchitz, 1859 (Frankfurt: Ferdinand Keip, 1969).

BRINZ, Alois. *Lehrbuch der Pandekten*. 2. ed. Erlangen: Andreas Deichert, 1873. vol. 1.

BRÜGGEMANN, Jürgen. *Die richterliche Begründungspflicht*. Berlin: Duncker & Humblot, 1971.

BUENO, Cássio Scarpinella. *Curso sistematizado de direito processual civil*. São Paulo: Saraiva, 2007. vol. I.

_____. In: BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2017, vol. I.

BULYGIN, Eugenio. Los Jueces Crean Derecho? *XII Seminario Eduardo García Maynez sobre Teoria e Filosofia del Derecho*. Mexico: UNAM.

BUZUID, Alfredo. Prefácio às instituições de direito processual civil de Chiovenda. *Grandes processualistas*. São Paulo: Saraiva, 1982.

_____. A influência de Liebman no direito processual civil brasileiro. *Grandes Processualistas*. São Paulo: Saraiva, 1982.

_____. *A ação declaratória no direito brasileiro*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986.

CABRAL, Antonio do Passo. *Convenções processuais*. Salvador: JusPodivm, 2016.

_____. *Coisa julgada e preclusões dinâmicas* – Entre continuidade, mudança e transição de posições processuais estáveis. Salvador: JusPodivm, 2013.

_____. *Nulidades no processo moderno*. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

_____. O contraditório como dever e a boa-fé processual objetiva. *Revista de Processo*. n. 126. São Paulo: Ed. RT, 2005.

_____. Il Principio del Contraddittorio come Diritto d’Influenza e Dovero di Dibattito, *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 2005.

CABRAL, Trícia Navarro Xavier. *Poderes instrutórios do juiz no processo de conhecimento*. Brasília: Gazeta Jurídica, 2012.

- CADIET, Loïc. *Avenir des Catégories, Catégories de l'Avenir: Perspectives. Common Law, Civil Law and the Future of Categories*. Markham: LexisNexis, 2010.
- _____; JEULAND, Emmanuel. *Droit Judiciaire Privé, 4. Ed.*. Paris: LITEC, 2004.
- _____; NORMAND, Jacques; MEKKI, Soraya Amrani. *Théorie Générale du Procès*. Paris: PUF, 2010.
- CAETANO, Marcello. *História do direito português (1140-1495)*. 2. ed. Lisboa: Editorial Verbo, 1985.
- CAIANIELLO, Vincenzo. Riflessioni sull'art. 111 della Costituzione. *Rivista di Diritto Processuale*, 2001.
- CALAMANDREI, Piero. *Introduzione allo Studio Sistematico dei Provvedimenti Cautelari*. Padova: Cedam, 1936.
- _____. Istituzioni di Diritto Processuale Civile secondo il Nuovo Codice. In: CAPPELLETTI, Mauro (coord.). *Opere Giuridiche*. Napoli: Morano Editore, 1970. vol. IV.
- _____. Gli studi di diritto processuale in Italia nell'ultimo trentennio. *Opere giuridiche*. Napoli: Morano, 1965. vol. 1.
- _____. *La condanna*. In: CAPPELLETTI, Mauro (org.). *Opere giuridiche*. Napoli: Morano, 1972. vol. V.
- _____. Verità e Verosimiglianza nel Processo Civile. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1955.
- CALVÃO DA SILVA, João. *Cumprimento e sanção pecuniária compulsória*. Coimbra: Coimbra Editora, 1997.
- CAMPOS, Eduardo Luiz Cavalcanti. *O Princípio da Eficiência no Processo Civil Brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2018.
- CANARIS, Claus-Wilhelm. *Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz*. 2. ed. Berlin: Duncker & Humblot, 1983.
- _____. *Direitos fundamentais e direito privado*. Coimbra: Almedina, 2003.
- CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito constitucional e teoria da Constituição*. 3. ed. Coimbra: Almedina, 1999.
- CAPONI, Remo. Autonomia Privata e Processo Civile: gli Accordi Processuali. *Accordi di Parte e Processo*. Milano: Giuffrè, 2008.
- _____. Il Principio di Proporzionalità nella Giustizia Civile: Prime Note Sistematiche. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 2011.
- CAPPELLETTI, Mauro. *La Testimonianza della Parte nel Sistema dell'Oralità*. Milano: Giuffrè, 1962. vol. I.
- _____. Diritto di Azione e di Difesa e Funzione Concretizzatrice della Giurisprudenza Costituzionale (art. 24 Costituzione e "Due Process of Law Clause"). *Processo e Ideologie*. Bologna: Il Mulino, 1969.
- _____. Repudiando Montesquieu? A expansão e a legitimidade da "justiça constitucional". *Revista da Faculdade de Direito da UFRGS*. vol. 20.
- _____; VIGORITI, Vincenzo. Le Garanzie Costituzionali delle Parti nel Processo Civile Italiano.

Giustizia e società. Milano: Edizioni di Comunità, 1972.

CARNACINI, Tito. Tutela Giurisdizionale e Tecnica del Processo. *Studi in Onore di Enrico Redenti nel XL Anno del suo Insegnamento*. Milano: Giuffrè, 1951. vol. II.

CARNEIRO, Athos Gusmão. *Jurisdição e competência*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1991.

CARNELUTTI, Francisco. *Diritto e Processo*. Napoli: Morano Editore, 1958.

_____. Scuola italiana del processo. *Rivista di Diritto Processuale*, 1947.

_____. Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni. *Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda*. Padova: Cedam, 1927.

_____. *Lezioni di diritto processuale civile*. Padova: Cedam, 1931. vol. 2.

_____. *Lite e Processo, Studi di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1939. vol. III.

CARPES, Artur. *Ônus dinâmico da prova*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

CARPI, Federico; BIAVATI, Paolo. *Diritto processuale comunitario*. 2. ed. Milano, Giuffrè, 2000.

CASTANHEIRA NEVES, Antonio. *Metodologia jurídica – problemas fundamentais*. Coimbra: Coimbra Editora, 1993.

CASTRO, Torquato. *Ação declaratória*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1942.

CECCHERINI, Grazia. *Risarcimento del danno e riparazione in forma specifica*. Milano: Giuffrè, 1989.

CHEMERINSKY, Erwin. *Constitutional Law – Principles and Policies*. 3. ed. New York: Aspen Publishers, 2006.

CHIARLONI, Sergio. Il nuovo art. 111 Cost. e il processo civile. *Rivista di Diritto Processuale*. 2000.

CHIASSONI, Pierluigi. *Tecnica dell' Interpretazione Giuridica*. Bologna: Il Mulino, 2007.

_____. *L' Indirizzo Analitico nella Filosofia del Diritto*. Torino: Giappichelli, 2009.

CHIAVARIO, Mauro. *Processo e garanzie della persona*. Milano: Giuffrè, 1982. vol. 2.

CHIOVENDA, Giuseppe. *Instituições de direito processual civil*. Trad. J. Guimarães Menegale, notas de Enrico Tullio Liebman e prefácio de Alfredo Buzaid. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1969. vol. I.

_____. _____. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1969. vol. II.

_____. _____. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1969. vol. III.

_____. Dell' Azione Nascente del Contratto Preliminare. *Saggi di Diritto Processuale Civile* (1894-1937). Milano: Giuffrè, 1993. vol. I.

_____. Lodovico Mortara. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1937.

_____. L'azione nel sistema dei diritti (1903). *Saggi di diritto processuale civile*. Roma: Foro Italiano, 1930.

_____. Le forme nella difesa giudiziale del diritto. *Saggi di diritto processuale civile*. Milano: Giuffrè, 1901 (reed. 1993).

COING, Helmut. *Grundzüge der Rechtsphilosophie*. 5. ed. Berlin: De Gruyter, 1993.

- COLESANTI, Vittorio. Lodovico Mortara e le riforme processuali. La prima fase (1901-1912). *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1997.
- COMOGLIO, Luigi Paolo. *Etica e Tecnica del “Giusto Processo”*. Torino: Giappichelli, 2004.
- _____. *La Garanzia dell’ Azione ed il Processo Civile*. Padova: Cedam, 1970.
- _____. Principi Costituzionale e Processo di Esecuzione. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1994.
- _____. Note Riepilogative su Azione e Forme di Tutela, nell’ Ottica della Domanda Giudiziale. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1993.
- CONNORS, Jordan Wilder. *Treating like subdecisions alike: the scope of stare decisis as applied to judicial methodology*. *Columbia Law Review*. n. 3. vol. 108. 2008.
- CORDEIRO, Antonio Menezes. *Tratado de direito civil português*. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2007. vol. I, t. I.
- _____. *Da boa fé no direito civil*. Coimbra: Almedina, 2001.
- COSTA E SILVA, Paula. *A nova face da justiça – os meios extrajudiciais de resolução de controvérsias*. Coimbra: Coimbra Editora, 2009.
- _____. *A litigância de má fé*. Coimbra: Coimbra Editora, 2008.
- _____. *Acto e processo*. Coimbra: Coimbra Editora, 2003.
- COUTO E SILVA, Clóvis do. *A obrigação como processo*. São Paulo: José Bushatsky Editor, 1976.
- _____. O direito civil brasileiro em perspectiva histórica e visão de futuro. In: FRADERA, Vera (org.). *O direito privado brasileiro na visão de Clóvis do Couto e Silva*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.
- COUTURE, Eduardo. Las Garantías Constitucionales del Proceso Civil. *Estudios de Derecho Procesal Civil*. Buenos Aires: Ediar, 1948. t. I.
- _____. *Fundamentos del derecho procesal civil*. 17. reimp. da 3. ed. (1958). Buenos Aires: Depalma, 1993.
- CRUZ E TUCCI, José Rogério. *Tempo e processo*. São Paulo: Ed. RT, 1997.
- _____. *A motivação da sentença no processo civil*. São Paulo: Saraiva, 1987.
- _____. *A Causa Petendi no processo civil*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2001.
- _____; AZEVEDO, Luiz Carlos. *Lições de história do processo civil romano*. 1. ed. 2. tir. São Paulo: Ed. RT, 2001.
- _____; LAURIA TUCCI, Rogério. *Constituição de 1988 e processo – regramentos e garantias constitucionais do processo*. São Paulo: Saraiva, 1989.
- CUNHA, Leonardo Carneiro da. *A atendibilidade dos fatos supervenientes no Processo Civil*. Coimbra: Almedina, 2012.
- _____. *Direito intertemporal e o Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2016.
- _____. *Interesse de agir na ação declaratória*. Curitiba: Juruá, 2002.
- _____. *Jurisdição e competência*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2013.

- DALL'AGNOL, Antonio. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2000. vol. II.
- DALMOTTO, Eugenio. Diritto alla Equa Riparazione per l'Eccessiva Durata del Processo. In: CHIARLONI, Sergio (coord.). *Misure Acceleratorie e Riparatorie contro l'Irragionevole Durata dei Processi*. Torino: Giappichelli, 2002.
- DAMASKA, Mirjan. *The Faces of Justice and State Authority – A Comparative Approach to the Legal Process*. New Haven: Yale University Press, 1986.
- DEGENKOLB, Heinrich. Einlassungszwang und Urteilsnorm. *Beiträge zur materiellen Theorie der Klagen, insbesondere der Anerkennungsklagen*. Leipzig: Druck und Verlag von Breitkopf und Härtel, 1877.
- DEL CLARO, Roberto. Devido processo legal substancial? In: MARINONI, Luiz Guilherme (coord.). *Estudos de direito processual civil – homenagem ao Professor Egas Dirceu Moniz de Aragão*. São Paulo: Ed. RT, 2005.
- DELFINO, Lúcio; ROSSI, Fernando. Juiz contraditor? *Revista Brasileira de Direito Processual*. Belo Horizonte: Fórum, 2013. n. 82.
- DENTI, Vittorio. *La Giustizia Civile*. 2. ed. Bologna: Il Mulino, 2004.
- _____. Sistematica e Post-sistematica nell'Evoluzione delle Dottrine del Processo Civile. *Sistemi e Riforme – Studi sulla Giustizia Civile*. Bologna: Il Mulino, 1990.
- _____. Il Processo di Cognizione nella Storia delle Riforme, *Sistemi e Riforme – Studi sulla Giustizia Civile*. Bologna: Il Mulino, 1999.
- _____. Diritti della persona e tecniche di tutela. In: BESSONE, M.; BONESCH, L.; CAIAZZA, G. (coord.). *L'informazione e i diritti della persona*. Napoli: Jovene, 1983.
- _____. "Intervento", Atti del XV Convegno Nazionale, Bari, 4-5 ottobre 1985. *La tutela d'urgenza*. Rimini: Maggioli Editore, 1985.
- DERNBURG, Heinrich. *Pandekten*. 2. ed. Berlin, 1888 (reed. Aalen: Scientia-Verlag, 1984). vol. 1.
- DI MAJO, Adolfo. Forme e tecniche di tutela. *Processo e tecniche di attuazione dei diritti*. Napoli: Jovene, 1989. vol. 1.
- _____. *La tutela civile dei diritti*. Milano: Giuffrè, 1993.
- DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. *Processo Constitucional e Estado Democrático de Direito*, 4. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2018.
- DICIOTTI, Enrico. *Interpretazione della Legge e Discorso Razionale*. Torino: Giappichelli, 1999.
- DIDIER JR., Fredie. *Curso de direito processual civil*. 12. ed. Salvador: JusPodivm, 2010. vol. I.
- _____. *Fundamentos do princípio da cooperação no direito processual civil português*. Coimbra: Coimbra Editora, 2010.
- _____. Os três modelos de direito processual: inquisitivo, dispositivo e cooperativo. *Revista de Processo*. n. 198. São Paulo: Ed. RT, 2011.
- _____. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- DINAMARCO, Cândido Rangel. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2018, vol. I.

- _____. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro e a ordem processual vigente. *Revista de Processo*. n. 247. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- _____. A formação do moderno processo civil brasileiro (uma homenagem a Enrico Tullio Liebman). *Fundamentos do processo civil moderno*. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. t. I.
- _____. O princípio do contraditório e sua dupla destinação. *Fundamentos do Processo Civil Moderno*. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. t. I.
- _____. *Instituições de direito processual civil*. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. v. I.
- _____. *A instrumentalidade do processo*. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
- _____. Tutela jurisdicional. *Revista de Processo*. vol. 81. São Paulo: Ed. RT, 1996.
- DINAMARCO, Pedro da Silva. *Ação civil pública*. São Paulo: Saraiva, 2001.
- DOMIT, Otávio. *Iura Novit Curia e causa de pedir*. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- DUARTE, Ronnie Preuss. *Garantia de acesso à justiça – os direitos processuais fundamentais*. Coimbra: Coimbra Editora, 2007.
- DWORKIN, Ronald. *Taking Rights Seriously*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1978.
- _____. *Law's Empire*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1986.
- EICHENBERGER, Kurt. *Die richterliche Unabhängigkeit als staatsrechtliches Problem*. Berna: Stämpfli, 1960.
- EISENBERG, Melvin. *The Nature of the Common Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1991.
- EKELÖF, Per Olof. Beweiswürdigung, Beweislast und Beweis des ersten Anscheins. *Zeitschrift für Zivilprozess*. n. 75. Köln: Carl Heymanns, 1962.
- ELY, John Hart. *Democracy and Distrust*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1980.
- ENGISCH, Karl. *Einführung in das juristische Denken*. 11. ed. Stuttgart: Kohlhammer, 2010.
- FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. *A ação declaratória incidental*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995.
- FACCHINI NETO, Eugênio. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do direito privado. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). *Constituição, direitos fundamentais e direito privado*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003.
- FALLON, Richard. Implementing the constitution. *Harvard Law Review*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1997.
- FALZEA, Angelo. *Introduzione alle Scienze Giuridiche – Il Concetto di Diritto*. 5. ed. Milano: Giuffrè, 1996.
- FAZZALARI, Elio. La Dottrina Processualistica Italiana: dall' "Azione" al "Processo" (1864-1994). *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1994.
- _____. Lodovico Mortara nella cultura processualistica italiana. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1997.
- _____. *Note in Tema di Diritto e Processo*. Milano: Giuffrè, 1957.
- FERRAJOLI, Luigi. *Principia Iuris – Teoria del Diritto e della Democrazia*. Roma: Laterza, 2007. v. I.

- FERRAND, Frédérique. *Le Principe Contradictoire et l'Expertise en Droit Comparé Européen. Revue Internationale de Droit Comparé*. Paris: Société de Législation Comparée, 2000.
- FERREIRA, Rony. *Coisa julgada nas ações coletivas*. Porto Alegre: Fabris, 2004.
- FERREIRA DA SILVA, Jorge Cesa. *Adimplemento e extinção das obrigações*. São Paulo: Ed. RT, 2007.
- FERRER BELTRÁN, Jordi. *La Valoración Racional de la Prueba*. Madrid: Marcial Pons, 2008.
- FINZI, Enrico. *Questioni Controverse in Tema di Esecuzione Provvisoria. Rivista di Diritto Processuale Civile*. Padova: Cedam, 1926.
- FISS, Owen. *The Forms of Justice. Harvard Law Review*. n. 93. Cambridge: Harvard University Press, 1979.
- _____. *Objectivity and interpretation. Stanford Law Review*. v. 34. Stanford: Stanford University Press, 1982.
- _____. *Um novo processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2004.
- FLACH, Daisson. *A verossimilhança no processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2009.
- FRANCO, Marcelo Veiga. *Processo justo*. Belo Horizonte: Del Rey, 2016.
- FRANK, Jerome. *Courts on Trial – Myth and Reality in American Justice*. Princeton: Princeton University Press, 1973.
- FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. *Condições da ação – Enfoque sobre o interesse de agir no processo civil brasileiro*. São Paulo: Ed. RT, 2000.
- FREITAS, José Lebre de. *Introdução ao processo civil*. Coimbra: Coimbra Editora, 1996.
- FRIGNANI, Aldo. *L'Injunction nella Common Law e l'Inibitoria nel Diritto Italiano*. Milano: Giuffrè, 1974.
- FULLER, Lon. *The morality of law*. 2. ed. New Haven: Yale University Press, 1969.
- GARGARELLA, Roberto. *Crisis de la Representación Política*. México: BEFDP, 1997.
- _____. *Las Teorías de la Justicia después de Rawls*. Barcelona: Paidós, 1999.
- GENOVESE, Andrea. *Contributo allo Studio del Danno da Irragionevole Durata del Processo*. Milano: Giuffrè, 2012.
- GIANNINI, Amedeo. *Gli studi di diritto processuale civile in Italia. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milano: Giuffrè, 1949*.
- GIDI, Antônio. *Coisa julgada e litispendência em ações coletivas*. São Paulo: Saraiva, 1995.
- GIL-ROBLES, Álvaro. *Los Nuevos Límites de la Tutela Judicial Efectiva*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1996.
- GIULIANI, Alessandro. *Il Concetto di Prova – Contributto alla Logica Giuridica*. Milano: Giuffrè, 1971.
- _____. *L'Ordo Judiciarius Medioevale – Riflessioni su un Modello Puro di Ordine Isonomico. Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1988.
- _____; PICARDI, Nicola. *La Responsabilità del Giudice*. Milano: Giuffrè, 1995.

- GOLDSCHMIDT, James. *Der Prozess als Rechtslage*. Berlin: Springer, 1925.
- GOMES, Orlando. *Raízes históricas e sociológicas do código civil brasileiro*. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- _____. *Obrigações*. Rio de Janeiro: Forense, 1992.
- GOMES DA SILVA, Nuno Espinosa. *História do direito português*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1985.
- GÖNNER, Nikolaus Thaddäus. *Handbuch des deutschen gemeinen Prozesses*. Erlangen: Palm, 1801. v. I.
- GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. *El Derecho a la Tutela Jurisdiccional*. 2. ed. Madrid: Civitas, 1989.
- GOODHARDT, Arthur. Legal Procedure and Democracy. *Cambridge Law Journal*. 1964.
- GOTTWALD, Peter; ROSENBERG, Leo; SCHWAB, Karl Heinz. *Zivilprozessrecht*. 17. ed. München: C. H. Beck, 2010.
- GRASSI, Lúcio. Cognição processual civil: atividade dialética e cooperação intersubjetiva na busca da verdade real. *Revista Dialética de Direito Processual*. n. 6. São Paulo: Dialética, 2003.
- _____. A função legitimadora do princípio da cooperação intersubjetiva no processo civil brasileiro. *Revista de Processo*. n. 172. São Paulo: Ed. RT, 2009.
- GRASSO, Eduardo. La Collaborazione nel Processo Civile. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1966.
- _____. La Dottrina del Processo Civile alla Fine del Secolo. *Rivista di Diritto Civile*. Padova: Cedam, 1997.
- GRAU, Eros. Por que tenho medo dos juízes (a interpretação/aplicação do direito e os princípios). 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.
- GRECO, Leonardo. *Jurisdição voluntária moderna*. São Paulo: Dialética, 2003.
- GREGER, Reinhard. Kooperation als Prozessmaxime. In: GOTTWALD, Peter; _____. PRÜTTING, Hans (coord.). *Dogmatische Grundfragen des Zivilprozess im geeinten Europa*. Bielefeld: Gieseking, 2000.
- _____. Cooperação como princípio processual. Trad. Ronaldo Kochem, revisão de Daniel Mitidiero. *Revista de Processo*. n. 206. São Paulo: Ed. RT, 2012.
- GRINOVER, Ada Pellegrini. *Ação declaratória incidental*. São Paulo: Ed. RT, 1972.
- _____. *As garantias constitucionais do direito de ação*. São Paulo: Ed. RT, 1973.
- _____. *Os princípios constitucionais e o Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 1975.
- _____. Ações coletivas para a defesa do ambiente e dos consumidores: a Lei 7.347, de 20.07.1985. *Novas tendências do direito processual*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990.
- GROSSI, Paolo. *L'Ordine Giuridico Medievale*. 3. ed. Roma: Laterza, 2007.
- GUASTINI, Riccardo. *Teoria e Dogmatica delle Fonti*. Milano: Giuffrè, 1998.
- _____. *Interpretare e Argomentare*. Milano: Giuffrè, 2011.
- _____. *Lezioni di Teoria del Diritto e dello Stato*. Torino: Giappichelli, 2006.

- GUEDES, Jefferson Carús. *Igualdade e desigualdade*. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- GUERRA, Marcelo Lima. *Execução indireta*. São Paulo: Ed. RT, 1999.
- _____. *Direitos fundamentais e a proteção do credor na execução civil*. São Paulo: Ed. RT, 2003.
- GUIMARÃES, Luís Machado. *Do Interêsse à Simples Declaração. Estudos de direito processual civil*. Rio de Janeiro: Editora Jurídica e Universitária, 1969.
- GUINCHARD, Serge. *Droit Processuel – Droit Commun et Droit Comparé du Procès Équitable*. 4. ed. Paris: Dalloz, 2007.
- HÄBERLE, Peter. *Die Wesengehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz*. 3. ed. Heidelberg: Müller, 1983.
- HACKL, Karl; KASER, Max. *Das römische Zivilprozessrecht*. 2. ed. München: C. H. Beck, 1996.
- HAHN, Bernhard. *Kooperationsmaxime im Zivilprozess?* Köln: Carl Heymanns, 1983.
- HART, Herbert. *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1993.
- HAZARD JR., Geoffrey C.; TARUFFO, Michele. *American civil procedure*. New Haven: Yale University Press, 1993.
- _____; JAMES JR., Fleming; LEUBSDORF, John. *Civil procedure*. 2. ed. Boston: Little, Brown & Co., 1992.
- HENNING, Fernando. *Ação concreta – relendo Wach e Chiovenda*. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2000.
- HESS, Burkhard. *Europäisches Zivilprozessrecht*. Heidelberg: C.F. Müller, 2010.
- HESSE, Konrad. *Elementos de direito constitucional da República Federal da Alemanha*. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1998.
- HO, Moon-Hyuck. *Zum Anspruchsbegriff der Feststellungsklage*. Pfaffenweiler: Centaurus, 1987.
- HOFFMAN, Paulo. *Razoável duração do processo*. São Paulo: Quartier Latin, 2006.
- HOHFELD, Wesley N. *Fundamental legal conceptions as applied to judicial reasoning*. Westport: Greenwood Press, 1978.
- HÖLDER, Eduard. Über Ansprüche und Einreden. *AcP*, Tübingen, Mohr Siebeck, v. 93, 1960.
- HOLMES JR., Oliver Wendell. *The Common Law*. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1963.
- HORN, Norbert. *Einführung in die Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie*. 5. ed. Heidelberg: C. F. Müller, 2011.
- HOROVITZ, Joseph. *Law and Logic*. Wien: Springer, 1972.
- HULSEBOSCH, Daniel. Writs to rights: “navigability” and the transformation of the common law in the nineteenth century. *Cardozo Law Review*. v. 23. New York: Cardozo Law School, 2002.
- IGARTUA SALAVERRÍA, Juan. *La Motivación de las Sentencias, Imperativo Constitucional*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003.
- INVREA, Francesco. Interesse e Azione. *Rivista di Diritto Processuale Civile*. Padova: Cedam, 1928.

- IRTI, Natalino. *L'Etat della Decodificazione*. 4. ed. Milano: Giuffrè, 1999.
- _____. *Codice Civile e Società Politica*. 7. ed. Roma: Laterza, 2005.
- JAKOBS, Horst Heinrich; SCHUBERT, Werner. *Die Beratung des BGB*, AT. Berlin: Keip, 1985. 2 v.
- JAMES JR., Fleming; HAZARD JR., Geoffrey C.; LEUBSDORF, John. *Civil procedure*. 2. ed. Boston: Little, Brown & Co., 1992.
- JATAHY, Vera Maria Barrera. *Do conflito de jurisdições*. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
- JEULAND, Emmanuel; CADIET, Loïc. *Droit Judiciaire Privé*. 4. ed. Paris: Litec, 2004.
- JIMÉNEZ CAMPO, Javier. *Derechos Fundamentales – Concepto y Garantías*. Madrid: Trotta, 1999.
- JOBIM, Marco. *Direito à duração razoável do processo: responsabilidade civil do estado em decorrência da intempestividade processual*. São Paulo: Conceito, 2011.
- _____. *Medidas estruturantes*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.
- _____. *As Funções da Eficiência no Processo Civil Brasileiro*. São Paulo: Ed. RT, 2018.
- JOLOWICZ, J. A. The Role of the Supreme Court at the National and International Level. In: YESSIOU-FALTSI, Pelayia (coord.). *The Role of the Supreme Courts at the National and International Level – Reports for the Thessaloniki International Colloquium*. Thessaloniki: Sakkoulas Publications, 1998.
- KASER, Max; KNÜTEL, Rolf. *Römisches Privatrecht*. 19. ed. München: C.H. Beck, 2008.
- _____; HACKL, Karl. *Das römische Zivilprozessrecht*. 2. ed. München: C. H. Beck, 1996.
- KELSEN, Hans. *Teoria pura do direito*. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1994.
- _____. *Jurisdição constitucional*. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- KIRCHHOF, Paul. Die Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts in Zeiten des Umbruchs. *NJW*. München: Beck, 1996.
- KNIJNIK, Danilo. *A prova nos juízos cível, penal e tributário*. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
- KNÜTEL, Rolf; KASER, Max. *Römisches Privatrecht*. 19. ed. München: C.H. Beck, 2008.
- KOCH, Harald. Prozessführung bei komplexen Verfahren in Europa. In: STORME, Marcel (coord.). *Procedural laws in Europe*. Appeldoorn: Maklu, 2003.
- KOCHEM, Ronaldo. Introdução às raízes históricas do princípio da cooperação (*Kooperationsmaxime*). *Revista de Processo*. n. 251. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- KOLLMANN, A. *Begriffs- und Problemgeschichte des Verhältnisses von formellem und materiellem Recht*. Berlin: Dunckner & Humboldt, 1996.
- KOSCHAKER, Paul. *Europa y el Derecho Romano*. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955.
- KROPFENGER, Inge. Zum Rechtsschutzbereich der Rüge gemäß § 321 a ZPO. *ZZP*. vol. 116. Köln: Heymanns, 2003.
- KUGLER, Klaus. *Die Kooperationsmaxime – Richtermacht und Parteienherrschaft im Zivilprozess – der gemeinsame Weg zum richtigen Prozessergebnis*. Linz: Johannes-Kepler-Universität, 2002.

- KYMLICKA, Will. *Multicultural Citizenship*. A liberal theory of minority rights. Oxford: Clarendon Press, 1995.
- LACERDA, Galeno. *O novo direito processual civil e os feitos pendentes*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
- LANES, Júlio. *Fato e direito no processo civil cooperativo*. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- LAURIA TUCCI, Rogério; CRUZ E TUCCI, José Rogério. *Constituição de 1988 e processo – regramentos e garantias constitucionais do processo*. São Paulo: Saraiva, 1989.
- LEONARD, Rolf. Der Anspruchsbegriff des Entwurfs eines bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche Reich. ZZZP. vol. 15. Köln: Heymanns, 1954.
- LEUBSDORF, John; HAZARD JR., Geoffrey C.; JAMES JR., Fleming. *Civil procedure*. 2. ed. Boston: Little, Brown & Co., 1992.
- LIEBMAN, Enrico Tullio. Diritto Costituzionale e Processo Civile. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1952.
- _____. Il Nuovo “Codigo de Processo Civil” Brasileiro. *Problemi del Processo Civile*. Napoli: Morano Editore, 1962.
- _____. Istituti del Diritto Comune nel Processo Civile Brasileiro. *Problemi del Processo Civile*. Napoli: Morano Editore, 1962.
- _____. O despacho saneador e o julgamento do mérito. *Estudos sobre o processo civil brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 1947.
- _____. Concepto de la acción civil. *Revista del Centro de Estudiantes de Derecho*. Montevideo: Universidad de la República, 1940.
- _____. L’Azione nella Teoria del Processo Civile. *Problemi del Processo Civile*. Napoli: Morano Editore, 1962.
- _____. La Sentenza come Titolo Esecutivo. *Problemi del Processo Civile*. Napoli: Morano Editore, 1962.
- _____. Unità del Procedimento Cautelare. *Problemi del Processo Civile*. Napoli: Morano Editore, 1962.
- _____. Il titolo esecutivo riguardo ai terzi. *Rivista di Diritto Processuale Civile*. Padova: Cedam, 1934.
- _____. *Manual de direito processual civil*. 3. ed. Tradução e notas de Cândido Rangel Dinamarco. São Paulo: Malheiros, 2005. v. I, p. 200.
- _____. _____. Tradução e notas de Cândido Rangel Dinamarco. Rio de Janeiro: Forense, 1984. v. I.
- _____. Execução e Ação Executiva. *Estudos sobre o processo civil brasileiro*. Notas de Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: José Bushatsky Editor, 1976.
- _____. *Processo de execução*. São Paulo: Saraiva, 1968.
- _____. _____. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1963.
- _____. *Embargos do executado* (oposições de mérito ao processo de execução). Tradução de J. Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1952.
- _____. *Opposizioni di merito nel processo di esecuzione*. Roma, 1936.

- LOBO DA COSTA, Moacir. *Breve notícia histórica do direito processual civil brasileiro e de sua literatura*. São Paulo: Ed. RT, 1970.
- LOCKE, John. *Ensaio sobre a verdadeira origem, extensão e fim do governo civil*. Lisboa: Edições 70, 1999.
- LOPES DA COSTA, Alfredo Araújo. *A Administração Pública e a ordem jurídica privada*. Belo Horizonte, 1961.
- LUCCA, Rodrigo Ramina de. *O dever de motivação das decisões judiciais*. Salvador: JusPodivm, 2015.
- LUCENA, João Paulo. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2000. v. XV.
- LUCON, Paulo. *Relação entre demandas*. Brasília: Gazeta Jurídica, 2016.
- LÜKE, Wolfgang. *Zivilprozessrecht*. 9. ed. München: C. H. Beck, 2006.
- MACCORMICK, Neil. *Institutions of Law – An Essay in Legal Theory*. Oxford: Oxford Press University, 2008.
- _____. *Rhetoric and the Rule of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- _____. *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press, 1978.
- _____. Rights in legislation. In: HACKER, Peter M. S.; RAZ, Joseph (ed.). *Law, morality and society: essays in honor of H. L. A. Hart*. Oxford: Clarendon Press, 1977.
- _____; SUMMERS, Robert. *Interpreting Statutes – A Comparative Study*. Dartmouth: Ashgate, 1991.
- _____; _____. *Interpreting Precedents – A Comparative Study*. Dartmouth: Ashgate, 1997.
- MACEDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi. *Ônus da prova e sua dinamização*. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016.
- MACHADO, Fábio Cardoso. Sobre o escopo jurídico do processo: o problema da tutela dos direitos. *Revista de Direito Processual Civil*. Curitiba: Genesis, 2004. vol. 32.
- MALTZ, Earl. The nature of precedent. *North Carolina Law Review*. 1988.
- MANDRIOLI, Crisanto. *L'Azione Esecutiva – Contributo alla Teoria Unitaria dell'Azione e del Processo*. Milano: Giuffrè, 1955.
- _____. L'esecuzione specifica dell'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1975.
- MARANHÃO, Clayton. *Tutela jurisdicional do direito à saúde*. São Paulo: Ed. RT, 2003.
- MARANHÃO, Juliano. *Positivismo jurídico lógico-inclusivo*. São Paulo: Marcial Pons, 2012.
- MARINONI, Luiz Guilherme. *Tutela cautelar e tutela antecipatória*. São Paulo: Ed. RT, 1992.
- _____. *Novas linhas do processo civil*. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2010.
- _____. *Tutela específica*. São Paulo: Ed. RT, 2000.
- _____. *Tutela inibitória*. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.
- _____. *Técnica processual e tutela dos direitos*. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2013.

- _____. *Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata da sentença*. São Paulo: Ed. RT, 1996.
- _____. *Tutela antecipatória e julgamento antecipado – parte incontroversa da demanda*. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2002.
- _____. *Antecipação da tutela*. 11. ed. São Paulo: Ed. RT, 2009.
- _____. *Abuso de defesa e parte incontroversa da demanda*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.
- _____. *Curso de processo civil*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2008. vol. I.
- _____. O direito à efetividade da tutela jurisdicional na perspectiva da teoria dos direitos fundamentais. *Gênesis Revista de Direito Processual Civil*. n. 28. Curitiba: Gênesis, 2003.
- _____. Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nella prospettiva della teoria dei diritti fondamentali. *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*. Milano: Giuffrè, 2005. vol. 1.
- _____. La efectividad de los derechos y la necesidad de un nuevo proceso civil. *Libro de ponencias del II Congreso Internacional de Derecho Procesal*. Lima: Universidad de Lima, 2002.
- _____. Tutela inhibitoria: la tutela de prevención del ilícito. *Revista de Derecho Procesal (Argentina)*. n. 3. 1999.
- _____. La prueba en la acción inhibitoria. *La prueba – Homenaje al maestro Hernando Devis Echandía*. Bogotá: Universidad Libre, 2003.
- _____. *Coisa julgada inconstitucional*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2011.
- _____; ARENHART, Sérgio Cruz. *Curso de processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2008. vol. IV.
- _____; _____. *Prova*. São Paulo: Ed. RT, 2009.
- _____; MITIDIERO, Daniel. *O projeto do CPC – crítica e propostas*. São Paulo: Ed. RT, 2010.
- _____; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. *Novo curso de processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015. vol. I.
- _____; _____. São Paulo: Ed. RT, 2015. vol. II.
- _____; _____. São Paulo: Ed. RT, 2015. vol. III.
- _____; _____. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- _____; SARLET, Ingo; MITIDIERO, Daniel. *Curso de direito constitucional*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- MARQUES, José Frederico. *Ensaio sobre a jurisdição voluntária* (1952). 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1959.
- MARTÍN PERROT, Pablo. Inconstitucionalidad, legalidad y orden jurídico. *Revista Discusiones*. ano 2. n. 2. 2001.
- MARTINETTO, Giuseppe. Contraddittorio (Principio del). *Novissimo digesto italiano*. Torino: UTET. v. 4.
- MARTINS-COSTA, Judith. *A boa-fé no direito privado*. São Paulo: Ed. RT, 2000.
- _____. O Novo Código Civil Brasileiro: em busca da “Ética da Situação”. *Diretrizes teóricas do Novo Código Civil Brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 2002. em coautoria com Gerson Branco.

- _____. *Comentários ao Novo Código Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2003. vol. V, t. II.
- MATTIROLLO, Luigi. *Trattato di Diritto Giudiziario Civile Italiano*. 4. ed. Torino: Fratelli Bocca Editori, 1892. vol. I.
- MATTOS, Sérgio. *Devido processo legal e proteção de direitos*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
- _____. *Da iniciativa probatória do juiz no processo civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
- MAURER, Hartmut. *Direito processual estatal-jurídico. Contributos para o direito do estado*. Trad. Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
- MAZZAMUTO, Salvatore. *L'attuazione degli obblighi di fare*. Napoli: Jovene, 1978.
- MEKKI, Soraya Amrani; CADIET, Loïc; NORMAND, Jacques. *Théorie Générale du Procès*. Paris: PUF, 2010.
- MELLO, Cláudio. Verdade moral e método jurídico na teoria constitucional de Ronald Dworkin. In: STORCK, Alfredo; LISBOA, Wladimir (coord.). *Normatividade & argumentação – ensaios de filosofia política e do direito*. Porto Alegre: Linus Editores, 2013.
- MENDES, Aluísio Gonçalves de Castro. *Ações coletivas*. São Paulo: Ed. RT, 2002.
- MICHELMAN, Frank. Constitutional authorship. In: ALEXANDER, Larry (ed.). *Constitutionalism: philosophical foundations*. New York: Cambridge University Press, 1998.
- MERRYMAN, John Henry; PÉREZ-PERDOMO, Rogelio. *The civil law tradition: an introduction to the legal systems of Europe and Latin American*. Stanford: Stanford University Press, 2007.
- MICHELON JR., Cláudio. Princípios e coerência na argumentação jurídica. In: MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto; BARBIERI, Catarina Helena Cortada (coord.). *Direito e interpretação – racionalidades e instituições*. São Paulo: Saraiva, 2011.
- MILLAR, Robert Wyness. *The Formative Principles of Civil Procedure. A History of Continental Civil Procedure*. Boston: Little, Brown & Company, 1927.
- MIRANDA, Jorge. *Manual de direito constitucional*. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2000. t. IV.
- MITIDIERO, Daniel. *Precedentes – da persuasão à vinculação*. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- _____. *Cortes superiores e cortes supremas – do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- _____. *Colaboração no processo civil – pressupostos sociais, lógicos e éticos*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- _____. *Antecipação da tutela – da tutela cautelar à técnica antecipatória*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- _____. *Elementos para uma teoria contemporânea do processo civil brasileiro*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
- _____. *Processo civil e Estado Constitucional*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
- _____. O processualismo e a formação do Código Buzaid. *Revista de Processo*. n. 183. São Paulo: Ed. RT, 2010.
- _____. Fundamentação e precedente – dois discursos a partir da decisão judicial. *Revista de Processo*. n. 206. São Paulo: Ed. RT, 2012.

_____. Por uma reforma da justiça civil no Brasil – um diálogo entre Mauro Cappelletti, Vittorio Denti, Ovídio Baptista e Luiz Guilherme Marinoni. *Revista de Processo*. n. 199. São Paulo: Ed. RT, 2011.

_____. A tutela dos direitos como fim do processo civil no Estado Constitucional. *Revista de Processo*. n. 229. São Paulo: Ed. RT, 2014.

_____. Polêmica sobre a teoria dualista da ação. *Revista de Direito Processual Civil*. vol. 34. Curitiba: Genesis, 2004.

_____; OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. *Curso de processo civil*. São Paulo: Atlas, 2010. vol. I.

_____; MARINONI, Luiz Guilherme. *O projeto do CPC – crítica e propostas*. São Paulo: Ed. RT, 2010.

_____; TARUFFO, Michele. *A Justiça Civil – da Itália ao Brasil, dos Setecentos a Hoje*. São Paulo: Ed. RT, 2018.

_____; _____. ARENHART, Sérgio Cruz. *Novo curso de processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015. vol. I.

_____; _____. São Paulo: Ed. RT, 2015. vol. II.

_____; _____. São Paulo: Ed. RT, 2015. vol. III.

_____; _____. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

_____; SARLET, Ingo; MARINONI, Luiz Guilherme. *Curso de direito constitucional*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.

MITIDIERO, Nei Pires. *Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

MONTESQUIEU, Charles-Louis Secondat (Barão de). *De L'Esprit des Lois*. Paris: Garnier, 1869.

MORO, Sérgio. *Jurisdição constitucional como democracia*. São Paulo: Ed. RT, 2004.

MORTARA, Lodovico. *Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile*. Milano: Vallardi, 1923.

_____. Milano: Giuffrè, 1923. v. 2.

_____. *Manuale della procedura civile*. Torino: Torinese, 1921.

MOTTA, Cristina. *A motivação das decisões cíveis*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.

MOTTA, Otávio. *Justificação da decisão judicial – a elaboração da motivação e a formação de precedente*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

MÜLLER, Hanns F. Abhilfemöglichkeiten bei der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach der ZPO-Reform. *NJW*. München: Beck, 2002.

MUSSET ITURRASPE, Jorge. *Responsabilidad por daños*. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 1988.

MUTHER, Theodor. Sobre la doctrina de la *actio romana*, del derecho de accionar actual, de la *litiscontestatio* y de la sucesión singular en las obligaciones. *Polémica sobre la actio*. Buenos Aires: Ejea, 1974.

_____. *Zur Lehre von der Römischen Actio, dem heutigen Klagrecht, der Litiscontestatio und der Singularsuccession in Obligationen – Eine Kritik des Windscheid'schen Buchs: Die Actio des römischen Civilrechts, vom Standpunkte des heutigen Rechts*. Erlangen: Andreas Deichert, 1857.

- NERY JUNIOR, Nelson. *Princípios do processo civil na Constituição Federal*. São Paulo: Ed. RT, 1992.
- _____. *Princípios do processo na Constituição Federal*. 9. ed. São Paulo: Ed. RT, 2009.
- NEVES, Celso. *A estrutura fundamental do processo civil*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997.
- NEVES, Daniel Amorim Assumpção. *Competência no processo civil*. São Paulo: Método, 2005.
- NIEVA FENOLL, Jordi. *La Valoración Racional de la Prueba*. Madrid: Marcial Pons, 2010.
- NOBILI, Massimo. *Il Principio del Libero Convincimento*. Milano: Giuffrè, 1974.
- NOJIRI, Sérgio. *O dever de fundamentar as decisões judiciais*. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2000.
- NORMAND, Jacques; CADIET, Loïc; MEKKI, Soraya Amrani. *Théorie Générale du Procès*. Paris: PUF, 2010.
- NÖRR, Knut Wolfgang. *Zur Stellung des Richters im gelehrten Prozeß der Frühzeit: Iudex secundum allegata non secundum conscientiam iudicat*. München: C. H. Beck, 1967.
- _____. Zum Historischen Schule im Zivilprozeß- und Aktionenrecht. *Iudicium est Actus Trium Personarum* – Beiträge zur Geschichte des Zivilprozeßrechts in Europa. Goldbach: Keip Verlag, 1993.
- NUNES, Dierle. *Processo jurisdicional democrático*. Curitiba: Juruá, 2008.
- _____; THEODORO JÚNIOR, Humberto; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. *Novo CPC – fundamentos e sistematização*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.
- OLIVEIRA, Bruno Silveira de. *Conexidade e efetividade processual*. São Paulo: Ed. RT, 2007.
- PACHECO, José da Silva. *Evolução do processo civil brasileiro*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.
- PATTI, Salvatore. *Prove – Disposizioni Generali*. Bologna: Zanichelli, 1987.
- PAULA RAMOS, Vitor de. *Ônus da prova no processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- PECZENIK, Aleksander. *On Law and Reason*. Dordrecht: Springer, 2009.
- PEDRON, Flávio; THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre. *Novo CPC – fundamentos e sistematização*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.
- PEIXOTO, Ravi; MACEDO, Lucas Buril de. *Ônus da prova e sua dinamização*. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016.
- PEREIRA, Luiz Fernando. *Tutela jurisdicional da propriedade intelectual*. São Paulo: Ed. RT, 2006.
- PEREIRA, Paula Pessoa. *Legitimidade dos precedentes – universabilidade das decisões do STJ*. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. *Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución*. 9. ed. Madrid: Tecnos, 2005.
- PÉREZ RAGONE, Álvaro. ¿Necesitamos los procesos colectivos? En torno a la justificación y legitimidad jurídica de la tutela de intereses multisubjetivos. *Procesos colectivos*. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 2005.
- _____. Prolegómenos de los amparos colectivos – Tutela de las incumbencias multisubjetivas. Parte general. *Revista de Derecho Procesal*. n. 4. vol. 1. Buenos Aires: Rubinzal Culzoni, 2001.

- _____. El nuevo proceso civil alemán: principios y modificaciones al sistema recursivo. *Revista de Direito Processual Civil*. vol. 32. Curitiba: Genesis.
- PÉREZ-PERDOMO, Rogelio; MERRYMAN, John Henry. *The civil law tradition: an introduction to the legal systems of Europe and Latin American*. Stanford: Stanford University Press, 2007.
- PESCATORE, Matteo. *Sposizione Compendiosa della Procedura Civile e Criminale nelle Somme sue Ragioni e nel suo Ordine Complemento sui Temi Principali di Tutto il Diritto Giudiziario*. Torino: UTET, 1864. vol. I. t. I.
- PETER, Hans. *Actio und Writ – Eine vergleichende Darstellung römischen und englischer Rechtsbehelfe*. Tübingen: Mohr, 1957.
- PICARDI, Nicola. Processo Civile: c) Diritto Moderno. *Enciclopedia del Diritto*. Milano: Giuffrè, 1987. vol. XXXVI.
- _____. “Audiatur et Altera Pars” – Le Matrici Storico-Culturali del Contraddittorio. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 2003.
- _____. La Vocazione del Nostro Tempo per la Giurisdizione. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 2004.
- _____; GIULIANI, Alessandro. *La Responsabilità del Giudice*. Milano: Giuffrè, 1995.
- PICÓ I JUNOY, Joan. *El Juez y la Prueba*. Barcelona: Bosch, 2007.
- PISANELLI, Giuseppe. *Commentario del Codice di Procedura Civile per gli Stati Sardi con la Comparazione degli altri Codici Italiani, e delle Principali Legislazioni Straniere*. Torino: Società Editrice, 1855. vol. I.
- PIZZOL, Patrícia Miranda. *A competência no processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2003.
- PLÓSZ, Alexander. *Beiträge zur Theorie des Klagerechts*. Leipzig: Duncker & Humblot, 1880.
- POLLOCK, Frederick. *The Expansion of the Common Law*. London: Stevens and Sons, 1904.
- PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Fontes e evolução do direito civil brasileiro*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1981.
- _____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. t. I.
- _____. _____. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. t. II.
- _____. _____. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. t. III.
- _____. _____. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. t. V.
- _____. _____. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. t. XIII.
- _____. _____. Rio de Janeiro: Forense, 1977. t. XVI.
- _____. _____. 2. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1959. t. V.
- _____. *Tratado de direito privado*. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1970. t. I.
- _____. _____. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. t. XXVI.
- _____. *Tratado das ações*. São Paulo: Ed. RT, 1970. t. I.
- _____. _____. São Paulo: Ed. RT, 1971. t. II.

- POSTEMA, Gerald. *Bentham and the Common Law Tradition*. Oxford: Oxford University Press, 1986.
- PRIETRO CASTRO Y FERRANDIZ, Leonardo. *La Acción Declarativa*. Madrid: Editorial Réus, 1932.
- PROTO PISANI, Andrea. Sulla Tutela Giurisdizionale Differenziata. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1979.
- _____. Appunti sulla Tutela Cautelare. *Rivista di Diritto Civile*. Padova: Cedam, 1987.
- _____. Giusto Processo e Valore della Cognizione Piena. *Rivista di Diritto Civile*. Padova: Cedam, 2002.
- _____. *Lezioni di Diritto Processuale Civile*. 4. ed. Napoli: Jovene, 2002.
- _____. “Intervento”, Atti del XV Convegno Nazionale, Bari, 4-5 ottobre 1985. *La tutela d'urgenza*. Rimini: Maggioli Editore, 1985.
- PUGLIESE, Giovanni. *Actio e Diritto Subiettivo*. Napoli: Jovene Editore, 2006.
- _____. *Istituzioni di Diritto Romano*, com a colaboração de Francesco Sitzia e Letizia Vacca. 3. ed. Torino: Giappichelli, 1991.
- RAPISARDA, Cristina. *Profili della Tutela Civile Inibitoria*. Padova: Cedam, 1987.
- _____. Premesse allo studio della tutela civile preventiva. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1980.
- RASSELLI, Alessandro. Sentenze determinative e classificazione delle sentenze. *Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti*. Padova: Cedam, 1950. vol. 2.
- RAWLS, John. *Uma teoria da justiça*. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- _____. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 1993.
- RAZ, Joseph. *The morality of freedom*. Oxford: Clarendon Press, 1986.
- REALE, Miguel. Significação histórica do Código Civil Francês. *Código Napoleão – Biblioteca de Legislação Estrangeira*, sob a coordenação de Souza Diniz. São Paulo: Record, 1962.
- _____. *História do Novo Código Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2005.
- REICHEL, Luís Alberto. *A prova no direito processual civil*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
- RIBA TREPAT, Cristina. *La eficacia temporal del proceso – El juicio sin dilaciones indebidas*. Barcelona: Bosch, 1997.
- RIBEIRO, Darcí. *La Pretensión Procesal y la Tutela Judicial Efectiva*. Barcelona: Bosch, 2004.
- _____. In: BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2017, vol. I.
- ROIG, Francisco Javier Ansuátegui; ARGÜELLES, Juan Ramón de Páramo. Los derechos en la Revolución Inglesa. *Historia de los derechos fundamentales*. Transito a la modernidad: siglos XVI y XVII. Madrid: Dykinson, 2003. t. 1.
- ROMANO, Santi. L' Ordinamento Giuridico. *L' Ultimo Santi Romano*. Milano: Giuffrè, 2013.
- _____. Principii di Diritto Costituzionale Generale. *L' Ultimo Santi Romano*. Milano: Giuffrè, 2013.

- ROSENBERG, Leo; SCHWAB, Karl Heinz; GOTTWALD, Peter. *Zivilprozessrecht*. 17. ed. München: C. H. Beck, 2010.
- ROSITO, Francisco. *Direito probatório – as máximas de experiência em juízo*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.
- ROSSI, Fernando; DELFINO, Lúcio. Juiz contraditor? *Revista Brasileira de Direito Processual*. n. 82. Belo Horizonte: Fórum, 2013.
- RUBINO, Gabriella. L'Accademia dei Lincei celebra Lodovico Mortara. *Rivista di Diritto Processuale*. Milano: Cedam, 1997.
- SANNA, Cecilia. *La Durata Ragionevole dei Processi nel Dialogo tra Giudici Italiani ed Europei*. Milano: Giuffrè, 2008.
- SANTIAGO NINO, Carlos. El Concepto de Validez Jurídica en la Teoría de Kelsen. *La Validez del Derecho*. Buenos Aires: Astrea, 1985.
- _____. *Ética y derechos humanos*. 2. ed. Buenos Aires: Astrea, 1989.
- SANTOS, Igor Raatz dos. Processo, igualdade e colaboração: os deveres de esclarecimento, prevenção, consulta e auxílio como meio de redução das desigualdades no processo civil. *Revista de Processo*. n. 192. São Paulo: Ed. RT, 2011.
- SARLET, Ingo. *A eficácia dos direitos fundamentais*. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
- _____. *Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988*. 3. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.
- _____. (coord.). *Dimensões da dignidade – ensaios de filosofia do direito e direito constitucional*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005.
- _____.; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. *Curso de direito constitucional*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- SATTA, Salvatore. Premesse generali alla dottrina della esecuzione forzata. *Rivista di Diritto Processuale Civile*. Padova: Cedam, 1932.
- SAVIGNY, Karl Friedrich von. *Vom Beruf unser Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*. Heidelberg: Mohr und Zimmer, 1814.
- _____. *System des heutigen römischen Rechts*. Berlin: Veit und Comp, 1840-1849.
- SCHAUER, Frederick. *Playing by the Rules*. Oxford: Clarendon Press, 1991.
- SCHMILL ORDÓÑEZ, Ulises. Observaciones a “Inconstitucionalidad y Derogación”. *Revista Discusiones*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 2001.
- SCHMITZ, Leonard Ziesemer. *Fundamentação das decisões judiciais*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- SCHUBERT, Werner; JAKOBS, Horst Heinrich. *Die Beratung des BGB*, AT. Berlin: Keip, 1985. 2 v.
- SCHWAB, Karl Heinz. Zur Wiederbelebung des Rechtsschutzanspruchs. *ZZP*. v. 81. Köln: Heymanns, 1954.
- _____.; ROSENBERG, Leo; GOTTWALD, Peter. *Zivilprozessrecht*. 17. ed. München: C. H. Beck, 2010.
- SEVERO, Sérgio. *Os danos extrapatrimoniais*. São Paulo: Saraiva, 1996.

- SICA, Heitor. *Preclusão Processual Civil*, 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- _____. *O direito de defesa no processo civil brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2011.
- SILBERMAN, Linda. In: CHASE, Oscar; HERSHKOFF, Helen (coord.). *Civil Litigation in Comparative Context*. St. Paul: Thomson/West, 2007.
- SILVA, Ana de Lourdes Coutinho. *Motivação das decisões judiciais*. São Paulo: Atlas, 2012.
- SILVA, Beclaute de Oliveira. *A garantia fundamental à motivação da decisão judicial*. Salvador: JusPodivm, 2010.
- SILVA, Carlos Augusto. *O processo civil como estratégia de poder: reflexo da judicialização da política no Brasil*. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.
- SILVA, Virgílio Afonso da. *A constitucionalização do direito*. São Paulo: Malheiros, 2005.
- _____. O proporcional e o razoável. *Revista dos Tribunais*. v. 798. São Paulo: Ed. RT, 2002.
- SIQUEIRA E CASTRO, Carlos Roberto. *O devido processo legal e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
- SOUZA, Miguel Teixeira de. *Estudos sobre o novo processo civil*. 2. ed. Lisboa: Lex, 1997.
- SOUZA, André Pagani de. *Vedação das decisões-surpresa no processo civil*. São Paulo: Saraiva, 2014.
- SOUZA, Artur César de. O princípio da cooperação no projeto do Novo Código de Processo Civil. *Revista de Processo*. n. 225. São Paulo: Ed. RT, 2013.
- STEINMERTZ, Wilson. *Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.
- STÜRNER, Rolf. *Die Aufklärungspflicht der Parteien des Zivilprozesses*. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1976.
- _____. Einwirkungen Rechtsschutz. In: STORME, Marcel (coord.). *Procedural Law in Europe. Apeldoorn: Maklu*, 2004.
- SUMMERS, Robert; MACCORMICK, Neil. *Interpreting Statutes – A Comparative Study*. Dartmouth: Ashgate, 1991.
- _____; _____. *Interpreting Precedents – A Comparative Study*. Dartmouth: Ashgate, 1997.
- TALAMINI, Eduardo. *Coisa julgada e sua revisão*. São Paulo: Ed. RT, 2005.
- TARELLO, Giovanni. *Il Realismo Giuridico Americano*. Milano: Giuffrè, 1962.
- _____. *Storia della Cultura Giuridica Moderna*. Bologna: Il Mulino, 1976.
- _____. *L' Interpretazione della Legge*. Milano: Giuffrè, 1980.
- TARTUCE, Fernanda. *Igualdade e vulnerabilidade no processo civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2012.
- _____. *Mediação nos conflitos civis*. 2. ed. Rio de Janeiro: Método, 2015.
- TARUFFO, Michele. *Studi sulla Rilevanza della Prova*. Padova: Cedam, 1970.
- _____. *La Motivazione della Sentenza Civile*. Padova: Cedam, 1975.

- _____. *A Motivação da Sentença Civil*. Trad. Daniel Mitidiero, Rafael Abreu e Vitor de Paula Ramos. São Paulo: Marcial Pons, 2015.
- _____. Precedente e Giurisprudenza. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 2007.
- _____. Il Controllo del Diritto e del Fatto in Cassazione. *Il Vertice Ambiguo – Saggi sulla Cassazione Civile*. Bologna: Il Mulino, 1991.
- _____. *La Giustizia Civile in Italia dal 700 a Oggi*. Bologna: Il Mulino, 1980.
- _____. Funzione della prova: la funzione dimostrativa. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 1997.
- _____. Sistema e Funzione del Processo Civile nel Pensiero di Giuseppe Chiovenda. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Milano: Giuffrè, 1986.
- _____. Il Controllo di Razionalità della Decisione fra Logica, Retorica e Dialettica. *Revista de Processo*. n. 143. São Paulo: Ed. RT, 2007.
- _____. La motivazione della Sentenza. *Revista de Direito Processual Civil*. vol. 30. Curitiba: Gênesis.
- _____. *La Semplice Verità*. Roma: Laterza, 2009.
- _____. (coord.). *La Prova nel Processo Civile*. Milano: Giuffrè, 2012.
- _____. *Uma simples verdade*. Trad. Vitor de Paula Ramos. São Paulo: Marcial Pons, 2012.
- _____. *La Prova dei Fatti Giuridici*. Milano: Giuffrè, 1992.
- _____. Idee per una Teoria della Decisione Giusta. *Sui Confini – Scritti sulla Giustizia Civile*. Bologna: Il Mulino, 2002.
- _____. Il Processo Civile di Civil Law e di Common Law: Aspetti Fondamentali. *Sui Confini – Scritti sulla Giustizia Civile*. Bologna: Il Mulino, 2002.
- _____. A atuação executiva dos direitos: perfis comparados. *Processo civil comparado – Ensaios, apresentação, organização e tradução de Daniel Mitidiero*. São Paulo: Marcial Pons, 2013.
- _____. Poderes probatórios das partes e do juiz na Europa. *Processo Civil Comparado – Ensaios, apresentação, organização e tradução de Daniel Mitidiero*. São Paulo: Marcial Pons, 2013.
- _____. Linee per una Riforma della Cassazione Civile. *Il Vertice Ambiguo – Saggi sulla Cassazione Civile*. Bologna: Il Mulino, 1991.
- _____. L'Attuazione Esecutiva dei Diritti: Profili Comparatistici. In: MAZZAMUTTO, Salvatore (coord.). *Processo e Tecniche di Attuazione dei Diritti*. Napoli: Jovene, 1989, v. I.
- _____. Abuse of Procedural Rights: Comparative Standards of Procedural Fairness. In: TARUFFO, Michele (coord.). *Abuse of Procedural Rights: Comparative Standards of Procedural Fairness*. The Hague: Kluwer Law International, 1999.
- _____. ; HAZARD JR., Geoffrey C. *American civil procedure*. New Haven: Yale University Press, 1993.
- _____. ; MITIDIERO, Daniel. *A Justiça Civil – da Itália ao Brasil, dos Setecentos a Hoje*. São Paulo: Ed. RT, 2018.
- _____. ; VARANO, Vincenzo (coord.). *Manuale di Diritto Processuale Civile Europeo*. Torino:

Giappichelli, 2011.

TARZIA, Giuseppe. Il Giusto Processo di Esecuzione. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 2002.

_____. Parità delle Armi tra le Parti e Poteri del Giudice nel Processo Civile. *Problemi del Processo Civile di Cognizione*. Padova: Cedam, 1989.

_____. L'art. 111 Cost. e le garanzie europee del processo civile. *Rivista di Diritto Processuale*. 2001.

_____. Il giusto processo di esecuzione. *Rivista di Diritto Processuale*. 2001.

_____. Sul procedimento di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo. *Giurisprudenza italiana*. 2001.

TESHEINER, José. *Jurisdição voluntária*. Rio de Janeiro: Aide, 1992.

TESORIERE, Giovanni. Appunti per una storia della scienza del processo civile in Italia dall'unificazione ad oggi (i pre-chiovendiani). *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. 1972.

TESSLER, Luciane Gonçalves. *Tutelas jurisdicionais do meio ambiente*. São Paulo: Ed. RT, 2004.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. *A execução de sentença e o devido processo legal*. Rio de Janeiro: Aide, 1987.

_____. Juiz e partes dentro de um processo fundado no princípio da cooperação. *Revista Dialética de Direito Processual*. n. 102. São Paulo: Dialética, 2011.

_____. Constituição e processo: desafios constitucionais da reforma do processo civil no Brasil. In: THEODORO JÚNIOR, Humberto; CALMON, Petrônio; NUNES, Dierle (coord.). *Processo e Constituição – os dilemas do processo constitucional e dos princípios processuais constitucionais*. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010.

_____; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. *Novo CPC – fundamentos e sistematização*. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

TREVES, Renato. *Diritto e Cultura*. Torino: Giappichelli, 1947.

TROCKER, Nicolò. *Processo Civile e Costituzione – Problemi di Diritto Tedesco e Italiano*. Milano: Giuffrè, 1974.

_____. *La Formazione del Diritto Processuale Europeo*. Torino: Giappichelli, 2011.

TROPPER, M. La función judicial. *Ética y democracia*. Barcelona: Gedisa, 2004.

TUNC, André. La Cour Suprême Idéale. In: BELLET, Pierre; TUNC, André (coord.). *La Cour Judiciaire Suprême – Une Enquête Comparative*. Paris: Economica, 1978.

UZELAC, Alan; VAN RHEE, C. H. (coord.). *Civil Justice between Efficiency and Quality: from Ius Commune to the CEPEJ*. Oxford: Intersentia, 2008.

VALLESPÍN PÉREZ, David. *El Modelo Constitucional de Juicio Justo en el Ámbito del Proceso Civil*. Barcelona: Atelier, 2002.

VAN RHEE, C. H. The Development of Civil Procedure Law in Twentieth Century Europe: a Retrospective View. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; CALMON, Petrônio (org.). *Direito Processual Comparado – XIII World Congress of Procedural Law*. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

_____. (coord.). *Judicial Case Management and Efficiency in Civil Litigation*. Oxford: Intersentia,

2008.

____; UZELAC, Alan (coord.). *Civil Justice between Efficiency and Quality: from Ius Commune to the CEPEJ*. Oxford: Intersentia, 2008.

VARANO, Vincenzo (coord.). *L'Altra Giustizia*. Milano: Giuffrè, 2007.

____; TARUFFO, Michele (coord.). *Manuale di Diritto Processuale Civile Europeo*. Torino: Giappichelli, 2011.

VENTURI, Elton. *Execução da tutela coletiva*. São Paulo: Malheiros, 2000.

VIEHWEG, Theodor. *Tópica e jurisprudência*. Brasília: UnB, 1979.

VIGNERA, Giuseppe; ANDOLINA, Italo. *Il Modello Costituzionale del Processo Civile Italiano*. Torino: Giappichelli, 1997.

VIGORITI, Vincenzo. *Garanzie Costituzionali del Processo Civile – Due Process of Law e art. 24 Costituzione*. Milano: Giuffrè, 1970.

____; CAPPELLETTI, Mauro. *Le Garanzie Costituzionali delle Parti nel Processo Civile Italiano. Giustizia e società*. Milano: Edizioni di Comunità, 1972.

VILLA, Vittorio. *Una Teoria Pragmaticamente Orientata dell'Interpretazione Giuridica*. Torino: Giappichelli, 2012.

VOKUHLE, Andreas. *Bruch mit einem Dogma: die Verfassung garantiert Rechtsschutz gegen den Richter*. NJW. München: Beck, 2003.

WACH, Adolf. *Handbuch des deutschen Civilprozessrechts*. Leipzig: Duncker & Humblot, 1885.

____. *Vorträge über die Reichs-Civilprozessordnung*. 2. ed. Bonn: Adolph Marcus, 1896.

____. *Der Feststellungsanspruch*. Leipzig: Fues's, 1889.

WALTER, Gerhard. *Libre Apreciación de la Prueba*. Bogotá: Temis, 1985.

WALUCHOW, W. J. *Inclusive legal positivism*. New York: Oxford University Press, 1994.

WASSERMANN, Rudolf. *Der soziale Zivilprozess*. Neuwied und Darmstadt: Luchterhand, 1978.

WASSERSTROM, Richardo. *The Judicial Decision – Toward a Theory of Legal Justification*. Stanford: Stanford University Press, 1961.

WATANABE, Kazuo. *Da cognição no processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 1987.

WIEACKER, Franz. *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit*. 2. ed. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996.

WINDSCHEID, Bernhard. *Die Actio – Abwehr gegen Dr. Theodor Muther*. Düsseldorf: J. Buddeus, 1857; Aalen: Scientia (reimpressão), 1984.

____. *Die Actio des römischen Civilrechts, vom Standpunkte des heutigen Rechts*. Düsseldorf: Verlagshandlung von Julius Budeus, 1856.

____. *La actio del derecho civil romano, desde el punto de vista del derecho actual. Polémica sobre la actio*. Buenos Aires: Ejea, 1974.

WRÓBLEWSKI, Jerzy. *Legal Decision and Its Justification. Logique et Analyse*, 1971.

____. *Legal Syllogism and Rationality of Judicial Decision. Rechtstheorie*. Berlin: Duncker &

Humblot, 1974. v. 5.

_____. *The Judicial Application of Law*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992.

YARSHELL, Flávio Luiz. *Tutela jurisdicional*. São Paulo: Atlas, 1999.

ZAGREBELSKY, Gustavo. *El derecho dúctil*. Madrid: Trotta, 2003.

ZANETI JUNIOR, Hermes. *Mandado de segurança coletivo*. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2001.

_____. *Constitucionalização do processo civil* (2007). 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

_____. *O valor vinculante dos precedentes*. Salvador: JusPodivm, 2015.

_____; DIDIER JR, Fredie. *Curso de direito processual civil*. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2013. vol. IV.

ZEISS, Walter. *Die arglistige Prozesspartei*. Berlin: Duncker & Humblot, 1967.

© desta edição [2018]

Índice Alfabético-remissivo

Ação

- Ação Declaratória, **Art. 19**, 1 a 6; **Art. 20**, 1.
- Classificação das Ações e das Tutelas, **Liv. II**, **Tít. I**, 4.15.
- Conceito, **Art. 3.º**, 1; **Liv. II**, **Tít. I**, 3 a 4 a 4.16.
- Princípio da Demanda, **Art. 2.º**, 1.

Aplicação

- Direito Intertemporal, **Art. 14**, 1 a 3.
- Normas Brasileiras, **Art. 13**, 1.
- Subsidiária do CPC, **Art. 15**, 1.
- Supletiva do CPC, **Art. 15**, 1.

Atos Concertados

- Instrumento de Cooperação Interna, **Art. 69**, 3.

Auxílio Direto

- Instrumento de Cooperação Internacional, **Arts. 28 a 34**.

Boa-Fé

- Comportamentos Contrários, **Art. 5.º**, 2.
- Conceito, **Art. 5.º**, 1 e 2.
- Destinatários, **Art. 5.º**, 3.
- Objetiva, **Art. 5.º**, 2.
- Subjetiva, **Art. 5.º**, 1.

Carta Rogatória

- Instrumento de Cooperação Internacional, **Art. 36**.

Código de Processo Civil

- Código Buzaid, **Lei 13.105**, de **16.03. 2015**, 1.2.

- Código de 1939, **Lei 13.105, de 16.03. 2015**, 1.1.
- Código Reformado, **Lei 13.105, de 16.03. 2015**, 1.2.
- Como Texto, **Lei 13.105, de 16.03. 2015**, 3.1.
- Como Norma, **Lei 13.105, de 16.03. 2015**, 3.1.
- Como Sistema, **Lei 13.105, de 16.03. 2015**, 3.2.
- Parte Geral e Parte Especial, **Parte Geral**, 1 e 2.

Cognição

- Cognição e Execução no Sistema da Tutela Jurisdicional dos Direitos, **Lei 13.105, de 16.03.2015**, 2.2.
- Como Atividade, não Como Processo, **Lei 13.105, de 16.03.2015**, 2.2.
- Sumária e Exauriente, **Lei 13.105, de 16.03.2015**, 2.4.

Colaboração

- Conceito, **Art. 6.º**, 1.
- Como Modelo, **Art. 6.º**, 2.
- Como Princípio, **Art. 6.º**, 3.
- Decisão de Mérito Justa, Tempestiva e Efetiva, **Art. 6.º**, 3.
- Dever de Auxílio, **Art. 6.º**, 3.
- Dever de Diálogo, **Art. 6.º**, 3.
- Dever de Esclarecimento, **Art. 6.º**, 3.
- Dever de Prevenção, **Art. 6.º**, 3.
- Deveres Cooperativos do Juiz, **Art. 6.º**, 3.
- Primazia do Mérito, **Art. 6.º**, 3.

Competência

- Alegação de Incompetência, **Art. 64**, 1 a 5.
- Competência Internacional Concorrente, **Liv. II, Tít. II, Cap. I**, 3; **Art. 21**, 1; **Art. 22**, 1 a 3.
- Competência Internacional Exclusiva, **Liv. II, Tít. II, Cap. I**, 3; **Art. 23**, 1 a 3.
- Competência Absoluta, **Liv. II, Tít. III, Cap. I, S. I**, 3.
- Competência Derrogável, **Art. 63**, 1 a 4.
- Competência Funcional, **Art. 44**, 5; **Art. 47**, 1.
- Competência Inderrogável, **Art. 62**, 1.
- Competência Objetiva, **Art. 44**, 2, 3 e 4; **Art. 45**, 1; **Art. 51**; **Art. 52**.
- Competência Relativa, **Liv. II, Tít. III, Cap. I, S. I**, 3.

- Competência Territorial, **Art. 44**, 6; **Art. 46**, 1 a 3; **Arts 47 a 50**; **Art. 53**.
- Conceito, **Tít. II, Cap. I**, 1.
- Conexão, **Art. 54**, 1; **Art. 55**; **Art. 56**; **Art. 57**; **Art. 61**, 1 e 2.
- Conflito de Competência, **Art. 66**, 1.
- Continência, **Art. 56**, 1; **Art. 57**.
- Critérios para a Definição, **Liv. II, Tít. III, Cap. I, S. I**, 1; **Art. 44**, 2 a 6.
- Fontes para a Definição, **Art. 44**, 1.
- Foro de Eleição, **Art. 63**, 1 a 4.
- Foro de Eleição Estrangeiro, **Art. 25**, 1 a 5.
- Foros Concorrentes, **Liv. II, Tít. III, Cap. I, S. I**, 2.
- *Forum Non Conveniens*, **Liv. II, Tít. III, Cap. I, S. I**, 2.
- *Forum Shopping*, **Art. 25**, 4; **Liv. II, Tít. III, Cap. I, S. I**, 2.
- Incompetência Absoluta, **Art. 64**, 2.
- Incompetência Relativa, **Art. 64**, 1.
- Justiça Estadual e Justiça Federal, **Art. 45**, 1 a 11.
- *Kompetenz-Kompetenz*, **Art. 66**, 1.
- Modificação de Competência, **Liv. II, Tít. III, Cap. I, S. II**, 1.
- Perpetuação, **Art. 43**, 1.
- Prevenção, **Art. 58**, 1 e 2; **Art. 59**, 1 e 2; **Art. 60**, 1.
- Prorrogação, **Art. 65**, 1.
- Regimes de Competência, **Liv. II, Tít. III, Cap. I, S. I**, 3.
- *Translatio Iudicii*, **Art. 43**, 2.

Constituição

- Direitos Fundamentais Processuais, **Liv. I**, 1, 2 e 3; **Liv. I, Tít. Único, Cap. I**, 1.
- Processo Civil e Constituição, **Liv. I**, 1, 2 e 3; **Art. 1.º**, 1.

Contraditório

- Conceito, **Art. 9.º**, 1.
- Diferido, **Art. 9.º**, 2.
- Eventual, **Art. 9.º**, 2.
- Exceções, **Art. 9.º**, 3.
- Prévio, **Art. 9.º**, 2.

- Vedação à Decisão-Surpresa, **Art. 10, 1.**

Cooperação Jurisdicional

- Cooperação entre a Jurisdição e a Arbitragem, **Art. 67, 2; Art. 69, 2.**
- Cooperação Interna, **Art. 67, 1.**
- Cooperação Internacional, **Art. 26, 1.**
- Instrumentos de Cooperação Interna, **Art. 69, 1 e 3.**
- Instrumentos de Cooperação Internacional, **Art. 28, 1; Art. 36, 1.**
- Objeto da Cooperação Interna, **Art. 68, 1.**
- Objeto da Cooperação Internacional, **Art. 27, 1.**

Cultura

- Evolução do Processo Civil Brasileiro, **Lei 13.105, de 16.03.2015, 1.**
- Processo Civil e Cultura, **Lei 13.105, de 16.03.2015, 1.**

Da Mihi Factum, Dado Tibi Ius

- Aplicação Condicionada ao Contraditório, **Art. 10, 3.**

Decisão Judicial

- Racionalidade, **Liv. II, Tít. I, 2.12 e 2.21.**

Decisão-Surpresa

- Contraditório, **Art. 9.º, 1; Art. 10, 1.**
- *Da Mihi Factum, Dado Tibi Ius*, **Art. 10, 3.**
- *Iura Novit Curia*, **Art. 10, 2.**

Democracia

- Administração Democrática da Justiça Civil, **Art. 11, 1.**
- Estado Constitucional, **Art. 1.º, 1.**

Duração Razoável do Processo

- Conceito, **Art. 4.º, 1, 3, 6 e 9.**
- Destinatários, **Art. 4.º, 2.**
- Economia Processual, **Art. 4.º, 9.**
- Ordem Preferencialmente Cronológica, **Art. 12, 1.**
- Parâmetros, **Art. 4.º, 7.**
- Reparação por Duração Irrazoável, **Art. 4.º, 8.**

Exceptio Doli

- Boa-Fé, **Art. 5.º**, 2.

Execução

- Cognição e Execução no Sistema da Tutela Jurisdicional dos Direitos, **Lei 13.105, de 16.03.2015**, 2.2.

- Como Atividade, não Como Processo, **Lei 13.105, de 16.03.2015**, 2.2.

Exercício Desequilibrado do Direito

- Boa-Fé, **Art. 5.º**, 2.

Fundamentação

- Colaboração, **Art. 6.º**, 3.
- Conceito, **Art. 11**, 2.
- Contraditório, **Art. 9.º**, 1.
- Decisão Fundamentada, **Art. 11**, 2, 2.1, 2.2 e 2.3; **Liv. II**, **Tít. I**, 2.11.
- Direito, **Art. 11**, 2.

Igualdade

- Como Direito à Idêntica Proteção, **Art. 7.º**, 1 a 3.
- Como Direito Fundamental Processual, **Liv. I**, 1, 2 e 3.
- Como Norma Fundamental do Processo Civil, **Art. 7.º**, 1 a 4.
- Como Vedação a Distinções Arbitrárias, **Art. 7.º**, 1 a 3.
- Condição do Contraditório, **Art. 7.º**, 4.
- Paridade de Armas, **Art. 7.º**, 4.

Impulso Oficial

- Conceito, **Art. 2.º**, 3.

Interesse de Agir

- Aferição, **Art. 17**, 3.
- Conceito, **Art. 17**, 2.
- Não se Trata de Condição da Ação, **Liv. II**, **Tít. I**, 3.9.

Interpretação

- Bem Comum, **Art. 8.º**, 2.
- Coerência, **Art. 11**, 2.2 e 2.3.
- Conforme a Constituição, **Art. 1.º**, 2.
- Diferença entre Texto e Norma, **Lei 13.105, de 16.03.2015**, 3.1.
- Dignidade da Pessoa Humana, **Art. 8.º**, 3.

- Eficiência, **Art. 8.º**, 8.
- Fins Sociais, **Art. 8.º**, 2.
- Legalidade, **Art. 8.º**, 4.
- Ordenamento Jurídico, **Art. 8.º**, 1.
- Proporcionalidade, **Art. 8.º**, 5.
- Razoabilidade, **Art. 8.º**, 5 e 6.
- Unidade da Constituição, **Art. 1.º**, 1 e 2.

Iura Novit Curia

- Aplicação Condicionada ao Contraditório, **Art. 10**, 2.

Jurisdição

- Conceito, **Liv. II, Tít. I**, 1 a 2.29; **Art. 16**, 1; **Liv. II, Tít. II, Cap. I**, 1.
- Ineficácia da Litispendência Estrangeira, **Art. 24**, 1 a 3.
- Justiça Multiportas, **Art. 3.º**, 2.
- Limites, **Liv. II, Tít. II, Cap. I**, 2 e 3; **Arts. 21 a 23**.

Justiça Multiportas

- Arbitragem, **Art. 3.º**, 2.2.
- Conciliação, **Art. 3.º**, 2.1.
- Mediação, **Art. 3.º**, 2.1.
- Métodos Autocompositivos, **Art. 3.º**, 2.1.
- Métodos Heterocompositivos, **Art. 3.º**, 2.2.

Nemo Potest Venire Contra Factum Proprium

- Boa-Fé, **Art. 5.º**, 2.

Legitimidade para a Causa

- Aferição, **Art. 17**, 3.
- Conceito, **Art. 17**, 2.
- Não se Trata de Condição da Ação, **Liv. II, Tít. I**, 3.9.
- Substituição Processual, **Art. 18**, 1.

Normas Fundamentais do Processo Civil

- Controle mediante RE ou REsp, **Liv. I, Tít. Único, Cap. I**, 2.
- Significado, **Liv. I, Tít. Único, Cap. I**, 1.
- Significado Topológico, **Liv. I, Tít. Único**, 1.

Normas Processuais Cíveis

- Código de Processo Civil, **Liv. I**, 1.
- Constituição, **Liv. I**, 1.
- Direito e Processo, **Liv. I**, 4.
- Efeito Imediato, **Art. 14**, 2.
- Efeito Retroativo, **Art. 14**, 2.
- Isolamento dos Atos Processuais e Efeitos das Normas Processuais, **Art. 14**, 3.
- Normas Brasileiras, **Art. 13**, 1.
- Normas Heterotópicas, **Liv. I**, 5.
- Processo Justo, **Liv. I**, 2 e 3.

Ordem Preferencialmente Cronológica

- Conceito, **Art. 12**, 1.
- Exceções, **Art. 12**, 4

Precedentes

- Jurisdição e Precedentes, **Liv. II**, **Tít. I**, 2.5, 2.10, 2.24 a 2.26.
- Tribunais, **Art. 16**, 4.

Primazia do Mérito

- Colaboração, Dever de Prevenção e Primazia do Mérito, **Art. 6.º**, 3.

Princípio

- Princípio da Boa-Fé, **Art. 5.º**, 2.
- Princípio da Colaboração, **Art. 6.º**, 3.
- Princípio da Demanda, **Art. 2.º**, 1 e 4.
- Princípio Dispositivo, **Art. 2.º**, 2.
- Princípio Inquisitório, **Art. 2.º**, 2.

Procedimento

- Comum, **Lei 13.105, de 16.03.2015**, 2.3.
- Diferenciado, **Lei 13.105, de 16.03. 2015**, 2.3.

Processo

- “Processo” de Conhecimento e “Processo” de Execução, **Lei 13.105, de 16.03. 2015**, 2.2.
- Processo Justo, **Liv. I**, 2 e 3.

Proporcionalidade

- Conceito, **Art. 8.º**, 5.

Publicidade

- Conceito, **Art. 11**, 3.
- Espécies, **Art. 11**, 3.

Racionalidade

- Decisão Judicial, **Liv. II, Tít. I**, 2.12 e 2.21.

Razoabilidade

- Conceito, **Art. 8.º**, 5.
- Equidade, **Art. 8.º**, 6.

Supressio

- Boa-Fé, **Art. 5.º**, 2.

Surrectio

- Boa-Fé, **Art. 5.º**, 2.

Técnica Processual

- Técnica Antecipatória, **Lei 13.105, de 16.03.2015**, 2.4.
- Técnica Executiva, **Lei 13.105, de 16.03.2015**, 2.2.

Tu Quoque

- Boa-Fé, **Art. 5.º**, 2.

Tutela dos Direitos

- Ação, **Liv. II, Tít. I**, 4 a 4.16.
- Contra o Dano, **Lei 13.105, de 16.03. 2015**, 2.1.
- Contra o Ilícito, **Lei 13.105, de 16.03. 2015**, 2.1.
- Dupla Dimensão, **Liv. II, Tít. I**, 2.26.
- Duplo Discurso, **Liv. II, Tít. I**, 2.26.
- Tutela Adequada, **Art. 3.º**, 1.1.
- Tutela Cautelar, **Lei 13.105, de 16.03. 2015**, 2.1.
- Tutela de Remoção do Ilícito, **Lei 13.105, de 16.03.2015**, 2.1.
- Tutela Definitiva, **Lei 13.105, de 16.03. 2015**, 2.4.
- Tutela Efetiva, **Art. 3.º**, 1.2.
- Tutela Inibitória, **Lei 13.105, de 16.03. 2015**, 2.1.
- Tutela Provisória, **Lei 13.105, de 16.03. 2015**, 2.4.

- Tutela Reparatória, **Lei 13.105, de 16.03. 2015**, 2.1.
- Tutela Ressarcitória, **Lei 13.105, de 16.03. 2015**, 2.1.
- Tutela Satisfativa, **Lei 13.105, de 16.03. 2015**, 2.1.
- Tutela Tempestiva, **Art. 3.º**, 1; **Art. 4.º**, 1 a 9.

© desta edição [2018]